

제20판

# 도해특허법

임병웅 著

리담지식재산교육원





## 제20판을 내면서

제20판에서는 다음의 개정 법령과 2026년 1월까지 새롭게 축적된 판례를 반영하였다.

| 번호 | 법령명      | 법령종류     | 공포번호    | 공포일자       | 시행일자       |
|----|----------|----------|---------|------------|------------|
| 1  | 특허법      | 법률       | 제21065호 | 2025.10.1. | 2025.10.1. |
| 2  | 특허법 시행령  | 대통령령     | 제35809호 | 2025.10.1. | 2025.10.1. |
| 3  | 특허법 시행규칙 | 총리령      | 제2054호  | 2025.10.1. | 2025.10.1. |
| 4  | 특허법 시행규칙 | 산업통상자원부령 | 제609호   | 2025.7.11. | 2025.7.11. |
| 5  | 특허법      | 법률       | 제20975호 | 2025.5.27. | 2025.5.27. |

제20판의 출간에 도움을 주신 분들께 감사드립니다.

2026년 2월

임 병 응





## 제19판을 내면서

제19판에서는 2025년 1월 21일에 공포되어 2025년 7월 22일에 시행되는 개정 특허법(법률 제 20700호)를 반영하였다. 또한 개정된 특허법 시행령(대통령령 제34657호, 제34808호), 특허법 시행규칙(산업통상자원부령 제570호, 제597호)과 2025년 1월까지 축적된 판례를 반영하였다.

제19판의 출간에 도움을 주신 분들께 감사드린다.

2025년 2월

임 병 응





## 제18판을 내면서

제18판에서는 3차례 개정된 특허법, 구체적으로 2023년 9월 14일 공포되어 2024년 3월 25일에 시행되는 특허법(법률 제19714호), 2024년 2월 6일에 공포되어 2024년 8월 7일에 시행되는 특허법(법률 제20200호) 및 2024년 2월 20일에 공포되어 2024년 8월 21일에 시행되는 특허법(법률 제20322호)를 반영하였다. 또한, 2024년 2월 6일 공포되어 2024년 8월 7일에 시행되는 발명진흥법(법률 제20197호)을 반영하였으며, 이외에 하위법령인 특허법시행령(대통령령 제33997호), 특허법시행규칙(산업통상자원부령 제536호)과 축적된 판례를 반영하였다.

제18판의 출간에 도움을 주신 분들께 감사드립니다.

2024년 3월

임 병 응





## 제17판을 내면서

제17판에서는 2022년 10월 18일 공포되어 2022년 10월 18일에 시행된 특허법(법률 제19007호)을 반영하였다. 또한, 하위법령인 특허법시행령(대통령령 제32590호, 제32973호), 특허법시행규칙(산업통상자원부령 제456호, 제474호), 2023년 개정된 특허?실용신안 심사기준과 제21판 이후 축적된 판례를 반영하였다.

제17판을 출간할 수 있게 도움을 주신 분들께 감사드린다.

2023년 5월

임 병 응





## 제16판을 내면서

제16판에서는 2021년 4월 20일 공포되어 2021년 10월 21일에 시행된 특허법(법률 제18098호), 2021년 8월 17일에 공포되어 2021년 11월 18일 또는 2022년 2월 18일에 시행된 특허법(법률 제18409호) 및 2021년 10월 19일에 공포되어 2022년 4월 20일에 시행되는 특허법(법률 제18505호)을 반영하였다.

또한, 하위법령인 특허법시행령(대통령령 제31813호), 특허법시행규칙(산업통상자원부령 제422호, 제434호), 특허·실용신안 심사기준(예규 제124호)과 축적된 판례를 반영하였다.

제16판을 출간할 수 있게 도움을 주신 분들께 감사드립니다.

2022년 3월  
임 병 응





## 제15판을 내면서

제15판에서는 2020년 6월 9일에 개정되어 2020년 12월 10일에 시행되고 있는 특허법(法律 제 17422호), 2020년 10월 20일에 개정되어 2020년 10월 20일에 시행되고 있는 특허법(法律 제 17536호) 및 2020년 12월 22일에 개정되어 2021년 6월 23일 시행될 특허법(法律 제17730호)을 반영하였다.

그 밖에 제14판 출간 이 후 개정 하위법령, 개정 특허·실용신안 심사기준(예규 제117호), 개정 심판편람(제13판) 및 축적된 판례를 반영하였다.

제15판을 출간할 수 있게 도움을 주신 분들께 감사드립니다.

2021년 4월  
임 병 응







## 제14판을 내면서

제14판에서는 2019년 12월 10일에 공포되어 2020년 3월 11일에 시행될 개정 특허법(法律 제 16804호)을 반영하였다.

그 밖에 개정된 특허법 시행령, 시행규칙, 특허·실용신안 심사기준(예규 제113호)과 제13판 이후 2020년 3월까지 축적된 판례를 반영하였고, 미진한 부분을 수정보완하였다.

제14판을 출간할 수 있게 도움을 주신 분들께 감사드립니다.

2020년 4월

임 병 응





## 제13판을 내면서

이번 제13판에서는 2018년 4월 17일에 공포되어 2018년 7월 18일에 시행되고 있는 개정 특허법(法律 제15582호)과 2019년 1월 8일에 공포되어 2019년 7월 9일에 시행될 개정 특허법(法律 제16208호)을 반영하였다.

그 밖에 개정된 특허·실용신안 심사기준(예규 제104호)과 제12판 이후 축적된 판례를 반영하였고, 미진한 부분을 수정보완하였다.

제13판을 출간할 수 있게 도움을 주신 분들께 감사드립니다.

2019년 5월  
임 병 응





## 제12판을 내면서

이번 제12판에서는 2017년 3월 21일에 공포되어 2017년 9월 22일에 시행된 특허법(法律 제14691호), 2017년 11월 28일에 공포되어 2018년 5월 29일에 시행될 특허법(法律 제15093호) 및 이에 상응하는 시행령, 시행규칙 등의 하위법령을 반영하였다.

또한, 2017년 12월 29일에 개정된 특허·실용신안 심사기준(예규 제101호)과 제11판 이후 현재까지 축적된 판례 중 주요한 내용을 추가, 수정, 보완하였다.

제12판을 출간할 수 있게 도움을 주신 분들께 감사드린다.

2018년 2월  
임 병 응





## 제11판을 내면서

이번 제11판에서는 2016년 2월 29일에 공포되어 2017년 3월 1일에 시행될 개정 특허법(法律 제14035호), 2016년 12월 2일에 공포되어 2017년 6월 3일에 시행될 개정 특허법(法律 제14371호) 및 이에 상응하는 시행령, 시행규칙 등의 하위법령을 반영하였다.

또한, 2017년도에 시행되는 심사기준과 심판편람과 제9판 출간 이후 현재까지 나온 판례 중 주요한 내용을 추가, 수정, 보완하였다.

도해 특허법이 수험생들의 수험기간을 조금이라도 단축시킬 수 있는 디딤돌이 되기를 기원하면서, 제11판을 출간할 수 있게 도움을 주신 분들께 감사드린다.

2017년 4월  
임 병 응





## 제10판을 내면서

이번 제10판에서는 개정 특허법([시행 2015.5.18.] [법률 제13317호, 2015.5.18., 일부개정]), 특허법 시행령([시행 2015.8.19.] [대통령령 제26494호, 2015.8.19., 일부개정])과 특허법 시행규칙([시행 2015.7.29.] [산업통상자원부령 제144호, 2015.7.29., 일부개정], [시행 2015.7.29.] [산업통상자원부령 제144호, 2015.7.29., 일부개정]) 및 주요한 특허법원, 대법원 판례를 반영하였다.

제10판을 출간할 수 있게 도움을 주신 분들께 감사드립니다.

2016년 3월

임 병 응





## 제9판을 내면서

2015년 1월 28일에 공포되어 2015년 7월 29일부터 시행될 개정 특허법(法律 제13096호), 2014년 하반기에 개정된 심판편람, 심사기준과 아울러 제8판 이후 현재까지 나온 주요 판례를 반영하기 위해 제9판을 출간하게 되었다.

제9판을 출간할 수 있게 도움을 주신 분들께 감사드린다.

2015년 3월  
임 병 응





## 제8판을 내면서

2014년 6월 11일에 공포되어 2015년 1월 1일부터 시행(일부규정은 공포와 동시에 시행)될 개정 특허법(法律 제12753호)과, 2014년 7월 개정된 특허실용신안심사기준 및 2014년 나온 주요 대법원 판례를 반영하기 위해 제8판을 출간하게 되었다.

제8판을 출간할 수 있게 도움을 주신 분들께 감사드린다.

2014년 7월  
임 병 응





## 제7판을 내면서

제7판에 대한 머리말을 쓰려고 상당한 시간을 고민하였지만, 쉽게 떠오르지 아니한다.

이는 제1판부터 제6판까지 圖解특허법을 출간하는 과정에서 저자가 밝힌 圖解특허법의 목적, 활용 방법과 관련된 내용을 벗어날 수 없기 때문인 것으로 사료된다.

독자들이 소중한 시간을 할애하여 제1판부터 제6판까지의 머리말을 정독한다면, 효율성을 제고하여 충분히 그 투자한 시간 이상의 보상이 독자들에게 주어질 것임을 저자는 확신하고 있으며, 이를 강력히 권하는 바이다.

마지막으로, 제7판을 출간할 수 있게 도움을 주신 분들께 감사드린다.

2014년 3월  
임 병 응







## 제6판을 내면서

도해 특허법의 목적은 정리의 효율화와 체계화를 도모함으로써 독자들의 공부량을 줄여주고, 시험에 합격하기까지의 기간을 단축시킴에 있다. 이러한 도해 특허법은 이지 특허법의 대체재가 아닌 보완재의 성격을 갖는 수험 교재라 할 수 있다. 독자의 성향에 따라 이지 특허법으로 단권화를 더 선호할 수 있지만, 그렇다고 하더라도 도해 특허법을 참고한다면 이지 특허법의 내용 중 강약을 조절할 수 있고 정리하는 체계를 익힐 수 있기 때문이다.

독자들이 도해 특허법의 체계를 효율적으로 활용하여 특허법뿐만 아니라 디자인보호법, 상표법의 공부방향을 인지할 수 있고, 그 결과 도해 특허법이 독자들의 수험기간 단축에 미력이나마 도움이 될 수 있길 간절히 바란다.

한편, 이번 도해 특허법 제6판을 저술할 때는 최근에 개정된 특허법, 하위법령, 변경된 심사 실무 및 축적된 판례들 중 수험용으로 적합한 것들을 선별하여 충실히 반영하기 위해 최대한 노력하였고, 저자의 이러한 노력이 도해 특허법으로 수험공부를 하는 독자들에게 부족함을 주지 않을 것이라고 확신한다.

제6판을 출간할 수 있게 도움을 주신 분들께 이 지면을 빌려 감사드린다.

2013년 3월

임 병 응





## 제5판을 내면서

올해는 김인배 변리사 著의 도해 디자인보호법뿐만 아니라 박종태 변리사 著의 도해 상표법이 출간될 예정이다. 비록 저자들은 서로 다르지만, 저자간의 충분한 공감대 형성을 통해 드디어 모든 산업재산권법에 대한 도해 시리즈를 발간하기로 결정하였다.

동일한 관점에서 산업재산권 3법을 볼 수 있다는 것은 변리사 시험을 준비하는 수험생에게 큰 행운이라고 생각한다. 비록 법 내용이 다를지라도, 법 내용을 담을 수 있는 체계가 같다면 회독수의 증진을 통해 보다 수월하게 법 내용을 정리할 수 있기 때문이다.

1차 시험공부 단계부터 법의 전체 구조를 본다는 것은 쉽지 아니한 일이다. 1차 수험생에게는 새로운 개념의 이해와 암기의 반복만으로도 충분히 벅차다. 또한 법의 전체 구조 속에서 각각의 논점에 대한 이론을 정립하지 않더라도 지문의 정오를 따지는 객관식 시험을 대비하는 것이 큰 무리가 있는 것도 아니다. 다만, 법을 바라보는 체계를 정립하고 이를 통해 정리하는 작업이 2차 논술 시험에서 큰 효용을 가져올 수 있게 할 것이다.

암기의 부담을 줄일 수 있으니 수험공부의 효율의 측면에서는 비책이라 부를만 하나, 이는 꿈수가 아니라 오히려 법을 이해하는 정도(正道)에 해당한다. 도해 시리즈는 방대한 법 내용을 단순 축약하는 것에 그치는 것이 아니라 정도를 걷는 방법론을 제시하고자 노력하였다.

도해 시리즈가 많은 이들에게 사랑받는 변리사 수험 교재가 될 수 있도록 주변과의 소통의 노력을 게을리 하지 아니한 저자들이 될 것을 약속드리며, 도해 시리즈를 출간할 수 있게 도움을 주신 모든 분들에게 감사의 말씀을 드린다.

2012년 4월

임 병 응





## 제4판을 내면서

간혹 신문이나 뉴스에서 단기간에 여러 고시를 합격한 이들의 소식이 들려오는데, 당연하게도 그들의 합격기는 많은 이들의 눈길을 사로잡게 된다. 대부분의 수험생들은 어느 하나라도 합격한다면 일생의 업이 될 수 있는 사법 고시, 행정 고시 그리고 외무 고시를 채 5년이 되지 아니한 시간에 척척 합격해 내는 이 고시 우등생들을 보면서, 이들은 애초부터 우수한 유전자를 지닌 천재, 아니 적어도 수재일 것이므로 우리와는 다른 종(種)이 세운 업적 그 이상의 의미를 두지 않으려 한다.

그러나 저자의 생각은 조금 다르다. 물론 각자가 지닌 유전적인 역량이 여러 시험의 합격을 가능케 하는 열쇠가 될 수도 있겠지만, 더 중요한 것은 이 우등생들은 공부의 왕도(王道)를 알고 있다는 것이다.

그렇다면 공부의 왕도(王道)는 무엇일까?

1~2년이라는 단기간 공부를 통해 시험에 합격한 사람이 그 보다 훨씬 여러 해 동안 공부를 한 사람보다 심화적인 내용을 이해하고 있다고 하기는 어렵다. 즉 많은 이들이 생각하는 것과는 달리 공부의 깊이가 합격을 좌우하지는 아니한다.

저자의 수험 경험, 그리고 10년 이상의 강의 경험을 통해 저자가 체득한 왕도(王道)는 살을 붙일 수 있는 뼈대를 세우는 것이라고 할 수 있다. 뼈대를 먼저 세우고 그 위에 살을 붙이는 공부를 하는 사람과 뼈대 없이 살만 찌우는 공부를 하는 사람은 어느 정도 기간이 지난 후 비교가 되지 않을 정도의 차이가 생기며, 이것이 합격의 당락을 정한다. 이는 비단 특허법에 한정되는 것이 아니라 모든 과목에서 공통된다. 여기서 “뼈대”는 목차를 통해 법 과목의 체계를 잡는 것을 말하며, “살”은 법조문을 통해 그 내용을 이해하는 것을 말한다.

저자는 도해 특허법이 수험생들이 특허법의 뼈대를 잡는 초석이 될 수 있기를 바라며, 현명한 수험생들이 본 서를 통해 얻은 뼈대를 디자인보호법, 상표법 기타 다른 법까지 확대하여 합격이라는 문까지 가장 빠른 시간에 도달할 수 있는 왕도(王道)를 걷기 바란다.

본 서(書)에 도움을 주신 화연이와 김변, 그리고 한빛의 김소영 과장님, 황이사님께 감사드립니다.

2011년 4월

임 병 응





## 제3판을 내면서

수험공부를 하는 독자들의 바람 중 하나는 법 과목에서 목차의 통일화라고 할 수 있다. 특허법, 디자인보호법, 상표법을 통일된 목차를 가지고 공부한다면, 동일한 틀 안에서 모든 논점을 정리할 수 있어 논점의 정리와 암기에 가장 효율적일 수 있다. 그러나 동일한 법 과목의 내용일지라도 그 법을 바라보는 저자의 관점에 따라 각각 다른 목차에 의하여 내용을 전개해 가는 것이 다반사인데, 하물며 다른 법 과목의 내용을 다른 저자가 동일한 목차에 의하여 내용을 전개해 가는 것은 더욱 어려운 일임은 자명하다.

따라서, 이번 제3판에서는 도해 디자인보호법의 저자인 김인배 변리사와 충분한 논의를 통해 책의 구조 및 전개방식 그리고 목차를 통일화하는 것에 개정의 역점을 두었다. 그리하여 도해 특허법을 통해 공부한 독자들이 손쉽게 디자인보호법을 접할 수 있도록 노력하였다. 또한 이러한 접근은 비단 디자인보호법을 2차 선택과목으로 하는 수험생들에게만 이점이 가는 것이 아니라, 변리사 1차, 2차를 대비하여 법 과목을 수학하는 모든 이들에게 일정한 관점을 가지고 법을 공부하는 것이 얼마나 효율적이고 깊이 있는 공부방법인가를 알 수 있게 해줄 것이라고 저자는 확신한다.

또한, 이지 특허법을 1차 특허법의 기본서로서 활용하는 많은 수험생들이 2차 공부를 위해서 별도로 다른 교재로 단권화를 하는 경향이 짙어지는 시점에서 1차를 공부하면서 정리한 이지 특허법의 모든 내용들을 2차 공부에도 그대로 활용 가능하도록, 도해 특허법은 이지 특허법의 충실한 서브노트로서의 기능을 가지도록 하는 것에도 개정의 주안점을 두었다.

이에 더하여 책의 내용적인 부분에 있어서 개정된 특허법, 시행규칙, 시행령, 심사지침서, 심판 편람 등을 충실히 반영하여 특허법 과목의 대비에 있어 부족함이 없도록 노력하였다.

1차 시험이든 2차 시험이든 법과목 공부의 출발점은 해당 과목에 대한 기본 구조를 파악하면서 넓게 때로는 깊게 이해를 반복하여 그 과목에 익숙해지는 것이다. 그에 동반되는 암기는 이해와 반복을 통해 자연스럽게 체득될 것이다. 본 도해 시리즈가 변리사 시험을 준비하는 분들에게 가장 가까이 있고자 하는 노력이 계속될 것임은 특허법을 강의하는 자의 입장에서 너무나 당연한 것이겠다. 다음 개정판에서는 디자인보호법 뿐만 아니라 상표법과도 통일화된 책을 출간하길 기대해 보면서, 본 서의 출간에 도움을 주신 영원한 후원자인 전화연님, 親友 김인배 변리사님, 출판부의 김소영 과장님, 그리고 한빛의 황이사님께 감사드린다.

2010년 4월  
임 병 응





## 제2판을 내면서

제1판을 출간한지 벌써 5년이라는 시간이 지나갔다. 이지 특허법을 저술하게 되면서 모든 사람들이 귀중하게 생각하는 책, 소위 명품을 만들기 위해 전력투구를 해야 된다는 생각에 본 도해 특허법에 대한 출간을 미루게 되었다. 하지만, 이지특허법으로 공부하는 수험생들의 공부 분량에 대한 부담감을 줄여줘야 한다는 의무감, 그리고 특히 2차 수험생들에게 저자가 이해하고 있는 공부방법론을 전달해야 한다는 생각에 다시 한 번 본 서를 출간할 결심을 하였다.

공부방법론의 관점에서 보면, 저자는 특허법을 수학에 비유하고 싶다. 수학이라는 과목은 매우 극단적이기 때문에 사람들은 수학공부를 아주 잘 하거나 아주 못하며, 중간 정도 수준의 공부를 하는 사람들은 드물다. 수학이라는 과목의 공부를 아주 잘 하기 위해서는, 응용 문제를 외워서 문제를 풀어 나가는 것이 아니라 기본 원리를 이해한 후 그 기본 원리를 응용 문제에 적용해야 한다.

특허법 역시 마찬가지이다. 2차 공부를 할 때 특허법을 공부하는 도중 현출되는 수없이 많은 단문이나 사례들의 내용과 목차를 단순히 암기의 대상으로 여긴다면 결코 좋은 점수를 받지 못할 것이다. 좋은 점수를 얻기 위해서는, 즉 특허법을 잘 하기 위해서는, 기본 목차를 먼저 충분히 이해하고 이를 바탕으로 내용 정리를 한 후 이를 응용하는 관점에서 단문이나 사례들을 바라보아야 한다.

다시 한 번 정리하면, 저자의 공부방법론의 핵심은 목차의 도구화라 할 수 있다. 목차를 도구화하는 것은 다른 사람이 잡아준 물고기를 먹는 것과 물고기를 잡는 방법을 알아가는 것의 차이하고 할 수 있다. 저자는 본 서에서 목차의 도구화를 위한 기본 목차를 제시하면서, 특허법을 정리해 나가고 있다. 기본 목차를 통해 특허법을 이해한 후 기본 목차가 응용된 단문과 사례를 정리한다면, 어떤 형식의 문제가 독자들에게 주어진다고 하더라도 독자들의 혼이 깃든 논리력을 담아 그 문제를 해결할 수 있을 것이며, 이를 이행하는 것은 현명한 독자들의 몫이라 생각한다.

마지막으로 본 서의 출간 작업을 하는데 항상 든든한 지지자의 역할을 해준 전화연님, 그리고 변함 없이 도움을 주시는 이경란 변리사님, 교정작업을 해 주신 김인배님, 염규관님, 편집작업을 해 주신 한빛 출판부 관계자분들께 감사의 말씀을 드린다.

2007년 8월

임 병 응





## 책을 내면서

특허법은 산업재산권법의 가장 밑바탕이 되는 과목으로써 변리사 시험을 대비하는 수험생들이 많은 시간을 할애하고 있지만 특허법에 대한 접근 방법이 쉽지 않기 때문에 많은 수험생들이 투자한 시간에 비례하여 높은 점수를 받지 못하고 있다.

한편, 현재 수험생들이 특허법 수험공부를 하기 위해 보는 책은 1차용과 2차용으로 구분되어 있는 실정이다. 그 이유는 1차용 수험서는 특허법의 전반적인 내용을 알 수 있도록 상세히 구성되어 있지만 2차 답안을 구성하는 데 있어 적합하지 않으며, 이와는 반대로 2차용 수험서는 2차 답안을 구성하기에는 적합하지만 1차 시험을 대비하기 위한 수험서로서는 내용이 빈약하기 때문이다. 그 결과, 2차 시험에 대비하기 위해서는 별도로 2차용 수험서를 다시 구입하여 공부해야 하기 때문에 수험생들은 시간적, 경제적으로 어려움을 겪고 있다.

필자는 이와 같은 수험생들의 어려움 극복에 도움을 주는 한편, 특허법에 보다 더 쉽게 접근할 수 있도록 하기 위해 본 서를 집필하였는바 본서의 특징은 다음과 같다.

- 첫째, 수험생들이 쉽게 특허법의 전반적인 틀을 체계적으로 이해할 수 있도록 하기 위해 모든 내용을 도표화하였으며 될 수 있으면 관련이론을 한 페이지에 정리하도록 노력하였다.
- 둘째, 될 수 있으면 목차를 단순화하고 통일화함으로써 암기의 부담을 덜 수 있도록 하였다.
- 셋째, 법조문을 첨가하고 필자가 생각하는 중요 법조문을 “역상”을 통해 표시함으로써 법조문을 공부하는 데 강약을 조절할 수 있도록 하는 한편, 법조문의 대한 해설을 통해 법조문에 쉽게 접근할 수 있도록 노력하였다.
- 넷째, 도표의 내용 및 법조문 중 중요하다고 생각되는 부분을 “볼드(진하게)”를 통해 구분함으로써 핵심 내용을 쉽게 공부할 수 있도록 하였다.
- 다섯째, 최근 판례 및 이슈가 되는 사항에 대한 내용을 정리하였다.

아무쪼록 본서가 수험생들의 합격에 도움을 될 수 있도록 끊임없이 노력할 것을 약속드리며, 본서가 출간되기까지 많은 도움을 주신 강명주님, 임병찬님에게 감사드리며, 특히 수험시간을 쪼개어 교정 작업을 해주신 황진원님 및 본서의 편집 및 발행에 도움을 주신 편집부와 황이사님께 깊은 감사의 말씀을 전한다.

2002년 10월  
임 병 응



# 목 차

## 제1장 총칙 및 보칙 • 1

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 01 목적(法 1) .....                    | 2  |
| I 법조문 .....                         | 2  |
| II 발명의 보호 .....                     | 3  |
| III 발명의 이용(이용=공개+실시) 및 장려 .....     | 3  |
| 02 정의(法 2) .....                    | 4  |
| I 법조문 .....                         | 4  |
| II 발명의 성립성(法 2 I) .....             | 5  |
| III 정의 규정의 필요성과 탄력적 해석 .....        | 6  |
| IV 발명의 성립성이 없는 예 .....              | 6  |
| V 실시(法 2 III) .....                 | 7  |
| <b>참고자료 1.1</b> 성립성이 문제되는 발명 .....  | 8  |
| I 전자상거래 관련 발명 .....                 | 8  |
| II 식물발명 .....                       | 9  |
| III 미생물 발명 .....                    | 10 |
| IV 용도발명 .....                       | 11 |
| V 의약발명 .....                        | 12 |
| <b>참고자료 1.2</b> 발명의 분류 .....        | 13 |
| I 분 류 .....                         | 13 |
| II 물건발명과 방법발명의 비교 .....             | 14 |
| III 물건발명과 그 물건을 제조하는 방법발명의 관계 ..... | 15 |
| 03 행위능력(法 3~5 ①) .....              | 16 |
| I 법조문 .....                         | 16 |
| II 권리능력과 행위능력의 구별 .....             | 17 |
| 04 대리인(法 3 ②, 5 ②~10, 12) .....     | 18 |
| I 법조문 .....                         | 18 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| II 대리인의 종류(法 3② 및 5) .....                           | 21 |
| III 대리권의 내용(法 6~10, 12) .....                        | 22 |
| 05 복수당사자의 대표(法 11) .....                             | 23 |
| I 법조문 .....                                          | 23 |
| II 복수당사자 대표(法 11) .....                              | 24 |
| 06 재외자의 재판관할(法 13) .....                             | 25 |
| 07 기일과 기간(法 14, 15) .....                            | 26 |
| I 법조문 .....                                          | 26 |
| II 기간의 계산(法 14) .....                                | 27 |
| III 기일과 기간의 종류(法 15) .....                           | 27 |
| IV 기간연장·단축 및 기일변경의 비교 .....                          | 27 |
| V 기간의 계산 사례 .....                                    | 28 |
| 08 특허에 관한 절차 일반(法 16, 28-28의5) .....                 | 29 |
| I 법조문 .....                                          | 29 |
| II 특허에 관한 절차 일반(法 16, 28~28의5) .....                 | 31 |
| III 절차의 무효(法 16) .....                               | 32 |
| IV 특허출원의 심사 .....                                    | 33 |
| <b>참고자료 1.3</b> 절차의 불수리(서류의 반려) .....                | 34 |
| 09 추후보완(法 17 및 67의3) .....                           | 35 |
| I 법조문 .....                                          | 35 |
| II 추후보완(法 17 및 67의3) .....                           | 35 |
| 10 절차의 효력 승계 및 절차의 속행(法 18, 19) .....                | 36 |
| 11 절차의 정지(法 20~24, 78, 164) .....                    | 37 |
| I 법조문 .....                                          | 37 |
| II 절차 정지의 구분(法 20~24, 78, 164) .....                 | 39 |
| 12 조약의 효력 .....                                      | 40 |
| I 법조문 .....                                          | 40 |
| II 특허 관련 조약의 개략적인 설명 .....                           | 41 |
| 13 보칙(法 215~224의5) .....                             | 42 |
| I 법조문 .....                                          | 42 |
| II 2이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 대한 특칙(法 215, 215의2) ..... | 46 |
| III 비밀유지명령제도(法 224의3~224의5) .....                    | 47 |



|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| <b>참고자료 2.1</b> 거절이유, 정보제공사유, 특허무효사유 및 특허취소사유의 비교 | 50 |
| 14 협의의 특허요건(法 29)                                 | 51 |
| I 법조문                                             | 51 |
| II 산업상 이용가능성(法 29①본문)                             | 52 |
| III 신규성(法 29①각호)                                  | 53 |
| IV 진보성(法 29②)                                     | 54 |
| V 결합발명의 신규성, 진보성 판단                               | 55 |
| VI 특수한 발명의 신규성, 진보성 판단                            | 56 |
| VII 확대된 선출원(法 29③④⑤⑥⑦)                            | 57 |
| 15 선출원주의(法 36)                                    | 58 |
| I 법조문                                             | 58 |
| II 선출원주의의 조문정리(法 36)                              | 59 |
| III 선출원주의(法 36)의 내용                               | 60 |
| IV 선출원주의(法 36)와 확대된 선출원(法 29③④)의 비교               | 61 |
| <b>참고자료 2.2</b> 제29조(협의의 특허요건)과 제36조(선출원주의) 판단    | 62 |
| I 출원발명의 등록금지적 효력                                  | 63 |
| II 적용의 구체적인 예                                     | 65 |
| 16 불특허발명(法 32)                                    | 66 |
| I 법조문                                             | 66 |
| II 불특허발명                                          | 67 |
| 17 국방상 필요한 발명(法 41, 106)                          | 68 |
| I 법조문                                             | 68 |
| II 조문정리                                           | 70 |
| III 비밀취급절차                                        | 70 |
| 18 출원인이 될 수 있는 자(法 25, 33, 44)                    | 71 |
| I 법조문                                             | 71 |
| II 출원인이 될 수 있는 자(法 25, 33, 44)                    | 72 |
| 19 특허를 받을 수 있는 권리(法 37, 38)                       | 73 |
| I 법조문                                             | 73 |
| II 특허를 받을 수 있는 권리(法 37)                           | 74 |
| III 특허를 받을 수 있는 권리의 승계(法 38)                      | 76 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 20 직무발명(발진법 2, 10~19, 58) .....           | 77  |
| I 법조문 .....                               | 77  |
| II 직무발명(발진법 2, 10~19, 58) .....           | 81  |
| III 종업원 발명의 법적 취급 .....                   | 83  |
| IV 사용자 등의 직무발명에 대한 승계 .....               | 83  |
| V 직무발명 절차 규정에 따른 법률관계 .....               | 84  |
| 21 특허출원(法 42~42의3, 43) .....              | 85  |
| I 법조문 .....                               | 85  |
| II 조문정리 .....                             | 89  |
| III 특허출원에 필요한 서류(法 42~42의3, 43) .....     | 90  |
| IV 명세서의 기재방법(法 42) .....                  | 92  |
| V 청구범위 기재불비의 예(法 42④) .....               | 96  |
| VI 다항제 기재의 예(法 42⑧) .....                 | 97  |
| VII 종속항의 종류 .....                         | 99  |
| VIII 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명의 특허법상 보호 ..... | 99  |
| <b>참고자료 2.3</b> 청구항의 작성형태 .....           | 100 |
| <b>참고자료 2.4</b> 연결부의 해석 .....             | 101 |
| 22 하나의 특허출원의 범위(法 45) .....               | 102 |
| I 법조문 .....                               | 102 |
| II 하나의 특허출원의 범위(法 45) .....               | 103 |
| III 하나의 특허출원범위 판단의 구체적 예 .....            | 104 |
| IV 다항제 기재방법과 하나의 특허출원범위의 관계 .....         | 105 |

---

### 제3장 이익제도 • 107

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| 23 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우(法 30) .....               | 108 |
| I 법조문 .....                                          | 108 |
| II 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우(法 30) .....               | 109 |
| III 각종 제도와 공지예외적용주장의 관계 .....                        | 110 |
| 24 정당한 권리자의 보호(法 34, 35, 99의2) .....                 | 111 |
| I 법조문 .....                                          | 111 |
| II 정당한 권리자의 출원의 무권리자의 출원일로 소급에 의한 보호(法 34, 35) ..... | 113 |
| III 특허권의 이전청구에 의한 보호(法 99의2) .....                   | 114 |

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 25 보정(法 46, 47, 51) .....                                       | 115 |
| I 법조문 .....                                                     | 115 |
| II 개념정리 .....                                                   | 117 |
| III 실체보정의 내용(法 47, 51) .....                                    | 118 |
| IV 보정각하(法 51) .....                                             | 120 |
| V 실체보정에 대한 심사절차 .....                                           | 121 |
| VI 법 제47조 제3항 제4호의 구체적인 예 .....                                 | 122 |
| VII 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생하지 않을 것의 구체적인 예(법 제47조 제2항 만족 전제) ..... | 123 |
| 26 분할출원(法 52) .....                                             | 124 |
| I 법조문 .....                                                     | 124 |
| II 분할출원(法 52) .....                                             | 125 |
| III 조약우선권주장을 수반하는 분할출원 .....                                    | 127 |
| 27 분리출원(法 52의2) .....                                           | 128 |
| I 법조문 .....                                                     | 128 |
| II 분리출원(法 52의2) .....                                           | 129 |
| 28 변경출원(法 53) .....                                             | 130 |
| I 법조문 .....                                                     | 130 |
| II 변경출원(法 53) .....                                             | 131 |
| III 분할출원, 분리출원 및 변경출원의 법조문 비교 .....                             | 132 |
| IV 분할출원, 분리출원 및 변경출원의 비교 .....                                  | 133 |
| 29 조약우선권주장출원(法 54) .....                                        | 134 |
| I 법조문 .....                                                     | 134 |
| II 조약우선권주장출원(法 54) .....                                        | 135 |
| III 우선권주장의 보정 또는 추가(法 54⑦) .....                                | 136 |
| 30 국내우선권주장출원(法 55, 56) .....                                    | 137 |
| I 법조문 .....                                                     | 137 |
| II 국내우선권주장출원(法 55, 56) .....                                    | 139 |
| III 이중우선(法 55⑤) .....                                           | 140 |
| IV 국내우선권주장 및 국내우선권주장출원의 취하(法 55⑧, 56) .....                     | 141 |
| V 조약우선권주장출원과 국내우선권주장출원의 비교 .....                                | 142 |
| <b>참고자료 3.1</b> 분할 · 분리 · 변경 · 조약우선권주장 · 국내우선권주장출원의 적법성 .....   | 143 |
| <b>참고자료 3.2</b> 발명의 동일성 및 판단대상의 비교 .....                        | 144 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| I 판례의 의한 각 규정별 동일성의 인정범위 ..... | 144 |
| II 특허요건 판단에서 동일성 인정 여부 .....   | 145 |
| III 각 규정별 판단대상의 비교 .....       | 146 |

---

## 제4장 심사 • 147

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 31 심사관 및 전문기관(法 57~58의2, 68) .....       | 148 |
| 32 심사청구제도(法 59, 60, 67의3) .....          | 149 |
| I 법조문 .....                              | 149 |
| II 심사청구제도(法 59, 60) .....                | 151 |
| III 심사의 보류 .....                         | 152 |
| 33 우선심사제도(法 61) .....                    | 153 |
| I 법조문 .....                              | 153 |
| II 우선심사제도(法 61) .....                    | 154 |
| 34 심사의 진행 .....                          | 155 |
| 35 출원의 취하 및 포기 .....                     | 156 |
| 36 특허여부결정(法 62, 63, 63의3, 66~67의3) ..... | 157 |
| I 법조문 .....                              | 157 |
| II 특허여부결정(法 62, 63, 66~67의2) .....       | 159 |
| III 직권보정(法 66의2) .....                   | 160 |
| IV 직권 재심사(法 66의3) .....                  | 161 |
| V 재심사 청구(法 67의2) .....                   | 162 |
| VI 거절이유통지(法 62)에 대한 출원인의 대응방안 .....      | 163 |
| VII 거절결정등본을 송달받은 출원인의 대응방안 .....         | 164 |
| 37 정보제공제도(法 63의2) .....                  | 165 |
| I 법조문 .....                              | 165 |
| II 정보제공제도(法 63의2) .....                  | 166 |
| 38 출원공개제도(法 64, 65) .....                | 167 |
| I 법조문 .....                              | 167 |
| II 출원공개제도(法 64, 65) .....                | 169 |
| III 보상금청구권(法 65) .....                   | 170 |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 39 특허료 납부 등(法 79~86)                          | 172 |
| I 법조문                                         | 172 |
| II 특허료(法 79~81의3)                             | 178 |
| III 특허료 납부 절차                                 | 179 |
| IV 등록의 효력                                     | 180 |
| 40 설정등록 및 등록공고(法 87)                          | 181 |
| I 법조문                                         | 181 |
| II 설정등록 및 등록공고(法 87)                          | 182 |
| III 출원공개제도와 등록공고제도의 비교                        | 183 |
| 41 존속기간과 존속기간연장등록제도(法 88~93, 95)              | 184 |
| I 법조문                                         | 184 |
| II 존속기간(法 88)                                 | 187 |
| III 허가 등과 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장의 비교(법조문)     | 188 |
| IV 허가 등과 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장의 비교(내용)       | 191 |
| 42 효력의 의의, 제한 및 확장(法 94~96, 127)              | 192 |
| I 법조문                                         | 192 |
| II 특허권의 효력(法 94①~96, 127)                     | 193 |
| III 권리소진에 의한 제한                               | 194 |
| IV 특허권의 하자에 의한 제한                             | 195 |
| V 권리남용에 의한 제한                                 | 196 |
| 43 특허발명의 보호범위(法 97)                           | 197 |
| I 법조문                                         | 197 |
| II 보호범위(法 97)의 판단                             | 198 |
| III 균등론                                       | 199 |
| IV 특허요건 판단과 보호범위 판단 시 발명의 특정                  | 200 |
| 44 이용 및 저촉 발명(法 98)                           | 201 |
| I 법조문                                         | 201 |
| II 이용·저촉관계의 조문 정리                             | 202 |
| III 이용 및 저촉발명(法 98)                           | 203 |
| IV 구체적 예                                      | 204 |
| 45 특허권의 침해 (法 97, 98, 126~132, 225, 230, 231) | 205 |

|             |                                                |     |
|-------------|------------------------------------------------|-----|
| I           | 법조문                                            | 205 |
| II          | 침해의 성립요건(法 97, 98, 127)                        | 208 |
| III         | 침해의 유형                                         | 209 |
| IV          | 직접침해의 유형별 검토                                   | 209 |
| V           | 침해에 대한 조치(法 126, 128~132, 225, 230, 231)       | 210 |
| VI          | 침해에 대한 손해배상청구권(法 128)                          | 211 |
| VII         | 간접침해(法 127)                                    | 213 |
| VIII        | 특허출원된 발명을 제3자가 실시하고 있을 때 출원인 및 제3자의 대응방안       | 215 |
| <b>참고자료</b> | <b>5.1</b> 특허요건 판단과 침해 성립요건 판단의 구별             | 216 |
| IX          | 특허요건 판단과 침해 성립요건 판단의 구별                        | 217 |
| 46          | 벌칙(法 225~232)                                  | 218 |
| I           | 법조문                                            | 218 |
| II          | 벌칙의 구별(法 225~232)                              | 220 |
| 47          | 특허권의 이전 및 공유(法 99, 99의2)                       | 221 |
| I           | 법조문                                            | 221 |
| II          | 특허권의 이전(法 99①, 99의2)                           | 222 |
| III         | 특허권의 공유(法 99②③④)                               | 223 |
| 48          | 실시권 일반(法 100~102, 118)                         | 224 |
| I           | 법조문                                            | 224 |
| II          | 전용실시권과 통상실시권의 법조문 비교                           | 225 |
| III         | 실시권 일반(法 100~102, 118)                         | 226 |
| 49          | 법정실시권(法 81의3⑤, 103~105, 122, 182, 183, 발진법 10) | 227 |
| I           | 법조문                                            | 227 |
| II          | 법정실시권의 성립요건 및 효력                               | 230 |
| III         | 법정실시권의 비교(1)                                   | 231 |
| IV          | 법정실시권의 비교(2)                                   | 232 |
| 50          | 강제실시권(法 106의2~115, 138)                        | 233 |
| I           | 법조문                                            | 233 |
| II          | 재정제도(法 107~115)                                | 236 |
| III         | 재정요건(法 107)의 비교                                | 238 |
| IV          | 재정절차                                           | 239 |
| V           | 강제실시권의 비교                                      | 240 |
| 51          | 특허권상 질권(法 121~123)                             | 241 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| I 법조문 .....                               | 241 |
| II 특허법상 질권(法 121~123) .....               | 242 |
| III 특허권의 변동과 특허를 받을 수 있는 권리의 변동의 비교 ..... | 243 |
| 52 특허권의 소멸(法 119, 120, 124) .....         | 244 |
| I 법조문 .....                               | 244 |
| II 특허권의 소멸(法 119, 120, 124) .....         | 245 |
| 53 실시보고 및 집행권원(法 125, 125의2) .....        | 246 |

---

## 제6장 심판 • 247

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| <b>참고자료 6.1</b> 심판의 분류 .....                        | 248 |
| 54 특허심판원(法 132의16, 143~153의2) .....                 | 249 |
| I 법조문 .....                                         | 249 |
| II 심판관의 제척·기피 및 회피(法 148~153의2) .....               | 251 |
| 55 심판의 당사자(청구인, 피청구인)(法 139) .....                  | 252 |
| I 법조문 .....                                         | 252 |
| II 심판의 당사자(法 139) .....                             | 253 |
| 56 심판의 참가인(法 155, 156) .....                        | 254 |
| I 법조문 .....                                         | 254 |
| II 심판의 참가인(法 155, 156) .....                        | 255 |
| 57 국선대리인, 전문심리위원 및 참고인(法 139의2, 154의2, 154의3) ..... | 256 |
| I 법조문 .....                                         | 256 |
| II 전문심리위원 .....                                     | 257 |
| 58 심판의 청구(法 140, 140의2) .....                       | 258 |
| 59 방식심리와 적법성심리(法 141, 142) .....                    | 260 |
| I 법조문 .....                                         | 260 |
| II 방식심리와 적법성심리(法 141~142) .....                     | 261 |
| III 심사단계에서 직권보정과 심판단계에서 직권보정의 비교 .....              | 262 |
| 60 본안심리(法 154, 157~160) .....                       | 263 |
| I 법조문 .....                                         | 263 |
| II 본안심리(法 154, 157~160) .....                       | 266 |
| 61 심판청구의 취하(法 161) .....                            | 267 |
| I 법조문 .....                                         | 267 |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| II 참가의 취하 및 심판청구의 취하의 비교 .....                    | 268 |
| 62 심결(法 162, 163) .....                           | 269 |
| I 법조문 .....                                       | 269 |
| II 심결(法 162) .....                                | 270 |
| III 일사부재리(法 163) .....                            | 271 |
| IV 일사부재리와 중복심판청구금지의 비교 .....                      | 272 |
| 63 조정위원회 회부, 심판비용 및 집행권원(法 164의2, 165, 166) ..... | 273 |
| 64 거절결정불복심판(法 132의17, 170~172, 176) .....         | 275 |
| I 법조문 .....                                       | 275 |
| II 거절결정불복심판(法 132의17, 170~172, 176) .....         | 276 |
| 65 특허무효심판(法 133) .....                            | 277 |
| I 법조문 .....                                       | 277 |
| II 특허무효심판(法 133) .....                            | 278 |
| III 정보제공(法 63의2)와 특허무효심판(法 133)의 비교 .....         | 279 |
| 66 존속기간연장등록무효심판(法 134) .....                      | 280 |
| I 법조문 .....                                       | 280 |
| II 존속기간연장등록무효심판(法 134) .....                      | 281 |
| 67 권리범위확인심판(法 135) .....                          | 282 |
| I 법조문 .....                                       | 282 |
| II 권리범위확인심판(法 135) .....                          | 283 |
| III 확인대상발명의 특정 .....                              | 284 |
| IV 권리 사이의 권리범위확인심판 인정여부 .....                     | 286 |
| 68 정정심판(法 136) .....                              | 287 |
| I 법조문 .....                                       | 287 |
| II 정정심판(法 136) .....                              | 288 |
| III 정정심판과 특허취소신청, 특허무효심판과의 관계 .....               | 289 |
| IV 특허의 정정과 정정심판의 구별 .....                         | 291 |
| V 청구범위의 실질적 변경 여부에 대한 구체적 예 .....                 | 291 |
| 69 정정무효심판(法 137) .....                            | 292 |
| I 법조문 .....                                       | 292 |
| II 정정무효심판(法 137) .....                            | 293 |
| 70 통상실시권허락심판(法 138) .....                         | 294 |
| I 법조문 .....                                       | 294 |



|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| II 통상실시권허락심판(法 138) .....                | 295 |
| <b>참고자료 6.2</b> 심판각론의 비교 .....           | 296 |
| I 비교 1 .....                             | 296 |
| II 비교 2 .....                            | 297 |
| 71 특허취소신청(法 132의2~132의15) .....          | 298 |
| I 법조문 .....                              | 298 |
| II 특허취소신청절차 .....                        | 301 |
| III 특허취소신청과 특허무효심판의 비교(법조문) .....        | 302 |
| IV 특허취소신청과 특허무효심판의 비교 .....              | 307 |
| 72 정정청구(法 132의3, 133의2, 137③④) .....     | 308 |
| I 법조문 .....                              | 308 |
| II 특허의 정정청구(法 132의3, 133의2, 137③④) ..... | 310 |
| III 특허의 정정과 정정심판의 비교 .....               | 311 |
| IV 특허출원을 하였을 때 특허를 받을 수 있을 것의 판단 .....   | 312 |
| 73 재심(法 178~185) .....                   | 313 |
| I 법조문 .....                              | 313 |
| II 재심에 대한 조문정리 .....                     | 315 |
| III 재심(法 178~185) .....                  | 316 |

---

## 제7장 특허소송 • 319

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 74 심결취소소송(협회의 특허소송)(法 186~189) .....     | 320 |
| I 법조문 .....                              | 320 |
| II 특허소송(심결취소소송) .....                    | 322 |
| III 광의의 특허소송의 분류 .....                   | 326 |
| IV 심판당사자의 원·피고적격 .....                   | 326 |
| V 공유특허권 또는 공동심판청구인 1인의 원·피고적격 .....      | 326 |
| 75 보상금 또는 대가에 대한 불복의 소(法 190, 191) ..... | 327 |
| 76 변리사의 보수와 소송비용(法 191의2) .....          | 328 |

---

## 제8장 국제출원 • 329

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| <b>참고자료 8</b> 우리나라 특허법 규정에 반영된 특허협력조약(PCT) ..... | 330 |
| 77 국제출원절차(法 192~198) .....                       | 331 |
| I 법조문 .....                                      | 331 |
| II 국제출원절차(法 192~198)의 법조문 정리 .....               | 335 |
| III 국제출원절차(法 192~198) .....                      | 336 |
| IV 자동지정제도와 자동선택제도 .....                          | 338 |
| V 국내출원과 국제출원의 방식심사의 비교 .....                     | 338 |
| 78 국제조사 및 국제예비심사(法 198의2) .....                  | 339 |
| I 법조문 .....                                      | 339 |
| II 국제단계절차의 개략도 .....                             | 340 |
| III 국제조사업무 흐름도 .....                             | 341 |
| IV 국제예비심사 업무 흐름도 .....                           | 342 |
| V 국제조사와 국제예비심사의 비교 .....                         | 343 |
| VI 국제공개와 국내공개의 비교 .....                          | 344 |
| 79 국제특허출원에 관한 특례(法 199~214) .....                | 345 |
| I 법조문 .....                                      | 345 |
| II 국제특허출원에 관한 특례(法 199~214) .....                | 351 |
| III 국어번역문의 제출 .....                              | 355 |
| IV 기준일의 정의 .....                                 | 356 |
| V 외국어특허출원과 외국어국제특허출원의 국어번역문 제출의 비교 .....         | 357 |
| VI 우선권주장의 특례(PCT 제8조의 해석) .....                  | 358 |
| VII 보정의 특례 .....                                 | 361 |

---

## 제9장 실용신안법 • 365

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 80 실용신안법의 보호대상 .....    | 366 |
| 81 특허법과 실용신안법의 비교 ..... | 367 |

도해특허법

## 제1장 총칙/보칙

## 제2장 특허요건

## 제3장 이익제도

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 01 | 목적(法 1)                       |
| 02 | 정의(法 2)                       |
| 03 | 행위능력(法 3~5①)                  |
| 04 | 대리인(法 3②, 5②~10, 12)          |
| 05 | 복수당사자 대표(法 11)                |
| 06 | 재외자의 재판관할(法 13)               |
| 07 | 기일과 기간(法 14, 15)              |
| 08 | 특허에 관한 절차 일반(法 16, 28~28의5)   |
| 09 | 추후보완(法 17, 67의3)              |
| 10 | 절차의 효력의 승계 및 절차의 속행(法 18, 19) |
| 11 | 절차의 정지(法 20~24, 78, 164)      |
| 12 | 조약의 효력                        |
| 13 | 보칙(法215~224의5)                |

# 01

## 목적(法 1)

### I 법조문

#### 제1조 【목적】 (★)

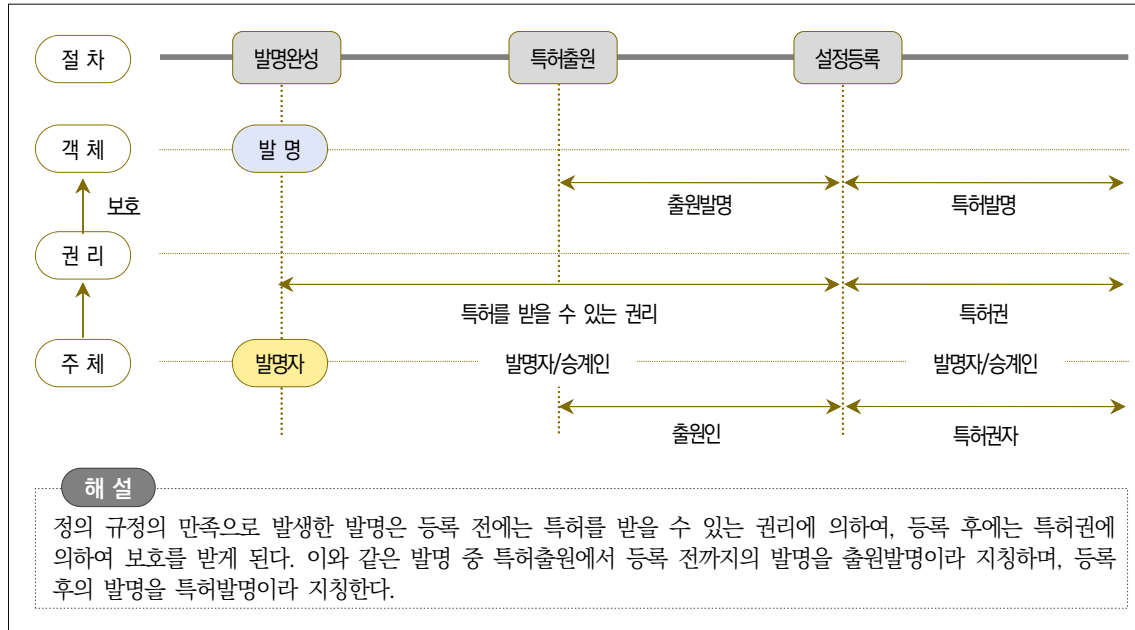
이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.  
[전문개정 2014.6.11.]

#### ■ 목적의 의의

- 특허법 전체의 해석지침을 제공
- 개개의 규정들은 특허법의 목적에 부합되도록 해석·운영

#### ■ 보호·장려(사익적 측면) + 이용 도모(공익적 측면) → 기술발전의 촉진 → 산업발전에 이바지

## II 발명의 보호



| 구 분 | 출원 전 보호                                            | 출원 후 설정등록 전 보호                                                                                                                                    | 설정등록 후 보호                                          |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 실체적 | 특허를 받을 수 있는 권리(法 33, 37, 38)                       |                                                                                                                                                   | 특허권(法 94①)                                         |
|     | 1. 선사용권(法 103)<br>2. 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건(法 96①Ⅲ) | 보상금청구권(法 65)                                                                                                                                      |                                                    |
| 절차적 | 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우(法 30)                      | 1. 보정(法 46, 47, 51)<br>2. 분할출원(法 52)<br>3. 분리출원(法 52의2)<br>4. 변경출원(法 53)<br>5. 조약우선권(法 54)<br>6. 국내우선권(法 55, 56)<br>7. 각종 불복<br>8. 거절이유의 법정(法 62) | 1. 특허의 정정(法 132의3, 133의2, 137)<br>2. 특허정정심판(法 136) |

## III 발명의 이용(이용=공개+실시) 및 장려

| 구 분    |    | 내 용                                                                                                                          |
|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 발명의 이용 | 공개 | 1. 발명의 설명 기재요건의 법정(法 42③ I)<br>2. 출원공개제도(法 64, 65)                                                                           |
|        | 실시 | 1. 특허권자의 실시 → 독점적 실시권(法 94①) + 실시 의무부과(法 107)<br>2. 제3자의 실시 → 특허권의 침해가 되지 않거나 권리행사가 제한되는 범위 내에서 실시                           |
| 발명의 장려 |    | 1. 일정한 경우 수수료 및 등록료의 감면 또는 면제(法 83, 징수규칙 8)<br>2. 발명진흥보조금의 지급과 관련하여서는 기존에는 특허법 제27조에 규정되어 있었으나 현재는 삭제되고, 발명진흥법 제4조에 별도로 규정함. |



## 정의(法 2)

### I 법조문

#### 제2조 【정의】 (★★)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2019. 12. 10., 2025. 1. 21.>

1. **【발명의 정의】** "발명"이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다.
2. **【특허발명의 정의】** "특허발명"이란 특허를 받은 발명을 말한다. **法 81의3③, 89, 107① I, II, 136③**
3. **【실시의 정의】** "실시"란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다.
  - 가. **【물건발명】** 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위
  - 나. **【방법발명】** 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위 **法 94②**
  - 다. **【제법발명】** 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

[전문개정 2014.6.11.]

## II 발명의 성립성(法 2 I)

| 요 건    |          | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서      | 정의       | 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도화된 것(法 2 I)                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 고안과의 구별  | 고안도 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이긴 하나 고도성을 요하지는 않으며, 물품의 형상, 구조 또는 그 조합에 관한 것일 것을 요한다.                                                                                                                                                                                              |
| 내 용    | 자연법칙을 이용 | 1. 자연법칙<br>자연법칙이란 자연계에 존재하는 원리·원칙으로서 과학상의 법칙 이외에 경험칙도 포함<br>2. 자연법칙의 이용<br>① 자연법칙 자체는 발견일 뿐 발명으로서 성립되지 않으며(cf - 용도발명), ② 발명은 자연법칙을 전체적으로 이용하여야 하며(cf - 컴퓨터 프로그램 관련발명), ③ 100%의 확실성을 요하지는 않지만 일정한 확실성 및 반복가능성이 있어야 하며(cf - 미생물 발명, 식물발명), ④ 발명자가 자연법칙에 대한 정확한 인식을 가질 필요는 없다. |
|        | 기술적 사상   | 1. 기술<br>일정한 목적을 달성하기 위한 구체적인 수단으로서 실제 이용할 수 있는 것을 의미. 다만, 제3자에게 그대로 전달될 수 있는 객관성이 있다는 점에서 기능, 기예(악기연주방법, 투구방법)와 구별<br>2. 사상<br>추상적이고 개념적인 착상을 말하는 것으로서 특허법상 발명은 반드시 기술일 필요는 없으며 기술적 사상이면 족하다. 즉, 발명은 기술과 같이 현실적으로 구체성을 띤 것이 아니라 창작 기술로서 실현가능성이 있으면 된다.                     |
|        | 창작성      | 만들어낸 것, 만들어낸 것이 아닌 것은 발견에 불과(cf - 용도발명)                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 고도성      | 고도성은 특허법상의 발명과 실용신안법상의 고안과의 구별기준                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 판 단      | 주체적 기준<br>심사관, 심판관, 법관                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 판 단    | 객체적 기준   | 대상<br>청구범위를 중심으로 발명의 설명·도면을 참작                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |          | 범위<br>청구항마다                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 시기적 기준   | 원칙<br>명문의 규정은 없으나 특허출원 시를 기준으로 판단<br>예외<br>① 무권리자에 대한 정당한 권리자의 출원의 경우 무권리자의 출원일(法 34, 35), ② 분할출원(法 52②), 분리출원(法 52②), 변경출원(法 53②)의 경우 원출원일, ③ 조약우선권주장출원(法 54①), 국내우선권주장출원(法 55③)의 경우 선출원일, ④ 국제특허출원의 경우 우선일의 출원 시를 기준으로 판단                                                 |
| 위반의 효과 |          | 1. 산업상 이용가능성(法 29①본문), 발명의 설명 기재(法 42③ I) 위반을 이유로 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法133①)<br>2. 기술적 범위를 특정할 수 없거나 실시불가능한 경우에는 권리범위 불인정                                                                                                                                    |
| 관련문제   |          | 1. 불성립발명의 등록금지적 효력<br>① 공지기술의 지위 - ○(98후270)<br>② 확대된 선출원의 지위 - ×(2000후2248, 91후1656)<br>③ 선출원의 지위 - ×(法 36④)<br>2. 특허와 노하우의 구별                                                                                                                                             |
|        |          | 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |          | 특 허                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |          | 노 하 우                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |          | 공개여부                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |          | 성립요건                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |          | 특허요건                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |          | 보호기간                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |          | 보호범위                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |          | 독점·배타성                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |          | 침해에 대한 구제                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Ⅲ 정의 규정의 필요성과 탄력적 해석

| 구 분                    | 정의 규정의 존재                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 정의 규정의 부존재 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 예측 가능성(법적안정성)          | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ×          |
| 새로운 발명 수용<br>(구체적 타당성) | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ○          |
| 특허법의 태도                | 1. 법적 안정성을 위해 정의 규정을 두고 있음(法 21)<br>2. 단점을 보완하여 정의규정을 탄력적으로 해석<br>① 컴퓨터 프로그램 관련 발명(자연법칙을 전체적으로 이용하지 않지만 시대적 흐름에 부응하고자 예외적으로 컴퓨터 프로그램이 장치, 기록매체 등과 유기적으로 결합한 경우에는 발명의 성립성 인정)<br>② 식물발명(일정한 확실성 및 반복가능성이 문제가 되며, 육종경과를 상세히 기재하여야만 발명의 성립성 인정)<br>③ 미생물발명(일정한 확실성 및 반복가능성이 문제가 되며, 통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 없는 경우 기탁을 통해 이를 보완, 다만 통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 입수방법만 기재하면 족함)<br>④ 용도발명(발견이지만 새로운 용도를 발견하고 이를 새로운 용도로 이용하는 과정에서 존재하는 창작적 요소가 보호할 가치가 있기 때문에 예외적으로 발명의 성립성 인정) |            |

### Ⅳ 발명의 성립성이 없는 예

| 구 분   | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비발명   | 1. 자연법칙 그 자체 - 만유인력의 법칙이나 가속도의 법칙, 열역학의 법칙, 에너지 보존의 법칙<br>2. 자연법칙에 위배된 것 - 영구운동의 기계장치<br>3. 자연법칙을 이용하지 아니한 것 - 자연법칙 이외의 법칙(경제법칙, 수학공식, 논리학적 법칙, 작도법 등), 인위적인 약속(게임의 규칙 등) 또는 인간의 정신활동(영업계획, 금융방법 그 자체 등)<br>4. 컴퓨터 프로그램 언어 자체, 컴퓨터 프로그램 자체<br>5. 반복하여 동일한 효과를 얻을 수 없는 것<br>6. 정보의 단순한 제시 - 녹음된 음악에만 특징이 있는 CD, 컴퓨터 프로그램 리스트 자체 등<br>7. 미적 창작물<br>8. 기능 - 악기 연주방법, 공을 손가락으로 잡는 방법과 공을 던지는 방법에 특징이 있는 투구방법<br>9. 발견 |
| 미완성발명 | 1. 목적달성을 위한 수단은 제시되었으나 그 수단으로 소기의 목적달성이 현저히 의심스러운 경우<br>2. 목적달성을 위한 수단이 불안전하게 기재되어 있어, 추상적 이론 혹은 희망적 사항을 열거한데 불과한 발명<br>3. 문제제기와 착상의 제출에 그치고, 어떻게 해서 이것이 실현되는가를 알 수 없는 발명<br>4. 해결수단이 제시되고 있으나, 막연하게 기재되어 있어 구체화에 대한 상세한 설명이 불분명한 경우<br>5. 해결수단이 제시되고 있으나, 목적달성이 불가능하다고 인정되는 경우                                                                                                                                   |



V 실시(法 2Ⅲ)

| 구 분 |            | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서   | 의의         | 실시란 발명을 그 발명의 내용에 따라 사용하는 것을 말하며, 특허법은 제2조제3호 가목 내지 다목에서 특허법상 실시를 물건의 발명, 방법의 발명 및 물건을 생산하는 방법으로 분류하여 규정하고 있다.                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 취지         | 특허법은 실시의 개념을 명확히 함으로써 법 해석의 혼동을 피하고 법 적용의 통일을 기하기 위해 실시의 정의를 규정하고 있다.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 태양  | 물건발명       | 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)를 하는 행위를 말한다(法 2Ⅲ가).                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 방법발명       | 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 말한다(法 2Ⅲ나).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 제법발명       | 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다(法 2Ⅲ다).                                                                                                                                                                                                                  |
| 내용  | 생산         | 특허발명의 구성요소를 충족하지 아니한 물건을 받은 자가 이를 사용하여 특허발명의 구성요소를 충족하는 물건을 만들어 내는 모든 의식적 행위를 의미한다고 보아야 하고, 반드시 공업적 생산에 한하지 아니하고 가공, 조립, 수리 등의 행위도 포함될 수 있다. 한편, 마지막 단계에서의 가공, 조립 등이 예정되어 있으나, 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면 이 역시 생산으로 간주한다(2019다222782, 2019다222799(병합)).                   |
|     | 사용         | 발명이 추구하는 본래의 목적을 달성하거나 작용·효과를 나타내도록 그 발명을 이용하는 것을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 양도         | 생산된 발명품의 소유권을 의사표시에 의하여 타인에게 유상 또는 무상으로 이전하는 것을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 대여         | 특허권자가 발명품을 유상 또는 무상으로 일정한 시기에 반환할 것을 조건으로 타인에게 빌려주는 것을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 수출         | 국내에서 외국에 물건을 내보내는 것을 말한다. 기존에는 수출을 특허발명의 실시행위로 보지 않았으나 개정법(법률 제20700호)에서는 물건발명, 물건을 생산하는 방법발명의 실시행위에 포함                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 수입         | 외국에서 생산된 물건을 국내에서 사용·양도·대여의 목적으로 외국에서 들어오는 것을 말한다. 그러나 보세구역내에 있는 동안은 아직 수입된 것으로 보지 아니한다.                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 양도, 대여 청약  | 양도·대여의 청약이란 특허품을 양도 또는 대여하기 위하여 계약을 성립시킬 것을 목적으로 하는 의사표시를 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 방법 사용 청약   | 방법의 발명인 경우에 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 발명의 실시로 규정하여, 온라인 전송행위를 방법발명의 실시의 일 유형으로 포섭함으로써 특허권의 침해가 될 수 있도록 하였다(法 2Ⅲ나). 다만, 소프트웨어 산업의 위축을 방지하기 위하여 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 특허권의 효력이 미치도록 제한하고 있다(法 94②). 따라서 방법의 사용을 청약하는 행위에는 특허법 제130조의 과실추정 규정이 적용되지 않으며, 특허권자로부터 침해 경고를 받은 이후에 실시를 중단하면 특허권의 침해가 되지 않는다. |
| 기타  | 소지, 구입, 보관 | 특허제품의 단순한 소지행위·단순구입·보관행위는 특허법상 실시에 해당하지 않으므로 그 자체가 특허권의 침해라고 볼 수 없다. 그러나 소지자 또는 보관자가 물건을 양도 또는 대여할 목적으로 소지하는 것은 특허권을 침해할 개연성이 있으므로 특허권자는 침해예방에 필요한 조치를 취할 수 있다                                                                                                                                                                    |
|     | 실시행위의 독립성  | 각각의 실시행위는 서로 독립적이므로 침해여부 역시 각각 독립적으로 판단해야 한다. 즉, 법 제2조제3호에서 규정한 각각의 실시행위는 특허권의 효력상 독립적이며 어느 하나의 실시행위는 다른 실시행위에 영향을 미치지 아니하기 때문에 한 단계의 실시행위가 적법하다고 하여 다른 단계의 행위까지도 적법하게 되는 것은 아니다.                                                                                                                                                 |
|     | 권리소진       | 권리소진이란 특허권자 또는 제조·판매권을 가진 실시권자(이하 “특허권자 등”이라 함)가 특허발명을 실질적으로 구현한 제품(이하 “특허제품”이라 함)을 적법하게 판매한 경우에 판매할 때 권리가 소진되어 동일물에 대해서는 특허권의 침해를 주장할 수 없게 되는 것을 말한다.                                                                                                                                                                            |
| 기타  | 실시와 침해의 구별 | 실시와 침해는 구별되어야 한다. 발명의 실시인지 여부는 법 제2조제3호 각목에 따라 판단하면 된다. 한편, 침해가 성립되기 위해서는 특허권 존속 중 정당한 권원없는 자가 업으로서 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 실시하여야 한다. 따라서, 발명의 실시라 할지라도 법률의 제한에 해당하거나 정당한 권원이 있다면 침해가 아닐 수 있으며, 발명의 실시가 아니더라도 법 제127조의 행위에 해당한다면 침해가 될 수 있다.                                                                                          |

참고자료 1.1 성립성이 문제되는 발명

I 전자상거래 관련 발명

| 발 명        |            | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서          | 의의         | 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되도록 컴퓨터 기술에 의하여 구현된 발명을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 취지         | 자연법칙을 100% 이용하지 아니하여 발명의 성립성이 문제되지만, 인터넷기술의 발달, 전자상거래의 확대 및 세계 각국의 발명으로서 인정경향 등을 반영해 특허법상 발명으로서 인정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 특허요건<br>등  | 성립성        | <p>1. 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 유형</p> <p>청구항에서 영업방법 자체를 추상적으로 청구하면서 각 단계가 컴퓨터상에서 어떻게 수행될 것인지에 대한 어떠한 구체적인 한정도 포함되지 아니한 경우로서, 이는 성립성이 부정된다. 이 유형은 ‘순수한 영업방법’과 ‘추상적 아이디어’로 분류될 수 있으며, 산업상 이용가능성이 없는 발명으로 거절된다.</p> <p>2. 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 있는 유형</p> <p>비즈니스 방법(business method) 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하며, 여기에서 「소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다」는 것은 소프트웨어가 컴퓨터에 의하여 단순히 읽혀지는 것에 그치지 않고, 소프트웨어와 하드웨어가 구체적인 상호 협동수단에 의하여 사용목적에 따른 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용목적에 대응한 특유의 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축되는 것을 말한다.</p> |
|            | 명세서<br>기재  | <p>1. 발명의 설명의 기재</p> <p>전자상거래 관련 발명의 청구항에 기재되어 있는 영업방법이 「컴퓨터상에서 수행되어지게 하는 구현기술」에 대하여 발명의 설명에는 그 구체적인 구성요소가 실시가능하도록 기재되어야 한다.</p> <p>2. 청구범위의 기재</p> <p>전자상거래 관련 발명을 포함하는 컴퓨터 프로그램 관련 발명의 청구항 작성형태에 대하여 살펴보면, 컴퓨터 프로그램에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있는 경우에 해당 컴퓨터 프로그램과 협동해 동작하는 정보 처리 장치(기계) 및 동작 방법을 각각 물건발명과 방법발명으로 청구할 수 있다. 또한, 해당 컴퓨터 프로그램을 설치하고 실행하거나 유통하기 위해 사용되는 “해당 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체” 또는 “하드웨어와 결합되어 특정과제를 해결하기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램(애플리케이션)”을 물건발명으로서 청구할 수 있다. 다만 매체에 저장되지 아니한 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터 프로그램 자체를 청구한 것이므로 허용되지 아니한다.</p>       |
|            | 기타<br>특허요건 | <p>1. 신규성(法 29①각호)</p> <p>영업방법상의 특징과 컴퓨터기술 구성상의 특징이 결합되어 있으므로 출원발명과 인용대상이 동일한 영업방법상의 특징을 가지고 있더라도 그 컴퓨터기술 구성상의 차이가 있으면 신규성이 있는 것으로 판단된다.</p> <p>2. 진보성(法 29②)</p> <p>출원발명과 인용자료의 구성요소를 대비하여 판단하며, 구체적으로 ① 종래의 영업방법을 통상의 자동화기술로 구현한 경우에는 진보성이 없는 것으로 판단되며, ② 종래의 영업방법을 새로운 기술로 구현한 경우 또는 새로운 영업방법이 새로운 기술로 구현된 경우에는 진보성이 인정될 수 있다.</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| 특허권의<br>효력 | 적극적<br>효력  | 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(法 94①). 방법의 발명인 경우에 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 발명의 실시로 규정하여, 컴퓨터 프로그램 실행(방법의 사용)을 위한 온라인 전송행위(청약)를 방법발명의 실시의 일 유형으로 포섭함으로써 특허권의 침해가 될 수 있도록 하였다(法 2Ⅲ나). 다만, 소프트웨어 산업의 위축을 방지하기 위하여 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 특허권의 효력이 미치도록 제한하고 있다(法 94②). 따라서 방법의 사용을 청약하는 행위에는 제130조의 과실추정 규정이 적용되지 않으며, 특허권자로부터 침해 경고를 받은 이후에 실시를 중단하면 특허권의 침해가 되지 않는다.                                                                                                                                                              |
|            | 소극적<br>효력  | 특허권자는 정당한 권원 없는 제3자가 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 경우에는 침해를 이유로 민·형사상 구제조치를 취할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## II 식물발명

| 발 명        |            | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서          | 의의         | 반복생식할 수 있는 변종식물에 대한 발명을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 취지         | 신규화합물의 특허성 인정과 더불어 식물 자체에 대해서도 창작성을 인정하게 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 특허요건<br>등  | 성립성        | 1. 구법 제31조에서는 “무성적으로 반복생식할 수 있는 변종식물을 발명한 자는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.”고 규정하고 있었으나, 동물발명의 경우 유·무성 상관없이 특허법에서 보호를 하는데, 식물발명은 무성번식한 경우에 한해서만 보호를 하는 것은 타당하지 않기 때문에 개정법(法律 제7871호, 2006. 03.03. 개정 / 2006. 10. 01 시행)에서 법 제31조를 삭제하였다. 즉, 식물발명도 유·무성 상관없이 변종식물에 해당한다면 특허를 받을 수 있다.<br>2. 식물발명의 발명의 특성을 재현할 수 있는 육종경과를 상세히 기재하여야만 발명의 성립성이 인정된다. |
|            | 명세서<br>기재  | 식물발명이라 하여 그 결과물인 식물 또는 식물소재를 기탁함으로써 명세서의 기재를 보충하거나 그것을 대체할 수 없다(96후2531).                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 기타<br>특허요건 | 1. 산업상 이용가능성(法 29①본문)<br>상업적 규모로 번식할 수 있어야 한다. 여기서 산업은 공업 외에 임업·농업 등을 포함하는 광의의 개념이다. 주로 농업분야에 이용되겠지만, 공해방지, 재해방지, 의학 등에도 이용이 가능하다.<br>2. 신규성(法 29①각호)<br>공지의 품종과 비교하여 형태적 또는 생리적으로 1 이상의 특징을 가진 것이어야 한다.<br>3. 진보성(法 29②)<br>출원발명과 공지발명 또는 공지식물 간에 변형특성 내지 개량상의 차이점 등을 중심으로 판단한다.                                                         |
|            | 이익제도<br>활용 | 필요한 경우 분할출원(法 52), 조약우선권주장출원(法 54), 국내우선권주장출원(法 55) 등을 이용할 수 있다(변경출원 ×).                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 특허권의<br>효력 | 적극적<br>효력  | 식물발명의 특허권자는 업으로서 식물발명을 실시할 권리를 독점한다(法 94①).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 소극적<br>효력  | 정당한 권원없이 제3자가 특허발명을 업으로서 실시할 경우에는 식물발명의 특허권자는 민·형사상 제재조치를 취할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### III 미생물 발명

| 발 명     |              |                   | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서       | 의의           |                   | 미생물이란 곰팡이·세균 등 미세 크기의 생명을 가진 물체로서, 미생물발명이란 미생물 자체의 발명, 미생물을 생산하는 방법에 관한 발명, 미생물을 이용하는 발명 등을 총칭한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 취지           |                   | 종래에는 미생물이 창작물이 아닌 단순한 발견이고 반복생산가능성이 없기 때문에 발명으로서의 성립요건을 갖추고 있지 않다는 이유로 특허성을 부정하였으나, 최근에는 i) 유전공학의 발달로 인하여 DNA 구조가 규명됨으로서 단순한 발견이 아니라는 것이 밝혀지고, ii) 서면주의의 예외를 인정하여 반복생산가능성에 대한 문제가 해결됨으로서 미생물의 특허성을 인정하고 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 특허요건 등  | 발명의 성립성      | 일반                | 1. 통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 있는 미생물은 반드시 국내에 현존할 필요×(99허8653)<br>2. 출발미생물만 기탁하면 되지 중간생성물이나 최종생성물까지 기탁할 필요×(90후1260).<br>3. 통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 있는 미생물인지 여부는 명세서 제출 당시인 출원 시를 기준으로 판단(96후658).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |              | 쉽게 입수 가능하지 아니한 경우 | 1. 기탁기관에 기탁(승 2①)<br>미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 특허출원 전에 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에 지식재산처장이 정하여 고시하는 방법에 따라 해당 미생물을 기탁하여야 하고, 기탁한 특허출원인은 특허출원서에 총리령이 정하는 방법에 따라 취지를 적어야 한다(승 2①②).<br>2. 기탁증명서 제출(승 2②)<br>미생물을 기탁한 자는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류(국제기탁기관에 기탁한 경우에는 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 규칙」 제7규칙에 따른 수탁증 중 최신의 수탁증 사본을 말한다)를 첨부하여야 한다. 다만, 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 기탁한 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 아니 할 수 있다. 한편 미생물의 기탁에 대하여 특허출원후 새로운 수탁번호가 부여된 때에는 지체없이 그 사실을 지식재산처장에게 신고하여야 한다(승 2②③).<br>3. 기탁사실의 기재(승 3)<br>미생물을 기탁한 경우에는 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 그 국내기탁기관, 국제기탁기관, 지정기탁기관에서 부여받은 수탁번호를 적어야 한다(승 3).<br>4. 기탁절차가 부적법한 경우의 취급:<br>① 미생물 기탁 관련 절차가 절차보정사유(法 46)에 해당하고, 무효로 할 수 있음<br>② 출원은 발명의 성립성이 없기 때문에 법 제29조제1항 본문 또는 법 제42조제3항제1호 위반을 이유로 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法 133①)에 해당함 |
|         |              | 쉽게 입수 가능한 경우      | 미생물이 통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 있는 것일 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있으며, 이 경우 명세서에 그 미생물의 입수방법을 적어야 한다(승 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | 미생물분양 및 이용금지 |                   | 1. 미생물의 분양<br>기탁된 미생물에 관계되는 발명을 시험 또는 연구를 위하여 실시하려는 자는 i) 그 미생물에 관계되는 발명에 대한 특허출원이 공개되거나 설정등록된 경우 및 ii) 거절이유통지(法 63)에 따른 의견서를 작성하기 위하여 필요한 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우 국내기탁기관, 국제기탁기관, 지정기탁기관으로부터 그 미생물을 분양받을 수 있다(승 4① I). 또한, 미생물을 기탁한 자로부터 미생물 분양에 대한 허락을 받은 자도 국내기탁기관, 국제기탁기관, 지정기탁기관에 신청하여 해당 미생물을 분양받을 수 있다(승 4②).<br>2. 제3자의 이용금지(승 4③)<br>미생물을 분양받은 자는 그 미생물을 타인에게 이용하게 해서는 안된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 특허권의 효력 | 효력           |                   | 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 정당한 권원 없는 제3자가 업으로서 특허발명을 실시하는 경우 침해를 이유로 특허권자는 민·형사상 제재조치를 취할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 효력의 확장       |                   | 미생물 발명이 의약품, 농약 또는 농약원제의 발명으로서 허가 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 장기간 실시할 수 없는 경우에는 5년의 기간까지 그 미생물 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다(法 89).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Ⅳ 용도발명

| 발 명            |         | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서              | 의의      | 새로운 속성을 발견하고 새로운 용도로 이용하는 과정에서 창작적 요소가 존재하는 발명을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | 취지      | 발명의 성립성이 문제 → 발견이지만 창작적 요소의 보호가치 인정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 특허<br>요건<br>등  | 성립성     | 1. 발견과의 구별<br>발견이란 기존에 존재하는 것을 단순히 찾아내는 것이나, 특허법상 발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작인 점에서 양자는 구별된다.<br>2. 용도발명의 성립성<br>① 새로운 속성의 발견에 상당한 정도의 노력과 수고가 요구되며, 새로운 속성의 발견과 새로운 용도로의 이용과정에서는 창작적 요소가 존재하여야 함. 창작적 요소가 존재하지 아니한 경우에는 단순한 발견에 불과하며, 새로운 용도로 이용할 수 없는 경우에는 구체성을 결여한 미완성발명이 됨.<br>② 그 용도가 당시까지 알려지지 않았던 새로운 것이면 충분하고, 그 물질이나 그 물질의 다른 용도가 출원 이전에 공지되어 있어야 하는 것은 아님(2012허2166). |
|                | 명세서 기재  | 1. 명세서 기재요령<br>① 용도발명은 별개의 독립된 카테고리가 아니므로 물건발명 또는 방법발명으로 특정가능<br>② 청구항에 용도를 한정하는 기재가 포함된 경우 발명의 설명 및 도면의 기재와 해당 기술분야의 출원 시의 기술상식을 참작하여 그 용도로 사용되는데 특별히 적합한 물건만을 의미하는 경우에는 신규성 등의 특허요건을 판단할 때 그 용도를 포함하여 발명을 이해하고, 그렇지 아니한 경우에는 그 용도를 배제하고 발명을 이해<br>2. 하나의 특허출원의 범위 만족(法 45)<br>물건발명과 그 물건의 용도발명은 단일성이 있기 때문에 하나의 특허출원으로 할 수 있다.                                            |
|                | 이익제도 활용 | 물건발명의 출원 후에 용도발명을 한 경우에는 조약우선권주장출원(法 54)이나 국내우선권주장출원(法 55)을 통해 보호받을 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 특허<br>권의<br>효력 | 효력      | 1. 특허권자는 업으로서 용도발명을 실시할 권리를 독점하며(法 94①), 정당한 권원 없는 제3자가 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 경우에는 침해를 이유로 민·형사상 구제조치를 취할 수 있다.<br>2. 한편, 용도발명은 물건발명을 그대로 이용한 것이므로 선출원되어 특허된 물건발명과 이용관계에 있다. 이 경우 용도발명의 특허권자는 물건발명의 특허권자의 동의를 받거나(法 98), 통상실시권 허락심판(法 138)에 의하는 등 정당한 권원을 획득하지 아니하고는 용도발명을 실시할 수 없다.                                                                                           |
|                | 효력의 확장  | 1. 용도발명의 실시를 위하여 타법의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간에서 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다(法 89).<br>2. 연장등록된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건에 대하여 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다(法 95).                                              |



V 의약발명

| 발 명            |                 | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서              |                 | 사람의 질병을 진단·치료·처리·예방을 하는 물질인 의약의 발명 이외에 둘 이상의 의약을 혼합하여 하나의 의약을 조제하는 방법의 발명까지 포함한 개념이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 특허<br>요건<br>등  | 성립성             | 의약발명 중 물질발명의 대부분은 천연물질에서 인체의 치료에 필요한 특정 성분을 발견하고 추출하여 의약으로 이용하는바, 용도발명의 일종이라 할 수 있다. 이처럼 특정 성분을 발견하고, 의약으로 이용함에 있어서, 무수한 노력, 실험 및 투자 등의 요소가 있어야 하므로 발견임에도 불구하고 발명의 성립성을 인정하고 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | 발명의<br>설명<br>기재 | 약리기전이 명확히 밝혀지지 아니한 이상 일정한 확실성 및 반복가능성이 미약하여 목적달성이 현저히 의심스럽기 때문에 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 발명의 설명의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(2015후727).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | 청구범위<br>기재      | 1. 의약용도발명의 구성요소는 물질과 용도: 의약용도발명에 있어서는 특정 물질이 가지고 있는 의약용도가 발명의 구성에 해당하므로 청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하는 것이 원칙이나, 특정 물질의 의약용도가 약리기전만으로 기재되어 있다 하더라도 명세서 등 발명의 설명의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 제 42조제4항제2호가 정한 청구항의 명확성 요건을 충족하는 것으로 볼 수 있다.<br>2. 의약용도발명의 구성요소가 물질, 약리기전 및 용도로 기재된 경우: 의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이고, 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하다. 따라서 의약용도발명의 청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다. 구체적인 사례로는 물질과 용도로 기재된 청구항에 약리기전을 추가하는 정정을 하는 것은 내적합성이 아니라 용도를 중복적으로 기재하는 것에 불과하여 청구범위의 감축이 아니기 때문에 허용되지 않는다는 사례(2012후3664), 물질, 약리기전 및 용도로 기재된 청구항은 물질과 용도의 구성요소를 가지는 발명으로 이해하여야 한다는 사례(2012후238)가 있다.<br>3. 투여용법과 투여용량을 구성요소로 볼 수 있는지 여부: 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고 보아야 하고, 이와 같은 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다(2014후768). |
|                | 진보성             | 1. 투여용법과 투여용량을 부가한 의약발명의 진보성이 인정되기 위해서는 특정한 투여용법이나 투여용량으로 인하여 나타난 유리한 효과가 통상의 기술자의 기술수준에서 예측되는 범위를 넘는 현저한 경우이거나 또는 통상의 기술자가 당해 의약발명의 약리효과가 온전히 유지되면서 독성이나 부작용이 최소화되는 특정한 투여용법이나 투여용량을 선행발명 또는 공지의 발명으로부터 예측할 수 없었던 경우이어야 한다.<br>2. 의약용도발명에서는 통상의 기술자가 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 그 진보성이 부정되고, 선행발명들에 임상시험 등에 의한 치료효과 확인이 요구되는 것은 아니다.<br>3. 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이다. 결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다(2018후10923).                                                                                              |
|                | 기타<br>특허요건      | 인체를 직접적인 구성요소로 하지 아니하여야만 산업상 이용가능성(法 29①본문)이 인정되고, 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하지 아니하여야만 공서양속에 위반되거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명(法 32)에 해당하지 않는다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 특허<br>권의<br>효력 | 효력              | 1. 특허권자는 업으로서 용도발명을 실시할 권리를 독점하며(法 94①), 정당한 권원 없는 제3자가 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 업으로서 실시할 경우에는 침해를 이유로 민·형사상 제재조치를 취할 수 있다.<br>2. 다만, 「약사법」에 따른 의약품의 품목허가·품목신고를 위한 연구 또는 시험의 경우에는 특허권의 효력이 미치지 아니하고(法 96① I), 둘 이상의 의약(사람의 질병의 진단·경감·치료·처리(處置) 또는 예방을 위하여 사용되는 물건을 말한다. 이하 같다)이 혼합되어 제조되는 의약의 발명 또는 둘 이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 「약사법」에 따른 조제행위와 그 조제에 의한 의약에는 미치지 아니한다(法 96②).<br>3. 또한, 특허발명을 실시하려는 자는 수입국에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의의 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 지식재산처장에게 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구할 수 있다(法 107).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | 효력의<br>확장       | 실시를 위하여 타법의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간에서 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다(法 89). 연장등록된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건에 대하여 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다(法 95).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

참고자료 1.2 발명의 분류

I 분 류

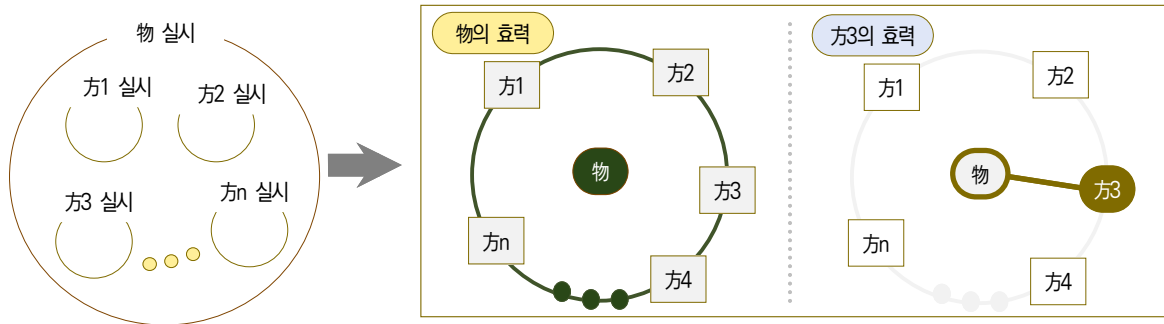
| 종 류  | 구별기준                                                                                                                                                 | 구별실의                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 물건발명 | 1. 기술적 사상의 창작이 물건 자체에 구체화된 발명<br>2. 물건발명은 화학물질, 음식물, 조성물과 같은 물품성이 없는 물질발명과 기계, 장치 등과 같은 물품성이 있는 협의의 물건발명으로 구별됨.                                      | 1. 물건발명이 신규성, 진보성○ → 제법발명은 신규성, 진보성 있음 / 물건발명이 신규성, 진보성 × → 신규성, 진보성 개별적 판단<br>2. 실시의 유형(法 2Ⅲ)이 다르기 때문에 특허권의 효력 범위에 차이가 있음 → 물건발명의 특허권의 효력이 방법발명의 특허권의 효력보다 강함.                                                                                                           |
| 방법발명 | 1. 일정한 목적을 향한 관련성이 있는 복수 개의 행위 또는 현상이 시계열적으로 구체화된 발명<br>2. 방법발명은 측정방법, 도장방법, 제어방법 등과 같은 단순방법발명과 물건을 생산하는 방법발명으로 구별됨.                                 | 3. 협의의 물건발명은 도면을 반드시 첨부해야 하나, 나머지 발명은 첨부 여부가 재량.<br>4. 협의의 물건발명만 실용신안등록출원 가능함.                                                                                                                                                                                            |
| 독립발명 | 다른 발명을 실시할 필요가 없이 자신의 발명을 실시할 수 있는 발명                                                                                                                | 중속발명에 대한 특허권자는 독립발명에 대한 특허권자와는 달리 선행발명에 대한 특허권의 침해가 되지 않으려면 원칙적으로 선행발명에 대한 특허권자의 허락을 받거나(法 98), 통상실시권허락심판(法 138)을 청구하여 정당한 권원을 획득하여야 한다.                                                                                                                                  |
| 중속발명 | 1. 다른 발명을 실시하지 않으면 자신의 발명을 실시할 수 없는 발명<br>2. 중속발명에는 발명의 범주가 다른 경우(물건발명 vs. 제법발명)와 발명의 범주가 같은 경우가 있고, 발명의 범주가 같은 경우는 외적으로 부가한 결합발명과 내적으로 부가한 선택발명이 있음 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 기본발명 | 그 발명이 속하는 분야에서 기술문제를 최초로 해결한 발명                                                                                                                      | 기본발명은 공지기술로부터 개량진보의 수준이 높아 발명적 기여력이 크기 때문에 개량발명에 비하여 보호범위를 넓게 인정.                                                                                                                                                                                                         |
| 개량발명 | 기본발명 또는 선행발명에서의 기술적 결핍에 대한 해결수단을 안출                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 대발명  | 특허법상 보호대상인 발명                                                                                                                                        | 대발명은 특허출원, 실용신안등록출원 중 택일할 수 있으나, 소발명의 경우에는 실용신안등록출원을 하여야 함. 다만, 기술적 사상의 창작이 고도성이 있는지 여부는 극히 주관적인 문제.                                                                                                                                                                      |
| 소발명  | 실용신안법상 보호대상인 고안                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 직무발명 | 종업원·법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(發振法 2①)                          | 자유발명에 대해서는 종업원이 모든 권리를 다 가질 수 있으나, 직무발명에 대해서는 종업원에서 원시적으로 특허를 받을 수 있는 권리를 인정하되, 사용자에게는 법정 실시권과 예약승계할 수 있는 권리를 인정.                                                                                                                                                         |
| 자유발명 | 직무발명 이외의 발명                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 단독발명 | 발명의 완성자가 1인인 경우를 말함                                                                                                                                  | 공동발명을 하면 특허를 받을 수 있는 권리가 공유이며(法 33②), 공동출원하여야 한다(法 44). 또한, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있고(法 37③), 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있으며, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다(法 99②④). |
| 공동발명 | 2인 이상의 자연인이 실질적으로 협력하여 완성한 발명을 말함                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## II 물건발명과 방법발명의 비교

| 발 명            |             | 물건발명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 방법발명                                               |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 서              | 의의          | 기술적 사상의 창작이 물건이나 물질 자체에 구체화된 발명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 일정한 목적을 향한 관련성이 있는 복수 개의 행위 또는 현상이 시계열적으로 구체화된 발명. |
|                | 종류          | 1. 협의의 물건발명 - 기계, 기구, 장치<br>2. 물질발명 - 화학물질                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 제법발명<br>2. 통상의 방법발명 - 통신방법, 측정방법, 제어방법          |
| 특허<br>요건<br>등  | 신규성/<br>진보성 | 1. 물건발명이 신규성, 진보성 ○ → 제법발명, 용도발명은 당연히 신규성, 진보성 ○<br>2. 물건발명이 신규성, 진보성 × → 제법발명, 용도발명은 개별적으로 판단                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
|                | 명세서<br>기재   | 1. 협의의 물건발명의 경우 반드시 도면 첨부<br>2. 도면의 간단한 설명은 도면을 첨부한 경우에 한해 기재하면 됨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
|                | 이익제도<br>활용  | 변경출원제도의 이용 - 협의의 물건발명은 변경출원가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 특허<br>권의<br>효력 | 효력          | 1. 효력 - 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(法 94①). 따라서, 정당한 권원 없는 제3자가 업으로서 특허발명을 실시하는 경우 침해를 이유로 특허권자는 민·형사상 조치를 취할 수 있다.<br>2. 실시의 개념<br>① 물건발명의 경우 그 물건을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다(法 2Ⅲ가).<br>② 단순한 방법발명의 경우 그 발명을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 말한다(法 2Ⅲ나).<br>③ 물건을 생산하는 방법발명의 경우 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산된 물건을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다(法 2Ⅲ다).<br>3. 효력범위 - 물건발명 > 방법발명 |                                                    |
|                | 효력의 제한      | 1. 제한 - 국내를 통과하는 데 불과한 선박, 항공기, 차량 또는 이에 사용되는 기계, 기구, 장치 기타의 물건(法 96①Ⅱ), 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건(法 96①Ⅲ)의 경우는 물건발명에만 적용<br>2. 이용관계<br>① 태양 - 동일 카테고리내의 방법발명간 또는 물건발명간에는 사상상의 이용관계가 성립하고, 다른 카테고리의 물건발명과 방법발명간에는 실시상의 이용관계가 성립한다.<br>② 동의 또는 허락 - 이용관계가 성립하는 경우 선출원 특허권자의 허락을 받거나(法 98) 통상 실시 권허락심판(法 138)에 의하는 등 정당한 권원을 획득하지 아니하고는 이를 실시할 수 없다.                                                                                                              |                                                    |
|                | 효력의 확장      | 1. 생산방법의 추정<br>물건을 생산하는 방법의 특허출원 전에 그 물건이 i) 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건, ii) 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 물건이 된 경우가 아니라면 물건을 생산하는 방법에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다(法 129).<br>2. 간접침해<br>① 물건발명의 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다(法 127Ⅰ).<br>② 방법발명의 경우 그 방법에 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다(法 127Ⅱ).                  |                                                    |



### III 물건발명과 그 물건을 제조하는 방법발명의 관계



1. 양자의 관계 → 物 : 方 = 1 : 多

2. 특허요건

- (1) 物이 신규성, 진보성○ → 方도 신규성, 진보성○
- (2) 物이 신규성, 진보성× → 方은 신규성, 진보성△

3. 병존가능성 및 등록 후 법률관계

| 선출원여부  | 후출원의 등록가능성                                                                                                                                                                                                                 | 후출원의 실시가 선출원의 침해인지 여부                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 物 > 方1 | 1. 物의 최초 명세서 또는 도면(최·명·도)에 기재된 方이 方1인 경우<br>① 物의 공개 전 출원 → 제29조제3항 위반<br>② 物의 공개 후 출원 → 제29조제1항 위반<br>2. 物의 최·명·도에 기재된 方이 方1이 아닌 경우<br>① 物의 공개 전 출원 → 등록가능<br>② 物의 공개 후 출원 → 物의 최·명·도에 기재된 方으로부터 쉽게 발명할 수 있는 경우 제29조제2항 위반 | 1. 方1의 실시는 物의 침해 ○(∵ 法 제2조제3호(가) 목의 실시의 유형-물건생산을 청약하는 행위는 제외)<br>2. 정당한 권원획득 후 실시<br>① 허락<br>② 통상실시권허락심판(乙이 등록된 경우)                        |
| 物 < 方1 | 1. 方1의 공개 전 출원 → 제29조제3항, 제36조 위반<br>2. 方1의 공개 후 출원 → 제29조제1항, 제36조 위반                                                                                                                                                     | 1. 物의 실시가 方1의 실시에 의한 경우 - 方1의 침해 ○<br>2. 物의 실시가 方1의 실시가 아닌 경우<br>① 方1의 침해 ×<br>② 단, 方1의 출원 전 物이 공지되지 않았다면 方1의 실시에 의하여 物을 생산한 것으로 추정(法 129) |
| 物 = 方1 | 실질적 동일성이 없는 경우 양자 모두 등록가능                                                                                                                                                                                                  | 양자 모두 등록된 경우 자유롭게 실시(∵ 제98조의 “특허출원일 전”의 해석결과 동일자 출원의 부적용)                                                                                  |



## 행위능력(法 3~5①)

### I 법조문

#### 제3조 【미성년자 등의 행위능력】

- ① **(행위제한능력의 행위능력)** 미성년자·피한정후견인 또는 피성년후견인은 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 출원·청구, 그 밖의 절차(이하 "특허에 관한 절차"라 한다)를 밟을 수 없다. 다만, 미성년자와 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다. **法 46**
- ② **(법정대리인의 대리권의 범위)** 제1항의 법정대리인은 후견감독인의 동의 없이 제132조의2에 따른 특허취소신청(이하 "특허취소신청"이라 한다)이나 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차를 밟을 수 있다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제4조 【법인이 아닌 사단 등】 (★)

법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 출원심사의 청구인, 특허취소신청인, 심판의 청구인·피청구인 또는 재심의 청구인·피청구인이 될 수 있다.

<개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제5조 【재외자의 특허관리인】

- ① **(재외자의 행위능력)** 국내에 주소 또는 영업소가 없는 자(이하 "재외자"라 한다)는 재외자(법인의 경우에는 그 대표자)가 국내에 체류하는 경우를 제외하고는 그 재외자의 특허에 관한 대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자(이하 "특허관리인"이라 한다)에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 대하여 소(訴)를 제기할 수 있다. **法 206**
- ② **(특허관리인의 대리권의 범위)** 특허관리인은 위임된 권한의 범위에서 특허에 관한 모든 절차 및 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 관한 소송에서 본인을 대리한다.

[전문개정 2014.6.11.]

## II 권리능력과 행위능력의 구별

| 구 분               |     | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 권리능력              | 내국인 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자연인과 법인에 대하여 권리능력 인정 (재내외자 불문)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | 외국인 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 재내자 - 권리능력 인정(法 25본문의 반대해석)</li> <li>■ 재외자               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 원칙 - 권리능력 불인정</li> <li>2. 예외 - 권리능력 인정(상호주의(法 25 I, II), 조약에 의한 경우(法 25III))</li> </ol> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 행위능력<br>(내외국인 불문) | 재내자 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 원칙 - 행위능력 인정</li> <li>■ 문제되는 경우               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제한능력자(法 3①) → 행위능력 불인정(∴제한능력자의 보호)                   <ol style="list-style-type: none"> <li>① 법정대리인의 의한 절차(法 3②)</li> <li>② 위반시 취급                       <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원칙 → 보정명령(法 46) 후 절차의 무효(法 16①본문)</li> <li>- 예외 → 추인의 소급효(法 7의2)</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2. 비법인 사단·재단                   <p>대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우 그 사단·재단의 이름으로 심사청구인, 특허취소신청인, 심판청구인·피청구인, 재심청구인·피청구인이 될 수 있음(法 4)</p> </li> </ol> </li> </ul> |
|                   | 재외자 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 원칙 - 행위능력 불인정(法 5①)(∴절차의 원활한 진행) → 특허관리인에 의한 절차 수행(法 5②)</li> <li>■ 예외               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 국내에 체류하는 경우(法 5①본문)</li> <li>2. 국제특허출원의 기준일 전까지(法 206①)</li> </ol> </li> <li>■ 위반시 취급 → 불수리</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## 대리인(法 3②, 5②~10, 12)

### I 법조문

#### 제3조 【미성년자 등의 행위능력】

- ① **(행위제한능력의 행위능력)** 미성년자·피한정후견인 또는 피성년후견인은 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 출원·청구, 그 밖의 절차(이하 "특허에 관한 절차"라 한다)를 밟을 수 없다. 다만, 미성년자와 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다. **法 46**
- ② **(법정대리인의 대리권의 범위)** 제1항의 법정대리인은 후견감독인의 동의 없이 제132조의2에 따른 특허취소신청(이하 "특허취소신청"이라 한다)이나 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차를 밟을 수 있다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제5조 【재외자의 특허관리인】

- ① **(재외자의 행위능력)** 국내에 주소 또는 영업소가 없는 자(이하 "재외자"라 한다)는 재외자(법인의 경우에는 그 대표자)가 국내에 체류하는 경우를 제외하고는 그 재외자의 특허에 관한 대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자(이하 "특허관리인"이라 한다)에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 대하여 소(訴)를 제기할 수 있다. **法 206**
- ② **(특허관리인의 대리권의 범위)** 특허관리인은 위임된 권한의 범위에서 특허에 관한 모든 절차 및 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 관한 소송에서 본인을 대리한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제6조 【대리권의 범위】(★) **法 46**

국내에 주소 또는 영업소가 있는 자로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인은 특별히 권한을 위임받아야만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다. 특허관리인의 경우에도 또한 같다. <개정 2016.2.29.>

1. 특허출원의 변경·포기·취하
2. 특허권의 포기
3. 특허권 존속기간의 연장등록출원의 취하
4. 신청의 취하
5. 청구의 취하
6. 제55조제1항[국내우선권주장]에 따른 우선권 주장 또는 그 취하
7. 제132조의17[거절결정불복심판청구]에 따른 심판청구
8. 복대리인의 선임

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제7조 【대리권의 증명】

특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인(특허관리인을 포함한다. 이하 같다)의 대리권은 서면으로써 증명하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제7조의2 【행위능력 등의 흠에 대한 추인】 **法 3①**

행위능력 또는 법정대리권이 없거나 특허에 관한 절차를 밟는 데 필요한 권한의 위임에 흠이 있는 자가 밟은 절차는 보정(補正)된 당사자나 법정대리인이 추인하면 행위를 한 때로 소급하여 그 효력이 발생한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제8조 【대리권의 불소멸】(★) **法 20단**

특허에 관한 절차를 밟는 자의 위임을 받은 대리인의 대리권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있어도 소멸하지 아니한다.

1. 본인의 사망이나 행위능력의 상실
2. 본인인 법인의 합병에 의한 소멸

3. 본인인 수탁자(受託者)의 신탁업무 종료
4. 법정대리인의 사망이나 행위능력의 상실
5. 법정대리인의 대리권 소멸이나 변경

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제9조 【개별대리】

특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 2인 이상이면 지식재산처장 또는 특허심판원장에 대하여 각각의 대리인이 본인을 대리한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제10조 【대리인의 선임 또는 교체 명령 등】

- ① **(선임명령)** 지식재산처장 또는 제145조제1항에 따라 지정된 심판장(이하 "심판장"이라 한다)은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리(口述審理)에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는 데 적당하지 아니하다고 인정되면 대리인을 선임하여 그 절차를 밟을 것을 명할 수 있다.
- ② **(교체명령)** 지식재산처장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는 데 적당하지 아니하다고 인정되면 그 대리인을 바꿀 것을 명할 수 있다. <개정 2019. 12. 10.>
- ③ **(변리사 대리)** 지식재산처장 또는 심판장은 제1항 및 제2항의 경우에 변리사로 하여금 대리하게 할 것을 명할 수 있다.
- ④ **(선임·교체명령 후 선임·교체 전 밟은 절차의 효력)** 지식재산처장 또는 심판장은 제1항 또는 제2항에 따라 대리인의 선임 또는 교체 명령을 한 경우에는 제1항에 따른 특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 제2항에 따른 대리인이 그 전에 지식재산처장 또는 특허심판원장에 대하여 한 특허에 관한 절차의 전부 또는 일부를 무효로 할 수 있다. <개정 2019.12.10>

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제12조 【「민사소송법」의 준용】

대리인에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「민사소송법」 제1편제2장제4절을 준용한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 민사소송법 제1편제2장제4절

##### 제4절 소송대리인

##### 제87조(소송대리인의 자격)

법률에 따라 재판상 행위를 할 수 있는 대리인 외에는 변호사가 아니면 소송대리인이 될 수 없다.

##### 제88조(소송대리인의 자격의 예외)

- ① 단독판사가 심리·재판하는 사건 가운데 그 소송목적의 값이 일정한 금액 이하인 사건에서, 당사자와 밀접한 생활관계를 맺고 있고 일정한 범위안의 친족관계에 있는 사람 또는 당사자와 고용계약 등으로 그 사건에 관한 통상사무를 처리·보조하여 오는 등 일정한 관계에 있는 사람이 법원의 허가를 받은 때에는 제87조를 적용하지 아니한다.
- ② 제1항의 규정에 따라 법원의 허가를 받을 수 있는 사건의 범위, 대리인의 자격 등에 관한 구체적인 사항은 대법원규칙으로 정한다.
- ③ 법원은 언제든지 제1항의 허가를 취소할 수 있다.

##### 제89조(소송대리권의 증명)

- ① 소송대리인의 권한은 서면으로 증명하여야 한다.
- ② 제1항의 서면이 사문서인 경우에는 법원은 공증인, 그 밖의 공증업무를 보는 사람(이하 "공증사무소"라 한다)의 인증을 받도록 소송대리인에게 명할 수 있다.
- ③ 당사자가 말로 소송대리인을 선임하고, 법원사무관등이 조서에 그 진술을 적어 놓은 경우에는 제1항 및 제2항의 규정을 적용하지 아니한다.

##### 제90조(소송대리권의 범위)

- ① 소송대리인은 위임을 받은 사건에 대하여 반소(反訴)·참가·강제집행·가압류·가처분에 관한 소송행위 등 일체의 소송행위와 변제(辨濟)의 영수를 할 수 있다.
- ② 소송대리인은 다음 각호의 사항에 대하여는 특별한 권한을 따로 받아야 한다.
  1. 반소의 제기
  2. 소의 취하, 화해, 청구의 포기·인낙 또는 제80조의 규정에 따른 탈퇴
  3. 상소의 제기 또는 취하
  4. 대리인의 선임

##### 제91조(소송대리권의 제한)

소송대리권은 제한하지 못한다. 다만, 변호사가 아닌 소송대리인에 대하여는 그러하지 아니하다.

##### 제92조(법률에 의한 소송대리인의 권한)

법률에 의하여 재판상 행위를 할 수 있는 대리인의 권한에는 제90조와 제91조의 규정을 적용하지 아니한다.

**제93조(개별대리의 원칙)**

- ① 여러 소송대리인이 있는 때에는 각자가 당사자를 대리한다.
- ② 당사자가 제1항의 규정에 어긋나는 약정을 한 경우 그 약정은 효력을 가지지 못한다.

**제94조(당사자의 경정권)**

소송대리인의 사실상 진술은 당사자가 이를 곧 취소하거나 경정(更正)한 때에는 그 효력을 잃는다.

**제95조(소송대리권이 소멸되지 아니하는 경우)**

다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하더라도 소송대리권은 소멸되지 아니한다.

- 1. 당사자의 사망 또는 소송능력의 상실
- 2. 당사자인 법인의 합병에 의한 소멸
- 3. 당사자인 수탁자(受託者)의 신탁임무의 종료
- 4. 법정대리인의 사망, 소송능력의 상실 또는 대리권의 소멸·변경

**제96조(소송대리권이 소멸되지 아니하는 경우)**

- ① 일정한 자격에 의하여 자기의 이름으로 남을 위하여 소송당사자가 된 사람에게 소송대리인이 있는 경우에 그 소송대리인의 대리권은 당사자가 자격을 잃더라도 소멸되지 아니한다.
- ② 제53조의 규정에 따라 선정된 당사자가 그 자격을 잃은 경우에는 제1항의 규정을 준용한다.

**제97조(법정대리인에 관한 규정의 준용)**

소송대리인에게는 제58조제2항·제59조·제60조 및 제63조의 규정을 준용한다.

## II 대리인의 종류(法 3② 및 5)

| 구 분   | 내 용                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 법정대리인 | 1. 종류 - 친권자와 후견인<br>2. 구별기준 - 무능력자의 부모인지 여부<br>① 부모 ○ → 친권자<br>② 부모 × → 후견인<br>3. 구별실익 - 후견감독인의 동의 유무<br>① 친권자 - 후견감독인의 동의없이 절차가능<br>② 후견인 - 능동적인 절차는 후견감독인의 동의가 있어야만 가능(法 3②)                |
| 임의대리인 | 1. 종류 - 통상의 위임대리인과 특허관리인<br>2. 구별기준 - 대리인 선임의 주체<br>① 재내자의 임의대리인 → 통상의 위임대리인<br>② 재외자의 임의대리인 → 특허관리인<br>3. 구별실익<br>재외자의 재판관할(法 13), 재외자의 특허관리인의 특례(法 206), 재외자에 대한 송달(法 220)의 측면에서 구별의 실익이 있음 |
| 구별기준  | 선임행위가 의사에 기한 것인지 법률의 규정에 의한 것인지 여부<br>1. 의사 → 임의대리인<br>2. 법률 → 법정대리인                                                                                                                          |
| 구별실익  | 대리권의 범위에서 구별 실익이 있음<br>1. 법정대리인 - 법률의 규정에 의하여 정해지며 특허에 관한 절차 이외의 권리의 처분권(각종 심판청구, 민·형사소송, 각종 실시권 설정 등)까지 대리권 인정<br>2. 임의대리인 - 수권행위에 의하여 위임을 받은 특허에 관한 절차(심결취소소송 포함)에 대리권 인정                   |

### III 대리권의 내용(法 6~10, 12)

| 구 분   |                                                                                                                                                                                                                                  | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서     | 의의                                                                                                                                                                                                                               | 대리인이란 특허에 관한 제반절차를 본인을 대신하여 밝은 자를 말하며 대리인이 밝은 절차의 법률적 효과는 본인에게 귀속된다.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 취지                                                                                                                                                                                                                               | 1. 사적 자치의 보충 - 법정대리인<br>2. 사적 자치의 확장 - 임의대리인                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 내용    | 범위                                                                                                                                                                                                                               | 임의대리인은 특별히 권한을 위임받아야만 i) 특허출원의 변경·포기·취하, ii) 존속기간연장등록출원의 취하, iii) 신청의 취하, iv) 청구의 취하, v) 국내우선권주장이나 취하, vi) 거절결정불복심판의 청구, vii) 복대리인의 선임, viii) 특허권의 포기 중 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다(法 6).                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 증명                                                                                                                                                                                                                               | 1. 특허에 관한 절차를 밝는 자의 대리인(특허관리인을 포함한다)의 대리권은 서면으로써 증명(法 7)<br>2. i) 둘 이상의 절차를 동시에 밝는 경우나 이미 위임장을 제출한 자가 다시 위임장을 제출하여야 할 때는 이미 제출된 위임장의 사본을 제출하거나 해당 서식의 첨부서류란에 그 취지를 기재함으로써 위임장에 갈음할 수 있으며(施規 10①②), ii) 대리인선임신고에 의하여 선임된 대리인이 그 위임사항의 범위에서 특허에 관한 절차를 밝는 경우나 포괄위임등록을 한 대리인이 그 포괄위임의 범위에서 특허에 관한 절차를 밝을 때는 위임장의 제출을 생략 가능(施規 10③) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                  | 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                  | 의 의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 포괄위임제도란 특허에 관한 절차를 대리인에 의하여 밝는 경우에 있어서 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 포괄적으로 위임을 하도록 하여, 일단 지식재산처에 포괄위임등록을 하면 그 등록된 범위에서는 개개의 절차마다 위임장을 제출할 필요 없이 특허에 관한 절차를 대리할 수 있도록 하는 제도(施規 5의2)                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                  | 포괄위임등록대상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 대리인에 의하여 절차를 밝는 경우 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 포괄적으로 가능(심판에 대해서도 포괄위임 가능)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                  | 포괄위임등록신청                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. 포괄위임등록신청서에 포괄위임장을 첨부하여 지식재산처장에게 제출. 이 경우 대리인은 포괄위임을 하려는 자에게 포괄위임에 대하여 설명하고 포괄위임장에 포괄위임을 하려는 자의 서명 또는 날인을 받아야 함(포괄위임을 하거나 포괄위임등록사항을 변경하려는 자가 포괄위임장을 온라인 제출하거나 전자적 기록매체에 수록하여 제출하는 경우에는 지식재산처에서 제공하는 소프트웨어나 지식재산처 홈페이지를 이용하여 그 포괄위임장에 전자서명을 하여 전자문서로 제출하거나, 휴대전화로 전송되는 인증번호를 입력하고 출원인이 서명 또는 날인한 포괄위임장의 전자적 이미지를 첨부하여 제출)<br>2. 지식재산처장은 포괄위임등록번호를 부여하고 이를 신청인에게 통지 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                  | 포괄위임의 효과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 포괄위임등록을 한 대리인이 절차를 대리하는 경우 포괄위임 등록번호를 기재하면 위임장 제출의 생략이 가능(施規 10③)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                  | 포괄위임의 원용 제한                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 포괄위임을 한 자가 특정한 사건에 대하여 포괄위임의 원용을 제한하려는 경우에는 그 신고서를 지식재산처장에게 제출(施規 5의3)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 포괄위임의 철회                                                                                                                                                                                                                         | 포괄위임을 한 자가 포괄위임을 철회하려는 경우에는 포괄위임등록철회서를 지식재산처장에게 제출(施規 5의4)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 불소멸                                                                                                                                                                                                                              | 1. 본인 - 사망, 행위능력상실, 합병, 수탁자의 신탁업무종료<br>2. 법정대리인 - 사망, 행위능력상실, 대리권의 소멸, 변경에 의하여 임의대리권 불소멸(法 8)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 개별대리  | 특허에 관한 절차를 밝는 자의 대리인이 2명 이상이면 지식재산처장 또는 특허심판원장에 대하여 각각의 대리인이 본인을 대리(法 9), 강행규정이므로 공동대리의 특약을 하더라도 대외적으로는 효력이 없음.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 선임·교체 | 1. 선임·교체명령<br>① 지식재산처장·심판장, 행위능력·진술능력이 없는 경우, 선임·교체 명령(法 10①②)(변리사라 하더라도 건강상의 이유 등으로 실질적으로 특허에 관한 절차를 원활히 수행할 수 없을 때 교체 가능)<br>② 선임·교체시 변리사 대리 가능(法 10③)<br>2. 절차의 무효<br>지식재산처장·심판장, 선임·교체 명령 후 선임·교체 전 밝은 절차, 무효로 할 수 있다(法 10④) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 준용    | 대리인에 관하여 특별히 규정이 있는 것을 제외하고는 민사소송법을 준용(法 12)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |





## 복수당사자의 대표(法 11)

### I 법조문

#### 제11조 【복수당사자의 대표】 (★) 法 20Ⅵ

- ① **(대표자가 없는 경우)** 2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 제외하고는 각자가 모두를 대표한다. **(대표자가 있는 경우)** 다만, 대표자를 선정하여 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 신고하면 그 대표자만이 모두를 대표할 수 있다.

〈개정 2016.2.29〉

1. 특허출원의 변경·포기·취하
2. 특허권 존속기간의 연장등록출원의 취하
3. 신청의 취하
4. 청구의 취하
5. 제55조제1항[국내우선권주장]에 따른 우선권 주장 또는 그 취하
6. 제132조의17[가결결정불복심판청구]에 따른 심판청구

- ② **(대표자 증명)** 제1항 단서에 따라 대표자를 선정하여 신고하는 경우에는 대표자로 선임된 사실을 서면으로 증명하여야 한다.  
[전문개정 2014.6.11.]

## II 복수당사자 대표(法 11)

| 구 분              |      | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 출원 및 심판청구        | 출원   | 1. 특허출원 → 공유자 모두가 공동출원하여야 하며(法 44), 이에 위반시 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法 133①). 다만, 등록 후 법원에 이전청구 가능하고(法 99의2), 이전청구에 기초하여 이전등록이 있으면 특허무효사유에서 제외<br>2. 존속기간연장등록출원 → 공유자 모두가 공동출원하여야 하며(法 90③, 92의3③), 이에 위반시 거절이유(法 91, 92의4), 무효사유(法 134①②) |
|                  | 심판청구 | 1. 특허무효심판(法 133), 특허권의 존속기간 연장등록무효심판(法 134), 정정무효심판(法 137) 또는 권리범위확인심판(法 135)을 청구하는 자가 2인 이상이 있는 때에는 그 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다(法 139①).<br>2. 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(法 139③). 이에 위반시 심결각하.      |
| 출원 및 심판청구 이외의 절차 |      | 1. 대표자를 선정하지 아니한 경우<br>① 원칙 → 각자대표(法 11①본문)<br>② 예외 → 법 제11조 제1항 각호에 해당하는 경우 모두대표(法 11①각호)<br>2. 대표자를 선정한 경우<br>① 원칙 → 대표자대표(法 11①단서)<br>② 문제되는 경우 → 법 제11조 제1항 각호에 해당하는 경우 모두의 동의<br>③ 대표자의 증명(法 11②) → 서면으로 증명                                    |



## 재외자의 재판관할(法 13)

### 제13조 【재외자의 재판관할】 法 220

재외자의 특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 특허관리인이 있으면 그 특허관리인의 주소 또는 영업소를, 특허관리인이 없으면 지식재산처 소재지를 「민사소송법」 제11조에 따른 재산이 있는 곳으로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 민사소송법 제11조

##### 제11조(재산이 있는 곳의 특별재판적)

대한민국에 주소가 없는 사람 또는 주소를 알 수 없는 사람에 대하여 재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 청구의 목적 또는 담보의 목적이나 압류할 수 있는 피고의 재산이 있는 곳의 법원에 제기할 수 있다.

- 재외자는 국내에 주소 또는 영업소가 없기 때문에 이를 해결하기 위한 조치로써 특허관리인의 주소 또는 영업소와 지식재산처 소재지를 재판관할로 인정하고 있다.



## 기일과 기간(法 14, 15)

### I 법조문

#### 제14조 [기간의 계산]

이 법 또는 이 법에 따른 명령에서 정한 기간의 계산은 다음 각 호에 따른다. <개정 2025. 11. 11.>

1. **(초일불산입의 원칙)** 기간의 첫날은 계산에 넣지 아니한다. (예외) 다만, 그 기간이 오전 0시부터 시작하는 경우에는 계산에 넣는다.
2. **(역일주의)** 기간을 월 또는 연(年)으로 정한 경우에는 역(曆)에 따라 계산한다.
3. **(만료일의 계산)** 월 또는 연의 처음부터 기간을 기산(起算)하지 아니하는 경우에는 마지막의 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전날로 기간이 만료한다. 다만, 월 또는 연으로 정한 경우에 마지막 월에 해당하는 날이 없으면 그 월의 마지막 날로 기간이 만료한다.
4. **(만료일이 공휴일인 경우)** 특허에 관한 절차에서 기간의 마지막 날이 공휴일(「노동절 제정에 관한 법률」에 따른 노동절 및 토요일을 포함한다)에 해당하면 기간은 그 다음 날로 만료한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제15조 [기간의 연장 등]

- ① **(법정기간의 연장)** 지식재산처장은 청구에 따라 또는 직권으로 제132조의17(가)절 결정 불복 심판에 따른 심판의 청구기간을 30일 이내에서 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다. <개정 2016.2.29.> **法 186③④⑤ / 67②**
- ② **(지정기간의 연장 또는 단축)** 지식재산처장·특허심판원장·심판장 또는 제57조제1항에 따른 심사관(이하 "심사관"이라 한다)은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 경우에는 청구에 따라 그 기간을 단축 또는 연장하거나 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 지식재산처장 등은 그 절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 아니하도록 단축 또는 연장 여부를 결정하여야 한다.
- ③ **(지정기일의 변경)** 심판장은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기일을 정한 경우에는 청구에 따라 또는 직권으로 그 기일을 변경할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

## II 기간의 계산(法 14)

| 순서       | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 초일의 결정   | 사실관계에서 파악                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 기산일의 결정  | 1. 원칙 : 초일불산입 → 초일의 다음 날 = 기산일<br>2. 예외 : 오전 0시부터 시작하는 경우( 법정·지정기간 등의 연장기간) → 초일 = 기산일<br>3. 초일이 공휴일인 경우 → 공휴일의 다음 날이 아닌 공휴일부터 계산                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 계산방법의 결정 | 1. 日, 週 → 자연적 계산방법(정확 + 불편)<br>2. 月, 年 → 역법적 계산방법(부정확 + 편리)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 만료일의 결정  | 1. 원칙 → 최후의 월 또는 년에서 그 기산일에 해당하는 날의 전날로 기간이 만료<br>2. 마지막 월에 해당일이 없는 경우 → 그 월의 마지막 날로 기간이 만료<br>3. 만료일이 공휴일인 경우<br>① 특허에 관한 절차에서 기간의 마지막 날이 공휴일(「노동절 제정에 관한 법률」에 따른 노동절 및 토요일을 포함한다)에 해당하면 기간은 그 다음 날로 만료<br>② i) 국내우선권 주장에 있어서 선출원의 취하로 보는 때, ii) 출원을 공개하여야 할 때, iii) 공시 송달의 효력이 발생한 때, iv) 특허권의 존속기간이 만료될 때 등의 특허에 관한 절차가 아닌 법정기간이나 지정기간은 마지막 날이 공휴일이라 하더라도 원래의 해당일에 종료한다.<br>③ 「특허에 관한 절차」는 특허에 관한 출원·청구 기타의 절차를 말하는 것으로서, 심결에 대한 소의 제소기간은 포함되지 않음 |

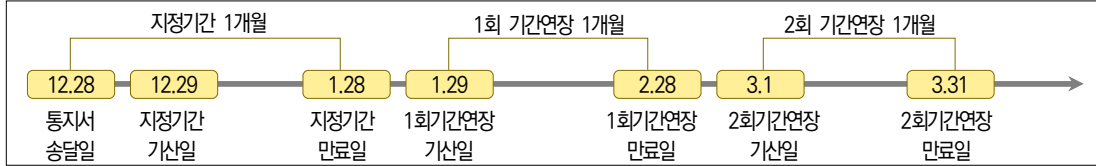
## III 기일과 기간의 종류(法 15)

| 구분 | 내용                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기일 | 지정(가변)기일 → 지정기일의 변경(法 15③)                                                                                                                                                                                                               |
| 기간 | 1. 종류 - 법정기간과 지정기간<br>2. 구별기준 - 법률의 규정에 의한 것인지 지정한 것인지 여부<br>① 법정기간 - 법률 또는 이에 근거한 명령으로 정한 기간<br>② 지정기간 - 지시에 의하여 정한 기간<br>3. 구별실익<br>① 법정기간<br>- 원칙 → 불변기간<br>- 예외 → 가변기간 → 법정기간의 연장(法 15①)<br>② 지정기간<br>- 가변기간 → 지정기간의 연장 또는 단축(法 15②) |

## IV 기간연장·단축 및 기일변경의 비교

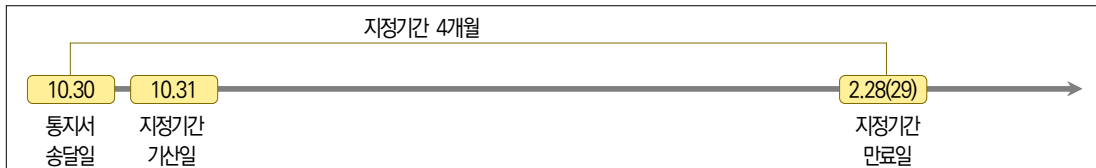
| 구분 | 법정기간의 연장 (法 15①)                                                                             | 지정기간의 연장·단축(法 15②)                                            | 지정기일의 변경(法 15③)       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 성격 | 재량행위                                                                                         |                                                               |                       |
| 요건 | 주체<br>1. 지식재산처장<br>2. 청구 또는 직권                                                               | 1. 지식재산처장, 특허심판원장, 심판장, 심사관<br>2. 단축 - 청구<br>3. 연장 - 청구 또는 직권 | 1. 심판장<br>2. 청구 또는 직권 |
|    | 대상<br>거절결정불복심판의 청구기간 (法 132의17)                                                              | 모든 지정기간                                                       | 모든 지정기일               |
| 효과 | 30일 이내 1회에 한해 기간의 연장 (단, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장가능) | 기간의 단축 또는 연장 (단, 이해관계인의 이익 부당 침해×)                            | 기일의 변경                |

【예1】기간 연장일이 월 또는 년의 첫날부터 기간을 기산하는 경우



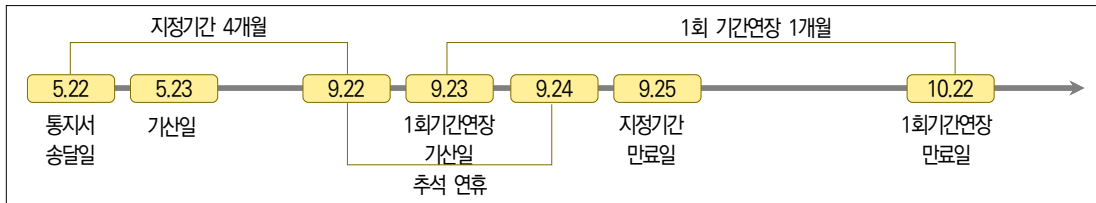
기간을 월 또는 년의 처음부터 기간을 기산하지 아니하는 때에는 마지막 월 또는 년에서 그 기산일에 해당하는 날의 전날로 기간이 만료한다(지정기간 만료일). 또한 기간연장 기산일이 월 또는 년의 첫날부터 기산한 때에는 마지막 월 또는 년의 마지막 날로 기간이 만료한다(2회의 기간연장 만료일).

【예2】최종월에 해당일이 없는 경우



특허법상 기간의 계산에 있어서 첫날은 계산에 넣지 아니한다. 다만, 기간이 오전 0시부터 시작하는 경우에는 계산에 넣는다. 상기 예에서 통지서 발송을 10. 30. 오전 0시에 한 경우에는 기간의 기산일은 10. 30. 이 되고 0시부터 시작하지 아니한 경우에는 기산일은 10. 31. 이 된다. 또한 마지막 월에 해당일이 없는 경우 그 월의 마지막 날로 기간이 만료한다. 즉 상기 예에서 2. 30. 이 없으므로 2월의 마지막 날인 2. 28.(2. 29. 까지 있는 경우에는 2. 29.)로 지정 기간이 만료한다.

【예3】지정기간 만료일이 공휴일인 경우로 기간연장하는 경우



특허에 관한 절차에 있어서 기간의 마지막 날이 공휴일인 경우에는 기간은 그 다음 날로 만료한다. 따라서 상기 예에서 기간연장이 없었다면 기간은 9. 25.로 만료된다. 그러나 기간의 기산일이 공휴일인 경우라도 기간의 기산일은 공휴일부터 시작된다. 따라서 기간연장의 만료일은 10. 22. 이 된다. 또한 상기 예에서 지정기간 만료일이 9. 25. 로 된 경우 9. 25.까지 지정기간 연장 신청을 할 수 있으나 신청이 비록 9. 25. 에 있었다 하더라도 기간연장의 기산일은 9. 23.이 되고 기간연장 만료일은 10. 22.이 된다.



## 특허에 관한 절차 일반(法 16, 28-28의5)

### I 법조문

#### 제16조 【절차의 무효】(★★)

- ① **【절차의 무효】** 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제46조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 제82조제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다.
- ② **【무효처분의 취소】** 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일로부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.>
- ③ **【송달】** 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항 본문·단서에 따른 무효처분 또는 제2항 본문에 따른 무효처분의 취소처분을 할 때에는 그 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제28조 【서류제출의 효력발생시기】

- ① **【원칙: 도달주의】** 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 출원서, 청구서, 그 밖의 서류(물건을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 제출의 효력이 발생한다. <개정 2014.6.11.>
- ② **【예외: 발신주의】** 제1항의 출원서, 청구서, 그 밖의 서류를 우편으로 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 날에 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 도달한 것으로 본다. (예외의 예외: 도달주의) 다만, 특허권 및 특허에 관한 권리의 등록신청서류와 「특허협력조약」 제2조(vii)에 따른 국제출원(이하 "국제출원"이라 한다)에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 그 서류가 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 효력이 발생한다. <개정 2014.6.11.> **法 101, 118, 194**
1. 우편물의 통신일부인(通信日附印)에 표시된 날이 분명한 경우: 표시된 날
2. 우편물의 통신일부인에 표시된 날이 분명하지 아니한 경우: 우체국에 제출한 날을 우편물 수령증에 의하여 증명할 날
- ③ 삭제 <1998.9.23.>
- ④ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 우편물의 지연, 우편물의 망실(亡失) 및 우편업무의 중단으로 인한 서류제출에 필요한 사항은 총리령[시행규칙 제86조, 제87조]으로 정한다. <개정 2014.6.11.>

[제목개정 2014.6.11.]

#### 시행규칙 제86조-제87조

##### 제86조(우편의 지연)

- ① 법령의 규정에 의하여 지식재산처장에게 제출하는 국제출원에 관한 서류로서 제출기간이 정하여져 있는 것을 등기우편에 의하여 제출하는 경우 우편의 지연으로 인하여 당해서류가 제출기간내에 도달되지 아니하는 때에는 출원인은 당해서류를 제출기간의 만료일 5일 이전에 우편으로 발송하였다는 사실을 증명하는 증거를 지식재산처장에게 제출할 수 있다. 다만, 당해서류를 항공우편으로 발송할 수 있고 또한 항공우편외의 방법으로는 도달에 통상 3일 이상 소요되는 것이 명백한 경우 당해서류를 항공우편으로 발송하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항의 규정에 의한 증거의 제출은 출원인이 서류의 도달지연을 알게 된 날 또는 상당한 주의를 하였다면 알 수 있었던 날부터 1월 이내, 당해서류의 제출기간의 만료일로부터 6월 이내에 제출하여야 한다.
- ③ 제1항의 규정에 의하여 제출된 증거에 의하여 당해서류가 제출기간내에 도달되지 아니한 원인이 우편의 지연으로 인한 것이라고 인정되는 경우에는 당해서류는 제출기간내에 제출된 것으로 본다.

[전문개정 1999. 7. 1.]

##### 제87조(우편물의 망실)

제86조의 규정은 국제출원에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우 당해우편물의 망실에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제86조제1항 내지 제3

항중 “증거”는 각각 “증거 또는 망실한 서류를 대신하는 새로운 서류 및 새로운 서류가 망실한 서류와 동일하다는 것을 증명하는 증거”로, 동조 제1항 및 제3항중 “우편의 지연으로”는 각각 “우편물의 망실로”로, 동조제3항중 “당해서류”는 “망실한 서류를 대신하여 제출된 새로운 서류”로 본다.

[전문개정 1999. 7. 1.]

## 제28조의2 【고유번호의 기재】

- ① **(신청에 의한 부여: 신청)** 특허에 관한 절차를 밟는 자 중 총리령으로 정하는 자는 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 자신의 고유번호의 부여를 신청하여야 한다.
- ② **(신청에 의한 부여: 부여 및 통지)** 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항에 따른 신청을 받으면 신청인에게 고유번호를 부여하고, 그 사실을 알려야 한다.
- ③ **(직권에 의한 부여)** 지식재산처장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 제1항에 따라 고유번호를 신청하지 아니하면 그에게 직권으로 고유번호를 부여하고, 그 사실을 알려야 한다.
- ④ **(활용)** 제2항 또는 제3항에 따라 고유번호를 부여받은 자가 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 총리령으로 정하는 서류에 자신의 고유번호를 적어야 한다. 이 경우 이 법 또는 이 법에 따른 명령에도 불구하고 그 서류에 주소(법인인 경우에는 영업소의 소재지를 말한다)를 적지 아니할 수 있다.
- ⑤ **(대리인의 준용)** 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인에 관하여는 제1항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.
- ⑥ 고유번호의 부여 신청, 고유번호의 부여 및 통지, 그 밖에 고유번호에 관하여 필요한 사항은 총리령[시행규칙 제9조]으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

## 제28조의3 【전자문서에 의한 특허에 관한 절차의 수행】 法 28의5

- ① **(종류)** 특허에 관한 절차를 밟는 자는 이 법에 따라 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 특허출원서, 그 밖의 서류를 총리령으로 정하는 방식에 따라 전자문서화하고, 이를 정보통신망을 이용하여 제출하거나 이동식 저장장치 등 전자적 기록매체에 수록하여 제출할 수 있다.
- ② **(서류와 동일한 효력)** 제1항에 따라 제출된 전자문서는 이 법에 따라 제출된 서류와 같은 효력을 가진다.
- ③ **(온라인 제출의 효력발생시기)** 제1항에 따라 정보통신망을 이용하여 제출된 전자문서는 그 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인할 수 있는 때에 지식재산처 또는 특허심판원에서 사용하는 접수용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 본다.
- ④ 제1항에 따라 전자문서로 제출할 수 있는 서류의 종류·제출방법, 그 밖에 전자문서에 의한 서류의 제출에 필요한 사항은 총리령[시행규칙 제9조의2, 4 내지 8]으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

## 제28조의4【전자문서 이용신고 및 전자서명】

- ① **(전자서명)** 전자문서로 특허에 관한 절차를 밟으려는 자는 미리 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 전자문서 이용신고를 하여야 하며, 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 전자문서에 제출인을 알아볼 수 있도록 전자서명을 하여야 한다.
- ② **(전자서명의 효력)** 제28조의3에 따라 제출된 전자문서는 제1항에 따른 전자서명을 한 자가 제출한 것으로 본다.
- ③ 제1항에 따른 전자문서 이용신고 절차, 전자서명 방법 등에 관하여 필요한 사항은 총리령[시행규칙 제9조의3]으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

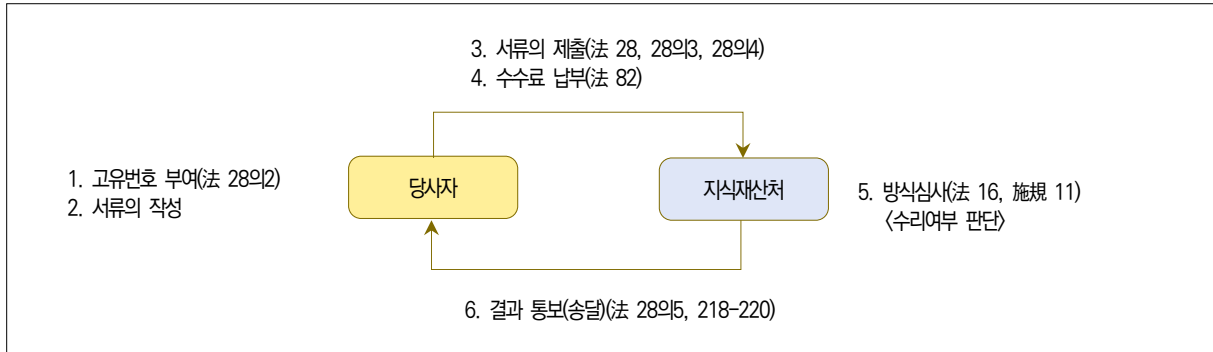
## 제28조의5 【정보통신망을 이용한 통지 등의 수행】 法 28의3, 218-220

- ① **(온라인 통지)** 지식재산처장·특허심판원장·심판장·심판관 또는 심사관은 제28조의4제1항에 따라 전자문서 이용신고를 한 자에게 서류의 통지 및 송달(이하 “통지등”이라 한다)을 하려는 경우에는 정보통신망을 이용하여 통지등을 할 수 있다.
- ② **(서류와 동일한 효력)** 제1항에 따라 정보통신망을 이용하여 한 서류의 통지등은 서면으로 한 것과 같은 효력을 가진다.
- ③ **(효력발생시기)** 제1항에 따른 서류의 통지등은 그 통지등을 받을 자가 자신이 사용하는 전산정보처리조직을 통하여 그 서류를 확인한 때에 지식재산처 또는 특허심판원에서 사용하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 도달한 것으로 본다.
- ④ 제1항에 따라 정보통신망을 이용하여 하는 통지등의 종류·방법 등에 관하여 필요한 사항은 총리령[시행규칙 제9조의8]으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]



## II 특허에 관한 절차 일반(法 16, 28~28의5)



| 구 분                       |                             |                             | 내 용                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 고유번호의 부여 및 기재<br>(法 28의2) |                             |                             | 1. 신청에 의한 부여(法 28의2①②)<br>2. 작권에 의한 부여(法 28의2③)<br>3. 기재의 효과 → 주소에 같음(法 28의2④)<br>4. 대리인번호의 준용(法 28의2⑤)                                                                                                                                |
| 특허에 관한 서류의 작성             |                             |                             | 특허법에서 정한 양식에 따라 서류를 작성(양식주의, 요식주의)                                                                                                                                                                                                     |
| 특허에 관한<br>서류의 제출          | 서면에 의한 제출<br>(法 28)         |                             | * 효력발생시기<br>1. 원칙 - 도달주의<br>2. 예외 - 우편의 경우 발신주의(통신일부인, 우편물 수령증에 의하여 판단)<br>3. 예외의 예외 - 우편의 경우라도 등록신청서류와 국제출원에 관한 서류는 도달주의                                                                                                              |
|                           | 전자문서에 의한 제출<br>(法 28의 3, 4) |                             | 1. 방법<br>① 종류 - 온라인 제출과 전자적 기록매체 제출(法 28의3①)<br>② 절차 - 전자문서이용신고 후 전자서명, 전자문서는 전자서명한 자가 제출한 것으로 간주(法 28의4)<br>2. 효력<br>① 서면과 동일한 효력(法 28의3②)<br>② 정보통신망을 이용하여 제출한 전자문서는 접수번호 확인할 수 있을 때, 접수용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 간주(法 28의3③) |
| 수수료의 납부                   |                             |                             | 1. 특허에 관한 절차를 밟은 자가 수수료 납부(法 82①)<br>2. 접수번호 부여받아 다음 날까지 납부                                                                                                                                                                            |
| 방식심사                      | 흡결이 없는 경우                   |                             | 서류의 수리                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           | 흡결이<br>있는<br>경우             | 보정가능(法 46)한<br>경미한 흡결의 경우   | 1. 일단 수리 후 보정명령<br>2. 보정에 의하여 하자가 치유된 경우 - 소급효<br>3. 보정에 의하여 하자가 치유되지 아니한 경우 - 해당 보정을 명한 특허에 관한 절차를 무효(재량)                                                                                                                             |
|                           |                             | 보정불가능(施規 11)한 중대한<br>흡결의 경우 | 1. 수리하지 않고 소명기회부여<br>2. 소명에 의하여 하자가 치유된 경우 - 처음 서류를 제출한 때 기준으로 수리<br>3. 소명에 의하여 하자가 치유되지 아니한 경우<br>① 반력요청한 경우 - 소명기간내라도 즉시 해당 소명기회를 준 특허에 관한 절차를 불수리(기속)<br>② 반력요청을 하지 아니한 경우 - 소명기간 경과후 해당 소명기회를 준 특허에 관한 절차를 불수리(기속)                 |

### III 절차의 무효(法 16)

| 제 도 |                   | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서   | 의 의               | 출원인·청구인 등이 지식재산처에 대하여 밝은 특허출원, 청구 등 특허에 관한 절차에 일정한 흠결이 있는 경우 그 절차의 효력을 소급하여 소멸시키는 지식재산처장 등의 행정처분을 말한다. 절차의 무효가 된 경우 해당 특허에 관한 절차는 처음부터 없었던 것으로 본다.                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 법적 성질             | 재량적 행정행위, 직권사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 요 건 | 주체적 요건            | 지식재산처장, 심판원장                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 객체적 요건            | 대상 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 法 16①본문               <ol style="list-style-type: none"> <li>① 행위능력이 없는 자가 특허에 관한 절차를 밝은 경우(法 3①)</li> <li>② 대리권의 범위에 흠결이 있는 경우(法 6)</li> <li>③ 법령이 정하는 방식에 위반된 경우</li> <li>④ 수수료를 내지 아니한 경우(法 82)</li> </ol> </li> <li>2. 法 16①단서               <p>제3자의 심사청구후 명세서 보정으로 증가된 청구항에 대하여 출원인이 심사청구료를 불납한 경우(法 82②)</p> </li> </ol> |
|     | 범위                | 1. 해당 보정을 명한 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있음. 해당 보정을 명한 특허에 관한 절차란 특허출원 절차뿐만 아니라 지식재산처장 등의 보정명령을 받은 해당 개별적 행위(심사청구, 보정 등)도 포함.<br>2. 法 16①단서에 해당하는 경우에는 출원인의 명세서 보정을 무효로 할 수 있음.                                                                                                                                                                                                      |
| 절 차 | 보정명령              | 지식재산처장 또는 특허심판원장은 법 제46조 각호 규정에 해당되는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다(기속).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 절차의 보정            | 보정명령을 받은 자는 그 기간에 그 보정명령에 대한 의견서를 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출할 수도 있고(法 46단서), 그 보정을 명한 절차를 보정할 수도 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 효 과 | 하자해소              | 보정된 내용대로 소급효가 인정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 하자<br>부<br>해<br>소 | 1. 해당 보정을 명한 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있으며, 무효처분을 한 경우 그 보정명령을 받은 자에게 처분 통지서를 송달(法 16③).<br>2. 무효가 된 경우 해당 특허에 관한 절차는 처음부터 없었던 것으로 보나(法 16①), 무효처분 이외의 절차는 계속 유효하게 진행됨.                                                                                                                                                                                                            |
| 불 복 | 소제기               | 행정심판이나 행정소송                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 무효처분의<br>취<br>소   | 지식재산처장 또는 특허심판원장은 절차의 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하여 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다(法 16②). 한편, 무효처분취소를 한 경우 지식재산처장 또는 특허심판원장은 그 보정명령을 받은 자에게 그 처분통지서를 송달하여야 한다(法 16③).                                                   |
| 비 교 |                   | 1. 출원의 취하, 포기<br>출원인의 자발적인 의사 또는 법률적 의제에 의하여 출원의 계속 상태를 종료시키는 것을 말한다.<br>2. 특허의 무효<br>특허가 특허무효사유에 해당하는 경우 특허무효심판에 의하여 그 특허권을 처음부터 또는 장래를 향하여 소멸시키는 것을 말한다.                                                                                                                                                                                                                  |

#### Ⅳ 특허출원의 심사

| 구 분                                                                    |                                |                         | 내 용                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>방식심사</b><br>- 지식재산처장<br>- 출원서류제출순서<br>- 출원서류전체                      | 방식흡결이 없는 경우                    |                         | 출원일자 인정                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                        | 방식<br>흡결이<br>있는<br>경우          | 보정가능한<br>경미한 흡결의<br>경우  | 1. 출원일자 인정 후 보정명령<br>2. 출원인의 보정서/의견서 제출<br>3. 보정에 의하여 하자가 치유된 경우 - 소급효<br>4. 보정에 의하여 하자가 치유되지 아니한 경우 - 그 보정을 명한 출원절차를 무효(재량)                                                                                                                 |
|                                                                        |                                | 보정불가능한<br>중대한 흡결의<br>경우 | 1. 출원일자 인정하지 않고 소명기회 부여<br>2. 출원인의 소명서 제출<br>3. 소명에 의하여 하자가 치유된 경우 - 처음 서류를 제출한 때를 기준으로 출원일자 인정<br>4. 소명에 의하여 하자가 치유되지 아니한 경우<br>① 반려요청한 경우 - 소명기간 내라도 즉시 그 소명기회를 준 출원 서류를 불수리(기속)<br>② 반려요청을 하지 아니한 경우 - 소명기간이 지난 후 그 소명기회를 준 출원서류를 불수리(기속) |
| <b>실체심사</b><br>- 심사관<br>- 심사청구순서<br>- 청구범위를 중심<br>으로 발명의 설명<br>· 도면 참작 | 특허요건흡결이 없는 경우<br>(법 제62조에 해당×) |                         | 특허결정(기속)                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                        | 특허요건흡결이 있는 경우<br>(법 제62조에 해당○) |                         | 1. 거절이유통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회부여<br>2. 출원인의 의견서/보정서 제출<br>3. 거절이유가 해소된 경우 - 특허결정(기속)<br>4. 거절이유가 해소되지 아니한 경우 - 특허거절결정(기속)                                                                                                                      |

참고자료 1.3 절차의 불수리(서류의 반려)

| 제 도 |          | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서   |          | 특허에 관한 절차에 보정하기 어려운 중대한 하자가 있는 경우 그 출원서나 청구서 등을 수리하지 아니한 지식재산처장 등의 행정처분을 말한다. 서류의 반려라고도 한다(기속적 행정행위).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 요건  | 주체적      | 지식재산처장, 심판원장                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 객체적      | 대상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 대상       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1건마다 서면을 작성하지 아니한 경우</li> <li>2. 출원 또는 서류의 종류가 불명확한 것인 경우</li> <li>3. 특허에 관한 절차를 밟는 자의 성명(법인의 경우에는 명칭) 또는 특허고객번호(특허고객번호가 없는 경우에는 성명·주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지))가 기재되지 아니한 경우</li> <li>4. 국어로 적지 아니한 경우(단, i) 외국어(영어)로 적은 명세서 및 도면, ii) 위임장, 국적증명서 및 우선권증명서류 등 외국어로 적은 서류는 제외한다)</li> <li>5. 출원서에 명세서(발명의 설명이 기재되어 있지 아니한 경우를 포함한다)를 첨부하지 아니한 경우</li> <li>6. 청구범위제출유예기간(法 42의2①)을 지나서 청구범위를 적지 아니한 명세서를 첨부하여 정당한 관리자가 출원한 경우</li> <li>7. 출원서에 임시 명세서를 첨부한 출원(施規 21⑤전단)의 보정 전에 명세서, 요약서 또는 도면을 보정한 경우</li> <li>8. 분리출원으로서 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니하거나 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 언어로 적은 경우</li> <li>9. 재외자가 특허관리인에 의하지 아니하고 제출한 출원서류등인 경우</li> <li>10. 분리출원을 기초로 새로운 분할출원, 분리출원 또는 변경출원을 하는 경우</li> <li>11. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류인 경우</li> <li>12. 연장이 허용되지 아니하는 기간에 대한 기간연장신청서인 경우</li> <li>13. 거절결정불복심판의 청구기간(法 132의17) 또는 지식재산처장·특허심판원장·심판장 또는 심사관이 지정한 기간을 경과하여 제출된 기간연장신청서인 경우</li> <li>14. 특허에 관한 절차가 종료된 후 그 특허에 관한 절차와 관련하여 제출된 서류인 경우</li> <li>15. 해당 특허에 관한 절차를 밟을 권리가 없는 자가 그 절차와 관련하여 제출한 서류인 경우</li> <li>16. 포괄위임등록신청서, 포괄위임원용제한신고서, 포괄위임등록철회서, 특허고객번호부여신청서 또는 직권으로 특허고객번호를 주어야 하는 경우로서 해당 서류가 불명확하여 수리할 수 없는 경우</li> <li>17. 정보통신망이나 전자적 기록매체로 제출된 특허출원서 또는 기타의 서류가 지식재산처에서 제공하는 소프트웨어 또는 지식재산처 홈페이지를 이용하여 작성되지 아니하였거나 전자문서로 제출된 서류가 전자정보처리조직에서 처리가 불가능한 상태로 접수된 경우</li> <li>18. 전자적 이미지의 첨부서류가 판독이 곤란하여 해당서류를 서면으로 제출하라는 명령을 받고 이를 기간에 제출하지 아니한 경우</li> <li>19. 국적·법인증명서류 등의 제출명령을 받고 소명기간에 제출하지 아니한 경우(施規 8)</li> <li>20. 특허출원인이 i) 청구범위가 기재된 명세서를 첨부하지 아니하거나 ii) 외국어특허출원인데 국어번역문을 제출하지 아니하고 제출한 출원심사청구서의 경우</li> <li>21. i) 청구범위가 기재되지 아니한 명세서를 첨부한 특허출원, ii) 국어번역문을 제출하지 아니한 외국어특허출원 및 iii) 등록공고를 한 특허는 출원공개의 대상이 되지 아니한데 이에 대하여 조기공개신청서를 제출한 경우</li> <li>22. 특허출원이 분할출원, 분리출원 또는 변경출원인 경우, 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우, 특허여부결정의 보류신청이 있기 전에 이미 특허거절결정서 또는 특허결정서를 통지한 경우 중 어느 하나에 해당하여 특허여부결정을 보류할 수 없는 경우</li> <li>23. 특허출원이 분할출원, 분리출원, 변경출원 또는 정당한 관리자의 출원인 경우, 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우, 특허출원심사의 유예신청이 있기 전에 이미 거절이유를 통지하거나 특허결정서를 통지한 경우 중 어느 하나에 해당하여 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 없는 경우</li> <li>24. 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면의 보정없이 재심사를 청구한 경우, 재심사에 따른 특허여부결정이 있는 경우, 거절결정불복심판청구가 있는 경우(제176조제1항에 따라 특허거절결정이 취소된 경우는 제외한다) 또는 그 특허출원이 분리출원인 경우 중 어느 하나에 해당하여 재심사를 청구할 수 없는 경우</li> <li>25. 번역문을 제출하지 않고 보정, 분할출원, 변경출원, 출원인의 심사청구, 조기공개신청이 있는 경우</li> <li>26. 동일한 출원인등이 이미 제출한 서류와 중복되는 서류를 제출한 경우</li> </ol> |
|     | 범위       | 해당 소명기회를 준 특허에 관한 절차를 불수리(다만, 심판청구서는 불수리 대상이 아닌 것으로 운영.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 절차  | 소명기회     | 소명기회 부여, 단, 특허절차를 밟는 자가 국적·법인증명서류 등의 제출명령을 받고도 소명기간 내에 제출하지 아니한 경우에는 반려이유를 고지하고 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다(施規 11②).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 소명서 제출 등 | 출원인 등이 소명하려는 경우에는 소명기간 내에 소명서를, 소명 없이 출원서류 등을 소명기간 이내에 반려 받으려는 경우에는 반려요청서를 제출하여야 한다(施規 11③). 한편, 지식재산처장이 정하여 고시하는 서류의 경우에는 방식심사 전에 반려요청을 할 수도 있다(施規 11의2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 효과  | 하자해소     | 해당 제출서류는 처음 제출한 날에 효력이 발생한 것으로 간주                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 하자 불해소   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 반려요청을 받은 경우 소명기간이라도 반려하고, 반려요청을 받지 아니한 경우 소명기간 지난 후 반려</li> <li>2. 해당 소명기회를 준 제반절차의 효과가 발생하지 아니한 것으로 간주.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 불복  |          | 행정심판이나 행정소송                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## 추후보완(法 17 및 67의3)

### I 법조문

#### 제17조 【절차의 추후보완】 法 67의3

특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.>

1. 제132조의17에 따른 심판의 청구기간
2. 제180조제1항에 따른 재심의 청구기간

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제67조의3 【특허출원의 회복】 法 17

① (요건) 특허출원인이 정당한 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허 거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다.

<개정 2021. 10. 19.>

1. 제59조제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간
2. 제67조의2제1항에 따라 재심사의 청구를 할 수 있는 기간

② (효과) 제1항에 따른 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구가 있는 경우에는 제59조제5항에도 불구하고 그 특허출원은 취하되지 아니한 것으로 보거나 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다.

[본조신설 2013.3.22.]

### II 추후보완(法 17 및 67의3)

| 제 도 |     | 제17조                                                                                                                                                 | 제67조의3                                                                                          |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 의 의 |     | 기간을 지나서 절차를 밟았지만 기간에 절차를 밟은 것으로 간주해 주는 것                                                                                                             |                                                                                                 |
| 요 건 | 주체적 | 책임질 수 없는 사유로 기간을 경과                                                                                                                                  | 정당한 사유로 기간을 경과                                                                                  |
|     | 객체적 | 1. 거절결정불복심판청구기간(法 132의17) → 거절결정 등본송달일로부터 3개월<br>2. 재심청구기간(法 180①) → 안 날로부터 30일<br>cf) 상기 규정한 심판 외에는 특별히 심판청구기간을 법률에서 정하고 있는 심판이 없으므로 추후보완의 인정 문제 不要 | 1. 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간(法 59②③) → 출원일로부터 3년<br>2. 재심사의 청구를 할 수 있는 기간(法 67의2①) → 거절결정등본송달일로부터 3개월 |
|     | 시기적 | 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내. 단 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 후에는 불가                                                                                                    |                                                                                                 |
| 절 차 |     | 기간경과구제신청서를 지식재산처장에게 제출(施規 17)                                                                                                                        |                                                                                                 |
| 효 과 | 적법  | 적법하게 심판청구된 것으로 보고 심판 진행                                                                                                                              | 적법하게 심사청구/재심사청구된 것으로 보고 심사 진행                                                                   |
|     | 부적법 | 심판청구를 할 수 있는 기간 경과로 심결각하                                                                                                                             | 1. 심사청구를 할 수 있는 기간 경과로 출원 취하 간주<br>2. 재심사청구를 할 수 있는 기간 경과로 거절결정의 확정                             |



## 절차의 효력 승계 및 절차의 속행(法 18, 19)

### 제18조 【절차의 효력 승계】

특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 밟은 절차의 효력은 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에게 미친다.

[전문개정 2014.6.11.]

### 제19조 【절차의 속행】

지식재산처장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 지식재산처 또는 특허심판원에 계속(係屬) 중일 때 특허권 또는 특허에 관한 권리가 이전되면 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 절차를 속행(續行)하게 할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### ■ 절차의 효력 승계(法 18)

- 승계가 있는 경우 이미 행한 절차는 유효하므로 다시 절차를 밟을 필요 없음

#### ■ 절차의 속행(法 19)

- 재량행위
- 지식재산처장 또는 심판장이 승계인에 대하여 절차를 속행하게 한 때에는 그 사실을 상대방(승계인 외의 당사자)에게 서면으로 통지하여야 한다(施規 18).
- 법 제18조는 승계 전에 밟은 절차의 효력에 관한 규정인데 반해, 법 제19조는 승계 후의 절차 진행에 관한 규정이라는 점에서 구별



## 절차의 정지(法 20~24, 78, 164)

### I 법조문

#### 제20조 【절차의 중단】 法 8

(원칙) 특허에 관한 절차가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 중단된다. (예외) 다만, 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 당사자가 사망한 경우
2. 당사자인 법인이 합병에 따라 소멸한 경우
3. 당사자가 절차를 밟을 능력을 상실한 경우
4. 당사자의 법정대리인이 사망하거나 그 대리권을 상실한 경우
5. 당사자의 신탁에 의한 수탁자의 임무가 끝난 경우
6. 제11조제1항 각 호 외의 부분 단서[대표자가 있는 경우]에 따른 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우
7. 파산관재인 등 일정한 자격에 따라 자기 이름으로 남을 위하여 당사자가 된 자가 그 자격을 잃거나 사망한 경우

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제21조 【중단된 절차의 수계】

제20조에 따라 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차가 중단된 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 자가 그 절차를 수계(受繼)하여야 한다.

1. 제20조제1호의 경우: 사망한 당사자의 상속인·상속재산관리인 또는 법률에 따라 절차를 속행할 자. 다만, 상속인은 상속을 포기할 수 있을 때까지 그 절차를 수계하지 못한다.
2. 제20조제2호의 경우: 합병에 따라 설립되거나 합병 후 존속하는 법인
3. 제20조제3호 및 제4호의 경우: 절차를 밟을 능력을 회복한 당사자 또는 법정대리인이 된 자
4. 제20조제5호의 경우: 새로운 수탁자
5. 제20조제6호의 경우: 새로운 대표자 또는 각 당사자
6. 제20조제7호의 경우: 같은 자격을 가진 자

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제22조 【수계신청】

- ① (신청에 의한 수계: 수계신청) 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청은 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 할 수 있다. 이 경우 그 상대방은 지식재산처장 또는 제143조에 따른 심판관(이하 "심판관"이라 한다)에게 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 수계신청할 것을 명하도록 요청할 수 있다.
- ② (신청에 의한 수계: 통지) 지식재산처장 또는 심판관은 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청이 있으면 그 사실을 상대방에게 알려야 한다.
- ③ (신청에 의한 수계: 수계여부의 결정) 지식재산처장 또는 심판관은 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여 직권으로 조사하여 이유 없다고 인정하면 결정으로 기각하여야 한다.
- ④ (신청에 의한 수계: 수계인정여부의 결정) 지식재산처장 또는 심판관은 결정 또는 심결의 등본을 송달한 후에 중단된 절차에 관한 수계신청에 대해서는 수계하게 할 것인지를 결정하여야 한다.
- ⑤ (명령에 의한 수계: 수계명령) 지식재산처장 또는 심판관은 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 중단된 절차를 수계하지 아니하면 직권으로 기간을 정하여 수계를 명하여야 한다.
- ⑥ (명령에 의한 수계: 수계간주) 제5항에 따른 기간에 수계가 없는 경우에는 그 기간이 끝나는 날의 다음 날에 수계가 있는 것으로 본다.
- ⑦ (명령에 의한 수계: 통지) 지식재산처장 또는 심판관은 제6항에 따라 수계가 있는 것으로 본 경우에는 그 사실을 당사자에게 알려야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제23조 【절차의 중지】



- ① **(당연중지)** 지식재산처장 또는 심판관이 천재지변이나 그 밖의 불가피한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 그 사유가 없어질 때까지 중지된다.
- ② **(결정중지)** 당사자에게 일정하지 아니한 기간 동안 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 장애사유가 생긴 경우에는 지식재산처장 또는 심판관은 결정으로 장애사유가 해소될 때까지 그 절차의 중지를 명할 수 있다.
- ③ **(결정중지의 취소)** 지식재산처장 또는 심판관은 제2항에 따른 결정을 취소할 수 있다.
- ④ **(통지)** 제1항 또는 제2항에 따른 중지나 제3항에 따른 취소를 하였을 때에는 지식재산처장 또는 심판장은 그 사실을 각각 당사자에게 알려야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제24조 【중단 또는 중지의 효과】

특허에 관한 절차가 중단되거나 중지된 경우에는 그 기간의 진행은 정지되고, 그 절차의 수계통지를 하거나 그 절차를 속행하였을 때부터 다시 모든 기간이 진행된다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제78조 【심사 또는 소송절차의 중지】 **法 164**

- ① **(심사절차의 중지)** 특허출원의 심사에 필요한 경우에는 특허취소신청에 대한 결정이나 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 그 심사절차를 중지할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
- ② **(소송절차의 중지)** 법원은 소송에 필요한 경우에는 특허출원에 대한 특허여부결정이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.
- ③ **(불복 不可)** 제1항 및 제2항에 따른 중지에는 대해서는 불복할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제164조 【소송과의 관계】 **法 78 / 132의15**

- ① **(심판절차의 중지)** 심판장은 심판에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 그 심판사건과 관련되는 특허취소신청에 대한 결정 또는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
- ② **(소송절차의 중지)** 법원은 소송절차에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허취소신청에 대한 결정이나 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
- ③ **(특허심판원장에게 통보)** 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소가 제기된 경우에는 그 취지를 특허심판원장에게 통보하여야 한다. 그 소송절차가 끝났을 때에도 또한 같다.
- ④ **(법원에 통보)** 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효 심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다. 그 심판청구서의 각하결정, 심결 또는 청구의 취하가 있는 경우에도 또한 같다.

[전문개정 2014.6.11.]



## II 절차 정지의 구분(法 20~24, 78, 164)

|              |       |           |                     |                                                                                                                                     |
|--------------|-------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정지의 종류       |       |           | 중단<br>(당사자의<br>교체○) | 1. 중단사유(法 20)<br>① 원칙 - 法 20 각호에 해당하는 경우 중단<br>② 예외 - 임의대리인이 있는 경우 중단 ×                                                             |
| 구분           | 절차 정지 | 절차 정지의 해소 |                     | 2. 수계자(法 21)                                                                                                                        |
|              | 당연중단  | 사유발생      |                     | 3 수계방법(法 22)<br>① 신청에 의한 수계<br>- 수계신청(法 22①②)<br>- 수계신청에 대한 결정(法 22③④)                                                              |
|              | 당연중지  | 사유발생      |                     | ② 명령에 의한 수계(法 22⑤⑥⑦)                                                                                                                |
|              | 결정중지  | 사유발생 & 결정 | 중지<br>(당사자의<br>교체×) | 1. 당연중지 및 해소(法 23①)<br>2. 결정중지(法 23②) 및 해소(法 23③)<br>3. 통지(法 23④)<br>4. 기타<br>① 타절차와의 관계에서 중지(法 78, 164)<br>② 제척·기피신청에 대한 중지(法 153) |
| 정지의 효과(法 24) |       |           |                     | 1. 절차의 정지 & 다시 모든 기간(잔존 기간×)이 진행<br>2. 참가인1, 공동심판청구인 중 1인에게 정지원인이 있는 경우 정지(法 139④, 155⑤)                                            |

# 12

## 조약의 효력

### I 법조문

#### 제26조 삭제 <2011.12.2.>

##### 구특허법 제26조

아래의 내용과 같이 조약우위설에 관한 규정이었으나 현재는 삭제되었고, 그 결과 헌법 제6조제1항에 따라 헌법과 특허법이 동등한 효력을 가진다

##### 제26조(조약의 효력)

특허에 관하여 조약에 이 법에서 규정한 것과 다른 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다.

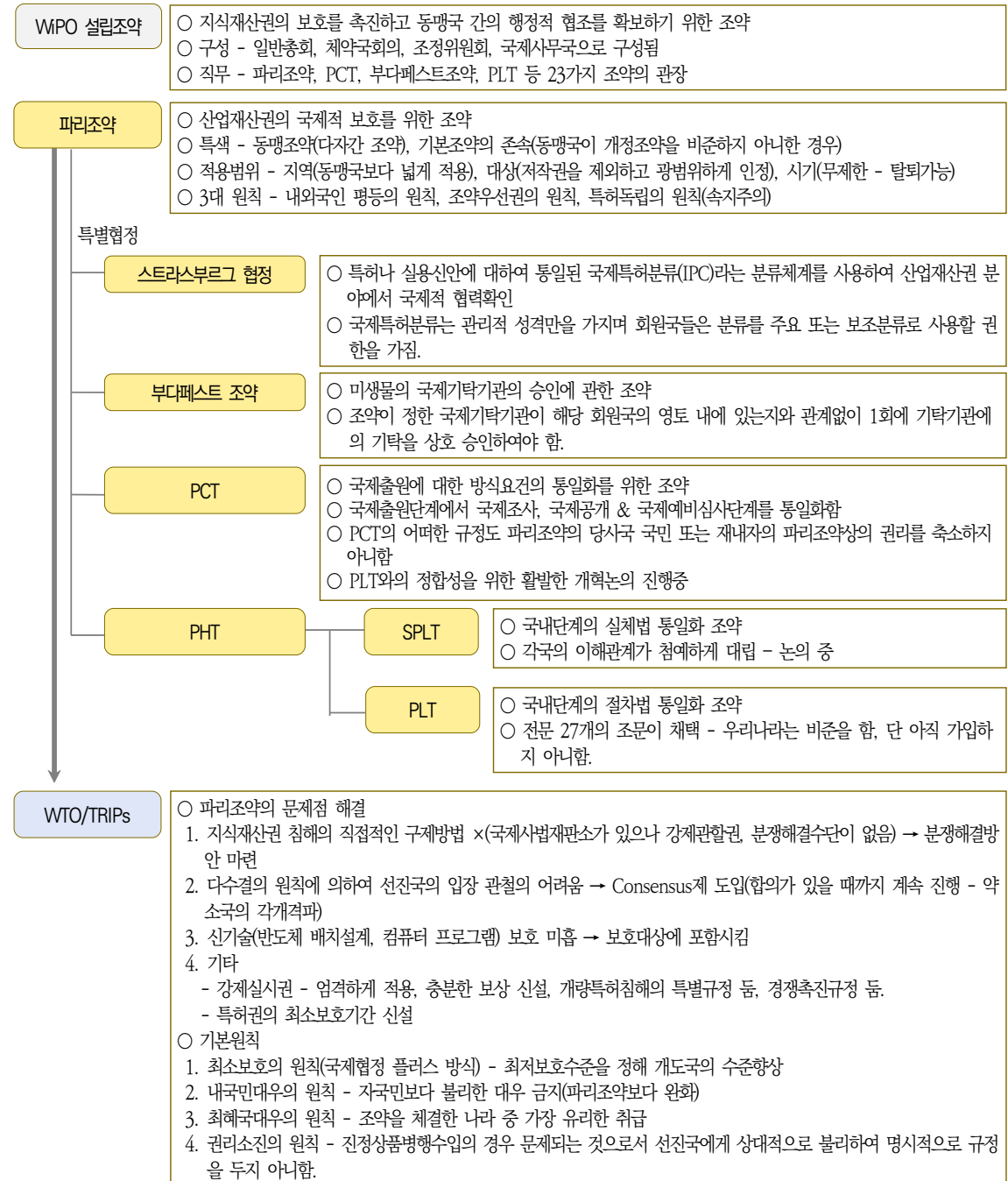
- 헌법 제6조 제1항에서는 “憲法에 의하여 체결·공포된 條約과 일반적으로 승인된 國際法規는 國內法과 같은 效力을 가진다.”고 규정되어 있다. 즉 헌법에 의하면 조약과 국내법은 동등한 효력을 갖는다. 그러나 조약이 국내법과 충돌할 때에는 어떠한 효력을 가지는가에 대하여 구법 제26조에서는 “특허에 관하여 조약에 이 법에서 규정한 것과 다른 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다.”라고 하여 조약이 특허법보다 우선한다는 조약(국제법) 우위설의 입장을 취하고 있었다. 그러나, 이는 i) 헌법 제6조 제1항의 조약의 국내법과 동일시하는 규정에 부합하지 않을뿐더러, ii) 한미 FTA 이행법과 관련하여, 미국은 FTA가 미국법을 개정하거나 수정하는 것으로 해석될 수 없다고 하는데 반해, 한국은 법 제26조에 의하여 FTA가 국내법보다 우위에 있다면 상호주의에 맞지 않기 때문에 개정법(법률 제11117호, 2011. 12. 2. 개정 / 2012. 3. 15. 시행)에서는 법 제26조를 삭제하였다.
- 조약의 국내법 체계로의 수용, 즉 「헌법에 의하여 체결·공포」되어 국내법과 같은 효력을 가지기 위해서는 국회의 동의 절차가 필요하며 헌법 제60조 제1항에는 국회는 “상호원조에 관한 조약, 안전보장에 관한 조약, 중요한 국제조직에 관한 조약, 우호통상항해조약, 주권의 제약에 관한 조약, 강화조약, 국가나 국민에게 중대한 재정적 부담을 지우는 조약 또는 입법사항에 관한 조약의 체결·비준에 대한 동의권을 가진다.”라고 국회의 동의 절차가 필요한 조약을 규정하고 있다. 국회의 비준 동의로 조약이 국내법 체계로 들어오면, 국내법과의 저촉충돌이 발생했을 때 이를 어떻게 해결할 것인지에 대해서는 상위법우선의 원칙, 대등한 법 규정 상호간에는 특별법 우선의 원칙, 후법 우선의 원칙, 국제법에 대한 우호적인 해석 등이 적용되고 있다.

## II 특허 관련 조약의 개략적인 설명

### 1. 특허제도의 국제화

- 초기의 목적 : 발명자들의 국제적 특허권 획득의 편의 제공
- 현재의 목적 : 타국에 대한 경제적 우위의 점거(기술적 지배수단) → 가입국의 강제 확대

### 2. 흐름



# 13

## 보칙(法 215~224의5)

### I 법조문

#### 제215조 【둘 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관한 특칙】

둘 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관하여 제65조제6항[보상금청구권의 소멸], 제84조제1항제2호·제6호[무효심결확정이나 특허권 포기에 의한 특허료의 반환], 제85조제1항제1호(소멸의 경우만 해당한다)[특허권의 소멸등록], 제101조제1항제1호[특허권 및 전용실시권 등록의 효과], 제104조제1항제1호·제3호·제5호[무효심판청구등록전의 실시에 의한 통상실시권], 제119조제1항[특허권 포기의 제한], 제132조의13제3항[특허취소신청에 의한 취소결정의 확정], 제133조제2항·제3항[무효심판에 의한 무효심결의 확정], 제136조제7항[정정심판], 제139조제1항[공통심판청구], 제181조[재심에 의하여 회복된 특허권의 효력제한], 제182조[재심에 의하여 회복한 선사용자의 통상실시권] 또는 「실용신안법」 제26조제1항제2호·제4호·제5호[무효심판청구등록전의 실시에 의한 통상실시권]를 적용할 때에는 청구항마다 특허가 되거나 특허권이 있는 것으로 본다.

〈개정 2016.2.29., 2016.3.29.〉

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제215조의2 【둘 이상의 청구항이 있는 특허출원의 등록에 관한 특칙】(★)

- ① (설정등록시 청구항별 포기) 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허료를 낼 때에는 청구항별로 이를 포기할 수 있다.
- ② (포기의 절차) 제1항에 따른 청구항의 포기에 관하여 필요한 사항은 총리령[시행규칙 제19조의2]으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제216조 【서류의 열람 등】(★) 法 29

- ① (신청) 특허출원, 특허취소신청, 심판 등에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사가 필요한 자는 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 서류의 열람 등의 허가를 신청할 수 있다. 〈개정 2016.2.29.〉
- ② (예외) 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류를 비밀로 유지할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 서류의 열람 또는 복사를 허가하지 아니할 수 있다. 〈개정 2016.2.29.〉
  1. 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원(제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 출원공개 또는 설정등록된 경우에는 그 선출원은 제외한다)에 관한 서류
  2. 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원의 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에 관한 서류
  3. 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 위생을 해칠 우려가 있는 서류

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제217조 【특허출원 등에 관한 서류 등의 반출 및 감정 등의 금지】

- ① (반출금지) 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 외부로 반출할 수 있다. 〈개정 2016. 2. 29., 2016. 12. 2., 2017. 11. 28., 2018. 4. 17., 2021. 8. 17., 2024. 2. 6.〉
  1. 제58조제1항, 제3항 또는 제4항에 따른 선행기술의 조사 등을 위하여 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출하는 경우
  - 1의2. 제164조의2제2항에 따른 조정을 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우
  2. 「산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률」 제12조제1항에 따른 산업재산문서 전자화업무의 위탁을 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우
  3. 「전자정부법」 제32조제2항에 따른 온라인 원격근무를 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우
  4. 외국 특허담당 정부기관 또는 국제기구와의 업무협약을 이행하기 위하여 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출하는 경우
- ② (감정 등의 금지) 특허출원·심사·특허취소신청·심판 또는 재심으로 계속 중인 사건의 내용이나 특허여부결정·심결 또는 결정의 내용에 관하여는 감정·증언하거나 질의에 응답할 수 없다. 〈개정 2016.2.29.〉
- ③ 제1항제4호에 따른 반출 요건·절차, 서류의 종류 등에 필요한 사항은 총리령[시행규칙 제20조의2]으로 정한다.

〈신설 2017.11.28.〉

[전문개정 2014.6.11.]

**제217조의2 삭제** <2024. 2. 6.>

**제218조 【서류의 송달】** **法 28의5**

이 법에 규정된 서류의 송달절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령[시행령 제18조]으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

**시행령 제18조**

**제18조(서류의 송달등)**

- ① 법에 따라 송달할 서류는 지식재산처 또는 특허심판원에서 당사자 또는 그 대리인이 이를 직접 수령하거나 정보통신망을 이용하여 수령하는 경우를 제외하고는 등기우편으로 발송하여야 한다. <개정 1993. 12. 31., 1997. 6. 26., 2001. 6. 27., 2007. 6. 28.>
- ② 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항의 규정에 의하여 서류를 송달한 경우에는 다음 각호에 정하는 바에 따라 수령증 또는 그 내용을 보관하여야 한다. <개정 2001. 6. 27.>
  1. 당사자 또는 대리인이 지식재산처 또는 특허심판원에서 직접 수령하는 경우에는 수령일자 및 수령자의 성명이 기재된 수령증
  2. 당사자 또는 대리인이 정보통신망을 이용하여 수령하는 경우에는 지식재산처 또는 특허심판원이 운영하는 발송용 전자정보처리조직의 파일에 기록된 내용
  3. 등기우편으로 발송하는 경우에는 등기우편물 수령증
- ③ 심판·재심·통상실시권 설정의 재정 및 특허권의 취소에 관한 심결 또는 결정의 등본을 송달하는 경우에는 우편법령에 따른 특별 송달의 방법으로 하여야 한다. 다만, 법 제28조의4제1항에 따른 전자문서 이용신고를 한 자에게 송달하는 경우에는 정보통신망을 이용하여 할 수 있다. <개정 1993. 12. 31., 1997. 6. 26., 1999. 6. 30., 2006. 9. 28., 2011. 2. 22.>
- ④ 송달에 있어서는 법 또는 이 영에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 송달을 받는 자에게 그 서류의 등본을 교부하여야 하며, 송달할 서류의 제출에 갈음하여 조서를 작성한 때에는 그 조서의 등본이나 초본을 교부하여야 한다.
- ⑤ 법 제3조제1항의 본문에 해당하는 자에 대한 송달은 그 법정대리인에게 하여야 한다.
- ⑥ 수인이 공동으로 대리권을 행사하는 경우에는 그 중 1인에게 송달한다. <개정 1993. 12. 31., 2011. 2. 22.>
- ⑦ 교도소 또는 구치소에 구속된 자에 대한 송달은 그 소장에게 한다. <개정 1993. 12. 31.>
- ⑧ 당사자 또는 그 대리인이 2인 이상인 경우로서 서류를 송달받기 위한 대표자 1인을 선정하여 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 신고한 경우에는 그 대표자에게 송달한다. <신설 2011. 2. 22.>
- ⑨ 송달할 장소는 이를 받을 자의 주소 또는 영업소로 한다. 다만, 송달을 받고자 하는 자가 송달을 받고자 하는 장소(국내에 한한다)를 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 미리 신고한 경우에는 그 장소로 한다. <개정 1993. 12. 31., 2005. 1. 31., 2011. 2. 22.>
- ⑩ 송달을 받을 자가 그 장소를 변경한 때에는 지체없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다. <신설 1993. 12. 31., 2011. 2. 22.>
- ⑪ 송달을 받는 자가 정당한 사유없이 송달받기를 거부함으로써 송달할 수 없게된 때에는 발송한 날에 송달된 것으로 본다. <개정 2011. 2. 22.>
- ⑫ 법에 따라 송달할 서류외의 서류의 발송등은 지식재산처장이 정하는 방법에 따른다. <신설 1993. 12. 31., 2007. 6. 28., 2011. 2. 22.>

**제219조 【공시송달】** **法 28의5**

- ① **(요건)** 서류를 송달받을 자의 주소나 영업소가 분명하지 아니하여 송달할 수 없는 경우에는 공시송달(公示送達)을 하여야 한다.
- ② **(방법)** 공시송달은 서류를 송달받을 자에게 어느 때라도 발급한다는 뜻을 특허공보에 게재하는 것으로 한다.
- ③ **(효력)** 최초의 공시송달은 특허공보에 게재한 날부터 2주일이 지나면 그 효력이 발생한다. 다만, 같은 당사자에 대한 이후의 공시송달은 특허공보에 게재한 날의 다음 날부터 효력이 발생한다.

[전문개정 2014.6.11.]

**제220조 【재외자에 대한 송달】(★)** **法 13, 28의5**

- ① **(특허관리인이 있는 경우)** 재외자로서 특허관리인이 있으면 그 재외자에게 송달할 서류는 특허관리인에게 송달하여야 한다.
- ② **(특허관리인이 없는 경우)** 재외자로서 특허관리인이 없으면 그 재외자에게 송달할 서류는 항공등기우편으로 발송할 수 있다.
- ③ **(특허관리인이 없는 경우)** 제2항에 따라 서류를 항공등기우편으로 발송한 경우에는 그 발송일에 송달된 것으로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

**제221조 【특허공보】**

- ① **(특허공보 발행)** 지식재산처장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 특허공보를 발행하여야 한다.
- ② **(전자적 매체 이용 가능)** 특허공보는 총리령[시행규칙 제20조의5]으로 정하는 바에 따라 전자적 매체로 발행할 수 있다.
- ③ **(전자적 매체 이용 절차)** 지식재산처장은 전자적 매체로 특허공보를 발행하는 경우에는 정보통신망을 활용하여 특허공보의 발행사실·주요목록 및 공시송달에 관한 사항을 알려야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

**제222조 【서류의 제출 등】** **法 132의15, 147③, 184 / 232①Ⅱ**

지식재산처장 또는 심사관은 당사자에게 특허취소신청, 심판 또는 재심에 관한 절차 외의 절차를 처리하기 위하여 필요한 서류나 그 밖의 물건의 제출을 명할 수 있다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

### 제223조 【특허표시 및 특허출원표시】

① **(특허표시)** 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 특허표시를 할 수 있다. <개정 2016.2.29., 2017.3.21.>

1. 물건의 특허발명의 경우: 그 물건에 "특허"라는 문자와 그 특허번호를 표시
2. 물건을 생산하는 방법의 특허발명의 경우: 그 방법에 따라 생산된 물건에 "방법특허"라는 문자와 그 특허번호를 표시
3. 삭제 <2017.3.21.>

② **(특허출원표시)** 특허출원인은 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 특허출원의 표시(이하 "특허출원표시"라 한다)를 할 수 있다. <개정 2017.3.21.>

1. 물건의 특허출원의 경우: 그 물건에 "특허출원(심사중)"이라는 문자와 그 출원번호를 표시
2. 물건을 생산하는 방법의 특허출원의 경우: 그 방법에 따라 생산된 물건에 "방법특허출원(심사중)"이라는 문자와 그 출원번호를 표시

③ **(용기/포장표시)** 제1항 또는 제2항에 따른 특허표시 또는 특허출원표시를 할 수 없는 물건의 경우에는 그 물건의 용기 또는 포장에 특허표시 또는 특허출원표시를 할 수 있다. <신설 2017.3.21.>

④ 그 밖에 특허표시 또는 특허출원표시에 필요한 사항은 총리령[**시행규칙 제21조**]으로 정한다. <신설 2017.3.21.>

[전문개정 2014.6.11.]

[제목개정 2017.3.21.]

### 제224조 【허위표시의 금지】

누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건 또는 그 물건의 용기나 포장에 특허표시 또는 특허출원표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위
2. 제1호의 표시를 한 것을 양도·대여 또는 전시하는 행위
3. 제1호의 물건을 생산·사용·양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 물건이 특허나 특허출원된 것 또는 특허된 방법이나 특허출원 중인 방법에 따라 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위
4. 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법을 사용·양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 방법이 특허 또는 특허출원된 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위

[전문개정 2014.6.11.]

### 제224조의2 【불복의 제한】

① 보정각하결정, 특허여부결정, 특허취소결정, 심결이나 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서의 각하결정에 대해서는 다른 법률에 따른 불복을 할 수 없으며, 이 법에 따라 불복할 수 없도록 규정되어 있는 처분에 대해서는 다른 법률에 따라 불복을 할 수 없다. <개정 2016.2.29.> **法 51③, 132의17, 186① / 78③, 132의6②, 132의13⑤, 152⑥, 156⑤.**

② 제1항에 따른 처분 외의 처분의 불복에 대해서는 「행정심판법」 또는 「행정소송법」에 따른다. **法 115 / 186⑥**

[전문개정 2014.6.11.]

### 제224조의3 【비밀유지명령】(★) **法 132**

① **(요건)** 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 그 당사자가 보유한 영업비밀에 대하여 다음 각 호의 사유를 모두 소명한 경우에는 그 당사자의 신청에 따라 결정으로 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자에게 그 영업비밀을 그 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하거나 그 영업비밀에 관계된 이 항에 따른 명령을 받은 자 외의 자에게 공개하지 아니할 것을 명할 수 있다. (예외) 다만, 그 신청 시점까지 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자가 제1호에 규정된 준비서면의 열람이나 증거조사 외의 방법으로 그 영업비밀을 이미 취득하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.3.29.>

1. 이미 제출하였거나 제출하여야 할 준비서면, 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거 또는 제132조제3항에 따라 제출하였거나 제출하여야 할 자료에 영업비밀이 포함되어 있다는 것
2. 제1호의 영업비밀이 해당 소송 수행 외의 목적으로 사용되거나 공개되면 당사자의 영업에 지장을 줄 우려가 있어 이를 방지하기 위하여 영업비밀의 사용 또는 공개를 제한할 필요가 있다는 것

② **(신청)** 제1항에 따른 명령(이하 "비밀유지명령"이라 한다)의 신청은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 한다.

1. 비밀유지명령을 받을 자
2. 비밀유지명령의 대상이 될 영업비밀을 특정하기에 충분한 사실
3. 제1항 각 호의 사유에 해당하는 사실

③ **(인용·송달)** 법원은 비밀유지명령이 결정된 경우에는 그 결정서를 비밀유지명령을 받은 자에게 송달하여야 한다.



- ④ **(인용: 효력)** 비밀유지명령은 제3항의 결정서가 비밀유지명령을 받은 자에게 송달된 때부터 효력이 발생한다.
- ⑤ **(불복)** 비밀유지명령의 신청을 기각하거나 각하한 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제224조의4 **【비밀유지명령의 취소】(★) 法 132**

- ① **(요건)** 비밀유지명령을 신청한 자 또는 비밀유지명령을 받은 자는 제224조의3제1항에 따른 요건을 갖추지 못하였거나 갖추지 못하게 된 경우 소송기록을 보관하고 있는 법원(소송기록을 보관하고 있는 법원이 없는 경우에는 비밀유지명령을 내린 법원)에 비밀유지명령의 취소를 신청할 수 있다.
- ② **(송달)** 법원은 비밀유지명령의 취소신청에 대한 재판이 있는 경우에는 그 결정서를 그 신청을 한 자 및 상대방에게 송달하여야 한다.
- ③ **(재판: 불복)** 비밀유지명령의 취소신청에 대한 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다.
- ④ **(재판: 효력)** 비밀유지명령을 취소하는 재판은 확정되어야 효력이 발생한다.
- ⑤ **(재판: 통지)** 비밀유지명령을 취소하는 재판을 한 법원은 비밀유지명령의 취소신청을 한 자 또는 상대방 외에 해당 영업비밀에 관한 비밀유지명령을 받은 자가 있는 경우에는 그 자에게 즉시 비밀유지명령의 취소 재판을 한 사실을 알려야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제224조의5 **【소송기록 열람 등의 청구 통지 등】(★) 法 132**

- ① **(열람 등의 청구 통지)** 비밀유지명령이 내려진 소송(모든 비밀유지명령이 취소된 소송은 제외한다)에 관한 소송기록에 대하여 「민사소송법」 제163조제1항의 결정이 있었던 경우, 당사자가 같은 항에서 규정하는 비밀 기재부분의 열람 등의 청구를 하였으나 그 청구 절차를 해당 소송에서 비밀유지명령을 받지 아니한 자가 밟은 경우에는 법원서기관, 법원사무관, 법원주사 또는 법원주사보(이하 이 조에서 "법원사무관등"이라 한다)는 「민사소송법」 제163조제1항의 신청을 한 당사자(그 열람 등의 청구를 한 자는 제외한다. 이하 제3항에서 같다)에게 그 청구 직후에 그 열람 등의 청구가 있었다는 사실을 알려야 한다.

#### 민사소송법 제163조

##### 제163조(비밀보호를 위한 열람 등의 제한)

- ① 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당한다는 소명이 있는 경우에는 법원은 당사자의 신청에 따라 결정으로 소송기록중 비밀이 적혀 있는 부분의 열람·복사, 재판서·조서중 비밀이 적혀 있는 부분의 정본·등본·초본의 교부(이하 "비밀 기재부분의 열람 등"이라 한다)를 신청할 수 있는 자를 당사자로 한정할 수 있다.
  1. 소송기록 중에 당사자의 사생활에 관한 중대한 비밀이 적혀 있고, 제3자에게 비밀 기재부분의 열람 등을 허용하면 당사자의 사회 생활에 지장이 클 우려가 있는 때
  2. 소송기록중에 당사자가 가지는 영업비밀(부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조제2호에 규정된 영업비밀을 말한다)이 적혀 있는 때
- ② **(열람 금지: 기간)** 제1항의 경우에 법원사무관등은 제1항의 청구가 있었던 날부터 2주일이 지날 때까지(그 청구 절차를 밟은 자에 대한 비밀유지명령 신청이 그 기간 내에 이루어진 경우에는 그 신청에 대한 재판이 확정되는 시점까지) 그 청구 절차를 밟은 자에게 제1항의 비밀 기재부분의 열람 등을 하게 하여서는 아니 된다.
- ③ **(열람 금지: 예외)** 제2항은 제1항의 열람 등의 청구를 한 자에게 제1항의 비밀 기재부분의 열람 등을 하게 하는 것에 대하여 「민사소송법」 제163조제1항의 신청을 한 당사자 모두가 동의하는 경우에는 적용되지 아니한다.

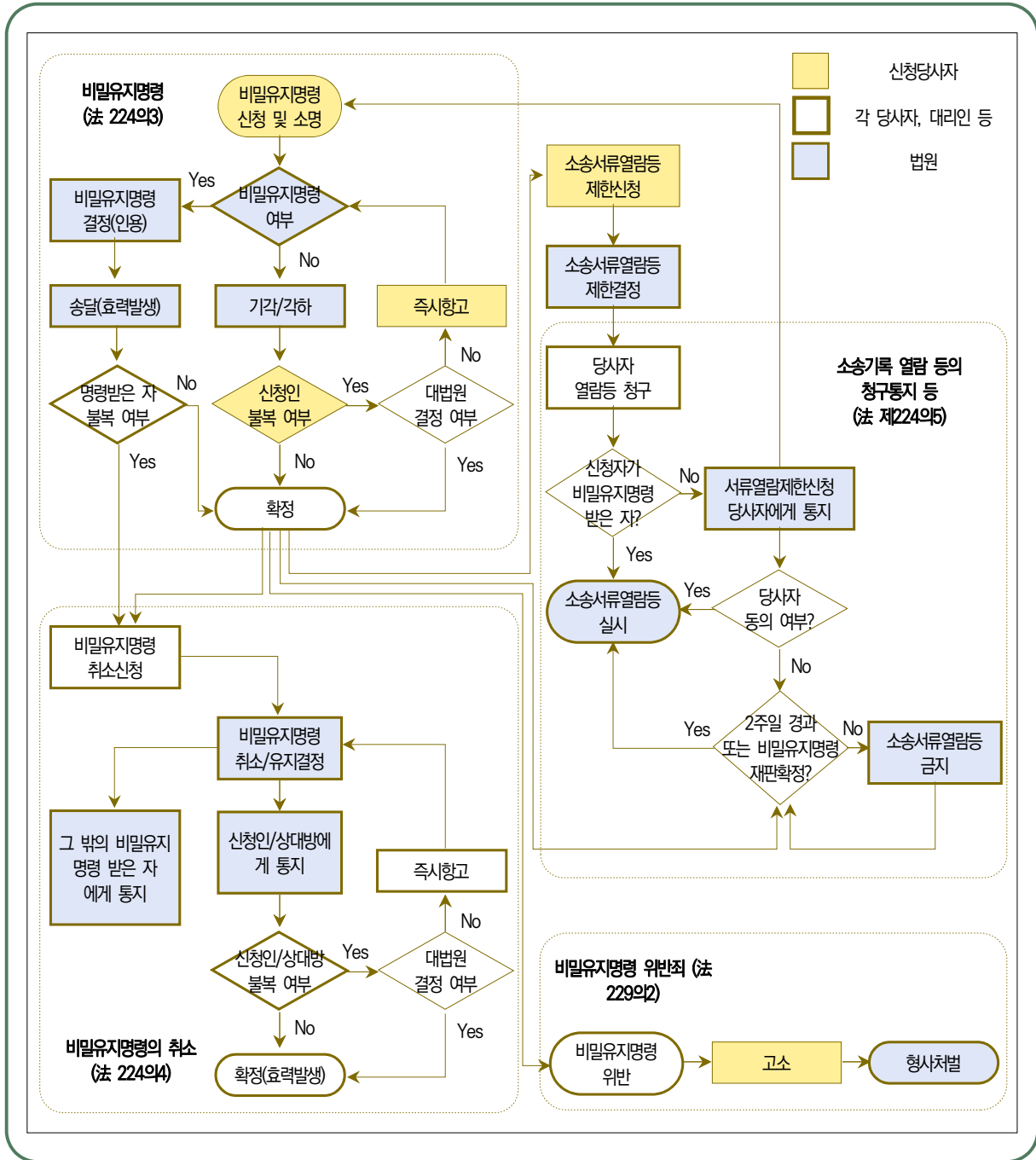
[전문개정 2014.6.11.]

II 2이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 대한 특칙(法 215, 215의2)

| 조 문                              | 내 용                                                  | 비 고                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 法 65⑥                            | 보상금청구권의 소멸                                           | 출원의 취하·포기·무효, 특허출원에 대한 거절결정확정은 준용×           |
| 法 84①II·VI                       | 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되거나 특허권을 포기한 해의 다음해부터의 특허료 해당분의 반환 |                                              |
| 法 85①I                           | 특허권의 소멸등록                                            | 특허권의 발생·이전·처분·존속기간의 연장은 청구항별 불가              |
| 法 101①I                          | 특허권 및 전용실시권의 등록의 효과                                  | 1. 청구항별 특허권의 이전·처분의 제한×<br>2. 청구항별 특허권의 포기 ○ |
| 法 104①I·III·V<br>(실용 26①II·IV·V) | 무효심판청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권                             |                                              |
| 法 119①                           | 특허권 포기의 제한                                           |                                              |
| 法 132의13③                        | 특허취소신청에 의한 소멸                                        |                                              |
| 法 133②③                          | 특허무효심판에 의한 소멸                                        |                                              |
| 法 136⑦                           | 정정심판의 청구시기                                           |                                              |
| 法 139①                           | 공동심판의 청구                                             |                                              |
| 法 181                            | 재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한                               |                                              |
| 法 182                            | 재심에 의하여 회복한 선사용자의 통상실시권                              |                                              |
| 法 215의2                          | 둘 이상의 청구항이 있는 경우 특허출원의 등록                            |                                              |



III 비밀유지명령제도(法 224의3~224의5)





도해특허법

## 제2장 특허요건

## 제3장 이익제도

## 제4장 심사

|    |    |                             |
|----|----|-----------------------------|
| 객체 | 14 | 협회의 특허요건(法 29)              |
|    | 15 | 선출원주의(法 36)                 |
|    | 16 | 불특허발명(法 32)                 |
|    | 17 | 국방상 필요한 발명(法 41, 106)       |
| 주체 | 18 | 출원인이 될 수 있는 자(法 25, 33, 44) |
|    | 19 | 특허를 받을 수 있는 권리(法 37, 38)    |
|    | 20 | 직무발명(발진법 2, 10~19, 58)      |
| 출원 | 21 | 특허출원(法 42~42의3, 43)         |
|    | 22 | 하나의 특허출원의 범위(法 45)          |

| 요건          | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                | 거절이유 | 정보제공<br>사유 | 특허무효사유 | 특허취소사유 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|--------|
| 주체적         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 외국인의 권리능력(法 25)</li> <li>■ 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 자(法 33①본문)</li> <li>■ 특허를 받을 수 없는 자(法 33①단서)</li> <li>■ 공동출원(法 44)</li> </ul>                                                                                             | ○    | ○          | ○*     |        |
| 실체적         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 산업상 이용가능성(法 29①본문)</li> <li>■ 신규성(法 29①각호)</li> <li>■ 진보성(法 29②)</li> <li>■ 확대된 선출원(法 29③④⑤⑥⑦)</li> <li>■ 선출원주의(法 36①②③)</li> </ul>                                                                                      |      |            |        | ○***   |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 불특허발명(法 32)</li> <li>■ 일반적 발명의 설명 기재(法 42③ I)</li> <li>■ 청구범위 기재(法 42④)</li> <li>■ 신규사항추가금지(法 47②)</li> <li>■ 분할출원의 범위를 벗어난 경우(法 52①)</li> <li>■ 분리출원의 범위를 벗어난 경우(法 52의2①)</li> <li>■ 변경출원의 범위를 벗어난 경우(法 53①)</li> </ul> | ○    | ○          | ○**    |        |
| 조약          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 조약을 위반한 경우</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | ○    | ○          | ○      |        |
| 절차적         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 발명의 설명 중 배경기술 기재(法 42③Ⅱ)</li> <li>■ 다항제 기재방법(法 42⑧)</li> <li>■ 하나의 특허출원의 범위(法 45)</li> </ul>                                                                                                                             | ○    |            |        |        |
| 후발적<br>무효사유 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 특허 후 특허권자가 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약을 위반된 경우</li> </ul>                                                                                                                                                               |      |            | ○      |        |

\* 단, 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 자(法 33①본문) 위반과 공동출원(法 44) 위반은 법 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에 제외

\*\* 단, 신규사항추가금지(法 47②)는 원문의 범위(法 47②전단)를 벗어난 경우, 분리출원(法 52의2)은 원출원의 최초 명세서 또는 도면의 범위를 벗어난 경우(法 52의2①각호 외의 부분 전단)에만 특허무효사유에 해당

\*\*\* 법 제29조(같은 조 제1항제1호에 해당하는 경우와 같은 호에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우는 제외한다)와 제36조 제1항 내지 제3항에 한하되, 등록특허공보에 게재된 선행기술을 기초로 하는 불가/심판 실무상 법 제29조제1항본문위반도 제외

## I 법조문

## 제29조 【특허요건】(★★★) 法 62 Ⅰ, 63의2, 132의2① Ⅰ, 133① Ⅰ

① (산업상 이용가능성) 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. (신규성 상실사유) 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명
2. (신규성 상실사유) 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명

② (진보성) 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

③ (확대된 선출원: 다른 출원이 국내특허출원인 경우) 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. (예외) 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.

法 52② Ⅰ, 52의2②, 53② Ⅰ, 55④⑤⑥, 202②③ Ⅱ

1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것
2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된 특허출원일 것

④ (확대된 선출원: 다른 출원이 국내실용신안출원인 경우) 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 고안(考案)과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. (예외) 다만, 그 특허출원의 발명자와 실용신안등록출원의 고안자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 실용신안등록출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.

法 52② Ⅰ, 52의2②, 53② Ⅰ, 55④⑤⑥, 202②③ Ⅱ

1. 그 특허출원일 전에 출원된 실용신안등록출원일 것
2. 그 특허출원 후 「실용신안법」 제15조에 따라 준용되는 이 법 제64조에 따라 출원공개되거나 「실용신안법」 제21조제3항에 따라 등록공고된 실용신안등록출원일 것

⑤ (확대된 선출원: 다른 출원이 국제특허출원인 경우) 제3항을 적용할 때 다른 특허출원이 제199조제2항에 따른 국제특허출원(제214조제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제3항 본문 중 "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면"으로, 같은 항 제2호 중 "출원공개"는 "출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개"로 본다.

法 207①②

⑥ (확대된 선출원: 다른 출원이 국제실용신안출원인 경우) 제4항을 적용할 때 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원(같은 법 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제4항 본문 중 "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "국제출원일까지 제출한 고안의 설명, 청구범위 또는 도면"으로, 같은 항 제2호 중 "출원공개"는 "출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개"로 본다. 法 207①②

⑦ (확대된 선출원: 국제특허출원/국제실용신안등록출원의 적용조건) 제3항 또는 제4항을 적용할 때 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원은 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보지 아니한다. 法 207①②

[전문개정 2014.6.11.]

## II 산업상 이용가능성(法 29①본문)

| 요 건    |        | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 의의     |        | 산업에서 실제 실시될 수 있는 발명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 내 용    | 산업     | 1. 최광의 개념으로 해석<br>2. 개인적·학술적·실험적 이용만 배제하는 소극적 해석(다만, 개인적·학술적·실험적으로 이용될 수 있는 것이라든 시판 또는 영업의 가능성이 있는 것은 산업상 이용가능성○)<br>3. 서비스업도 포함(단, 인터넷을 이용하지 아니한 단순한 보험업, 금융업 제외)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 이용가능성  | 1. 동일결과 반복 실시 가능성으로 장래 이용가능성이 있으면 족함(즉, 발명은 기술적 사상이면 되고 기술일 필요는 없다).<br>2. 다만, 출원일 당시 기술적 사상이어야 하고 사상이어서는 안된다(수지상 세포 사건(2001후2801)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 판 단    | 주체적 기준 | 심사관, 심판관, 법관                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 객체적 기준 | 대상 청구범위를 중심으로 발명의 설명·도면을 참작                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |        | 범위 청구항마다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 시기적 기준 | 원칙 명문의 규정은 없으나 실무상 특허출원 시 기준으로 판단                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |        | 예외 ① 무권리자에 대한 정당한 권리자의 출원의 경우 무권리자의 출원일(法 34, 35), ② 분할출원(法 52②), 분리출원(法 52의2②), 변경출원(法 53②)의 경우 원출원일, ③ 조약우선권주장출원(法 54①), 국내우선권주장출원(法 55③)의 경우 선출원일, ④ 국제특허출원의 경우 우선일의 출원 시를 기준으로 판단                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 판단방법   | 1. 의료업<br>① 인체를 직접적인 구성요소로 하는지 여부가 판단기준<br>② 직접적인 구성요소로 하는 수술방법, 치료방법, 진단방법, 인간으로부터 채취한 것을 치료를 위해 채취한 자에게 되돌려 줄 것을 전제로 처리하는 방법(혈액투석방법) 산업상 이용가능성 없음.<br>③ 간접적인 구성요소로 하거나 구성요소로 하지 아니한 i) 사람으로부터 자연적으로 배출된 것(예: 소변, 땀, 태반, 모발, 손톱) 또는 채취된 것(예: 혈액, 피부, 세포, 종양, 조직)을 처리하는 방법이 의료행위와는 분리 가능한 별개의 단계로 이루어진 방법인 경우 또는 단순히 데이터를 수집하는 방법인 경우, ii) 인체를 직접적인 구성요소로 하지 아니한 의료행위에 사용하는 의료기기·장치 및 의약품, iii) 의료기기의 작동방법 또는 의료기기를 이용한 측정방법 발명(다만, 그 구성에 인체와 의료기기 간의 상호작용이 인체에 직접적이면서 일시적이 아닌 영향을 주는 경우 또는 실질적인 의료행위를 포함하는 경우를 제외), iv) 인간 이외의 동물 한정 명시의 경우(90후250), v) 진단방법이라고 할지라도 의사의 임상적 판단(의학적 지식 및 경험을 바탕으로 질병 또는 건강상태를 판단하는 정신적 활동)을 포함하지 아니한 경우 산업상 이용가능성 있음.<br>④ 의료행위가 아닌 경우에는 인체를 구성요소로 하더라도 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하여 특허를 받을 수 없는 발명(法 32)에 해당하지 아니하면 산업상 이용가능성이 있어 특허를 받을 수 있음(모발의 웨이브방법 사건(2003허6104)).<br>⑤ 치료 효과와 비치료 효과(예: 미용효과)를 동시에 가지는 경우, 치료 효과와 비치료 효과를 구별 및 분리할 수 없는 방법은 치료방법으로 간주되어 산업상 이용가능성 불인정. 다만, i) 그 청구항이 비치료적 용도(예: 미용용도)로만 한정되어 있고, ii) 명세서에 기재되어 있는 발명의 목적, 구성 및 효과를 종합적으로 고려할 때 비치료적 용도로 그 방법의 사용을 분리할 수 있으며, iii) 어느 정도의 건강증진 효과가 수반된다고 하더라도 그것이 비치료적인 목적과 효과를 달성하기 위한 과정에서 나타나는 부수적 효과인 경우에는 산업상 이용가능성 인정.<br>2. 경제성<br>사회 경제적 요건에 따라 결정되는 상대적 개념, 고려 無.<br>3. 불성립발명<br>발명의 성립성 위반이 제한열거적인 법정거절이유(法 62)에 기재되어 있지 않기 때문에 실무상 우회적으로 산업상 이용가능성이 흠결된 것을 이유로 거절. 예를 들어, i) 오존층의 감소에 따른 자외선의 증가를 방지하기 위하여 지구표면 전체를 자외선흡수 플라스틱 필름으로 둘러싸는 방법, ii) 지구와 달을 연결하는 다리 등과 같이 현실적으로 명백하게 실시할 수 없는 발명은 사상으로 서 기술적 사상으로 구체화되지 못한 미완성 발명이므로, 산업상 이용가능성 위반으로 거절결정됨<br>4. 타법과의 관계<br>타법의 규제를 배제하는 것은 아니지만, 타법에 의하여 산업상 이용가능성이 제한받지 않음.<br>5. 결과물과의 관계<br>발명 자체를 기준으로 판단하며 발명을 이용하여 생산된 결과물의 활용상태까지 고려하지는 않음(예를 들어, 전투용 소총에 관한 생산방법). |
| 위반의 효과 |        | 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法133①)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### III 신규성(法 29①각호)

| 요 건 |                      | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 의의  |                      | 발명의 내용이 사회일반에 아직 알려지지 아니한 발명으로서 객관적으로 창작성이 있는 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 내 용 | 공지                   | 불특정인(비밀유지의무 없는 자)이 널리 알 수 있는 상태에 놓여있는 것(인식 不要)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 공연실시                 | 공연(발명의 주요부의 비밀이 해제)히 알려진 상태 또는 알려질 수 있는 상태의 실시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 반포된 간행물 게재           | 1. 반포<br>① 불특정다수인이 열람할 수 있는 상태에 놓여져 있는 것(학위논문 반포시점 - 최종심사후 도서관 등에 입고 또는 반포된 시점 / 카탈로그 제작 - 반포 추정)<br>② 간행물의 반포시기의 결정<br>- 발행시기가 기재되어 있는 경우 발행의 연도만이 기재되어 있는 때에는 그 연도의 마지막 날, 발행의 연·월이 기재되어 있는 때에는 그 연·월의 마지막 날, 발행연월일이 기재되어 있는 때에는 그 연월일에 반포된 것으로 추정<br>- 간행물의 발행시기가 기재되어 있지 아니한 경우<br>i) 외국간행물로서 국내에 입수된 시기가 분명한 때에는 그 입수된 시기로부터 발행국에서 국내에 입수되는데 소요되는 통상의 기간을 소급한 시기에 반포된 것으로 추정<br>ii) 해당 간행물에 대하여 서평·발췌·카탈로그 등을 게재한 간행물이 있으면 그 발행시기로부터 해당 간행물의 반포시기를 추정<br>iii) 해당 간행물에 관하여 중판 또는 재판 등이 있고, 여기에 초판의 발행시기가 기재되어 있을 때에는 그 초판의 발행일을 반포시기로 추정한다(다만 재판의 경우에는 재판과 초판의 인용하는 부분의 내용이 상호일치할 것을 전제).<br>2. 간행물 - 정보성과 공개성을 갖는 문서·도면 등의 정보전달매체(출원명세서원본, 비밀출판물은 간행물이 아니지만, 특허공보, 고문서는 간행물임)<br>3. 게재 - 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도이어야 하며, 언어의 종류는 불문 |
|     | 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능 | 1. 전기통신회선이란, 인터넷은 물론 전기통신회선을 통한 공중게시판, 이메일 그룹 등이 포함되며, 앞으로 기술의 발달에 따라 새로이 나타날 수 있는 전기·자기적인 통신방법도 포함<br>2. 공중의 이용가능성<br>① 일반적인 검색엔진에 의하여 접근이 불가능한 경우, ② 암호를 부여하여 불특정 다수인의 접근이 불가능한 경우, ③ 접근을 위하여 과다한 요금을 요구하는 경우 등은 사안별로 검토하여 공중이 이용가능한 경우에만 선행기술로 채택                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 주체적 기준               | 심사관, 심판관, 법관                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 판 단 | 객체적 기준               | 대상 1. 공지기술과 청구범위를 비교(판례는 미완성 발명도 공지기술이라 함)<br>2. 하나의 공지기술과 대비○, 복수의 공지기술과 대비×<br>범위 청구항마다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 시기적 기준               | 원칙 1. 출원 시(시각주의 - 특허출원 전의 해석결과)<br>2. 출원일과 간행물의 발행일이 같은 경우에 명백한 경우 제외하고는 신규성 상실× 취급<br>예외 ① 무권리자에 대한 정당한 권리자의 출원의 경우 무권리자의 출원일(法 34, 35), ② 분할출원(法 52②), 분리출원(法 52의2②), 변경출원(法 53②)의 경우 원출원일, ③ 조약우선권주장출원(法 54①), 국내우선권주장출원(法 55③)의 경우 선출원일, ④ 국제특허출원의 경우 우선일의 출원 시를 기준으로 판단                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 지역적 기준               | 국제주의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 판단방법                 | 1. 동일성 판단<br>2. 청구항에 기재된 발명이 상위개념, 공지기술이 하위 개념 - 동일성○<br>3. 청구항에 기재된 발명이 하위개념, 공지기술이 상위 개념 - 동일성 ×<br>4. 독립항 신규성○이면 종속항 신규성○, 독립항 신규성×이면 종속항 신규성 개별판단<br>5. 물건발명 신규성○이면 방법발명 또는 용도발명 신규성○, 물건발명 신규성×이면 방법발명 또는 용도발명 신규성 개별판단                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 위반의 효과               | 1. 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허취소사유(法 132의2①), 특허무효사유(法133①)(단, 법 제29조제1항제1호의 특허출원 전 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명에 해당되어 신규성에 위반된 경우는 제외되고, 등록특허공보에 게재된 선행기술에 기초한 이 유로는 특허취소신청(法 132의2) 불가)<br>2. 신규성이 없음에도 불구하고 착오로 등록된 경우에는 권리범위 불인정(81후56.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

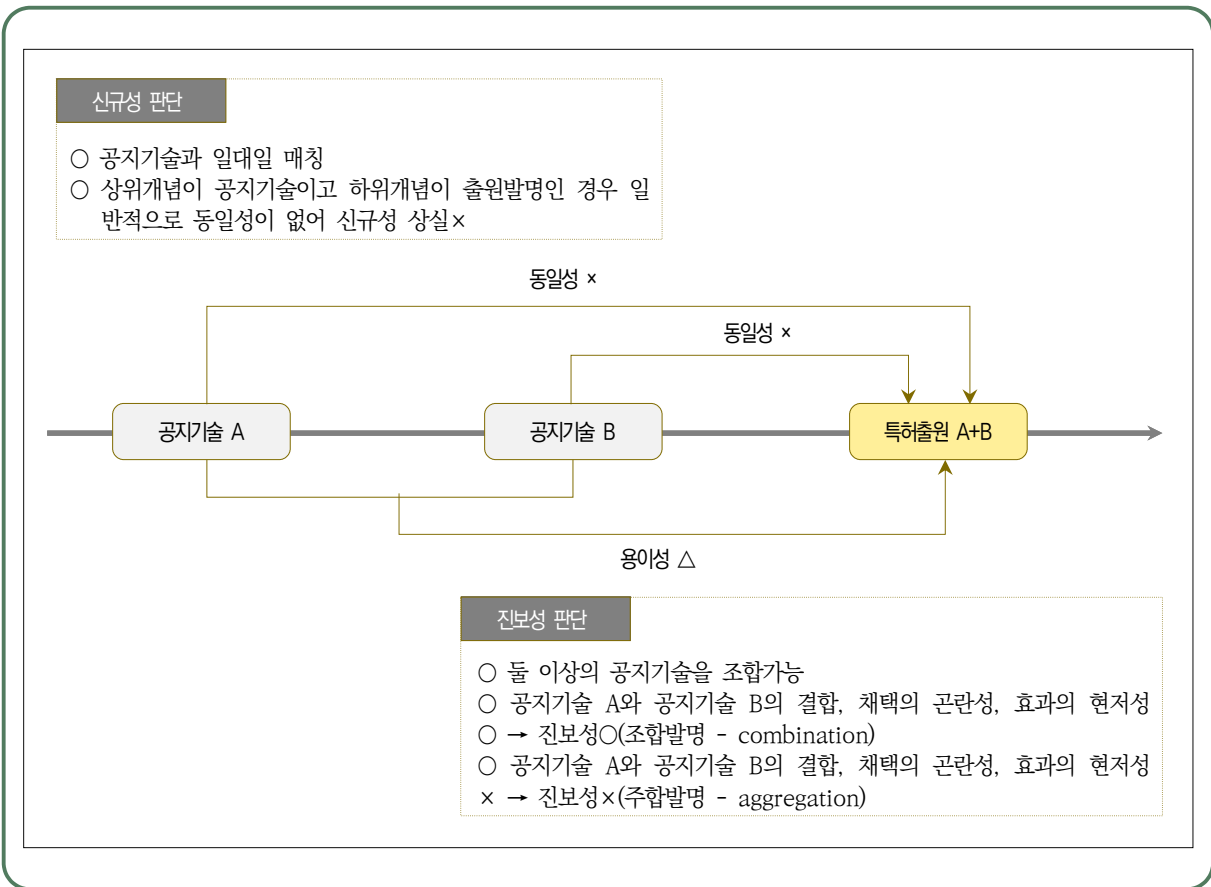


IV 진보성(法 29②)

| 요 건    |     | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 의의     |     | 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 발명할 수 없는 것으로 주관적 창작성이 있는 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 주체적 기준 |     | 심사관, 심판관, 법관이 통상의 기술자의 입장(상상의 인물, 자연인, 국내의 기술수준고려)에서 판단                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 객체적 기준 | 대상  | 1. 공지기술과 청구범위를 비교<br>2. 2이상의 공지기술을 상호 조합가능(신규성과 차이점).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 범위  | 청구항마다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 시기적 기준 | 원칙  | 출원 시(시각주의 - 특허출원 전의 해석결과)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 예외  | ① 무권리자에 대한 정당한 권리자의 출원의 경우 무권리자의 출원일(法 34, 35), ② 분할출원(法 52②), 분리출원(法 52의2②), 변경출원(法 53②)의 경우 원출원일, ③ 조약우선권주장출원(法 54①), 국내우선권주장출원(法 55③)의 경우 선출원일, ④ 국제특허출원의 경우 우선일의 출원 시를 기준으로 판단                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 지역적 기준 |     | 공지기술인지 여부에 대한 판단은 국제주의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 판 단    | 일반적 | 1. 전제 - 法 29①만족 여부를 먼저 검토 / 사후적 고찰의 금지<br>2. 일반적 판단방법 → 청구항에 기재된 구성의 곤란성, 효과의 현저성에 따라 판단<br>① 구성의 곤란성 - 통상의 기술자가 공지기술로부터 동기 유발에 의하여 또는 통상의 창작능력의 발휘를 통하여 청구항에 기재된 발명을 쉽게 생각해낼 수 있는지 여부에 대한 판단기준<br>② 효과의 현저성 - 해당 발명으로부터 초래되는 효과가 출원 당시의 기술수준으로 보아서 예측할 수 없는 유리한 효과(이질효과/동질우수효과)인지 여부에 대한 판단기준 / 구성의 곤란성을 따져 보지 않고 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단×(2019후10609) / 특허발명의 유리한 효과가 발명의 설명에 기재되어 있지 아니하더라도 통상의 기술자가 발명의 설명의 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있을 때에는 진보성 판단을 할 때 그 효과도 참작(2000후3234).<br>3. 참酌적 판단방법 - ①상업적 성공에 의한 모방품의 발생○, ②장기간 미해결 과제의 해결○, ③발명이 해당 기술분야에서 특정 기술과제에 대한 연구 및 개발을 방해하는 기술적 편견으로 인해 통상의 기술자가 포기하였던 기술적 수단을 채용하여 그 기술과제를 해결한 경우○, ④출원발명이 다른 사람이 해결하려고 하다가 실패한 기술적 곤란을 극복하는 방안을 제시하였거나 과제를 해결하는 방안을 제시하는 경우○, ⑤출원발명이 새로운 첨단 기술분야에 속해 있어 관련된 선행기술이 전혀 없는 경우 또는 가장 가까운 선행기술이 출원발명과 차이가 현격한 경우○, ⑥발명의 완성과정×, ⑦외국에의 대응특허여부×                                                                                                                       |
|        | 구체적 | 1. 독립항과 종속항의 경우 - 독립항의 진보성이 인정되는 경우에는 그 독립항에 종속되는 종속항도 진보성이 인정. 그러나 독립항의 진보성이 인정되지 아니한 경우에는 그 독립항에 종속되는 종속항에 대하여는 별도로 진보성을 판단<br>2. 청구항이 마쿠쉬 형식으로 기재된 경우 - 청구항에 기재된 발명이 마쿠쉬(Markush Claim) 등으로 기재된 경우에 그 선택요소 중 어느 하나를 선택하여 인용대상과 대비한 결과 진보성이 인정되지 않으면 그 청구항에 기재된 발명 전체에 대하여 진보성이 없는 것으로 인정.<br>3. 퇴보적 발명 - 진보성×<br>4. 발명의 카테고리가 다른 경우 - 물건의 발명이 진보성이 인정되는 경우에는 그 물건의 제조방법에 관한 발명 및 그 물건의 용도발명은 원칙적으로 진보성이 인정된다.<br>5. 주지관용기술에 의한 경우 - 지식재산치의 심사 및 특허심판원의 심판절차에서는 주지관용기술에 해당된다고 인정되는 경우 증거자료를 첨부하지 않고 거절이유를 통지할 수 있으나, 출원인이 주지관용기술이 아니라고 주장하는 경우 심사관, 심판관은 원칙적으로 그 거절이유에 대한 증거자료를 제시하여야 한다. 그러나 심결취소소송절차에서는, 주지관용기술이 소송상 공지 또는 현저한 사실이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 알려져 있지 아니한 경우에 그 주지관용기술은 심결취소소송에 있어서는 증명을 필요로 하고(변론주의 원칙), 이때 법원은 자유로운 심증에 의하여 증거 등 기록에 나타난 자료를 통하여 주지관용의 기술을 인정할 수 있으나(직권주의 가미), 변론종결 후 제출된 참고자료까지 여기의 증거 등 기록에 나타난 자료에 포함된다고 볼 수는 없다.<br>6. 부정적 교시의 경우 - 선행발명이 특허발명에 이르지 못하도록 저해하는 기재(부정적 교시)가 있다면, 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다는 유력한 근거가 된다. |
| 위반의 효과 |     | 1. 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허취소사유(法 132의2①), 특허무효사유(法133①)(단, 법 제29조 제1항제1호의 특허출원 전 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명에 해당되어 진보성에 위반된 경우는 제외되고, 등록특허공보에 게재된 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청(法 132의2) 불가)<br>2. 진보성 위반임이 명백한데 착오로 등록된 경우 특별한 사정이 없는 한 권리남용으로 권리행사 불가                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 관련문제   |     | 1. 고도성과의 관계 - 발명의 고도성은 성립요건으로서 고안과 구별하기 위한 척도이며 주관적 성질을 가지는 반면, 진보성은 특허요건으로서 객관적 성질을 갖는다. 따라서 고도성의 판단시점은 발명의 완성 시이어야 하나 실무상 진보성의 판단시점은 출원 시에 판단<br>2. 고안의 진보성과의 관계 - 고안은 발명의 “용이성”보다 낮은 정도의 창작성인 “극히 용이성”을 요구한다. 따라서 진보성 위반으로 거절이유를 받은 출원인은 발명이 실용신안등록의 대상적격인 물품의 형상·구조 또는 조합인 경우 실용신안으로 변경출원하여 실용신안등록을 고려가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## V 결합발명의 신규성, 진보성 판단



## Ⅵ 특수한 발명의 신규성, 진보성 판단

| 종 류     | 신규성 판단                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 진보성 판단                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 결합발명    | 결합발명은 선행발명에 구성요소를 더 부가한 것으로 일반적으로 선행발명과 동일성이 없으므로 신규성이 인정된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 청구항에 기재된 발명은 전체로서 고려되어야 하며 구성요소 각각이 공지 또는 자명하다고 하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 부정할 수 없다. 즉, 청구항에 기재된 발명의 과제해결원리를 배제한 채 청구항에 기재된 구성을 하나하나 분해한 후 선행기술의 대응 구성요소로부터 도출이 곤란한지만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제해결원리에 기초하여 그 발명에 채용된 특유한 구성요소들과 나머지 구성요소들 사이의 결합관계를 포함하여 유기적으로 결합된 전체로서의 진보성을 살펴보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.                                                                                                                                              |
| 선택발명    | 선행발명이 선택발명을 구성하는 그 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있어야 하고, 개시에는 선행발명을 적은 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.                                                                                                                                                                                                                                  | 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 공지된 상위개념인 선행발명과 비교하여 구성의 곤란성이 인정되어야 한다. 구성의 곤란성이 인정되는지와 관련해서는 i) 상위개념의 크기, ii) 선행발명이 선택발명을 선택할 동기를 제공하거나 선행발명에 암시가 있는지, iii) 선행발명에 기재된 하위개념발명과 선택발명이 구조적으로 유사한지 아닌지 등이 고려되어야 한다. 선택발명의 진보성을 판단할 때는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                |
| 수치한정 발명 | 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, 그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 아니한다면 그 신규성이 부정된다. 그리고 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다는 것에는, 그 수치범위의 수치가 공지된 발명을 적은 선행문헌의 실시예 등에 나타나 있는 경우 등과 같이 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다. | 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에는 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 특허발명이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서, 공지된 발명과 비교하여 이질적인 효과나 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과 차이가 생기지 않는 것이라면 진보성이 부정된다.                                                                                                                                                                               |
| 파라미터 발명 | 청구항에 기재된 파라미터가 신규하다고 해서 그 발명의 신규성이 인정되는 것은 아니고, 파라미터에 의한 한정이 공지된 물건에 내재된 본래의 성질 또는 특성 등을 시험적으로 확인한 것에 불과하거나, 파라미터를 사용하여 표현방식만 달리한 것이라면 청구항에 기재된 발명의 신규성은 부정된다. 구체적으로, 파라미터 발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 발명의 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 파라미터 발명은 신규성이 부정된다.       | 파라미터발명은 청구항에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상 이를 발명의 구성에서 제외하고 선행기술과 대비할 수 없으므로, 파라미터 발명의 경우 파라미터로부터 기인하는 성질 또는 특성 등을 감안하여 쉽게 발명될 수 있는지에 의하여 진보성을 판단한다. 구체적으로 먼저 파라미터의 도입에 기술적 의의가 있는지를 살펴야 하는바, 청구항에 기재된 파라미터가 출원 전 공지된 물성을 표현방식만 달리하여 나타낸 것에 불과하거나 공지된 물건에 내재된 본래의 성질 또는 특성을 시험적으로 확인한 것에 불과한 경우 또는 파라미터와 더 나은 효과와의 인과관계가 부족한 경우에는 기술적 의의를 인정할 수 없으므로 진보성을 부정한다. 그러나 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그로 인해 특유한 효과를 갖는다고 인정되는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다. |

Ⅶ 확대된 선출원(法 29③④⑤⑥⑦)

| 요 건    |        | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 의의     |        | 특허출원한 발명이 그 특허출원일 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 그 특허출원 후에 출원공개되거나 등록공고된 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없도록 선출원의 지위를 부여하는 것을 말한다. 「확대된 선출원」이란 강학상 용어로서 선출원으로서 후출원을 배제할 수 있는 범위가 출원공개 또는 등록공고를 요건으로 청구범위에서 출원서에 최초로 첨부된 명세서·도면 전체에 기재된 발명으로 확대된 것을 의미한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 판단     | 주체적 기준 | 심사관, 심판관, 법관                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 객체적 기준 | 대상<br>1. 다른 출원의 최초 명세서·도면과 그 특허출원의 청구범위를 비교 - 「최초」란 출원할 때 처음으로 첨부된 것을 기준으로 한다는 의미이며, 보정 유무와 무관함<br>2. 미완성은 발명은 다른 출원의 지위×(91후1656)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |        | 범위<br>청구항마다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 원칙     | 1. 의의<br>그 특허출원일 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 그 특허출원 후 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원은 출원공개되거나 등록공고되었을 것<br>2. 그 특허출원일 전의 해석<br>그 특허출원의 출원일과 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원일이 동일인 경우에는 적용×<br>3. 그 특허출원 후의 해석<br>그 특허출원의 출원일과 다른 출원의 공개일이 같은 경우에는 시각주의에 의하여 적용됨. 구체적으로 ① 그 출원의 출원 시가 다른 출원의 공개시보다 더 빠르면 확대된 선출원이 적용되며, ② 그 출원의 출원 시가 다른 출원의 공개시보다 더 늦으면 신규성(法 29①각호)이 적용되며, ③출원 시와 공개시를 알 수 없는 경우에는 심사 실무상 확대된 선출원이 적용<br>4. 출원공개 또는 등록공고의 해석<br>출원공개 또는 등록공고되지 아니한 경우 본 규정 적용 ×. 일반적으로 출원공개가 등록공고보다 먼저 되기 때문에 등록공고를 요건으로 적용되는 경우는 출원공개되지 않고 등록공고된 경우에 한함.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 시기적 기준 | 예외<br>1. 다른 출원이 분할출원(法 52②), 분리출원(法 52의2②), 변경출원(法 53②)인 경우<br>출원일이 소급되지 않고 분할출원일, 분리출원일, 변경출원일을 기준으로 한다.<br>2. 다른 출원이 조약우선권주장출원(法 54①), 국내우선권주장출원(法 55④)인 경우<br>우선권주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명중 그 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 선출원일의 다음날부터 우선권주장출원의 출원공개 또는 등록공고 전에 출원된 제3자의 발명에 대하여 확대된 선출원을 적용한다. 다만 우선권주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명중 그 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재되지 아니한 발명은 우선권주장출원일의 다음날부터 우선권주장출원의 출원공개 또는 등록공고 전에 출원된 제3자의 발명에 대하여 확대된 선출원을 적용한다.<br>3. 다른 출원이 국제특허출원인 경우<br>특허출원한 발명이 그 특허출원일 전에 국제특허출원 또는 국제실용신안등록출원을 하여 그 특허출원 후에 「출원공개 또는 특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개」되거나 등록공고된 다른 국제특허출원 또는 국제실용신안등록출원의 「국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에는 그 발명에 대해서는 확대된 선출원 위반으로 특허를 받을 수 없다(法 29⑤⑥). 다만, 출원인이 국내서면제출기간에 발명(고안)의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하여 취하된 것으로 보는 국제특허출원(국제실용신안등록출원)은 확대된 선출원 적용 시 다른 출원의 지위를 갖지 아니한다(法 29⑦). |
|        | 지역적 기준 | 속지주의 원칙상 국내출원을 기준으로 판단                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 판단방법   | 동일성 판단                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 위반의 효과 |        | 1. 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허취소사유(法 132의2①), 특허무효사유(法133①)(단, 등록특허공보에 게재된 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청(法 132의2) 불가)<br>2. 확대된 선출원 위반임에도 불구하고 착오로 등록된 경우에는 권리범위 불인정(2007후2827).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 적용의 예외 |        | 발명자가 동일(진정한 발명자 보호)하거나 그 특허출원할 때의 출원인 동일(발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명을 보호받으려는 출원인의 이익 보호)한 경우 적용×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## I 법조문

## 제36조 【선출원】(★★) 法 62 I, 63의2, 132의2①II, 133① I

- ① **(이일출원)** 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
- ② **(동일출원: 협의제)** 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.
- ③ **(이일출원)** 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것이면 제1항을 준용하고, (동일출원) 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것이면 제2항을 준용한다.
- ④ **(선출원의 지위가 없는 경우)** 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. (예외) 다만, 제2항 단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
  2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
- ⑤ **(선출원의 지위가 없는 경우)** 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다.
- ⑥ **(동일출원: 협의명령)** 지식재산처장은 제2항의 경우에 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 제2항에 따른 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다. 法 38⑦

[전문개정 2014.6.11.]

## Ⅱ 선출원주의의 조문정리(法 36)

| 구 분           | 내 용                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이일출원          | 최선의 출원인(法 36①③)                                                                                                         |
| 동일출원          | 1. 협의제(法 36②③)<br>2. 협의명령(法 36⑥)                                                                                        |
| 선출원의 지위의 인정여부 | 1. 선출원의 지위가 없는 경우<br>① 출원의 무효·취하·포기·거절결정의 확정(法 36④본문)<br>② 무권리자출원(法 36⑤)<br>2. 선출원의 지위가 있는 경우(法 36④단서) - 협의하지 않아 거절결정확정 |

### III 선출원주의(法 36)의 내용

| 요 건                     |                                                                                                                                                                       | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |                         |            |         |                     |   |   |        |   |   |         |                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------------------------|------------|---------|---------------------|---|---|--------|---|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 의의                      |                                                                                                                                                                       | 동일한 발명에 대하여 2이상의 특허출원이 있는 경우 가장 먼저 출원한 자에게 특허를 허여하는 주의                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |                         |            |         |                     |   |   |        |   |   |         |                                                                                                                                                                       |  |
| 내 용                     | 이일출원                                                                                                                                                                  | 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있으며, 이는 실용신안등록출원과 경합하는 경우에도 준용(法 36①③)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |                         |            |         |                     |   |   |        |   |   |         |                                                                                                                                                                       |  |
|                         | 동일출원                                                                                                                                                                  | 1. 협의제(法 36②③)<br>동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가 성립하지 아니 하거나(不成) 협의를 할 수 없는 경우(不能)에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다. 이는 실용신안등록출원과 경합하는 경우에도 준용.<br>2. 협의명령(法 36⑥)<br>지식재산처장은 동일출원의 경우에 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 협의제(法 36②)에 따른 협의는 성립되지 아니한 것(不成)으로 간주 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |                         |            |         |                     |   |   |        |   |   |         |                                                                                                                                                                       |  |
|                         | 선출원의 지위가 없는 경우                                                                                                                                                        | 1. 특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효·취하 또는 포기되거나 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우(法 36④). 단, 동일자 출원에 대하여 법 제36조 제2항 또는 제3항에 의한 협의 불성립 등으로 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 선출원의 지위 인정<br>2. 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원의 경우(法 36⑤)<br>3. 특허권의 무효는 선출원 지위 불인정(89후1103), 특허권의 포기는 선출원 지위 인정(2005후3017)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |                         |            |         |                     |   |   |        |   |   |         |                                                                                                                                                                       |  |
| 판 단                     | 주체적 기준                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 심사관, 심판관, 법관                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |       |                         |            |         |                     |   |   |        |   |   |         |                                                                                                                                                                       |  |
|                         | 객체적 기준                                                                                                                                                                | 대상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 선출원의 청구범위와 후출원의 청구범위                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |       |                         |            |         |                     |   |   |        |   |   |         |                                                                                                                                                                       |  |
|                         |                                                                                                                                                                       | 범위                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 청구항마다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |       |                         |            |         |                     |   |   |        |   |   |         |                                                                                                                                                                       |  |
|                         | 시기적 기준                                                                                                                                                                | 원칙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 출원일을 기준으로 선·후출원을 판단                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |       |                         |            |         |                     |   |   |        |   |   |         |                                                                                                                                                                       |  |
|                         |                                                                                                                                                                       | 예외                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ① 무권리자에 대한 정당한 권리자의 출원의 경우 무권리자의 출원일(法 34·35), ② 분할출원(法 52②), 분리출원(法 52의2②), 변경출원(法 53②)의 경우 원출원일, ③ 조약우선권주장출원(法 54①), 국내우선권주장출원(法 55③)의 경우 선출원일, ④ 국제특허출원의 경우 우선일을 기준으로 판단                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |       |                         |            |         |                     |   |   |        |   |   |         |                                                                                                                                                                       |  |
|                         | 지역적 기준                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 속지주의 원칙상 국내출원을 기준으로 판단                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |       |                         |            |         |                     |   |   |        |   |   |         |                                                                                                                                                                       |  |
| 판단방법                    |                                                                                                                                                                       | 동일성 판단                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |                         |            |         |                     |   |   |        |   |   |         |                                                                                                                                                                       |  |
| 위반의 효과                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허취소사유(法 132의2①), 특허무효사유(法133①)(단, 등록특허공보에 게재된 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청(法 132의2) 불가)<br>2. 선출원주의 위반임에도 불구하고 착오로 등록된 경우에는 권리범위 불인정(2007후2827).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |       |                         |            |         |                     |   |   |        |   |   |         |                                                                                                                                                                       |  |
| 선발명주의와의 비교              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <table><tr><th>구분</th><th>선출원주의</th><th>선발명주의</th></tr><tr><td>진정한 발명자 보호<br/>(구체적 타당성)</td><td>×(선출원자 보호)</td><td>○(선발명자)</td></tr><tr><td>판단의 용이성<br/>(법적 안정성)</td><td>○</td><td>×</td></tr><tr><td>조기공개유도</td><td>○</td><td>×</td></tr><tr><td>특허법의 태도</td><td colspan="2">1. 선출원주의의 채택<br/>2. 진정한 발명자 보호에 미흡한 점을 보완 - 선발명주의적 요소의 가미<br/>① 출원일 또는 판단시점의 소급효<br/>② 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건(法 96①Ⅲ)<br/>③ 선사용권(法 103)<br/>④ 발명자 동일시 확대된 선출원 부적용(法 29③④단서)</td></tr></table> | 구분 | 선출원주의 | 선발명주의 | 진정한 발명자 보호<br>(구체적 타당성) | ×(선출원자 보호) | ○(선발명자) | 판단의 용이성<br>(법적 안정성) | ○ | × | 조기공개유도 | ○ | × | 특허법의 태도 | 1. 선출원주의의 채택<br>2. 진정한 발명자 보호에 미흡한 점을 보완 - 선발명주의적 요소의 가미<br>① 출원일 또는 판단시점의 소급효<br>② 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건(法 96①Ⅲ)<br>③ 선사용권(法 103)<br>④ 발명자 동일시 확대된 선출원 부적용(法 29③④단서) |  |
| 구분                      | 선출원주의                                                                                                                                                                 | 선발명주의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |                         |            |         |                     |   |   |        |   |   |         |                                                                                                                                                                       |  |
| 진정한 발명자 보호<br>(구체적 타당성) | ×(선출원자 보호)                                                                                                                                                            | ○(선발명자)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |                         |            |         |                     |   |   |        |   |   |         |                                                                                                                                                                       |  |
| 판단의 용이성<br>(법적 안정성)     | ○                                                                                                                                                                     | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |                         |            |         |                     |   |   |        |   |   |         |                                                                                                                                                                       |  |
| 조기공개유도                  | ○                                                                                                                                                                     | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |                         |            |         |                     |   |   |        |   |   |         |                                                                                                                                                                       |  |
| 특허법의 태도                 | 1. 선출원주의의 채택<br>2. 진정한 발명자 보호에 미흡한 점을 보완 - 선발명주의적 요소의 가미<br>① 출원일 또는 판단시점의 소급효<br>② 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건(法 96①Ⅲ)<br>③ 선사용권(法 103)<br>④ 발명자 동일시 확대된 선출원 부적용(法 29③④단서) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |                         |            |         |                     |   |   |        |   |   |         |                                                                                                                                                                       |  |

Ⅳ 선출원주의(法 36)와 확대된 선출원(法 29③④)의 비교

| 요 건   |      |       | 선출원주의                                                                              |        | 확대된 선출원                                                                                                                                                                   |                                 |                                                          |
|-------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 서     | 의 의  |       | 동일한 발명에 대하여 둘 이상의 특허출원이 있는 때에 가장 먼저 특허출원한 자에게 특허를 허여하는 주의를 말한다.                    |        | 특허출원한 발명이 그 특허출원일 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원하여 그 특허출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에는 특허를 받을 수 없도록 선출원의 지위를 부여하는 것을 말한다. |                                 |                                                          |
|       | 취 지  |       | 발명조기공개, 중복특허금지, 권리의 안정성                                                            |        | 선출원주의의 단점 보완, 출원공개제도와 심사청구제도의 효율적 운영, 방어출원의 감소                                                                                                                            |                                 |                                                          |
| 판단    | 기준   | 주 체 적 | 판단자                                                                                |        | 심사단계 → 심사관, 심판단계 → 심판관 합의제, 법원 → 법관                                                                                                                                       |                                 |                                                          |
|       |      |       | 발명자·출원인 동일                                                                         |        | 동일 여부에 관계없이 적용                                                                                                                                                            | 발명자나 그 출원할 때의 출원인이 동일한 경우에는 부적용 |                                                          |
|       |      | 객 체 적 | 범 위                                                                                |        | 청구항별로                                                                                                                                                                     |                                 |                                                          |
|       |      |       | 대 상                                                                                |        | 선·후출원의 청구범위                                                                                                                                                               |                                 | 다른(선) 출원의 최초 명세서·도면과 그(후)출원의 청구범위                        |
|       |      |       | 선출원 보정                                                                             | 삭제     | 선출원의 지위 불인정                                                                                                                                                               |                                 | 최초 명세서·도면에 기재되어 있으면 인정                                   |
|       |      |       |                                                                                    | 추가     | 선출원의 지위 인정                                                                                                                                                                |                                 | 최초 명세서·도면에 기재되어 있지 않으면 불인정                               |
|       |      |       | 분할·분리·변경출원                                                                         |        | 원출원일로 출원일이 소급                                                                                                                                                             |                                 | 분할·분리·변경출원이 다른 출원에 해당하는 경우 분할·분리·변경출원일을 기준으로 확대된 선출원을 인정 |
|       |      |       | 무효·취하·포기·특허거절결정 확정                                                                 |        | 선출원의 지위 불인정<br>(단, 협의 불성립 등으로 특허거절결정이 확정된 경우에는 선출원의 지위 인정)                                                                                                                |                                 | 무효·취하·포기·특허거절결정확정 전 출원공개·등록공고되었으면 확대된 선출원 적용             |
|       |      |       | 무권리자                                                                               |        | 무권리자의 출원이 출원공개·등록공고되었으면 제3자에 대해서는 확대된 선출원을 적용하나, 정당한 권리자에 대해서는 발명자가 동일하기 때문에 확대된 선출원을 부적용                                                                                 |                                 |                                                          |
|       |      | 시 기 적 | 동일출원                                                                               |        | 협의제, 협의명령에 의하여 정하여진 하나의 출원인만이 특허 가능                                                                                                                                       |                                 | 적용하지 아니함(∴ 그 특허출원일 전의 해석결과)                              |
|       |      |       | 출원공개·등록공고                                                                          |        | 출원공개·등록공고여부와 관계없이 적용                                                                                                                                                      |                                 | 다른 출원이 출원공개·등록공고된 경우에만 확대된 선출원을 적용                       |
|       |      | 방 법   |                                                                                    | 동일성 판단 |                                                                                                                                                                           |                                 |                                                          |
| 총괄 효과 | 등록 전 |       | 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2)                                                         |        |                                                                                                                                                                           |                                 |                                                          |
|       | 등록 후 |       | 특허취소사유(法 132의2①), 특허무효사유(法 133①)(단, 등록특허공보에 게재된 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청(法 132의2) 불가) |        |                                                                                                                                                                           |                                 |                                                          |

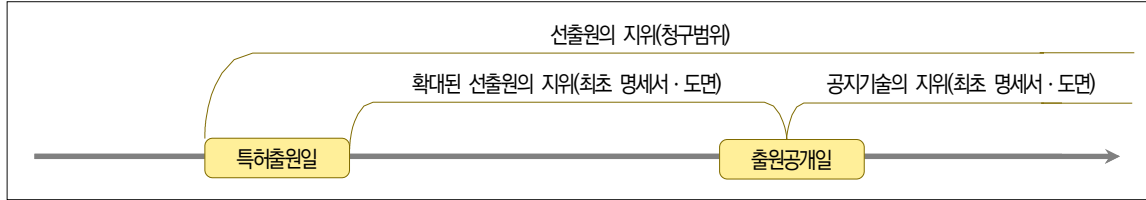
참고자료 2.2 제29조(협회의 특허요건)과 제36조(선출원주의) 판단

| 판 단      |     | 산업상<br>이용가능성        | 신규성                 | 진보성                                                                                          | 확대된 선출원                                                                                                                        | 선출원                                                                                                    |
|----------|-----|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 판단<br>기준 | 주체적 | 심사관, 심판관, 법관        |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 심사관, 심판관, 법관</li> <li>• 통상의 기술자의 입장에서 판단</li> </ul> | 심사관, 심판관, 법관                                                                                                                   |                                                                                                        |
|          | 객체적 | × vs 청구범위           | 공지기술(1개)<br>vs 청구범위 | 공지기술(1개 이상)<br>vs 청구범위                                                                       | 다른 출원의 최·명·도<br>(최초 명세서 또는 도면)<br>vs 그 출원의 청구범위                                                                                | 선출원의 청구범위 vs<br>후출원의 청구범위                                                                              |
|          | 시기적 | 법규정 ×<br>(실무상 출원 시) | 특허출원 전(출원 시)        |                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 그 특허출원일 전 다른 출원 - 역일주의(단, 동일자 적용 ×)</li> <li>• 그 특허출원 후 다른 출원의 공개 - (시각주의)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 역일주의</li> <li>- 이일: 최선출원</li> <li>- 동일: 협의제, 협의 명령</li> </ul> |
|          | 지역적 | ×                   | 국제주의                |                                                                                              | 국내주의(속지주의 원칙)                                                                                                                  |                                                                                                        |
| 판단방법     |     | 정확한 기준 ×            | 동일성                 | 용이성                                                                                          | 동일성                                                                                                                            |                                                                                                        |

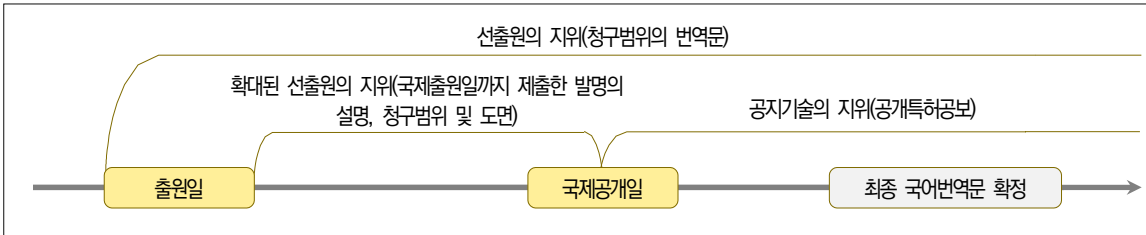


## I 출원발명의 등록금지적 효력

### 1. 통상의 국내출원의 경우

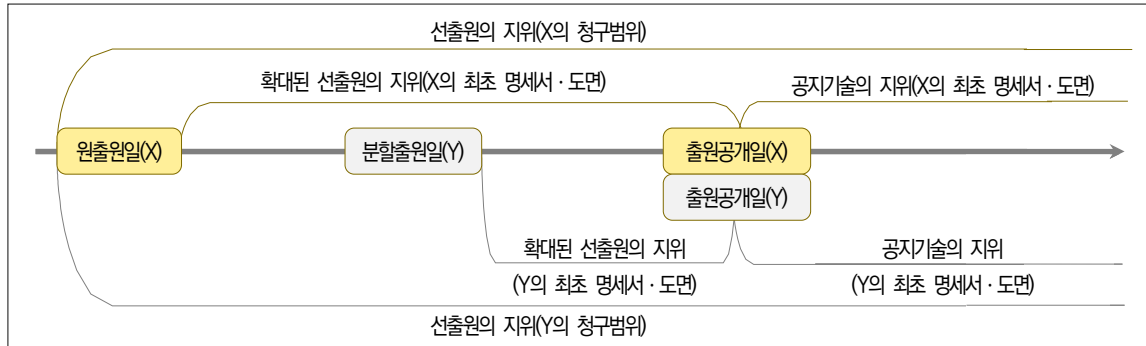


### 2. 외국어국제특허출원의 경우

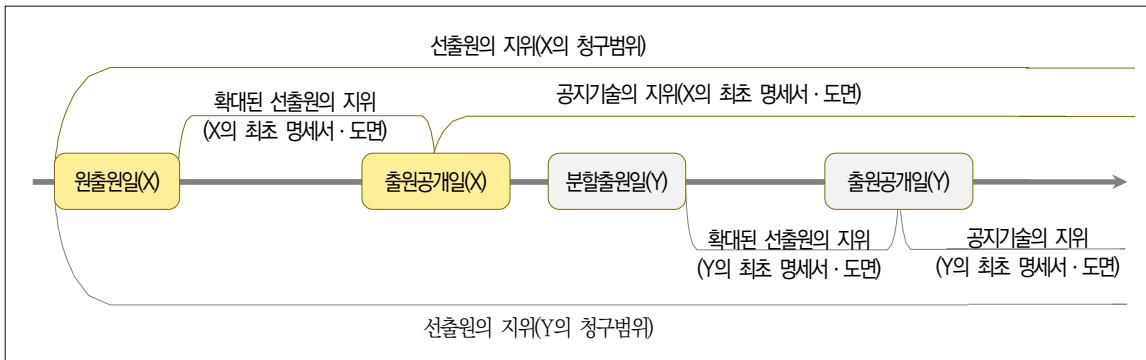


### 3. 분할출원, 분리출원의 경우

#### (1) 원출원의 출원공개 전 분할출원, 분리출원한 경우

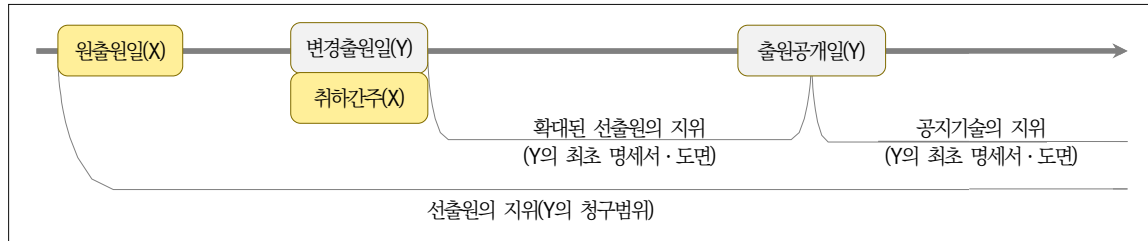


#### (2) 원출원의 출원공개 후 분할출원, 분리출원한 경우

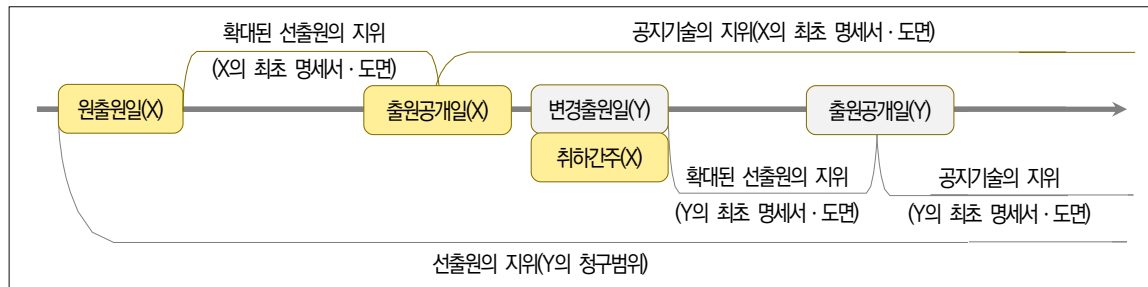


#### 4. 변경출원의 경우

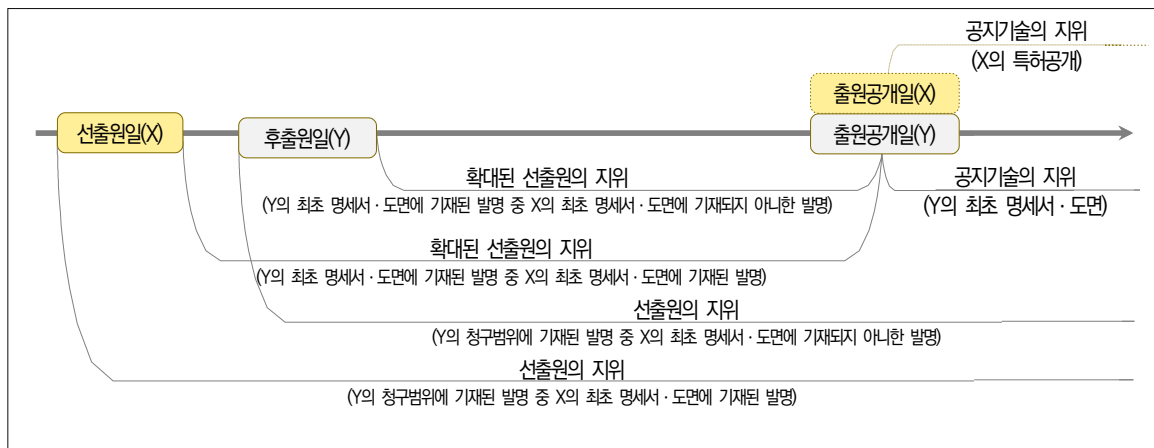
##### (1) 원출원의 출원공개 전 변경출원한 경우



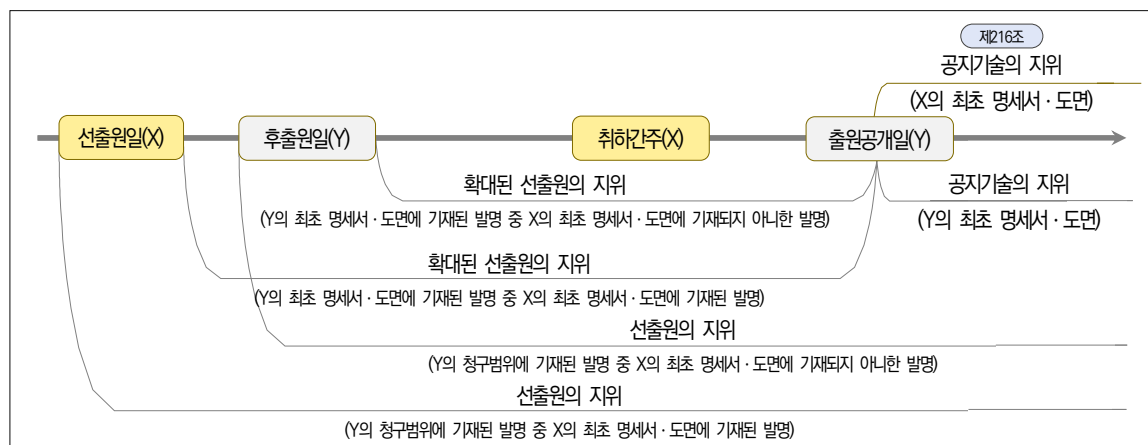
##### (2) 원출원의 출원공개 후 변경출원한 경우



#### 5. 조약우선권주장출원의 경우



#### 6. 국내우선권주장출원의 경우



## II 적용의 구체적인 예

| 유 형                                                                                                                                                                                                    | 제29조 및 제36조의 위반 여부                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                          |              |              |                         |                                  |                         |                                          |                   |                   |                         |                                  |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------------------|----|-------|-------|-------------------|
| <div><div><div>A</div><div>A, B</div></div><div>2018.1.1(X출원)2019.7.1(X공개)</div></div>                                                                                                                 | <table><tr><th></th><th>2018. 1. 5 출원</th><th>2019. 8.1 출원</th></tr><tr><td>A</td><td>제36조, 제29조제3항 위반 by X출원</td><td>제36조 위반 X출원<br/>제29조제1항 위반 by X공개</td></tr><tr><td>B1</td><td>흡결 x*</td><td>제29조제2항 위반 by X공개</td></tr><tr><td>B</td><td>제29조제3항 위반 by X출원</td><td>제29조제1항 위반 by X공개</td></tr></table> <p>* B로부터 B1를 쉽게 발명할 수 있으나, B와 B1은 동일하지 않음</p>                                                                                                                                                                                                                        |                                  | 2018. 1. 5 출원                            | 2019. 8.1 출원 | A            | 제36조, 제29조제3항 위반 by X출원 | 제36조 위반 X출원<br>제29조제1항 위반 by X공개 | B1                      | 흡결 x*                                    | 제29조제2항 위반 by X공개 | B                 | 제29조제3항 위반 by X출원       | 제29조제1항 위반 by X공개                |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |
|                                                                                                                                                                                                        | 2018. 1. 5 출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019. 8.1 출원                     |                                          |              |              |                         |                                  |                         |                                          |                   |                   |                         |                                  |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |
| A                                                                                                                                                                                                      | 제36조, 제29조제3항 위반 by X출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 제36조 위반 X출원<br>제29조제1항 위반 by X공개 |                                          |              |              |                         |                                  |                         |                                          |                   |                   |                         |                                  |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |
| B1                                                                                                                                                                                                     | 흡결 x*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 제29조제2항 위반 by X공개                |                                          |              |              |                         |                                  |                         |                                          |                   |                   |                         |                                  |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |
| B                                                                                                                                                                                                      | 제29조제3항 위반 by X출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 제29조제1항 위반 by X공개                |                                          |              |              |                         |                                  |                         |                                          |                   |                   |                         |                                  |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |
| <div><div><div>A, B</div><div>A, B, C</div></div><div>2018.1.1(X출원)2019.7.1(X공개)</div><div>2018.7.1(X보정)<div><div>A, C</div><div>A, C</div></div></div></div>                                          | <table><tr><th></th><th>2018. 6.1 출원</th><th>2019. 8.1 출원</th></tr><tr><td>A</td><td>제36조, 제29조제3항 위반 by X출원</td><td>제36조 위반 X출원<br/>제29조제1항 위반 by X공개</td></tr><tr><td>B</td><td>제29조제3항 위반 by X출원</td><td>제29조제1항 위반 by X공개</td></tr><tr><td>C</td><td>제36조, 제29조제3항 위반 by X출원</td><td>제36조 위반 X출원<br/>제29조제1항 위반 by X공개</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | 2018. 6.1 출원                             | 2019. 8.1 출원 | A            | 제36조, 제29조제3항 위반 by X출원 | 제36조 위반 X출원<br>제29조제1항 위반 by X공개 | B                       | 제29조제3항 위반 by X출원                        | 제29조제1항 위반 by X공개 | C                 | 제36조, 제29조제3항 위반 by X출원 | 제36조 위반 X출원<br>제29조제1항 위반 by X공개 |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |
|                                                                                                                                                                                                        | 2018. 6.1 출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019. 8.1 출원                     |                                          |              |              |                         |                                  |                         |                                          |                   |                   |                         |                                  |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |
| A                                                                                                                                                                                                      | 제36조, 제29조제3항 위반 by X출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 제36조 위반 X출원<br>제29조제1항 위반 by X공개 |                                          |              |              |                         |                                  |                         |                                          |                   |                   |                         |                                  |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |
| B                                                                                                                                                                                                      | 제29조제3항 위반 by X출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 제29조제1항 위반 by X공개                |                                          |              |              |                         |                                  |                         |                                          |                   |                   |                         |                                  |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |
| C                                                                                                                                                                                                      | 제36조, 제29조제3항 위반 by X출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 제36조 위반 X출원<br>제29조제1항 위반 by X공개 |                                          |              |              |                         |                                  |                         |                                          |                   |                   |                         |                                  |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |
| <div><div><div>A</div><div>A, B</div></div><div>2018.1.1(X출원)2019.7.1(Y공개)</div><div>2018.2.1(Y변경출원)2018.5.1(Y보정)<div><div>A</div><div>A, C</div></div><div><div>A</div><div>A</div></div></div></div> | <table><tr><th></th><th>2018. 1. 5 출원</th><th>2018. 3.1 출원</th><th>2019. 8.1 출원</th></tr><tr><td>A</td><td>제36조 위반 by Y출원</td><td>제36조, 제29조제3항 위반 by Y출원</td><td>제36조 by Y출원<br/>제29조제1항 위반 by Y공개</td></tr><tr><td>B</td><td>흡결 x</td><td>흡결 x</td><td>흡결 x*</td></tr><tr><td>C</td><td>흡결 x</td><td>제29조제3항 위반 by Y출원</td><td>제29조제1항 위반 by Y공개</td></tr></table> <p>* A, C로부터 B를 쉽게 발명할 수 있는 경우에는 제29조제2항 위반)</p>                                                                                                                                                              |                                  | 2018. 1. 5 출원                            | 2018. 3.1 출원 | 2019. 8.1 출원 | A                       | 제36조 위반 by Y출원                   | 제36조, 제29조제3항 위반 by Y출원 | 제36조 by Y출원<br>제29조제1항 위반 by Y공개         | B                 | 흡결 x              | 흡결 x                    | 흡결 x*                            | C | 흡결 x | 제29조제3항 위반 by Y출원       | 제29조제1항 위반 by Y공개                   |    |       |       |                   |
|                                                                                                                                                                                                        | 2018. 1. 5 출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2018. 3.1 출원                     | 2019. 8.1 출원                             |              |              |                         |                                  |                         |                                          |                   |                   |                         |                                  |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |
| A                                                                                                                                                                                                      | 제36조 위반 by Y출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 제36조, 제29조제3항 위반 by Y출원          | 제36조 by Y출원<br>제29조제1항 위반 by Y공개         |              |              |                         |                                  |                         |                                          |                   |                   |                         |                                  |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |
| B                                                                                                                                                                                                      | 흡결 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 흡결 x                             | 흡결 x*                                    |              |              |                         |                                  |                         |                                          |                   |                   |                         |                                  |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |
| C                                                                                                                                                                                                      | 흡결 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 제29조제3항 위반 by Y출원                | 제29조제1항 위반 by Y공개                        |              |              |                         |                                  |                         |                                          |                   |                   |                         |                                  |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |
| <div><div><div>A</div><div>A, B, B1</div></div><div>2018.1.1(X특허출원)2019.4.1(X취하)</div><div>2018.2.1(Y국내우선권)2019.7.1(Y공개)<div><div>A, C</div><div>A, B, C</div></div></div></div>                       | <table><tr><th></th><th>2018. 1. 5 출원</th><th>2018. 3.1 출원</th><th>2019. 8.1 출원</th></tr><tr><td>A</td><td>제36조, 제29조제3항 위반 by Y출원</td><td>제36조, 제29조제3항 위반 by Y출원</td><td>제36조 위반 by Y출원<br/>제29조제1항 위반 by Y공개, X공개</td></tr><tr><td>B</td><td>제29조제3항 위반 by Y출원</td><td>제29조제3항 위반 by Y출원</td><td>제29조제1항 위반 by Y공개, X공개</td></tr><tr><td>C</td><td>흡결 x</td><td>제36조, 제29조제3항 위반 by Y출원</td><td>제36조 위반 by Y출원<br/>제29조제1항 위반 by Y공개</td></tr><tr><td>B1</td><td>흡결 x*</td><td>흡결 x*</td><td>제29조제1항 위반 by X공개</td></tr></table> <p>* B로부터 B1를 쉽게 발명할 수 있으나, B와 B1은 동일하지 않음</p> |                                  | 2018. 1. 5 출원                            | 2018. 3.1 출원 | 2019. 8.1 출원 | A                       | 제36조, 제29조제3항 위반 by Y출원          | 제36조, 제29조제3항 위반 by Y출원 | 제36조 위반 by Y출원<br>제29조제1항 위반 by Y공개, X공개 | B                 | 제29조제3항 위반 by Y출원 | 제29조제3항 위반 by Y출원       | 제29조제1항 위반 by Y공개, X공개           | C | 흡결 x | 제36조, 제29조제3항 위반 by Y출원 | 제36조 위반 by Y출원<br>제29조제1항 위반 by Y공개 | B1 | 흡결 x* | 흡결 x* | 제29조제1항 위반 by X공개 |
|                                                                                                                                                                                                        | 2018. 1. 5 출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2018. 3.1 출원                     | 2019. 8.1 출원                             |              |              |                         |                                  |                         |                                          |                   |                   |                         |                                  |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |
| A                                                                                                                                                                                                      | 제36조, 제29조제3항 위반 by Y출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 제36조, 제29조제3항 위반 by Y출원          | 제36조 위반 by Y출원<br>제29조제1항 위반 by Y공개, X공개 |              |              |                         |                                  |                         |                                          |                   |                   |                         |                                  |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |
| B                                                                                                                                                                                                      | 제29조제3항 위반 by Y출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 제29조제3항 위반 by Y출원                | 제29조제1항 위반 by Y공개, X공개                   |              |              |                         |                                  |                         |                                          |                   |                   |                         |                                  |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |
| C                                                                                                                                                                                                      | 흡결 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 제36조, 제29조제3항 위반 by Y출원          | 제36조 위반 by Y출원<br>제29조제1항 위반 by Y공개      |              |              |                         |                                  |                         |                                          |                   |                   |                         |                                  |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |
| B1                                                                                                                                                                                                     | 흡결 x*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 흡결 x*                            | 제29조제1항 위반 by X공개                        |              |              |                         |                                  |                         |                                          |                   |                   |                         |                                  |   |      |                         |                                     |    |       |       |                   |

# 16

## 불특허발명(法 32)

### I 법조문

**제32조 【특허를 받을 수 없는 발명】(★)** 法 62Ⅰ, 63의2, 133①Ⅰ / 64④ / 154③ / 216②Ⅲ

공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 제29조제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

## II 불특허발명

| 요 건                  |       | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서                    |       | 특허를 받을 수 없는 발명에 관하여 명문규정(法 32)을 두어 특허 제도를 둘러싼 사익과 공익의 조화를 꾀하고 있으며, 우리나라는 1987년 특허법 개정시 의약 또는 둘 이상의 의약을 혼합하여 하나의 의약을 조제하는 방법발명, 화학물질발명 및 그 용도발명을, 1990년 특허법 개정시 음식물 또는 기호물의 발명을, 1995년 특허법 개정시 WTO/TRIPs 제27조제1항을 반영하여 원자핵 변환방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명을 불특허사유에서 삭제하여 특허대상의 범위가 확대되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 공서양속에 어긋날 우려가 있는 발명  | 의의    | 「공공의 질서」는 국가사회의 일반적 이익을 의미하고, 「선량한 풍속」은 사회의 일반적·도덕적 관념을 의미함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | 구체적 예 | 1. 일 반<br>i) 女體에 해를 미칠 염려가 있는 피임기구와 같이 일면 발명이 어떤 유용한 효과가 인정되더라도 보통의 경우 이를 사용할 때 공서양속을 해할 염려가 있는 경우, ii) 아편흡입기구, 위조지폐 제조기구와 같이 발명의 본래 목적이 사회질서 등을 해할 염려가 있는 발명으로서 실제 해하지는 않더라도 해할 개연성이 있는 경우, iii) 발명의 공개 또는 사용이 공서양속에 반하는 경우 등은 법 제32조 위반<br>2. 인체를 구성요소로 하는 경우<br>그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 발명 및 인간의 존엄성을 손상시키는 결과를 초래하는 발명은 공서양속에 반하여 특허가 부여되지 아니함. 또한, 식품관련발명의 경우 질병치료 등의 특수한 목적이 아닌 일상적 섭취를 위한 것임을 고려해볼 때, 인체 일부 또는 인체의 배출물을 식품의 재료로서 사용하는 것은 윤리적으로 허용될 수 없으므로 불인정.<br>3. 성(보조)기구의 경우<br>i) 노골적으로 사람의 특정 성적 부위 등을 적나라하게 표현 또는 묘사하는 음란한 물건에 해당하거나, ii) 발명의 실시가 공연한 음란행위를 필연적으로 수반할 것이 예상되거나(따라서, 공연성이 인정되지 않는 사적인 공간에서 음란행위가 수반되는 것이 예상되는 경우는 제외된다고 할 것이다), iii) 이에 준할 정도로 성적 도의 관념에 반하는 발명의 경우에만 법 제32조 위반<br>4. 본래 목적 이외의 목적에 사용할 경우<br>본래 목적 이외의 목적에 변칙적이거나 부당하게 사용한 결과 사회질서 등을 해할 염려가 있는 경우 부적용 |
| 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명 | 의의    | 제품의 안전성·품질을 확보하는 것은 다른 법률로서 규정할 문제이므로, 특허법 제32조 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명은 명백한 경우에 한하여 제한적으로 적용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | 구체적 예 | 1. 발명의 실시로 필연적으로 공중의 위생을 해하는 경우<br>발명의 실시로 필연적으로 공중의 위생을 해하는 경우 그 발명은 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 해당되어 특허를 받을 수 없다(금지물질이 발명의 실시를 위해 필연적으로 제조·활용되는 발명인 경우).<br>2. 부작용으로 인한 경우<br>발명 본래의 유익한 목적은 달성되지만 그 결과 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 경우에도 그 해를 제거하는 수단이 존재한다면, 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 것으로 보지 않고, 그 해를 제거하는 수단이 없더라도, 그 효과의 유익성과 위해성을 비교衡量하여 그 실시로 인한 부작용이 본래의 유익한 목적에서 허용될 수 있는 수준이라면 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 것으로 보지 아니함<br>3. 제조방법의 경우<br>발명이 제조방법인 경우 그 방법 자체가 공중위생을 해칠 우려가 있는지 여부를 판단하여야 할 뿐만 아니라 그 제조방법의 목적생성물이 공중위생을 해칠 우려가 있는지에 대해서도 고려<br>4. 학술서에 유해하다고 기재된 경우<br>발명이 학술서에서 유해하다고 되어있는 경우라도 국내외 관련 관청으로부터 제조 또는 사용허가를 받은 경우에는 해당 학술서의 기재만으로 법 제32조 위반 ×                                                                                                                                                                                          |
| 판단                   |       | 1. 판단시기 - 특허여부결정시를 기준으로 하는 것이 바람직<br>2. 판단방법<br>① 심사절차내에서 판단<br>② 합리적 의심이 드는 경우 - 거절이유통지 후 의견서/보정서 등 출원인의 반론 반영하여 다시 심사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 흥결효과                 |       | 1. 출원공개의 예외(승 19③)<br>2. 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法 제133①각호)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## 국방상 필요한 발명(法 41, 106)

### I 법조문

#### 제41조 【국방상 필요한 발명 등】(★) 法 106, 190

- ① (외국에의 출원금지 및 비밀취급명령) 정부는 국방상 필요한 경우 외국에 특허출원하는 것을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 특허출원의 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있다. 다만, 정부의 허가를 받은 경우에는 외국에 특허출원을 할 수 있다. 法 64③, 87④
- ② (특허 및 수용) 정부는 특허출원된 발명이 국방상 필요한 경우에는 특허를 하지 아니할 수 있으며, 전사·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다.
- ③ (보상금 지급) 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실에 대해서는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.
- ④ (보상금 지급) 제2항에 따라 특허하지 아니하거나 수용한 경우에는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.
- ⑤ (특허를 받을 수 있는 권리의 포기간주) 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 본다.
- ⑥ (보상금청구권의 포기간주) 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실보상금의 청구권을 포기한 것으로 본다.
- ⑦ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 및 비밀취급의 절차, 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 수용, 보상금 지급의 절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령(시행령 제11조 내지 제16조, 특허권의 수용 실시 등에 관한 규정)으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 시행령 제11조-제16조

##### 제11조(국방관련 특허출원의 비밀분류기준)

지식재산처장은 법 제41조제1항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급하여야 하는 발명의 선별에 필요한 분류기준(이하 “분류기준”이라 한다)을 방위사업청장과 협의하여 정하여야 한다. <개정 2006. 9. 28.>

##### 제12조(비밀취급절차)

- ① 지식재산처장은 국내에 주소 또는 영업소를 가진 자의 특허출원이 제11조의 규정에 의한 분류기준에 해당되는 경우에는 방위사업청장에게 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있는지 여부를 조회하여야 한다. <개정 2006. 9. 28.>
- ② 지식재산처장은 제1항의 규정에 의하여 방위사업청장에게 조회한 경우에는 그 특허출원의 발명자·출원인·대리인 및 그 발명을 알고 있다고 인정하는 자(이하 “발명자등”이라 한다)에게 그 사실을 통지하고 보안을 유지하도록 요청하여야 한다. <개정 2006. 9. 28.>
- ③ 방위사업청장은 제1항의 규정에 의하여 조회를 받은 경우에는 2월 이내에 회신하여야 하며, 그 특허출원에 대하여 비밀취급이 필요하다고 인정되는 경우에는 지식재산처장에게 비밀로 분류하여 취급하도록 요청하여야 한다. <개정 2006. 9. 28.>
- ④ 지식재산처장은 제3항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받은 경우에는 「보안업무규정」에 따라 필요한 조치를 취하고 그 특허출원의 발명자등에게 비밀로 분류하여 취급하도록 명하여야 하며, 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받지 아니한 경우에는 그 특허출원의 발명자등에게는 제2항의 보안유지 요청의 해제통지를 하여야 한다. <개정 2005. 1. 31.>
- ⑤ 지식재산처장은 제3항의 규정에 의한 방위사업청장의 회신을 받은 때에는 지체없이 제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급하도록 명하거나 보안유지 요청의 해제통지를 하여야 한다. <개정 2006. 9. 28.>

##### 제13조(비밀에서의 해제등)

- ① 지식재산처장은 제12조제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급할 것을 명한 특허출원에 대하여는 비밀에서의 해제, 비밀보호기간의 연장 또는 비밀등급의 변경여부를 연 2회이상 방위사업청장과 협의하여 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2006. 9. 28.>
- ② 제12조제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급할 것을 명령받은 발명자등은 지식재산처장에게 비밀에서의 해제 또는 비밀등급의 변경이나 특허출원된 발명의 일정범위의 공개 또는 실시의 허가를 청구할 수 있다.

##### 제14조(보상금)

- ① 특허출원인은 법 제41조제3항의 규정에 의하여 외국에의 특허출원이 금지됨에 따른 손실 또는 비밀로 취급됨에 따른 손실에 대한 보상금(이하 “보상금”이라 한다)을 방위사업청장에게 청구할 수 있다. <개정 2001. 6. 27., 2006. 9. 28.>
- ② 특허출원인이 제1항의 규정에 의하여 보상금을 청구하는 경우에는 보상금청구서와 손실을 증명할 수 있는 증거자료를 제출하여야 한다.

③ 방위사업청장은 특허출원인으로부터 제1항의 규정에 의한 보상금청구를 받은 경우에는 보상액을 결정하여 지급하여야 하며, 필요한 경우에는 지식재산청장과 협의할 수 있다. <개정 2006. 9. 28.>

**제15조(외국에의 특허출원금지 및 허가)**

① 국내에 주소 또는 영업소를 가진 자가 특허출원한 발명이 제12조제2항의 규정에 의하여 지식재산청장으로부터 보안유지 요청을 받거나, 동조제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급하도록 명령을 받은 경우에는 지식재산청장의 허가를 받은 경우에 한하여 외국에 특허출원을 할 수 있다.

② 외국에의 특허출원 허가를 신청하고자 하는 자는 총리령이 정하는 신청서를 지식재산청장에게 제출하여야 한다. <개정 1993. 3. 6., 1996. 6. 3., 1999. 6. 30., 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>

**제16조(방위사업청장과의 협의)**

지식재산청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 허가를 하고자 하는 경우에는 미리 방위사업청장과 협의하여야 한다.

<개정 2006. 9. 28.>

1. 제13조제2항의 규정에 의한 비밀로 취급되고 있는 발명의 일정범위의 공개 또는 실시허가
2. 제15조제2항의 규정에 의한 외국에의 특허출원 허가

[제목개정 2006. 9. 28.]

**제106조 【특허권의 수용】(★) 法 41, 190**

① **(특허권의 수용)** 정부는 특허발명이 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에는 특허권을 수용할 수 있다.

② **(부수적 권리의 소멸)** 특허권이 수용되는 경우에는 그 특허발명에 관한 특허권 외의 권리는 소멸된다.

③ **(보상)** 정부는 제1항에 따라 특허권을 수용하는 경우에는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에 대하여 상당한 보상금을 지급하여야 한다. 法 123

④ 특허권의 수용 및 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령【특허권의 수용 실시 등에 관한 규정】으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

**제229조의3 【외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령 위반죄】**

제41조제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

[본조신설 2025. 1. 21.]

**제230조 【양벌규정】(★)**

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제225조제1항【침해죄】, 제228조【허위표시의 죄】, 제229조【거짓행위의 죄】 또는 제229조의3【외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령 위반죄】의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2025. 1. 21.>

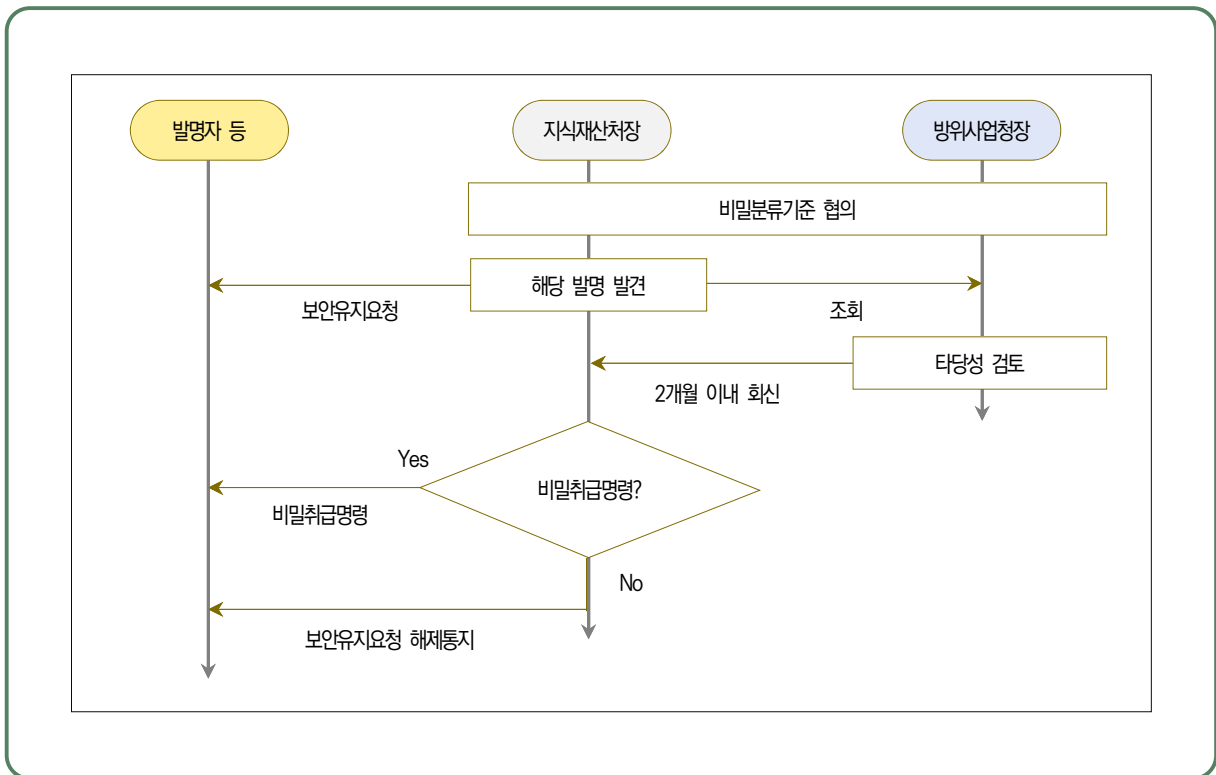
1. 제225조제1항의 경우: 3억원 이하의 벌금
2. 제228조 또는 제229조의 경우: 6천만원 이하의 벌금
3. 제229조의3의 경우: 1억원 이하의 벌금

[전문개정 2014.6.11.]

## II 조문정리

| 구분          | 법 규정      | 취 급          | 요 건                                  | 보 상       | 비 고                                                                                                                |
|-------------|-----------|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 등<br>록<br>전 | 제41조 제1항  | 외국에의<br>출원금지 | 국방상 필요                               | ○(法 41③)  | 1. 위반시 특허를 받을 수 있는 권리 포기, 보상<br>금청구권 포기 간주(法 41⑤⑥)<br>2. 위반시 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의<br>벌금형(法 229의3), 양벌규정 적용(法 230) |
|             | 제41조 제2항  | 비밀취급<br>명령   |                                      | ○(法 41④)  |                                                                                                                    |
| 등<br>록<br>후 | 제106조 제1항 | 불특허<br>수용    | 전시·사변 또는<br>이에 준하는<br>비상시에 국방상<br>필요 | ○(法 106③) | 1. 특허권 이외의 권리 소멸(法 106②)<br>2. 질권자는 보상받지 못함<br>(∴물상대위가능(法 123))                                                    |

## III 비밀취급절차





# 18

## 출원인이 될 수 있는 자(法 25, 33, 44)

### I 법조문

#### 제25조 【외국인의 권리능력】(★★) 法 62 I, 63의2, 133① I

재외자 중 외국인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 특허권 또는 특허에 관한 권리를 누릴 수 없다.

1. (상호주의) 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우
2. (상호주의) 대한민국이 그 외국인에 대하여 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우에는 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우
3. (조약에 의한 경우) 조약 또는 이에 준하는 것(이하 "조약"이라 한다)에 따라 특허권 또는 특허에 관한 권리가 인정되는 경우

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제33조 【특허를 받을 수 있는 자】(★★)

① (권리적격자=정당권리자) 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. (특허를 받을 수 없는 자) 다만, 지식재산처 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다. 法 62 II, 63의2, 133① II / 34, 35, 99의2

② (공동발명) 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다. 法 44

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제44조 【공동출원】(★★) 法 33② / 法 62 I, 63의2, 133① II / 99의2, 133① II 단서, 103의2

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

## II 출원인이 될 수 있는 자(法 25, 33, 44)

| 요 건                                                  |               | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서                                                    |               | 출원인이 되기 위해서는 ① 일반적인 권리의 주체가 될 수 있는 능력인 권리능력이 있어야 하며, ② 권리능력이 있는 자라 하더라도 해당 발명에 대한 권리의 주체가 될 수 있는 권리적격이 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 권리능력자                                                | 내국인           | 자연인, 법인(국가, 지방자치단체도 법인으로 의제, 단 국가기관(경북대학교 사건(96후825))은 권리능력 x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                      | 외국인<br>(法 25) | 1. 재내자 - 권리능력 ○<br>2. 재외자<br>① 원칙 - 권리능력 x<br>② 예외<br>- 상호주의(法 25 I, II)<br>- 조약에 의한 경우(法 25Ⅲ) - 조약당사국 국민, 준당사국 국민(무국적자)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 권리적격자<br>(= 정당한 권리자<br>= 특허를 받을 수<br>있는 권리를 가진<br>자) | 발명자           | 자연인 ○ / 법인 x(·: 발명행위는 사실행위) / 인공지능 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                      | 승계인           | 자연인 ○ / 법인 ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      | 공동발명          | 1. 공동발명 → 특허를 받을 수 있는 권리의 공유(法 33②) → 공동출원(法 44)<br>2. 공동발명이란?<br>① 2인 이상의 자연인이 실질적으로 협력하여 완성한 발명<br>② 실질적 관여 여부는 발명의 착상단계에서 구체화하는 단계에 실질적으로 관여한 것을 의미<br>③ 단순한 보조자, 관리자, 위탁자, 자본주 등은 공동발명자 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | 문제되는<br>경우    | 1. 지식재산처·심판원 직원 - 상속이나 유증의 경우를 제외하고는 재직중 특허 x(法 33①단서)<br>(단, 특허를 받을 수 있는 권리는 가점)<br>2. 무권리자 - 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자를 말하며, 法 제33조 제1항 본문위반                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 총결효과                                                 |               | 1. 法 25, 法 33①본문·단서, 法 44 위반의 경우 - 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法 133①)<br>2. 법 제33조제1항 본문 위반과 관련하여<br>① 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 승계인이 다시 특허를 받을 수 있는 권리를 재양도한 후 출원한 경우에 무권리자 출원(2006허6143)<br>② 발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 후 스스로 특허출원한 경우에도 무권리자 출원(2020후10087)<br>③ 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경했다라도, 그 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 아니한 경우도 무권리자에 포함(2009후2463)<br>3. 법 제44조 위반과 관련하여 - 공유자 중 일부가 나머지 공유자로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 모두를 이전받아 단독 권리자가 된다면 그 하자는 치유(2004허5894)<br>4. 무효심판청구와 관련하여<br>① 청구인 - 법 제33조제1항 본문, 제44조 위반의 경우 이해관계인이더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허무효심판을 청구<br>② 증명책임 - 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자(무효심판청구인)에게 있다(2019후11268).<br>③ 후발적 사유 - 특허된 후에 특허권자가 외국인의 권리능력 규정(法 25)에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자가 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우 특허무효심판에 의하여 무효가 되면 그 사유가 발생한 날로부터 장래를 향하여 특허권이 소멸<br>5. 이전청구와 관련하여 - 法 33①본문 또는 法 44 위반으로 특허무효사유(法 133①II)에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 법원에 이전청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 해당 특허권과 보상금 지급 청구권(法 65②, 207④)은 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다. 이전청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 법 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다(法 99의2). 한편, 이전청구에 기초하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 이전등록(法 99의2)이 있으면 이전등록된 특허권(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)은 특허무효심판을 청구할 수 있는 대상에서 제외된다(法 133①II 단서). |

# 19

## 특허를 받을 수 있는 권리(法 37, 38)

### I 법조문

#### 제37조 【특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등】(★★) 法 99

- ① (이전) 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다. 法 38
- ② (질권설정 不可) 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다.
- ③ (공유) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제38조 【특허를 받을 수 있는 권리의 승계】(★★)

- ① (특허출원 전 승계) 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다.
- ② (동일자 출원: 협의제) 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있으면 특허출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생한다.
- ③ (동일자 출원: 협의제) 동일한 자로부터 동일한 발명 및 고안에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 및 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 특허출원 및 실용신안등록출원이 있으면 특허출원인 및 실용신안등록출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생한다.
- ④ (특허출원 후 승계) 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다. 法 101① I
- ⑤ (특허출원 후 승계: 상속 기타 일반승계) 특허를 받을 수 있는 권리의 상속, 그 밖의 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다.
- ⑥ (동일자 출원인변경신고: 협의제) 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원인변경신고가 있으면 신고를 한 자 간에 협의하여 정한 자에게만 신고의 효력이 발생한다.
- ⑦ (협의명령) 제2항·제3항 또는 제6항의 경우에는 제36조제6항[협의명령]을 준용한다.

[전문개정 2014.6.11.]

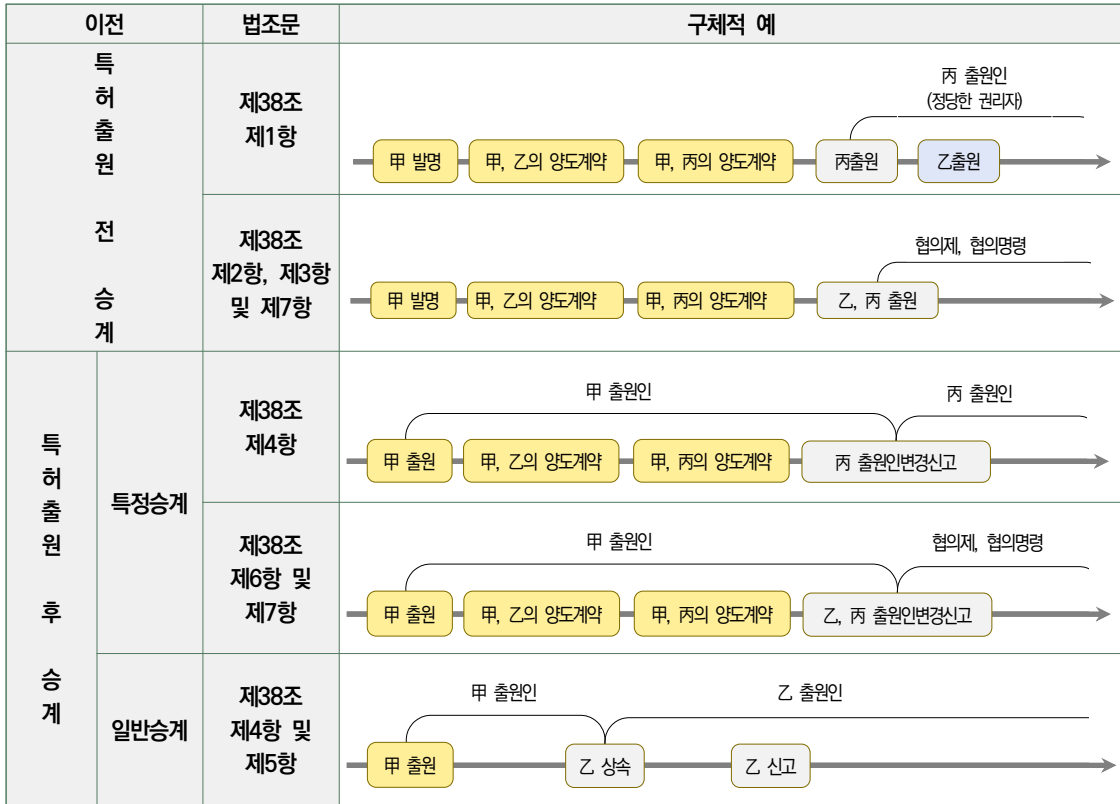
■ 이전 = 특정승계(양도) + 일반승계(상속)

## II 특허를 받을 수 있는 권리(法 37)

| 권 리 |                    | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |          |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|
| 서   | 의의                 | 발명의 완성에 의하여 발생하고 발명자에게 원시적으로 귀속되는 권리로서, 특허출원에 대한 거절결정이 확정되거나 설정등록되기 전까지 인정되는 권리를 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |          |
|     | 취지                 | 특허권의 발생이전 단계에서 발명자 또는 승계인을 보호하기 위한 소정의 권리부여 필요                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |          |
|     | 법적성질               | 특허부여 요구설, 발명자권설, 병합설 중 다수설은 특허부여 요구설과 발명자권설을 병합하는 병합설                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |          |
| 발생  |                    | 특허요건의 구비 여부와는 별개로 발명의 완성에 의하여 발생                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |          |
| 효력  | 특허부여<br>요구권적<br>효력 | 1. 권리부여의 요구 - 정당한 권리자인 발명자 또는 승계인은 특허를 받을 수 있는 권리에 기인하여 국가에 대하여 특허부여를 요구할 수 있으며 이를 특허출원이라 한다. 즉, 「특허출원」이라 함은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명의 공개를 전제로 하여 지식재산처에 대하여 특허권을 받으려는 의사를 객관적으로 표시하는 행위를 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |          |
|     |                    | 2. 타인의 등록금지 - 특허출원한 후 출원공개된 경우 선출원의 지위(法 36), 공지기술의 지위(法 29①각 호, 29②), 확대된 선출원의 지위(法 29③④)에 의하여 타인의 등록을 금지시킬 수 있는 효력이 발생한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |          |
|     |                    | 시기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 선출원의 지위 | 확대된 선출원의 지위 | 공지기술의 지위 |
|     |                    | 공개전 소멸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 불인정     | 불인정         | 불인정      |
|     |                    | 공개후 소멸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 불인정     | 인정          | 인정       |
| 효력  | 발명자권<br>적 효력       | 1. 인격권 - 발명자는 발명의 완성과 동시에 발명자 인격권을 갖는다. 파리조약 제4조의3은 “발명자는 특허증에 발명자로서 기재되는 권리를 갖는다”라고 규정되어 있고, 발명자 인격권은 간접적으로 발명자 게재권으로 인정되고 있다. 한편 시행규칙 제28조에 따라 발명자의 추가 또는 정정이 가능함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |          |
|     |                    | 2. 재산권<br>① 발명의 실시 - 정당한 권리자는 타인의 권리 또는 법에 저촉되지 않는 한 발명을 자유롭게 실시할 수 있다. 타인이 먼저 특허출원을 한다면 타인이 특허권을 획득하여 타인의 특허권의 침해를 이유로 정당한 권리자의 실시를 금지시킬 수 있다. 다만, 정당한 권리자는 일정한 경우 선사용에 의한 통상실시권(法 103) 또는 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건(法 96①Ⅲ)에 관한 규정에 의하여 보호받을 수 있다.<br>② 침해행위에 대한 보호 - 권리자의 특허출원에 대해서는 정당한 권리자의 출원에 출원일 소급효 인정(法 34, 35)이나 무권리자의 특허의 이전청구(法 99의2)를 통해, 무단공표에 대해서는 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우(法 30)에 의해, 무단실시행위에 대해서는 보상금청구권(法 65)을 통해 특허법상 보호받을 수 있다. 다만, 보상금청구권이 인정된다고 하더라도 특허권 발생 이전에는 타인의 실시를 금지시킬 수 없다. |         |             |          |
| 변동  | 이전                 | 특허를 받을 수 있는 권리는 출원 전·후를 불문하고 이전할 수 있다(法 37①). 또한, 지분에 대한 일부 이전도 가능하다. 이전하였을 때 효력은 출원전과 출원후로 구분하여 제38조에서 규정함.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |          |
|     | 질권설정<br>금지         | 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적이 될 수 없다(法 37②). 질권설정 불가 이유(法 37②)에 대하여는 불측의 손해설(불확정 권리), 탈취설(싼 값), 권리훼손설(신규성 상실), 거래 안전설(공시방법×) 등이 있음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |          |
|     | 수용 등               | 정부는 특허출원한 발명이 국방상 필요한 경우에는 외국에 특허출원하는 것을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 특허출원의 발명을 비밀로 취급하도록 명하거나 또는 불특허할 수 있으며, 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다(法 41①②).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |          |
|     | 강제집행               | 질권의 목적이 될 수 없으므로 권리의 성질상 강제집행의 대상도 될 수 없다고 본다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |          |
| 소멸  | 출원절차<br>종료         | 출원의 무효·취하·포기 또는 출원에 대한 거절결정이 확정되거나 설정등록이 되면 특허를 받을 수 있는 권리는 소멸한다. 다만, 출원의 무효·취하·포기 또는 거절결정의 확정에 의한 소멸은 선출원의 지위가 남지 않으므로 출원공개전이라면 재출원할 수 있어 상대적 소멸이라 할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |          |
|     | 권리능력<br>상실         | 외국인이 권리능력을 상실하거나 상속인이 존재하지 아니한 경우 등 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 권리능력이 소멸한 경우에 특허를 받을 수 있는 권리는 소멸한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |          |

|    |            |                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 공유 | 의의         | 2인 이상이 공동으로 발명한 때(法 33②) 또는 단독발명 후 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 일부를 타인에게 이전하는 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 공유가 된다.                                                                                                          |
|    | 지분양도       | 1. 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다(法 37③). 새로운 공유자의 자본력·신용력·기술력 여하 등이 다른 공유자의 이해관계에 지대한 영향을 미치기 때문이다.<br>2. 다만, 지분의 상속, 공유자끼리의 지분양도는 다른 공유자의 동의없이 가능하다.              |
|    | 공동출원       | 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다(法 44). 공동발명임에도 불구하고 1명이 단독으로 출원한 경우에는 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法 133①)이다. 다만, 등록 후 법원에 이전청구 가능하고(法 99의2), 이전청구에 기초하여 이전등록이 있으면 특허무효사유에서 제외 |
|    | 공동심판 청구    | 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(法 139③). 이에 위반하여 단독으로 심판을 청구한 경우 심결각하(法 142).                                                                               |
|    | 심결취소 소송 제기 | 거절결정불복심판의 기각심결에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 중 일부가 심결취소의 소 제기 가능(인용/기각 모두 합일확정의 요청에 반하지 않음)                                                                                                                  |

III 특허를 받을 수 있는 권리의 승계(法 38)



| 이전형식<br>이전시기 | 일반승계                                                                                                                                                      | 특정승계                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 출원 전         | 1. 사유발생시 효력발생<br>2. 승계인이 특허출원 → 제3자 대항요건(法 38①)<br>3. 동일자 출원<br>① 협약제, 협의명령(法 38②③⑦) → 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력발생<br>② 협의가 성립되지 아니하면 승계의 효력 불발생 → 무권리자 출원으로 간주 |                                                                                                                                                            |
| 출원 후         | 1. 사유발생시 효력 발생(∵ 권리의 단절 막기 위해)<br>2. 승계인이 지식재산처장에 신고 要(法 38⑤)                                                                                             | 1. 승계인의 출원인변경신고 → 효력발생요건<br>2. 동일자 출원인변경신고<br>① 협약제, 협의명령(法 38⑥⑦) → 협의하여 정한 자에게만 출원인변경신고의 효력발생<br>② 협의가 성립되지 아니하면 출원인변경신고의 효력 불발생 → 피승계인이 출원인인 상태로 출원절차 진행 |



## 직무발명(발진법 2, 10~19, 58)

### I 법조문

#### 발명진흥법 제2조 [정의]

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2010. 1. 27., 2010. 6. 8., 2013. 7. 30., 2015. 5. 18., 2023. 1. 3., 2024. 2. 6.>

1. "발명"이란 「특허법」, 「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.
2. **(직무발명의 정의)** "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원 등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자 등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.
3. "개인발명가"란 직무발명 외의 발명을 한 자를 말한다.
4. "산업재산권"이란 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」 또는 「상표법」에 따라 등록된 특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권을 말한다.
5. "특허관리전담부서"란 사용자 등에서 산업재산권에 관한 기획, 조사 및 관리 등의 업무를 담당하는 부서를 말한다.
- 5의2. "공익변리사"란 제26조의2에 따라 설치된 공익변리사 특허상담센터에서 업무를 수행하는 변리사를 말한다.
6. 삭제 <2024. 2. 6.>
7. 삭제 <2024. 2. 6.>
8. 삭제 <2024. 2. 6.>
9. "산업재산권 서비스업"이란 산업재산권의 창출·보호·활용을 지원하는 다음 각 목의 서비스업을 말한다.
  - 가. 산업재산권에 관한 정보를 수집·분석·가공·변역·유통 또는 관리하거나 이와 관련한 소프트웨어 또는 시스템을 개발하거나 구축하는 업
  - 나. 「변리사법」 제2조에서 규정하는 업
  - 다. 산업재산권의 경제적 가치 및 기술적 우수성을 가액(價額)·등급 또는 점수 등으로 평가하는 업
  - 라. 산업재산권의 양도 또는 실시권의 설정·허락 등 산업재산권의 거래행위를 중개·알선하는 업
  - 마. 그 밖에 대통령령으로 정하는 업
10. "산업재산권 서비스사업자"란 산업재산권 서비스업을 영위하는 자를 말한다.

#### 발명진흥법 제10조 [직무발명]

- ① **(법정실시권의 성립요건)** 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다. 다만, 사용자 등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원 등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013.7.30>
  1. 종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자 등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정
  2. 종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정
- ② **(공무원의 직무발명의 승계 및 소유)** 제1항에도 불구하고 공무원 또는 국가나 지방자치단체에 소속되어 있으나 공무원이 아닌 자(이하 "공무원등"이라 한다)의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계할 수 있으며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원등의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교(이하 "국·공립학교"라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계할 수 있으며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권 등은 그 전담조직의 소유로 한다. <개정 2021. 4. 20.>
- ③ **(예약승계)** 직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.
- ④ **(국유특허권의 처분 및 관리)** 제2항에 따라 국유로 된 특허권 등의 처분과 관리(특허권 등의 포기를 포함한다)는 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 지식재산처장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2009.1.30., 2010.1.27.>



### 발명진흥법 제10조의2 【공무원등의 직무발명 처분의 특례】

「국유재산법」 제65조의11제2항 단서에도 불구하고 지식재산처장이 정하여 고시하는 경우에는 제10조제2항에 따라 국유로 된 특허권등에 관한 전용실시권 설정을 한 번 이상 갱신할 수 있다. [본조신설 2021. 4. 20.]

### 발명진흥법 제11조 【직무발명보상제도의 실시와 지원시책】

- ① 정부는 종업원 등의 직무발명을 장려하기 위하여 직무발명보상제도 등의 실시에 관한 지원시책을 수립·시행하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 지원시책에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다. <개정 2013.7.30>
  1. 표준이 되는 보상규정의 작성 및 보급
  2. 보상과 관련된 분쟁을 예방 및 해결하기 위한 합리적인 절차규정의 작성 및 보급
  3. 직무발명보상제도의 실시·운영에 관한 상담 등의 지원
- ③ 정부는 직무발명에 대한 보상을 실시하는 사용자 등에 대하여는 제3장과 제4장에 따른 발명의 권리화와 사업화를 촉진하기 위한 조치를 먼저 하여야 한다.

### 발명진흥법 제11조의2 【직무발명보상 우수기업 인증 등】

- ① 지식재산처장은 제11조제1항에 따른 직무발명보상제도의 활성화를 위하여 직무발명보상제도를 모범적으로 운영하는 기업을 직무발명보상 우수기업(이하 “우수기업”이라 한다)으로 인증할 수 있다. <개정 2024. 2. 6.>
  - ② 우수기업 인증을 받고자 하는 기업은 지식재산처장에게 신청하여야 한다. <신설 2024. 2. 6.>
  - ③ 지식재산처장은 제2항에 따른 인증신청을 받은 경우에는 인증을 받으려는 기업에 대한 심사를 하고, 인증기준에 적합하면 유효기간을 정하여 인증을 하여야 한다. <신설 2024. 2. 6.>
  - ④ 지식재산처장은 인증받은 우수기업이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 인증을 취소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 인증을 취소하여야 한다. <신설 2024. 2. 6.>
    1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 인증을 받은 경우
    2. 제6항에 따른 인증기준에 적합하지 아니하게 된 경우
  - ⑤ 국가 및 지방자치단체는 인증받은 우수기업에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. <신설 2024. 2. 6.>
  - ⑥ 우수기업 인증의 기준, 절차, 재인증, 유효기간, 그 밖에 인증에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2024. 2. 6.>
- [본조신설 2013. 3. 22.]  
[제목개정 2024. 2. 6.]

### 발명진흥법 제12조 【직무발명 완성사실의 통지】

종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원 등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다. <개정 2022. 11. 15.>

### 발명진흥법 제13조 【직무발명의 권리승계】

- ① (예약승계계약의 체결 등이 있는 경우) 제12조에 따라 통지를 받은 사용자 등이 종업원 등의 직무발명에 대하여 미리 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 정한 경우에는 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자 등에게 승계된다. 다만, 사용자 등이 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리를 승계하지 아니하기로 종업원 등에게 통지하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2024. 2. 6.>
- ② (예약승계계약의 체결 등이 없는 경우) 제1항에 따른 계약 또는 근무규정이 모두 없는 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 제12조에 따라 통지를 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 서면으로 알려야 한다. 이 경우 사용자 등은 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다. <개정 2024. 2. 6.>
- ③ (예약승계계약의 체결 등이 없는 경우) 사용자 등이 제2항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자 등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원 등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다. <개정 2024. 2. 6.>

[제목개정 2024. 2. 6.]

### 발명진흥법 제14조 【공동발명에 대한 권리의 승계】

종업원 등의 직무발명이 제삼자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.



### 발명진흥법 제15조 【직무발명에 대한 보상】

- ① **(보상받을 권리)** 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 상당한 보상을 받을 권리를 가진다.
- ② **(보상규정의 작성 및 통지)** 사용자 등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원 등에게 서면으로 알려야 한다. <개정 2013.7.30., 2022. 11. 15>
- ③ **(보상규정의 변경)** 사용자 등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원 등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원 등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원 등의 과반수의 동의를 받아야 한다. <개정 2013.7.30>
- ④ **(보상사항의 통지)** 사용자 등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원 등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다. <신설 2013.7.30>
- ⑤ 사용자 등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원 등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2013.7.30>
- ⑥ **(보상규정에 따른 보상의 효력)** 사용자 등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원 등에게 보상한 경우에는 상당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2013.7.30>
- ⑦ **(공무원의 직무발명에 대한 보상받을 권리)** 공무원 등의 직무발명에 대하여 제10조 제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 상당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다. <개정 2013.7.30>

### 발명진흥법 제16조 【출원 유보사의 보상】

사용자 등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원(出願)하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 상당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원 등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

### 발명진흥법 제16조의2 【승계한 권리의 포기 및 종업원등의 양수】

- ① **(의의)** 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 공공연구기관(이하 이 조에서 “공공연구기관”이라 한다)이 국내 또는 해외에서 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권등(이하 “직무발명에 대한 권리”라 한다)을 종업원등으로부터 승계한 후 이를 포기하는 경우 해당 직무발명을 완성한 모든 종업원등은 그 직무발명에 대한 권리를 양수할 수 있다.
- ② **(종업원 등의 양수 불가)** 제1항에도 불구하고 공공연구기관의 장이 대통령령으로 정하는 바에 따라 공공의 이익을 위하여 특별히 직무발명에 대한 권리를 포기할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 권리를 종업원등에게 양도하지 아니할 수 있다. 이 경우 공공연구기관의 장은 제3항의 기간 내에 종업원등에게 그 사유를 구체적으로 알려야 한다.
- ③ **(종업원 등의 양수: 포기통지)** 제1항에 따라 직무발명에 대한 권리를 포기하려는 공공연구기관의 장은 대통령령으로 정하는 기간 내에 해당 직무발명을 완성한 모든 종업원등에게 그 사실을 통지하여야 한다.
- ④ **(종업원 등의 양수: 양수의사통지)** 제3항에 따른 통지를 받은 종업원등은 직무발명에 대한 권리를 양수하려는 경우 통지를 받은 날부터 대통령령으로 정하는 기간 내에 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 공공연구기관의 장에게 서면으로 알려야 한다. <개정 2022. 11. 15>
- ⑤ **(종업원 등의 양수: 양수시기)** 제4항에 따라 종업원등이 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 알린 경우 제4항의 기간이 끝난 날의 다음 날부터 그 권리가 종업원등에게 양도된 것으로 본다. 이 경우 공공연구기관이 직무발명에 대한 권리를 제3자와 공유한 경우에는 공공연구기관의 장이 다른 공유자 모두의 동의를 받은 때에 한정하여 그 권리가 양도된 것으로 본다.
- ⑥ **(종업원 등의 양수: 공유)** 제4항에 따라 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 알린 종업원등이 2명 이상인 경우에는 그 권리를 공유한다.
- ⑦ **(유지 및 비용분담 협의)** 공공연구기관의 장과 종업원등은 공공연구기관이 직무발명에 대한 권리를 계속 유지하기 위한 비용을 종업원등이 일부 부담하는 대신 직무발명에 대한 종업원등의 보상을 조정하는 방안을 제3항의 기간 내에 상호 협의할 수 있다.
- ⑧ **(종업원 등의 양수: 비용부담)** 공공연구기관의 장은 제5항 전단에 따라 직무발명에 대한 권리가 종업원등에게 양도된 것으로 보는 날 이후 그 권리와 관련하여 발생하는 비용(세금을 포함한다)을 종업원등에게 청구할 수 있다.

[본조신설 2021. 4. 20.]

### 발명진흥법 제17조 【직무발명심의위원회의 운영 등】

- ① 사용자 등은 종업원 등의 직무발명에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 직무발명심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)를 설치·운영할 수 있다. <개정 2013.7.30>

1. 직무발명에 관한 규정의 작성·변경 및 운용에 관한 사항
  2. 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관한 종업원 등과 사용자 등의 이견 조정에 관한 사항
  3. 그 밖에 직무발명과 관련하여 필요한 사항
- ② 심의위원회는 사용자 등과 종업원 등(법인의 임원은 제외한다)을 각각 대표하는 같은 수의 위원으로 구성하되, 필요한 경우에는 관련 분야의 전문가를 자문위원으로 위촉할 수 있다. <개정 2013.7.30>
- ③ 그 밖에 심의위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2013.7.30>

#### 발명진흥법 제18조 【직무발명 관련 분쟁의 조정 등】

- ① 종업원 등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사용자 등에게 심의위원회를 구성하여 심의하도록 요구할 수 있다. <개정 2024. 2. 6>
1. 직무발명인지 여부에 관하여 사용자 등과 이견이 있는 경우
  2. 사용자 등이 제10조제3항을 위반하여 종업원 등의 의사와 다르게 직무발명 외의 발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우
  3. 사용자 등이 제13조제2항을 위반하여 종업원 등의 의사와 다르게 직무발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우
  4. 사용자 등이 제10조 제1항 단서 또는 제13조 제3항을 위반하여 통상실시권을 주장하는 경우
  5. 사용자 등이 제시한 보상규정에 이견이 있는 경우
  6. 사용자 등과의 협의 또는 동의 절차에 이견이 있는 경우
  7. 사용자 등이 제15조 제4항에 따라 통지한 보상액 등 보상의 구체적 사항에 이견이 있는 경우
  8. 사용자 등이 제15조 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원 등에게 보상하지 아니하는 경우
  9. 그 밖에 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관하여 사용자 등과 종업원 등 간에 이견이 있는 경우
- ② 제1항에 따른 권리는 제1항 각 호의 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 행사하여야 한다. 다만, 제1항 제7호의 경우에는 종업원 등이 통지를 받은 날부터 30일 이내에 행사하여야 한다.
- ③ 사용자 등은 제1항에 따른 요구를 받은 경우에 60일 이내에 심의위원회를 구성하여 심의하도록 하여야 한다. 이 경우 심의위원회에는 직무발명 관련 분야의 전문가인 자문위원이 1명 이상 포함되도록 하여야 한다.
- ④ 제3항에 따른 심의위원회는 심의의 결과를 사용자 등과 종업원 등에게 지체 없이 서면으로 통지하여야 한다.
- ⑤ 정부는 사용자 등의 요청에 따라 관련 분야의 전문가를 제3항에 따른 자문위원으로 파견할 수 있으며, 이에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑥ 제3항에 따른 심의위원회의 심의 결과에 불복하거나 직무발명과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 사용자 등 또는 종업원 등은 제41조에 따른 산업재산분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다.

#### 발명진흥법 제19조 【비밀유지의 의무】

- ① 종업원 등은 사용자 등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자 등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013.7.30>
- ② 제18조 제3항에 따라 자문위원으로 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. <신설 2013.7.30>

#### 발명진흥법 제58조 【벌칙】

- ① 국내외에서 정당한 사유 없이 제55조의9제1항에 따른 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <신설 2024. 2. 6>
- ② **(비밀유지의무)** 제19조를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2024. 2. 6>
- ③ 제31조의7을 위반한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <신설 2023. 1. 3., 2024. 2. 6>
- ④ **(친고죄)** 제1항 및 제2항의 죄는 비밀유지명령을 신청한 자 및 사용자 등의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다. <개정 2023. 1. 3., 2024. 2. 6>

## II 직무발명(발진법 2, 10~19, 58)

| 요건/취급    |                        | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서        | 의의                     | 종업원·법인의 임원 또는 공무원(이하 '종업원 등'이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 '사용자 등'이라 한다)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다(發振法 2II).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 취지                     | 종업원 등과 사용자 등의 합리적인 이익배분을 통한 직무발명의 장려                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 요건       |                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>종업원 등이 그 직무에 관하여 발명하였을 것 <ol style="list-style-type: none"> <li>종업원 등 - 종업원·법인의 임원 또는 공무원 등을 의미. 상근·비상근, 보수지급유무, 근로기준법상의 최하 연령 등을 불문하고 사용자와 고용관계(사실상 타인에게 노무 제공 의무 부담)에 있는 한 종업원등</li> <li>직무 - 직무란 종업원 등이 사용자 등의 요구에 따라 사용자의 업무의 일부를 담당하는 것으로, 해당 종업원의 지위·급여·발명과 수행하였던 업무와 연관성 등을 종합적으로 고려하여 판단</li> </ol> </li> <li>사용자 등의 업무범위에 속할 것 <ol style="list-style-type: none"> <li>사용자 등 - 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체 등을 의미.</li> <li>업무범위 - 업무범위란 사용자 등이 수행하는 사업의 범위로서 사용자가 개인, 법인 및 국가인지에 따라 각각 달리 해석(법인의 경우 정관에 정해진 목적범위보다 넓게 해석. 국가의 경우 공무원이 소속된 기관의 직제와 사무분장규칙에 정해진 업무범위로 한정하여 해석)</li> </ol> </li> <li>발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것 <ol style="list-style-type: none"> <li>발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 직무에 속하는 발명 - 종업원 등이 발명에 대한 구체적인 과제를 사용자 등으로부터 부여받지 아니하였을지라도 종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 말함.</li> <li>현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명 - 발명 완성 당시 고용 관계에 있는 사용자를 기준으로 판단함. 따라서, 완성후 퇴직한 발명은 직무발명이지만, 퇴직후 완성한 발명은 자유발명임.</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 법적<br>취급 | 종업원<br>등의<br>권리·<br>의무 | <ol style="list-style-type: none"> <li>특허를 받을 수 있는 권리의 원시적 취득(法 33①본문)</li> <li>발명완성사실통지 의무<br/>종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체없이 그 사실을 사용자 등에게 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 통지하여야 한다. 2명 이상의 종업원 등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 통지하여야 한다(發振法 12).</li> <li>비밀유지의무<br/>종업원 등은 사용자 등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자 등이 승계하지 아니하기로 확정된 때에는 그러하지 아니하다(發振法 19). 이를 위반하여 부정한 이익을 받거나 사용자 등에게 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자는 사용자의 고소가 있을 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다(發振法 58).</li> <li>승계된 경우 보상 받을 권리</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 사용자<br>등의<br>권리·<br>의무 | <ol style="list-style-type: none"> <li>무상의 통상실시권 취득 <ol style="list-style-type: none"> <li>사용자 등은 종업원 등이 출원한 직무발명이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 경우 법정실시권인 통상실시권을 취득한다(發振法 10①). 이 때의 통상실시권은 무상이며, 실시범위에 제한이 없으며, 특허권자가 특허권을 포기하거나, 그 특허발명의 명세서·도면에 대한 특허의 정정 또는 정정심판을 청구할 때 동의권이 있다(法 119①, 136⑧). 다만, 사용자가 특허취소신청, 무효심판을 청구한 경우에는 동의권이 없다.</li> <li>다만, 사용자 등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원 등과의 협의를 거쳐 미리 예약승계에 관한 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 사용자 등은 통상실시권을 취득하지 못한다(發振法 10①단서).</li> </ol> </li> <li>예약승계할 수 있는 권리 인정 <ol style="list-style-type: none"> <li>직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다(發振法 10③)</li> <li>종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다(發振法 14).</li> <li>출원 전에 제3자가 종업원 등으로부터 그 권리를 이종양도 받아서 사용자보다 먼저 특허출원을 하면 사용자 등이 그 승계사실을 제3자에게 주장할 수 없게 된다(法 38①). 이 경우 사용자 등은 단지 고용계약 위반을 이유로 종업원에 대하여 징계처분 또는 해고 등을 하거나 民法상 채무불이행에 의한 손해배상을 청구 또는 이종양도로 취한 이득에 대하여 부당이득반환청구를 하여 불이익을 회복할 수 있다. 또한, 사용자 등은 종업원에게 비밀유지의무(發振法 19) 위반에 대하여 형사책임(發振法 58)과 刑法상 배임죄(刑法 355)의 책임을 물을 수도 있다. 기타 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률(제36조~제39조) 또는 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률(제18조~제20조)의 적용을 고려해 볼 수도 있다.</li> <li>다만, 종업원 등과 제3자의 이종양도계약이 민법 제103조 위반의 반사회적 법률행위로서 무효인 경</li> </ol> </li> </ol> |

|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | <p>우(예를 들어, 특허를 받을 수 있는 권리가 이미 사용자 등에게 양도된 사실을 잘 알면서도 발명자인 종업원 등과 이중계약을 체결하여 그 이중양도행위에 적극적으로 가담한 경우) 제3자의 출원은 발명자가 아닌 자로서 승계인이 아닌 자, 즉 무권리자에 의한 출원이 되므로 법 제33제1항 본문 위반으로 거절이유 등에 해당한다.</p> <p>3. 직무발명의 권리승계</p> <p>① 예약승계계약의 체결 등이 있는 경우 - 그 권리는 발명을 「완성한 때」부터 사용자 등에게 승계된다. 다만, 사용자 등이 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리를 승계하지 아니하기로 종업원 등에게 통지하는 경우에는 그러하지 아니하다(發振法 13①).</p> <p>② 예약승계계약의 체결 등이 없는 경우(국가나 지방자치단체는 제외한다) - 직무발명 완성사실의 통지를 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 서면으로 알려야 한다. 이 경우 사용자 등은 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다(發振法 13②). 다만, 사용자 등이 대통령령으로 정하는 기간에 승계 여부를 통지하지 아니한 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자 등은 그 발명을 한 종업원 등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다(發振法 13③).</p> <p>4. 승계한 경우 정당한 보상을 해 줄 의무</p> <p>① 보상받을 권리 - 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다(發振法 15①). 강행규정임.</p> <p>② 보상규정의 작성 및 통지 - 사용자 등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원 등에게 서면으로 알려야 한다(發振法 15②).</p> <p>③ 보상규정의 변경 - 사용자 등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원 등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원 등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원 등의 과반수의 동의를 받아야 한다(發振法 15③).</p> <p>④ 보상사항의 통지 - 사용자 등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원 등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 서면으로 알려야 한다(發振法 15④).</p> <p>⑤ 보상규정에 따른 보상의 효력 - 사용자 등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원 등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다(發振法 15⑥). 직무발명에 대한 보상이 계약 또는 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 정하고 있더라도 사용자 등의 이익과 사용자 등과 종업원 등의 공헌 정도를 고려하여 적절한 수준으로 이루어지지 아니한다면 법원이 보상액의 적정여부를 판단하게 된다.</p> <p>⑥ 출원유보시의 보상<br/>사용자 등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원(出願)하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원 등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다(發振法 16).</p> |
| 관련문제 | 공무원 직무발명 | <p>1. 공무원의 직무발명의 승계<br/>공무원 또는 국가나 지방자치단체에 소속되어 있으나 공무원이 아닌 자(이하 “공무원등”이라 한다)의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계할 수 있으며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원 등의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유(公有)로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립 학교(이하 “국·공립학교”라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계할 수 있으며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권 등은 그 전담조직의 소유로 한다(發振法 10②).</p> <p>2. 국유특허권의 처분·관리<br/>국유특허권은 지식재산처장이 처분 및 관리권을 갖는다(發振法 10④). 한편, 「국유재산법」 제65조의11제2항 단서에도 불구하고 지식재산처장이 정하여 고시하는 경우에는 국유로 된 특허권등에 관한 전용실시권 설정을 한 번 이상 갱신할 수 있다(發振法 10의2).</p> <p>3. 보상<br/>공무원 등의 직무발명에 대하여 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다(發振法 15④).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 대학교수 발명  | <p>1. 연구비 또는 연구설비를 지원받은 경우 - 직무발명</p> <p>2. 연구비 또는 연구설비를 지원받지 아니한 경우 - 학설의 대립이 있으나 자유발명이 통설.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



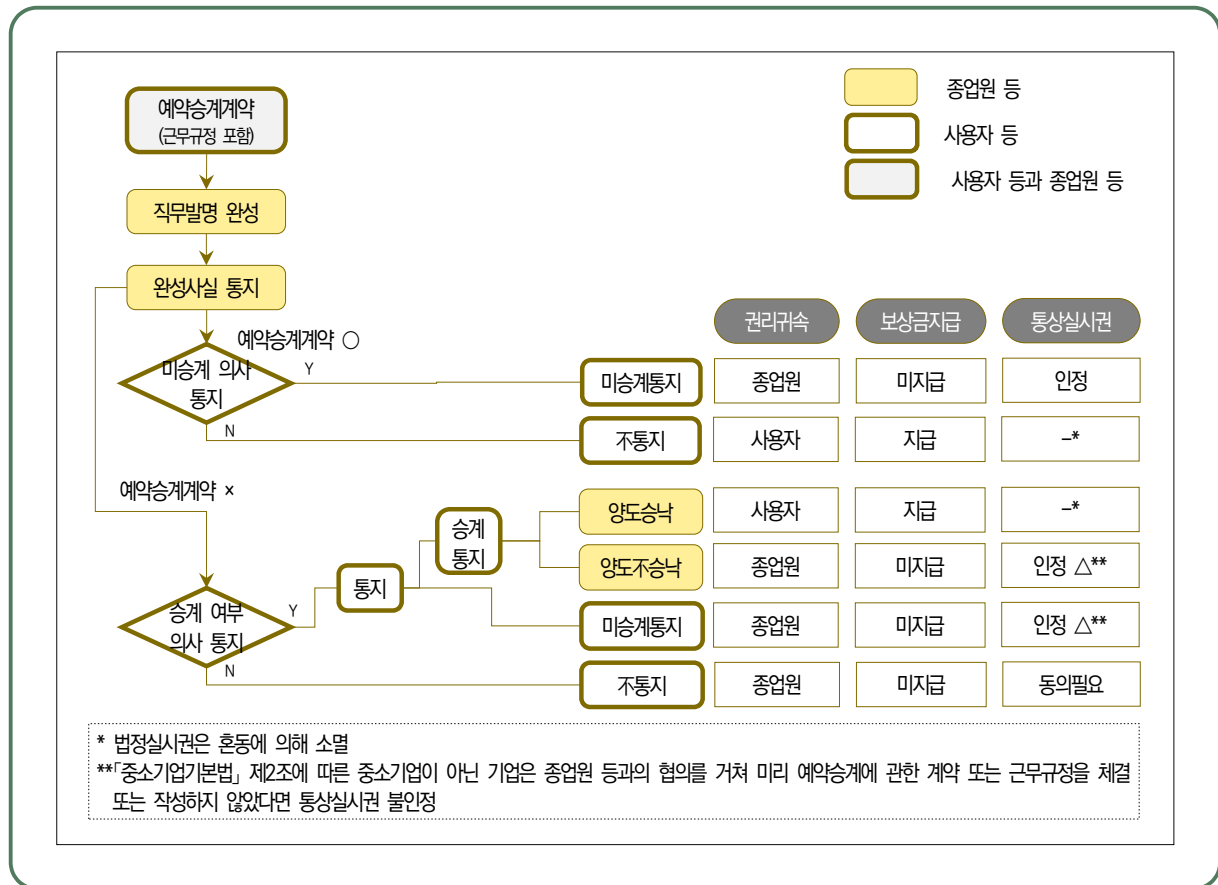
### Ⅲ 종업원 발명의 법적 취급

| 구 분  | 종업원 등의 권리 및 의무                                                                                                     | 사용자 등의 권리 및 의무                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 직무발명 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 특허를 받을 수 있는 권리의 원시적 취득</li> <li>■ 발명완성사실통지의무</li> <li>■ 비밀유지의무</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 법정실시권(단, 대기업의 경우 예약승계계약의 체결 또는 근무규정의 작성에 있는 경우에 한함)</li> <li>■ 예약승계               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예약승계계약이나 근무규정에 근거한 승계취득</li> <li>- 승계한 경우 정당한 보상 의무</li> </ul> </li> </ul> |
| 자유발명 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 특허를 받을 수 있는 권리의 원시적 취득</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 승계한 경우 정당한 보상 의무</li> </ul>                                                                                                                                                                           |

### Ⅳ 사용자 등의 직무발명에 대한 승계

| 구 분      |                     | 발명 완성 전 예약승계                                                                            | 발명 완성 후 승계 |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 직무<br>발명 | 특허를 받을 수 있는 권리 승계계약 | 가능                                                                                      | 가능         |
|          | 특허권 승계계약            | 가능                                                                                      |            |
|          | 전용실시권 설정계약          | 가능                                                                                      |            |
|          | 통상실시권 허락계약          | 종업원 등 또는 승계인이 특허를 받은 경우 법정실시권 발생하기 때문에 불필요(단, 대기업의 경우 예약승계계약의 체결 또는 근무규정의 작성이 된 경우에 한함) |            |
| 자유<br>발명 | 특허를 받을 수 있는 권리 승계계약 | 불가능                                                                                     | 가능         |
|          | 특허권 승계계약            | 불가능                                                                                     |            |
|          | 전용실시권 설정계약          | 불가능                                                                                     |            |
|          | 통상실시권 허락계약          | 가능                                                                                      |            |

## V 직무발명 절차 규정에 따른 법률관계





## 특허출원(法 42~42의3, 43)

### I 법조문

#### 제42조 【특허출원】(★★★) 法 193

① (출원서) 특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다. <개정 2014.6.11.> 法 200의2②

1. 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
3. 발명의 명칭
4. 발명자의 성명 및 주소

#### 시행규칙 제28조

##### 제28조(발명자의 추가 등)

- ① 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자의 기재를 일부 누락하거나 잘못 적은 경우에는 발명자를 추가 또는 정정할 수 있다. 다만, 특허출원인은 법 제66조에 따른 특허결정이 있는 때부터 법 제87조제1항에 따른 특허권의 설정등록을 받기 전까지는 발명자를 추가할 수 없고 발명자의 동일성이 유지되지 않는 경우 발명자를 정정할 수 없다.
- ② 특허출원인은 제1항에 따라 발명자를 추가 또는 정정하려는 경우에는 별지 제9호서식의 보정서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출해야 한다. 다만, 특허출원서에 적은 발명자의 기재가 일부 누락되거나 발명자를 잘못 적은 것이 명백한 경우에는 제2호에 따른 서류를 첨부하지 않을 수 있다.
  1. 발명자의 추가 또는 정정 이유를 기재한 설명서 1통
  2. 특허출원인 및 추가 또는 정정의 대상이 되는 발명자가 서명 또는 날인한 확인서류 1통. 다만, 발명자의 사망 등으로 서명 또는 날인이 불가능한 특별한 사유가 있는 경우에는 그 사유를 확인서류에 기재하고 서명 또는 날인을 생략할 수 있다.
  3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통
- ③ 특허권자는 법 제87조제1항에 따른 특허권의 설정등록을 받은 이후에 제1항 본문에 따라 발명자를 추가 또는 정정하려는 경우에는 별지 제29호서식의 정정발급신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출해야 한다.
  1. 발명자의 추가 또는 정정 이유를 기재한 설명서 1통
  2. 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류 1통
  3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통
- ④ 제3항에도 불구하고 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 같은 항 제2호에 따른 서류를 첨부하지 않을 수 있다.
  1. 특허출원서에 적은 발명자의 기재가 일부 누락된 경우
  2. 발명자를 잘못 적은 것이 명백한 경우
  3. 특허권자가 법 제99조의2제2항에 따라 특허권 이전등록을 받은 자인 경우

[전문개정 2024. 10. 31.]

② (첨부서류) 제1항에 따른 특허출원서에는 발명의 설명·청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다. <개정 2014.6.11.> 法 200의2②③

③ (발명의 설명 기재방법) 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. <개정 2014.6.11.>

1. (일반적인 기재방법) 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것 法 62Ⅳ, 63의2, 133①Ⅰ
2. (배경기술 기재) 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것 法 62Ⅳ
- ④ (청구범위 기재방법: 원칙) 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 "청구항"이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. <개정 2014.6.11.>
  1. (뒷받침 요건) 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것 法 62Ⅳ, 63의2, 133①Ⅰ
  2. (명확성 요건) 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것 法 62Ⅳ, 63의2, 133①Ⅰ

⑤ 삭제 <2014.6.11.>

⑥ **(청구범위 기재방법: 구성요소 기재방법)** 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다.

<개정 2014.6.11.>

⑦ 삭제 <2014.6.11.>

⑧ **(청구범위 기재방법: 다항제 기재방법)** 제2항에 따른 청구범위의 기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령(시행령 제5조)으로 정한다. <개정 2014.6.11.> **法 62Ⅳ**

#### 시행령 제5조

##### 제5조(청구범위의 기재방법)

① 법 제42조제8항에 따른 청구범위의 청구항(이하 “청구항”이라 한다)을 기재할 때에는 독립청구항(이하 “독립항”이라 한다)을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(이하 “종속항”이라 한다)을 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다.  
<개정 2006. 9. 28., 2007. 6. 28., 2014. 12. 30.>

② 청구항은 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재하여야 한다. <개정 2003. 6. 13.>

③ 삭제 <1999. 6. 30.>

##### 구시행령 제5조제3항

③종속항은 독립항 또는 다른 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는데 필요한 수로 기재하여야 한다.

④ 다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 적어야 한다. <개정 2013. 6. 28.>

⑤ 2이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다. <개정 2003. 6. 13.>

⑥ 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니 된다. 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다. <개정 2006. 9. 28.>

⑦ 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 한다. <개정 2003. 6. 13.>

⑧ 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.

[제목개정 2014. 12. 30.]

⑨ **(그 밖의 발명의 설명, 도면 및 요약서의 기재방법)** 제2항에 따른 발명의 설명, 도면 및 요약서의 기재방법 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

<개정 2014.6.11.>

[제목개정 2014.6.11.]

#### 시행규칙 제21조

##### 제21조(특허출원서 등)

① 법 제42조제1항에 따라 특허출원을 하려는 자는 별지 제14호서식의 특허출원서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지식재산청장에게 제출하여야 한다. <개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29., 2014. 12. 30.>

1. 명세서·요약서 및 도면 각 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통
3. 기타 법령의 규정에 의한 증명서류 1통

② 제1항의 명세서는 별지 제15호서식, 요약서는 별지 제16호서식, 도면은 별지 제17호서식에 따른다. <개정 2006. 12. 29., 2009. 6. 30.>

③ 제1항제1호에 따른 명세서의 발명의 설명에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2014. 12. 30.>

1. 발명의 명칭
2. 기술분야
3. 발명의 배경이 되는 기술
4. 다음 각 목의 사항이 포함된 발명의 내용
  - 가. 해결하려는 과제
  - 나. 과제의 해결 수단
  - 다. 발명의 효과
5. 도면의 간단한 설명
6. 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용
7. 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항

④ 제3항제2호·제4호·제5호 및 제7호의 사항은 해당하는 사항이 없는 경우에는 그 사항을 생략할 수 있다. <신설 2007. 6. 29., 2014. 12. 30.>



- ⑤ 제2항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 법 제42조의2제1항 후단에 따라 명세서에 청구범위를 적지 않고 출원할 때에는 특허출원서에 제2항부터 제4항까지의 기재방법을 따르지 않고 발명의 설명을 적은 명세서(이하 "임시 명세서"라 한다)를 첨부하여 제출할 수 있다. 이 경우 임시 명세서를 전자문서로 제출하기 위해서는 지식재산처장이 정하여 고시하는 파일 형식을 따라야 한다. <신설 2020. 3. 30.>
- ⑥ 제5항에 따라 임시 명세서를 제출하는 경우에는 특허출원서에 그 취지를 기재해야 하며, 법 제47조에 따라 임시 명세서를 보정할 때에는 별지 제9호서식의 보정서에 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 명세서, 요약서 및 필요한 도면을 첨부하여 지식재산처장에게 제출해야 한다. <신설 2020. 3. 30.>
- [전문개정 1998. 12. 31.]  
[제목개정 2001. 6. 30.]

## 제42조의2 【특허출원일 등】(★★) 法 59②Ⅰ, 64②Ⅰ / 52의2③ / 199②

- ① (의의) 특허출원일은 명세서 및 필요한 도면을 첨부한 특허출원서가 지식재산처장에게 도달한 날로 한다. 이 경우 명세서에 청구범위는 적지 아니할 수 있으나, 발명의 설명은 적어야 한다.
- ② (유예기간) 특허출원인은 제1항 후단에 따라 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 보정을 하여야 한다. 法 52⑧, 53⑧
- ③ (부제출의 효과) 특허출원인이 제2항에 따른 보정을 하지 아니한 경우에는 제2항에 따른 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다.
- [본조신설 2014.6.11.]

## 제42조의3 【외국어특허출원 등】(★★) 法 47⑤, 52①단서, 53①Ⅱ, 59②Ⅱ, 64②Ⅱ / 52의2③ / 199②, 201

- ① (외국어 특허출원) 특허출원인이 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다. 이하 제2항 및 제5항에서 같다)을 국어가 아닌 총리령(시행규칙 제21조의2)으로 정하는 언어로 적겠다는 취지를 특허출원을 할 때 특허출원서에 적은 경우에는 그 언어로 적을 수 있다.

### 시행령 제21조의2

#### 제21조의2(외국어특허출원의 언어 등)

- ① 법 제42조의3제1항에서 "총리령으로 정하는 언어"란 영어를 말한다.
- ② 법 제42조의3제1항에 따라 명세서 및 도면을 제1항에 따른 언어로 적으려는 자는 그 취지를 별지 제14호서식의 특허출원서에 적어야 한다.
- [본조신설 2014. 12. 30.]  
[종전 제21조의2는 제21조의4로 이동 <2014. 12. 30.>]

- ② (국어번역문의 제출) 특허출원인이 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 제1항에 따른 언어로 적은 특허출원(이하 "외국어특허출원"이라 한다)을 한 경우에는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 그 명세서 및 도면의 국어번역문을 총리령으로 정하는 방법에 따라 제출하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 제출하여야 한다. 法 52⑦, 53⑦
- ③ (국어번역문의 교제) 제2항에 따라 국어번역문을 제출한 특허출원인은 제2항에 따른 기한 이전에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 명세서 또는 도면을 보정(제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)한 경우 法 47⑤
  2. 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우
- ④ (국어번역문의 부제출의 효과) 특허출원인이 제2항에 따른 명세서의 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 제2항에 따른 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다.
- ⑤ (국어번역문의 제출의 효과) 특허출원인이 제2항에 따른 국어번역문 또는 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 외국어특허출원의 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다. 다만, 제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막 국어번역문(이하 이 조 및 제47조제2항 후단에서 "최종 국어번역문"이라 한다) 전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.
- ⑥ (오역의 정정) 특허출원인은 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 총리령(시행규칙 제21조의3)으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제5항을 적용하지 아니한다. 法 47②후단

⑦ **(여러 차례 오역정정이 있는 경우)** 제6항 전단에 따라 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다. <신설 2016.2.29.> **法 47④**

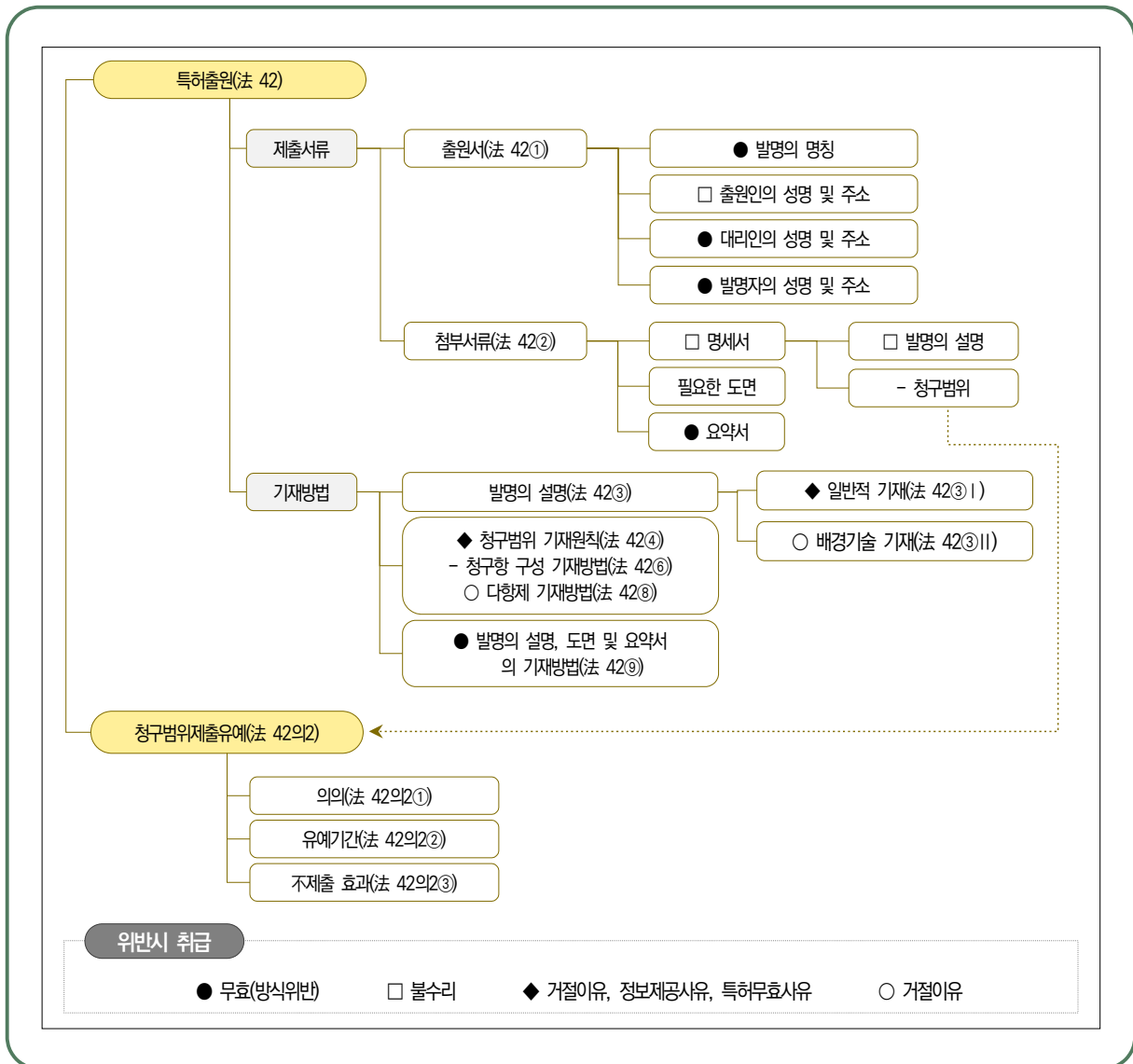
[본조신설 2014.6.11.]

**제43조 【요약서】(★) **法 97****

제42조제2항에 따른 요약서는 기술정보로서의 용도로 사용하여야 하며, 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

## II 조문정리



III 특허출원에 필요한 서류(法 42~42의3, 43)

| 종 류                   |    | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 특<br>허<br>출<br>원<br>서 | 의의 | 1. 발명자 및 출원인에 대한 인적사항이나 특허출원을 하는데 필요한 기초적 사항, 그리고 특허법상 제도의 적용을 받기 위한 각종 취지를 적은 서면<br>2. 출원인의 성명 및 주소, 대리인의 성명 및 주소, 발명자의 성명 및 주소, 발명의 명칭 등을 기재(法 42①). 그 밖에 특허출원 시에 할 수 있는 특허에 관한 절차에서 요구하는 사항도 기재가능.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | 위반 | 1. 불수리 - ① 특허에 관한 절차를 밟는 자의 성명(법인의 경우에는 명칭) 또는 특허고객번호[특허고객번호가 없는 경우에는 성명·주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)]가 기재되지 아니한 경우, ② 1건마다 서면을 작성하지 아니한 경우, ③ 출원 또는 서류의 종류가 불명확한 것인 경우<br>2. 무효 - ① 대리권 범위의 흠결, ② 발명자의 성명 또는 주소가 기재되지 아니한 경우, ③ 발명의 명칭이 기재되지 아니한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 명<br>세<br>서           | 의의 | 1. 특허를 받으려는 발명의 기술적인 내용을 문장을 통해 명확하고 상세하게 기재한 서면<br>2. 명세서에는 ① 발명의 설명 및 ② 청구범위를 기재하도록 법정되어 있다(法 42②).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | 유예 | 1. 유예기간<br>① 원 칙<br>특허출원일은 명세서 및 필요한 도면을 첨부한 특허출원서가 지식재산처장에게 도달한 날로 한다. 이 경우 명세서에 청구범위는 적지 않을 수 있으나, 발명의 설명은 적어야 한다(法 42의2①). 특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 한다(法 42의2②본문).<br>② 제3자가 심사청구하는 경우<br>출원인은 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월 이전에 제3자의 심사청구가 있는 경우 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 한다(法 42의2②단서).<br>③ 분할출원, 변경출원, 분리출원의 경우<br>특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 분할출원, 변경출원에 관하여는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날(다만, 기한 이전에 출원심사 청구의 취지를 통지(法 60 ③)받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)의 기한이 지난 후에도 분할출원, 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다(法 52⑧, 53⑧). 다만, 분리출원의 경우에는 청구범위제출 유예를 할 수 없다(法 52의2③).<br>2. 출원인 심사청구의 제한<br>특허출원인은 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에는 출원심사의 청구를 할 수 없다(法 59② I).<br>3. 출원공개의 예외<br>명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에는 출원공개를 하지 아니한다(法 64② I).<br>4. 발명의 설명 기재 형식 유예<br>청구범위제출유예제도를 이용하는 경우에, 출원서에 취지를 기재한다면 발명의 설명 형식적 기재방법(法 42 ⑨)을 따르지 않고 발명의 설명을 적은 명세서(임시 명세서)를 제출할 수 있고, 이 경우 임시명세서를 보정할 때 보정서에 형식적 기재방법을 따른 명세서를 첨부하여 지식재산처장에게 제출해야 한다. |
|                       | 위반 | 1. 불수리<br>① 출원서에 명세서(발명의 설명이 기재되어 있지 아니한 경우를 포함한다)를 첨부하지 아니한 경우, ② 명세서가 국어 또는 총리령이 정하는 언어(영어)로 기재되지 아니한 경우, ③ 분리출원으로서 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에 출원을 불수리하여야 하며, ④ 특허출원서에 임시 명세서를 첨부한 출원(施規 21⑤전단)의 보정 전에 명세서, 요약서 또는 도면을 보정한 경우 보정을 불수리하여야 한다(施規 11).<br>2. 무효<br>① 발명의 명칭이 기재되지 아니한 경우, ② 도면을 제출함에도 불구하고 도면의 간단한 설명이 기재되지 아니한 경우 등 총리령으로 정하는 발명의 설명에 대한 형식적 기재 요건(法 42⑨)에 위반된 경우 기간을 정하여 보정을 명하고 출원인이 기간 내 흠결을 치유하지 못한 경우<br>3. 취하간주<br>명세서에 청구범위를 적지 아니하고 특허출원한 경우 i) 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월 또는 ii) 제3자의 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 3개월이 되는 날 중 빠른 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하지 아니하면 그 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다(法 42의2③).<br>4. 거절이유 등<br>일반적인 발명의 설명 기재방법(法 42③ I), 청구범위 기재방법(法 42④) 위반 - 거절이유(法 62), 정보제공 사유(法 63의2), 특허무효사유(法 133①)에 해당하고, 발명의 설명 중 배경기술 기재(法 42③ II), 다항제 기재방법(法 42⑧) 위반의 경우에는 거절이유(法 62)에 해당.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 필요한도면   | 의의      | 1. 발명의 실시예를 구체적으로 표시하여 발명의 실체를 파악하는데 도움을 주는 서면으로서 명세서의 보조수단으로 이용.<br>2. 실무상 협의의 물건발명은 물건발명이나 방법발명과 달리 발명의 특징을 위해 도면의 첨부이 반드시 요구됨.<br>3. 결정구조, 금속조직 등 작도하기가 곤란한 경우에는 사진으로 대응가능.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 위반      | 무효 - 도면이 기재방식에 위반된 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 요약서     | 의의      | 1. 기술정보의 용도로 사용하여야 하며, 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다(法 43).<br>2. 【요약】, 【대표도】란을 기재                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 위반      | 무효 - 요약서가 기재방식에 위반되거나 제출되지 아니한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 외국어특허출원 | 의의      | 특허출원인이 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다. 이하 제2항 및 제5항에서 같다)을 국어가 아닌 총리령으로 정하는 언어(영어)로 적겠다는 취지를 특허출원을 할 때 특허출원서에 적은 경우에는 그 언어로 적을 수 있다(法 42의3①). 다만, 출원서와 요약서는 국어로 작성하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 제출 및 교체 | 1. 제출<br>특허출원인이 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 제1항에 따른 언어로 적은 특허출원(이하 "외국어특허출원"이라 한다)을 한 경우에는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 그 명세서 및 도면의 국어번역문을 총리령으로 정하는 방법에 따라 제출하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 제출하여야 한다(法 42의3②).<br>2. 교체<br>국어번역문을 제출한 특허출원인은 기한 이전에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다(法 42의3③).<br>i) 명세서 또는 도면을 보정(제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외)한 경우<br>ii) 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우<br>3. 예외<br>분할출원, 변경출원이 외국어특허출원(실용신안등록출원)인 경우에 출원인은 국어번역문(法 42의3②) 또는 새로운 국어번역문(法 42의3③본문)을 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날(다만, 기한 이전에 출원심사 청구의 취지를 통지(法 60③)받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)의 기한이 지난 후에도 분할출원, 변경출원일로부터 30일 이내에 국어번역문을 제출할 수 있다(法 52⑦, 53⑦). 다만, 분리출원의 경우에는 외국어특허출원을 할 수 없다(法 52의2③). |
|         | 부제출 효과  | 1. 명세서의 경우<br>특허출원인이 법 제42조의3제2항에 따른 명세서의 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 법 제42조의3제2항에 따른 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다(法 42의3④).<br>2. 도면(설명부분에 한정)의 경우<br>도면(설명부분에 한정)에 대한 국어번역문을 제출하지 않은 경우는 명세서에 대한 국어번역문을 제출하지 않은 것과 달리 취하한 것으로 보지는 않지만, 도면의 기재요건 위반(法 42⑨) 등으로 보정 대상이 될 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 제출 효과   | 특허출원인이 제2항에 따른 국어번역문 또는 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 외국어특허출원의 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다. 다만, 제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막 국어번역문(이하 이 조 및 제47조제2항 후단에서 "최종 국어번역문"이라 한다) 전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 42의3⑤).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 오역의 정정  | 1. 요 건<br>특허출원인은 법 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 오역을 정정할 수 있다(法 42의3⑥전단). 다만, 국어번역문에 오역이 있더라도 그 오역이 국어번역문에 직접적으로 표현하는 기재는 없으나 기재되어 있다고 자명하게 이해할 수 있는 사항은 오역정정할 필요가 없다.<br>2. 절 차<br>오역정정을 하기 위해서는 오역정정의 내용을 기재한 「국어번역문 오역 정정서」에 오역정정의 이유를 기재한 「설명서」를 첨부하여 제출하여야 한다(施規 21의3③). 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅰ) 또는 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ)에 오역 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 42의3⑦).<br>3. 효 과<br>① 국어번역문 신규사항의 판단대상: 정정된 국어번역문이 제47조제2항후단에 따라 보정에 대한 신규사항의 판단대상이 된다(法 47②후단).<br>② 보정 효과의 미부여: 정정된 국어번역문에 관하여는 보정의 효과(法 42의3⑤)를 부여하지 아니한다(法 42의3⑥후단). 즉, 오역 정정은 명세서를 보정한 것이 아니라 국어번역문만을 정정한 것이기 때문에 국어번역문에 오역이 있는 경우에는 국어번역문에 대한 오역정정과 별도로 심사대상 명세서 등에 대하여 보정을 하여야 한다.                                                                                                                                                                                      |

#### Ⅳ 명세서의 기재방법(法 42)

| 요 건                                           |              | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서                                             | 의의           | 명세서란 특허를 받으려는 발명의 기술적인 내용을 문장을 통해 명확하고 상세하게 적은 서면으로, 발명의 설명 및 청구범위를 기재하도록 법정되어 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 발<br>명<br>의<br>설<br>명<br><br>기<br>재<br>방<br>법 | 일반적인<br>기재방법 | <p>1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것(法 42③Ⅰ)</p> <p>① 의의 - 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다(法 42③Ⅰ). 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 발명의 설명만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명의 기재에 의하여 그 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.</p> <p>② 통상의 기술자 - 출원이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자</p> <p>③ 과도한 실험이나 특수한 지식 - 어느 정도까지 통상의 기술자에게 기대할 수 있는 것인가에 대한 객관성을 담보하는 구체적인 기준이 필요</p> <p>④ 그 발명 - 청구항에 기재된 발명으로 해석된다. 따라서 발명의 설명의 기재에 오류가 있다고 하더라도 i) 그러한 오류가 청구항에 기재되어 있지 아니한 발명에 관한 것이거나 ii) 청구항에 기재된 발명의 실시를 위하여 필요한 사항 이외의 부분에 관한 것이어서 그 오류에도 불구하고 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우라면 법 제42조제3항제1호 위반이 되지는 아니한다(2012후2586).</p> <p>⑤ 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도 - 「재현」이란 물건발명에서는 그 물건을 생산, 사용 등을 할 수 있고, 방법발명에 있어서는 그 방법을 사용할 수 있고, 물건을 생산하는 방법의 발명에 있어서는 그 방법에 의하여 그 물건을 생산할 수 있을 정도를 말한다. 여기서, 물건발명의 경우 「생산, 사용 등」의 의미에 관하여 i) 단순히 물건 자체의 생산, 사용 등을 의미한다는 형식적 재현설, ii) 발명의 설명에 기재된 효과를 가지는 물건의 생산, 사용 등을 의미한다는 실질적 재현설이 있으나, 판례(2014후2061)는 실질적 재현설을 지지</p> <p>2. 배경기술을 적을 것(法 42③Ⅱ)</p> <p>발명의 배경기술은 그 발명의 기술적 특징을 쉽게 파악하는데 도움이 되어 그 발명에 관한 특허출원의 심사에 유용할 뿐만 아니라 특허협력조약(PCT) 규칙에서도 필수 기재사항으로 규정하고 있음을 감안하여 개정법(法律 제10716호, 2007. 05. 24. 공포/2007. 07. 01. 시행)은 발명의 설명의 기재요건에서 배경기술을 적을 것을 의무화하고 있다.</p> |
|                                               | 형식적인<br>기재방법 | <p>1. 의의</p> <p>발명의 설명에는 i) 발명의 명칭, ii) 기술분야, iii) 발명의 배경이 되는 기술, iv) 발명의 내용, v) 도면의 간단한 설명, vi) 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 및 vii) 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항을 포함하여야 한다. 다만, ii), iv), v) 및 vii)의 사항은 해당하는 사항이 없는 경우에는 그 사항을 생략할 수 있다(法 42⑨, 施規 21③④).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p> <b>【발명의 설명】</b><br/> <b>【발명의 명칭】</b><br/> <b>【기술분야】</b><br/> <b>【발명(고안)의 배경이 되는 기술】</b><br/> <b>【선행기술문헌】</b><br/> <b>【특허문헌】</b><br/> <b>【비특허문헌】</b><br/> <b>【발명의 내용】</b><br/> <b>【해결하려는 과제】</b><br/> <b>【과제 해결 수단】</b><br/> <b>【발명의 효과】</b><br/> <b>【도면의 간단한 설명】</b><br/> <b>【발명의 실시를 위한 구체적인 내용】</b><br/> <b>【실시예】</b><br/> <b>【산업상 이용가능성】</b><br/> <b>【부호의 설명】</b><br/> <b>【수탁번호】</b><br/> <b>【서열목록 자유텍스트】</b><br/> <b>【청구범위】</b><br/> <b>【청구항 1】</b><br/> <b>【청구항 2】</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p>2. 구체적인 기재방법</p> <p>(1) 서 설</p> <p>발명의 설명은 원칙적으로 <b>【발명의 명칭】</b>, <b>【기술분야】</b>, <b>【배경기술】</b>, <b>【선행기술문헌】</b>, <b>【발명의 내용】</b>, <b>【도면의 간단한 설명】</b>, <b>【발명의 실시를 위한 구체적인 내용】</b>, <b>【산업상 이용가능성】</b>, <b>【부호의 설명】</b>, <b>【수탁번호】</b> 및 <b>【서열목록 자유텍스트】</b>란으로 구분하여 적으며, 그 내용은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 이해하고 또한 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다. 다만, <b>【발명의 명칭】</b>, <b>【배경기술】</b>, <b>【발명의 실시를 위한 구체적인 내용】</b>을 제외한 위 식별항목에 해당 사항이 없는 경우에는 작성하지 않을 수 있다.</p> <p>(2) 발명의 명칭</p> <p><b>【발명의 명칭】</b>란에는 발명의 명칭이 발명의 표제일 뿐만 아니라 출원발명을 분류하여 기술분야를 특정하고 정리·검색을 쉽게 하기 위해 적는 것이기 때문에, 발명내용을 고려하여 카테고리가 구분되도록 간단·명료하게 적는다. 발명의 기술분야는 발명의 명칭뿐만 아니라 발명의 구성 및 효과 등을 모두 감안하여 결정하게 되나 일반적으로 발명의 명칭을 주로 참조하여 결정하고 있다.</p> <p>(3) 기술분야</p> <p><b>【기술분야】</b>란에는 특허를 받으려는 발명의 기술분야를 명확하고 간결하게 적어야 한다. 기술분야를 적어도 1개 이상 적어야 하나, 명시적 기재가 없더라도 통상의 기술자가 기술상식으로 그 발명이 속하는 기술분야를 이해할 수 있을 때에는 적지 아니하여도 된다. 출원인이 발명이 속하는 국제특허분류(IPC)를 알고 있는 경우에는 참조하여 적을 수 있다.</p> <p>(4) 배경기술</p> <p><b>【배경기술】</b>란에는 발명의 이해, 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 명시한다. 다만, 종래기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의하여 개발된 발명으로 배경이 되는 기술을 알 수 없는 경우에는 그 취지를 기재함으로써 배경기술 기재를 대신할 수 있다. 명세서에 배경기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수 없다(2013후 37). 이는 출원 전 공지된 것인지는 사실인정의 문제인데 배경기술이라는 항목(명세서의 기재형식)에 기재했다는 것에 근거하여 공지기술로 간주하는 태도는 객관적 진실에 반하는 결과를 낳을 수 있고, 더욱이 배경기술이란 공개 여부는 묻지 않고 출원 전 존재한 기술을 말하는 것이기 때문이다.</p> <p>(5) 선행기술문헌</p> <p><b>【선행기술문헌】</b>란에는 특허를 받으려는 자가 알고 있는 종래기술의 문헌 정보를 다음과 같이 <b>【특허문헌】</b>과 <b>【비특허문헌】</b>란으로 구분하여 적되 그 문헌의 명칭, 발간일, 종래기술이 기재된 페이지 등의 정보를 구체적으로 적는다.</p> <p>(6) 발명의 내용</p> <p>① <b>【발명의 내용】</b>란은 원칙적으로 <b>【해결하려는 과제】</b>, <b>【과제해결 수단】</b> 및 <b>【효과】</b>란으로 구분하여 적는다. 다만, 구분하여 기재하기 어려운 경우에는 별도로 나누어 적지 아니하여도 된다.</p> <p>② <b>【해결하려는 과제】</b>란에는 종래기술의 문제점을 분석하여 그 문제점으로부터 발명이 해결하려는 과제를 종래기술과 관련하여 적는다.</p> <p>③ <b>【과제 해결 수단】</b>란에는 청구항에 기재된 발명에 의하여 어떻게 해당 과제가 해결되었는지를 적는다. 일반적으로는 청구항에 기재된 발명이 해결수단 그 자체가 되므로 청구항에 기재된 발명을 기재하면 된다.</p> |

|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                 | <p>④ 【효과】란에는 특허를 받으려는 발명이 종래의 기술과 관련하여 가지는 유리한 효과를 적는다. 발명의 설명에 기재된 효과는 그 발명의 신규성, 진보성의 존재를 추인하는 하나의 요소로 될 수 있으므로 출원인이 아는 한도 내에서 충분히 적을 필요가 있다.</p> <p>(7) 도면의 간단한 설명<br/>【도면의 간단한 설명】란은 도면을 첨부하는 경우에만 기재하고, 도면이 구체적으로 나타내려는 것이 무엇인지를 쉽게 파악할 수 있을 정도로 첨부도면의 종류·도시상태 및 도시부분에 대한 설명을 간단히 적는다. 구체적으로 각각의 도면에 대한 설명을 【도 1】, 【도 2】와 같이 구분하여 적되, 각 도면에 대한 설명은 줄을 바꾸어 적는다.</p> <p>(8) 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용<br/>【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】란에는 통상의 기술자가 그 발명이 어떻게 실시되는지를 쉽게 알 수 있도록 그 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 적어도 하나 이상, 가급적 여러 형태로 적는다. 필요한 경우에는 【실시예】란을 만들어 기재하고, 도면이 있으면 그 도면을 인용하여 적는다.</p> <p>(9) 산업상 이용가능성<br/>【산업상 이용가능성】란은 특허를 받으려는 발명이 산업상 이용가능한 것인지 여부가 불분명할 때 그 발명의 산업상 이용방법, 생산방법 또는 사용방법 등을 적는다. 다만, 산업상 이용가능성은 대부분 발명의 설명의 다른 기재로부터 충분히 유추 가능하므로 별도의 기재를 하지 아니하여도 된다.</p> <p>(10) 부호의 설명<br/>【부호의 설명】란에는 도면의 주요 부분을 나타내는 부호들에 대한 설명을 적는다. 해당 부호들은 발명의 설명 및 도면에 같이 기재하여야 하며, 청구범위를 적을 경우에도 해당 부호를 병기할 수 있다.</p> <p>(11) 수탁번호<br/>【수탁번호】란은 발명의 설명에 기재된 미생물들의 수탁번호들을 별도로 정리하려는 경우에 적는다.</p> <p>(12) 서열목록 자유텍스트<br/>【서열목록 자유텍스트】란에는 발명의 설명에 첨부된 서열목록에 기재된 자유텍스트를 필요에 따라 반복하여 적는다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 청구범위<br>기재방법 | 청구항<br>기재<br>원칙 | <p>1. 의의<br/>청구범위에는 보호를 받으려는 사항을 적은 항(이하 “청구항”이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 i) 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것 및 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것을 모두 만족하여야 한다(法 42④).</p> <p>2. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것(法 42④ I)</p> <p>① 의의 및 취지 - 발명의 설명은 기술 공개서로서 역할을 하는 바, 발명의 설명에 적지 아니함에 따라 공개하지 아니한 사항을 청구범위에 청구항으로 적어 특허권이 부여되면 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 결과가 되기 때문이다.</p> <p>② 판단 - 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구항에 적혀 있는 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 적혀 있는지에 의하여 판단하여야 한다. 따라서 출원 시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다. 도면은 실시예 등을 구체적으로 보여줌으로써 발명의 구성을 더욱 쉽게 이해할 수 있도록 해주는 것으로서 도면이 첨부되어 있는 경우에는 도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 발명의 설명이 청구항을 뒷받침하고 있는지 여부를 판단할 수 있다.</p> <p>③ 청구범위가 발명의 설명에 뒷받침되고 있을지라도, 청구항에는 기재되지 아니하고 발명의 설명에만 기재된 발명은 원칙적으로 보호받지 못한다. 다만, 이 경우 출원인은 발명의 설명에만 기재된 발명에 대하여 별도의 신규출원, 보정(法 47), 분할출원(法 52), 국내우선권주장출원(法 55) 등을 통해 보호받을 수 있다.</p> <p>④ 법 제42조제3항제1호와의 관계 - 법 제42조제4항제1호는 출원인이 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 특허요건이고 법 제42조제3항제1호는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 요건으로서 법 제42조제4항제1호와는 독립된 특허요건이기 때문에 둘 중 어느 하나를 위반하였다고 반드시 다른 특허요건을 위반한 것은 아니며, 개별적으로 위반 여부를 판단해야 한다.</p> <p>3. 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것(法 42④ II)</p> <p>① 의의 및 취지 - 청구항의 기재가 불명확하거나 그 기재내용이 간결하지 아니한 발명은 특허요건 판단 등이 불가능하며 특허권이 부여되면 발명의 보호범위가 불명확하여 특허발명의 보호범위를 결정할 수 없기 때문이다.</p> <p>② 판단 - 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다.</p> |
|              | 청구항<br>구성       | <p>1. 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다(法 42⑥). 즉, 청구항에는 보호받으려는 발명의</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 요소<br>기재<br>방법  | <p>필수구성요소를 적되, 청구항의 구성요소(elements of claim)는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등의 다양한 형태의 기재가 허용된다.</p> <p>2. 즉, 출원인은 발명의 필수구성요소이지만 하면 스스로 발명을 보호할 수 있는 가장 적절한 구성요소를 선택하여 청구범위를 작성할 수 있다. 여기서 「필수구성요소」란 발명의 설명에 특정된 발명의 구성요소 중 출원인의 주관적 사고에 근거하여 추출한 후 청구항에 적은 구성요소를 말한다. 발명의 설명에 특정된 발명의 구성요소 중 어떤 구성요소를 추출하여 청구항에 적을 것인지는 출원인의 의사에 의한 것으로서, 일부를 청구항에 적지 아니한 경우 특허발명의 권리범위를 넓힐 수는 있으나 신규성, 진보성의 심사에 있어서 다소 불리한 위치에 서게 된다.</p> <p>3. 법 제42조제6항은 거절이유, 정보제공사유 또는 무효사유에 해당하지 아니한다. 청구범위는 출원인의 자유의사에 의하여 적는 것인데, 이를 거절이유 등으로 규정하는 것은 불합리하게 청구범위의 기재를 제약하기 때문이다.</p>                                                                                                                                                |
|                  | 다항제<br>기재<br>방법 | <p>1. 법 제42조제8항에 따른 청구범위의 청구항(이하 "청구항"이라 한다)을 기재할 때에는 독립청구항(이하 "독립항"이라 한다)을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(이하 "종속항"이라 한다)을 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다.</p> <p>2. 청구항은 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재하여야 한다.</p> <p>3. &lt;삭 제&gt; &lt;1999. 6. 30&gt;</p> <p>4. 다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 적어야 한다.</p> <p>5. 2 이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 백일적으로 기재하여야 한다.</p> <p>6. 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니 된다. 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다.</p> <p>7. 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 한다.</p> <p>8. 각 청구항은 행마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.</p> |
| 위<br>반<br>효<br>과 | 불수리             | ① 명세서가 국어 또는 산업자원부령이 정하는 언어(영어)로 기재되지 아니한 경우, ② 출원서에 명세서(명세서에 발명의 설명을 적지 아니한 경우 포함)를 첨부하지 아니한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | 무효              | ① 출원서에 기재된 발명의 명칭과 발명의 설명에 기재된 발명의 명칭이 다른 경우, ② 명세서에 기재된 발명의 명칭이나 도면의 간단한 설명이 부적합한 경우, ③ 발명의 명칭이 기재되지 아니한 경우 또는 ④ 도면을 제출하였음에도 불구하고 도면의 간단한 설명이 기재되지 아니한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | 거절<br>이유등       | <p>1. 法 42③Ⅰ, ④ 위반된 경우 - 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法 133①)</p> <p>2. 法 42③Ⅱ, 42⑥ 위반된 경우 - 형식적인 요건으로서 실체파악 및 권리범위의 확정여부와는 관계가 없는 사항이므로 거절이유(法 62)에만 해당</p> <p>3. 기술적 범위를 특정할 수 없거나 실시가 불가능한 경우에는 권리범위 불인정(97후1344 등)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | 직권보정<br>등       | <p>1. 심사관은 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우이고 다른 거절이유가 없다면 직권보정하면서 특허결정할 수 있다. 이 경우 직권보정은 신규사항이 추가되지 아니한 범위(法 47②)에서 하여야 한다((法 66의2①). 「명백히 잘못된 경우」란 사소한 오타자 이외에 명백히 잘못된 기재된 기재불비가 있는 경우를 말하고, 여기서 명백히 잘못 기재된 기재불비란 통상의 기술자가 그 기재가 잘못되었다는 사실을 쉽게 인식할 수 있고, 명세서 등의 기재, 의견서 및 출원 시 기술상식을 참작하여 출원인의 당초 의도를 명확히 알 수 있어서 해당 보정이 어떻게 이루어질 것인지 쉽게 예측할 수 있는 경우를 말한다.</p> <p>2. 심사관은 법 제51조에 의한 보정각하 판단시에도 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 것인지와 관련하여, 기재불비가 명백히 잘못된 경우이어서 직권보정(法 66의2)을 할 수 있는 사항이라면, 보정을 승인하고 이후 절차를 진행할 수 있다. 명백히 잘못된 새로운 거절이유가 실수로 포함된 경우 보정각하되고 거절결정되는 것은 출원인에게 너무 가혹하기 때문이다. 이 경우 심사관은 특허결정하면서 직권보정을 하게 된다.</p>                                                                         |
| 구제방법             |                 | 특허 등록 전에는 출원보정(法 47), 분할출원(法 52)으로, 특허 등록 후에는 특허의 정정(法 133의2, 137), 정정심판(法 136)을 통해 구제받을 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

V 청구범위 기재불비의 예(法 42④)

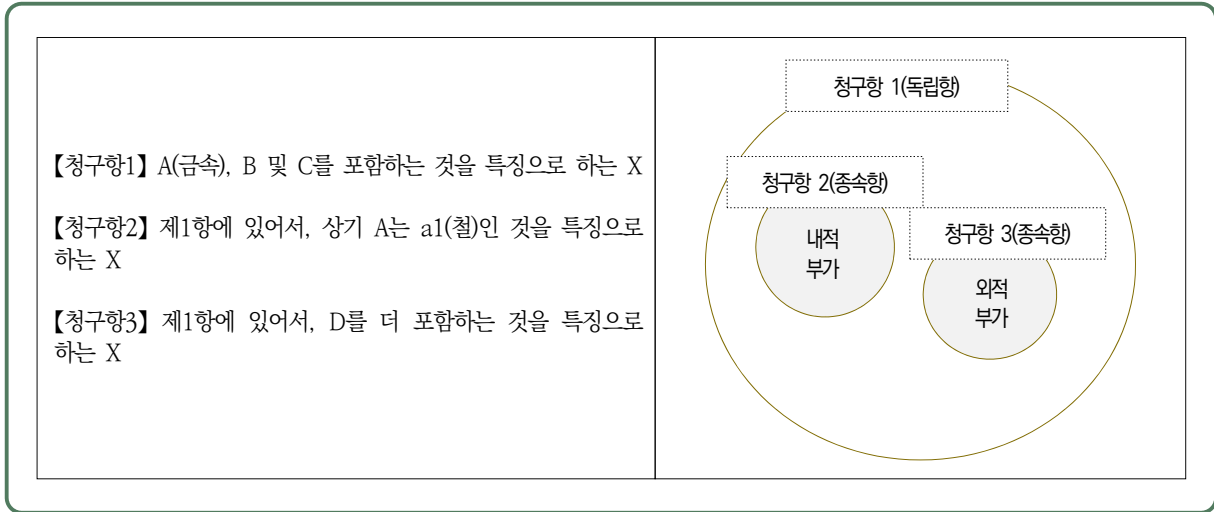
| 조문       | 구체적인 예                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法 42④ I  | <p>청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고, 암시도 되어 있지 아니한 경우 법 제42조 제4항 제1호 위반이다.</p> <p>【예1】 청구항에는 초음파모터를 이용한 발명에 대해서만 기재하고 있으나 발명의 설명에는 초음파모터를 이용한 발명에 대해서는 전혀 기재되어 있지 않고 직류모터를 이용한 발명만이 기재되어 있는 경우. 다만, 발명의 설명에는 그 실시예로 직류모터에 대해서 기재하고 있으나 직류모터만이 아니라 다른 모터도 이용할 수 있다는 기재가 있고 출원당시의 기술상식에서 판단했을 때 초음파 모터를 이용한 실시도 가능한 경우에는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 것으로 인정할 수 있다.</p> <p>【예2】 청구항에는 가소성물(可塑性物)의 압출성형방법(壓出成形方法)에 관해서 기재되어 있으나, 발명의 설명에는 그 발명을 가소성물의 압출에 적용하는 방법에 대하여는 단순히 언급만 되어 있을 뿐, 탄수화물이나 단백질 등을 주성분으로 하는 농수산 가공품의 식용가소성물의 제조방법에 대해서만 세부적으로 기재되어 있고, 그 기재된 성형방법은 성형온도나 성형압력 등으로 보아서 세라믹스나 금속 등의 가소성물의 압출성형에는 부적절하다고 인정되는 경우에는 특허법 제42조 제3항 제1호 위반으로 거절이유를 통지한다. 또한 발명의 설명에 발명을 농수산물의 압출 이외에 금속이나 세라믹 등 다른 가소성물의 압출방법에 적용한다는 기재가 없는 경우에는 특허법 제42조 제4항 제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.</p> <p>【예3】 청구항에는 치환기(X)로 CH<sub>3</sub>, OH, COOH가 택일적으로 기재된 치환벤젠의 원료화합물을 니트로화하여 파라니트로치환벤젠을 제조하는 방법이 기재되어 있으나 발명의 설명에는 그 실시예로 원료화합물이 톨루엔(X가 CH<sub>3</sub>)인 경우에만 기재되어 있고 그 방법은 CH<sub>3</sub>와 COOH의 현저한 배향성의 상이(相異) 등으로 보아 원료가 안식향산(X가 COOH)인 경우에는 부적절하다고 인정되는 경우에는 특허법 제42조 제3항 제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.</p> <p>【예4】 청구항에는 구체적인 수치한정을 하고 있으나 발명의 설명에는 그 수치에 대하여 기재되어 있지 아니한 경우. 다만, 이러한 수치한정이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원 시 해당 기술분야의 기술상식에 비추어 보아 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 범위 이내라고 판단할 경우에는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 것으로 인정할 수 있다.</p> |
|          | <p>출원 시 해당 기술분야의 통상의 지식에 비추어 보아 청구된 발명의 범위까지 발명의 설명에 기재된 내용을 확장하거나 일반화할 수 없는 경우 법 제42조 제4항 제1호 위반이다.</p> <p>【예1】 청구항에는 달성하려는 결과, 예를 들어 달성하려는 에너지 효율의 범위에 의하여 발명을 특정하려고 하고 있으나, 발명의 설명에는 특정 수단에 의한 실시예 밖에 기재되어 있지 않고 출원당시 기술분야의 통상의 지식으로도 그 제시된 실시예를 청구된 발명 전 범위로 확장하거나 일반화할 수 없다고 인정되는 경우</p> <p>【예2】 청구항에는 원하는 성질에 의하여 정의된 화합물을 유효성분으로 하는 특정 용도의 치료제로서 청구되어 있지만, 발명의 설명에는 청구항에 포함된 일부의 구체적인 화합물에 대해서만 해당 치료제로서 유용성이 확인되어 있고, 이를 벗어나는 청구항에 포함된 화합물에 대해서는 그 유용성이 출원당시 기술분야의 통상의 지식으로도 인정될 수 없는 경우</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | <p>발명의 설명에 기재된 발명의 과제를 해결하기 위한 수단이 청구항에 기재되어 있지 않아 발명의 설명에 기재된 범위를 벗어난 발명을 청구하는 경우 법 제42조 제4항 제1호 위반이다.</p> <p>【예】 전달력 증가를 위한 기구가 발명의 설명에 기재되어 있으나, 청구항에는 전달력 가변기구를 기재하고 있어 전달력이 감소되는 것까지 포함함으로써 발명의 설명을 벗어난 발명을 청구하는 경우</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | <p>청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 기재되어 있는 경우 법 제42조 제4항 제2호 위반이다. 다만, 이러한 표현을 사용하지 않고서는 해당 발명을 간단명료하게 나타낼 수 있는 적절한 표현이 없고 그 의미가 발명의 설명에 의하여 명확히 뒷받침되며 발명의 특정(特定)에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 허용할 수 있다.</p> <p>【예 1】「소매에 따라」,「필요에 따라」,「특히」,「예를 들어」,「및/또는」 등의 자구(字句)와 함께 임의부가적 사항 또는 선택적 사항이 기재된 경우(‘A 및/또는 B’는 ‘A 및 B’인 경우와 ‘A 또는 B’인 경우를 함께 기재한 것이므로, 발명이 ‘A 및 B’인 경우와 ‘A 또는 B’인 경우 모두에 대하여 각각 특허법 제42조 제4항 제1호 및 제2호 위반 여부를 판단한다. 이때, ‘및/또는’의 기재로 하나의 청구항에서 이질적인 복수의 발명을 청구하는 것은 아닌지 여부(청구항이 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재되었는지 여부)에 대해서도 판단한다.)</p> <p>【예 2】「주로」,「주성분으로」,「주공정으로」,「적합한」,「적량의」,「많은」,「높은」,「대부분의」,「거의」,「대략」,「약」 등 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현이 사용된 경우</p> <p>【예 3】「... 을 제외하고」,「... 이 아닌」과 같은 부정적 표현이 사용된 경우</p> <p>【예 4】수치한정발명에서 「... 이상」,「... 이하」,「0~10」과 같이 상한이나 하한이 불명확한 수치한정이나 0을 포함하는 수치한정(0을 포함하는 성분이 필수성분이 아니라 임의성분인 경우에는 제외한다)을 한 경우 또는 「120~200℃, 바람직하게는 150~180℃」와 같이 하나의 청구항내에서 이중으로 수치한정을 한 경우(여기서 ‘임의성분’이란 출원인이 필요에 따라 선택적으로 첨가하거나 첨가하지 않아도 좋다고 인식하는 성분으로, 명세서에 그 취지가 명확히 기재된 성분을 말한다.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | <p>지시의 대상이 불명확하여 발명의 구성이 불명확한 경우 법 제42조 제4항 제2호 위반이다. 다만, 지시의 대상이 문언상으로 일치하지 않더라도 그것이 명백한 오기에 불과하여 통상의 기술자가 발명의 구성을 정확하게 이해하여 재현할 수 있는 정도이면 적법한 기재로 본다.</p> <p>【예 1】 청구항에 여러가지 종류의 기어가 기재되어 있고 그 중 어느 특정기어를 지시할 때 「상기 평기어」, 「전기 베벨기어」 등과 같이 지시의 대상을 명확히 기재하지 않고 「상기 기어」, 「전기 기어」 등과 같이 기재한 결과 어느 기어를 지시하는 지가 불명확한 경우</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 法 42④ II |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

VI 다항제 기재의 예(法 42⑧)

| NO | 구체적인 예                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>【예1】【청구항 1】 A, B 및 C를 포함하는 것을 특징으로 하는 발명 X.<br/>         【청구항 2】 제1항에 있어서, D를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 발명 X.<br/>         【예2】【청구항 1】 A, B 및 C를 포함하는 것을 특징으로 하는 발명 X.<br/>         【청구항 2】 A, B, C 및 D를 포함하는 것을 특징으로 하는 발명 X.</p> <p>【예1】의 청구항 2에 기재된 발명과 【예2】의 청구항 2에 기재된 발명은 동일한 발명이다. 다만, 【예1】의 청구항 2는 종속항의 형식에 의해, 【예2】의 청구항 2는 독립항의 형식에 의하여 A, B, C 및 D로 구성된 발명 X를 표현하고 있을 뿐이다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2  | <p>【예】【청구항 1】 ... 방법<br/>         【청구항 2】 청구항 1에 있어서, ... 방법<br/>         【청구항 3】 청구항 2에 있어서, ... 물건<br/>         【청구항 4】 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, ... 방법(또는 물건)</p> <p>청구항 3 및 청구항 4는 다른 카테고리에 속하는 청구항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 것으로 인정되지 아니하고, 발명이 명확히 특정되지 않아서 법 제42조제4항제2호 위반이다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | <p>【예1】 하나의 청구항에 2이상의 물이 기재되어 있는 경우 : ... 고분자 화합물 및 그 고분자 화합물을 이용한 컨택트 렌즈<br/>         【예2】 청구항 내에서 2이상의 항을 인용하고 그 인용한 청구항 내에서 다시 다수의 항을 인용하는 경우 : 「청구항○ 또는 청구항○의 방법으로 제조되는 청구항○ 또는 청구항○의 물건」과 같은 것을 말하며, 이는 2이상의 항을 인용하는 종속항이 2이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용한 경우와 같은 혼란을 야기하므로 배제하는 것으로 한다.</p> <p>발명의 단일성을 만족하는 경우라도 청구항이 적정한 수로 기재되지 아니한 경우는 하나의 청구항에 카테고리가 다른 둘 이상의 발명이 기재된 경우, 하나의 청구항에 청구하는 대상이 2 이상인 경우, 동일한 청구항을 중복하여 기재(문언적으로 동일한 경우를 말하며 실질적으로 동일할 뿐 표현을 달리한 경우는 제외한다)하는 경우, 하나의 청구항 내에서 다수의 청구항을 다중으로 인용하는 경우 등은 시행령 제5조 제2항 위반이다.</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | <p>【예1】【청구항 1】 A, B 및 C로 구성된 것을 특징으로 하는 방법 X.<br/>         【청구항 2】 제1항의 방법 X에 의해 제조된 물건 Y.<br/>         【청구항 3】 제1항에 있어서, D를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법 X.<br/>         【예2】【청구항 1】 치차전동기구를 구비한 .....구조의 동력전달장치<br/>         【청구항 2】 제1항에 있어서, 치차전동기구 대신 벨트전동기구를 구비한 동력전달장치</p> <p>【예1】의 청구항 1과 청구항 2는 독립항이며, 청구항 3은 종속항이다. 【예2】의 청구항 2는 독립항으로 보고 심사를 진행한다. (한정하거나 부가하여 구체화하는지 여부에 따라 판단)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5  | <p>【예】【청구항 1】 엔진<br/>         【청구항 2】 청구항 1에 있어서, 알루미늄으로 만들어진 엔진<br/>         【청구항 3】 전술한 항 중 어느 한 항의 엔진 연료가 가솔린인 엔진<br/>         【청구항 4】 섀시, 미션 및 전술한 항 중 어느 한 항의 엔진을 갖는 자동차</p> <p>청구항 3(종속항) 및 청구항 4(독립항)는 인용되는 항의 번호를 적지 않았기 때문에, 시행령 제5조 제4항 위반이다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | <p>【예1】 ① 청구항 1, 청구항 2에 있어서, ... 장치<br/>         ② 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, ... 장치<br/>         ③ 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3 어느 한 항에 있어서, ... 장치<br/>         【예2】 ① 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, ... 장치<br/>         ② 청구항 1 내지 청구항 3중 어느 하나의 항에 있어서, ... 장치<br/>         ③ 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서, ... 장치<br/>         ④ 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3 에 있어서, ... 장치<br/>         ⑤ 청구항 1 내지 청구항 7 및 청구항 9 내지 청구항 11중 어느 한 항에 있어서... 장치<br/>         ⑥ 청구항 1, 청구항 2 및 청구항 4 내지 청구항 7중 어느 한 항에 있어서... 장치</p> <p>【예2】는 항의 번호를 택일적으로 기재한 예시이고, 【예1】은 항의 번호를 택일적으로 기재하지 않아 시행령 제5조 제5항에 위반된 예시이다.</p> <p>【예】【청구항 1】 ...를 특징으로 하는 영상신호 압축기를 구비한 송신기<br/>         【청구항 2】 ...를 특징으로 하는 영상신호 신장기를 구비한 수신기<br/>         【청구항 3】 청구항 1의 송신기와 청구항 2의 수신기를 포함하는 영상신호 전송장치</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 청구항 3은 하나의 항이 선택되도록 항의 번호를 기재하지 않았지만 발명을 명확하고 간결하게 기재하기 위한 것으로 인정하여 특허법 시행령 제5조제5항의 위반으로 보지 않는다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | <p>【예】【청구항 1】…… 장치<br/>         【청구항 2】청구항1 에 있어서, …… 장치<br/>         【청구항 3】청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, …… 장치<br/>         【청구항 4】청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, …… 장치</p> <p>청구항 4는 2이상의 항을 인용하는 종속항으로서 2이상의 항을 인용한 다른 청구항(청구항 3)을 인용하고 있어 시행령 제5조 제6항 위반이다.</p> <p>【예】【청구항 1】…… 장치<br/>         【청구항 2】청구항 1에 있어서, …… 장치<br/>         【청구항 3】청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, …… 장치<br/>         【청구항 4】청구항 3에 있어서, …… 장치<br/>         【청구항 5】청구항 2 또는 청구항 4에 있어서, …… 장치<br/>         【청구항 6】청구항 5에 있어서, …… 장치</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 | <p>청구항 제4항은 청구항 제3항만 인용하고 있다고 하더라도 제3항이 2이상의 청구항을 인용하고 있어서, 실질적으로 2이상의 항을 인용하는 경우와 같으므로 제5항에 대하여 특허법 제42조 제8항 위반으로 거절이유를 통지한다. 한편, 특허법시행령 제5조 제6항은 ‘둘 이상의 항을 인용하는 청구항’을 대상으로 하고 있어, 하나의 청구항만을 인용하는 청구항에 대해서는 적용할 수 없다는 점에 주의하여야 한다. 청구항 제6항은 시행령 제5조 제6항을 위반하는 청구항 제5항을 인용하고 있어 실질적으로 다수의 다른 청구항을 참조하여 해석하여야 하는 어려움은 있으나 둘 이상의 항을 인용하는 청구항이 아니므로 시행령 제5조 제6항의 위반으로 되지는 아니한다.</p> <p>【예】【청구항 1】… 를 특징으로 하는 결합 디바이스<br/>         【청구항 2】…를 특징으로 하는 방법<br/>         【청구항 3】청구항 2에 있어서, … 상기 디바이스는 청구항 1의 결합 디바이스인 것을 특징으로 하는 방법<br/>         【청구항 4】청구항 2 또는 청구항 3의 방법을 수행하는 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체</p> <p>청구항 4는 2이상의 항을 인용하는 청구항으로서 2이상의 항을 인용하는 다른 청구항(청구항 3)을 인용하고 있지만, 청구항 3은 발명을 명확하고 간결하게 기재하기 위한 것으로 인정되므로, 청구항 4는 시행령 제5조제6항의 위반으로 취급하지 않는다</p> |
| 8 | <p>【예】【청구항 1】…… 장치<br/>         【청구항 2】제1항에 있어서, …… 장치<br/>         【청구항 3】제4항에 있어서, …… 장치</p> <p>청구항 3은 인용되는 청구항이 인용하는 청구항보다 먼저 기재되지 않았기 때문에 청구항 2와 달리 시행령 제5조 제7항 위반이다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## VII 종속항의 종류



## VIII 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명의 특허법상 보호

| 구분      | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 특허법상 보호 | <p>1. 보 정<br/>법 제47조제1항의 기간에 해당하는 경우 출원서에 최초로 첨부한 명세서의 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명을 청구범위에 추가하는 보정이 가능하다. 다만 최후거절이유에 대한 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ) 및 재심사를 청구할 때(法 47①Ⅲ)에는 청구범위를 확장하거나 변경하는 보정이 인정되지 않기 때문에 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명을 청구범위에 추가하는 보정을 할 수 없다.</p> <p>2. 분할출원<br/>발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명은 보정을 할 수 있는 기간, 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(거절결정불복심판청구를 할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 기간을 말한다) 또는 특허결정등본(특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다))을 송달받은 날로부터 3개월(다만, 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날짜까지의 기간) 이내에 청구범위에 기재한 새로운 특허출원으로 분할하여 보호받을 수 있다. 이 경우 분할출원은 원출원 시에 포함되었던 사항이기 때문에 출원일의 소급효가 인정된다(法 52②). 이때 분할출원은 출원일의 소급효가 인정된다(法 52②). 원출원일로 출원일 소급효가 인정되면 특허요건 판단 시에 유리한 위치에 있게 되지만, 그만큼 존속기간이 짧아지게 된다.</p> <p>3. 우선권주장<br/>발명의 설명 또는 도면에만 기재하고 청구범위로 기재하지 아니한 부분의 발명이라 하더라도 그 특허출원일로부터 1년 이내라면 그것을 조약우선권 또는 국내우선권주장출원할 때 청구범위에 포함시킴으로써 보호받을 수 있다. 우선권주장에 의하여 그 발명을 보호받는 경우 선출원일로 판단시점이 소급하게 된다(法 54①, 法 55③). 우선권주장출원은 1년이라는 우선기간의 제한이 있지만, 우선권주장할 때 발명의 설명 또는 도면에 기재되지 아니한 새로운 발명을 추가할 수 있다.</p> <p>4. 별도의 출원<br/>출원인이 동일한 경우에는 확대된 선출원을 적용하지 않으므로 발명의 설명이나 도면에만 기재된 발명이라 하더라도 그 특허출원이 출원공개 전이라면 그 발명을 청구범위에 기재하고 별도의 새로운 출원을 하여 보호받을 수 있다. 별도출원은 분할출원에 비하여 특허요건 판단 시에 불리한 위치에 있지만, 등록된 후에는 존속기간을 더 길게 보호받을 수 있다.</p> |
| 소급적 보호  | <p>1. 확대된 선출원의 지위<br/>비록 청구범위에 기재하지 아니하였다고 하더라도 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 발명의 설명이나 도면에 기재된 발명은 출원공개 또는 등록공개 되었을 때 선출원의 범위가 확대되어 출원공개 또는 등록공개 전 타인의 동일한 후출원을 거절시킬 수 있다. 이는 새로운 발명을 공개하지 아니한 자에게는 독점·배타적인 특허권을 부여할 이유가 없기 때문이다.</p> <p>2. 공지기술의 지위<br/>출원서에 최초로 첨부된 명세서의 발명의 설명이나 도면에만 기재된 발명은 출원공개 또는 설정등록에 의하여 공지기술이 되므로, 출원공개 또는 설정등록 후에 출원한 타인의 후출원에 대하여 신규성 및 진보성의 판단시 인용대상이 된다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



참고자료 2.3 청구항의 작성형태

| 구 분     | 젤슨 청구항                                                                                                                                                                                                                                                                     | PBP 청구항                                                                                                                                                                                                          | 기능적 표현 청구항                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 형태      | ……에 있어서, ~를 특징으로 하는 ○○발명                                                                                                                                                                                                                                                   | X 단계후 Y 단계를 거치는 방법에 의해 제조되는 화합물 Z                                                                                                                                                                                | 구성요소의 일부 또는 전부가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 기능적 표현으로 기재된 청구항                   |
| 필요성     | 소위 개량발명에 있어서 선행기술을 청구항의 전제부에 기재하고 그 선행기술에 대하여 그 발명이 특징으로 하는 개량부분을 특징부에 명확하게 지적하여 독점권이 허여될 발명의 기술영역을 명백히 하는데 공헌함                                                                                                                                                            | 물건(product)의 구조적 특성을 규명하지 못하여 그것을 제조하는 제법(process)을 특정하지 않으면 그 물건도 한정할 수 없는 경우에 이용됨                                                                                                                              | 발명의 구성요소로 통상적인 구조, 방법, 물질 등을 명확하게 구체화하는 것이 불필요하거나 그에 대한 적합한 발명 명칭이 존재하지 않은 경우에 이용됨      |
| 특허요건 판단 | 전제부의 구성요소와 특징부의 구성요소의 결합에 의한 전체에 의하여 출원발명을 특정함(다만, 명세서의 전체적인 기재와 출원 경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 공지기술이라는 취지로 청구 범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우(공지 자인)에는 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함)                                                                       | 물건(제조방법의 기재가 물건의 구조나 성질에 영향을 준 경우 그 제조방법에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건)으로 출원발명을 특정함<br>→ 제조방법에 특허성이 있는지 여부와는 무관                                                                                                       | 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명으로 출원발명을 특정함                                                     |
| 침해여부 판단 | 특허요건 판단과 마찬가지로 전제부의 구성요소와 특징부의 구성요소의 결합에 의한 전체에 의하여 특허발명을 특정함. 다만 출원인이 출원과정에서 선행기술과의 관계에서 신규성 및 진보성 결여의 거절이유를 극복하기 위하여, 구성요소 중 일부를 전제부로 돌리면서 전제부에 대해서는 권리의 보호범위로 주장하지 않겠다는 의사를 분명히 한 때에는, 등록 후에 특징부에는 해당하지 않고 전제부에만 해당하는 균등한 구성요소를 포함하는 기술의 실시에는 자신의 권리를 주장하지 않겠다는 의사로 파악함 | 특허요건 판단과 마찬가지로 물건(제조방법의 기재가 물건의 구조나 성질에 영향을 준 경우 그 제조방법에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건)으로 특허발명을 특정함. 다만, 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정해석함 | 청구항 그 자체만으로 특허발명의 기술적 구성의 내용을 알 수 없으므로 기능적 표현에 상응되는 발명의 설명과 도면에 기재된 실시예로 제한하여 특허발명을 특정함 |

참고자료 2.4 연결부의 해석

| 종 류  | 형 태             | 미 국                                                                                                        | 한 국                                                                                                                                                               |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개방형  | ~을 포함하는         | 열거한 구성요소를 모두 포함하고 그 이외의 것을 더 포함하더라도 여전히 보호범위에 속함.                                                          | 미국과 동일<br>(2003후2072)                                                                                                                                             |
| 폐쇄형  | ~으로 이루어지는       | 열거된 구성요소만 포함하는 경우에만 보호범위에 속하고 그 이외의 것을 포함하는 것은 보호범위에 속하지 않음.                                               | -                                                                                                                                                                 |
| 반폐쇄형 | ~으로 필수적으로 이루어지는 | 열거된 구성요소만을 포함하는 경우에만 보호범위에 속하고 그 이외의 것을 포함하는 것은 보호범위에 속하지 않음. 다만, 주요하지 아니한 구성요소를 더 포함하는 경우에는 여전히 보호범위에 속함. | 명확성 요건(法 42④Ⅱ) 위반의 기재불비에 해당(대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후1442). 단, 용어만을 기준으로 일률적으로 판단하여서는 안 되고 청구범위로부터 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563) |

# 22

## 하나의 특허출원의 범위(法 45)

### I 법조문

#### 제45조 【하나의 특허출원의 범위】(★★) 法 62Ⅳ

- ① (원칙: 하나의 발명 하나의 특허출원) 특허출원은 하나의 발명마다 하나의 특허출원으로 한다. (예외: 일 군의 발명 하나의 특허출원) 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군(群)의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있다.
- ② (일 군의 요건) 제1항 단서에 따라 일 군의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있는 요건은 대통령령[시행령 제6조]으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 시행령 제6조

##### 제6조(1군의 발명에 대한 1특허출원의 요건)

법 제45조제1항 단서의 규정에 의한 1군의 발명에 대하여 1특허출원을 하기 위하여는 다음 각호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 있을 것
2. 청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있을 것. 이 경우 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 것이어야 한다.

[전문개정 2003. 6. 13.]



## II 하나의 특허출원의 범위(法 45)

| 요 건      |                                                                                         | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |              |                  |         |             |             |          |             |     |     |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 서        | 의의                                                                                      | 「하나의 특허출원의 범위」란 하나의 특허출원으로 할 수 있는 발명의 범위를 말하는 것으로서, 하나의 발명마다 하나의 특허출원으로 하는 것을 원칙으로 하나, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군의 발명에 대하여도 하나의 특허출원으로 할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |                  |         |             |             |          |             |     |     |                                                                                         |
|          | 취지                                                                                      | 1. 관련기술 - 하나의 특허권으로 취득함으로써 출원인의 편익을 도모<br>2. 비관련기술 - 담당 기술분야별로 분류하여 심사의 적정성을 기하기 위해 별도로 출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |              |                  |         |             |             |          |             |     |     |                                                                                         |
| 내용       |                                                                                         | 1. 원칙: 하나의 발명마다 하나의 특허출원<br>하나의 발명마다 하나의 특허출원으로 하는 것을 원칙으로 한다(法 45①본문). 「하나의 발명」이란 원칙적으로 카테고리와는 관계없이 하나의 청구항을 의미한다. 다만, 하나의 청구항이라도 마쿠쉬 타입으로 기재된 청구항 또는 둘 이상의 항을 인용하는 청구항은 둘 이상의 발명을 포함할 수 있다.<br>2. 예외: 일 군의 발명에 대해서도 하나의 특허출원 가능<br>하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군(群)의 발명에 대하여도 하나의 특허출원으로 할 수 있다(法 45①단서). 「일 군의 발명」이란 카테고리의 동일성 여부를 불문하고 복수의 발명으로서 하나의 청구 범위에 표현될 수 있는 기술적 상호관련성이 있는 발명을 말한다. 실무적으로는 일 군의 발명에 해당하는 경우에 「발명의 단일성(unity of invention)」을 만족한다고 표현한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |                  |         |             |             |          |             |     |     |                                                                                         |
| 판 단      | 대상                                                                                      | 독립항만을 기준으로 판단                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                  |         |             |             |          |             |     |     |                                                                                         |
|          | 방법                                                                                      | 1. 하나의 특허출원의 요건(단일성)을 만족하는지 여부는 ① 청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 있을 것, ② 청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있을 것(단, 이 경우 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 것이어야 한다.)에 의하여 판단한다.<br>2. 심사 실무는 「개선」의 의미를 신규성, 진보성을 구비한 것으로 파악함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |                  |         |             |             |          |             |     |     |                                                                                         |
| 흥결효과     |                                                                                         | 하나의 특허출원범위의 위반은 발명의 실체에 하자가 있는 것이 아니라 단지 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 절차상의 하자에 불과하기 때문에 거절이유(法 62)에만 해당                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |                  |         |             |             |          |             |     |     |                                                                                         |
| 구제방법     |                                                                                         | 보정(法 47), 분할출원(法 52)을 통해 구제가능.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |                  |         |             |             |          |             |     |     |                                                                                         |
| 기 타      | 다항제 기재방법과의 관계                                                                           | 「다항제의 기재방법」이란 여러 발명을 독립항과 종속항이라는 형식으로 기재하는 방법을 말하고, 「하나의 특허출원의 범위」란 하나의 출원으로 할 수 있는 발명의 범위를 말하는 것으로서, 여러 발명이 다항제 기재방법을 만족하더라도 단일성이 없으면 하나의 특허출원의 범위를 만족하지 아니하기 때문에 하나의 특허출원을 할 수 없게 된다. 다항제 기재방법과 하나의 특허출원의 범위는 상호 독립적이지만 양 제도를 함께 운영하면 독립항만을 기준으로 단일성을 만족하는지 판단하면 되기 때문에 판단의 효율성을 높일 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |              |                  |         |             |             |          |             |     |     |                                                                                         |
|          | 보정에 의한 변화                                                                               | 어떤 특정한 독립항을 기준으로 하여 단일성을 판단한 결과 단일성의 요건이 만족되었을 경우에도, 보정에 의하여 그 기준이 되었던 특정한 독립항이 삭제되거나 또는 발명의 내용이 변경된 결과 단일성의 요건이 만족되지 않게 될 수 있다. 따라서 이와 같은 경우에는 단일성의 요건에 대한 판단을 다시 하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |              |                  |         |             |             |          |             |     |     |                                                                                         |
|          | 개별출원과 1출원의 비교                                                                           | <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[다수의 발명] --&gt; B{일 군의 발명?<br/>(독립항 기준으로 판단)}     B -- No --&gt; C[개별 특허출원(法 45①본문)]     B -- Yes --&gt; D[하나의 특허출원(法 45①단서)]     E[1. 청구항 발명 간에 기술적 상호관련성이 있을 것<br/>2. 발명 전체로 보아 선행기술과 비교하여 개선된 기술적 특징이 동일하거나 상응할 것] --&gt; D           </pre> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단일성을 만족하는 경우</th><th>단일성을 만족하지 아니한 경우</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>개별 특허출원</td><td>가능(法 45①본문)</td><td>가능(法 45①본문)</td></tr> <tr> <td>하나의 특허출원</td><td>가능(法 45①단서)</td><td>불가능</td></tr> <tr> <td>비 고</td><td colspan="2">단일성을 만족하는 발명에 대해서는 비용, 등록가능성 및 권리행사 측면을 고려하여 개별 특허출원할 것인지 아니면 하나의 특허출원을 할 것인지 선택하여야 한다.</td></tr> </tbody> </table> | 구 분 | 단일성을 만족하는 경우 | 단일성을 만족하지 아니한 경우 | 개별 특허출원 | 가능(法 45①본문) | 가능(法 45①본문) | 하나의 특허출원 | 가능(法 45①단서) | 불가능 | 비 고 | 단일성을 만족하는 발명에 대해서는 비용, 등록가능성 및 권리행사 측면을 고려하여 개별 특허출원할 것인지 아니면 하나의 특허출원을 할 것인지 선택하여야 한다. |
| 구 분      | 단일성을 만족하는 경우                                                                            | 단일성을 만족하지 아니한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |                  |         |             |             |          |             |     |     |                                                                                         |
| 개별 특허출원  | 가능(法 45①본문)                                                                             | 가능(法 45①본문)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |              |                  |         |             |             |          |             |     |     |                                                                                         |
| 하나의 특허출원 | 가능(法 45①단서)                                                                             | 불가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |              |                  |         |             |             |          |             |     |     |                                                                                         |
| 비 고      | 단일성을 만족하는 발명에 대해서는 비용, 등록가능성 및 권리행사 측면을 고려하여 개별 특허출원할 것인지 아니면 하나의 특허출원을 할 것인지 선택하여야 한다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |              |                  |         |             |             |          |             |     |     |                                                                                         |

### Ⅲ 하나의 특허출원범위 판단의 구체적 예

| 구분                              | 구체적 예                                                                                                                                                                          | 설 명                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 만<br>족<br>하<br>는<br>예           | <p>【청구항 1】<br/>램프용 필라멘트 A</p> <p>【청구항 2】<br/>필라멘트 A가 있는 램프 B</p> <p>【청구항 3】<br/>필라멘트 A가 있는 램프 B와 회전테 C로 구성되는 서치라이트(searchlight)</p>                                            | 상기 모든 청구항에 공통되는 [특별한 기술적 특징]은 필라멘트 A이다. 청구항 1, 2 및 3 사이에는 단일성이 존재한다.                                                                                                                                                                        |
|                                 | <p>【청구항 1】<br/>영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기</p> <p>【청구항 2】<br/>수신한 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기</p> <p>【청구항 3】<br/>영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기와 수신한 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기로 이루어진 영상신호의 전송장치</p> | 청구항 1의 [특별한 기술적 특징]은 시간축 신장기에 있는 반면 청구항 2의 [특별한 기술적인 특징]은 시간축 압축기에 있으며, 이들은 서로 대응하는 기술적 특징이다(소위 서브컴비네이션과 서브컴비네이션). 따라서 청구항 1과 청구항 2사이에는 단일성이 존재한다. 청구항 3은 청구항 1 및 청구항 2의 [특별한 기술적 특징]들을 모두 포함하므로 청구항 1및 청구항 2와 단일성이 있다(소위 컴비네이션과 서브 컴비네이션). |
| 만<br>족<br>하<br>지<br>않<br>는<br>예 | <p>【청구항 1】<br/>직류모터용 제어회로 A</p> <p>【청구항 2】<br/>직류모터용 제어회로 B</p> <p>【청구항 3】<br/>제어회로 A가 있는 직류모터를 이용하는 장치</p> <p>【청구항 4】<br/>제어회로 B가 있는 직류모터를 이용하는 장치</p>                        | 제어회로 A는 하나의 [특별한 기술적 특징]이고, 제어회로 B는 제어회로 A와는 관련이 없는 또 다른 [특별한 기술적 특징]이다. 따라서 청구항 1과 청구항 3 사이 또는 청구항 2와 청구항 4 사이에는 단일성이 있으나, 청구항 1과 청구항 2 사이 또는 청구항 3과 청구항 4 사이에는 단일성이 없다.                                                                   |
|                                 | <p>【청구항 1】<br/>특징 A를 갖는 콘베이어벨트</p> <p>【청구항 2】<br/>특징 B를 갖는 콘베이어벨트</p> <p>【청구항 3】<br/>특징 A 및 특징 B를 갖는 콘베이어벨트</p>                                                                | 특징 A는 하나의 [특별한 기술적인 특징]이고, 특징 B는 또 다른 하나의 [특별한 기술적인 특징]이다. 따라서 청구항 1과 청구항 3사이 또는 청구항 2와 청구항 3사이에는 단일성이 있으나, 청구항 1과 청구항 2사이에는 단일성이 없다.                                                                                                       |

#### Ⅳ 다항제 기재방법과 하나의 특허출원범위의 관계

【예】【청구항 1】 a, b, c로 구성된 것을 특징으로 하는 X.

【청구항 2】 제1항에 있어서, d를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 X.

【청구항 3】 a, b, e로 구성된 것을 특징으로 하는 Y.

【청구항 4】 제3항에 있어서, f를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 Y.

【해설】 청구항 1 내지 4는 4개의 발명을 2개의 독립항과 2개의 종속항으로 표현함으로써 다항제 기재방법을 만족하고 있다. 그러나 다항제 기재방법을 만족한다고 하더라도 4개의 발명이 각각 단일성을 만족하지 않으면 하나의 특허출원으로 할 수 없다. 상기와 같이 청구항이 4개인 경우에는 원칙적으로 단일성을 만족하는지 6번(=4C2)을 판단하여야 한다. 이하 구체적으로 단일성을 만족하는지 판단하여 본다.

1. 청구항 1과 청구항 2의 판단: 청구항 2는 청구항 1의 종속항으로서 청구항 1과 기술적 특징(a, b, c)이 공통되므로 단일성을 만족한다. 청구항 3과 청구항 4도 마찬가지이다. 즉, 독립항과 그 독립항의 종속항 사이에서는 단일성을 만족하는지 여부를 판단할 필요가 없다.
2. 청구항 1과 청구항 3의 판단: 청구항 1과 청구항 3은 단일성을 만족하는지 판단하여야 한다. 구체적으로 a, b가 발명의 기술적 특징이라면 청구항 1과 청구항 3은 단일성을 만족하여 하나의 특허출원으로 할 수 있지만, c, e가 발명의 기술적 특징이라면 청구항 1과 청구항 3은 단일성을 만족하지 아니하여 하나의 특허출원으로 할 수 없다.
3. 청구항 1과 청구항 4의 판단: a, b가 발명의 기술적 특징이기 때문에 청구항 1과 청구항 3이 단일성을 만족한다면, 청구항 3의 종속항인 청구항 4는 청구항 1과 관련하여 판단할 필요가 없이 단일성을 만족한다. 한편 c, e가 발명의 기술적 특징이기 때문에 청구항 1과 청구항 3이 단일성을 만족하지 아니하면, 청구항 1과 청구항 4는 단일성을 만족하는지 판단할 필요가 없다. 각각 모두가 단일성을 만족하지 아니하면 1특허출원으로 할 수 없기 때문이다. 결국 청구항 1과 청구항 4는 단일성을 만족하는지 판단할 필요가 없다. 청구항 2와 청구항 3 또는 청구항 2와 청구항 4도 마찬가지이다.
4. 결론: 청구항 1과 청구항 3이 단일성을 만족하면 법 제45조제1항 본문과 단서가 모두 적용될 수 있기 때문에 하나 이상의 특허출원을 할 수 있고, 단일성을 만족하지 아니하면 법 제45조제1항 단서가 적용될 수 없기 때문에 최소한 둘 이상의 특허출원(예를 들어, 둘의 특허출원을 하는 경우 청구항 1과 청구항 2를 하나의 특허출원, 청구항 3과 청구항 4를 다른 특허출원으로 할 수 있다.)을 해야 한다.

그 결과 단일성을 만족하는지 여부는 독립항만을 기준으로 판단하면 된다. 즉, 다항제 기재방법은 여러 발명을 독립항과 종속항이라는 형식으로 기재하는 방법을 말하며, 하나의 특허출원의 범위란 여러 발명을 하나의 특허출원으로 할 수 있는 발명의 범위를 말하는 것으로서, 서로 독립적인 제도이지만 양 제도를 함께 운영하면 독립항만을 기준으로 단일성을 만족하는지 판단하면 되기 때문에 판단의 효율성을 높일 수 있다.



도해특허법

### 제3장 이익제도

제4장  
심사

제5장  
특허권

23 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우(法 30)

24 정당한 권리자의 보호(法 34, 35, 99의2)

25 보정(法 46, 47, 51)

26 분할출원(法 52)

27 분리출원(法 52의2)

28 변경출원(法 53)

29 조약우선권주장출원(法 54)

30 국내우선권주장출원(法 55, 56)

## I 법조문

## 제30조 【공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우】(★★) 法 200

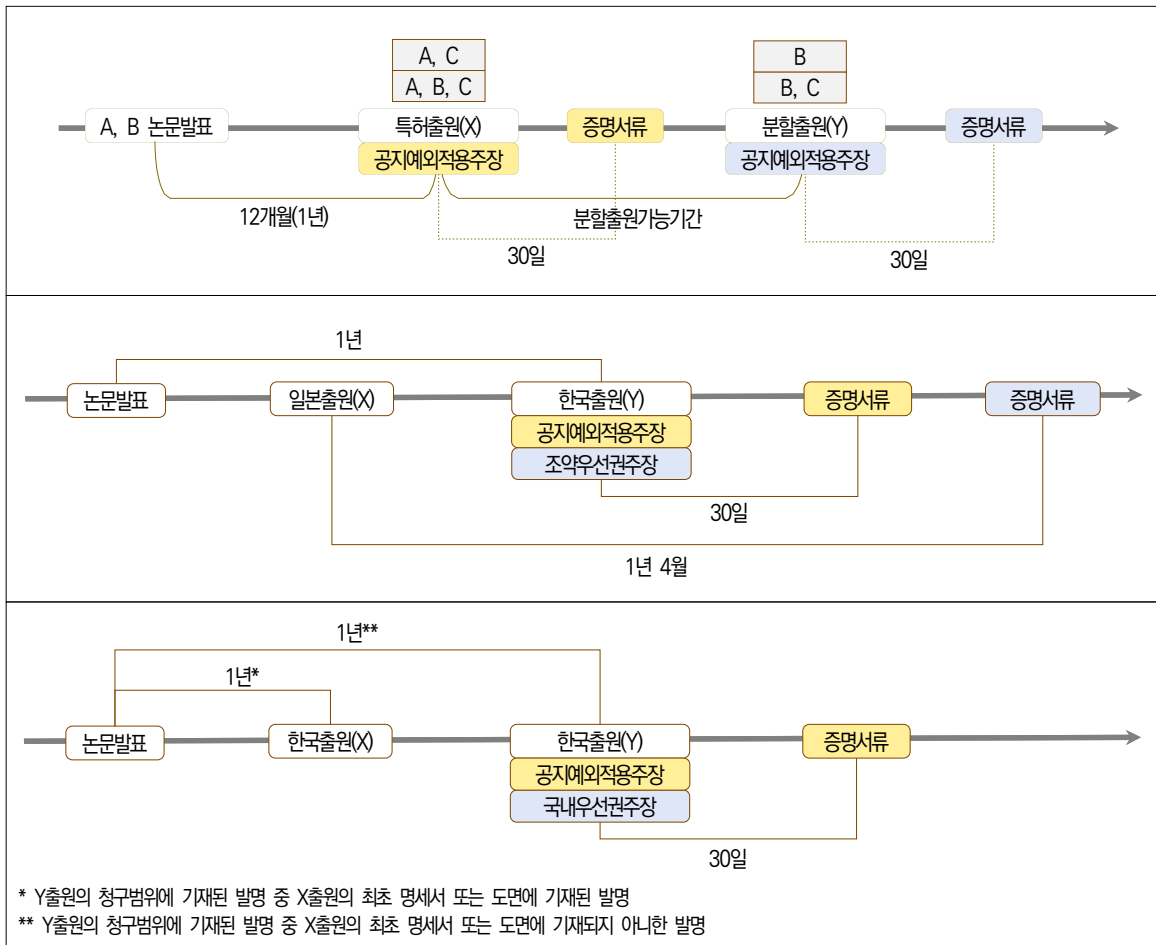
- ① (요건 및 효과) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다. 法 52②본문, 52의2②, 53②본문, 55③
1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다.
  2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우
- ② (절차: 원칙) 제1항 제1호를 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 총리령으로 정하는 방법에 따라 특허출원일로부터 30일 이내에 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 法 52②II, 52의2②, 53②II, 55③
- ③ (절차: 예외) 제2항에도 불구하고 총리령으로 정하는 보원수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다. <신설 2015.1.28.>
1. 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간
  2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간 法 52①III

[전문개정 2014.6.11.]

## II 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우(法 30)

| 제 도     |                   | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서       | 의의                | 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 특허출원 전에 이미 공지 등이 된 것이라 하더라도 법정 사유에 해당하고 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 신규성(法 29 ①) 또는 진보성(法 29②)을 적용할 때에 그 발명은 공지 등이 되지 아니한 것으로 보는 것을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 취지                | 부득이한 사유로 출원 전 공지가 된 경우 출원인의 보호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 요 건     | 주체적               | 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명에 대한 공지가 있을 것.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 객체적               | 1. 공지가 法 30①각호의 법정사유에 해당할 것<br>① 자기 의사에 의하여 공지된 경우<br>특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 법 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록 공고된 경우는 자기 의사에 의하여 공지된 경우에 해당하지 아니한다(法 30① I).<br>② 자기 의사에 반해 공지된 경우<br>특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 법 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우를 말한다(法 30① II). 이는 공지시점을 기준으로 특허를 받을 수 있는 자가 공개시키지 아니하여야겠다는 의사, 즉 「반공개 의사」를 가지고 있음에도 불구하고 이에 반해 발명이 공지된 경우로서, 협박·사기·강박 등에 의하여 공지된 경우를 말한다.<br>2. 공지된 발명과 출원된 발명은 비교 不要.                                                  |
|         | 시기적               | 최선의 공지일로부터 12개월 이내 출원할 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 절 차     | 의사에 의한 공지         | 1. 원칙: 법 제30조제1항제1호의 규정을 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 30②).<br>2. 예외: 보완수수료를 납부한 경우에는 보정기간 또는 특허결정등본송달일로부터 3개월 이내(단, 설정 등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우 그 날까지의 기간)에 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다(法 30③).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 의사에 반한 공지         | 공지일로부터 12개월 이내에는 특허출원을 하여야 하나, 취지기재 및 증명서류는 차후 심사관이 신규성 또는 진보성이 위반되었다고 의견서 제출기회를 주는 경우 그 공지가 의사에 반한다는 증명서류를 제출하면 된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 효 과     | 적법                | 발명의 신규성 또는 진보성을 판단할 때 그 공지기술은 공지 등이 되지 아니한 것으로 본다. 출원일이 소급되거나 선출원주의의 예외가 아니므로 12개월의 유예기간이 있더라도 될 수 있으면 빨리 출원.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 부적법               | 1. 공지예외적용주장이 방식에 위반된 경우 해당 보정명령을 한 절차인 공지예외적용주장을 무효<br>2. 심사관은 공지예외적용을 주장한 공지기술에 의하여 출원된 발명의 신규성 또는 진보성을 판단                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 관 련 문 제 | 다른 출원과의 관계        | 1. 공지일과 공지예외적용을 주장한 특허출원(이하 “甲 출원”라 함)일 사이에 타인의 특허출원(이하 “乙 출원”라 함)이 있으면, 甲 출원은 乙 출원이 공개된 경우 확대된 선출원 위반으로 특허를 받을 수 없게 될 수도 있다. 한편 乙 출원은 신규성 위반으로 특허를 받을 수 없다.<br>2. 甲 출원과 같은 날에 乙 출원이 있는 경우 - 선출원주의에서 협의제, 협의명령은 선출원의 지위가 있음을 전제로 하는데 乙 출원은 신규성 위반으로 거절결정이 확정될 것이고, 2006년 3월 3일 이후 출원에 대해서는 거절결정이 확정되었을 때 선출원의 지위를 인정하지 않기 때문에(개정법 法律 제 7871호), 협의명령을 함이 없이 甲 출원에 대하여 특허를 허여함이 타당할 것이다. 다만, 실무의 태도는 「심사관은 乙 출원은 신규성이 없다는 이유로 거절이유를 통지함과 동시에 甲 출원과 乙 출원에 대하여 협의명령을 한다. 그 결과 협의명령에 따라 乙 출원의 취하 등의 적절한 조치가 있는 경우 甲 출원은 특허를 받을 수 있다.」는 입장이다. |
|         | 복수회에 걸친 공지가 있는 경우 | 1. 공지가 모두 공지예외적용사유(法 30①각호)에 해당하는 경우<br>최선의 공지일로부터 12개월이내 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 출원일로부터 30일 이내 각각 제출하여야 한다. 다만 특정한 어느 하나의 공지와 밀접불가분의 관계에 있는 복수회에 걸친 공지일 경우에는 출원인의 편의를 위해 2번째 이후의 공지에 대하여는 취지기개 및 증명서류의 제출을 생략할 수 있다.<br>2. 공지 중 일부가 공지예외적용사유(法 30①각호)에 해당하지 아니한 경우<br>공지예외적용사유(法 30①각호)가 아닌 공지에 의하여 신규성 또는 진보성을 판단하여야 한다. 예를 들어, 공지예외적용사유에 해당하는 공지가 있는 날과 특허출원일 사이에 출원발명과 동일한 발명에 대하여 공지예외적용사유가 아닌 공지가 있는 경우 그 특허출원된 발명은 신규성이 없는 것으로 하여 거절결정된다.                                                                        |
|         | 국제특허출원의 특례        | 국제특허출원에 관한 발명에 대하여 특허법 제30조 제1항 제1호의 규정을 적용받으려는 자는 그 취지를 적은 서류 및 증명서류를 기준일이 지난 후 30일 이내에 지식재산처장에게 제출할 수 있다(法 200, 施規 111).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### III 각종 제도와 공지예외적용주장의 관계



| 구 분                  | 12개월(法 30①) | 취지기재서면 및 증명서류(法 30②) |
|----------------------|-------------|----------------------|
| 분할출원<br>(法 52②)      | 소급효 ○       | 소급효 ×                |
| 분리출원<br>(法 52의2②)    | 소급효 ○       | 소급효 ×                |
| 변경출원<br>(法 53②)      | 소급효 ○       | 소급효 ×                |
| 조약우선권주장출원<br>(法 54③) | 소급효 ×*      | 소급효 ×                |
| 국내우선권주장출원<br>(法 55①) | 소급효 ○**     | 소급효 ×                |

\* 법 제30조제1항의 “특허출원”을 국내출원으로 제한해석하므로 소급효 불인정  
 \*\* 단, 국내우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서만 인정



## I 법조문

**제34조 【무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호】(★)** 法 88② / 92의2④ I / 59③

발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제2호[거절이유]에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2014.6.11.]

**제35조 【무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호】(★)** 法 133①II 본문, 104 / 99의2 / 88② / 92의2④ I / 59③

제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조제1항제2호[특허무효사유]에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

**제99조의2 【특허권의 이전청구】(★)** 法 133①II 단서, 103의2 / 35 / 86③II

① (이전청구) 특허가 제133조제1항제2호 본문[특허무효사유]에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.

② (권리의 귀속시기) 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다.

1. 해당 특허권
2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권
3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구권

③ (권리가 공유인 경우) 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항[지분양도나 질권설정시 다른 공유자의 동의 필요]에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.

[본조신설 2016.2.29.]

**제103조의2 【특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권】(★★)** 法 99의2 / 133①II 단서 / 118②③

① (성립요건 및 효력) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제99조의2제2항에 따른 특허권의 이전등록이 있기 전에 해당 특허가 제133조제1항제2호 본문[특허무효사유]에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1. 이전등록된 특허의 원(原)특허권자
2. 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.

② (대가) 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 이전등록된 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

[본조신설 2016.2.29.]

**제104조 【무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권】(★★)** 法 118②③

① (성립요건 및 효력) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다. <개정 2016.2.29.>

1. 동일한 발명에 대한 둘 이상의 특허 중 그 하나의 특허를 무효로 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자

2. 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우 그 무효로 된 실용신안등록의 원(原)실용신안권자
  3. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자 **法 35 / 133①Ⅱ**
  4. 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 실용신안의 원실용신안권자 **法 35 / 133①Ⅱ**
  5. 제1호부터 제4호까지의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.
- ② **(대가)** 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.
- [전문개정 2014.6.11.]

■ 무권리자 출원의 등록 전후에 정당한 권리자의 보호방안

| 정당한 권리자<br>보호      | 무권리자의 출원 | 무권리자의 특허  | 비 고                                                         |
|--------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 출원일의 소급효           | ○(法 34)  | ○(法 35)   | 선의의 무권리자에게 중용권(法 104) 인정가능                                  |
| 특허권(특허출원)의<br>이전청구 | ○(해석상)   | ○(法 99의2) | 선의의 무권리자에게 특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권(法 103의2) 인정가능 |

## II 정당한 권리자의 출원의 무권리자의 출원일로 소급에 의한 보호(法 34, 35)

| 제 도              |     | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서                | 의의  | 1. 정당한 권리자란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자로서 일반적으로 발명자나 그 승계인(法 33①본문).<br>2. 무권리자란 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있지 아니한 자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | 취지  | 정당한 권리자 보호와 무권리자의 배척(선발명주의적 요소의 가미)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 소<br>급<br>요<br>건 | 주체적 | 1. 무권리자출원이 있을 것<br>2. 무권리자가 선의·악의인지는 불문. 다만, 선의의 무권리자는 일정요건을 갖출 경우 중용권(法 104)발생                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | 객체적 | 정당한 권리자 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 무권리자 출원의 발명 범위에 포함되어 있어야 한다.(무권리자의 최초 명세서 또는 도면 ≥ 정당한 권리자의 명세서 또는 도면).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 시기적 | 1. 특허를 받지 못하게 된 경우<br>무권리자가 한 특허출원이 법 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 거절이유(法 62Ⅱ)에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 정당한 권리자의 특허출원이 있어야 한다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다(法 34). 「거절이유에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 날」이란 특허거절결정의 확정일을 의미한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  |     | 2. 무효심결이 확정된 경우<br>무권리자의 특허가 법 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 특허 무효사유(法 133①Ⅱ)에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 정당한 권리자의 특허출원이 있어야 한다. 다만, 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권 리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다(法 35).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 절차               |     | 정당한 권리자가 특허출원을 하려면 출원서, 명세서, 필요한 도면 및 요약서와 함께 정당한 권리자임을 증 명하는 서류를 첨부하여 제출하여야 한다(施規 31). 법 제46조의 절차보정사유로 보아 후에 보정할 수 있 도록 함이 타당하다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 효<br>과           | 적법  | 1. 출원일의 소급효(法 34, 35)<br>2. 존속기간(法 88②) - 무권리자 출원일의 다음 날부터 기산<br>3. 소급효의 예외 - 특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지 연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장 할 수 있다. 여기서 특허출원일부터 4년을 기산할 때에는 법 제34조, 제35조에 따른 정당한 권리자의 특허출원의 경우에는 정당한 권리자가 출원을 한 날을 특허출원일로 본다(法 92의2①④).<br>4. 심사청구의 특례 - 정당한 권리자의 특허출원이 무권리자의 출원일로부터 3년의 기간이 지난 후라도 정 당한 권리자가 특허출원을 한 날부터 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다(法 59③).<br>5. 중용권의 발생 - 무권리자의 특허 또는 등록실용신안을 무효로 하고 동일한 발명에 관해 정당한 권리자 에게 특허를 허여한 경우 무효심판청구등등록전에 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발 명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 또는 고안 및 사업의 목적의 범위안에서 유상의 통상실시권을 가진다(法 104). |
|                  | 부적법 | 1. 출원일의 불소급<br>① 정당한 권리자 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 무권리자 출원에 기재된 발명과 다른 발명이 있는 경우 출원일은 소급되지 아니한다.<br>② 다만, 정당한 권리자의 출원은 무권리자의 출원에 의하여 거절결정되지 아니하기 때문에 다른 거절이 유가 없는 경우 특허결정함<br>2. 불수리 - 청구범위를 적지 아니한 명세서를 특허출원서에 첨부하여 특허출원한 정당한 권리자 출원으로 서 그 특허출원 당시에 이미 청구범위제출유예기간이 지난 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### III 특허권의 이전청구에 의한 보호(法 99의2)

| 구 분      | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이전청구     | <p>1. 등록 후의 이전청구<br/>특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하여(法 33①본문) 특허무효사유(法 133①II)에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전을 청구할 수 있다(法 99의2①). 특허권의 이전을 청구할지 아니면 정당한 권리자의 보호규정(法 34, 35)에 따라 정당한 권리자가 별도의 특허출원을 할지 여부는 정당한 권리자의 선택의 문제로서 동일한 발명이라고 할지라도 발명의 설명이나 청구범위를 어떻게 기재하느냐에 따라 권리범위 자체가 달라지기 때문에 권리범위의 재설계의 필요성이 있다면 별도의 특허출원을 하고, 특허절차의 신속성이나 편의성을 고려한다면 특허권의 이전청구를 선택하면 된다.</p> <p>2. 등록 전의 출원인변경신고<br/>법 제99조의2에 명시되어 있지 않지만 무권리자의 특허가 아닌 특허출원에 대하여도 정당한 권리자가 무권리자의 특허출원을 승계, 즉 출원인변경신고를 통하여 특허출원을 계속 진행하는 것을 인정하여 줄 필요가 있다. 무권리자의 특허출원에 대한 심사과정이 정당한 권리자가 특허를 받는데 유리한 상황이라면, 굳이 별도로 특허출원하여 출원일의 소급효를 인정받고 나서 심사과정을 반복할 필요가 없기 때문이다. 이 경우 정당한 권리자는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 취지의 판결(출원인변경 절차의 이행)을 구하는 소 또는 정당한 권리자에 관한 확인의 소에 의한 판결을 출원인변경신고에 첨부하면 될 것이다. 무권리자가 특허출원한 경우에는 특허법 제33조 제1항 본문의 거절이유가 존재하나, 정당한 권리자로 출원인이 변경된 경우에 그 하자는 치유된다고 봐야 한다.</p> |
| 권리의 귀속시기 | <p>특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 법원에의 이전청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 해당 특허권과 보상금 지급 청구권(法 65②, 207④)은 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다(法 99의2②). 이는 처음부터 특허권을 취득할 수 있었던 자는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자이고, 해당 특허발명이 공개됨에 따라 산업발달에 이미 기여하였다는 점에서 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 권리의 행사를 처음부터 인정함이 타당하기 때문이다. 그 결과 前 특허권자가 특허권, 보상금청구권의 행사를 통해 받은 이익은 부당이득으로 이전등록된 특허권자에게 반환해야 할 대상이 될 것이다. 또한, 이전등록이 있기 전의 前 특허권자와 실시권자의 실시권 허락 계약도 무효로 될 것이나 일정한 경우 후술하는 특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권(法 103의2)에 의하여 실시권자의 보호가 가능하다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 무효사유 제외  | <p>특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니함에도 불구하고 등록된 특허라 하더라도 특허권의 이전청구에 기초하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 이전등록(法 99의2)이 있으면 이전등록된 특허권은 특허무효심판을 청구할 수 있는 대상에서 제외된다(法 133①II단서).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 법정실시권 발생 | <p>다음의 어느 하나에 해당하는 자가 특허권의 이전청구에 기초하여 특허권의 이전등록이 있기 전에(法 99의2②) 해당 특허가 법 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하여 특허무효사유(法 133①II)에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 유상의 통상실시권을 가진다(法 103의2).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) 이전등록된 특허의 원(原)특허권자</li> <li>ii) 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자(다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## I 법조문

## 제46조 【절차의 보정】(★★) 法 16 / 195

지식재산처장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다. 이 경우 보정명령을 받은 자는 그 기간에 그 보정명령에 대한 의견서를 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출할 수 있다.

1. 제3조제1항[미성년자 등의 행위능력] 또는 제6조[대리권의 범위]를 위반한 경우
2. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우
3. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우

[전문개정 2014.6.11.]

## 제16조 【절차의 무효】(★★)

① **【절차의 무효】** 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제46조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 제82조제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다.

② **【무효처분의 취소】** 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.>

③ **【송달】** 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항 본문·단서에 따른 무효처분 또는 제2항 본문에 따른 무효처분의 취소처분을 할 때에는 그 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

## 제47조 【특허출원의 보정】(★★) 法 208

① **【보정시기】** 특허출원인은 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다. <개정 2016.2.29.> 法 30③Ⅰ, 52①Ⅰ

1. 거절이유통지(거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 法 170①
2. 거절이유통지(제66조의3제2항[직권 재심사에 따른 특허결정 취소]에 따른 통지를 한 경우에는 그 통지 전의 거절이유통지는 제외한다)에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 法 51①Ⅱ, 63①Ⅱ / 170①
3. 제67조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 청구할 때

② **【보정범위: 신규사항추가금지】** 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. **【외국어특허출원의 경우】**이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다. 法 62Ⅴ, 63의2, 133①Ⅵ(제47조제2항전단 위반) / 66의2⑥

③ **【보정범위: 청구범위 보정범위의 제한】** 제1항제2호 및 제3호에 따른 보정 중 청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.

1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우
2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우
3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우

4. 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우

④ **(보정절차: 여러 차례 보정이 있는 경우)** 제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 보정을 하는 경우에는 각각의 보정절차에서 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하된 것으로 본다. **法 42의3⑦, 170① / 201⑦**

⑤ **(외국어특허출원의 경우: 보정시기)** 외국어특허출원인 경우에는 제1항 본문에도 불구하고 제42조의3제2항에 따라 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. **法 42의3③ I**

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제51조 【보정각하】(★★) **法 170①**

① **(요건)** 심사관은 제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. **(예외)** 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보정인 경우에는 그러하지 아니하다.

<개정 2016.2.29.> **法 170①**

1. 제66조의2에 따른 직권보정을 하는 경우: 그 직권보정 전에 한 보정

2. 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우: 취소된 특허결정 전에 한 보정 **法 47① II 괄호, 63① II**

3. 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우: 그 청구 전에 한 보정

② **(방식)** 제1항에 따른 각하결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다. **法 63① 단서**

③ **(불복)** 제1항에 따른 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다. **(예외)** 다만, 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에서 그 각하결정(제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 각하결정과 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 각하결정은 제외한다)에 대하여 다투는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]



## II 개념정리

| 개 념      | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 최초거절이유통지 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 거절이유통지 전부터 원시적으로 존재하는 거절이유</li> <li>■ 직권 재심사를 하려고 특허출원인에게 특허결정을 취소한다는 사실을 통지한 경우에 그 통지 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유</li> <li>■ 거절결정불복심판에서 취소환송되었는데 취소환송 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 최후거절이유통지 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 한 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 경우<br/>cf) 다만 일반적으로 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 한 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 제51조제1항에 위반되어 보정각하됨</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 특허거절결정   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 거절이유가 동일한 경우(동일한 거절이유에 대해서는 2번의 거절이유통지를 하지 아니함)</li> <li>■ 단, 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 특허거절결정을 하려는 경우에는 최초거절이유통지</li> <li>■ 거절이유의 동일성 판단               <ol style="list-style-type: none"> <li>① 세부적인 표현에 있어 차이가 있더라도 주된 취지에 있어서 동일하면, 동일한 거절이유</li> <li>② 구체적인 예를 들어, 법조문을 달리 하면 거절이유를 달리하며, 법조문을 같이 하더라도 사실을 달리 하면 거절이유를 달리함.</li> </ol> </li> <li>cf) 심판단계에서 거절이유가 동일한 경우에는 기각심결을 하게 됨</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 보정각하     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 원칙 - 최후거절이유통지이후(法 47①Ⅲ시기)의 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 또는 청구범위 보정범위제한(法 47③)을 위반하거나 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 경우</li> <li>■ 예외               <ol style="list-style-type: none"> <li>① 법 제47조제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 경우 최후거절이유통지</li> <li>② 직권보정 전에 한 부적법한 보정이 특허결정이 취소된 후 발견된 경우(직권보정 전 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 또는 재심사 청구할 때 부적법한 보정이 특허결정이 취소된 후 발견된 경우) 보정인정 후 심사진행</li> <li>③ 취소된 특허결정 전에 한 부적법한 보정이 직권 재심사 후 발견된 경우(취소된 특허결정 전 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 또는 재심사 청구할 때 부적법한 보정이 직권 재심사 후 발견된 경우) 보정인정 후 심사진행</li> <li>④ 재심사의 청구 전에 한 부적법한 보정이 재심사 청구 후 발견된 경우(재심사청구 전 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 부적법한 보정이 재심사 청구 후 발견된 경우) 보정인정 후 심사진행</li> <li>⑤ 거절결정불복심판청구 전에 한 부적법한 보정이 거절결정불복심판청구 후 발견된 경우(심판청구 전 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 또는 재심사 청구할 때 부적법한 보정이 심판청구 후 발견된 경우) 보정인정 후 심리진행</li> <li>⑥ 발생한 새로운 거절이유가 직권보정(法 66의2)을 할 수 있는 경우 다른 거절이유가 없다면 특허 결정하면서 직권보정</li> </ol> </li> </ul> |

III 실체보정의 내용(法 47, 51)

| 제 도     |       |         | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요 건     | 주체적   |         | 1. 특허출원인 - 공동출원의 경우 각자<br>2. 임의대리인 - 임의대리인은 특별히 권한을 위임받지 않아도 됨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 시기적   |         | 1. 원칙 - 특허결정의 등본을 송달하기 전(法 47①본문)<br>2. 예외<br>① 최초거절이유통지의 의견서 제출기간(法 47① I)<br>② 최후거절이유통지의 의견서 제출기간(法 47① II)<br>③ 재심사를 청구하는 경우 재심사를 청구할 때(法 47① III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 객체적   |         | 1. 신규사항의 추가금지<br>제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다(法 47②전단).<br>2. 최후거절이유통지 이후(法 47① II III 시기)의 청구범위 보정의 제한(法 47③)<br>① 청구범위에 대한 보정은 i) 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우, ii) 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, iii) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 및 iv) 신규사항추가에의 경우 보정전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 제47조 제3항 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우 중 어느 하나에 해당<br>② 청구범위의 감축의 예 - 청구항의 한정 또는 삭제, 택일적으로 기재된 요소의 삭제, 상위개념의 기재로부터 하위개념의 기재로의 변경, 구성요소의 직렬적 부가 등.<br>3. 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생되지 않을 것(法 51①): 그 보정서의 제출로 인해 전에 없던 거절이유가 발생되지 않아야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 절 차   |         | 출원인은 보정서를 제출하고 다음 날까지 보정료를 내야 한다(法 82①).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| 효 과     | 적법    |         | 명문의 규정은 없으나 보정된 내용대로 출원한 것으로 취급(해석상 소급효 인정)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 부 적 법 | 시기      | 불수리                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|         |       | 미 보 정 전 | 1. 法 47①본문 또는 法 47① I 시기의 보정이 法 47②의 범위에 위반된 경우 → 거절이유통지<br>2. 法 47① II 또는 法 47① III 시기의 보정이 法 47②③의 범위에 위반된 경우 또는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생된 경우<br>① 보정이 부적법하면 더 이상의 의견서 제출기회를 주지 않고 서면으로 이유를 붙여 보정을 보정각하(法 51①②, 63①단서). 그 결과 심사관은 보정 전의 명세서 또는 도면에 의하여 출원을 심사하여 거절이유가 동일한 경우 거절결정.<br>② 보정각하결정에 대해서는 별도로 불복할 수 없으며, 이후 특허거절결정에 대한 불복심판의 심리 중에 보정각하결정이 부당함을 함께 다룰 수 있음. 단, i) 법 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 각하결정과 ii) 법 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 각하결정은 거절결정불복심판에서 다룰 수 없음(法 51③).<br>③ 보정각하의 예외<br>i) 청구항을 삭제하는 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 경우, ii) 법 제66조의2에 따른 직권보정을 하는 경우 그 직권보정 전에 한 보정, iii) 법 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 보정, iv) 법 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정은 보정각하결정을 하지 아니한다(法 51①단서). 또한, v) 발생한 새로운 거절이유가 직권보정(法 66의2)을 할 수 있는 경우라면, 심사관은 보정을 승인하고 이후 절차를 진행할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                    |
|         |       |         | 미 보 정 후                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. 신규사항의 추가금지(法 47②전단) 위반 → 특허무효사유(法 133①)<br>2. 청구범위 보정범위 제한(法 47③) 위반의 경우 → 제재조치× (형식적 하자, 일반적인 이익을 해치지 않음)<br>3. 다만, 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생하지 않을 것(法 51①중단) 위반 → 다른 거절이유가 제한열거적인 특허무효사유에 해당하는 경우 무효심판청구가능(法 133①) |
| 외국어특허출원 |       |         | 1. 보정시기의 제한<br>일반적으로 법 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 보정할 수 있음에도 불구하고 외국어특허출원인 경우에는 국어번역문을 제출한 경우(法 42의3②)에만 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다(法 47⑤). 한편, 명세서 또는 도면을 보정한 경우에는 국어번역문을 교체할 수 없다(法 42의3③ I)<br>2. 보정범위의 제한<br>법 제47조제2항의 신규사항추가금지와 관련하여, 외국어특허출원에 대한 명세서 또는 도면의 보정은 특허                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |

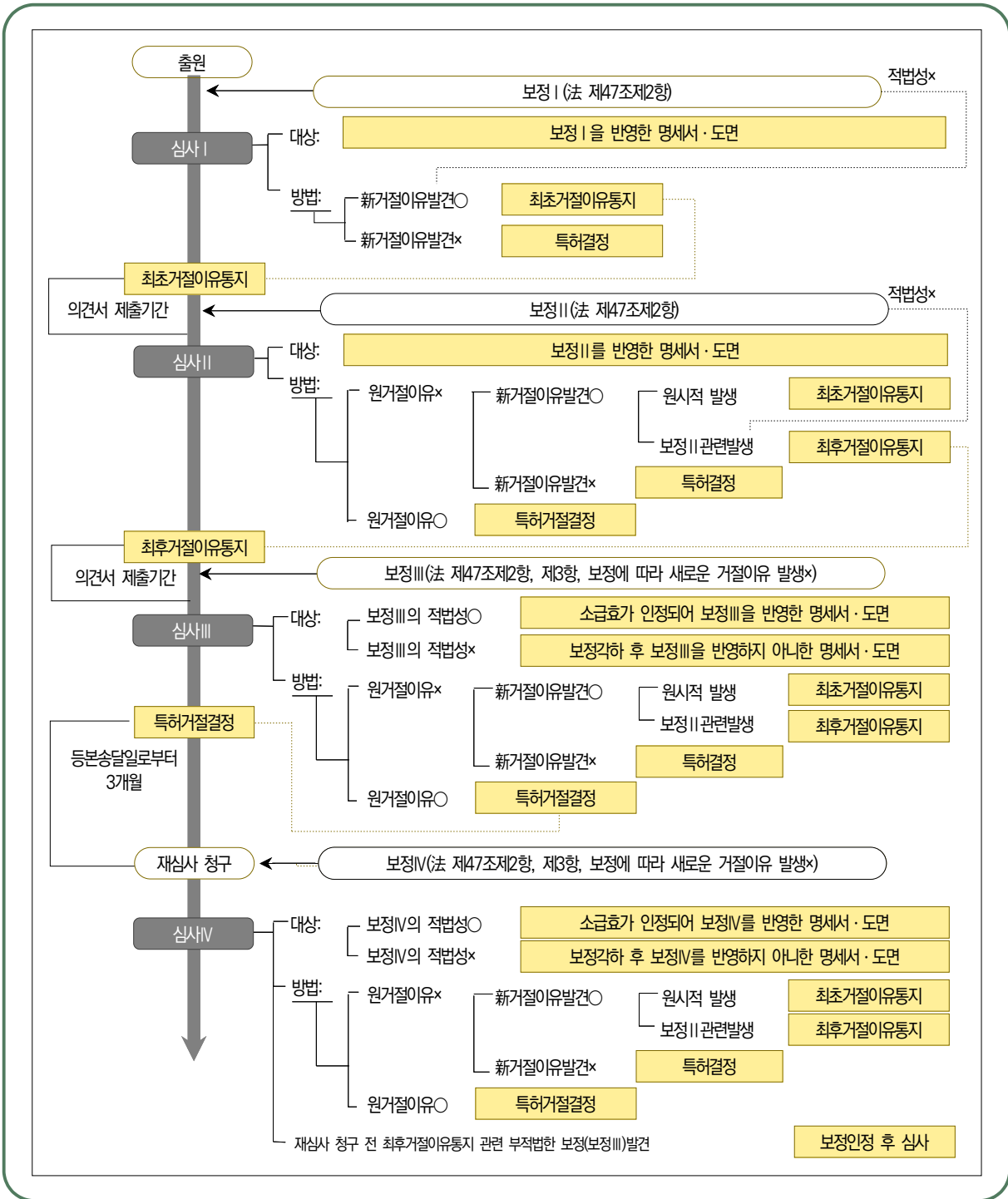


|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 또한, 보정은 최종 국어번역문(법 제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분을 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다(法 47②). 즉, 명세서 또는 도면의 보정은 원문(외국어 명세서 또는 도면) 및 국어번역문 범위이어야 한다.</p> <p>3. 신규사항추가금지(法 47②) 위반의 취급</p> <p>(1) 등록 전</p> <p>① 심사관은 法 47①본문 시기의 자진보정이 원문 및 국어번역문 중 어느 하나의 범위를 벗어난 신규사항추가금지(法 47②) 위반인 경우에는 최초거절이유통지를 하고, 法 47① I 시기의 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 위반인 경우에는 최후거절이유통지를 한다.</p> <p>② 또한, 심사관은 法 47①IIIII시기의 보정이 원문 및 국어번역문 중 어느 하나의 범위를 벗어나 신규사항추가금지(法 47②) 위반인 경우에는 서면으로 이유를 붙여서 보정에 대하여 직권으로 각하결정을 한다(法 51①②). 출원인은 보정각하결정에 대해서는 별도로 불복할 수 없으며, 이후 특허거절결정에 대한 불복심판의 심리 중에 보정각하결정이 부당함을 함께 다룰 수 있다. 다만, i) 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 각하결정과 ii) 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 각하결정은 거절결정불복심판에서 다룰 수 없다(法 51③).</p> <p>(2) 등록 후</p> <p>등록 후에는 원문의 범위를 벗어난 보정(法 47②전단)의 경우에 특허무효사유(法 133①)이다. 원문 기준의 보정 기회를 부여하여 출원인의 진정한 권리를 보장하는 한편, 국어번역문의 제출은 실제적인 문제라기보다는 심사관과 일반 공중이 정확한 내용을 알기 위한 절차적인 문제에 해당하기 때문에, 법 제47조제2항 후단의 국어번역문에 기재된 사항의 범위를 벗어난 보정은 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2)에만 해당하고, 특허무효사유(法 133①)에는 해당하지 않는다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>국제특허출원의 특례</b></p> | <p>1. 보정시기의 제한</p> <p>① 국제출원은 국제단계에서 국제사무국 또는 국제예비심사기관에 대하여 보정을 할 수 있으나 국내 단계에 있어서는 일정한 제한이 있다. 즉 국제특허출원에 관하여는 i) 법 제82조제1항에 따른 수수료를 낼 것, ii) 법 제201조제1항에 따른 국어번역문을 제출할 것(다만, 국어로 출원된 국제특허출원인 경우는 그러하지 아니하다), 및 iii) 기준일(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사를 청구한 때를 말한다)이 지날 것의 요건을 모두 갖추지 아니하면 법 제47조제1항에도 불구하고 보정(법 제204조제2항 및 제205조제2항에 따른 보정은 제외한다)을 할 수 없다(法 208①).</p> <p>② 그러나 국제사무국에 대한 보정 또는 국제예비심사기관에 대한 보정이 있는 후에 지식재산처에 제출된 국어번역문 또는 사본은 각각 법 제204조제2항 또는 법 제205조제2항에 따라 그 국어번역문 또는 사본에 의하여 보정된 것으로 간주되므로 이 조의 적용을 받지 아니한다. 즉, 기준일이 지나기 전에 보정했음에도 불구하고 국어번역문 또는 사본을 제출한 경우 국내법의 적용을 받는 보정으로 간주한다.</p> <p>2. 보정범위의 제한</p> <p>외국어로 출원된 국제특허출원의 경우 명세서 또는 도면의 보정은 「국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」에 기재된 사항의 범위에서 하여야 하고, 「법 제201조제5항에 따른 최종 국어번역문(법 제201조제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 국제출원일까지 제출한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)」에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다(法 47②).</p> <p>3. 신규사항추가금지(法 47②) 위반의 취급</p> <p>(1) 등록 전</p> <p>① 심사관은 法 47①본문 시기의 자진보정이 원문 및 국어번역문 중 어느 하나의 범위를 벗어난 신규사항추가금지(法 47②) 위반인 경우에는 최초거절이유통지를 하고, 法 47① I 시기의 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 위반인 경우에는 최후거절이유통지를 한다.</p> <p>② 또한, 심사관은 法 47①IIIII시기의 보정이 원문 및 국어번역문 중 어느 하나의 범위를 벗어나 신규사항추가금지(法 47②) 위반인 경우에는 서면으로 이유를 붙여서 보정에 대하여 직권으로 각하결정을 한다(法 51①②). 출원인은 보정각하결정에 대해서는 별도로 불복할 수 없으며, 이후 특허거절결정에 대한 불복심판의 심리 중에 보정각하결정이 부당함을 함께 다룰 수 있다. 다만, 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 각하결정은 거절결정불복심판에서 다룰 수 없다(法 51③).</p> <p>(2) 등록 후</p> <p>등록 후에는 원문의 범위를 벗어난 보정(法 47②전단)의 경우에 특허무효사유(法 133①)이다.</p> |

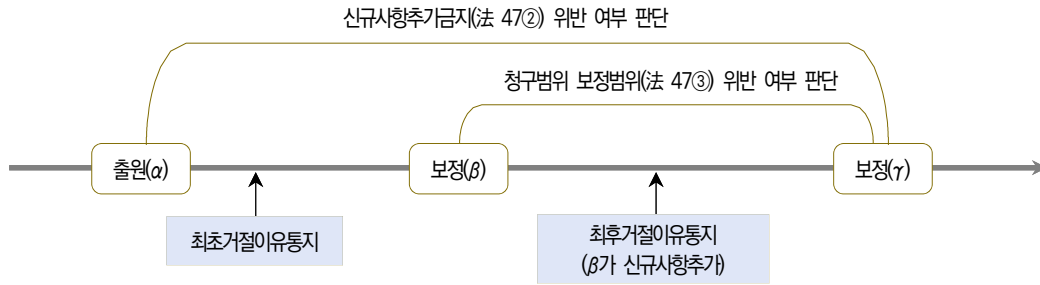
Ⅳ 보정각하(法 51)

| 제 도 |            | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서   | 의의         | 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ) 또는 재심사를 청구할 때(法 47①Ⅲ)의 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 또는 청구범위 보정범위제한(法 47③)을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되는 경우에 그 보정을 결정으로 각하하는 행정처분이다. 보정각하를 한 경우 심사관 또는 심판관은 보정 전의 명세서 또는 도면에 의하여 거절이유가 해소되었는지를 판단하게 된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 취지         | 신규사항추가 등과 같은 부적법한 보정은 ① 선출원주의에 반하고 ② 선의의 제3자에게 불측의 손해를 주어 법적 안정성을 훼손하게 되는바 제한된 범위내에서 보정을 허용하고 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 요건  | 주체적        | 심사단계에서는 심사관이, 심판단계에서는 심판관이 행한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 객체적        | 1. 원칙<br>최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ) 또는 재심사를 청구할 때(法 47①Ⅲ) 보정이 보정의 범위(法 47②③)를 벗어나거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되어 부적법한 경우<br>2. 예외<br>① 법 제47조제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 경우 - 최후거절이유통지<br>- 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 특허법 제42조제3항제1호, 제4항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우<br>- 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경하거나<br>- 종속항이 2 이상의 항을 인용하는 경우에 인용되는 항의 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재를 누락함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우<br>- 다만, 청구항을 삭제하는 보정을 하였더라도 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 불포함<br>② 직권보정 전에 한 부적법한 보정이 특허결정이 취소된 후 발견된 경우 - 보정인정 후 심사 진행<br>③ 취소된 특허결정 전에 한 부적법한 보정이 직권 재심사 후 발견된 경우 - 보정인정 후 심사 진행<br>④ 재심사의 청구 전에 한 부적법한 보정이 재심사 청구 후 발견된 경우 - 보정인정 후 심사 진행<br>⑤ 거절결정불복심판청구 전 부적법한 보정이 거절결정불복심판청구 후 발견된 경우 - 보정인정 후 심리 진행<br>⑥ 발생한 새로운 거절이유가 직권보정(法 66의2)을 할 수 있는 경우 - 다른 거절이유가 없다면 특허결정하면서 직권보정 |
| 절차  | 방식         | 1. 서면으로 이유를 구체적으로 명시함.(法 51②)<br>2. 단, 직권으로 보정각하결정함에도 불구하고 의견서 제출기회를 주지 않아도 됨(法 63①단서).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 불복         | 1. 원칙<br>출원인은 보정각하결정에 대하여는 단독으로 불복할 수 없고 특허거절결정에 대한 심판을 청구한 경우에는 함께 보정각하결정에 대하여 다룰 수 있다(法 51③).<br>2. 예외<br>i) 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 보정각하결정과 ii) 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정각하결정은 거절결정불복심판에서 다룰 수 없다(法 51③괄호).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 효과  | 보정의 불인정    | 보정각하된 경우 해당 보정은 없었던 상태로 되므로 심사관·심판관은 보정전의 명세서를 기준으로 심사 또는 심판을 진행한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 보정각하후 절차진행 | 1. 일반심사단계 또는 재심사단계 - 거절결정<br>2. 심판단계 - 기각심결                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

V 실제보정에 대한 심사절차



VI 법 제47조 제3항 제4호의 구체적인 예



해설

보정(β)된 명세서 또는 도면이 출원(α)의 명세서 또는 도면과 비교하여 신규사항추가라는 이유로 최후거절이유가 통지되었을 때 보정(γ)이 적법하기 위해서는 i) 신규사항추가가 아닐 것(法 47②), ii) 청구범위 보정범위의 제한을 만족할 것(法 47③), iii) 보정에 따라 새로운 거절이유가 생기지 않을 것을 만족하여야 한다. 그런데 신규사항추가인지 여부(法 47②)는 출원(α)의 명세서 또는 도면과 보정(γ)된 명세서 또는 도면을 비교하여 판단하고, 청구범위 보정범위의 제한을 만족하는지(法 47③)는 보정(β)된 청구범위와 보정(γ)된 청구범위를 비교하여 판단한다. 이 경우 최후거절이유를 해소하기 위해 신규사항추가한 사항을 삭제하는 보정을 하려고 하는 경우 청구범위의 확장으로 제47조제3항제1호 위반의 문제가 될 수 있으므로 제47조제3항제4호에서 그 예외를 인정하고 있으며, 구체적인 예1)는 다음과 같다.

|       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사실 관계 | 청구항 1 : A+B로 이루어진 장치<br>청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치<br><b>【최초거절이유통지】</b> 청구항 1은 인용대상에 의하여 진보성 없음<br><b>【최초보정 후의 명세서】</b><br>청구항 1 : A+B+D로 이루어진 장치(D는 신규사항, 진보성은 인정됨)<br>청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치<br><b>【최후거절이유통지】</b> 청구항 1의 D는 신규사항임 |                                                                                                                                                   |
| 예1    | <b>【최후보정 후의 명세서】</b><br>청구항 1 : A+B로 이루어진 장치<br>청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치                                                                                                                                                          | <b>【보정인정】</b> 신규사항이 추가되기 직전의 청구범위로 되돌아갔으므로 보정은 인정됨<br><b>【특허거절결정】</b> 청구항 1은 진보성 없으므로 특허거절결정<br>(단, 출원인의 의견서 등의 내용을 검토하여 진보성 있는 것으로 판단되는 경우 특허결정) |
| 예2    | <b>【최후보정 후의 명세서】</b><br>청구항 1 : A+b로 이루어진 장치(b는 B의 하위개념, 진보성은 인정됨)<br>청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치                                                                                                                                    | <b>【보정인정】</b> 청구항 1은 신규사항이 추가되기 직전의 청구범위로 되돌아가면서 청구항을 한정하여 청구범위를 감축하는 경우이므로 보정은 인정됨<br><b>【특허결정】</b> 청구항 1, 2는 거절이유를 발견할 수 없으므로 특허결정함             |
| 예3    | <b>【최후보정 후의 명세서】</b><br>청구항 1 : A+B+E로 이루어진 장치(A+B+E는 최초 명세서 등의 범위 내 발명이고 진보성은 인정됨)<br>청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치                                                                                                                   | <b>【보정인정】</b> 청구항 1은 신규사항이 추가되기 직전의 청구범위로 되돌아가면서 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우이므로 보정은 인정됨<br><b>【특허결정】</b> 청구항 1, 2는 거절이유를 발견할 수 없으므로 특허결정함             |

1) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준」, 2023, 4211면.

**Ⅶ 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생하지 않을 것의 구체적인 예(법 제47조 제2항 만족 전제)**

| 구체적 예                                                                                                                                                                                                                                     | 설 명                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>청구항 1 : A+B로 이루어진 장치<br/> 청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치<br/> 【최후거절이유통지】 청구항 1, 청구항 2는 인용대상에 의하여 진보성 없음.<br/> 【최후보정 후의 명세서】<br/> 청구항 1 : 삭제<br/> 청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치</p>                                                                    | <p>【보정인정】 청구항 삭제로서 청구범위의 감축이고, 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생하지 아니하여 보정 인정됨.<br/> 【특허거절결정】 청구항 2는 진보성이 없으므로 특허거절결정함</p>                                                                                       |
| <p>청구항 1 : A+B로 이루어진 장치<br/> 청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치<br/> 【최후거절이유통지】 청구항 1, 청구항 2는 인용대상에 의하여 진보성 없음.<br/> 【최후보정 후의 명세서】<br/> 청구항 1: 삭제<br/> 청구항 2: A+B+C+D로 이루어진 장치</p>                                                                    | <p>【보정인정】 청구항 1의 삭제와 청구항 2의 D 부가는 청구범위의 감축이고, 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생하지 아니하여 보정 인정함.<br/> 【특허거절결정 또는 특허결정】 청구항 2가 진보성이 없는 경우 특허거절결정하고, 청구항2가 진보성이 있는 경우 특허결정함.</p>                                     |
| <p>청구항1: A+B로 이루어진 장치<br/> 청구항2: A+B+C로 이루어진 장치<br/> 【최후거절이유통지】 청구항 1, 청구항 2는 진보성 없음.<br/> 【최후보정 후의 명세서】<br/> 청구항1: 삭제<br/> 청구항2: A+B+C이고, A는 a로 이루어진 장치(A는 a로 내적한정하면서, 기재불비가 발생한 경우)</p>                                                 | <p>【보정각하】 청구항 2의 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생하였기 때문에 보정이 부적법하여 보정각하함.<br/> 【특허거절결정】 청구항 1, 청구항 2는 진보성이 없으므로 특허거절결정함.</p>                                                                                    |
| <p>청구항 1 : A+B로 이루어진 장치<br/> 【최후거절이유통지】 청구항 1이 인용대상 1에 의하여 진보성 없음.<br/> 【최후보정 후의 명세서】<br/> 청구항 1 : A+B+C로 이루어진 장치(인용대상 1에 대해서는 진보성이 인정되나 인용대상 1 및 인용대상 2에 의하여 진보성 없음. 인용대상 2는 C의 부가로 인해 추가로 필요)</p>                                       | <p>【보정각하】 청구항 1의 보정에 따라 보정 전에 없던 새로운 거절이유가 발생하였기 때문에 보정각하함.<br/> 【특허거절결정】 청구항 1(A+B)은 인용대상 1에 의하여 진보성이 없으므로 특허거절결정함.</p>                                                                            |
| <p>청구항 1 : A로 이루어진 장치<br/> 【최후거절이유통지】 청구항 1이 인용대상 1에 의하여 진보성 없음.<br/> 【최후보정 후의 명세서】<br/> 청구항 1 : A+B로 이루어진 장치(인용대상 1에 B도 개시되어 있어 여전히 진보성이 부정됨)</p>                                                                                        | <p>【보정인정】 청구항 1에 기재된 발명이 인용대상 1로부터 진보성이 부정된다는 거절이유는 기 통지되었던 거절이유이므로 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하지 아니하여 보정 인정함<br/> 【특허거절결정】 청구항 1(A+B)은 인용대상 1에 의하여 진보성이 없으므로 특허거절결정함.</p>                                  |
| <p>청구항 1 : A+B로 이루어진 장치<br/> 청구항 2 : 청구항 1에 있어서, C를 부가한 장치<br/> 【최후거절이유통지】 청구항 1은 진보성 없음.<br/> 【최후보정 후의 명세서】<br/> 청구항 1 : 삭제<br/> 청구항 2 : 청구항 1 에 있어서, C를 부가한 장치</p>                                                                      | <p>【보정인정】 청구항 1을 삭제하는 보정은 청구범위의 감축에 해당함. 청구항 1의 삭제로 청구항 2에 기재불비라는 새로운 거절이유가 발생하였으나 법 제51조 제1항 괄호 규정에 의하여 보정은 인정<br/> 【최후거절이유통지】 청구항을 삭제하면서 다항제 기재불비라는 새로운 거절이유가 생긴 경우 다시 최후거절이유통지를 함.</p>           |
| <p>청구항 1 : A+B로 이루어진 장치<br/> 청구항 2 : A+E로 이루어진 장치<br/> 청구항 3 : 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, C를 부가한 장치<br/> 【최후거절이유통지】 청구항 1은 진보성 없음.<br/> 【최후보정 후의 명세서】<br/> 청구항 1 : 삭제<br/> 청구항 2 : A+E로 이루어진 장치<br/> 청구항 3 : 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, C를 부가한 장치</p> | <p>【보정인정】 청구항 1을 삭제하는 보정은 청구범위의 감축에 해당함. 한편, 청구항 3은 삭제된 청구항 1을 인용하고 있지만 삭제된 청구항 1의 인용을 제외하고 해석하여 청구항의 발명이 A+E+C로 명확하게 파악되기 때문에 오기임이 명백한 경우로 취급하여 보정을 인정함<br/> 【특허결정】 특허결정하면서 명백한 오기에 대해서는 직권보정함</p> |



26

## 분할출원(法 52)

## I 법조문

## 제52조 【분할출원】(★) 法 52의2④, 55①II / 59③

- ① (요건) 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 다만, 그 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다. <개정 2015. 1. 28., 2016. 2. 29., 2021. 10. 19.>
1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간 法 208①
  2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간
  3. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간 法 62VI, 63의2, 133①VI / 30③II
- ② (효과) 제1항에 따라 분할된 특허출원(이하 "분할출원"이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. (예외) 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 法 92의2④II
1. 분할출원이 제29조제3항[확대된 선출원]에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우
  2. 제30조제2항[공지예외적용주장출원의 취지 및 증명서류]을 적용하는 경우
  3. 제54조제3항[조약우선권주장출원의 취지]을 적용하는 경우
  4. 제55조제2항[국내우선권주장출원의 취지]을 적용하는 경우
- ③ (절차: 일반) 제1항에 따라 분할출원을 하려는 자는 분할출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다.
- ④ (절차: 우선권주장 및 증명서류 제출 간주) 분할의 기초가 된 특허출원이 제54조 또는 제55조에 따라 우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 특허출원에 대하여 제54조제4항에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다. <신설 2021. 10. 19.>
- ⑤ (기간의 특례: 우선권주장취하 시기의 특례) 제4항에 따라 우선권을 주장한 것으로 보는 분할출원에 관하여는 제54조제7항 또는 제55조제7항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취할 수 있다. <신설 2021. 10. 19.>
- ⑥ (기간의 특례: 조약우선권증명서류 제출의 특례) 분할출원의 경우에 제54조에 따른 우선권을 주장하는 자는 같은 조 제4항에 따른 서류를 같은 조 제5항에 따른 기간이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 3개월 이내에 지식재산처장에게 제출할 수 있다. <개정 2013.3.22.>
- ⑦ (기간의 특례: 외국어특허출원의 국어번역문 제출의 특례) 분할출원이 외국어특허출원인 경우에는 특허출원인은 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 제42조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다. <개정 2021. 10. 19.>
- ⑧ (기간의 특례: 청구범위제출유예기간의 특례) 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 분할출원에 관하여는 제42조의2제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다. <개정 2021. 10. 19.>

[전문개정 2014.6.11.]

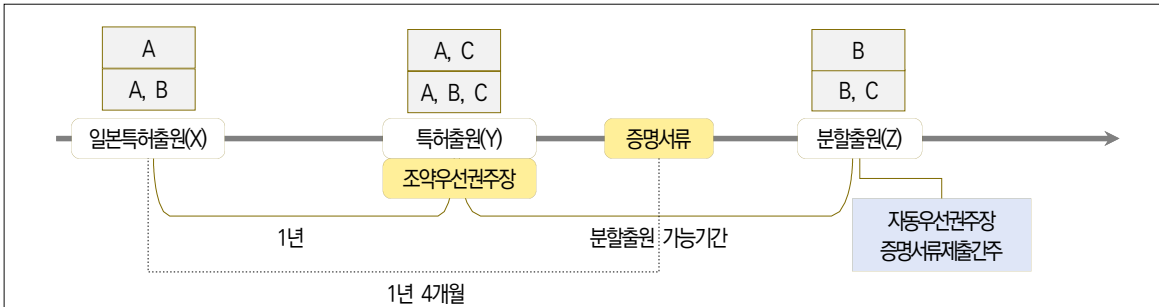
## II 분할출원(法 52)

| 제 도    |     | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서      | 의의  | 원출원에 둘 이상의 발명이 포함된 경우 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 보정할 수 있는 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(거절결정불복심판청구를 할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 기간을 말한다) 또는 특허결정등본을 송달받은 날로부터 3개월(다만, 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간) 이내의 기간에 그 일부를 별개의 특허출원으로 분할하는 것을 말하며, 분할출원을 한 경우 그 분할출원은 원출원한 때에 출원한 것으로 본다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 취지  | 출원일체의 원칙 회피 / 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명의 보호 / 권리범위 재설계 기회 확보                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 요<br>건 | 주체적 | 분할출원 당시 분할출원인은 원출원의 출원인 또는 그 승계인과 동일인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 객체적 | 1. 원출원의 요건<br>① 원출원의 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 둘 이상의 발명이 포함<br>② 분할출원 당시 원출원이 적법하게 출원계속중(원출원이 취하 또는 포기된 날과 동일일자 분할출원이 있는 경우 출원계속중인 것으로 간주),<br>③ 분리출원이 아닐 것<br>2. 분할출원의 요건<br>분할출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내이어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 시기적 | 1. i) 제47조 제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간, ii) 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(거절결정불복심판청구를 할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 기간을 말한다) 이내의 기간 또는 iii) 특허결정 또는 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 법 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간<br>2. ii)의 기간에 거절결정불복심판을 청구하였더라도 분할출원가능. ii), iii)의 기간에 재심사 청구를 한 경우에는 그 기간 이내라도 분할출원 불가. 물론, 재심사 과정에서 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 다시 분할출원 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 절차     |     | 1. 원출원 표시를 한 분할출원서와 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 지식재산처장에게 제출(法 52③)<br>2. 원출원이 조약 또는 국내우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며(자동우선권주장간주), 원출원에 대하여 제54조제4항의 조약우선권주장의 증명서류 제출기간 내 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다(자동증명서류제출간주)(法 52④).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 효<br>과 | 적법  | 1. 출원일의 소급효<br>적법한 분할출원은 원출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원이 다음에 해당하는 경우에는 해당 분할출원 시에 출원한 것으로 본다.<br>① 확대된 선출원에 관한 규정(法 29③④)에서 다른 특허출원에 해당하는 경우<br>② 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 주장을 위한 취지기재, 증명서류 제출기간(法 30②)<br>③ 조약우선권주장출원의 취지기재(法 54③)<br>④ 국내우선권주장출원의 취지기재(法 55②)<br>⑤ 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장(法 92의2①)시 특허출원일의 기산일(法 92의2④)<br>2. 원출원과의 관계 - 원출원과는 별개의 출원으로 심사청구, 출원공개 및 등록료 납부 등을 별개로 하여야 함. 그러나 분할출원의 심사순서는 지식재산처장이 정하는 바(분할출원의 심사청구순서)에 의함. 원출원이 우선권주장을 하지 않은 경우 분할출원은 그 주장을 할 수 없으나, 원출원이 공지예외적용주장을 하지 않더라도 분할출원은 그 주장이 가능<br>3. 선출원주의의 회피 - 분할 후 원출원의 청구범위에 기재된 발명과 분할출원의 청구범위에 기재된 발명이 동일한 경우에는 동일자에 동일발명에 관한 출원이 있으므로 협의제(法 36②)가 적용(원출원의 청구범위에 기재된 발명의 삭제 보정 필요)<br>4. 우선권주장취하기간의 특례 - 법 제52조제4항에 따라 우선권을 주장한 것으로 보는 분할출원에 관하여는 우선권주장의 보정 또는 추가의 기한(法 54⑦, 55⑦)이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다(法 52⑤).<br>5. 조약우선권주장 증명서류 제출의 특례 - 분할출원이 조약우선권주장을 수반하는 경우에는, 최우선일로부터 1년 4개월의 기간이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 3개월 이내에 지식재산처장에게 증명서류 제출(法 52⑥)<br>6. 청구범위제출유예의 특례 - 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 분할출원에 관하여는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날(다만, 기한 이전에 출원심사 청구의 취지를 통지(法 60③) 받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)의 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정(法 52⑧). |

|                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |           | <p>7. 심사청구의 특례 - 분할출원에 관하여는 원출원일로부터 3년의 기간이 지난 후라도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 심사청구(法 59③).</p> <p>8. 국내우선권주장출원 불가 - 분할출원은 국내우선권주장출원의 기초가 되는 선출원이 될 수 없다(法 55①Ⅱ). 그러나 국내우선권주장출원을 기초로 분할출원할 수는 있다(法 52④⑤참조).</p>                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 | 부적법       | <p>1. 불수리 - ① 분할출원 당시 분할출원의 출원인이 원출원의 출원인과 일치하지 아니한 경우, ② 분할출원서가 기간을 지나서 제출된 경우, ③ 분리출원을 기초로 분할출원서가 제출된 경우, ④ 원출원의 절차가 종료된 이후에 분할출원서가 제출된 경우</p> <p>2. 거절이유 등 - 분할출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 포함되어 있지 아니한 경우 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法 133①)</p>                                                                                                                                                |
| 외<br>국<br>어<br>특<br>허<br>출<br>원 | 원출원       | 원출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 국어번역문(法 42의3②)이 제출된 경우에만 분할출원할 수 있다(法 52①단서).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | 분할출원      | <p>1. 분할출원이 외국어특허출원인 경우에 특허출원인은 국어번역문(法 42의3②) 또는 새로운 국어번역문(法 42의3③본문)을 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날(다만, 기한 이전에 출원심사 청구의 취지를 통지(法 60③)받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)의 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다(法 52⑦본문).</p> <p>2. 다만, i) 명세서 또는 도면을 보정(법 제42조의3제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)한 경우, ii) 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다(法 52⑦단서).</p> |
| 관<br>련<br>문<br>제                | 재분할출원     | 원출원(이하 “父출원”이라 한다)으로부터 분할출원(이하 “子출원”이라 한다)하고, 다시 子출원을 원출원으로 하여 분할출원(이하 “孫子출원”이라 한다)하였을 때 i) 孫子출원이 子출원에 대하여 분할출원의 요건을 충족할 것, ii) 子출원이 父출원에 대하여 분할출원의 요건을 충족할 것, iii) 孫子출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 父출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 범위 이내일 것을 만족하는 경우 孫子출원의 출원일은 父출원의 출원일로 소급한다.                                                                                                                                                         |
|                                 | 국제특허출원 특례 | 국제특허출원을 분할출원하기 위해서는 수수료 납부 및 출원번역문 제출(단, 국어출원의 경우 제외) 및 기 준일이 지나야만 한다(法 208①).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



### III 조약우선권주장을 수반하는 분할출원



#### 해설

분할출원(Z)은 원출원(Y)의 출원일로 소급효가 인정되는 것을 제외하고는 원출원(Y)과는 별개의 출원이다. 따라서 원출원(Y)이 조약우선권주장을 수반하였다고 할지라도 분할출원(Z)이 그 효과를 적용받기 위해서는 분할출원(Z) 역시 우선기간인 1년 이내 출원, 출원할 때 주장(취지 기재) 및 최우선일로부터 1년 4개월 이내 증명서류를 제출하여야 한다. 그런데 분할출원(Z)이 조약우선권주장을 수반하는 경우 출원인의 이익을 위해서 1년은 Y 출원일을 기준으로 판단하고, 원출원(Y)이 조약우선권을 주장한 특허출원이었으면 분할출원(Z)도 분할출원을 한때 조약우선권주장을 한 것으로 보며(자동 주장 간주), 원출원(Y)에 대하여 조약우선권주장의 증명서류 제출기간 내 증명서류 제출이 되었으면 분할출원(Z)도 증명서류가 제출된 것으로 본다(자동 증명서류 제출간주). 한편 최우선일(X)로부터 1년 4개월까지 원출원(Y)에 대하여 조약우선권주장의 증명서류 제출이 되지 아니하면 분할출원(Z)에 대하여 자동 증명서류 제출간주가 적용되지 않지만, 최우선일(X)로부터 1년 4개월과 분할출원(Z)을 한 날부터 3개월 중 늦은 날까지 조약우선권주장의 증명서류 제출을 할 수 있다. 이때 분할출원(Z)은 Y 출원일로 출원일의 소급효가 인정되고, 분할출원(Z)의 청구범위에 기재된 B 발명은 X 출원일로 판단시점이 소급하게 된다.

## I 법조문

**제52조의2 【분리출원】(★)** 法 52의2④, 55①Ⅱ / 59③ / 67의2①Ⅲ

- ① **(요건)** 특허거절결정을 받은 자는 제132조의17에 따른 심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리할 수 있다. 이 경우 새로운 특허출원의 청구범위에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다. 法 62Ⅵ, 63의2, 133①Ⅶ
1. 그 심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항
  2. 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항
  3. 제1호 또는 제2호에 따른 청구항을 제47조제3항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항
  4. 제1호부터 제3호까지 중 어느 하나의 청구항에서 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항
- ② **(절차 및 효과: 분할출원 준용)** 제1항에 따라 분리된 특허출원(이하 “분리출원”이라 한다)에 관하여는 제52조제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “분할”은 “분리”로, “분할출원”은 “분리출원”으로 본다. 法 92의2④Ⅱ의Ⅱ
- ③ **(청구범위 제출 유예 및 외국어출원 불가)** 분리출원을 하는 경우에는 제42조의2제1항 후단 또는 제42조의3제1항에도 불구하고 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니하거나 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 언어로 적을 수 없다.
- ④ **(분리출원, 분할출원, 변경출원 기초 불가)** 분리출원은 새로운 분리출원, 분할출원 또는 「실용신안법」 제10조에 따른 변경출원의 기초가 될 수 없다.

[본조신설 2021. 10. 19.]

## II 분리출원(法 52의2)

| 제 도 |     | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서   | 의의  | 특허거절결정을 받은 자가 거절결정불복심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리하는 것을 말하며, 분리출원을 한 경우 그 분리출원은 원특허출원한 때에 출원한 것으로 본다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 취지  | 특허거절결정불복심판에서 기각심결이 있는 후에는 심결취소의 소 제기 전까지 특허가능한 청구항을 새로운 특허출원으로 분리하여 신속하게 추가적인 권리획득할 수 있는 기회를 제공                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 요 건 | 주체적 | 분리출원 당시 분리출원인은 원출원의 출원인 또는 그 승계인과 동일인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 객체적 | 1. 원출원의 요건<br>① 분리출원 당시 원출원이 적법하게 출원계속중(원출원이 취하 또는 포기되거나 심판청구의 취하에 의한 거절결정이 확정된 날과 동일일차 분리출원이 있는 경우 출원계속중인 것으로 간주),<br>② 분리출원이 아닐 것<br>2. 분리출원의 요건<br>① 분리출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내이어야 한다(法 52의2①각호 외의 부분 전단).<br>② 분리출원의 청구범위에는 다음의 어느 하나에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다(法 52의2①후단)<br>i) 그 심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항<br>ii) 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항<br>iii) i) 또는 ii)에 따른 청구항을 제47조제3항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항<br>iv) i)부터 iii)까지 중 어느 하나의 청구항에서 그 특허출원(원출원)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 시기적 | 특허출원에 대한 거절결정불복심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 분리출원 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 절차  |     | 1. 원출원 표시를 한 분리출원서와 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 지식재산처장에게 제출(法 52의2②)<br>2. 원출원이 조약 또는 국내우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 분리출원을 한 때에 그 분리출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며(자동우선권주장간주), 원출원에 대하여 제54조제4항의 조약우선권주장의 증명서류 제출기간 내 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 분리출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다(자동증명서류제출간주)(法 52의2②).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 효 과 | 적법  | 1. 출원일의 소급효<br>적법한 분리출원은 원출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분리출원이 다음에 해당하는 경우에는 해당 분리출원 시에 출원한 것으로 본다.<br>① 확대된 선출원에 관한 규정(法 29③④)에서 다른 특허출원에 해당하는 경우<br>② 공시 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 주장을 위한 취지기재, 증명서류 제출기간(法 30②)<br>③ 조약우선권주장출원의 취지기재(法 54③)<br>④ 국내우선권주장출원의 취지기재(法 55②)<br>⑤ 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장(法 92의2①)시 특허출원일의 기산일(法 92의2④)<br>2. 원출원과의 관계 - 원출원과는 별개의 출원으로 심사청구, 출원공개 및 등록료 납부 등을 별개로 하여야 함. 그러나 분리출원의 심사순서는 지식재산처장이 정하는 바(원출원의 심사청구순서)에 의한. 원출원이 우선권주장을 하지 않은 경우 분리출원은 그 주장을 할 수 없으나, 원출원이 공지에의적용주장을 하지 않더라도 분리출원은 그 주장이 가능<br>3. 선출원주의의 회피 - 원출원의 청구범위에 기재된 발명과 분리출원의 청구범위에 기재된 발명이 동일한 경우에는 동일자에 동일발명에 관한 출원이 있으므로 협의제(法 36②)가 적용/원출원에 대한 심결취소소송과 원출원에서 특허가능한 청구항에 대한 분리출원이 동시에 계속 중인 경우 분리출원에 대한 심사를 진행하고 원출원을 인용발명으로 하는 선출원주의 위반(法 36②)의 거절이유를 제외한 거절이유를 발견할 수 없는 때 분리출원에 대해 특허결정함<br>4. 우선권주장취하기간의 특례 - 법 제52조제4항에 따라 우선권을 주장한 것으로 보는 분리출원에 관하여는 우선권주장의 보정 또는 추가의 기한(法 54⑦, 55⑦)이 지난 후에도 분리출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다(法 52②).<br>5. 청구범위제출유예 및 외국어출원 불가(法 52의2③)<br>6. 심사청구의 특례 - 분리출원에 관하여는 원출원일로부터 3년의 기간이 지난 후라도 분리출원을 한 날부터 30일 이내에 심사청구(法 59③).<br>7. 새로운 분리출원, 분할출원, 변경출원, 국내우선권주장출원 및 재심사청구 불가(法 52의2④, 55①Ⅱ, 67의2①Ⅲ) |
|     | 부적법 | 1. 불수리 - ① 분리출원 당시 분리출원의 출원인이 원출원의 출원인과 일치하지 아니한 경우, ② 원출원의 절차가 종료된 이후에 분리출원서가 제출된 경우, ③ 분리출원을 기초로 분리출원서가 제출된 경우, ④ 분리출원서가 기간을 지나서 제출된 경우, ⑤ 청구범위제출유예하거나 외국어로 된 분리출원서가 제출된 경우<br>2. 거절이유 등 - 분리출원의 명세서 또는 도면의 요건(法 52의2①각호 외의 부분 전단) 위반된 경우 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法 133①)이고, 분리출원의 청구범위 요건(法 52의2①후단) 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# 28

## 변경출원(法 53)

### I 법조문

#### 제53조 【변경출원】(★) 法 6, 11 / 52의2④, 55①Ⅱ / 59③ / 209

- ① **(요건)** 실용신안등록출원인은 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2014. 6. 11., 2016. 2. 29., 2021. 10. 19.> 法 62Ⅶ, 63의2, 133①Ⅶ
1. 그 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(「실용신안법」 제3조에 따라 준용되는 이 법 제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말한다)이 지난 경우
  2. 그 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제8조의3제2항에 따른 외국어실용신안등록출원인 경우로서 변경하여 출원할 때 같은 항에 따른 국어번역문이 제출되지 아니한 경우
- ② **(효과)** 제1항에 따라 변경된 특허출원(이하 "변경출원"이라 한다)이 있는 경우에 그 변경출원은 실용신안등록출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다. **(예외)** 다만, 그 변경출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2014.6.11.> 法 92의2④Ⅲ
1. 제29조제3항[확대된 선출원]에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우
  2. 제30조제2항[공지예외적용주장출원의 취지 및 증명서류]를 적용하는 경우
  3. 제54조제3항[조약우선권주장출원의 취지]를 적용하는 경우
  4. 제55조제2항[국내우선권주장출원의 취지]를 적용하는 경우
- ③ **(절차)** 제1항에 따라 변경출원을 하려는 자는 변경출원을 할 때 특허출원서에 그 취지 및 변경출원의 기초가 된 실용신안등록출원의 표시를 하여야 한다. <개정 2014.6.11.> 法 52②Ⅲ, 52의2②, 53②Ⅲ
- ④ **(원출원의 취하간주)** 변경출원이 있는 경우에는 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다. <개정 2014.6.11.>
- ⑤ 삭제 <2014.6.11.>
- ⑥ **(조약우선권증명서류 제출의 특례)** 변경출원의 경우에 제54조에 따른 우선권을 주장하는 자는 같은 조 제4항에 따른 서류를 같은 조 제5항에 따른 기간이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 3개월 이내에 지식재산처장에게 제출할 수 있다. <개정 2013.3.22.>
- ⑦ **(외국어특허출원의 국어번역문 제출의 특례)** 특허출원인은 변경출원이 외국어특허출원인 경우에는 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 제42조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다. <신설 2014.6.11.>
- ⑧ **(청구범위제출유예기간의 특례)** 특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 변경출원의 경우 제42조의2제2항에 따른 기한이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다. <신설 2014.6.11.>
- [전문개정 2006.3.3.]

## II 변경출원(法 53)

| 제 도     |           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서       | 의의        | 실용신안등록출원(이하 “원출원”이라 함)을 한 자가 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월까지 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경하는 것을 말하며, 변경출원을 한 경우 그 변경출원은 실용신안등록출원을 한 때에 출원된 것으로 본다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 취지        | 1. (실용 → 특허) 출원형식 과오의 치유<br>2. (특허 → 실용) 진보성 위반의 극복 방안(단, 물품성이 있어야 함)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 요건      | 주체적       | 1. 변경출원 당시 변경출원인은 원출원의 출원인 또는 그 승계인과 동일인<br>2. 통상의 위임대리인은 특별히 권한을 위임받아야 함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 객체적       | 1. 원출원의 요건 - ① 변경출원당시 원출원은 적법하게 출원계속중 / ② 분리출원이 아닐 것<br>2. 변경출원의 요건 - 변경출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내이어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 시기적       | 원출원이 있는 후 변경출원을 할 수 있으나 최초거절결정등본송달일로부터 3개월(연장된 경우에는 연장된 기간)이 경과한 경우에는 불가(法 53①⑤).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 절차      |           | 원출원 표시를 한 변경출원서와 명세서, 필요한 도면, 요약서를 지식재산처장에게 제출(法 53③)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 효과      | 적법        | 1. 소급효<br>적법하게 변경출원된 경우 그 변경출원은 원실용신안등록출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 변경출원이 다음에 해당하는 경우 해당 변경출원 시에 출원한 것으로 본다(法 53②).<br>① 확대된 선출원에 관한 규정(法 29③④)에서 다른 특허출원에 해당하는 경우<br>② 공지등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 주장을 위한 취지기재, 증명서류 제출기간 기산시(法 30②)<br>③ 조약우선권주장출원의 취지기재(法 54③)<br>④ 국내우선권주장출원의 취지기재(法 55②)<br>⑤ 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장(法 92의2①)시 특허출원일의 기산일(法 92의2④)<br>2. 원출원과의 관계 - 원출원과는 별개의 출원으로 심사청구, 출원공개 및 등록료 납부 등을 별개로 하여야 함. 그러나 변경출원의 심사순서는 지식재산처장이 정하는 바(원출원의 심사청구순서)에 의함. 원출원이 우선권주장을 하지 않은 경우 변경출원은 그 주장을 할 수 없으나, 원출원이 공지예외적용주장을 하지 않더라도 변경출원은 그 주장이 가능<br>3. 원출원의 취하간주 - 변경출원이 있는 경우에는 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다(法 53④). 이것은 동일한 발명에 대한 중복 권리 허여를 배제하기 위함.<br>3. 조약우선권주장 증명서류 제출의 특례 - 변경출원이 조약우선권주장을 수반하는 경우에는, 최우선일로부터 1년 4개월의 기간이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 3개월 이내에 지식재산처장에게 증명서류 제출(法 53⑥)<br>4. 청구범위제출유예의 특례 - 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 변경출원에 관하여는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날(다만, 기한 이전에 출원심사 청구의 취지를 통지(法 60③)받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)의 기한이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정(法 53⑧).<br>5. 심사청구의 특례 - 변경출원에 관하여는 원출원일로부터 3년의 기간이 지난 후라도 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 심사청구(法 59③). |
|         | 부적법       | 1. 불수리 - ① 변경출원 당시 변경출원의 출원인이 원출원의 출원인과 일치하지 아니한 경우(복수인 경우에는 모두 일치해야 함), ② 원출원의 절차가 종료된 이후에 변경출원서가 제출된 경우, ③ 분리출원을 기초로 변경출원서가 제출된 경우, ④ 변경출원서가 기간을 지나서 제출된 경우<br>2. 거절이유 등 - 변경출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 포함되어 있지 아니한 경우 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法 133①)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 외국어특허출원 | 원출원       | 원출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 국어번역문(法 42의3②)이 제출된 경우에만 변경출원할 수 있다(法 52①단서). 심사관과 일반 공중이 변경출원의 적합성 여부를 확인하기 위해서는 국어번역문을 필요로 하기 때문이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 변경출원      | 1. 변경출원이 외국어특허출원인 경우에 특허출원인은 국어번역문(法 42의3②) 또는 새로운 국어번역문(法 42의3③본문)을 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날(다만, 기한 이전에 출원심사 청구의 취지를 통지(法 60③)받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)의 기한이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다(法 53⑦본문).<br>2. 다만, i) 명세서 또는 도면을 보정(법 제42조의3제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)한 경우, ii) 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다(法 53⑦단서).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 관련문제    | 분할출원과의 관계 | 분할출원을 한 후 그 분할출원을 원출원으로 하여 변경출원을 할 수 있다. 다만 분할출원과 변경출원이 하나의 절차에 의하여 이루어질 수는 없으므로 특허출원 발명(A, B) 중 일부(A)를 특허로 보호받고, 일부(B)를 실용신안으로 보호받고자 할 때에는 일단 그 발명(B)을 동일한 출원형식으로 분할출원을 하고 그 분할출원을 다시 변경출원하여야 한다. 그 발명(B)을 분할출원하지 않고 특허출원(A, B)을 바로 변경출원하는 경우에는 특허출원이 취하간주되어(法 53④) 변경출원한 일부 발명(B)에 대해서만 실용신안으로 보호를 받을 수 있게 된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 국제특허출원 특례 | 국제실용신안등록출원에 대하여 변경출원을 하기 위해서는 수수료 납부 및 출원번역문 제출(단, 국어출원의 경우 제외)이 있어야 한다(法 209).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Ⅲ 분할출원, 분리출원 및 변경출원의 법조문 비교

| 제 도       |               | 분할출원(法 52) | 분리출원(法 52의2) | 변경출원(法 53) |
|-----------|---------------|------------|--------------|------------|
| 요건        |               | 제52조제1항    | 제52조의2제1항    | 제53조제1항    |
| 효과        |               | 제52조제2항    | 제52조의2제2항    | 제53조제2항    |
| 절차        |               | 제52조제3항    | 제52조의2제2항    | 제53조제3항    |
| 협약제 회피    |               | -          | -            | 제53조제4항    |
| 자동주장/증명서류 |               | 제52조제4항    | 제52조의2제2항    | -          |
| 기간특례      | 우선권주장<br>취하   | 제52조제5항    | 제52조의2제2항    | -          |
|           | 조약우선권<br>증명서류 | 제52조제6항    | -            | 제53조제6항    |
|           | 번역문제출         | 제52조제7항    | 제52조의2제3항    | 제53조제7항    |
|           | 청구범위제출유예      | 제52조제8항    | 제52조의2제3항    | 제53조제8항    |
|           | 심사청구          | 제59조제3항    | 제59조제3항      | 제59조제3항    |



#### Ⅳ 분할출원, 분리출원 및 변경출원의 비교

| 제 도    |         | 분할출원(法 52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 분리출원(法 52의2)                                                                                                                                                 | 변경출원(法 53)                                                                                                       |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서      | 의의      | 원출원에 둘 이상의 발명이 포함된 경우 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 보정할 수 있는 기간, 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 또는 특허결정등본을 송달받은 날부터 3개월 기간(다만, 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간) 이내의 기간에 그 일부를 별개의 특허출원으로 분할하는 것을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 거절결정을 받은 자의 불복심판청구가 기각된 경우 심결 등본을 송달받은 날부터 30일(심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간) 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리하는 것을 말한다. | 실용신안등록출원을 한 자가 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 최초의 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월까지 특허출원으로 변경하는 것을 말한다. |
|        | 취지      | 1. 출원일체의 원칙의 회피<br>2. 발명의 설명/도면에만 기재된 발명의 보호<br>3. 권리범위 재설계 기회 확보                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 거절결정불복심판에 대한 기각심결이 있는 후 소 제기 전까지 추가적인 권리획득할 수 있는 기회 제공                                                                                                       | 1. 출원형식선택의 과오 치유 (실→특)<br>2. 진보성 위반 거절이유 극복 (특→실)                                                                |
| 요건     | 주체적     | 1. 분할·분리·변경출원 당시 원출원인 또는 그 승계인과 분할·분리·변경출원인이 동일인<br>2. 임의대리인이 변경출원하는 경우에는 특별히 권한을 위임받아야 함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|        | 원출원     | 1. 분할·분리·변경출원 당시 출원계속 중이고, 분리출원이 아닐 것<br>2. 분할출원의 경우 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 둘 이상의 발명 포함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|        | 객체적     | 1. 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항 범위<br>2. 분리출원의 경우 청구범위에 기재된 청구항이 다음의 i) 내지 iv) 어느 하나에 해당할 것<br>i) 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항, ii) 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항, iii) i) 또는 ii)에 따른 청구항을 제47조제3항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항, iv) i)부터 iii)까지 중 어느 하나의 청구항에서 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|        | 시기적     | 1. 보정을 할 수 있는 기간(法 47①),<br>2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(연장된 경우 그 기간)<br>3. 특허결정등본을 송달받은 날부터 3개월 기간(다만, 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 거절결정불복심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다)                                                                         | 원출원이 있는 후 최초의 특허거절결정 등본을 송달받은 날부터 3개월(연장된 경우에는 연장된 기간)                                                           |
| 절차     |         | 1. 그 취지 및 원출원 표시를 한 분할·분리·변경출원서와 명세서, 필요한 도면 및 요약서 제출<br>2. 분할·분리출원의 경우 원출원이 우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 자동 주장 간주하며, 원출원에 대하여 조약우선권주장증명서류 제출기간 내 증명서류 제출이 있는 자동 제출간주. 이 경우 우선권주장의 보정 또는 추가기한이 지난 후에도 분할·분리출원을 한 날부터 30일 이내 우선권 주장의 전부 또는 일부 취하기능 / 단, 변경출원은 변경출원과 동시에 우선권주장을 하고 증명서류를 별도로 제출                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
| 효과     | 적법      | 1. 출원일의 소급효(예외 있음)<br>2. 원출원과의 독립성. 단 심사순서는 지식재산처장이 정하는 바(분할출원은 분할출원의 심사청구순서, 분리, 변경출원은 원출원의 심사청구순서)에 의함 / 원출원이 우선권주장하지 않은 경우 분할·분리·변경출원도 불가<br>3. 형의제의 회피 - 분할·분리출원은 원출원과 청구범위가 동일한 경우 회피해야 하나, 변경출원은 변경출원과 동시에 원출원의 취하간주로 회피 불필요<br>4. 우선권주장취하사기의 특례 - 우선권 자동 주장 간주 분할·분리출원에 관하여는 우선권주장의 보정 또는 추가의 기한이 지난 후에도 분할·분리출원을 한 날부터 30일 이내에 주장의 전부 또는 일부를 취하기능<br>5. 조약우선권주장의 증명서류 제출기간의 특례 - 최우선일로부터 1년 4개월 지난 후라도 분할출원, 변경출원일로부터 3개월 이내<br>6. 청구범위제출유예기간의 특례 - 청구범위제출유예기간(法 42의2②)이 지난 후라도 분할출원, 변경출원일로부터 30일 이내 / 단, 분리출원은 청구범위제출유예 불가<br>7. 심사청구기간의 특례 - 원출원일로부터 3년 지난 후라도 분할출원, 분리출원, 변경출원일로부터 30일 이내<br>8. 국내우선권주장출원과의 관계 - 분할출원, 분리출원, 변경출원은 국내우선권주장출원의 선출원 불가 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|        | 부적법     | 1. 불수리 → 주체적, 시기적 요건 위반 / 분할·분리·변경출원 당시 원출원에 관한 절차가 종료된 경우 / 분리출원서를 기초로 분할·분리·변경출원서 제출 / 청구범위제출유예하거나 외국어로 된 분리출원<br>2. 거절이유, 정보제공사유 및 특허무효사유 → 원출원의 최초 명세서 또는 도면의 범위를 벗어난 경우 (분리출원은 청구범위의 요건 위반한 경우도 거절이유, 정보제공사유)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
| 외국어    | 원출원     | 국어번역문이 제출된 경우에만 분할출원, 변경출원 가능(분리출원도 마찬가지)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|        | 분할·변경출원 | 국어번역문 제출기간이 지난 후라도 분할출원, 변경출원일로부터 30일(단 보정하거나, 출원인이 심사청구한 경우 새로운 국어번역문 제출 불가) / 분리출원은 외국어출원 불가                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
| 국제특허출원 |         | 1. 분할출원은 수수료 납부+번역문 제출(단, 국어출원 제외)+기준일(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사의 청구 이후) 지난 후(法 208①)<br>2. 변경출원은 수수료 납부+번역문 제출 후(法 209)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |





## 조약우선권주장출원(法 54)

### I 법조문

#### 제54조 [조약에 의한 우선권 주장](★) 法 199②

- ① (요건 및 효과) 조약에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제29조 및 제36조를 적용할 때에 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다.
1. 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국의 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우
  2. 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 대한민국 국민이 특허출원한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우
- ② (우선기간) 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일부터 1년 이내에 특허출원을 하지 아니하면 우선권을 주장할 수 없다.
- ③ (우선권주장기간) 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국가명 및 출원의 연월일을 적어야 한다. 法 52②Ⅲ, 52④⑤, 52의2②, 53②Ⅲ
- ④ (증명서류: 제출대상) 제3항에 따라 우선권을 주장한 자는 제1호의 서류 또는 제2호의 서면을 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 다만, 제2호의 서면은 총리령으로 정하는 국가의 경우만 해당한다. 法 52④
1. 최초로 출원한 국가의 정부가 인증하는 서류로서 특허출원의 연월일을 적은 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본
  2. 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호 및 그 밖에 출원을 확인할 수 있는 정보 등 총리령으로 정하는 사항을 적은 서면

#### 시행규칙 제25조

##### 제25조(우선권증명서류의 제출 등)

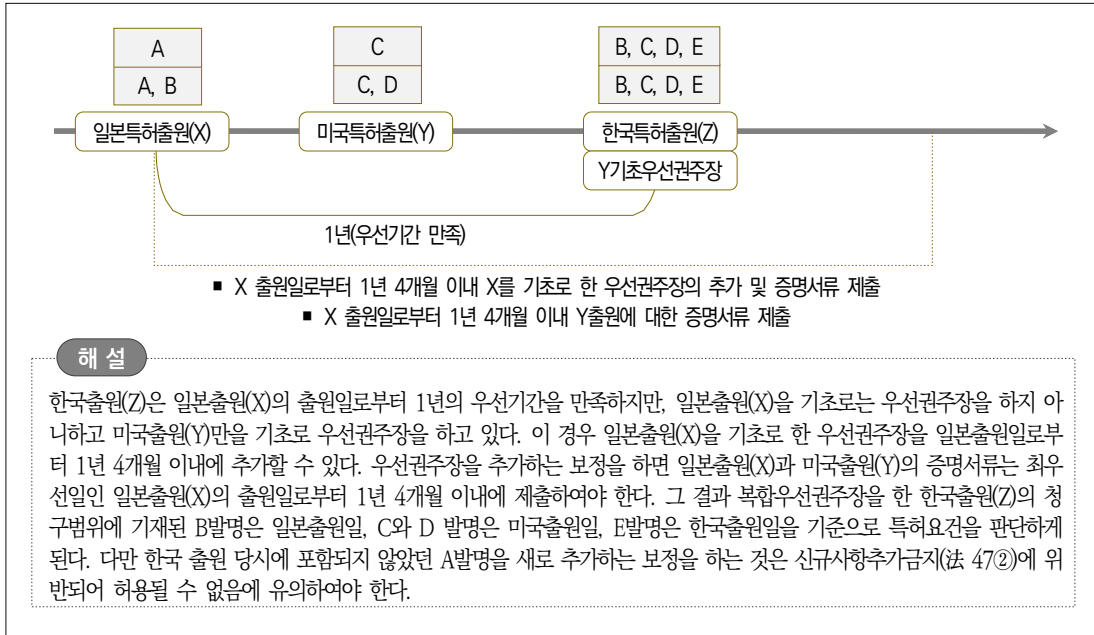
- ① 법 제54조제4항에 따른 서류 또는 서면의 제출은 별지 제13호서식의 서류제출서에 따른다. 이 경우 대리인에 의하여 절차를 밟는 때에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통을 첨부하여야 한다. <개정 2005. 2. 11., 2006. 9. 29., 2006. 12. 29., 2014. 12. 30.>
- ② 법 제54조제4항 각 호 외의 부분 단서 중 “총리령이 정하는 국가”란 지식재산처와 외국의 특허업무를 담당하는 행정기관간에 우선권증명서류를 전자적 매체에 의하여 교환할 수 있는 체제가 구축된 국가로서 지식재산처장이 고시하는 국가를 말한다. <개정 2008. 9. 30., 2013. 3. 23.>
- ③ 지식재산처장 또는 특허심판원장은 심사·특허취소신청 또는 심판을 위하여 필요한 경우 법 제54조제1항의 규정에 의하여 우선권주장을 한 자에 대하여 기간을 정하여 우선권증명서류에 대한 국어번역문을 제출하도록 명할 수 있다. <신설 2005. 2. 11., 2017. 2. 28.>
- ④ 제3항에 따라 제출명령을 받은 자가 그 국어번역문을 제출하려는 경우에는 별지 제13호서식의 서류제출서에 따른다. 다만, 우선권주장에 관한 서류 중 명세서 및 도면의 기재내용이 법 제42조제2항에 따른 특허출원서에 첨부된 명세서 및 도면의 기재내용과 동일한 부분에 대하여는 그 취지를 기재하고 국어번역문의 제출을 생략할 수 있다. <신설 2005. 2. 11., 2006. 12. 29., 2007. 6. 29., 2014. 12. 30.>
- ⑤ 삭제 <2017. 9. 22.>
- ⑥ 법 제54조제4항제2호에서 “그 밖에 출원을 확인할 수 있는 정보 등 총리령으로 정하는 사항”이란 최초로 출원한 국가에서 부여한 접근코드를 말한다. <개정 2017. 9. 22., 2020. 7. 1.>
- ⑦ 제1항에도 불구하고 법 제54조제4항제2호에 따른 서면의 제출은 특허출원서에 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호 및 접근코드를 적음으로써 별지 제13호서식의 서류제출서를 갈음할 수 있다. <신설 2014. 12. 30.>  
[전문개정 2001. 6. 30.]  
[제목개정 2005. 2. 11.]

- ⑤ (증명서류: 제출기간) 제4항에 따른 서류 또는 서면은 다음 각 호에 해당하는 날 중 최우선일(最優先日)부터 1년 4개월 이내에 제출하여야 한다. 法 52⑥, 53⑥
1. 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일
  2. 그 특허출원이 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일
  3. 그 특허출원이 제3항에 따른 다른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일
- ⑥ (증명서류: 제출의 효과) 제3항에 따라 우선권을 주장한 자가 제5항의 기간에 제4항에 따른 서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권 주장은 효력을 상실한다.
- ⑦ (우선권주장의 보정 또는 추가) 제1항에 따라 우선권 주장을 한 자 중 제2항의 요건을 갖춘 자는 제5항에 따른 최우선일로부터 1년 4개월 이내에 해당 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다. 法 52⑤ / 55⑦  
[전문개정 2014.6.11.]

## II 조약우선권주장출원(法 54)

| 제 도        |          | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서          | 의의       | 조약에 의하여 우리나라 국민에게 우선권을 인정하는 당사자 국민 또는 대한민국 국민이 조약 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원(이하 “선출원”이라 함)을 한 후 1년 이내에 동일발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우에 제29조 및 제36조를 적용할 때에 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 보는 출원을 말한다(法 54①).                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 취지       | 시간·거리·비용 등의 절차상 제약 극복하고 발명의 국제적 보호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 법적성질     | ① 여러 국가에 우선권주장이 가능한 복수성, ② 제2국 출원과 운명을 같이하는 부속성, ③ 제1국 출원에 의하여 발생하나 제1국과는 별개로 취급되는 독립성, ④ 1년의 기간이내에 주장하여야 하는 한시성, ⑤ 우선권 주장을 해야 비로소 인정되는 잠재성                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 유형       | 1. 복합우선 - 제1국에 한 2이상의 출원에 대하여 제2국에서 하나의 출원으로 조약우선권주장출원<br>2. 부분우선 - 제1국 출원에 포함되지 아니한 새로운 내용을 추가하여 제2국에서 조약우선권주장출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 요 건        | 주체적      | 1. 우선권주장을 할 수 있는 자 - 대한민국 국민, 조약당사국 국민, 준당사국 국민<br>2. 우선권주장출원인은 선출원의 출원인과 동일인이거나 정당승계인. 우선권주장출원 당시 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 일치해야 하는 것은 아니나, 승계인은 우선권의 독립성에 기인하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였다 하더라도 우선권을 별도로 승계해야 함                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 객체적      | 1. 선출원의 요건<br>① 출원의 최선성<br>동맹 제1국의 최초 출원을 기초(다만, ① 후속출원이 같은 국가에서 같은 대상에 대하여 있을 것, ② 후속 출원이 있기 전에 전출원이 취하, 포기 또는 거절되었을 것, ③ 최선출원이 공개되지 않았을 것, ④ 최선 출원에 의하여 어떤 권리도 존속하지 않았을 것, ⑤ 최선출원이 우선권주장의 기초로 되지 않았을 것을 만족하는 경우에 후속출원을 기초로 우선권주장을 할 수 있다.)<br>② 출원의 정규성<br>우선권의 독립성에 기인하여 선출원은 정규의 출원(출원일 부여)으로만 인정되면 됨. 출원계속필요×<br>③ 형식의 무제한 - 특허출원, 실용신안등록출원 뿐만 아니라 디자인등록출원을 기초로 하여 우선권주장가능<br>2. 우선권주장출원(후출원)의 요건<br>선출원의 최초 명세서 또는 도면≥후출원의 청구범위(다만, 발명별 판단) |
|            | 시기적      | 1. 원칙 - 제1국출원일로부터 1년 이내 출원<br>2. 이중우선시 우선기간<br>① 특→실 / 실→특 - 1년<br>② 실→디 - 6월(파리조약) / 디→실 - 제1국설(6월)과 제2국설(1년) - 통설(제1국설)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 절 차        | 출원서 제출   | 1. 우선권 주장<br>① 출원과 동시에 취지, 최초 출원국가명, 출원연월일 기재(法 54③)<br>② 원출원이 조약우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 분할출원, 분리출원을 한 때에 그 분할출원, 분리출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 간주 / 변경출원은 출원과 동시에 제54조제3항 기재<br>2. 우선권주장의 보정 또는 추가<br>① 조약우선권주장을 한 자 중 선출원일로부터 1년 이내(우선기간) 출원할 것을 만족한 자는 최우선일로부터 1년 4월이내에 해당 우선권주장의 보정·추가 가능(法 54⑦)<br>② 우선권을 주장한 것으로 보는 분할출원, 분리출원에 관하여는 우선권주장의 보정 또는 추가의 기한(法 54⑦)이 지난 후에도 분할출원, 분리출원을 한 날부터 30일 이내에 그 주장의 전부/일부 취하 가능<br>3. 외국의 심사결과 제출명령 가능(法 63의3)   |
|            | 증명서류의 제출 | 1. 원칙 - 출원일 연월일을 기재한 서면, 명세서 또는 도면 등본을 최우선일로부터 1년 4월이내(法 54④⑤)<br>2. 예외<br>① 총리령이 정하는 국가(대만 및 DAS를 통하여 우선권 증명서류를 전자적으로 송달하기로 합의한 국가)의 경우 - 출원번호 및 접근코드(출원서 기재시 생략 가능) 제출 가능<br>② 분할·변경출원의 경우 - 최우선일로부터 1년 4개월의 기간이 지난 후에도 분할출원, 변경출원을 한 날부터 3개월 이내에 지식재산처장에게 제출가능(法 52⑥, 53⑥)/원출원에 대하여 조약우선권주장의 증명서류 제출 기간 내 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원, 분리출원에 대해서도 자동 제출 간주                                                                                      |
| 효 과        | 적법       | 우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 선출원일로 판단시점이 소급. 단, ① 심사청구기간의 기산, ② 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 출원기간, 취지 기재 및 증명서류 제출 기간, ③ 존속기간의 기산, ④ 재정에 있어서 출원일의 기산, ⑤ 등록지면에 따른 특허권의 존속기간의 연장시 특허출원일(法 92의2①)의 기산(法 92의2④)은 불소급(法 54①)                                                                                                                                                                                                         |
|            | 부적법      | 1. 무효 → 우선권주장의 요건, 절차에 위반된 경우 방식위반으로 우선권주장을 무효로 할 수 있다.<br>2. 출원의 판단시점 소급효 불인정<br>우선권주장이 무효된 경우 실제 출원일인 후출원일을 기준으로 심사.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 국제특허출원의 특례 |          | 국제특허출원에 관해서는 특허협력조약의 규정에 의하며 조약우선권주장의 규정(法 54)을 적용하지 아니한다(法199②) - PCT 8(1)(2)(a) 적용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### III 우선권주장의 보정 또는 추가(法 54⑦)



| 구 분     | 우선기간                                                                                                                                                                                                                       | 우선권주장기간                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 의 의     | 제2국에 출원할 수 있는 기간                                                                                                                                                                                                           | 제2국에 출원한 후 우선권주장을 할 수 있는 기간 |
| 파리조약    | 1년                                                                                                                                                                                                                         | 동맹국의 자국법에 일임                |
| 특허법의 태도 | 1. 출원과 동시에 우선권주장을 하도록 함(法 54③)<br>2. 단점(출원인에게 불이익)의 보완<br>○ 우선권주장의 보정 또는 추가(法 54⑦)의 인정<br>○ 요건<br>- 조약우선권주장을 한 자 & 우선기간 만족<br>○ 효과<br>- 최우선일로부터 1년 4월 이내 - 우선권주장의 보정 또는 추가<br>- 최우선일로부터 1년 4월 이후 - 명백한 오기의 정정 또는 우선권주장의 취하 |                             |



## 국내우선권주장출원(法 55, 56)

### I 법조문

#### 제55조 【특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장】(★) 法 202

- ① (요건) 특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 "선출원"이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.>
1. 그 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년이 지난 후에 출원된 경우
  2. 선출원이 제52조제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분할출원 또는 제52조의2제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분리출원이거나 제53조제2항 또는 「실용신안법」 제10조제2항에 따른 변경출원인 경우
  3. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 포기·무효 또는 취하된 경우
  4. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
- ② (절차) 제1항에 따른 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 하여야 한다. 法 6, 11 / 法 52②Ⅳ, 52④⑤, 52의2②, 53②Ⅳ
- ③ (효과) 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 제29조제1항제2항, 같은 조 제3항 본문, 같은 조 제4항 본문, 제30조제1항, 제36조제1항부터 제3항까지, 제96조제1항제3호, 제98조, 제103조, 제105조제1항제2항, 제129조 및 제136조제5항(제132조의3제3항 또는 제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 「실용신안법」 제7조제3항제4항 및 제25조, 「디자인보호법」 제95조 및 제103조제3항을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다. <개정 2016.2.29.>
- ④ (확대된 선출원: 국내 vs. 국내) 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록공고되었을 때에 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관하여 출원 공개가 된 것으로 보고 제29조제3항 본문, 같은 조 제4항 본문 또는 「실용신안법」 제4조제3항 본문·제4항 본문을 적용한다.
- ⑤ (이중우선권주장) 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 그 선출원에 관하여 우선권 주장의 기초가 된 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 제3항과 제4항을 적용하지 아니한다.
1. 선출원이 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우
  2. 선출원이 「공업소유권의 보호를 위한 파리 협약」 제4조D(1)에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우
- ⑥ (확대된 선출원: PCT vs. 국내) 제4항을 적용할 때 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하더라도 제29조제7항을 적용하지 아니한다.
1. 선출원이 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원인 경우
  2. 선출원이 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원인 경우
- ⑦ (우선권주장의 보정 또는 추가) 제1항에 따른 요건을 갖추어 우선권 주장을 한 자는 선출원일(선출원이 둘 이상인 경우에는 최선출원일을 말한다)부터 1년 4개월 이내에 그 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다. 法 56②, 52⑤, 52의2② / 54⑦
- ⑧ (선출원의 설정등록 불가) 제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 제79조에 따른 설정등록을 받을 수 없다. 다만, 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2021. 10. 19.>

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제56조 【선출원의 취하 등】(★★) 法 202

- ① (선출원의 취하간주) 제55조제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 본다. (예외) 다만, 그 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.>

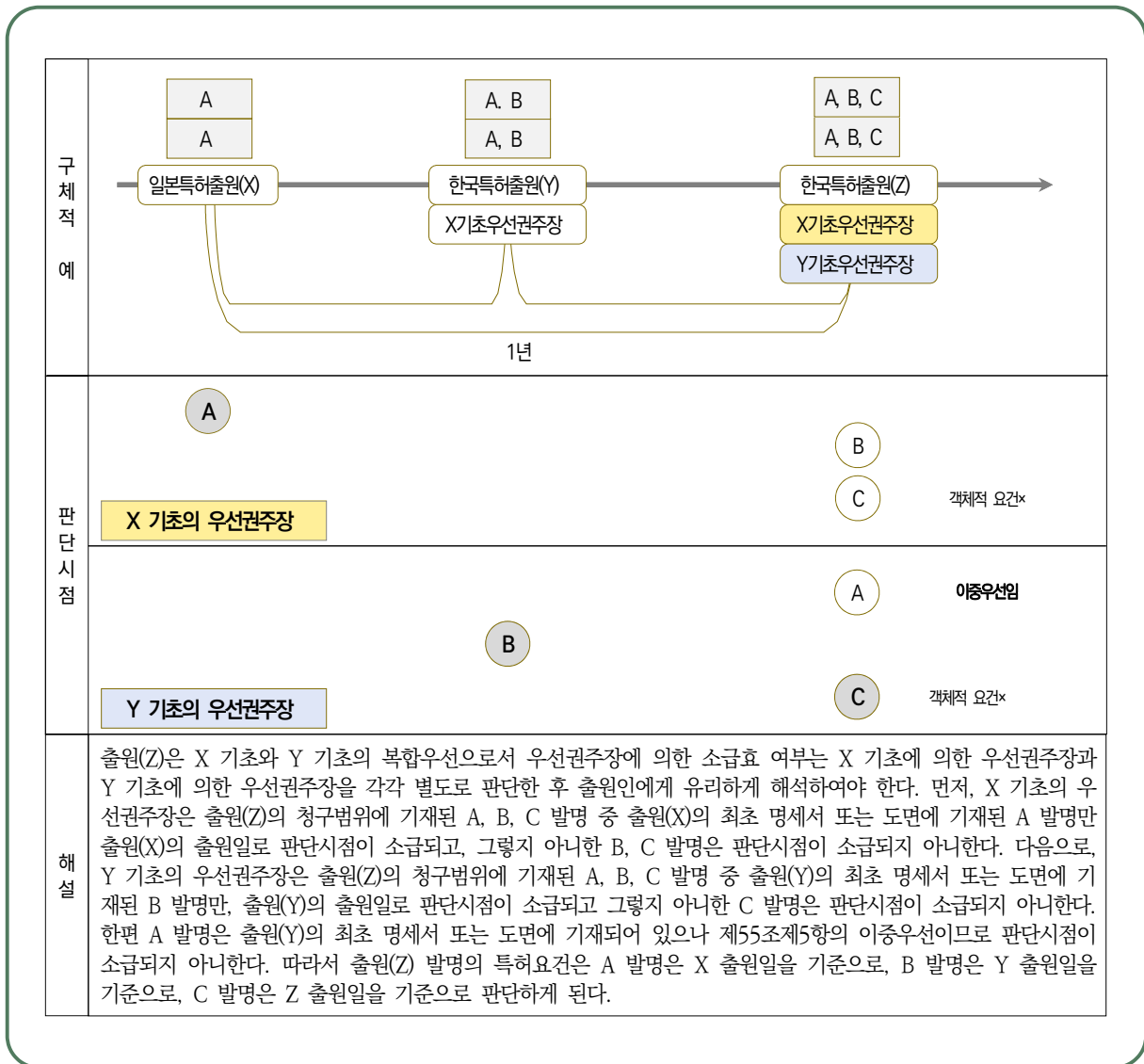
1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
  2. 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
  3. 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우
- ② **(우선권주장의 취하금지)** 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원인은 선출원의 출원일부터 1년 3개월이 지난 후에는 그 우선권 주장을 취하할 수 없다. **法 6, 11, 55②**
- ③ **(우선권주장의 취하간주)** 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년 3개월 이내에 취하된 때에는 그 우선권 주장도 동시에 취하된 것으로 본다.
- [전문개정 2014.6.11.]



## II 국내우선권주장출원(法 55, 56)

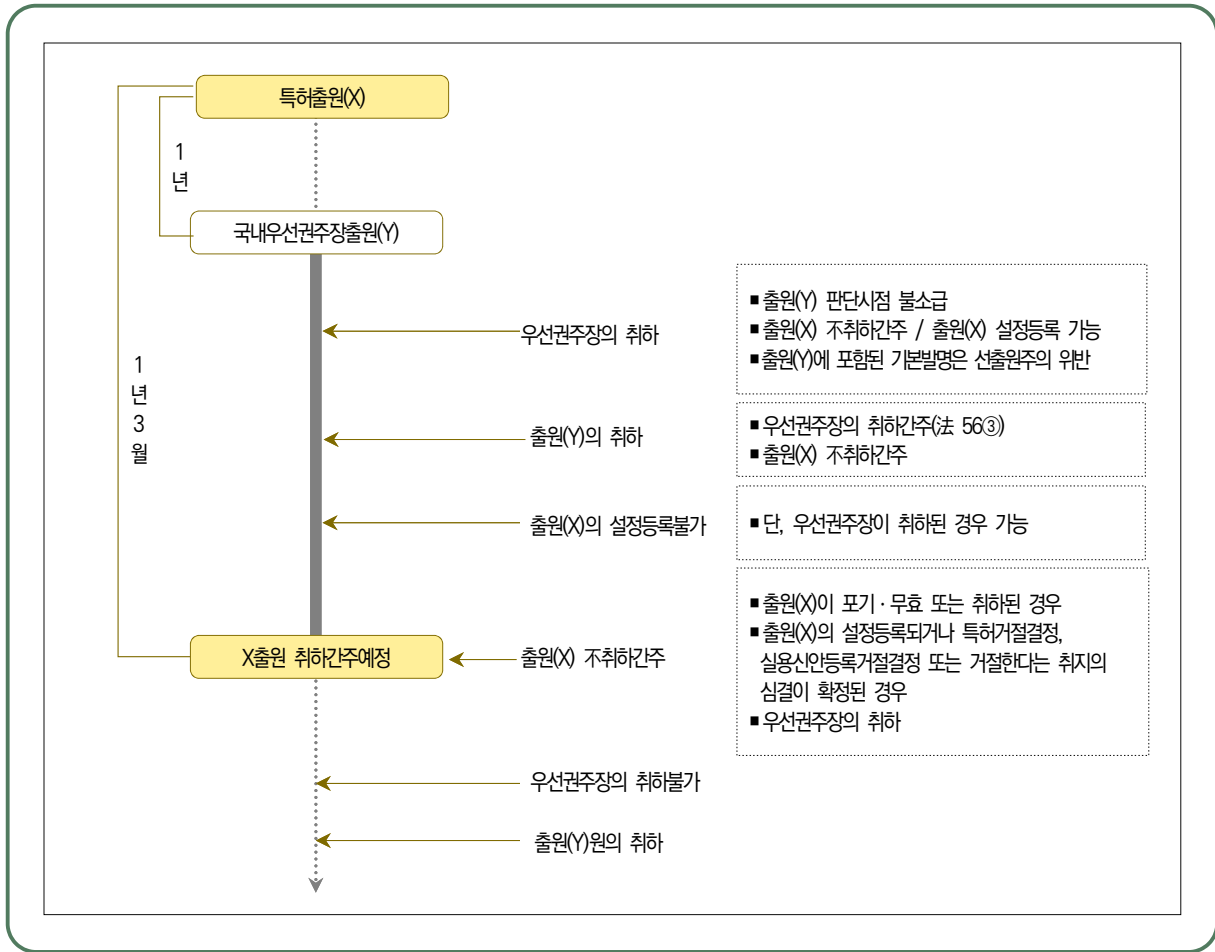
| 제 도 |            | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서   | 의의         | 특허를 받으려는 자가 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 “선출원”이라 한다)을 기초로 1년 이내 우선권주장의 출원을 한 경우에 우선권주장출원에 포함된 선출원발명은 법 제55조 제3항에 열거된 규정에 대하여 선출원을 한 때에 출원한 것으로 판단시점을 소급하여 주는 출원을 말한다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 취지         | ① 개량발명 보호의 적정화, ② 내·외국인간 발명보호의 형평성 도모, ③ 국제출원이용의 활성화                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 요건  | 주체적        | 1. 선출원인 또는 선출원인의 정당한 승계인이다(우선권주장출원 당시 출원일 일치 불필요)<br>2. 임의대리인은 특별히 권한을 위임받아야 함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 객체적        | 1. 선출원의 요건<br>① 우선권주장출원을 할 때에 선출원이 출원 계속 중(法 55①ⅢⅣ)<br>② 분할·분리·변경출원이 아닐 것(法 55①Ⅱ)<br>③ 형식에 제한 - 특허출원, 실용신안등록출원만을 대상으로 하며, 디자인등록출원은 대상에 불포함<br>2. 우선권주장출원의 요건<br>선출원의 최초 명세서 또는 도면≥우선권주장출원의 청구범위(다만, 발명별 판단)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 시기적        | 선출원의 출원일로부터 1년이내(法 55①Ⅰ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 절차         | 1. 우선권주장<br>① 출원과 동시에 취지 기재 및 선출원의 표시(法 55②)<br>② 원출원이 국내우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 분할출원, 분리출원을 한 때에 그 분할출원, 분리출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 간주 / 변경출원은 출원과 동시에 제55조제2항 기재<br>2. 우선권주장의 보정 또는 추가<br>① 국내우선권주장을 한 자 중 法55①의 요건을 갖춘 자는 최선출원일로부터 1년 4월 이내에 해당 우선권주장을 보정하거나 추가가능(法 55⑦), 단 선출원일로부터 1년 3월 경과후에는 우선권주장의 취하불가(法 56②).<br>② 우선권을 주장한 것으로 보는 분할출원, 분리출원에 관하여는 우선권주장의 보정 또는 추가의 기한(法 55⑦)이 지난 후에도 분할출원, 분리출원을 한 날부터 30일 이내에 그 주장의 전부/일부 취하 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 효과  | 증명서류       | 선출원이 국내출원이므로 증명서류 제출 불요                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 적법         | 1. 판단시점의 소급효<br>우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 선출원일로 판단시점이 소급. 단, ① 심사청구기간의 기산, ② 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 취지 및 증명서류 제출 기간, ③ 존속기간의 기산, ④ 재정에 있어서 출원일의 기산, ⑤ 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장시 특허출원일(法 92의2①)의 기산(法 92의2④), ⑥ 선출원이 다른 국내우선권주장 또는 조약우선권주장을 수반하는 이중우선(法 55⑥)은 불소급(法 55③)<br>2. 확대된 선출원<br>① 국내우선권주장을 수반하는 특허출원(후특허출원)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 그 특허출원(후특허출원)이 출원공개되거나 등록공고된 때에 그 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 확대된 선출원의 규정을 적용한다(法 55④). 다만, 다른 국내우선권주장 또는 조약우선권주장을 수반하는 이중우선인 경우(法 55⑥)에는 확대된 선출원의 소급효 불인정<br>② 선출원이 국내서면제출기간에 발명(고안)의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하여 취하된 것으로 보는 국제특허출원(실용신안등록출원)이더라도 제55조제4항에 따른 확대된 선출원을 적용(法 55⑥).<br>3. 선출원의 취하간주(法 56①) 및 설정등록불가<br>① 원칙 - 우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일로부터 1년 3월이 경과한 때에 취하된 것으로 본다(法 56①본문) / 선출원은 설정등록 불가. 다만, 우선권 주장이 취하된 경우 가능(法 55⑧).<br>② 예외 - 국내우선권주장출원 후 1년 3월을 경과하기 전 ① 해당 선출원이 포기, 무효·취하 또는 각하된 경우(法 56①Ⅰ), ② 해당 선출원이 설정등록되거나 거절결정 또는 심결이 확정된 경우(法 56①Ⅱ), ③ 우선권주장이 취하된 경우(法 56①Ⅲ)에는 선출원이 취하간주되지 아니한다.<br>4. 우선권주장의 취하금지<br>우선권주장을 수반하는 특허출원의 출원인은 선출원의 출원일로부터 1년 3월을 경과한 후에는 그 우선권주장의 취하불가(法 56②). 1년 3월 전 취하하기 위해서는 임의대리인은 특별히 권한을 위임받아야 하고, 취하된 경우 우선권주장이 효력을 상실하기 때문에 실제 출원일을 기준으로 특허요건을 판단<br>5. 우선권주장의 취하간주(法 56③)<br>우선권주장을 수반하는 특허출원이 선출원의 출원일로부터 1년 3월 이내에 취하된 때에는 그 우선권주장도 동시에 취하된 것으로 본다. 그 결과 1년 3월이 되었을 때 선출원이 취하간주되지 않음(法 56①Ⅲ). |
|     | 부적법        | 1. 무효 - 우선권주장의 요건, 절차에 위반된 경우 방식위반으로 우선권주장을 무효로 할 수 있다.<br>2. 출원의 판단시점 소급효 불인정 - 우선권주장이 무효 또는 취하된 경우 실제 출원일인 후출원일 기준으로 심사.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 국제특허출원의 특례 | 국제특허출원이 자기지정인 경우 요건과 효과는 국내법에 일임 - PCT 8(1)(2)(b)적용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### III 이중우선(法 55⑤)





IV 국내우선권주장 및 국내우선권주장출원의 취하(法 55⑧, 56)



V 조약우선권주장출원과 국내우선권주장출원의 비교

| 제 도        |     | 조약우선권주장출원(法 54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 국내우선권주장출원(法 55, 56)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서          | 의의  | 조약에 의하여 우리나라 국민에게 우선권을 인정하는 당사자 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일발명에 대하여 우리나라에 출원하여 우선권을 주장하는 때에 일정요건에 대하여 선출원 시에 출원한 것으로 판단시점을 소급하여주는 제도를 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 특허를 받으려는 자가 국내의 선출원을 한 후 그 선출원의 출원일부터 우선권주장의 출원을 한 경우에 후출원에 포함된 선출원 발명은 일정요건에 대하여 선출원 시에 출원한 것으로 판단시점을 소급하여 주는 특허법상의 제도를 말한다.                                                                                                                                                           |
|            | 취지  | 절차상 제약 극복하고 발명의 국제적 보호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. 개량발명 보호의 적정화<br>2. 내·외국인간 발명보호의 형평성 도모<br>3. 국제출원이용의 활성화                                                                                                                                                                                                                             |
| 요건         | 주체적 | 1. 우선권주장을 할 수 있는 자<br>대한민국 국민, 조약당사국 국민, 준당사국 국민<br>2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있다면 출원인의 동일성 불필요(다만, 승계인은 우선권 별도로 승계 → 우선권의 독립성)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있다면 출원인의 동일성 불필요<br>2. 임의대리인은 국내우선권 주장 또는 취하지 특별히 권한을 위임받아야 함                                                                                                                                                                                                    |
|            | 객체적 | 1. 선출원의 요건<br>① 최선성(예외있음)<br>② 정규성<br>③ 형식제한 × → 디자인 ○<br>2. 후출원의 요건<br>후출원의 청구범위에 기재된 발명이 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 선출원의 요건<br>① 후출원당시 선출원이 출원 계속 중일 것<br>② 분할·분리·변경출원이 아닐 것<br>③ 형식 제한 ○ → 디자인 ×                                                                                                                                                                                                        |
|            | 시기적 | 1. 원칙(동종우선) → 제1국출원일로부터 1년 이내 출원<br>2. 이중우선시 우선기간은 6개월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 선출원의 출원일로부터 1년 이내                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 절차  | 출원서 제출<br>1. 출원과 동시에 취지, 최초 출원국가명 및 출원연월일 기재(法 54③) - 단 분할·분리출원의 경우 원출원이 조약우선권주장을 수반하는 경우 자동 주장 간주(法 52④, 52의2②) / 변경출원은 변경출원 시 별도주장 필요(法 53②)<br>2. 우선권주장의 보정 또는 추가(法 54⑦) - 단, 분할출원, 분리출원의 경우 기간이 지난 후라도 그 날로부터 30일(法 52④, 52의2②) 이내 전부/일부 취하기능<br>증명서류의 제출<br>1. 원칙<br>출원일 적은 서면 및 명세서 또는 도면(단, 일정한 경우 출원번호 및 총리령으로 정하는 사항)을 최우선일로부터 1년 4개월 이내 제출(法 54④⑤⑥)<br>2. 예외<br>① 분할·변경출원의 경우 최우선일로부터 1년 4개월 지난 후라도 분할·변경출원일로부터 3개월 이내 지식재산처장에게 제출(法 52⑥, 53⑥)<br>② 분할·분리출원의 경우 원출원이 증명서류 제출한 경우 자동 제출 간주(法 52④, 52의2②) | 출원서 제출<br>1. 출원과 동시에 취지, 선출원의 표시(法 55②) - 단 분할·분리출원의 경우 원출원이 국내우선권주장을 수반하는 경우 자동 주장 간주(法 52④, 52의2②) / 변경출원은 변경출원 시 별도주장 필요(法 53②)<br>2. 우선권주장의 보정 또는 추가(法 55⑦)<br>① 단, 1년 3개월 지난 후에는 우선권주장 취하불가<br>② 단, 분할출원, 분리출원의 경우 기간이 지난 후라도 그 날로부터 30일(法 52④, 52의2②) 이내 전부/일부 취하기능<br>증명서류 제출 불요 |
| 효과         | 적법  | 1. 판단시점의 소급효(예외 있음)(法 54①)<br>2. 확대된 선출원 적용은 해석상 국내우선권주장출원과 동일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. 판단시점의 소급효(예외 있음)(法 55③⑤)<br>2. 확대된 선출원(法 55④⑤⑥)<br>3. 선출원의 취하간주(法 56①) 및 등록불가(法 55③)<br>4. 우선권의 취하 금지 및 취하간주(法 56②③)                                                                                                                                                                 |
|            | 부적법 | 우선권주장 → 무효 / 출원 → 소급효 ×, 실제출원일을 기준으로 판단                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 국제특허출원의 특례 |     | PCT 제8조 (1)과 (2)(a)를 적용(法 199②)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PCT 제8조 (1)과 (2)(b)를 적용(法 55, 56, 202)                                                                                                                                                                                                                                                  |

참고자료 3.1 분할·분리·변경·조약우선권주장·국내우선권주장출원의 적법성

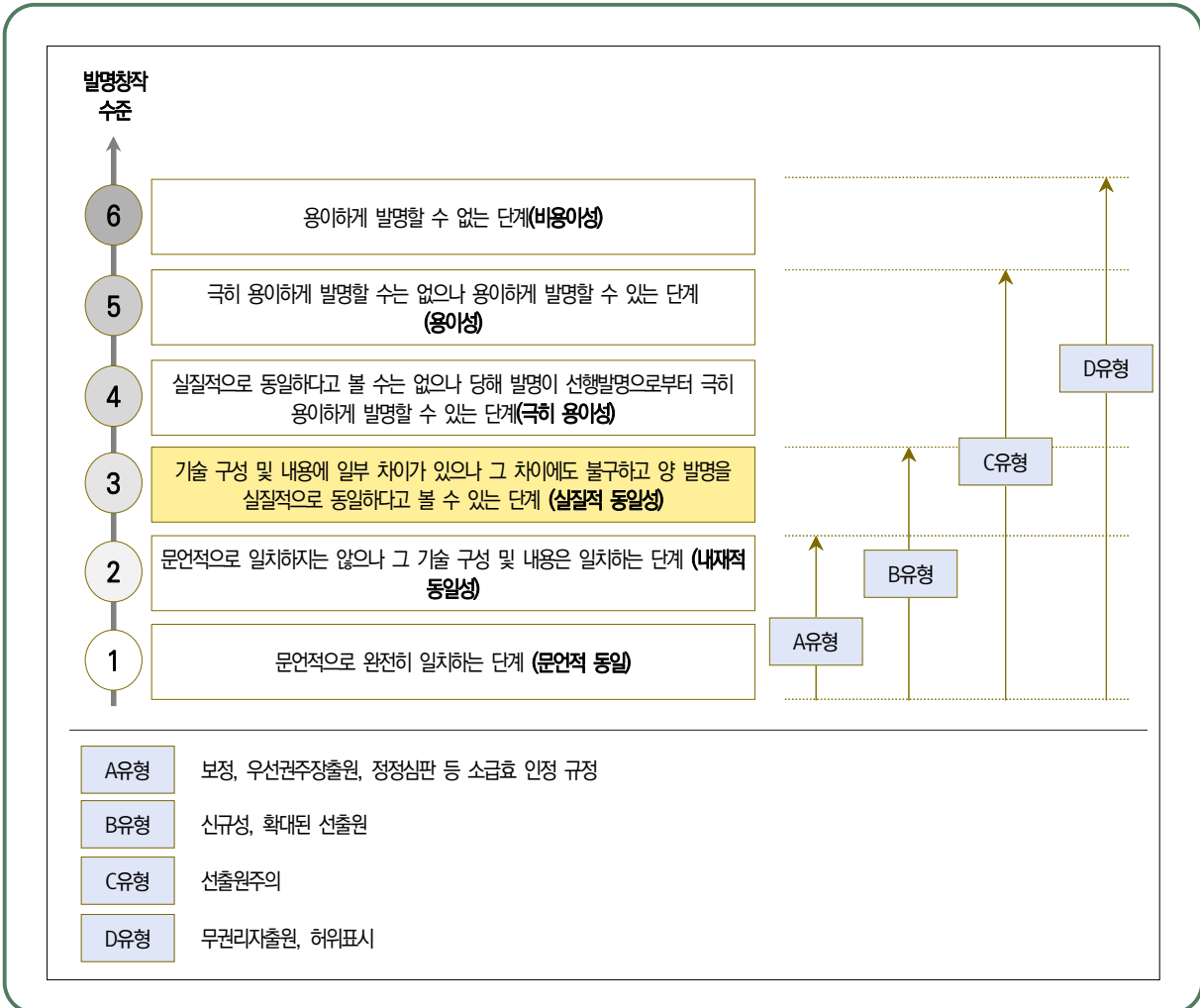
| 예  | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">X 출원</div> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; right: 0; top: -5px;">→</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">Y 출원</div> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; right: 0; top: -5px;">→</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">Z 출원</div> </div> |                                  |             |              |                                               |                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 적용 | Z 출원<br>Y 출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 분할출원                             | 분리출원        | 변경출원         | 조약우선권주장출원                                     | 국내우선권주장출원                                                                                                              |
|    | 분할출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 가능*                              | 가능*         | 가능*          | 외국법이 국내법과 동일하지 아니하기 때문에 논의 실익 x               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 불가능</li> <li>■ 요건 불만족하여 무효처분 (∴ 심사의 어려움)</li> <li>■ 선출원이 취하간주되지 않음</li> </ul> |
|    | 분리출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 불가능                              | 불가능         | 불가능          |                                               |                                                                                                                        |
|    | 변경출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 가능*                              | 가능*         | 가능*          |                                               |                                                                                                                        |
|    | 조약우선권<br>주장출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 가능(우선기간(1년) - 소급효 ○, 취지 - 소급효 x) |             |              | 최선성 요건 불만족하여 무효처분 (∴ 우선기간의 실질적 연장을 방지하기 위해)** | 요건 만족하지만 이중우선으로 소급효의 예외 인정 (∴ 우선기간의 실질적 연장을 방지하기 위해)                                                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 자동주장간주                           | 자동주장간주      | 출원과 동시에 주장   |                                               |                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 자동증명서류 제출간주/ 증명서류 제출기간 특례        | 자동증명서류 제출간주 | 증명서류 제출기간 특례 |                                               |                                                                                                                        |
|    | 국내우선권<br>주장출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 가능(우선기간(1년) - 소급효 ○, 취지 - 소급효 x) |             |              |                                               |                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 자동주장간주                           | 자동주장간주      | 출원과 동시에 주장   |                                               |                                                                                                                        |

\* X 출원과 Y 출원 사이에 분할(분리, 변경)출원의 요건을 만족하고 Y 출원과 Z 출원 사이에 분할(분리, 변경)출원의 요건을 만족하며, Z 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 X 출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 범위내이면, Z 출원이 X 출원의 출원일로 소급

\*\* 다만, Z 출원에 포함된 발명 중 X 출원에 기재되어 있지 않지만, Y 출원에 새로이 추가된 발명이 있는 경우에는 그 추가된 발명은 최선성이 있기 때문에 우선권주장을 무효처분하는 것이 아니라 그 추가된 발명에 대해서만 우선권 주장의 효과를 인정(2004하8749).

참고자료 3.2 발명의 동일성 및 판단대상의 비교

I 판례의 의한 각 규정별 동일성의 인정범위



## II 특허요건 판단에서 동일성 인정 여부

| 구 분                            |          |    | 인용대상                | 본원발명                | 동일성 인정여부 | 비고   |
|--------------------------------|----------|----|---------------------|---------------------|----------|------|
| 문언적 동일                         |          |    | a+b(직접 기재)          | a+b                 | 인정       |      |
| 내재적 동일성                        |          |    | a+b(직접 기재와 마찬가지로)   | a+b                 | 인정       |      |
| 실<br>질<br>적<br><br>동<br>일<br>성 | 범주<br>상이 |    | 물건발명                | 제법발명                | 일반적 불인정  |      |
|                                |          |    | 제법발명                | 물건발명                | 일반적 인정   |      |
|                                | 범위<br>상이 | 부가 | a+b                 | a+b+c               | 일반적 불인정  | 결합발명 |
|                                |          |    | a+b+c               | a+b                 | 일반적 인정   |      |
|                                |          | 한정 | A+b<br>(A는 a의 상위개념) | a+b                 | 일반적 불인정  | 선택발명 |
|                                |          |    | a+b                 | A+b<br>(A는 a의 상위개념) | 일반적 인정   |      |
|                                | 구성<br>변경 |    | a+b1                | a+b                 | 일반적 불인정* |      |

\* 협의의 동일성(신규성, 확대된 선출원): 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 단순한 부가, 전환, 삭제 등에 불과하여 새로운 효과 발생이 없고, 발명 간의 차이가 발명의 사상에 실질적인 영향을 미치지 않는 비본질적 사항에 불과한 경우를 말한다.

\* 광의의 동일성(선출원주의): 그 변경이 목적달성을 위한 구체화 수단으로서 통상의 기술자에 의하여 일반적으로 채용될 수 있는 정도의 기술수단의 단순한 치환, 부가 또는 삭제 등에 해당하는 것이고 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우를 말한다.

### III 각 규정별 판단대상의 비교

| 구분              | 내용                                   | 본원발명                     | 비교대상                  | 비고                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 특허<br>요건<br>판단  | 신규성(法 29①각호)                         | 청구범위                     | 공지기술(1개)              | 동일성 판단                                                                                                                |
|                 | 진보성(法 29②)                           | 청구범위                     | 공지기술(1개 이상)           | 용이성 판단                                                                                                                |
|                 | 확대된 선출원<br>(法 29③④)                  | 그 특허출원의<br>청구범위          | 다른 출원의 최초<br>명세서·도면   | 동일성 판단                                                                                                                |
|                 | 선출원주의(法 36)                          | 청구범위                     | 청구범위                  | 동일성 판단                                                                                                                |
| 출원일<br>소급효      | 무권리자에 대한<br>정당한 권리자의<br>출원(法 34, 35) | 정당한 권리자<br>출원의<br>명세서·도면 | 무권리자 출원의 최초<br>명세서·도면 | 1. 협의제 회피방안 → 무권리자 출원의 선<br>출원지위 불인정<br>2. 객체적 요건: 동일성 판단<br>→ 출원전체로서 판단<br>→ 위반시 소급효 불인정                             |
|                 | 신규사항추가금지<br>(法 47②전단)                | 명세서·도면                   | 최초 명세서·도면             | 객체적 요건: 동일성 판단<br>→ 출원전체로서 판단<br>→ 위반시 거절이유 등                                                                         |
|                 | 분할출원(法 52)                           | 명세서·도면                   | 원출원의 최초<br>명세서·도면     | 1. 협의제 회피방안 → 청구범위가 동일하지<br>않을 것을 요함<br>2. 객체적 요건: 동일성 판단<br>→ 출원전체로서 판단<br>→ 위반시 거절이유 등                              |
|                 | 분리출원(法 52의2)                         | 명세서·도면*                  | 원출원의 최초<br>명세서·도면     | 1. 협의제 회피방안 → 청구범위가 동일하지<br>않을 것을 요함<br>2. 객체적 요건: 동일성 판단<br>→ 출원전체로서 판단<br>→ 위반시 거절이유 등                              |
|                 | 변경출원(法 53)                           | 명세서·도면                   | 원출원의 최초<br>명세서·도면     | 1. 협의제 회피방안 → 원출원의 취하간주<br>2. 객체적 요건: 동일성 판단<br>→ 출원전체로서 판단<br>→ 위반시 거절이유 등                                           |
| 판단<br>시점<br>소급효 | 조약우선권주장<br>출원(法 54)                  | 청구범위                     | 선출원의 최초<br>명세서·도면     | 1. 협의제 회피방안 → 외국의 선출원은 선<br>출원의 지위, 확대된 선출원의 지위 불인<br>정되어 회피 불필요<br>2. 객체적 요건: 동일성 판단<br>→ 발명단위로 판단<br>→ 발명단위로 소급효 결정 |
|                 | 국내우선권주장<br>출원(法 55)                  | 청구범위                     | 선출원의 최초<br>명세서·도면     | 1. 협의제 회피방안 → 선출원의 취하간주<br>2. 객체적 요건: 동일성 판단<br>→ 발명단위로 판단<br>→ 발명단위로 소급효 결정                                          |

\* 단, 분리출원의 경우 청구범위에 기재된 청구항이 다음의 i) 내지 iv) 어느 하나에 해당할 것

i) 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항, ii) 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항, iii) i) 또는 ii)에 따른 청구항을 제47조제3항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항, iv) i)부터 iii)까지 중 어느 하나의 청구항에서 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항

도해특허법

## 제4장 심사

## 제5장 특허권

## 제6장 심판

|    |    |                                 |
|----|----|---------------------------------|
| 주체 | 31 | 심사관 및 전문기관(法 57~58의2, 68)       |
| 청구 | 32 | 심사청구제도(法 59, 60, 67의3)          |
|    | 33 | 우선심사제도(法 61)                    |
| 진행 | 34 | 심사의 진행                          |
| 종료 | 35 | 출원의 취하 및 포기                     |
|    | 36 | 특허여부결정(法 62, 63, 63의3, 66~67의3) |
| 관련 | 37 | 정보제공제도(法 63의2)                  |
|    | 38 | 출원공개제도(法 64, 65)                |



**제57조 【심사관에 의한 심사】 法 68/93/226**

- ① (심사관의 심사) 지식재산처장은 심사관에게 특허출원을 심사하게 한다. **法 93**  
 ② (심사관의 자격) 심사관의 자격에 관하여 필요한 사항은 대통령령[시행령 제8조 제1항]으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

**제58조 【전문기관의 등록 등】**

- ① (선행기술조사 등의 의뢰) 지식재산처장은 출원인이 특허출원할 때 필요하거나 특허출원을 심사(국제출원에 대한 국제조사 및 국제예비심사를 포함한다)할 때 필요하다고 인정하면 제2항에 따른 전문기관에 미생물의 기탁·분양, 선행기술의 조사, 특허분류의 부여, 그 밖에 대통령령[시행령 제8조의3]으로 정하는 업무를 의뢰할 수 있다. <개정 2016.12.2.> **法 217①1**  
 ② (전문기관의 등록) 제1항에 따라 지식재산처장이 의뢰하는 업무를 수행하려는 자는 지식재산처장에게 전문기관의 등록을 하여야 한다. <신설 2016.12.2.>  
 ③ (전담기관의 업무 대행) 지식재산처장은 제1항의 업무를 효과적으로 수행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 전담기관으로 하여금 전문기관 업무에 대한 관리 및 평가에 관한 업무를 대행하게 할 수 있다. <신설 2018. 4. 17.> **法 217①1**  
 ④ (협조요청 또는 의견청취) 지식재산처장은 특허출원의 심사 필요하다고 인정하는 경우에는 관계 행정기관, 해당 기술분야의 전문기관 또는 특허에 관한 지식과 경험이 풍부한 사람에게 협조를 요청하거나 의견을 들을 수 있다. 이 경우 지식재산처장은 예산의 범위에서 수당 또는 비용을 지급할 수 있다. <개정 2016. 12. 2., 2018. 4. 17.> **法 217①1**  
 ⑤ 제2항에 따른 전문기관의 등록기준, 선행기술의 조사 또는 특허분류의 부여 등의 의뢰에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2016. 12. 2., 2018. 4. 17.>

[전문개정 2014.6.11.]

[제목개정 2016.12.2.]

**제58조의2 【전문기관 등록의 취소 등】 法 217의2②**

- ① (요건) 지식재산처장은 제58조제2항에 따른 전문기관이 제1호에 해당하는 경우에는 전문기관의 등록을 취소하여야 하며, 제2호 또는 제3호에 해당하는 경우에는 그 등록을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다.  
 <개정 2016. 2. 29., 2016. 12. 2., 2018. 4. 17.>  
 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우  
 2. 제58조제5항에 따른 등록기준에 맞지 아니하게 된 경우  
 3. 전문기관의 임직원이 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우 **法 226의2①**  
 ② (청문) 지식재산처장은 제1항에 따라 전문기관의 등록을 취소하거나 업무정지를 명하려면 청문을 하여야 한다. <개정 2016.12.2.>  
 ③ 제1항에 따른 처분의 세부 기준과 절차 등에 관하여 필요한 사항은 총리령[시행규칙 제36조의2]으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

[제목개정 2016.12.2.]

**제68조 【심판규정의 심사예외의 준용】 法 57**

특허출원의 심사에 관하여는 제148조제1호부터 제5호까지 및 제7호[심판관의 제척사유, 단 전심판예 제외]를 준용한다.

[전문개정 2014.6.11.]

■ 심사의 주체 → 심사관(法 57, 68) + 전문기관(法 58, 58의2)



## 심사청구제도(法 59, 60, 67의3)

### I 법조문

#### 제59조 【특허출원심사의 청구】(★) 法 84①V, V의II, 210

① (효과○: 실제심사) 특허출원에 대하여 심사청구가 있을 때에만 이를 심사한다.

#### 시행규칙 제38조, 제40조-제40조의3

##### 제38조(심사의 순위)

- ① 특허출원에 대한 심사는 법 제59조제1항에 따른 출원심사의 청구순위에 따른다. <개정 2014. 4. 10.>
- ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지식재산청장이 정하는 바에 따라 심사한다. <개정 2022. 4. 19., 2024. 10. 31.>
  1. 심사청구된 특허출원을 법 제52조에 따라 분할출원하여 심사청구한 경우
  2. 심사청구된 특허출원을 법 제52조의2에 따라 분리출원하여 심사청구한 경우
  3. 심사청구된 실용신안등록출원을 법 제53조에 따라 특허출원으로 변경출원하여 심사청구한 경우
- ③ 삭제 <2019. 6. 10.>

##### 제40조(동일출원의 심사)

- ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 선출원이 처리되거나 출원공개 또는 등록공고 될 때까지 후출원의 심사를 보류하여야 한다. 다만, 선출원을 거절할 이유와 동일한 이유에 의하여 후출원을 거절하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 1997. 7. 1., 2014. 12. 30., 2019. 6. 10.>
- ② 심사관이 제1항에 따라 심사를 보류하려는 경우에는 지식재산청장이 지정한 심사장의 확인을 받아야 한다. <신설 2019. 6. 10.>

##### 제40조의2(특허여부결정의 보류)

- ① 심사관은 특허출원심사의 청구 후 출원인이 특허출원일부터 6개월 이내에 별지 제22호의2서식의 결정 보류신청서를 지식재산청장에게 제출하는 경우에는 특허출원일부터 12개월이 경과하기 전까지 특허여부결정을 보류할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2008. 9. 30.>
  1. 특허출원이 분리출원 또는 변경출원인 경우 <개정 2022. 4. 19.>
  2. 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우
  3. 특허여부결정의 보류신청이 있기 전에 이미 특허거절결정서 또는 특허결정서를 통지한 경우
- ② 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제1항에 따른 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. [본조신설 2007. 6. 29.]

##### 제40조의3(특허출원심사의 유예)

- ① 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우로서 출원심사의 청구일부터 24개월이 지난 후에 특허출원에 대한 심사를 받으려면 출원심사의 청구일부터 9개월 이내에 심사를 받으려는 시점(출원일부터 5년 이내에 한정하며, 이하 “유예희망시점”이라 한다)을 적은 별지 제22호의2서식의 심사유예신청서를 지식재산청장에게 제출할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 따른 특허출원서 또는 심사청구서에 그 취지 및 유예희망시점을 적음으로써 그 신청서를 갈음할 수 있다. <개정 2011. 2. 25.>
  1. 제37조제1항 단서에 따라 특허출원과 동시에 심사청구를 하면서 심사유예신청도 같이 하는 경우에는 별지 제14호서식의 특허출원서
  2. 심사청구와 동시에 심사유예신청을 하는 경우(제1호의 경우는 제외한다)에는 별지 제22호서식의 심사청구서
- ② 특허출원인이 제1항에 따른 심사유예신청을 취하하거나 유예희망시점을 변경하려면 심사유예신청서를 제출한 날부터 2개월 이내에 별지 제12호서식의 취하서 또는 별지 제9호서식의 보정서를 제출하여야 한다.
- ③ 심사관은 제1항에 따른 심사유예신청이 있으면 유예희망시점까지 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2022. 4. 19.>
  1. 특허출원이 분리출원, 변경출원 또는 정당한 권리자의 출원인 경우
  2. 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우
  3. 특허출원심사의 유예신청이 있기 전에 이미 거절이유를 통지하거나 특허결정서를 통지한 경우
- ④ 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제1항에 따른 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. [본조신설 2008. 9. 30.]

- ② **(요건: 일반)** 누구든지 특허출원에 대하여 특허출원일부터 3년 이내에 지식재산처장에게 출원심사의 청구를 할 수 있다. **(예외)** 다만, 특허출원인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원심사의 청구를 할 수 없다. <개정 2016.2.29.> **法 42의3③Ⅱ**
1. 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우
  2. 제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다)
- ③ **(요건: 분할출원·분리출원·변경출원·정당한 권리자출원의 특례)** 제34조 및 제35조에 따른 정당한 권리자의 특허출원, 분할출원, 분리출원 또는 변경출원에 관하여는 제2항에 따른 기간이 지난 후에도 정당한 권리자가 특허출원을 한 날, 분할출원을 한 날, 분리출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날부터 각각 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다. <개정 2021. 10. 19.>
- ④ **(효과○: 취하금지)** 출원심사의 청구는 취하할 수 없다.
- ⑤ **(효과×: 취하간주)** 제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간에 출원심사의 청구가 없으면 그 특허출원은 취하한 것으로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제60조 【출원심사의 청구절차】(★)

- ① **(제출)** 출원심사의 청구를 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 출원심사청구서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.
1. 청구인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
  2. 출원심사의 청구대상이 되는 특허출원의 표시
- ② **(제재)** 지식재산처장은 출원공개 전에 출원심사의 청구가 있으면 출원공개 시에, 출원공개 후에 출원심사의 청구가 있으면 지체 없이 그 취지를 특허공보에 게재하여야 한다.
- ③ **(통지)** 지식재산처장은 특허출원인이 아닌 자로부터 출원심사의 청구가 있으면 그 취지를 특허출원인에게 알려야 한다. **法 42의2②, 42의3②**

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제67조의3 【특허출원의 회복】 **法 17**

- ① **(요건)** 특허출원인이 정당한 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다.
- <개정 2021. 10. 19.>
1. 제59조제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간
  2. 제67조의2제1항에 따라 재심사의 청구를 할 수 있는 기간
- ② **(효과)** 제1항에 따른 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구가 있는 경우에는 제59조제5항에도 불구하고 그 특허출원은 취하되지 아니한 것으로 보거나 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다.

[본조신설 2013.3.22.]

## II 심사청구제도(法 59, 60)

| 제 도  |                 | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서    | 의의              | 출원일로부터 3년 이내 심사청구가 있는 특허출원에 대하여만 청구의 순서에 따라 심사하는 제도를 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 취지              | 경험적 사실에 기초하여 선택적으로 심사함으로써 → 심사대상의 감소 및 심사 촉진                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 요건   | 주체적             | 1. 누구든지. 비법인 사단·재단도 대표자나 관리인이 있는 경우 사단·재단의 이름으로 가능(法 4).<br>2. 다만, 출원인은 1) 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우 또는 2) 외국어특허출원인데 국어번역문을 제출하지 아니한 경우 심사청구 불가(法 59②단서).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 객체적             | 적법하게 출원계속중인 발명(청구항별 ×)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 시기적             | 1. 원칙 - 출원일로부터 3년 이내<br>2. 예외<br>① 여기서 출원일은 ① 무권리자에 대한 정당한 권리자의 출원의 경우 무권리자의 출원일(法 34, 35), ② 분할출원(法 52②), 분리출원(法 52의2②), 변경출원(法 53②)의 경우 원출원일, ③ 조약우선권주장출원(法 54①), 국내우선권주장출원(法 55②)의 경우 우선권주장출원일을 말한다.<br>② 분할출원·분리출원·변경출원·정당한 권리자출원이 원출원일로부터 3년이 지난 후라도 분할출원·분리출원·변경출원·정당한 권리자출원을 한 날로부터 30일 이내에 심사청구를 할 수 있다(法 59③)<br>③ 국제특허출원의 경우 심사청구기간은 국제출원일의 다음 날부터 기산되고 출원인은 수수료 납부·출원번역문 제출(단, 국어출원의 경우 제외) 이후에 심사청구할 수 있으나, 제3자는 국내서면제출기간이 지난 후에만 심사청구할 수 있다(法 210).                                                    |
| 절차   | 제출              | 심사청구서의 제출(法 60①). 다만, 출원과 동시에 출원심사청구를 하는 경우(청구범위가 기재된 명세서가 첨부된 경우에 한함)에는 출원서에 그 취지를 기재함으로써 심사청구서에 갈음가능(施規 37①).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 게재              | 지식재산처장은 출원공개전에 출원심사의 청구가 있으면 출원공개시에, 출원공개후에 출원심사의 청구가 있으면 지체없이 그 취지를 특허공보에 게재(法 60②).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 통지              | 1. 취지통지 - 지식재산처장은 제3자의 출원심사의 청구가 있으면 그 취지를 특허출원인에게 통지(法 60③).<br>2. 청구범위의 보정<br>출원인은 제3자의 심사청구가 있는 경우 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 하며(法 42의2②단서), 보정을 하지 아니하면 그 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다(法 42의2③).<br>3. 국어번역문의 제출<br>출원인은 제3자의 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 국어번역문을 제출하여야 하며(法 42의3②단서), 출원인이 국어번역문을 제출하지 아니하면 그 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다(法 42의3④). |
|      | 심사청구료 납부        | 1. 일반적인 경우 - 독립항·종속항 불문하고 심사청구한 자가 청구항 수별로 심사청구료 납부.<br>2. 보정에 의하여 청구항수가 증가한 경우 - 제3자의 심사청구후 출원인의 보정에 의하여 증가한 청구항에 대해서는 출원인이 심사청구료를 내야 하는데, 이를 내지 아니한 경우 지식재산처장은 보정명령 후 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다(法 16①단서).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 효과   | 기한내 심사청구가 있는 경우 | 1. 심사의 개시<br>① 원칙 - 심사청구가 있으면 심사청구의 순서에 따라 실제심사가 이루어진다(法 59①, 施規 38①).<br>② 예외 - i) 분할출원, 분리출원 또는 변경출원은 지식재산처장이 정하는 순서에 따라 심사하며(施規 38②), ii) 법 제61조에 의한 법정사유에 해당하는 우선심사의 대상인 경우 심사청구순서보다 먼저 심사한다.<br>2. 심사청구의 취하금지(法 59④) - 출원심사의 청구는 취하할 수 없다.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 기한내 심사청구가 없는 경우 | 1. 취하간주 - 심사청구기간에 출원심사의 청구가 없는 때에는 그 특허출원은 취하간주(法 59⑤).<br>2. 불수리 - ① 심사청구할 수 있는 기간을 경과하여 심사청구된 경우, ② 출원인이 명세서에 청구범위를 적지 아니하고 심사청구한 경우, ③ 출원인이 외국어특허출원인데 국어번역문을 제출하지 아니하고 심사청구한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 관련문제 |                 | 1. 출원공개제도와 확대된 선출원<br>① 출원공개제도 - 출원공개제도는 심사청구여부와 관계없이 출원발명을 일정기간이 지난 후에 공개시켜 제3자의 중복투자 및 중복연구를 방지함으로써 심사청구의 제도의 효율성을 높여준다.<br>② 확대된 선출원 - 선출원의 심사청구가 지연되어도 선출원의 공개를 요건으로 선출원의 지위를 청구범위로부터 최초 명세서·도면의 범위로 확대하여 먼저 심사청구한 후출원의 심사를 신속히 진행 시킴으로써 심사청구제도를 효율적으로 운용할 수 있도록 하고 있다(法 29③④).<br>2. 특허출원의 회복: 특허출원인이 정당한 사유로 출원심사청구를 할 수 있는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있고, 이 경우 그 특허출원은 취하되지 아니한 것으로 본다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다(法 67의3).                           |

### III 심사의 보류

| 구 분                | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 동일발명에 대한<br>심사의 보류 | 동일한 발명에 대하여 둘 이상의 특허출원이 있을 때에는 선출원이 처리되거나 출원공개 또는 등록공고될 때까지 후출원의 심사를 보류하여야 한다. 이는 후출원이 선출원에 의하여 확대된 선출원에 위반되기 위해서는 선출원이 출원공개 또는 등록공고됨을 요건으로 하기 때문이다. 다만, 선출원을 거절할 이유와 동일한 이유에 의하여 후출원을 거절하는 경우에는 그러하지 아니하다(施規 40).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 특허여부 결정의<br>보류     | 1. 심사관은 특허출원심사의 청구 후 출원인이 특허출원일부터 6개월 이내에 결정 보류신청서를 지식재산처장에게 제출하는 경우에는 특허출원일부터 12개월이 지나기 전까지 특허여부결정을 보류할 수 있다(施規 40의2①본문).<br>2. 다만, i) 특허출원이 분리출원, 변경출원 또는 우선심사의 결정이 있는 특허출원이거나, ii) 특허여부결정의 보류신청이 있기 전에 이미 특허거절결정서 또는 특허결정서가 통지된 경우에는 특허여부결정을 보류할 수 없으며, 제출된 보류 신청서는 불수리된다(施規 11, 40의2①단서).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 특허출원심사의<br>유예      | 1. 신청<br>특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우로서 출원심사의 청구일부터 24개월이 지난 후에 특허출원에 대한 심사를 받으려면 출원심사의 청구일부터 9개월 이내에 심사를 받으려는 시점(출원일부터 5년 이내에 한정하며, 이하 "유예희망시점"이라 한다)을 적은 심사유예신청서를 지식재산처장에게 제출할 수 있다. 다만, 특허출원과 동시에 심사청구를 하면서 심사유예신청도 같이 하는 경우에는 출원서에 그 취지 및 유예희망시점을 적음으로써 그 신청서를 갈음할 수 있으며, 심사청구와 동시에 심사유예신청을 하는 경우에는 심사청구서에 그 취지 및 유예희망시점을 적음으로써 그 신청서를 갈음할 수 있다(施規 40의3①).<br>2. 변경 또는 취하<br>특허출원인이 심사유예신청을 취하하거나 유예희망시점을 변경하려면 심사유예신청서를 제출한 날부터 2개월 이내에 취하서 또는 보정서를 제출하여야 한다(施規 40의3②).<br>3. 결정<br>심사관은 심사유예신청이 있으면 유예희망시점까지 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 있다. 다만, i) 특허출원이 분리출원, 변경출원 또는 정당한 권리자의 출원인 경우, ii) 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우, iii) 특허출원심사의 유예신청이 있기 전에 이미 거절이유를 통지하거나 특허결정서를 통지한 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하며, 제출된 유예 신청서는 불수리된다(施規 11, 40의3③).<br>4. 심사청구료의 납부<br>심사청구와 동시에 특허출원심사 또는 실용신안등록출원심사의 유예를 신청한 경우에는 심사를 받으려는 시점으로부터 2개월 전까지 심사청구를 하였을 때의 심사청구료를 내야 한다(徵收規則 8④). |

## I 법조문

## 제61조 【우선심사】(★)

지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원에 대해서는 심사관에게 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다. <개정 2020. 12. 22.>

1. 제64조에 따른 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업(業)으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우
  2. 대통령령[시행령 제9조제1항]으로 정하는 특허출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우
  3. 대통령령[시행령 제9조제2항]으로 정하는 특허출원으로서 재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 경우
- [전문개정 2014.6.11.]

## 시행령 제9조

## 제9조(우선심사의 대상)

- ① 법 제61조제2호에서 “대통령령으로 정하는 특허출원”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 지식재산처장이 정하는 특허출원을 말한다. <개정 2000. 6. 23., 2001. 6. 27., 2005. 1. 31., 2006. 9. 28., 2007. 6. 28., 2008. 9. 30., 2009. 6. 26., 2013. 6. 28., 2014. 12. 30., 2015. 8. 19., 2017. 1. 10., 2018. 4. 24., 2019. 7. 9., 2021. 6. 22., 2022. 11. 1>
  1. 방위산업분야의 특허출원
  2. 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에 따른 녹색기술과 직접 관련된 특허출원
    - 2의2. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원
    - 2의3. 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 특허출원(지식재산처장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 특허출원으로 한정한다)
  3. 수출촉진에 직접 관련된 특허출원
  4. 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원(「고등교육법」에 따른 국·공립학교의 직무에 관한 특허출원으로서 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항에 따라 국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직에 의한 특허출원을 포함한다)
  5. 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제25조에 따른 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원
    - 5의2. 「중소기업기술혁신 촉진법」 제15조에 따라 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원
    - 5의3. 「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 인증된 기업의 특허출원
    - 5의4. 「발명진흥법」 제24조의2에 따라 지식재산 경영인증을 받은 중소기업의 특허출원
  6. 「국가연구개발혁신법」 제2조제1호에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 특허출원
  7. 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원(당해 특허출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국 특허담당 정부기관에서 특허에 관한 절차가 진행중인 것에 한정한다)
    - 7의2. 법 제198조의2에 따라 지식재산처가 「특허협력조약」에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원
  8. 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 특허출원
  9. 삭제 <2019. 7. 9.>
  10. 지식재산처장이 외국지식재산처장과 우선심사하기로 합의한 특허출원
  11. 삭제 <2023. 12. 19.>
  12. 삭제 <2023. 12. 19.>
- ② 법 제61조제3호에서 “대통령령으로 정하는 특허출원”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원을 말한다. <신설 2021. 6. 22.>
  1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것으로서 지식재산처장이 정하여 고시하는 특허출원
    - 가. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제21호에 따른 의료·방역 물품과 직접 관련된 특허출원
    - 나. 「재난안전산업 진흥법」 제16조에 따라 인증을 받은 재난안전제품과 직접 관련된 특허출원
  2. 재난으로 인한 긴급한 상황에 대응하기 위해 지식재산처장이 우선심사 신청 기간을 정해 공고한 대상에 해당하는 특허출원

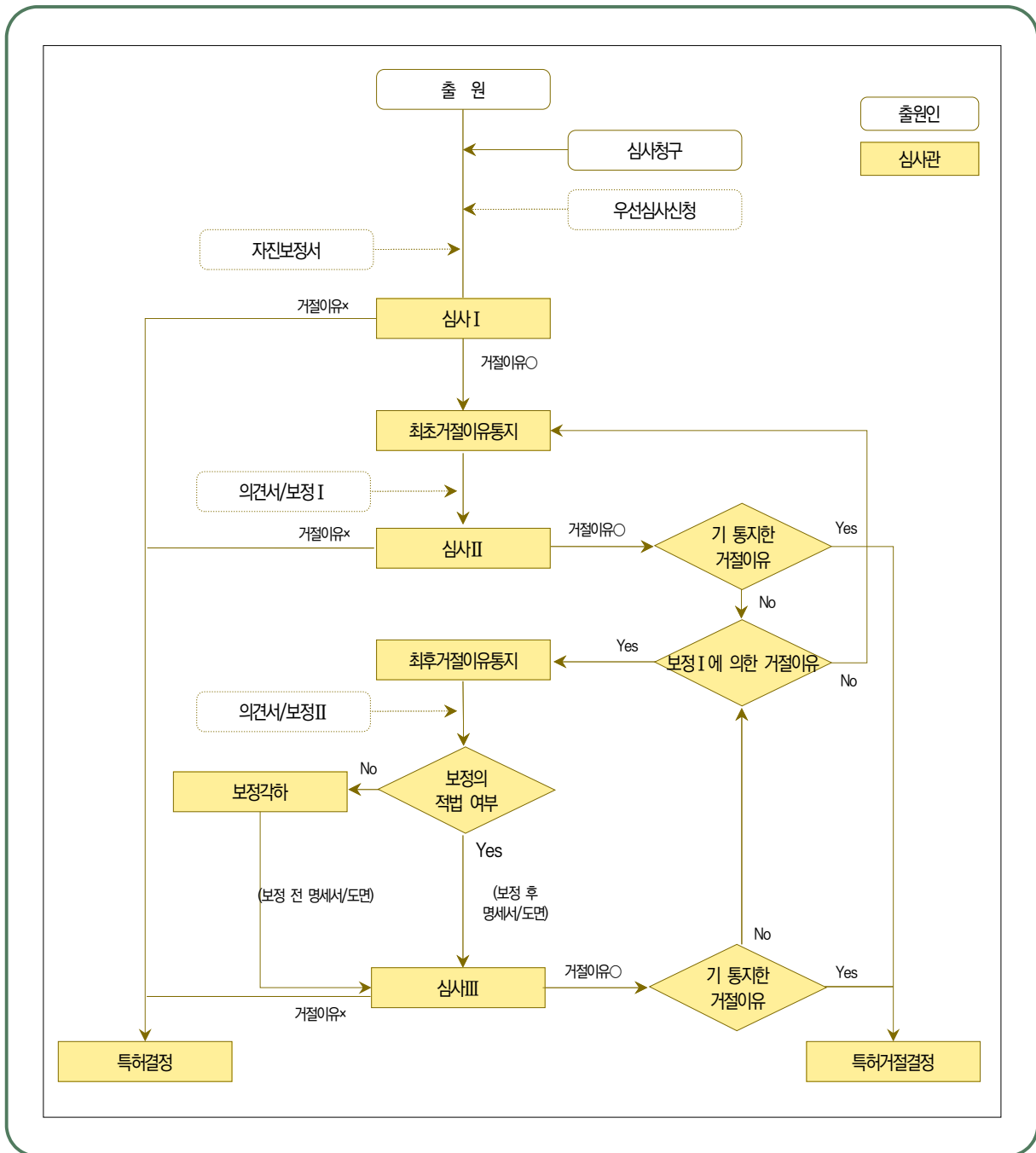
[전문개정 1999. 6. 30.]



## II 우선심사제도(法 61)

| 제 도 |       | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서   | 의의    | 심사청구된 특허출원에 대하여 그 심사를 본래의 심사청구순위에 관계없이 우선하여 심사하는 것을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 취지    | 심사청구순서의 예외를 인정함으로써 공공의 이익 및 출원인의 이익 보호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 요 건 | 주체적   | 누구든지. 다만, 국가·지방자치단체의 직무에 관한 특허출원의 경우는 국가 또는 지방자치단체(국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직을 포함한다)만 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 객 체 적 | 대 상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 대 상   | <ol style="list-style-type: none"> <li>출원공개후 제3자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우(法 61 I)</li> <li>대통령령이 정하는 특허출원으로서 긴급처리가 필요하다고 인정되는 경우(法 61 II, 令 9①) <ol style="list-style-type: none"> <li>방위산업분야의 특허출원</li> <li>「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에 따른 녹색기술과 직접 관련된 특허출원</li> <li>인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원</li> <li>반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 특허출원(지식재산처장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 특허출원으로 한정한다)</li> <li>수출촉진에 직접 관련된 특허출원</li> <li>국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원(고등교육법에 따른 국·공립학교의 직무에 관한 출원으로서 기술이전및사업화촉진에관한법률 제11조 제1항에 따라 국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직에 의한 출원을 포함한다)</li> <li>벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원</li> <li>중소기업기술혁신 촉진법 제15조의 규정에 의하여 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원</li> <li>「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 인증된 기업의 특허출원</li> <li>「발명진흥법」 제24조의2에 따라 지식재산 경영인증을 받은 중소기업의 특허출원</li> <li>「과학기술기본법」 제11조에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 특허출원</li> <li>조약에 의한 우선권 주장의 기초가 되는 특허출원(당해 특허출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국 특허담당 정부기관에서 특허에 관한 절차가 진행중인 것에 한정한다)</li> <li>법 제198조의2에 따라 지식재산처가 「특허협력조약」에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원</li> <li>특허출원인이 업으로서 실시중이거나 실시준비중인 특허출원(부품소재기술개발전문기업의 확인을 받거나 국가 또는 지방자치단체가 주최·주관한 공모전이나 경진대회에서 선정되어 사업화지원을 받은 출원을 포함한다)</li> <li>지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관의 장과 우선심사하기로 합의한 특허출원</li> </ol> </li> <li>대통령령으로 정하는 특허출원으로서 재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 경우(法 61 II, 令 9②) <ol style="list-style-type: none"> <li>다음의 어느 하나에 해당하는 것으로서 지식재산처장이 정하여 고시하는 특허출원 <ol style="list-style-type: none"> <li>「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제21호에 따른 의료·방역 물품과 직접 관련된 특허출원</li> <li>「재난안전산업 진흥법」 제16조에 따라 인증을 받은 재난안전제품과 직접 관련된 특허출원</li> </ol> </li> <li>재난으로 인한 긴급한 상황에 대응하기 위해 지식재산처장이 우선심사 신청 기간을 정해 공고한 대상에 해당하는 특허출원</li> </ol> </li> <li>타법에서 규정하고 있는 경우 <ol style="list-style-type: none"> <li>첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법 제26조에 따라 규제 특례가 적용되는 입주의료연구개발기관이 제출한 첨단의료복합단지 내 의료연구개발과 관련한 특허출원</li> <li>규제자유특구 및 지역특화발전특구에 대한 규제특례법 제36조의8에 따라 규제특례가 적용된 특화사업과 직접 관련된 특허출원</li> </ol> </li> </ol> |
|     | 범위    | 다수의 청구항 중 그 하나가 우선심사대상으로 인정되는 경우에는 출원 전체를 우선심사대상으로 함.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 시기적   | <ol style="list-style-type: none"> <li>제3자의 무단실시의 경우(法 61 I) → 심사청구 + 출원공개후</li> <li>그 밖의 사유 → 심사청구후</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 절 차 | 신청    | 우선심사신청서에 우선심사신청설명서 및 증빙서류를 첨부하고 수수료를 납부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 심사    | 지식재산처장은 ① 우선심사의 신청대상인지 여부, ② 우선심사신청대상에 해당되는지 여부가 제출된 서류만으로 분명한지 여부에 대하여 심사하여 불분명한 경우에는 1월의 기간을 정하여 우선심사신청서를 보완할 것을 지시한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 결정    | <ol style="list-style-type: none"> <li>지식재산처장은 우선심사의 대상이라고 판단되는 경우 우선심사 결정을 하여 그 사실을 통보해 주며, 우선심사대상이 아니라고 판단되는 경우 우선심사 신청을 각하하고, 이를 통보하여야 한다.</li> <li>우선심사 신청이 각하된 경우 우선심사신청료는 반환해준다.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 불복    | 우선심사결정은 행정처분이 아닌 내부적인 사무관리상의 문제이므로 이에 대하여 별도로 불복할 수 없다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 효과  |       | <ol style="list-style-type: none"> <li>우선심사 → 우선심사의 결정이 있으면, 심사청구의 순위에 관계없이 우선적으로 심사에 착수</li> <li>신속한 권리구제 및 분쟁의 조속한 해결</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





| 제 도 |          | 출원의 취하                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 출원의 포기                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 의 의 |          | 출원인의 의사 또는 법률에 의하여 출원 계속의 효과를 소멸시키는 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 의 사 | 주체적 요건   | 출원인<br>공동출원의 경우에는 공유자 모두. 단, 대표자가 있는 경우 다른 당사자의 동의를 받은 후 단독으로 가능<br>대리인<br>1. 법정대리인 - 친권자는 언제나 절차를 밟을 수 있으나, 후견인은 후견감독인의 동의가 필요하다.<br>2. 임의대리인 - 임의대리인은 특별히 권한을 위임받아야 함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 객체적 요건   | 원칙<br>출원 전체에 대하여 취하·포기 가능<br>예외<br>삭제보정을 통해 우회적으로 청구항별 취하 가능 (2001후1044).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 특허결정을 받은 자가 특허료를 납부하는 때에는 청구항별로 포기(法 215의2①).                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 시기적 요건   | 출원절차가 계속중이면 언제든지 출원의 취하·포기가 가능. 즉, 출원인은 특허출원이 무효, 설정등록 또는 거절결정확정되기 전까지 자유로이 그 특허출원을 취하·포기 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 절차       | 출원취하서·출원포기서를 지식재산처장에게 제출                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 법률규정     | <p>1. 국내출원의 경우</p> <p>① 명세서에 청구범위를 적지 아니하고 특허출원하였는데 i) 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월 또는 ii) 제3자의 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 3개월이 되는 날 중 빠른 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하지 아니한 경우(法 42의2②)</p> <p>② 외국어특허출원하였는데 i) 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월 또는 ii) 제3자의 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 3개월이 되는 날 중 빠른 날까지 그 명세서 및 도면의 국어번역문을 총리령으로 정하는 방법에 따라 제출하지 아니한 경우(法 42의3②)</p> <p>③ 변경출원의 기초가 되는 원특허출원의 경우(法 53④)</p> <p>④ 출원일로부터 3년 이내에 심사청구하지 아니한 경우(法 59⑤)</p> <p>⑤ 국내우선권주장의 기초가 된 선출원이 그 출원일로부터 1년 3개월을 지난 경우 (다만, 그 선출원이 i) 포기, 무효 또는 취하된 경우, ii) 특허여부의 결정, 실용신안등록여부의 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우, iii) 선출원을 기초로 한 우선권주장이 취하된 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다)(法 56①)</p> <p>2. 국제출원의 경우</p> <p>① 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니한 경우(法 196①I)</p> <p>② 수수료를 수수료 미납부에 대한 보정명령을 받은 날로부터 1개월(施規 106) 이내에 내지 아니한 경우(法 196①II)</p> <p>③ 국제출원일로부터 4개월 이내에 그 국제출원이 보완사유(法 194①각호)에 해당하는 경우(法 196①III)</p> <p>④ 국내서면제출기간(연장된 경우 연장된 기간)에 발명의 설명, 청구범위의 국어 번역문을 제출하지 아니한 경우(法 201④)</p> <p>⑤ 국내우선권주장의 선출원인 경우 국제출원일로부터 1년 3개월이 지난 때와 기준일 중 늦은 때인 경우(法 202③III)</p> <p>⑥ 재외자가 기준일이 지난 후 2개월(施規 116) 이내에 특허관리인을 선임·신고하지 아니한 경우(法 206③)</p> <p>⑦ 국제조사기관이 인정하지 아니하는 언어로 국제출원이 되었는데 출원인이 국제조사를 위하여 국제조사기관이 인정하는 언어로 된 번역문을 지식재산처장에게 제출하지 아니한 경우(施規 95의2).</p> | <p>1. 정부는 국방상 필요한 경우에 외국에의 특허출원을 금지하거나 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있는데, 이를 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 본다(法 41⑤).</p> <p>2. 추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허출원을 이를 포기한 것으로 본다(法 81③).</p> |
| 효 과 | 절차의 종료   | ① 심사계속중이면 심사가 종료되고, ② 거절결정불복심판 계속중이면 흡결을 보정할 수 없는 부적법한 심판으로서 심결각하의 대상이 되며, ③ 분할·분리·변경출원 및 국내우선권주장의 기초×(단, 조약우선권주장출원은 가능)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 등록금지적 효력 | 출원공개후에 특허출원이 취하·포기되면 출원공개된 발명의 내용에 의하여 출원공개된 후출원에 대해서는 확대된 선출원의 지위(法 29③④)에 의해, 출원공개후 후출원에 대해서는 공지기술의 지위(法 29①각호, 29②)에 의하여 후출원의 등록을 금지시킬 수 있다. 한편, 취하·포기된 특허출원은 선출원의 지위×(法 36④).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 보상금청구권   | 보상금청구권은 특허출원이 취하·포기되면 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다(法 65⑥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 출원료등 반환  | <p>1. 특허출원(분할출원, 변경출원 및 우선심사의 신청이 있는 특허출원을 제외한다) 후 1월 이내에 해당 특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 납부한 수수료 중 특허출원료 및 우선권주장신청료는 반환. 또한, 심사청구후 동일인의 동일출원에 의한 협의 결과 신고 명령, 거절이유통지 또는 특허결정등본송달이 있기 전 출원을 취하하거나 포기한 경우 심사청구료 반환(法 84①)</p> <p>2. 통지받은 날로부터 5년 이내 청구에 의하여 반환받을 수 있음.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# 36

## 특허여부결정(法 62, 63, 63의3, 66~67의3)

### I 법조문

#### 제62조 【특허거절결정】(★★★) 法 63의2, 132의2, 133 / 66

심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 특허거절결정을 하여야 한다. <개정 2021. 10. 19.>

1. 제25조[외국인의 권리능력·제29조[특허요건·제32조[특허를 받을 수 없는 발명·제36조제1항부터 제3항까지[선출원] 또는 제44조[공동출원]에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
2. 제33조제1항 본문[특허를 받을 수 있는 재]에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
3. 조약을 위반한 경우
4. 제42조제3항[발명의 설명의 기재·제4항[청구범위 기재방법·기재원칙·제8항[청구범위 기재방법·다항제 기재방법] 또는 제45조[하나의 특허출원의 범위]에 따른 요건을 갖추지 아니한 경우
5. 제47조제2항[신규사항추가금지·외국어특허출원의 경우 원문 및 국어번역문의 범위]에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우
6. 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원 또는 제52조의2제1항에 따른 범위를 벗어나는 분리출원인 경우
7. 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제63조 【거절이유통지】(★) 法 93 / 170①

① (의견서 제출기회의 부여) 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 특허출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. (예외) 다만, 제51조제1항에 따라 각하결정을 하려는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.> 法 51②

1. 제62조에 따라 특허거절결정을 하려는 경우
2. 제66조의3제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 특허거절결정을 하려는 경우 法 47①II 괄호, 51①II

② (청구항별 통지) 심사관은 청구범위에 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 제1항 본문에 따라 거절이유를 통지할 때에는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명확히 밝히고, 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 적어야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제63조의3 【외국의 심사결과 제출명령】法 87③Ⅶ, 132의2②

심사관은 제54조에 따른 우선권 주장을 수반한 특허출원의 심사에 필요한 경우에는 기간을 정하여 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원을 한 국가의 심사결과에 대한 자료(그 심사결과가 없는 경우에는 그 취지를 적은 의견서를 말한다)를 총리령으로 정하는 방법에 따라 제출할 것을 특허출원인에게 명할 수 있다.

[본조신설 2016.2.29.]

#### 제66조 【특허결정】(★) 法 62 / 170①

심사관은 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정을 하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제66조의2 【직권보정 등】(★)

- ① (요건) 심사관은 제66조에 따른 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정(이하 "직권보정"이라 한다)할 수 있다. 이 경우 직권보정은 제47조제2항에 따른 범위에서 하여야 한다. <개정 2016. 2. 29., 2021. 8. 17.>
- ② (절차: 통지) 제1항에 따라 심사관이 직권보정을 하려면 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달과 함께 그 직권보정 사항을 특허출원인에게 알려야 한다.
- ③ (절차: 의견서의 제출) 특허출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없으면 제79조제1항에 따라 특허료를

낼 때까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

- ④ **(효과: 의견서가 제출된 경우)** 특허출원인이 제3항에 따라 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다. 이 경우 그 특허결정도 함께 취소된 것으로 본다. 다만, 특허출원서에 첨부된 요약서에 관한 직권보정 사항의 전부 또는 일부만 처음부터 없었던 것으로 보는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.> **法 51① I**

⑤ 삭제 <2016.2.29.>

- ⑥ **(효과: 부적합한 경우)** 직권보정이 제47조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다. <신설 2021. 8. 17.>

[전문개정 2014.6.11.]

[제목개정 2016.2.29.]

### 제66조의3 【특허결정 이후 직권 재심사】(★)

- ① **(요건 및 효과)** 심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원을 다시 심사(이하 "직권 재심사"라 한다)할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 거절이유가 제42조제3항제2호[배경기술 기재, 같은 조 제8항[청구범위 기재방법, 다항제 기재방법] 및 제45조[해의 특허출원의 범위]에 따른 요건에 관한 것인 경우 **法 63의2**
2. 그 특허결정에 따라 특허권이 설정등록된 경우
3. 그 특허출원이 취하되거나 포기된 경우

- ② **(절차: 통지)** 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 특허결정을 취소한다는 사실을 특허출원인에게 통지하여야 한다.

- ③ **(절차: 통지 전 설정등록되거나 취하, 포기된 경우)** 특허출원인이 제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 특허출원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 특허결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다. **法 63①II, 51①II, 47①II괄호**

[본조신설 2016.2.29.]

### 제67조 【특허여부결정의 방식】 **法 93**

- ① **(방식)** 특허결정 및 특허거절결정(이하 "특허여부결정"이라 한다)은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.

- ② **(송달)** 지식재산처장은 특허여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 특허출원인에게 송달하여야 한다. **法 67의2① / 15① / 162⑥**

[전문개정 2014.6.11.]

### 제67조의2 【재심사의 청구】(★★)

- ① **(요건)** 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사(이하 "재심사"라 한다)를 청구할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016. 2. 29., 2021. 10. 19.>

1. 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허여부의 결정이 있는 경우
2. 제132조의17에 따른 심판청구가 있는 경우(제176조제1항에 따라 특허거절결정이 취소된 경우는 제외한다)
3. 그 특허출원이 분리출원인 경우 **法 52의2④ / 55①II**

- ② **(절차: 의견서의 제출)** 특허출원인은 제1항에 따른 재심사의 청구와 함께 의견서를 제출할 수 있다.

- ③ **(효과: 특허여부결정취소간주)** 제1항에 따라 재심사가 청구된 경우 그 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허결정 또는 특허거절결정은 취소된 것으로 본다. 다만, 재심사의 청구절차가 제16조제1항에 따라 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.> **法 51①III**

- ④ **(효과: 취하금지)** 제1항에 따른 재심사의 청구는 취하할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

### 제67조의3 【특허출원의 회복】 **法 17**

- ① **(요건)** 특허출원인이 정당한 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.>

1. 제59조제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간
2. 제67조의2제1항에 따라 재심사의 청구를 할 수 있는 기간

- ② **(효과)** 제1항에 따른 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구가 있는 경우에는 제59조제5항에도 불구하고 그 특허출원은 취하되지 아니한 것으로 보거나 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다.

[본조신설 2013.3.22.]

## II 특허여부결정(法 62, 63, 66~67의2)

| 제 도 |       | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서   |       | 특허출원의 특허적격 여부에 관하여 심사관이 행하는 최종적 판단으로서의 행정처분을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 종 류 | 특허 결정 | 심사관이 특허출원된 발명에 대하여 심사한 결과 거절이유를 발견할 수 없는 때에 행하는 것으로서 이는 특허를 허여한다는 취지의 행정처분이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 거절 결정 | 1. 심사관이 특허출원된 발명에 대하여 심사한 결과 거절이유를 발견한 때에 행하는 것으로서 이는 특허를 허여하지 아니한다는 취지의 행정처분이다. 거절이유는 제한적 열거조항으로 해석되며, 재량 불인정<br>2. 법 제62조의 거절이유에 명시되지 아니한 발명의 성립성에 위반된 경우에는 우회적으로 법 제29조제1항 본문의 산업상 이용할 수 있는 발명 또는 법 제42조제3항제1호의 명세서 기재의 위반으로 거절결정하고 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 요 건 | 주체    | 심사관. 한편 공정성을 확보하기 위하여 심판관의 제척제도(전심판여배제) 준용(法 68).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 대상    | 1. 심사청구된 특허출원<br>2. 보정한 경우의 대상<br>① 실체심사에 착수하기 이전(法 47①본문)에 제출된 자진 보정과 최초거절이유통지에 대한 의견서 제출기간(法 47①I)에 제출된 보정이 있는 경우 보정된 내용을 반영한 명세서 또는 도면<br>② 최후거절이유통지에 대한 의견서 제출기간(法 47①II)에 제출된 보정 또는 재심사를 청구할 때(法 47①III) 보정은 특허여부결정을 하기에 앞서 보정각하 여부를 먼저 판단하여 심사대상 명세서 또는 도면을 확정<br>3. 외국어특허출원(외국어국제특허출원 포함)의 경우의 대상<br>외국어특허출원(외국어국제특허출원 포함)의 경우 국어번역문에 따라 실제보정한 것으로 간주하기 때문에(法 42의3⑤, 201⑤), 국어번역문을 그 심사대상으로 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 시기    | 1. 거절결정의 경우<br>① 거절이유의 통지 → 심사관은 특허출원이 거절이유를 포함하고 있어 특허거절결정을 해야 하는 경우에는 거절결정을 하기 전에 일단 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다(法 63① 본문). 심사관은 청구범위에 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 거절이유를 통지할 때에는, 그 통지서에 거절되는 청구항을 명확히 밝히고 그 청구항별로 거절이유를 구체적으로 기재하여야 한다(法 63②)<br>② 출원인의 의견서·보정서 제출<br>③ 거절결정을 하여야 하는 경우 → 심사관은 거절이유통지에 따라 제출된 의견서·보정서에 의해서도 이미 통지한 거절이유가 해소되지 아니하고 동일한 경우에는 다른 거절이유가 있더라도 다시 거절이유를 통지하지 아니하고 특허거절결정을 한다. 한편, 심사관은 특허출원에 있어서 청구범위에 2이상의 청구항이 있고, 하나의 청구항이라도 거절이유가 해소되지 못한 경우에는 출원 전체를 특허거절결정해야 한다.<br>2. 특허결정의 경우<br>심사관이 심사결과 ① 거절이유를 발견할 수 없는 경우, ② 거절이유통지를 하고 그에 의하여 제출된 의견서, 보정서에 의하여 재심사한 결과 거절이유통지서에 지적한 거절이유가 해소되고 그 이외의 새로운 거절이유를 발견할 수 없을 경우 특허결정을 한다.                                                                                                                                                                                                                     |
| 절 차 | 방식    | 특허여부결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다(法 67①).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 송달    | 지식재산처장은 특허여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 특허출원인에게 송달하여야 한다(法 67②).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 효 과 | 거절 결정 | 1. 불복 - 특허거절결정을 받은 자가 이에 대하여 불복할 때에는, 최초 거절결정등본을 송달받은 경우에는 그 날로부터 3개월 이내 재심사 청구와 거절결정불복심판의 청구 중 어느 하나를 할 수 있으며(法 67의2, 132의17), 필요한 경우 분할출원, 변경출원을 할 수 있다. 한편, 재심사에 따른 특허거절결정등본을 송달받은 경우에는 그 날로부터 3개월 이내 분할출원이나 거절결정불복심판을 청구할 수 있으나, 재심사청구는 할 수 없다(法 67의2①I).<br>2. 거절결정의 확정 - 특허거절결정에 대한 심판청구를 할 수 있는 기간이 도과하거나, 특허거절결정에 대하여 심판을 청구했다 하더라도 나중에 심판청구를 취하하거나 심판청구에 대하여 기각(각하)심결이 확정된 경우에는 특허거절결정에 대하여 더 이상 불복할 수 없으므로 특허거절결정이 확정된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 특허 결정 | 1. 특허료 납부 및 설정등록 - 특허결정에 대한 등본을 출원인에게 송달한 때 해당 특허결정이 확정된다. 지식재산처장은 출원인이 특허결정등본송달일로부터 3월내에 최초 3년분의 특허료를 낸 경우에 직권으로 특허 등록을 하게 된다.<br>2. 직권보정 - 심사관은 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에 직권으로 보정할 수 있다(法 66의2).<br>3. 직권재심사 - 심사관이 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원을 다시 심사할 수 있다(法 66의3).<br>4. 재심사청구 - 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간에 재심사를 청구할 수 있다(法 67의2①본문).<br>5. 국내우선권주장출원 - 출원일로부터 1년 이내라면 특허결정등본을 송달된 경우라도 설정등록 전에 국내우선권주장출원을 할 수 있다(法 55①IV). 선출원은 우선권주장이 취하된 경우를 제외하고는 설정등록을 받을 수 없다(法 55⑧).<br>6. 공지의예외적용주장, 분할출원 또는 변경출원<br>특허결정 또는 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간에 공지의예외적용주장(제30조제1항제1호의 취지/증명서류) 또는 분할출원을 할 수 있다. 다만, 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간까지 할 수 있다(法 30③, 52①III). 또한, 특허출원에 대하여 최초 특허거절결정이 되지 않고 특허결정등본이 송달된 경우에 특허료를 내서 설정등록 전에는 출원 계속 중이기 때문에 변경출원을 할 수 있다(法 53①). |



### III 직권보정(法 66의2)

| 제 도 |                  | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서   | 의의               | 심사관이 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에 직권으로 보정하는 것을 말한다(法 66의2①).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 취지               | 적힌 사항이 명백히 잘못되었는데 불필요한 의견제출통지로 인한 심사절차의 지연이 되는 것을 방지하고 명세서 또는 도면의 하자를 치유하여 명세서 또는 도면의 완벽성을 높이기 위함이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 요 건 | 주체적              | 심사관                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 객체적              | 1. 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우이어야 한다(法 66의2①본문). 「명백히 잘못된 경우」란 사소한 오타자 이외에 명백히 잘못 기재된 기재불비가 있는 경우를 말하고, 여기서 명백히 잘못 기재된 기재불비란 통상의 기술자가 그 기재가 잘못되었다는 사실을 쉽게 인식할 수 있고, 명세서 등의 기재, 의견서 및 출원 시 기술상식을 참작하여 출원인의 당초 의도를 명확히 알 수 있어서 해당 보정이 어떻게 이루어질 것인지 쉽게 예측할 수 있는 경우를 말한다.<br>2. 직권보정은 신규사항이 추가되지 아니한 범위(法 47②)에서 하여야 한다(法 66의2①단서).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 시기적              | 특허결정할 때                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 절차               | 1. 특허결정의 등본 송달과 함께 그 직권보정 사항을 특허출원인에게 알려야 한다(法 66의2②).<br>2. 특허출원인은 직권보정 사항의 일부 또는 전부를 받아들일 수 없으면 법 제79조제1항에 따라 특허료를 낼 때까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 66의2③).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 효 과 | 의견서<br>제출<br>불가능 | 1. 특허출원인이 의견서를 제출하지 아니한 경우 이를 수용한다는 의사가 있는 것이기 때문에 출원인의 의사에 의한 보정과 같이 취급한다.<br>2. 다만, 직권보정이 신규사항을 추가하거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 66의2⑥).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 의견서<br>제출        | 1. 특허출원인이 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 일부 또는 전부는 처음부터 없었던 것으로 본다. 이 경우 그 특허결정도 함께 취소된 것으로 본다. 다만, 특허출원서에 첨부된 요약서에 관한 직권보정 사항의 전부 또는 일부만 처음부터 없었던 것으로 보는 경우에는 그러하지 아니하다(法 66의2④). 요약서에 관한 기재는 거절이유가 아니기 때문에 굳이 특허결정이 취소된 것으로 볼 이유가 없다.<br>2. 특허결정이 취소된 것으로 보는 경우 심사관은 직권보정 전 명세서 또는 도면에 의하여 다시 심사를 진행한다. 이 때 심사관이 직권보정 전에 이미 통지된 거절이유가 발견되더라도 다시 거절이유를 통지하여야 한다. 다만, 그 거절이유가 출원인이 받아들이지 아니한 직권보정사항에 해당하고, 이미 통지된 거절이유라면 바로 거절결정할 수 있다.<br>3. 심사관은 직권보정 전에 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ) 또는 재심사를 청구할 때(法 47①Ⅲ) 한 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 또는 청구범위 보정범위제한(法 47③)을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생했음에도 불구하고 보정각하결정을 하지 아니하고 이를 간과하여 특허결정한 것을 특허결정을 취소한 후에 발견한 경우에는 보정을 인정하고 심사를 진행한다(法 51①Ⅰ). 이는 보정이 인정됨을 전제로 특허결정을 받았다는 것을 신뢰한 출원인의 이익을 보호하기 위함이다. |

Ⅳ 직권 재심사(法 66의3)

| 제 도 |     | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서   | 의의  | 심사관이 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원을 다시 심사하는 것을 말한다(法 66의3①본문).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 취지  | 1. 기존에는 심사관이 특허결정을 한 후 하자를 발견하더라도 이를 취소하고 다시 심사할 수 있는 명문 규정이 없어 무효 가능성이 있는 특허가 그대로 등록되는 문제점이 있었기 때문에 2017. 3. 1. 시행되는 개정법(法律 제14035호, 2016. 2. 29. 개정)에서는 직권으로 특허결정을 취소할 수 있는 규정을 신설하였다.<br>2. 본 제도는 주로 특허결정 후 제3자의 정보제공에 의하여 거절이유를 발견한 경우에 이용될 수 있을 것이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 요 건 | 주체적 | 심사관                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 객체적 | 특허결정된 특허출원에 관하여 배경기술 기재(法 42③Ⅱ), 다항제 기재방법(法 42⑧) 및 하나의 특허출원의 범위(法 45) 위반을 제외한 명백한 거절이유를 발견한 경우이어야 한다. 여기서, 「명백한 거절이유」란 특허결정된 특허출원이 등록되었을 때 무효로 될 가능성이 있다는 정도로는 부족하고, 무효로 될 것이 명백한 경우를 의미한다고 할 것이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 시기적 | 특허결정 후 i) 그 특허결정에 따라 특허권이 설정등록된 경우나 ii) 그 특허출원이 취하되거나 포기된 경우에는 직권 재심사를 할 수 없다. i)의 경우 이미 등록된 상태에서 특허결정을 취소하고, 그 출원을 다시 심사하는 것은 권리의 안정성을 해하는 것이고, ii)의 경우 출원절차가 종료되어 취소할 특허결정이 없기 때문이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 절차  |     | 1. 심사관이 직권 재심사를 하려면 특허결정을 취소한다는 사실을 특허출원인에게 통지하여야 한다(法 66의3②).<br>2. 특허출원인이 통지를 받기 전에 그 특허출원이 i) 특허결정에 따라 특허권이 설정등록된 경우나 ii) 취하되거나 포기된 경우에는 특허결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다(法 66의3③).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 효과  |     | 1. 심사관은 특허결정을 취소한 경우에는 다시 심사를 진행한다. 심사관은 직권 재심사에 이르게 된 명백한 거절이유에 대해서는 특허출원인에게 최초거절이유를 통지하여 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 47①Ⅱ괄호). 즉, 심사관이 특허결정을 취소한 경우에는 다시 최초거절이유통지를 하여, 출원인에게 청구범위를 확장, 변경할 수 있는 보정기회를 주고 있다(法 47②).<br>2. 심사관은 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 특허거절결정을 하려는 경우에도 특허출원인에게 최초거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 63①Ⅱ).<br>3. 심사관은 취소된 특허결정 전 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ) 또는 재심사를 청구할 때(法 47①Ⅲ) 한 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 또는 청구범위 보정범위제한(法 47③)을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생했음에도 불구하고 보정각하결정을 하지 아니하고 이를 간과하여 특허결정한 것을 특허결정을 취소한 후에 직권 재심사단계에서 발견한 경우에는 보정을 인정하고 심사를 진행한다(法 51①Ⅱ, 47①Ⅱ). 다만, 발생한 새로운 거절이유가 직권보정(法 66의2)을 할 수 있는 경우라면, 심사관은 보정을 승인하고 이후 절차를 진행할 수 있다.<br>4. 특허결정을 취소하기 전에 한 보정각하결정은 추후 거절결정불복심판에서 다룰 수 없다(法 51③괄호). 이는 직권 재심사단계에서 직권 재심사의 전 보정각하결정에 대하여 충분히 다룰 수 있는 기회를 주었기 때문이다. |



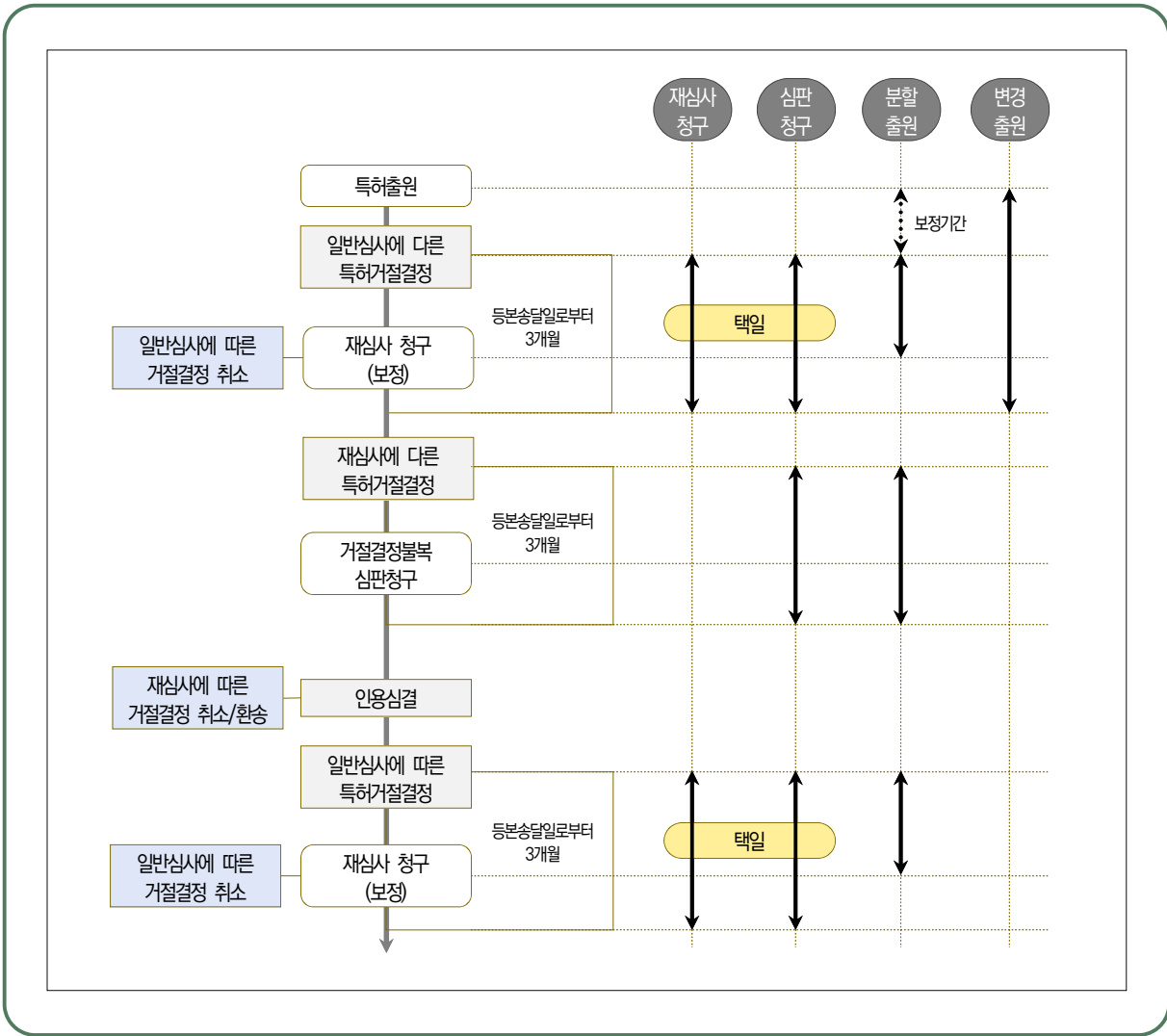
**V 재심사 청구(法 67의2)**

| 제 도      |     | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서        | 의의  | 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(법 제15조 제1항에 따라 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다.) 이내에 그 특허출원의 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관하여 재심사를 청구할 수 있다(法 67의2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 취지  | 1. 종래 보정을 위하여 거절결정불복심판을 청구하여야 하는 심사전치제도의 불합리 개선<br>2. 특허결정등본을 송달받았을지라도 권리범위 재설계 기회 제공                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 요 건      | 주체적 | 출원인 또는 그 승계인, 임의대리인의 특별히 권한을 위임받지 않더라도 가능하고 공동출원인 각자도 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 객체적 | 실체보정이 있어야 함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 시기적 | 1. 원칙<br>그 특허출원에 관하여 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |     | 2. 예외<br>① 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허여부의 결정이 있는 경우<br>② 거절결정불복심판청구(法 132의17)가 있는 경우(제176조제1항에 따라 특허거절결정이 취소된 경우는 제외한다)<br>③ 그 특허출원이 분리출원인 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 절차       |     | 1. 재심사의 청구는 명세서 등의 보정서에 그 취지를 병기하여 제출하여야 한다(施規 37의2).<br>2. 출원인은 재심사의 청구와 함께 의견서를 제출할 수 있다(法 67의2②).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 효 과      | 적법  | 1. 특허여부결정의 취소간주 및 재심사<br>① 재심사의 청구가 있는 경우에는 해당 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허결정 또는 특허거절결정은 취소된 것으로 본다(法 67의2③).<br>② 특허법 제51조제1항에 의하여 보정의 적법성을 판단하여, 보정이 적법하면 보정 후의 명세서 및 도면에 의해, 보정이 부적법하면 보정을 각하(法 51①)하고, 보정 전의 명세서 및 도면에 의하여 출원이 거절이유(法 62)가 존재하는 지 판단하여 특허여부 결정을 한다.<br>③ 거절이유가 존재하는 경우 거절결정을 하고 거절결정등본을 출원인에게 송달한다. 이 경우 출원인은 거절결정등본송달 후 3개월 이내에 거절결정불복심판(法 132의2)을 청구하거나 분할출원(法 52)을 할 수 있다.<br>④ 재심사의 청구 전 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 내(法 47①II)에 한 보정이 보정의 범위를 벗어나거나(法 47②③), 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생(法 51①중단) 하였는데 심사관이 이를 간과하여 추후 재심사단계에서 발견한 경우에는 보정을 인정하고 심사를 진행한다.<br>2. 취하금지<br>재심사의 청구는 취하할 수 없다(法 67의2④). |
|          | 부적법 | 1. 재심사의 청구절차가 절차보정사유(法 46)에 해당하여 법 제16조제1항에 따라 무효로 된 경우에는 특허거절결정 또는 특허거절결정은 취소되지 아니한 것으로 본다(法 67의2③단서).<br>2. i) 명세서 또는 도면의 보정없이 재심사 청구한 경우, ii) 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허여부결정이 있는 경우, iii) 재심사를 청구할 때에 거절결정불복심판이 있는 경우 또는 iv) 재심사청구한 출원이 분리출원인 경우에는 재심사청구서는 반려된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 특허출원의 회복 |     | 특허출원인이 정당한 사유로 재심사의 청구를 할 수 있는 기간(특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다))을 지키지 못하여 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 재심사의 청구를 할 수 있고, 이 경우 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다(다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다(法 67의3)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Ⅵ 거절이유통지(法 62)에 대한 출원인의 대응방안

| 구 분          |        | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서            |        | 심사관은 출원한 발명의 청구범위의 청구항별로 거절이유를 검토하지만, 일부항의 거절이유가 극복되지 아니하면 특허출원 전체에 대하여 거절결정을 한다. 다만, 심사관은 특허출원한 발명이 거절이유에 해당하는 경우 거절결정을 하기 전에 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출기회를 주어야 한다. 이 때 출원인은 거절이유의 타당성을 검토하고, 그 검토 결과에 따라 적절한 대응조치를 취할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 거절이유의 타당성 검토 |        | 심사관이 지적한 거절이유가 타당한지 먼저 검토하여야 한다. 구체적으로 ① 출원발명에 거절이유가 존재하는지 여부, ② 거절이유와 함께 제시된 인용대상이 적법하게 존재하는지 여부, ③ 심사관의 법 적용에 착오가 없었는지 여부 등을 검토하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 거절이유 타당 ○    | 거북 가능  | <p><b>1. 공지예외적용의 주장(法 30)</b><br/>출원인은 신규성(法 29①) 또는 진보성(法 29②) 위반으로 거절이유통지를 받은 경우 취지 및 증명서류를 제출하면서 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 주장을 할 수 있다. 다만, 공지 등이 된 날로부터 12개월 이내에 출원한 경우에 한하고, 법 제30조제1항제1호의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 의한 공지는 법 제30조제1항제2호의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반한 공지와 달리 보완수수료를 납부하여야 한다(法 30①③).</p> <p><b>2. 무권리자의 특허출원·특허에 대한 정당한 권리자의 주장(法 34, 35)</b><br/>무권리자의 특허출원이나 특허로 인해 거절이유통지를 받은 경우 정당한 권리자의 주장을 하여 무권리자 출원의 출원일로 소급효를 인정받을 수 있다(法 34, 35). 다만, 출원일이 소급되기 위해서는 정당한 권리자의 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 무권리자의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 포함되어 있어야 하기 때문에 신규성(法 29①), 확대된 선출원(法 29③④), 선출원주의(法 36)에 위반되었다는 이유로 거절이유를 통지받은 경우에 한한다. 한편 정당한 권리자가 무권리자의 특허출원을 승계하였거나 무권리자의 특허를 이전등록받았다면 정당한 권리자는 그 출원을 취하, 포기하면 될 것이다.</p> <p><b>3. 보정서 제출(法 47)</b><br/>심사관이 지적한 거절이유를 극복하기 위해 보정할 수 있다. 예를 들어, 신규성(法 29①) 또는 진보성(法 29②) 위반으로 거절이유통지를 받은 경우 청구범위를 삭제하거나 감축하는 보정 등을 통해 거절이유를 극복할 수 있을 것이다. 다만, 최초거절이유통지를 받은 경우에는 의견서 제출기간 내에 신규사항추가금지(法 47②)에 위반되지 아니한 범위 내에서 보정할 수 있으나, 최후거절이유통지이후의 보정범위 제한(法 47③④)도 만족하여야 하고, 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생하지 아니하여야 한다.</p> <p><b>4. 분할출원(法 52)</b><br/>일부청구항에 대하여 거절이유가 있거나, 하나의 특허출원범위(法 45)에 위반된 경우에 분할출원을 하여 출원일체의 원칙을 회피할 수 있다. 다만, 청구범위에 기재된 발명을 분할출원하는 경우에는 협의제를 회피하기 위해 삭제보정을 수반해야 한다.</p> <p><b>5. 변경출원(法 53)</b><br/>심사관으로부터 진보성(法 29②)에 위반되었다는 이유로 거절이유통지 또는 거절결정을 받은 경우에 최초 거절결정등본의 송달일로부터 3개월까지 변경출원을 고려해볼 수 있다. 실용신안은 특허보다 창작수준이 낮은 정도의 진보성인 「극히 용이」를 요구하기 때문이다. 다만, 물품성이 있어야 한다.</p> <p><b>6. 우선권주장출원(法 54, 55, 56)</b><br/>심사관이 기재불비(法 42③④⑧) 등으로 거절이유를 통지한 경우 출원일로부터 1년이 지나지 않았다면 조약우선권 주장출원, 국내우선권주장출원 등을 고려해 볼 수 있을 것이다. 물론, 통상적으로 기재불비의 경우 보정으로 하자가 치유될 수 있으나 신규사항추가금지(法 47②) 범위를 벗어난 경우에는 조약우선권주장출원 또는 국내우선권주장출원이 거절이유를 극복하기 위한 적절한 수단이 될 수 있다.</p> <p><b>7. 의견서 제출</b><br/>심사관이 지적한 거절이유는 타당하나 보정, 분할출원 등을 통하여 거절이유를 극복하였기 때문에 재심사하여 특허결정해줄 것을 내용으로 하는 의견서를 제출할 수 있다.</p> |
|              | 거북 불가능 | 출원의 취하·포기를 할 수 있다. 출원의 취하 또는 포기는 취하서 또는 포기서가 적법하게 수리된 때부터 효력이 발생한다. 또한, 출원인은 거절이유통지에 대하여 아무런 대응을 하지 않고 그대로 방치할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 거절이유 타당 ×    |        | <p><b>1. 의견서 또는 보정서 제출</b><br/>심사관의 거절이유가 타당하지 않다는 의견서를 제출할 수 있다. 이 경우 필요한 경우 보정서를 첨부할 수도 있다.</p> <p><b>2. 거절결정에 대한 불복</b><br/>특허거절결정을 받은 자가 이에 대하여 불복할 때에는, 최초 거절결정등본을 송달받은 경우에는 그 날로부터 3개월 이내 재심사 청구와 거절결정불복심판의 청구 중 어느 하나를 할 수 있으며(法 67의2, 132의17), 필요한 경우 분할출원, 변경출원을 할 수 있다. 한편, 재심사단계에서 거절결정등본을 송달받은 경우에는 그 날로부터 3개월 이내 분할출원이나 거절결정불복심판을 청구할 수 있다.</p> <p><b>3. 불복의 소 제기</b><br/>거절결정불복심판에서 기각심결을 받은 경우, 심결등본송달일로부터 30일 이내 분리출원하거나 심결불복의 소를 특허법원에 제기할 수 있으며, 심결취소의 소에서 기각판결을 받은 경우 기각판결송달일로부터 2주일 이내에 대법원에 상고할 수 있다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

VII 거절결정등본을 송달받은 출원인의 대응방안



# 37

## 정보제공제도(法 63의2)

### I 법조문

#### 제63조의2 【특허출원에 대한 정보제공】(★) 法 62, 132의2, 133 / 66의3 / 170①

특허출원에 관하여 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 지식재산처장에게 제공할 수 있다. 다만, 제42조제3항제2호[배경기술 기재], 같은 조 제8항[청구범위 기재방법, 다항제 기재방법] 및 제45조[하나의 특허출원의 범위]에 따른 요건을 갖추지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2014.6.11.]

## II 정보제공제도(法 63의2)

| 제 도 |                  | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서   | 의의               | 특허출원에 관하여 누구든지 그 특허출원이 법 제62조 각 호의 거절이유(단, 法 42③Ⅱ·42⑧·45 제외) 규정에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 지식재산처장에게 제공할 수 있는 제도를 말한다.                                                                                                                                                                           |
|     | 취지               | 특허출원에 대하여 누구든지 그 출원이 특허되어서는 안 된다는 정보를 증거와 함께 제공하게 함으로써 심사관에 의한 심사의 신속성 및 정확성을 높여 심사의 질적 향상에 기여하도록 함에 정보제공제도의 취지가 있다.                                                                                                                                                                                |
| 요건  | 정보제공자            | 누구든지 정보제공을 할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 정보 제공 대상         | 거절이유(法 62) 중 절차적 요건((발명의 설명 중 배경기술 기재(法 42③Ⅱ), 다항제 기재방법(法 42⑧), 하나의 특허출원의 범위(法 45)) 제외                                                                                                                                                                                                              |
|     | 사유 범위            | 청구항별로 정보제공 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 정보제공 시기          | 1. 그 특허출원이 지식재산처에 계속 중인 경우에는 언제든지 정보제공을 할 수 있다. 따라서 출원이 무효, 취하, 포기 설정등록되기 전이나 또는 특허거절결정이 확정되기 전까지 정보제공을 할 수 있다.<br>2. 거절결정불복심판이 청구된 경우에도 심판원장에 정보제공 가능(정정심판도 정보제공이 허용된다는 것이 심판 실무임)<br>3. 한편, 특허결정된 특허출원에 대하여 설정등록 전에 정보제공된 경우, 심사관은 제출된 증거자료를 살펴서 특허결정된 특허출원에 명백한 거절이유가 있다면 직권 재심사를 하게 된다(法 66의3). |
| 절차  |                  | 정보제공자는 특허될 수 없다는 취지의 정보와 필요한 증거를 지식재산처장(거절결정불복심판단계에서는 심판원장)에게 제출할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                             |
| 효과  | 심사의 참고           | 1. 심사관이 제출된 정보를 근거로 특허거절결정을 하여야 하는 의무는 없다. 제출된 증거를 채택할지 유무는 심사관의 재량사항이다.<br>2. 정보제공자는 특허법상 그 특허출원에 관한 절차에서 당사자는 아니기 때문에 심사관은 채택여부의 통지에 관해 정보제공자에게 통지할 의무는 없다. 그러나 심사 실무상 정보제공이 있는 출원이 특허거절결정, 특허결정 또는 기타의 사유로 심사가 종결되는 때에는 심사관이 그 결과 및 제출 정보의 활용여부를 정보제공자에게 통보하도록 하고 있다.                            |
|     | 심사의 신속성 및 정확성 향상 | 심사관은 심사에 있어 필요한 자료 및 증거 등을 쉽게 수집할 수 있어, 그 출원에 대한 심사를 신속하고 정확하게 할 수 있다. 아울러 일반 공중에 의한 심사 협조를 통해 완전한 심사가 이루어지면 하자 있는 권리의 발생가능성이 그만큼 줄어들게 되므로 특허권의 법적 안정성이 확보된다.                                                                                                                                       |



## 출원공개제도(法 64, 65)

### I 법조문

#### 제64조 【출원공개】(★) 法 207

- ① (출원공개 요건 및 절차) 지식재산청장은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 6개월이 지난 후 또는 그 전이라도 특허출원인이 신청한 경우에는 총리령(시행규칙 제44조)으로 정하는 바에 따라 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 출원공개를 하여야 한다. 法 42의2②, 42의3②
1. 제54조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 그 우선권 주장의 기초가 된 출원일
  2. 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 선출원의 출원일
  3. 제54조제1항 또는 제55조제1항에 따른 둘 이상의 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 해당 우선권 주장의 기초가 된 출원일 중 최우선일
  4. 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하지 아니하는 특허출원의 경우: 그 특허출원일

#### 시행규칙 제44조

##### 제44조(조기공개 등의 신청)

- ① 법 제64조제1항에 따라 특허출원일부터 1년 6개월이 경과하기 전에 특허출원의 공개를 신청하려는 자는 별지 제25호서식의 조기공개신청서를 지식재산청장에게 제출하여야 한다. 다만, 특허출원과 동시에 공개를 신청하려는 경우(청구범위가 기재된 명세서가 첨부된 경우만 해당한다)에는 출원서에 그 취지를 기재함으로써 신청서의 제출에 갈음할 수 있다. <개정 1998. 12. 31., 2006. 12. 29., 2007. 6. 29., 2014. 12. 30.>
- ② 외국어특허출원 또는 국제특허출원의 경우에는 법 제42조의3제2항 또는 법 제201조제1항에 따라 국어번역문을 제출한 후가 아니면 조기공개의 신청을 할 수 없다. <신설 1997. 7. 1., 1998. 12. 31., 2014. 12. 30.>
- ③ 특허에 관한 절차를 밟는 자가 제1항의 규정에 의한 조기공개의 신청을 취하고자 하는 경우에는 조기공개신청서를 제출한 날부터 10일 이내에 별지 제12호서식의 취하서를 제출하여야 한다. <신설 2003. 5. 17., 2006. 12. 29.>
- ④ 대리인이 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 절차를 밟고자 하는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. <개정 2003. 5. 17.>
- [본조신설 1996. 6. 22.]  
[제목개정 2003. 5. 17.]

- ② (출원공개의 예외) 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원공개를 하지 아니한다.
1. 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우
  2. 제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다)
  3. 제87조제3항에 따라 등록공고를 한 특허의 경우
- ③ (출원공개의 예외) 제41조제1항에 따라 비밀취급된 특허출원의 발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 그 특허출원의 출원공개를 보류하여야 하며, 그 발명의 비밀취급이 해제된 경우에는 지체 없이 제1항에 따라 출원공개를 하여야 한다. 다만, 그 특허출원이 설정등록된 경우에는 출원공개를 하지 아니한다.
- ④ (출원공개의 방법) 제1항의 출원공개에 관하여 출원인의 성명·주소 및 출원번호 등 특허공보에 게재할 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 시행령 제19조

##### 제19조(특허공보)

- ① 법 제221조제1항에 따른 특허공보는 등록특허공보와 공개특허공보로 구분한다. <개정 2014. 12. 30.>
- ② 법 제87조제3항제8호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <개정 2017. 1. 10.>
1. 분류기호
  2. 법 제30조에 따른 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 발명에 관한 사항
  3. 특허출원서에 첨부된 명세서 및 도면(법 제87조제2항에 따른 설정등록 시에 첨부된 명세서 및 도면을 말한다)



4. 분할출원, 분리출원 또는 변경출원에 관한 사항
5. 우선권주장에 관한 사항
6. 출원공개번호 및 공개연월일
7. 법 제66조의2에 따른 직권보정에 관한 사항
8. 법 제132조의3, 제133조의2, 제136조 또는 제137조에 따라 정정된 내용
9. 그 밖에 지식재산청장이 필요하다고 인정하는 사항
- ③ 공개특허공보에는 다음 각 호의 사항을 게재한다. 다만, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있다고 인정되는 사항은 게재하지 아니한다. <개정 1999. 6. 30., 2001. 6. 27., 2003. 6. 13., 2006. 9. 28., 2013. 6. 28., 2014. 12. 30.>
  1. 다음 각 목의 구분에 따른 사항
    - 가. 출원인이 자연인인 경우: 성명 및 주소
    - 나. 출원인이 법인인 경우: 법인의 명칭 및 영업소의 소재지
  2. 출원번호·분류기호 및 출원연월일
  3. 발명자의 성명 및 주소
  4. 출원공개번호 및 공개연월일
  5. 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면. 다만, 법 제42조의3제1항에 따라 명세서 및 도면을 국어가 아닌 언어로 적은 특허출원(이하 "외국어특허출원"이라 한다)과 법 제199조제1항에 따른 국제특허출원 중 국어가 아닌 언어로 적은 국제특허출원(이하 "외국어국제특허출원"이라 한다)의 경우에는 다음 각 목의 구분에 따른 명세서(외국어국제특허출원의 경우에는 발명의 설명 및 청구범위를 말한다. 이하 이 호에서 같다) 및 도면으로 한다.
    - 가. 외국어특허출원의 경우: 법 제42조의3제5항에 따라 보정한 것으로 보는 명세서 및 도면
    - 나. 외국어국제특허출원의 경우: 법 제201조제5항에 따라 보정한 것으로 보는 명세서 및 도면
  - 5의2. 특허출원서에 첨부된 요약서
  - 5의3. 법 제42조의2제2항에 따른 명세서 보정에 관한 사항
  6. 우선권주장에 관한 사항
  7. 변경출원, 분리출원 또는 분할출원에 관한 사항
  8. 법 제60조제2항에 따른 출원심사의 청구사실. 다만, 출원공개시에 그 사실이 게재되지 아니한 경우에는 해당 출원의 공개번호·분류기호 및 출원번호를 그 심사청구사실과 함께 추후 발행되는 공개특허공보에 게재하여야 한다.
  9. 법 제63조의2의 규정에 의하여 누구든지 그 특허출원이 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 지식재산청장에게 제공할 수 있다는 취지
  10. 기타 특허출원의 공개에 관계되는 사항
- ④ 지식재산청장은 법 제87조제3항 및 이 조 제3항에 따라 자연인인 특허권자, 자연인인 출원인 또는 발명자의 주소를 게재하는 경우 그 특허권자, 출원인 또는 발명자의 신청이 있으면 그 주소의 일부만을 게재할 수 있다. <신설 2013. 6. 28., 2017. 1. 10.>
- ⑤ 제4항에 따른 신청 방법 및 절차, 주소의 게재 범위는 지식재산청장이 정하여 고시한다. <신설 2013. 6. 28.>

#### 제65조 【출원공개의 효과】(★★★) **법 207③④**

- ① (경고) 특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다.
- ② (성립요건 및 보상금액) 특허출원인은 제1항에 따른 경고를 받거나 제64조에 따라 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. <개정 2019. 1. 8.> **법 99의2②**
- ③ (행사시기) 제2항에 따른 청구권은 그 특허출원된 발명에 대한 특허권이 설정등록된 후에만 행사할 수 있다.
- ④ (특허권과의 독립성) 제2항에 따른 청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 아니한다.
- ⑤ (준용규정) 제2항에 따른 청구권을 행사하는 경우에는 제127조[간접침해]·제129조[생산방법의 추정]·제132조[자료제출명령] 및 「민법」 제760조[공동불법행위책임]·제766조[손해배상청구권의 소멸시효]를 준용한다. 이 경우 「민법」 제766조제1항 중 "피해자나 그 법정 대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날"은 "해당 특허권의 설정등록일"로 본다.
- ⑥ (소멸) 제64조에 따른 출원공개 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2항에 따른 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다. <개정 2016.2.29.>
  1. 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 경우
  2. 특허출원에 대하여 제62조에 따른 특허거절결정이 확정된 경우
  3. 제132조의13제1항에 따른 특허취소결정이 확정된 경우
  4. 제133조에 따른 특허를 무효로 한다는 심결(같은 조 제1항제4호[후발적 무효사유]에 따른 경우는 제외한다)이 확정된 경우 [전문개정 2014.6.11.]



## II 출원공개제도(法 64, 65)

| 제 도                       |                    | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서                         | 의의                 | 특허출원된 내용에 대하여 심사청구의 유무에 관계없이 출원일로부터 1년 6개월이 지난 후 또는 특허출원일부<br>터 1년 6개월이 지나기 전이라도 출원인의 신청이 있는 때에는 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 사<br>회일반에 공표하는 제도를 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | 취지                 | 1. 동일한 발명에 대한 제3자의 중복투자 및 중복연구를 방지<br>2. 심사청구제도의 효율적으로 운영                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 요건                        | 주체적                | 지식재산처장에 의하여 강제공개되나, 출원인의 신청에 의하여 조기공개가 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | 원칙                 | 지식재산처에 출원계속중인 모든 특허출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           | 예외                 | 1. 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우(法 64②Ⅰ)<br>2. 법 제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다)(法 64②Ⅱ)<br>3. 법 제87조제3항에 따라 등록공고를 한 특허의 경우(法 64②Ⅲ)<br>4. 국방상 필요한 발명으로서 비밀취급이 필요한 경우(法 64③)<br>5. 공서양속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 경우(令 19③)                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | 시기적                | 원칙<br>출원일로부터 1년 6개월이 지난 후<br>예외<br>1. 출원일은 ① 무권리자에 대한 정당한 권리자의 출원의 경우 무권리자의 출원일(法 34, 35), ② 분할출원(法<br>52②), 분리출원(法 52의2②), 변경출원(法 53②)의 경우 원출원일, ③ 조약우선권주장출원(法 54①), 국내우<br>선권주장출원(法 55③)의 경우 최우선일, ④ 국제특허출원의 경우 우선일을 기준으로 판단<br>2. 1년 6개월 전이라도 출원인의 신청에 의하여 조기공개가 가능                                                                                                                                                                                     |
| 절차                        | 조기공개               | 1. 신청서의 제출<br>① 「출원인이 지식재산처장에게 조기공개 신청서를 제출 다만, 특허출원과 동시에 신청하는 경우(청구범위가 기재된 명세서가<br>첨부된 경우에 한한다) 출원서에 그 취지를 기재함으로써 신청서의 제출에 갈음(施規 44①).<br>② 1) 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우, 2) 법 제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한<br>경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다), 3) 등록공고를 한 특허는 출원공개의 대상이 되지 아니한데 이에 대하여<br>조기공개신청서를 제출한 경우, 지식재산처장은 조기공개신청서를 불수리(施規 11).<br>2. 신청의 취하 - 조기공개신청서를 제출한 날로부터 10일 이내에 취하서를 제출(施規 44③).                                                                      |
|                           | 방법                 | 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면이 공개특허공보에 전문공개, CD-ROM배포(令 19③)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 효과                        | 보상금<br>청구권의<br>발생  | 특허출원인이 출원공개가 있는 후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한<br>자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록시까지의 기간동안 그 특허발명의 실<br>시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있는 권리가 발생한다(法 65).                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | 우선심사               | 출원공개후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우에는 우선심사<br>를 신청할 수 있다(法 61Ⅰ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | 서류의<br>열람 등의<br>신청 | 특허출원, 특허취소신청, 심판 등에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 특허원부 및 서류의 열람 또는<br>복사가 필요한 자는 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 서류의 열람 등의 허가를 신청할 수 있다. 지식재산<br>처장 또는 특허심판원장은 신청이 있더라도 i) 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원(국내우선권 주장<br>을 수반하는 특허출원이 출원공개 또는 설정등록된 경우에는 그 선출원은 제외한다)에 관한 서류, ii) 출원공개<br>또는 설정등록되지 아니한 특허출원의 특허거절결정에 대한 심판(法 132의17)에 관한 서류, iii) 공공의 질서<br>또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 서류의 어느 하나에 해당하는 서류를 비밀로<br>유지할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 서류의 열람 또는 복사를 허가하지 아니할 수 있다(法 216). |
|                           | 미생물의<br>분양         | 기탁된 미생물에 관계되는 발명을 시험 또는 연구를 위하여 실시하려는 자는 i) 그 미생물에 관계되는 발명에<br>대한 특허출원이 공개되거나 설정등록된 경우 및 ii) 거절이유통지(法 63)에 따른 의견서를 작성하기 위하여<br>필요한 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우 국내기탁기관, 국제기탁기관, 지정기탁기관으로부터 그 미생물을 분<br>양받을 수 있다(令 4①Ⅰ). 또한, 미생물을 기탁한 자로부터 미생물 분양에 대한 허락을 받은 자도 국내기탁기<br>관, 국제기탁기관, 지정기탁기관에 신청하여 해당 미생물을 분양받을 수 있다(令 4②).                                                                                                                                            |
|                           | 공지기술로<br>활용        | 제3자는 출원공개된 발명을 기술정보로서 이용하여 중복투자 및 중복연구를 방지할 수 있으며, 심사관은 출원<br>공개전 후출원에 대해서는 확대된 선출원의 지위(法 29③④)에 의해, 출원공개후 후출원에 대해서는 신규성(法<br>29①), 진보성(法 29②)에 의하여 후출원의 등록을 금지시킬 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 국제<br>특허<br>출원<br>의<br>특례 | 국제공개               | 원칙적으로 우선일로부터 1년 6개월 경과시 공개되나, 조기공개를 신청할 때에는 그 전에 공개가 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | 국내공개               | 1. 원칙 - 우선일로부터 국내서면제출기간인 2년 7개월 경과시 공개(국어출원의 경우 국제공개를 국내공개로 간주)<br>2. 예외 - ① 국제공개된 경우 심사청구일과 우선일로부터 1년 6개월 중 늦은 때 공개된다. ② 다만 이 경우에도 조기공개<br>신청하는 경우 출원번역문(단, 국어출원의 경우 제외) 제출한 후이면 국내서면제출기간 전에 공개가능하다.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           | 공개의<br>효과          | 1. 보상금청구권 인정여부 - 국내공개(국어로 출원된 국제특허출원인 경우 국제공개를 말한다)된 경우 인정(法 207③④).<br>2. 확대된 선출원 적용 - 국제공개 또는 국내공개에 의하여 확대된 선출원 적용(法 29⑤⑥, 202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### III 보상금청구권(法 65)

| 권 리          |               | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서            | 의의            | 특허출원인이 출원공개가 있는 후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록시까지의 기간동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있는 권리를 말한다(法 65①②).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 취지            | 공개된 발명에 대하여 제3자의 모방이나 도용에 의하여 출원인의 이익이 훼손되므로 그 상실된 이익을 보전하기 위해 보상금청구권 인정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 법적성질          | 1. 해제조건부 권리 - 출원계속 상태의 종료 또는 특허권의 소급 소멸시 소급하여 소멸<br>2. 채권적 권리 - 독점배타적 권리인 특허권과는 달리 출원발명을 무단실시한 경우 합리적 금액을 인정<br>3. 권리의 독립성 - 보상금청구권의 행사는 특허권의 행사와 별개                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 성립요건<br>(발생) |               | 1. 특허출원이 출원공개될 것<br>공개특허공보의 발행을 말하고(施規 43), 국제특허출원의 경우에는 국어에 의한 출원공개가 있어야 한다(法 207②).<br>2. 출원인이 서면으로 경고하거나 공개된 발명을 알고 있을 것<br>① 「경고」는 사실의 통지이며, 구체적으로 하여야 하고 추후 증명을 위해 통상적으로 내용증명우편으로 행한다. 「경고」는 출원공개후는 물론 출원공개전에도 할 수 있는데, 다만, 출원공개전 경고를 한 경우에는 출원공개된 때부터 보상금청구권이 발생한 것으로 해석된다.<br>② 보정에 의하여 청구범위가 확장 또는 변경된 경우에는 그 확장 또는 변경된 내용에 대하여 보상금 청구권을 행사하기 위해서는 다시 경고를 해야 하나 보정에 의하여 청구범위가 감축 또는 삭제된 경우에는 재경고를 할 필요가 없다.<br>③ 제3자가 공개된 사실을 알고 실시한 때는 경고하지 않아도 된다. 다만 이러한 악의의 증명은 출원인이 해야 하기 때문에 대개는 서면으로 경고를 하게 된다.<br>3. 정당한 권원없는 제3자가 업으로서 출원발명을 실시할 것 |
| 효 력          | 보상금액          | 제3자가 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다(法 65②).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 행사시기          | 특허출원된 발명에 대한 특허권이 설정등록된 후에만 행사할 수 있다(法 65③).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | 독립성           | 보상금청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 아니한다(法 65④).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 준용<br>(法 65⑤) | 1. 특허법상 준용<br>① 간접침해(法 127)<br>② 생산방법의 추정(法 129)<br>③ 자료의 제출(法 132)<br>2. 민법상 준용<br>① 민법상 공동불법행위책임(민법 760)<br>② 소멸시효(민법 766) - 설정등록 후 3년 이내에 행사가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 소 멸          | 원인<br>(法 65⑥) | 1. 특허권이 설정등록되지 아니한 경우 - ① 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 경우, ② 특허출원의 특허거절결정이 확정된 경우<br>2. 특허권이 소급하여 소멸한 경우 - ① 특허취소신청에 의한 특허취소결정이 확정된 경우, ② 심판에 의하여 무효로 한다는 심결(후발적 무효사유 제외)이 확정된 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 효과            | 보상금청구권 행사후 특허권 소급 소멸로 보상금청구권이 소멸한 경우<br>1. 특허권자에게 고의·과실이 있는 경우 - 손해배상청구 가능<br>2. 특허권자에게 고의·과실이 없는 경우 - 부당이득반환청구 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

The diagram illustrates the timeline of events related to a patent and the right to claim compensation. A horizontal timeline is shown with two parallel lines. The top line represents the patent process, with key events marked by yellow dots: 甲 (Application), A 출원 (Filing), 공개 (Disclosure), 경고/안배 (Warning/Arrangement), and 등록 (Registration). The bottom line represents the third party's actions, with a key event marked by a yellow dot: A 실시 (Implementation). A bracket labeled '3년' (3 years) spans from the registration date to the end of the timeline. Below the timeline, two horizontal arrows indicate the periods for the right to claim compensation: '보상금청구권 발생' (Occurrence of the right to claim compensation) starts from the disclosure date and ends at the registration date. '보상금청구권 행사' (Exercise of the right to claim compensation) starts from the registration date and continues until the end of the 3-year period. A third arrow labeled '특허권에 의한 조치' (Action by the patent right) starts from the registration date and continues until the end of the 3-year period.

|    |    |                                                |
|----|----|------------------------------------------------|
| 발생 | 39 | 특허료의 납부 등(法 79~86)                             |
|    | 40 | 설정등록 및 등록공고(法 87)                              |
| 효력 | 41 | 존속기간과 존속기간연장등록제도(法 88~93, 95)                  |
|    | 42 | 효력의 의의, 제한 및 확장(法 94~96, 127)                  |
|    | 43 | 특허발명의 보호범위(法 97)                               |
|    | 44 | 이용 및 저촉발명(法 98)                                |
|    | 45 | 특허권의 침해(法 97, 98, 126~132, 225, 230, 231)      |
|    | 46 | 벌칙(法 225~232)                                  |
| 변동 | 47 | 특허권의 이전 및 공유(法 99, 99의2)                       |
|    | 48 | 실시권 일반(法 100~102, 118)                         |
|    | 49 | 법정실시권(法 81의3⑤, 103~105, 122, 182, 183, 발진법 10) |
|    | 50 | 강제실시권(法 106의2~115, 138)                        |
|    | 51 | 특허법상 질권(法 121~123)                             |
| 소멸 | 52 | 특허권의 소멸(法 119, 120, 124)                       |
| 관련 | 53 | 실시보고 및 집행권원(法 125, 125의2)                      |

## I 법조문

## 제79조 【특허료】 法 67의2①

- ① (납부주체) 제87조제1항에 따른 특허권의 설정등록을 받으려는 자는 설정등록을 받으려는 날(이하 "설정등록일"이라 한다)부터 3년분의 특허료를 내야 하고, 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료를 해당 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 내야 한다.
- ② (포괄납부) 제1항에도 불구하고 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료는 그 납부연도 순서에 따라 수년분 또는 모든 연도분을 함께 낼 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항에 따른 특허료, 그 납부방법 및 납부기간, 그 밖에 필요한 사항은 총리령〔특허료 등의 징수규칙 제8조〕으로 정한다. 法 30③Ⅱ, 52①Ⅲ

[전문개정 2014.6.11.]

## 특허료 등의 징수규칙 제8조

## 제8조(납부방법 등)

- ① 이 규칙에 따른 특허료·등록료 및 수수료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 하여 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각 호에서 각각 정하는 바에 따른다. <개정 2005. 7. 1., 2006. 4. 27., 2006. 9. 29., 2006. 12. 30., 2014. 6. 30., 2016. 9. 1.>
1. 제6조제2호 내지 제5호·제9호 및 제10조제1항제10호의 경우에는 각종 증서·사본 또는 복사물을 수령하기 이전까지 납부하여야 한다.
  2. 제5항·제7항 내지 제9항의 경우에는 동 규정에 따른 기간 이내에 지식재산처장이 부여한 납부자번호로 납부하거나 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 한다.
  3. 삭제 <2006. 12. 30.>
  4. 「특허법」 제46조제3호, 「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 「특허법」 제46조제3호, 「디자인보호법」 제47조제3호 또는 「상표법」 제39조제2호·제176조의 규정에 해당하여 지식재산처장 또는 특허심판원장이 기간을 정하여 보정을 명한 때에 납부자번호를 부여한 경우에는 그 기간 이내에 그 납부자번호로 해당 수수료를 납부하여야 한다.
  5. 「특허법」 제199조 또는 「실용신안법」 제34조의 규정에 따라 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보는 국제출원(「특허법」 제214조 또는 「실용신안법」 제40조의 규정에 따른 국제출원을 포함한다)으로서 번역문을 제출하여야 하는 국제출원에 있어서는 그 번역문 제출시에 접수번호를 부여받아 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 한다.
- ② 제1항의 규정에 따른 특허료·등록료 및 수수료의 납부일이 공휴일(「노동절 제정에 관한 법률」에 따른 노동절 및 토요일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫번째 근무일까지 납부하여야 한다. <개정 2018. 4. 6.>
- ③ 이 규칙에 따른 가산료는 그 기본료와 합산하여 납부하여야 한다.
- ④ 심사청구료·재심사청구료·우선심사신청료는 심사청구·재심사청구·우선심사신청을 하는 자가 심사청구·재심사청구·우선심사신청 시 접수번호를 부여받아 그 다음 날까지 납부하여야 하되, 심사청구와 동시에 「특허법 시행규칙」 제40조의3 또는 「실용신안법 시행규칙」 제10조의3에 따른 특허출원심사 또는 실용신안등록출원심사의 유예를 신청한 경우에는 심사를 받으려는 시점으로부터 2개월 전까지 심사청구를 하였을 때의 심사청구료를 납부하여야 한다. 심사청구 후에 보정에 따라 심사청구료가 증가된 경우(새로운 청구범위의 항이 추가되어 그 항에 대한 심사청구료가 추가된 경우를 포함한다)에는 출원인이 보정서를 제출할 때 접수번호를 부여받아 그 다음 날까지 그 증가액을 납부하여야 한다. <개정 2006. 4. 27., 2009. 7. 1., 2010. 12. 30., 2016. 3. 25.>
- ⑤ 특허료·실용신안등록료 또는 디자인등록료는 최초 3년분을 특허결정, 등록결정 또는 등록심결의 등본을 받은 날부터 3개월 이내에 일시에 납부하여야 한다. 이 경우 특허증, 실용신안등록증 및 디자인등록증을 전자문서에 의해 발급하는 경우에는 2023년 12월 31일까지 각각 1만원(총액이 1만원 미만이면 그 금액)을 차감한 금액을 납부하여야 한다. <개정 2019. 7. 9.>
- ⑥ 제5항의 기간이 경과된 후에도 특허료·실용신안등록료 또는 디자인등록료는 그 기간이 경과된 날부터 6개월 이내에 납부할 수 있다. 이 경우 다음 각 호의 구분에 따른 금액을 해당 특허료·실용신안등록료 또는 디자인등록료에 가산하여 납부하여야 한다. <개정 2005. 7. 1., 2006. 9. 29., 2009. 7. 1., 2014. 2. 21.>
1. 1개월이 지나기 전: 100분의 3에 상당하는 금액
  2. 2개월이 지나기 전: 100분의 6에 상당하는 금액
  3. 3개월이 지나기 전: 100분의 9에 상당하는 금액

4. 4개월이 지나기 전: 100분의 12에 해당하는 금액
  5. 5개월이 지나기 전: 100분의 15에 해당하는 금액
  6. 6개월이 지나기 전: 100분의 18에 해당하는 금액
- ⑦ 상표권의 설정등록료, 지정상품 추가등록료 및 상표권의 존속기간갱신등록료는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 납부하여야 한다. 다만, 「상표법」 제74조에 따라 납부기간을 연장하려 할 때에는 그 납부기간 경과 전에 등록료납부기간의 연장신청을 하여야 한다. <개정 2010. 7. 27., 2016. 9. 1., 2018. 4. 6., 2019. 7. 9.>
1. 상표권의 설정등록료(「상표법」 제72조제1항 후단에 따라 분할납부하는 경우의 1회차 설정등록료를 포함한다)는 등록결정 또는 등록심결의 등본을 받은 날부터 2개월 이내에 납부하여야 하며, 「상표법」 제72조제1항 후단에 따라 분할납부하는 경우의 2회차 설정등록료(1회차 설정등록료 납부 후 「상표법」 제93조제1항 또는 제94조제1항에 따라 상표권을 분할이전하거나 분할한 경우에는 각 상표권의 2회차 설정등록료를 말한다)는 상표권의 설정등록일부터 5년 이내에 납부자번호를 부여받아 납부자번호를 부여받은 날의 다음날까지 납부하여야 한다. 이 경우 상표등록증을 전자문서에 의해 발급하는 경우에는 2023년 12월 31일까지 1만원(총액이 1만원 미만이면 그 금액)을 차감한 금액을 납부하여야 한다.
  2. 지정상품 추가등록료는 등록결정 또는 등록심결의 등본을 받은 날부터 2개월 이내에 납부하여야 한다.
  3. 상표권의 존속기간갱신등록료(「상표법」 제72조제1항 후단에 따라 분할납부하는 경우의 1회차 존속기간갱신등록료를 포함한다)는 「상표법」 제84조제2항에서 정하는 기간 내에 접수번호를 부여받아 접수번호를 부여받은 날의 다음날까지 납부하여야 하며, 「상표법」 제72조제1항 후단에 따라 분할납부하는 경우의 2회차 존속기간갱신등록료(1회차 존속기간갱신등록료 납부 후 「상표법」 제93조제1항 또는 제94조제1항에 따라 상표권을 분할이전하거나 분할한 경우에는 각 상표권의 2회차 존속기간갱신등록료를 말한다)는 상표권의 갱신등록일부터 5년 이내에 납부자번호를 부여받아 납부자번호를 부여받은 날의 다음날까지 납부하여야 한다.
- ⑧ 특허권자·실용신안권자·디자인권자(관련디자인권자를 포함한다. 이하 같다)는 4년차분부터의 특허료 또는 등록료를 해당권리의 설정등록일을 기준으로 하여 매년 1년분씩 그 전년도에 납부하여야 한다. 다만, 그 납부기간에 납부하지 아니한 경우에는 그 납부기간이 지난 날부터 다음 각 호의 구분에 따른 금액을 해당 특허료 또는 등록료에 가산하여 납부하여야 한다. <개정 2005. 7. 1., 2009. 7. 1., 2010. 12. 30., 2014. 2. 21., 2019. 7. 9.>
1. 1개월이 지나기 전: 100분의 3에 상당하는 금액
  2. 2개월이 지나기 전: 100분의 6에 상당하는 금액
  3. 3개월이 지나기 전: 100분의 9에 상당하는 금액
  4. 4개월이 지나기 전: 100분의 12에 해당하는 금액
  5. 5개월이 지나기 전: 100분의 15에 해당하는 금액
  6. 6개월이 지나기 전: 100분의 18에 해당하는 금액
- ⑨ 제5항부터 제8항까지의 규정에도 불구하고 「특허법」 제81조의2, 「실용신안법」 제20조에 따라 준용되는 「특허법」 제81조의2, 「디자인보호법」 제83조 및 「상표법」 제76조에 따라 특허료 또는 등록료의 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날부터 1개월 이내에 특허료 또는 등록료를 보전하여야 한다. 다만, 특허료 또는 등록료의 납부기간 또는 추가납부기간을 경과하여 보전하는 때에는 부족하게 납부된 금액의 100분의 3에 상당하는 금액을 가산하여 납부하여야 한다. <개정 2005. 3. 31., 2005. 7. 1., 2006. 9. 29., 2009. 7. 1., 2014. 2. 21., 2014. 6. 30., 2016. 9. 1.>
- ⑩ 「특허법」 제81조의3제3항, 「실용신안법」 제20조(「특허법」 제81조의3제3항을 준용하는 경우를 말한다) 또는 「디자인보호법」 제84조제3항에 따라 소멸한 특허권·실용신안권 또는 디자인권을 회복하려는 자는 제8항 단서 또는 제9항 본문의 규정에 따른 기간의 만료일부터 3월 이내에 특허료 또는 등록료를 납부하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 구분에 따른 금액을 납부하여야 한다. <신설 2005. 7. 1., 2006. 9. 29., 2014. 6. 30., 2016. 7. 29.>
1. 특허권 회복의 경우: 제2조제2항제1호에 따른 특허료의 2배에 상당하는 금액
  2. 실용신안권 회복의 경우: 제3조제2항제1호에 따른 실용신안등록료의 2배에 상당하는 금액
  3. 디자인권 회복의 경우: 제4조제2항제1호에 따른 디자인등록료의 2배에 상당하는 금액
- ⑪ 제8항 본문에도 불구하고 특허권자·실용신안권자·디자인권자는 4년차분부터의 특허료 또는 등록료를 그 납부연차 순위에 따라 여러 연차분 또는 모든 연차분을 일괄하여 납부할 수 있으며, 제8항 본문에 따른 납부기간이 경과하지 않은 4년차분 이후부터의 특허료 또는 등록료를 3년분 이상 일괄하여 납부하는 경우에는 별표 1부터 별표 3까지에 따라 납부하여야 할 특허료 또는 등록료 총액에서 그 총액의 100분의 10에 해당하는 금액을 차감한 금액을 납부할 금액으로 한다. 이 경우 일괄납부 후에 특허료 또는 등록료의 금액이 변경되었을 때에는 변경된 특허료 또는 등록료를 납부한 것으로 본다. <개정 2010. 12. 30., 2019. 7. 9., 2019. 12. 31.>
- ⑫ 특허료·등록료·수수료 및 「지방세법」 제28조제1항제11호와 같은 항 제12호에 따른 등록면허세(「지방세법」 제151조제1항에 따른 지방교육세를 포함한다. 이하 같다) 또는 「인지세법」 제8조의4에 따른 인지세를 납부하는 자는 인터넷으로 등 정보통신망을 이용한 전자적 수단으로 납부하거나 별지 제1호의2 서식에 기재사항을 적어 현금으로 납부하여야 한다. 이 경우 지식재산처장은 정보통신망을 이용한 전자적 수단으로 납부한 자에 대하여는 별지 제2호서식의 납입영수증을 발급할 수 있다. <개정 2009. 7. 1., 2019. 7. 9.>
- ⑬ 제12항에 따라 전자적 수단을 이용하여 납부하려는 자가 정보통신망의 장애, 지식재산처가 사용하는 컴퓨터 또는 관련 장치의 장애(정보통신망, 지식재산처가 사용하는 컴퓨터 또는 관련 장치의 유지·보수를 위하여 그 사용을 일시 중단한 경우로서 지식재산처장이 사전에 공지한 경우는 제외한다)로 인하여 기한 내에 납부할 수 없는 경우에는 그 장애가 제거된 날의 다음 날에 그 기한이 도래한 것으로 본다. <신설 2017. 2. 28.>
- ⑭ 우편으로 특허료·등록료·수수료 및 등록면허세 또는 인지세를 납부하여야 하는 서류를 제출하는 경우에는 통상환을 동봉하여 제출하여야 한다. <개정 2009. 7. 1., 2017. 2. 28., 2019. 7. 9.>
- ⑮ 접수번호를 부여받은 날의 다음 날이 경과하여 납부한 특허료·등록료 및 수수료는 이를 반환한다. <개정 2017. 2. 28.>



- ①⑥ 제12항에도 불구하고 특허료·등록료 또는 수수료를 자동납부하려는 경우 또는 자동납부를 취하하려는 경우에는 별지 제4호 서식의 수수료 자동납부신청(취하)서를 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 다만, 제10조제1항제4호다목·라목 및 제6호부터 제9호까지의 규정에 따른 수수료를 자동납부하려는 재외자는 신청서의 제출을 생략할 수 있다. <신설 2009. 7. 1., 2017. 2. 28.>
- ①⑦ 등록면허세는 인지세 및 수수료 또는 등록료와 일괄하여 납부하여야 한다. <신설 2009. 7. 1., 2014. 2. 21., 2017. 2. 28., 2019. 7. 9.>
- ①⑧ 제17항에 따라 등록면허세를 인지세 및 수수료와 일괄하여 납부한 때에는 인지세, 등록면허세, 수수료의 순서로 총당하고, 등록면허세를 등록료와 함께 일괄하여 납부한 때에는 등록면허세, 등록료의 순서로 총당한다. <신설 2009. 7. 1., 2017. 2. 28., 2019. 7. 9.>
- ①⑨ 지식재산처장은 등록면허세 또는 인지세를 잘못 납부받은 때에는 이를 납부한 자에게 통지하여야 하며, 납부한 자의 청구에 따라 잘못 납부 받은 등록면허세 또는 인지세를 반환한다. <신설 2009. 7. 1., 2017. 2. 28., 2019. 7. 9.>

#### 제80조 【이해관계인에 의한 특허료의 납부】

- ① **【이해관계인의 대납】** 이해관계인은 특허료를 내야 할 자의 의사와 관계없이 특허료를 낼 수 있다.
- ② **【비용상환청구】** 이해관계인은 제1항에 따라 특허료를 낸 경우에는 내야 할 자가 현재 이익을 얻는 한도에서 그 비용의 상환을 청구할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제81조 【특허료의 추가납부 등】

- ① **【추가납기간】** 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자는 제79조제3항에 따른 납부기간이 지난 후에도 6개월 이내(이하 "추가납부기간"이라 한다)에 특허료를 추가로 낼 수 있다.
- ② **【추가금액】** 제1항에 따라 특허료를 추가로 낼 때에는 내야 할 특허료의 2배의 범위에서 총리령[**특허료 등의 징수규칙 제8조**]으로 정하는 금액을 납부하여야 한다.
- ③ **【불납의 효과】** 추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 제81조의2제2항에 따른 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허출원 은 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 제79조제1항 또는 제2항에 따라 낸 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제81조의2 【특허료의 보전】

- ① **【보전명령】** 지식재산처장은 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 제79조제3항 또는 제81조제1항에 따른 기간에 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에는 특허료의 보전(補填)을 명하여야 한다.
- ② **【보전기간】** 제1항에 따라 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날부터 1개월 이내(이하 "보전기간"이라 한다)에 특허료를 보전할 수 있다.
- ③ **【보전금액】** 제2항에 따라 특허료를 보전하는 자는 내지 아니한 금액의 2배의 범위에서 총리령[**특허료 등의 징수규칙 제8조**]으로 정한 금액을 내야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제81조의3 【특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원과 특허권의 회복 등】(★★)

- ① **【회복요건: 등록료, 유지료】** 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 정당한 사유로 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 그 특허료를 내거나 보전할 수 있다. 다만, 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.>
- ② **【회복효과】** 제1항에 따라 특허료를 내거나 보전한 자는 제81조제3항에도 불구하고 그 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.
- ③ **【회복요건2: 유지료】** 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허발명의 특허권이 소멸한 경우 그 특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일로부터 3개월 이내에 제79조에 따른 특허료의 2배를 내고, 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다. **【회복효과】** 이 경우 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.
- ④ **【효력제한】** 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원 또는 특허권의 효력은 추가납부기간 또는 보전기간이 지난 날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간(이하 이 조에서 "효력제한기간"이라 한다) 중에 타인이 특허출원된 발명 또는 특허발명을 실시한 행위에 대해서는 그 효력이 미치지 아니한다.
- ⑤ **【법정실시권의 발생】** 효력제한기간 중 국내에서 선의로 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원된 발명 또는 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명 또는 특허발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다. **法 118②③**
- ⑥ **【법정실시권의 대가】** 제5항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.
- ⑦ 제1항 본문에 따른 납부나 보전 또는 제3항 전단에 따른 신청에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

[시행일:2014.6.11.] 제81조의3제3항

[시행일:2015.1.1.] 제81조의3

## 제82조 【수수료】(★) 法 46

- ① (납부주체) 특허에 관한 절차를 밟는 자는 수수료를 내야 한다.
- ② (제3자의 심사청구 후 증가된 청구항) 특허출원인이 아닌 자가 출원심사의 청구를 한 후 그 특허출원서에 첨부한 명세서를 보정하여 청구범위에 적은 청구항의 수가 증가한 경우에는 그 증가한 청구항에 관하여 내야 할 심사청구료는 특허출원인이 내야 한다.
- ③ 제1항에 따른 수수료, 그 납부방법 및 납부기간, 그 밖에 필요한 사항은 총리령[특허료 등의 징수규칙 제8조]으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

## 제83조 【특허료 또는 수수료의 감면】

- ① (면제대상) 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허료 및 수수료는 제79조 및 제82조에도 불구하고 면제한다.
  1. 국가에 속하는 특허출원 또는 특허권에 관한 수수료 또는 특허료
  2. 제133조제1항, 제134조제1항·제2항 또는 제137조제1항에 따른 심사관의 무효심판청구에 대한 수수료
- ② (감면대상) 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 한 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 제79조 및 제82조에도 불구하고 총리령[특허료 등의 징수규칙 제7조, 제13조]으로 정하는 특허료 및 수수료를 감면할 수 있다. <개정 2016. 3. 29., 2021. 8. 17.>
  1. 「국민기초생활 보장법」에 따른 의료급여 수급자
  2. 「재난 및 안전관리 기본법」 제36조에 따른 재난사태 또는 같은 법 제60조에 따른 특별재난지역으로 선포된 지역에 거주하거나 주된 사무소를 두고 있는 자 중 총리령으로 정하는 요건을 갖춘 자
  3. 그 밖에 총리령으로 정하는 자

### 특허료 등의 징수규칙 제7조, 제13조

#### 특허료 등의 징수규칙 제7조(특허료, 등록료 및 수수료의 감면)

- ① 특허료, 등록료 및 수수료의 감면에 관한 사항은 다음 각 호의 구분에 따른다. <개정 2022. 2. 18.>

1. 특허료, 등록료 및 수수료의 면제: 별표 4
2. 특허료, 등록료 및 수수료의 감정: 별표 5
3. 특허료, 등록료 및 수수료의 한시적 감면: 별표 6

- ② 삭제 <2022. 2. 18.>

- ③ 삭제 <2022. 2. 18.>

- ④ 삭제 <2022. 2. 18.>

- ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 공동으로 출원하여 「특허법」제83조제1항제1호(「실용신안법」제20조에 따라 준용되는 경우를 포함한다) 또는 「디자인보호법」제86조제1항제1호 및 이 규칙 제7조제1항 각 호 또는 제13조제2항에 따른 감면을 받으려는 경우(공동으로 출원하는 자가 모두 해당 특허료, 등록료 또는 수수료의 감면 대상인 경우만 해당한다)에 감면율(제7조제1항 각 호에 따라 특허료, 등록료 및 수수료가 면제되는 경우 감면율을 100분의 100으로 한다)이 서로 다르면 각각의 감면율을 더하여 감면대상자수로 나누어 구한 평균감면율을 적용하여 감면한다. 이 경우 소숫점 이하는 올림한다. <신설 2014. 2. 21., 2015. 7. 29., 2019. 7. 9., 2022. 2. 18.>

1. 삭제 <2022. 2. 18.>

2. 별표 4부터 별표 7까지의 경우 중 어느 하나에 해당하는 자

3. 「특허법」 제83조제1항제1호에 따른 국가에 속하는 특허출원을 한 자, 「실용신안법」 제20조에 따라 준용되는 「특허법」 제83조제1항제1호에 따른 국가에 속하는 실용신안등록출원을 한 자 또는 「디자인보호법」 제86조제1항제1호에 따른 국가에 속하는 디자인등록출원을 한 자

- ⑥ 제1항 각 호 또는 제13조제2항에 따른 감면을 받으려는 자는 출원시의 출원서, 「특허법」 제203조의 서면, 심사청구서의 심사청구서, 심판청구서의 심판청구서 또는 권리설정등록 시와 4년차 분부터의 특허료 또는 등록료 납부 시의 특허(등록)료납부서 등에 감면의 사유와 그 대상 등을 적고, 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 첨부하여 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 다만, 제1항제2호·제3호 또는 제2항제1호부터 제5호까지의 규정에 해당하는 자로서 감면대상에 해당함을 증명하는 서류를 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 이미 제출한 경우에는 그 서류의 첨부를 생략할 수 있다.

<개정 2008. 12. 31., 2011. 12. 2., 2014. 2. 21., 2014. 12. 31., 2015. 7. 29., 2022. 2. 18.>

1. 별표 4 제1호부터 제8호까지 및 제12호에 해당하는 자의 경우에는 그 자격을 증명하는 서류 1통

2. 별표 4 제9호에 해당하는 자의 경우에는 재학증명서 1통

- 2의2. 별표 4 제11호에 해당하는 자의 경우에는 복무증명서 1통

3. 별표 5부터 별표 7까지의 각 호에 해당하는 자의 경우에는 그 사실을 증명하는 서류 1통

- ⑦ 제6항에 따라 첨부하여야 하는 서류 중 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당공무원이 확인하도록 지식재산처장이 정하여 고시하는 서류는 이를 첨부하지 아니할 수 있다. 다만, 신청인이 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 해당 서류를 첨부하도록 하여야 한다. <개정 2010. 7. 27., 2010. 12. 30., 2014. 2. 21.>



- ⑧ 제6항에 따른 감면사유와 그 대상 등을 적지 아니하거나 이를 증명하는 서류를 첨부하지 아니한 이유 등으로 제1항 각 호 및 제13조제2항에 따른 감면을 받지 못하고 납부한 자가 감면분을 반환받으려는 경우에는 출원·심사청구·권리설정등록·권리범위확인심판청구 및 권리관계변경신고 등을 할 당시에 감면대상이었음을 증명하는 서류와 별지 제3호 서식의 수수료 사후 감면 신청서를 그 반환의 대상이 되는 출원료, 심사청구료, 특허료·실용신안등록료·디자인등록료, 심판청구료, 이전등록료 또는 출원인변경신고료 등을 납부한 날부터 5년 이내에 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 이 경우 신청서를 제출받은 지식재산처장 또는 특허심판원장은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 신청인의 입금계좌정보를 확인해야 하며, 신청인이 확인에 동의하지 않는 경우에는 통장의 사본을 첨부하도록 해야 한다. <개정 2009. 7. 1., 2014. 2. 21., 2017. 2. 28., 2019. 12. 31., 2022. 2. 18.>

[전문개정 2007. 12. 21.]

[제목개정 2022. 2. 18.]

#### 제13조(재난 등 발생시 수수료 등의 감면에 관한 특례)

- ① 지식재산처장은 「특허법」 제83조제2항제2호 및 「디자인보호법」 제86조제2항제2호에 따라 「재난 및 안전관리 기본법」 제36조에 따른 재난사태 또는 같은 법 제60조에 따른 특별재난지역으로 선포된 지역에 거주하거나 주된 사무소를 두고 있는 자에 대하여 특허료, 등록료 및 수수료를 감면할 수 있다. <개정 2022. 2. 18.>
- ② 제1항에 따른 특허료, 등록료 및 수수료의 감면은 별표 7과 같다. <개정 2022. 2. 18.>

[본조신설 2021. 2. 15.]

- ③ 제2항에 따라 특허료 및 수수료를 감면받으려는 자는 총리령으로 정하는 서류를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

- ④ **(부정감면의 제재)** 지식재산처장은 제2항에 따른 특허료 및 수수료 감면을 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 받은 자에 대하여는 총리령으로 정하는 바에 따라 감면받은 특허료 및 수수료의 2배액을 징수할 수 있다. 이 경우 그 출원인 또는 특허권자가 하는 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 총리령으로 정하는 기간 동안 제2항을 적용하지 아니한다. <신설 2021. 8. 17.>

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제84조 【특허료 등의 반환】

- ① **(반환대상)** 납부된 특허료 및 수수료는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 납부한 자의 청구에 의하여 반환한다.  
<개정 2015. 5. 18., 2016. 2. 29., 2016. 3. 29., 2021. 8. 17., 2021. 10. 19.>

1. 잘못 납부된 특허료 및 수수료

2. 제132조의13제1항에 따른 특허취소결정이나 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분

3. 특허권의 존속기간의 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분

4. 특허출원(분할출원, 분리출원, 변경출원 및 제61조에 따른 우선심사의 신청을 한 특허출원은 제외한다) 후 1개월 이내에 그 특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 낸 수수료 중 특허출원료 및 특허출원의 우선권 주장 신청료

5. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목 중 어느 하나가 있기 전까지 특허출원을 취하(제53조제4항 또는 제56조제1항 본문에 따라 취하된 것으로 보는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료

- 가. 제36조제6항에 따른 협의의 결과 신고 명령(동일인에 의한 특허출원에 한정한다)

나. 삭제 <2021. 8. 17.>

다. 제63조에 따른 거절이유통지

라. 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달

- 5의2. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간 내에 특허출원을 취하하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액

가. 제5호가목에 따른 신고 명령 후 신고기간 만료 전까지

나. 제5호다목에 따른 거절이유통지(제47조제1항제1호에 해당하는 경우로 한정한다) 후 의견서 제출기간 만료 전까지

6. 특허권을 포기한 해의 다음 해부터의 특허료 해당분

7. 제176조제1항에 따라 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정이 취소된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함하되, 심판 또는 재심 중 제170조제1항에 따라 준용되는 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 보정이 있는 경우는 제외한다)에 이미 낸 수수료 중 심판청구료(재심의 경우에는 재심청구료를 말한다. 이하 이 조에서 같다)

8. 심판청구가 제141조제2항에 따라 결정으로 각하되고 그 결정이 확정된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액

9. 심리의 종결을 통지받기 전까지 제155조제1항에 따른 참가신청을 취하한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액

10. 제155조제1항에 따른 참가신청이 결정으로 거부된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액

11. 심리의 종결을 통지받기 전까지 심판청구를 취하한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액

② **(반환통지)** 지식재산처장 또는 심판원장은 납부된 특허료 및 수수료가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사실을 납부한 자에게 통지하여야 한다. <개정 2016.3.29>

③ **(반환절차)** 제1항에 따른 특허료 및 수수료의 반환청구는 제2항에 따른 통지를 받은 날부터 5년이 지나면 할 수 없다.

<개정 2022. 10. 18.>

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제85조 【특허원부】

① 지식재산처장은 지식재산처에 특허원부를 갖추어 두고 다음 각 호의 사항을 등록한다.

1. 특허권의 설정·이전·소멸·회복·처분의 제한 또는 존속기간의 연장
2. 전용실시권 또는 통상실시권의 설정·보존·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한
3. 특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한

② 제1항에 따른 특허원부는 그 전부 또는 일부를 전자적 기록매체 등으로 작성할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 등록사항 및 등록절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

④ 특허발명의 명세서 및 도면, 그 밖에 대통령령으로 정하는 서류는 특허원부의 일부로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제86조 【특허증의 발급】

① 지식재산처장은 특허권의 설정등록을 한 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 특허권자에게 특허증을 발급하여야 한다.

② 지식재산처장은 특허증이 특허원부나 그 밖의 서류와 맞지 아니하면 신청에 따라 또는 직권으로 특허증을 회수하여 정정 발급하거나 새로운 특허증을 발급하여야 한다.

③ 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 결정, 심결 또는 이전등록에 따른 새로운 특허증을 발급하여야 한다. <개정 2016.2.29>

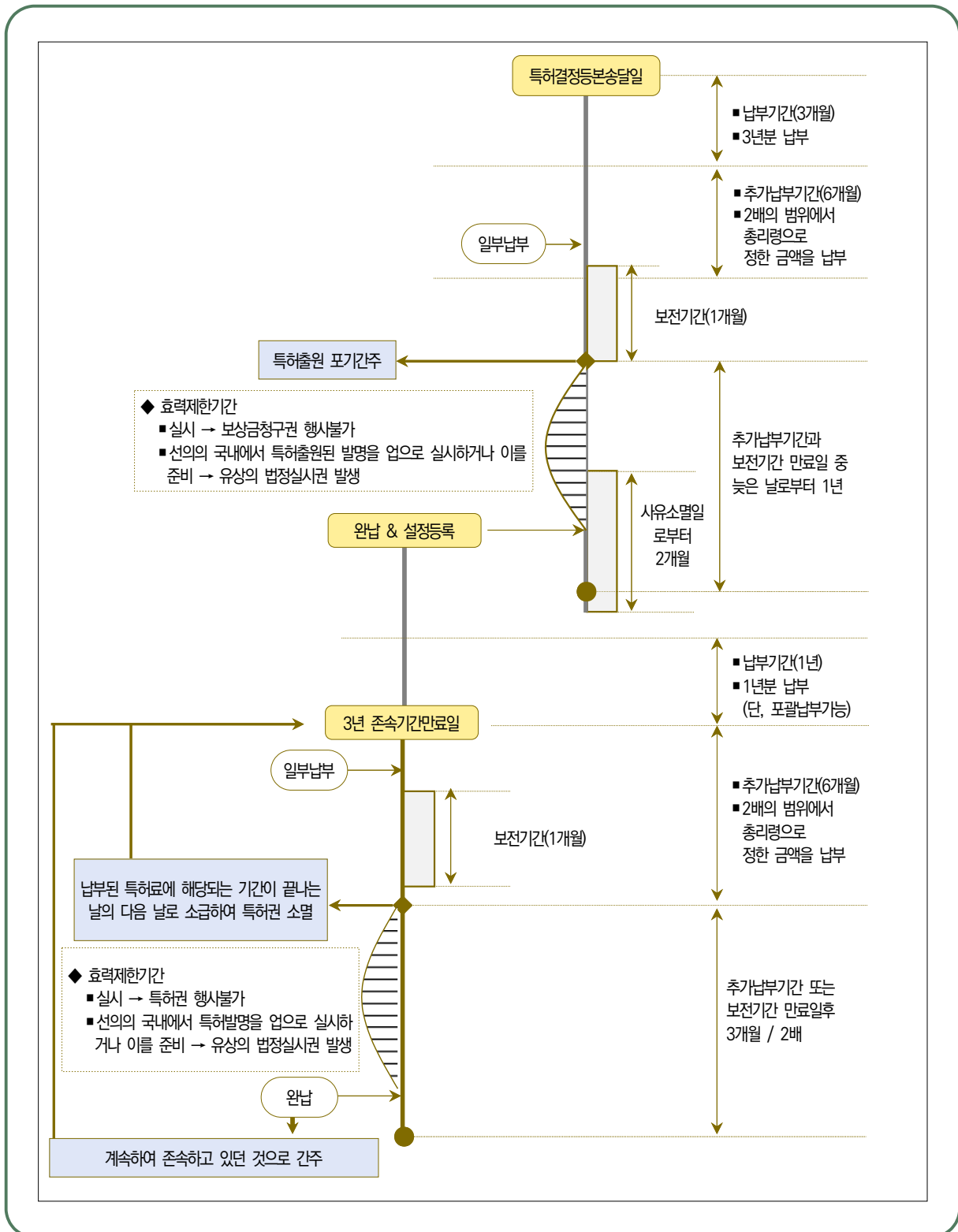
1. 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 인정한다는 취지의 결정 또는 심결이 확정된 경우
2. 제99조의2제2항에 따라 특허권이 이전등록된 경우

[전문개정 2014.6.11.]

## II 특허료(法 79~81의3)

| 구 분 |        | 내 용                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서   | 의의     | 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 국가에 내야 하는 금액(法 79①).                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 성질     | ① 행정상 수수료라는 수수료설, ② 재산에 대한 징수라는 조세설, ③ 특허권의 대가라는 특허료설 등이 있으나 특허료 불납시 보정명령을 하지 아니하기 때문에 수수료는 타당하지 않으며, 나머지 학설의 종합적인 성질을 가진다고 볼 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 요 건 | 납부 주체  | 납부의무자                                                                                                                               | 특허권의 설정등록을 받으려는 자(설정등록료 납부) 또는 특허권자(유지료 납부)                                                                                                                                                                                                     |
|     |        | 이해관계인 대납                                                                                                                            | 1. 이해관계인은 내야 할 자의 의사에 관계없이 특허료 대납가능(法 80①),<br>2. 의사에 반해 낸 경우 내야 할 자가 현재 이익을 받은 한도에서 그 비용의 상환을 청구(法 80②)(단, 특허권자의 의사에 의하여 낸 경우 낸 비용 모두 청구가능).                                                                                                   |
|     | 납부 대상  | 설정등록료                                                                                                                               | 특허결정 받은 특허출원에 포함된 청구항 전체를 대상으로 하나, 설정등록료 납부할 때 청구항별로 포기할 수 있다(法 215의2).                                                                                                                                                                         |
|     |        | 유지료                                                                                                                                 | 청구항 수별로 납부해야 하나, 특허권을 청구항별로 포기할 수 있다(法 215의2).                                                                                                                                                                                                  |
|     | 납부 시기  | 납부 기간                                                                                                                               | 설정 등록료<br>특허결정 또는 특허할 것이라는 등록심결의 등본을 받은 날로부터 3개월 이내에 최초 3년분의 특허료를 일시에 내야 한다(徵收規則 8⑤).                                                                                                                                                           |
|     |        |                                                                                                                                     | 유지료<br>해당 특허권 설정등록일을 기준으로 매년 1년분씩 전년도에 내야 한다. 다만 일괄하여 납부할 수 있으며 일괄납부후 특허료의 금액이 변경된 경우 변경된 특허료를 낸 것으로 본다(徵收規則 8⑧⑩).                                                                                                                              |
|     |        | 추가납부 기간                                                                                                                             | 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자는 특허료 납부기간(法 79②)이 경과한 후에도 6개월 이내에 특허료를 추가납부할 수 있다. 다만, 특허료를 추가납부할 때에는 내야 할 특허료의 2배의 범위에서 총리령으로 정하는 금액을 납부하여야 한다(法 81①②).                                                                                              |
|     |        | 보전기간                                                                                                                                | 1. 지식재산처장은 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 납부기간(法 79②) 또는 추가납부기간(法 81①)의 기간에 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에 특허료의 보전을 명하여야 하며, 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날로부터 1개월 이내에 특허료를 보전할 수 있다(法 81의2①②).<br>2. 특허료를 보전하는 자는 내지 아니한 금액의 2배의 범위에서 총리령으로 정하는 금액을 내야 한다(法 81의2③). |
|     | 불납의 효과 |                                                                                                                                     | 추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허출원은 이를 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 낸 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다(法 81③).                                                     |
| 회 복 | 요건     | 정당한 사유                                                                                                                              | 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 정당한 사유로 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하면 i) 그 사유가 소멸한 날로부터 2개월 및 ii) 추가납부기간의 만료일과 보전기간의 만료일 중 늦은 날로부터 1년 이내에 그 특허료를 내거나 보전할 수 있다(法 81의3①).                                                                     |
|     |        | 부지 등의 사유                                                                                                                            | 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허발명의 특허권이 소멸한 경우 그 특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일로부터 3개월 이내에 법 제 79조에 따른 특허료의 2배를 내고 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다(法 81의3③).                                                                                         |
|     | 효과     | 권리 회복                                                                                                                               | 특허료를 내거나 보전한 자는 그 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다(法 81의3②③). 그 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 보는 경우 지식재산처장은 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하며, 설정등록에 의하여 특허권이 발생한다(法 87①②).                                                                         |
|     |        | 효력 제한                                                                                                                               | 회복된 특허출원 또는 특허권의 효력은 특허료 추가납부기간 또는 보전기간이 지난 날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간(이하 “효력제한기간”이라 한다) 중에 타인이 특허출원된 발명 또는 특허발명을 실시한 행위에 대해서는 그 효력이 미치지 아니한다(法 81의3④).                                                                                           |
|     |        | 법정실시권 발생                                                                                                                            | 효력제한기간 중 국내에서 선의로 특허출원된 발명 또는 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명 또는 특허발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 81의3⑤⑥).                                          |

### III 특허료 납부 절차



#### Ⅳ 등록의 효력

| 권 리              |          | 특허권                    | 전용실시권                  | 통상실시권           |
|------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 등<br>록<br>사<br>항 | 설정       | ○                      | ○                      | ○<br>(법정실시권 제외) |
|                  | 이전       | ○<br>(상속 그 밖의 일반승계 제외) | ○<br>(상속 그 밖의 일반승계 제외) | ○               |
|                  | 변경       | -<br>(∴ 전면적 지배성)       | ○<br>(∴ 일면적 지배성)       | ○               |
|                  | 소멸       | ○<br>(포기에 한함)          | ○<br>(혼동 제외)           | ○               |
|                  | 처분<br>제한 | ○                      | ○                      | ○               |
| 효 력              |          | 효력발생요건                 |                        | 대항요건            |

# 40

## 설정등록 및 등록공고(法 87)

### I 법조문

#### 제87조 【특허권의 설정등록 및 등록공고】(★)

- ① (특허권의 발생) 특허권은 설정등록에 의하여 발생한다. **法 101① I / 216**
- ② (설정등록) 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다.
  1. 제79조제1항에 따라 특허료를 냈을 때
  2. 제81조제1항에 따라 특허료를 추가로 냈을 때
  3. 제81조의2제2항에 따라 특허료를 보전하였을 때
  4. 제81조의3제1항에 따라 특허료를 내거나 보전하였을 때
  5. 제83조제1항제1호 및 같은 조 제2항에 따라 그 특허료가 면제되었을 때
- ③ (등록공고: 일반) 지식재산처장은 제2항에 따라 등록한 경우에는 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다. <개정 2016.2.29.> **法 64②Ⅲ**
  1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다)
  2. 특허출원번호 및 출원연월일
  3. 발명자의 성명 및 주소
  4. 특허출원서에 첨부된 요약서
  5. 특허번호 및 설정등록연월일
  6. 등록공고연월일
  7. 제63조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 통지한 거절이유에 선행기술에 관한 정보(선행기술이 적혀 있는 간행물의 명칭과 그 밖에 선행기술에 관한 정보의 소재지를 말한다)가 포함된 경우 그 정보 **法 63의3, 132의2②**
  8. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항
- ④ (등록공고: 예외) 비밀취급이 필요한 특허발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 그 특허의 등록공고를 보류하여야 하며, 그 발명의 비밀취급이 해제된 경우에는 지체 없이 제3항에 따라 등록공고를 하여야 한다.
- ⑤ 삭제 <2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

## II 설정등록 및 등록공고(法 87)

| 구 분              |    | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서                |    | 특허권은 설정등록에 의하여 발생한다. 지식재산처장은 특허료를 내거나 특허료가 면제된 경우 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하며 등록한 경우에는 일정 사항을 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다(法 87)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | 의의 | 지식재산처장이 특허출원에 대한 심사관의 특허결정 후에 특허권이 발생하였음을 직권으로 특허원부에 기재하는 절차를 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 설<br>정<br>登<br>록 | 요건 | 1. 특허결정<br>2. 특허료 납부 및 면제                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | 절차 | 지식재산처장은 특허료의 납부 또는 면제시에는 직권으로 지식재산처에 비치된 특허원부에 특허권의 설정등록                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | 효과 | 1. 특허권의 발생<br>독점배타권인 특허권은 설정등록에 의하여 발생한다(法 87①). 그러므로 특허권의 설정등록이 있으면 특허출원인은 특허권자가 되고 출원발명은 특허발명(法 2Ⅱ)이 된다.<br>2. 보상금청구권의 행사<br>특허권자는 특허권이 설정등록된 후에는 출원중인 발명을 업으로 실시한 제3자에 대하여 특허권과는 별개로 보상금청구권을 행사할 수 있다(法 65③④). 다만, 등록 후 3년을 지난 후에는 보상금청구권을 행사할 수 없다(法 65⑤).<br>3. 등록의 추정적 효력<br>특허권의 설정등록은 공시의 효과만 있을 뿐 공신력이 있는 것은 아니다. 이것은 거래의 안전보다는 진정한 권리자를 보호하기 위함이다.<br>4. 공지기술로서의 이용<br>설정등록된 후에는 신청에 의하여 서류를 열람할 수 있다(法 216①). 그 결과 제3자는 공개된 발명을 기술정보로써 이용하여 중복투자 및 중복연구를 방지할 수 있으며, 심사관은 후출원 발명에 대하여 신규성(法 29①각호), 진보성(法 29②) 등의 거절이유의 인용대상으로 활용할 수 있다.<br>5. 특허증의 발급<br>지식재산처장은 특허권의 설정등록을 한 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 특허권자에게 특허증을 발급하여야 한다. 지식재산처장은 특허증이 특허원부나 그 밖의 서류와 맞지 아니하면 신청에 따라 또는 직권으로 특허증을 회수하여 정정발급하거나 새로운 특허증을 발급하여야 하고, 정정을 인정한다는 취지의 결정 또는 심결이 확정된 경우나 특허권이 이전등록(法 99의2②)된 경우에는 그 결정, 심결 또는 이전등록에 따른 새로운 특허증을 발급하여야 한다(法 86). 특허증의 이전이나 분실 여부가 특허권에 영향을 미치는 것은 아니다.<br>6. 기탁된 미생물의 분양<br>기탁된 미생물에 관계되는 발명을 시험 또는 연구를 위하여 실시하려는 자는 i) 그 미생물에 관계되는 발명에 대한 특허출원이 공개되거나 설정등록된 경우 또는 ii) 제63조제1항(제170조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 의견서를 작성하기 위하여 필요한 경우 총리령으로 정하는 바에 따라 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관으로부터 그 미생물을 분양받을 수 있다(令 4①). 한편 미생물을 기탁한 자로부터 미생물 분양에 대한 허락을 받은 자도 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에 신청하여 해당 미생물을 분양받을 수 있다(令 4②). |
| 登<br>록<br>공<br>고 | 의의 | 특허권이 발생하였을 때 발명의 내용을 일반에게 공표하여 침해하지 않도록 유도함으로써 특허분쟁을 미리 방지하기 위한 절차를 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | 요건 | 지식재산처장은 특허권 설정등록이 있으면 그 특허에 관하여 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다. 다만 지식재산처장은 국방상 필요한 발명으로서 비밀취급이 필요한 특허발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 그 특허의 등록공고를 보류하여야 하며, 그 발명의 비밀취급이 해제된 경우에는 지체 없이 등록공고를 하여야 한다(法 87③④).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | 절차 | 등록특허공보의 발행, CD-ROM으로 발행가능(令 19②).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | 효과 | 1. 특허취소사유의 제한<br>특허공보에 게재된 제87조제3항제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다(法 132의2②). 심판관 합의체는 특허취소신청이 이를 이유로 한 것으로 인정되는 경우에는 결정으로 그 특허취소신청을 기각하여야 한다(法 132의13④).<br>2. 확대된 선출원의 적용<br>특허출원이 출원공개되지 않고 설정등록되어 등록공고된 경우 특허출원일의 다음 날부터 등록공고 전 다른 특허(실용신안등록)출원에 대하여 확대된 선출원이 적용된다(法 29③④).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



### III 출원공개제도와 등록공고제도의 비교

| 제 도 |       | 출원공개제도                                                                                                                                   | 등록공고제도                                                                                                                                        |                                   |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 서   | 의 의   | 특허출원된 내용에 대하여 심사청구의 유무에 관계없이 일정기간이 지나면 그 출원내용을 공보에 게재하여 사회일반에 공표하는 것을 말한다.                                                               | 특허권이 발생하였을 때 발명의 내용을 일반에게 공표하는 제도를 말한다.                                                                                                       |                                   |
|     | 취 지   | ■출원인 → 보상금청구권 발생<br>■제3자 → 중복투자 및 중복연구 방지<br>■지식재산처 → 심사청구제도를 효율적 운영                                                                     | 특허권을 침해하지 않도록 유도하여 특허분쟁을 미연에 방지                                                                                                               |                                   |
| 요 건 | 주체적   | 지식재산처장에 의한 강제공개, 단신청에 의한 조기공개 가능                                                                                                         | 출원인의 신청 유무와 관계없이 지식재산처장이 등록공고                                                                                                                 |                                   |
|     | 객 체 적 | 원칙                                                                                                                                       | 지식재산처에 출원계속 중인 모든 특허출원                                                                                                                        | 출원인의 특허료 납부 등에 의하여 특허권 설정등록이 된 발명 |
|     |       | 예외                                                                                                                                       | ■명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우<br>■외국어특허출원인데 국어번역문을 제출하지 아니한 경우<br>■등록공고를 한 특허의 경우<br>■국방상 필요한 발명으로서 비밀취급이 필요한 경우<br>■공서양속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 경우 | 국방상 필요한 발명으로서 비밀취급이 필요한 경우        |
|     | 시 기 적 | 원칙                                                                                                                                       | ■일반 출원일로부터 1년 6개월이 지난 후<br>■조기공개 1년 6개월이 지나기 전이라도 가능                                                                                          | 특허권의 설정등록이 있는 경우                  |
|     |       | 예외                                                                                                                                       | ■정당한 권리자 출원(法 34, 35) → 무권리자 출원일<br>■분할출원·분리출원·변경출원(法 52②·52의2②·53②) → 원출원일<br>■조약·국내우선권주장출원(法 54①·55③) → 최우선일                                |                                   |
| 절 차 |       | 공개특허공보에 전문공개, CD-ROM 배포                                                                                                                  | 등록특허공보에 전문공개, CD-ROM 배포                                                                                                                       |                                   |
| 효 과 |       | ■보상금청구권의 발생(法 65)<br>■우선심사(法 61 I)<br>■특허출원에 관한 서류의 열람 등의 신청(法 216)<br>■기탁된 미생물의 분양(令 4①)<br>■공지기술로서 이용(法 29①각호·29②)<br>■확대된 선출원(法 29③④) | ■특허공보에 게재된 선행기술을 기초로 한 이유로는 특허취소신청 不可(法 132의2②)<br>■확대된 선출원(法 29③④)                                                                           |                                   |

## I 법조문

## 제88조 【특허권의 존속기간】(★)

- ① (원칙) 특허권의 존속기간은 제87조제1항에 따라 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다.
- ② (정당한 권리자의 출원) 정당한 권리자의 특허출원이 제34조 또는 제35조에 따라 특허된 경우에는 제1항의 특허권의 존속기간은 무권리자의 특허출원일의 다음 날부터 기산한다.

[전문개정 2014.6.11.]

## 제89조 【허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장】(★) 法 92의2

- ① (의의) 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 "허가 등"이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령(시행령 제7조)으로 정하는 발명인 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간(제92조의5제2항에 따라 특허권의 존속기간의 연장이 등록된 경우에는 그 연장된 날까지를 말한다)을 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 허가등을 받은 날부터 14년을 초과하여 연장할 수 없다. <개정 2025. 1. 21.>

## 시행령 제7조

## 제7조(허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원 대상 발명 등)

- ① 법 제89조제1항에서 "대통령령으로 정하는 발명"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명을 말한다. <개정 1996. 6. 3., 2000. 6. 23., 2005. 1. 31., 2007. 6. 28., 2008. 9. 30., 2011. 12. 2., 2013. 4. 3., 2020. 7. 14.>
1. 특허발명을 실시하기 위하여 「약사법」 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품(신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다) 또는 「마약류 관리에 관한 법률」 제18조제2항 또는 제21조제2항에 따라 품목허가를 받은 마약 또는 향정신성의약품(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 마약 또는 향정신성의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 마약 또는 향정신성의약품으로 한정한다)의 발명
  2. 특허발명을 실시하기 위하여 「농약관리법」 제8조제1항, 제16조제1항 또는 제17조제1항에 따라 등록된 농약 또는 원제의 발명
- ② 제1항 각 호의 발명과 관련하여 법 제89조제1항에 따른 특허발명을 실시할 수 없었던 기간의 산정 및 그 밖에 특허권의 존속기간 연장등록출원의 심사에 관한 세부적인 사항은 지식재산처장이 정하여 고시한다. <신설 2020. 7. 14.>

[제목개정 2020. 7. 14.]

- ② (연장기간) 제1항을 적용할 때 허가 등을 받은 자에게 책임있는 사유로 소요된 기간은 제1항의 "실시할 수 없었던 기간"에 포함되지 아니한다.

[전문개정 2014.6.11.]

## 제90조 【허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원】 法 92의3

- ① (출원서 제출) 제89조제1항에 따라 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하려는 자(이하 이 조 및 제91조에서 "연장등록출원인"이라 한다)는 다음 각 호의 사항을 적은 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.
1. 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
  2. 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
  3. 연장대상특허권의 특허번호 및 연장대상청구범위의 표시
  4. 연장신청의 기간
  5. 제89조제1항에 따른 허가 등의 내용
  6. 총리령(시행규칙 제53조)으로 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)
- ② (시기적 요건) 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 제89조제1항에 따른 허가 등을 받은 날부터 3개월 이내에 출원하여야 한다. 다만, 제88조에 따른 특허권의 존속기간의 만료 전 6개월 이후에는 그 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 할 수 없다.

- ③ **(주체적 요건)** 특허권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.
- ④ **(출원의 효과: 존속기간 연장간주)** 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있으면 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만, 그 출원에 관하여 제91조의 연장등록거절결정이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ **(출원의 효과: 특허공보 게재)** 지식재산처장은 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있으면 제1항 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.
- ⑥ **(출원서의 보정)** 연장등록출원인은 지식재산처장이 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 연장등록출원서에 적혀 있는 사항 중 제1항제3호부터 제6호까지의 사항(제3호 중 연장대상특허권의 특허번호는 제외한다)에 대하여 보정할 수 있다. 다만, 제93조에 따라 준용되는 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다.
- ⑦ **(객체적 요건)** 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권이 있는 경우에는 연장등록출원인은 그 중 하나의 특허권에 대해서만 존속기간의 연장등록출원을 하여야 하고, 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원이 있는 경우에는 어느 특허권의 존속기간도 연장할 수 없다. <신설 2025. 1. 21.>
- ⑧ **(객체적 요건)** 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 출원은 제7항을 적용할 때는 처음부터 없었던 것으로 본다. <신설 2025. 1. 21.>
1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
  2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
- [전문개정 2014.6.11.]

#### 제91조 【허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정】(★) **법 92의4 / 134①**

심사관은 제90조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다. <개정 2025. 1. 21.>

1. **(객체: 허가 등의 필요성)** 그 특허발명의 실시가 제89조제1항에 따른 허가 등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 아니하는 경우
2. **(객체: 허가 등의 취득)** 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조제1항에 따른 허가 등을 받지 아니한 경우
3. **(객체: 연장기간)** 연장신청의 기간이 제89조에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하는 경우
4. **(주체)** 연장등록출원인이 해당 특허권자가 아닌 경우
5. **(주체)** 제90조제3항을 위반하여 연장등록출원을 한 경우
6. **(객체: 연장횟수)** 제90조제7항을 위반하여 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원을 한 경우

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제92조 【허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록결정 등】 **법 92의5**

- ① **(등록결정)** 심사관은 제90조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 제91조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 발견할 수 없을 때에는 연장등록결정을 하여야 한다.
- ② **(특허원부 등록)** 지식재산처장은 제1항에 따른 연장등록결정을 한 경우에는 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다.
- ③ **(특허공보 게재)** 지식재산처장은 제2항에 따른 등록을 한 경우에는 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.
  1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
  2. 특허번호
  3. 연장등록의 연월일
  4. 연장기간
  5. 제89조제1항에 따른 허가 등의 내용

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제92조의2 【등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장】(★) **법 89**

- ① **(의의)** 특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.
- ② **(연장기간: 일반)** 제1항의 규정을 적용함에 있어서 출원인으로 인하여 지연된 기간은 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장에서 제외된다. 다만, 출원인으로 인하여 지연된 기간이 겹치는 경우에는 특허권의 존속기간의 연장에서 제외되는 기간은 출원인으로 인하여 실제 지연된 기간을 초과하여서는 아니된다.
- ③ **(연장기간: 지연기간)** 제2항에서 "출원인으로 인하여 지연된 기간"에 관한 사항은 대통령령[시행령 제7조의2, 시행규칙 제54조의5]으로 정한다.
- ④ **(연장기간: 출원일 기산)** 제1항에 따라 특허출원일부터 4년을 기산할 때에는 제34조, 제35조, 제52조제2항, 제52조의2제2항,

제53조제2항, 제199조제1항 및 제214조제4항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 날을 특허출원일로 본다.

<개정 2021. 10. 19.>

1. 제34조 또는 제35조에 따른 정당한 권리자의 특허출원의 경우에는 정당한 권리자가 출원을 한 날
2. 제52조에 따른 분할출원의 경우에는 분할출원을 한 날
- 2의2. 제52조의2에 따른 분리출원의 경우에는 분리출원을 한 날
3. 제53조에 따른 변경출원의 경우에는 변경출원을 한 날
4. 제199조제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원의 경우에는 제203조제1항 각 호의 사항을 기재한 서면을 제출한 날
5. 제214조에 따라 특허출원으로 보는 국제출원의 경우에는 국제출원의 출원인이 제214조제1항에 따라 결정을 신청한 날
6. 제1호부터 제5호까지의 규정 중 어느 하나에 해당되지 아니하는 특허출원에 대하여는 그 특허출원일

[본조신설 2011.12.2.]

### 제92조의3 【등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원】 法 90

- ① (출원서 제출) 제92조의2에 따라 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하려는 자(이하 이 조 및 제92조의4에서 "연장등록출원인"이라 한다)는 다음 각 호의 사항을 적은 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

<개정 2013.3.23., 2013.7.30.>

1. 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
  2. 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
  3. 연장 대상 특허권의 특허번호
  4. 연장신청의 기간
  5. 총리령[시행규칙 제54조의3]이 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)
- ② (시기적 요건) 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 특허권의 설정등록일부터 3개월 이내에 출원하여야 한다.
- ③ (주체적 요건) 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.
- ④ (출원서의 보정) 연장등록출원인은 심사관이 특허권의 존속기간의 연장등록 여부결정 전까지 연장등록출원서에 기재된 사항 중 제1항제4호 및 제5호의 사항에 대하여 보정할 수 있다. 다만, 제93조에 따라 준용되는 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다.

[본조신설 2011.12.2.]

### 제92조의4 【등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정】(★) 法 91 / 134②

심사관은 제92조의3에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다.

1. (객체: 연장기간) 연장신청의 기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과한 경우
2. (주체) 연장등록출원인이 해당 특허권자가 아닌 경우
3. (주체) 제92조의3제3항을 위반하여 연장등록출원을 한 경우

[본조신설 2011.12.2.]

### 제92조의5 【등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록결정 등】 法 92

- ① (등록결정) 심사관은 제92조의3에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 제92조의4 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 발견할 수 없는 경우에는 연장등록결정을 하여야 한다.
- ② (특허원부 등록) 지식재산처장은 제1항의 연장등록결정이 있으면 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다.
- ③ (특허공보 게재) 제2항에 따른 등록이 있으면 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.

1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 특허번호
3. 연장등록 연월일
4. 연장 기간

[본조신설 2011.12.2.]

### 제93조 【준용규정】

특허권의 존속기간의 연장등록출원의 심사에 관하여는 제57조제1항[심사관의 심사], 제63조[거절이유통지], 제67조[특허여부결정의 방식], 제78조제1항·제3항[심사 또는 소송절차의 중지], 제148조제1호부터 제5호까지 및 같은 조 제7호[심판관의 제척사유, 단 전심판여 제외]를 준용한다. 이 경우 제78조제1항 중 “특허취소신청에 대한 결정”은 “제92조의4 및 제92조의5에 따른 연장등록거절결정 또는 연장등록결정”으로, “그 심사절차”는 “허가등에 따른 연장등록출원 심사 절차”로 본다. <개정 2025. 1. 21.>

[전문개정 2011.12.2.]

#### 제94조 【특허권의 효력】(★★)

① (일반) 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 제100조제2항【전용실시권의 효력】에 따라 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다. <개정 2019. 12. 10.> **法 95**

② (방법 사용의 청약) 특허발명의 실시가 제2조제3호나목에 따른 방법의 사용을 청약하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미친다. <신설 2019. 12. 10.> **法 2Ⅲ나**

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제95조 【허가 등에 따른 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력】(★★) **法 94①**

제90조제4항에 따라 특허권의 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건에 대하여 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다.

[전문개정 2014.6.11.]

## II 존속기간(法 88)

| 구 분     | 내 용                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원칙      | 특허권을 설정등록한 날로부터 특허출원일 후 20년(法 88①).                                                                                                                                                                           |
| 예외      | 1. 무권리자에 대한 정당한 권리자의 특허출원 - 무권리자의 특허출원일의 다음 날부터 기산(法 88②).<br>2. 분할·분리·변경출원 - 원출원일의 다음 날로부터 기산(法 52②, 52의2②, 53②)<br>3. 조약우선권주장출원·국내우선권주장출원 - 우선권주장출원일의 다음 날부터 기산(法 54①, 55③)<br>4. 국제특허출원 - 국제출원일의 다음 날부터 기산 |
| 공휴일의 경우 | 특허에 관한 절차가 아니므로 그 다음 날로 만료되지 않고 공휴일로 만료(法 14Ⅳ)                                                                                                                                                                |



### III 허가 등과 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장의 비교(법조문)

| 조 문     | 허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장 | 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장 |
|---------|------------------------|------------------------|
| 의 의     | 제89조                   | 제92조의2                 |
| 연장등록출원  | 법 제90조                 | 제92조의3                 |
| 거절결정    | 제91조                   | 제92조의4                 |
| 등록결정등   | 제92조                   | 제92조의5                 |
| 준용규정    | 제93조                   |                        |
| 특허권의 효력 | 제95조                   | 제94조제1항                |

| 조 문 | 허가 등에 따른 존속기간 연장                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 등록지연에 따른 존속기간 연장                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 의 의 | <p><b>제89조 【허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장】</b></p> <p>① (의의) 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 "허가 등"이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간(제92조의5제2항에 따라 특허권의 존속기간의 연장이 등록된 경우에는 그 연장된 날까지를 말한다)을 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 허가등을 받은 날부터 14년을 초과하여 연장할 수 없다.</p> <p>② (연장기간) 제1항을 적용할 때 허가 등을 받은 자에게 책임있는 사유로 소요된 기간은 제1항의 "실시할 수 없었던 기간"에 포함되지 아니한다.</p> | <p><b>제92조의2 【등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장】</b></p> <p>① (의의) 특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.</p> <p>② (연장기간: 일반) 제1항의 규정을 적용할 때 출원인으로 인하여 지연된 기간은 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장에서 제외된다. 다만, 출원인으로 인하여 지연된 기간이 겹치는 경우에는 특허권의 존속기간의 연장에서 제외되는 기간은 출원인으로 인하여 실제 지연된 기간을 초과하여서는 아니된다.</p> <p>③ (연장기간: 지연기간) 제2항에서 "출원인으로 인하여 지연된 기간"에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.</p> <p>④ (연장기간: 출원일 기산) 제1항에 따라 특허출원일부터 4년을 기산할 때에는 제34조, 제35조, 제52조제2항, 제52조의2제2항, 제53조제2항, 제199조제1항 및 제214조제4항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 날을 특허출원일로 본다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제34조 또는 제35조에 따른 정당한 권리자의 특허출원의 경우에는 정당한 권리자가 출원을 한 날</li> <li>2. 제52조에 따른 분할출원의 경우에는 분할출원을 한 날</li> <li>2의2. 제52조의2에 따른 분리출원의 경우에는 분리출원을 한 날</li> <li>3. 제53조에 따른 변경출원의 경우에는 변경출원을 한 날</li> <li>4. 제199조제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원의 경우에는 제203조제1항 각 호의 사항을 기재한 서면을 제출한 날</li> <li>5. 제214조에 따라 특허출원으로 보는 국제출원의 경우에는 국제출원의 출원인이 제214조제1항에 따라 결정을 신청한 날</li> <li>6. 제1호부터 제5호까지의 규정 중 어느 하나에 해당되지 아니하는 특허출원에 대하여는 그 특허출원일</li> </ol> |
| 출원  | <p><b>제90조 【허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원】</b></p> <p>① (출원서 제출) 제89조제1항에 따라 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하려는 자(이하 이 조 및 제91조에서 "연장등록출원인"이라 한다)는 다음 각 호의 사항을 적은 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>제92조의3 【등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원】</b></p> <p>① (출원서 제출) 제92조의2에 따라 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하려는 자(이하 이 조 및 제92조의4에서 "연장등록출원인"이라 한다)는 다음 각 호의 사항을 적은 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 지식재산</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>1. 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)</p> <p>2. 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)</p> <p>3. 연장대상특허권의 특허번호 및 연장대상청구범위의 표시</p> <p>4. 연장신청의 기간</p> <p>5. 제89조제1항에 따른 허가 등의 내용</p> <p>6. 총리령으로 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)</p> <p>② <b>(시기적 요건)</b> 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 제89조제1항에 따른 허가 등을 받은 날부터 3개월 이내에 출원하여야 한다. 다만, 제88조에 따른 특허권의 존속기간의 만료 전 6개월 이후에는 그 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 할 수 없다.</p> <p>③ <b>(주체적 요건)</b> 특허권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.</p> <p>④ <b>(출원의 효과)</b> 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있으면 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만, 그 출원에 관하여 제91조의 연장등록거절결정이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>⑤ <b>(특허공보 게재)</b> 지식재산처장은 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있으면 제1항 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.</p> <p>⑥ <b>(출원서의 보정)</b> 연장등록출원인은 지식재산처장이 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 연장등록출원서에 적혀 있는 사항 중 제1항제3호부터 제6호까지의 사항(제3호 중 연장대상특허권의 특허번호는 제외한다)에 대하여 보정할 수 있다. 다만, 제93조에 따라 준용되는 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다.</p> <p>⑦ <b>(객체적 요건)</b> 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권이 있는 경우에는 연장등록출원인은 그 중 하나의 특허권에 대해서만 존속기간의 연장등록출원을 하여야 하고, 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원이 있는 경우에는 어느 특허권의 존속기간도 연장할 수 없다.</p> <p>⑧ <b>(객체적 요건)</b> 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 출원은 제7항을 적용할 때는 처음부터 없었던 것으로 본다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 포기, 무효 또는 취하된 경우</li> <li>2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우</li> </ol> | <p>처장에게 제출하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)</li> <li>2. 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)</li> <li>3. 연장 대상 특허권의 특허번호</li> <li>4. 연장신청의 기간</li> <li>5. 총리령이 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)</li> </ol> <p>② <b>(시기적 요건)</b> 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 특허권의 설정등록일로부터 3개월 이내에 출원하여야 한다.</p> <p>③ <b>(주체적 요건)</b> 특허권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.</p> <p>④ <b>(출원서의 보정)</b> 연장등록출원인은 심사관이 특허권의 존속기간의 연장등록 여부결정 전까지 연장등록출원서에 기재된 사항 중 제1항제4호 및 제5호의 사항에 대하여 보정할 수 있다. 다만, 제93조에 따라 준용되는 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다.</p> |
| 거절 결정 | <p><b>제91조 【허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정】</b></p> <p>심사관은 제90조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>(객체적 요건)</b> 허가 등의 필요성 그 특허발명의 실시가 제89조</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>제92조의4 【등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정】</b></p> <p>심사관은 제92조의3에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>제1항에 따른 허가 등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 아니하는 경우</p> <p>2. <b>(객체: 허가 등의 취득)</b> 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조 제1항에 따른 허가 등을 받지 아니한 경우</p> <p>3. <b>(객체: 연장기간)</b> 연장신청의 기간이 제89조에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하는 경우</p> <p>4. <b>(주체)</b> 연장등록출원인이 해당 특허권자가 아닌 경우</p> <p>5. <b>(주체)</b> 제90조제3항을 위반하여 연장등록출원을 한 경우</p> <p>6. <b>(객체: 연장횟수)</b> 제90조제7항을 위반하여 하나의 허가 등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원을 한 경우</p>                                                                                                                   | <p>1. <b>(객체: 연장기간)</b> 연장신청의 기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과한 경우</p> <p>2. <b>(주체)</b> 연장등록출원인이 해당 특허권자가 아닌 경우</p> <p>3. <b>(주체)</b> 제92조의3제3항을 위반하여 연장등록출원을 한 경우</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 등록 결정 | <p><b>제92조 【허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록결정 등】</b></p> <p>① <b>(등록결정)</b> 심사관은 제90조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 제91조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 발견할 수 없을 때에는 연장등록결정을 하여야 한다.</p> <p>② <b>(특허원부 등록)</b> 지식재산처장은 제1항에 따른 연장등록 결정을 한 경우에는 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다.</p> <p>③ <b>(특허공보 게재)</b> 지식재산처장은 제2항에 따른 등록을 한 경우에는 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)</li> <li>2. 특허번호</li> <li>3. 연장등록의 연월일</li> <li>4. 연장기간</li> <li>5. 제89조제1항에 따른 허가 등의 내용</li> </ol> | <p><b>제92조의5 【등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록결정 등】</b></p> <p>① <b>(등록결정)</b> 심사관은 제92조의3에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 제92조의4 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 발견할 수 없는 경우에는 연장등록결정을 하여야 한다.</p> <p>② <b>(특허원부 등록)</b> 지식재산처장은 제1항의 연장등록결정이 있으면 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다.</p> <p>③ <b>(특허공보 게재)</b> 제2항에 따른 등록이 있으면 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)</li> <li>2. 특허번호</li> <li>3. 연장등록 연월일</li> <li>4. 연장 기간</li> </ol> |
| 준용 규정 | <p><b>제93조 【준용규정】</b></p> <p>특허권의 존속기간의 연장등록출원의 심사에 관하여는 제57조제1항, 제63조, 제67조, 제78조제1항·제3항, 제148조제1호부터 제5호까지 및 같은 조 제7호를 준용한다. 이 경우 제78조제1항 중 “특허취소신청에 대한 결정”은 “제92조의4 및 제92조의5에 따른 연장등록거절결정 또는 연장등록결정”으로, “그 심사절차”는 “허가등에 따른 연장등록출원 심사 절차”로 본다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 효력    | <p><b>제95조 【허가 등에 따른 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력】</b></p> <p>제90조제4항에 따라 특허권의 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건에 대하여 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>제94조 【특허권의 효력】</b></p> <p>① 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 제100조제2항[<b>전용실시권의 효력</b>]에 따라 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다.</p> <p>&lt;개정 2019. 12. 10.&gt;</p> <p>② 특허발명의 실시가 제2조제3호나목에 따른 방법의 사용을 청약하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미친다. &lt;산설 2019. 12. 10.&gt;</p> <p>[전문개정 2014.6.11.]</p>                                                                                           |

Ⅳ 허가 등과 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장의 비교(내용)

| 제 도 |     | 허가 등에 따른 존속기간연장등록제도                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 등록지연에 따른 존속기간연장등록제도                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서   | 의 의 | 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간(제92조의5제2항에 의한 등록지연에 따라 특허권의 존속기간의 연장이 등록된 경우에는 그 연장된 날까지를 말한다)을 한 차례만 연장(단, 허가등을 받은 날부터 14년을 초과하여 연장 불가)할 수 있는 제도를 말한다(法 89).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있는 제도를 말한다(法 92의2①).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 취 지 | 설정등록 후에도 실시할 수 없었던 특허권자의 불이익을 해소                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 심사처리기간 등에 따라 달라지는 존속기간을 합리적으로 조정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 요 건 | 주체적 | 특허권자, 공유인 경우에는 전원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 객체적 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 허가 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명일 것(약사법에 의하여 허가를 받아야 하는 의약품, 마약류 관리에 관한 법률에 따라 품목허가를 받은 마약/향정신성의약품, 농약관리법에 의하여 등록을 받아야 하는 농약/원제)</li> <li>2. 실시를 위하여 허가 등을 받을 것</li> <li>3. 특허발명을 실시할 수 없었던 기간(단, 허가 등을 받은 자의 책임있는 사유로 소요된 기간은 제외)으로서 5년까지 존속기간(등록지연에 따라 연장등록된 경우 그 날까지) 연장 가능. 단, 허가 등을 받은 날부터 14년을 초과하여 연장 불가</li> <li>4. 1차례만 연장가능(하나의 허가 등에 둘 이상의 특허권이 있는 경우 하나의 특허권만 연장등록출원 가능)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에 그 지연된 기간일 것(단, 출원인으로 인해 실제 지연된 기간은 제외)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 시기적 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 연장등록당시 특허권이 유효할 것</li> <li>2. 허가 등을 받은 날로부터 3개월 이내 및 존속기간만료 6개월 이전에 출원할 것(위반시 불수리)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 특허권의 설정등록일로부터 3개월 이내 출원할 것(위반시 불수리)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 절 차 |     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 연장등록출원서의 제출(연장대상청구범위의 표시)</li> <li>2. 연장등록출원서의 보정               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (시기) 연장등록여부결정의 등본송달전(단, 심사관이 거절이유통지한 경우 의견서제출기간)</li> <li>- (대상) 출원인, 특허번호 변경 보정 불가</li> </ul> </li> <li>3. 연장등록출원의 효과               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 존속기간연장간주(단, 거절결정이 확정된 경우 제외)</li> <li>- 특허공보에 게재</li> </ul> </li> <li>4. 거절결정               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (주체) 특허권자가 출원하지 않은 경우</li> <li>- (주체) 공유인데 모두가 출원하지 않은 경우</li> <li>- (객체) 허가 등을 받을 필요성이 없는 경우</li> <li>- (객체) 특허권자, 전용실시권, 등록된 통상실시권자가 허가 등을 받지 않은 경우</li> <li>- (객체) 연장기간을 초과한 경우</li> <li>- (객체) 하나의 허가 등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 연장등록출원을 한 경우</li> </ul> </li> <li>5. 등록결정 및 특허공보게재</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 연장등록출원서의 제출</li> <li>2. 연장등록출원서의 보정               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (시기) 연장등록여부결정전(단, 심사관이 거절이유통지한 경우 의견서제출기간)</li> <li>- (대상) 출원인, 특허번호 변경 보정 불가</li> </ul> </li> <li>3. 거절결정               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (주체) 특허권자가 출원하지 않은 경우</li> <li>- (주체) 공유인데 모두가 출원하지 않은 경우</li> <li>- (객체) 연장기간을 초과한 경우</li> </ul> </li> <li>4. 등록결정 및 특허공보게재</li> </ol> |
|     |     | 심사·심판절차의 준용 - 법 제57조제1항, 제63조, 제67조 및 제148조제1호부터 제5호 및 제7호 준용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 효 과 |     | 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건에 대하여 특정의 용도가 정해져 있는 경우에는 있어서는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다(法 95).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 특허권자는 연장된 존속기간 동안 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(法 94①).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# 42

## 효력의 의의, 제한 및 확장(法 94~96, 127)

### I 법조문

#### 제94조 【특허권의 효력】(★★)

- ① (일반) 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 제100조제2항[전용실시권의 효력]에 따라 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다. <개정 2019. 12. 10.> 法 95
- ② (방법 사용의 청약) 특허발명의 실시가 제2조제3호나목에 따른 방법의 사용을 청약하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미친다. <신설 2019. 12. 10.> 法 2Ⅲ나

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제95조 【허가 등에 따른 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력】(★★) 法 94①

제90조제4항에 따라 특허권의 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건에 대하여 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제96조 【특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위】(★★)

- ① 특허권의 효력은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에는 미치지 아니한다.
1. 연구 또는 시험(「약사법」에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 「농약관리법」에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다)을 하기 위한 특허발명의 실시
  2. 국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치, 그 밖의 물건
  3. 특허출원을 한 때부터 국내에 있는 물건 法 103
- ② 둘 이상의 의약[사람의 질병의 진단·경감·치료·처치(處置) 또는 예방을 위하여 사용되는 물건을 말한다. 이하 같다]이 혼합되어 제조되는 의약의 발명 또는 둘 이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 「약사법」에 따른 조제행위와 그 조제에 의한 의약에는 미치지 아니한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제127조 【침해로 보는 행위】(★★) 法 65⑤ / 181②Ⅱ,Ⅲ / 225

다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다. <개정 2025. 1. 21.>

1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

[전문개정 2014.6.11.]

## II 특허권의 효력(法 94①~96, 127)

| 효 력              |                 | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 효<br>력<br>범<br>위 | 시간적             | 설정등록한 날로부터 특허출원일 후 20년(法 88①). 단, 일정한 경우 연장가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | 내용적             | 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(法 97).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 지역적             | 속지주의 원칙에 따라 우리나라의 영토내에서만 미친다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 효<br>력<br>내<br>용 | 의의              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 序 - 특허권자가 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 것을 말한다(法 94①).</li> <li>2. 업으로서 의미 - 가정적·개인적 실시를 제외한 사업으로서를 의미. 영리·비영리, 실시의 빈도 등은 문제×</li> <li>3. 특허발명의 실시 - 「특허발명」이란 특허를 받은 발명(法 2II). 그러므로 설정등록된 이후의 발명으로서 특허권의 존속 중에 있는 발명은 특허발명임. 「실시」는 발명이 물건발명, 방법발명, 물건을 생산하는 방법발명인지 여부에 따라 구분됨(法 2III).</li> <li>4. 독점적 실시 - 특허발명은 특허권자만이 독점적으로 실시할 수 있다. 한편, 이러한 특허권의 독점성을 보장하기 위해서는 반대급부적으로 독점성을 침해하는 행위에 대해서는 그 행위를 배제할 수 있는 배타성이 인정되어야 한다. 따라서, 타인이 정당한 권원없이 업으로서 특허발명의 보호범위에 속하는 확인대상발명을 실시하여 특허권을 침해하는 경우 특허권자는 침해자에 대하여 민·형사상의 구제조치를 취할 수 있다.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | 소극적<br>효력<br>제한 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 실시권의 존재에 의한 제한</li> <li>2. 권리소진에 의한 제한</li> <li>3. 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(法 96) <ol style="list-style-type: none"> <li>① 연구 또는 시험(「약사법」에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 「농약관리법」에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다)을 위한 특허발명의 실시(法 96①I) - 특허발명 자체의 시험 또는 연구이어야 하고, 다른 연구 또는 시험의 목적을 위하여 특허발명을 이용한 실시는 이에 해당되지 않음. 각각의 실시행위별로 침해인지 여부를 판단해야 하기 때문에 시험 또는 연구의 결과 제작된 것을 업으로서 시험 또는 연구 이외의 것에 사용하거나 양도 및 대여 등을 했을 때에는 특허권의 침해가 됨. 한편, 특허권 존속기간 중 약사법의 허가, 농약관리법의 등록을 얻기 위한 시험은 이에 해당하여 침해가 아님.</li> <li>② 국내를 통과하는데 불과한 교통기관 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치 기타의 물건(法 96①II) - 일시적 또는 우발적으로 선박·항공기·차량 또는 이들에서 사용하는 기계·기구 등을 육상에서 수리 등을 하는 경우에 수리장치 또는 방법이 특허물에 해당되거나 선박 또는 항공기에 적재된 특허물이 수입을 목적으로 하는 경우에는 이에 해당하지 않음.</li> <li>③ 특허출원을 한 때부터 국내에 있는 물건(法 96①III) - 출원 후 동일한 물건을 제조하는 것은 이에 해당하지 않음. 한편, 실제 본 규정이 적용되는 경우는 해당 물건이 비밀상태에 있어서 신규성을 이유로 무효심판을 청구할 수 없거나 또는 선사용권의 요건에 해당되지 아니한 경우이다.</li> <li>④ 둘 이상의 의약을 혼합하여 제조되는 의약발명 또는 그 제법발명에 있어서 약사법에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약(法 96②)</li> </ol> </li> <li>4. 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권의 효력 제한 - 효력제한기간 중에 다른 사람이 특허발명을 실시한 행위에 대하여는 그 효력이 미치지 아니한다(法 81의3④).</li> <li>5. 재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한 - ① 무효가 된 특허권(존속기간이 연장등록된 특허권을 포함한다)이 재심에 의하여 회복된 경우, ② 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우, ③ 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우, ④ 취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 i) 선의로 수출 또는 수입하거나 또는 국내에서 생산하거나 취득한 물건, ii) 선의의 실시행위 및 iii) 선의의 간접침해행위 중 어느 하나에 대해서는 미치지 아니한다(法 181).</li> <li>6. 특허권의 하자에 의한 제한</li> <li>7. 자유기술에 의한 제한 <ol style="list-style-type: none"> <li>① 의의 - 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다. 실시자가 이를 이유로 항변하는 것을 「자유기술의 항변」이라 한다.</li> <li>② 확인대상발명 - 심판청구인이 특정한 확인대상고안의 구성 전체(전체구성설)(2008후64)</li> <li>③ 적용범위 - 문언침해, 균등침해 모두 적용(2016후366).</li> <li>④ 공지의예외적용주장과 항변 - 공지의예외적용주장의 대상이 된 공지는 자유기술 항변 부정</li> </ol> </li> <li>8. 권리남용에 의한 제한</li> </ol> |
|                  | 적극적<br>효력<br>제한 | 이용·저촉관계의 경우에는 선출원 권리자의 허락을 받지 아니하거나 통상실시권허락심판에 의하지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다(法 98, 138), 즉, 후출원 특허발명에 관한 특허권의 적극적 효력이 제한됨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | 소극적<br>효력<br>확장 | 특허발명의 실시는 아니지만 침해의 전 단계에 있어 그대로 방치할 경우 침해의 개연성이 높은 행위에 대하여 특허권의 침해로 간주한다. 구체적으로 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위, 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다(法 127).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



### III 권리소진에 의한 제한

| 구 분 | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 의의  | 특허권자 또는 제조·판매권을 가진 실시권자(이하 “특허권자 등”이라 함)가 특허발명을 실질적으로 구현한 제품(이하 “특허제품”이라 함)을 적법하게 판매한 경우에 판매할 때 권리가 소진되어 동일물에 대해서는 특허권의 침해를 주장할 수 없게 되는 것을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 취지  | 특허제품을 유통할 때에 양도시마다 특허권자의 동의를 얻어야 한다면 특허제품의 유통이 현저히 방해될 수 있고(유통과정 및 전독자의 보호), 특허권자가 특허제품을 판매할 때에 이미 특허권자에게 특허발명의 대가를 배타적으로 취득할 기회가 주어지는 것이어서 이중 이득의 기회를 줄 필요가 없기 때문이다(권리자 이중 이득의 불필요).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 요건  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 특허권자 또는 제조·판매권을 가진 실시권자일 것 - 특허권자 또는 제조·판매권을 가진 실시권자가 판매하여야 한다. 따라서 실시권자가 실시권의 제한조건을 벗어나서 판매를 한 경우에는 권리소진의 효과가 발생하지 않아서 특허권의 침해가 된다. 단, 부수적인 제한조건을 위반한 경우에는 계약의 내용, 유통을 금지할 실익, 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 권리소진 여부를 판단(2018도14446)</li> <li>2. 특허발명을 실질적으로 구현한 제품(특허제품)일 것 - 특허발명을 실질적으로 구현한 제품을 판매하여야 한다. 즉, 특허발명 청구항의 모든 구성요소를 포함하여 문언적으로 포함한 경우나 일부가 변경되었다고 하더라도 균등의 범위내에서 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타낼 정도로 구현된 제품을 판매하여야 한다. 한편, 특허발명 중 일부만이 구현되어 있거나 다른 부품과 결합될 때 비로소 특허발명이 완성되어 실시되는 제품이라고 할지라도 해당 제품이 특허발명의 핵심적 특징을 모두 가지고 있다면 특허발명을 실질적으로 구현한 제품으로 볼 수 있다.</li> <li>3. 적법하게 판매할 것 - 판매단 그 형식을 가리지 아니하고 제품의 소유권이 적절한 대가관계를 통해 이전되는 모든 거래행위를 가리킨다. 따라서 일반적인 양도나 증여와 같은 자발적인 처분행위는 물론 경매와 같은 비자발적 처분행위도 모두 포함한다.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 논점  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 방법발명의 특허에 대해서도 권리가 소진된다고 할 것인지 여부             <ol style="list-style-type: none"> <li>① 방법발명의 경우에도 제품이 특허발명을 실질적으로 구현하였다면 권리가 소진되고, 제품이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지 여부는 i) 사회통념상 인정되는 그 제품의 본래 용도가 그 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도가 없는지 여부, ii) 그 제품에 그 방법발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, iii) 그 제품을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 실질적으로 차지하는 비중 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 함(2017다289903).</li> <li>② 단, 방법의 발명에 대한 특허권이 공유인 경우에 있어서는, 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용되는 물건이 양도되었다고 하더라도, 그 물건이 공유자 중 일부의 소유이고 그 소유자가 아닌 다른 공유자가 그 물건의 양도에 대해서 동의를 한 바가 없다면, 양수인 또는 전독자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여 법 제99조제4항을 무력화시킬 수 있기 때문에 특허권이 소진되지 아니함(2008허13299).</li> </ol> </li> <li>2. 조건부 판매로 권리소진을 제한할 수 있는지 여부 - 우리나라는 이에 관한 사례가 아직 존재하지 않으나, 만약 조건부 판매에 의하여 권리소진을 제한할 수 있다면 i) 조건부 판매가 계약법적으로 유효한지 여부, ii) 계약법적으로 유효하더라도 특허권의 남용이나 공정거래법 등의 법률에 위반되는지 여부와 함께 검토되어야 함. 공정거래법 제59조와 관련하여 지식재산권의 행사가 정당한 것인지 여부를 판단하는 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」에서는 조건부 판매를 지식재산권의 부당한 행사로 명시함</li> <li>3. 외국에서의 판매에 대하여 권리소진이 적용될 것인지 여부             <ol style="list-style-type: none"> <li>① 권리소진을 적용함에 있어서 판매지역은 국내외를 불문하나, 권리소진이 발생하는 지역은 특허권이 부여된 국가로 한정된다고 해석함이 타당함</li> <li>② 따라서, i) 국내와 외국 특허권의 특허권자가 각기 다른데 외국의 특허권자가 판매한 특허제품(진정상품)을 제3자가 구매하여 국내에 병행수입(parallel import)하는 경우 외국에서 특허권의 경우 권리소진이 발생하지만, 국내에서 특허권의 경우 특허권자가 달라 국내의 특허권자가 특허제품의 판매를 통해 이득을 취한 것도 아니고 특허독립의 원칙 및 속지주의에 의하여 국내에서 권리소진이 발생하지 않아서, 국내 특허권의 침해라고 볼 것이고, ii) 국내와 외국 특허권의 특허권자가 동일한데 특허권자가 외국에서 판매한 특허제품을 제3자가 구매한 후 국내에 병행수입하는 경우 외국에서 특허제품의 판매를 통해 외국과 국내에서 특허권의 권리소진이 발생하였고, 특허권자가 이득을 취하였기 때문에 국내 특허권의 침해가 아니라고 볼 것이고, iii) 국내 특허권자가 특허권이 없는 외국에서 특허제품을 판매하거나 국내에서 판매하여 외국에 수출하였는데, 제3자가 이를 그대로 또는 가공하여 국내에 수입할 경우 국내의 특허제품의 판매를 통해 국내 특허권의 권리소진이 발생하였고, 특허권자가 이득을 취하였기 때문에 국내 특허권의 침해가 아니라고 봐야 함(81가합466)</li> </ol> </li> <li>4. 수리 내지 부품 교환을 하는 행위가 특허권을 침해하는 것으로 볼 것인지 여부             판례는 부품이 비소모품인 경우와 소모품인 경우를 달리 보고 있다. 부품이 비소모품인 경우에는 발명의 기술적 사상과 관련된 본질적인 구성요소라면 부품의 교체가 생산에 해당하고, 특허발명의 대상 또는 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모품인 경우에는 i) 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 ii) 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 iii) 해당 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, iv) 특허권자 측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면 생산에 해당함. 다만, 최근 판례(2017나1001)는 부품을 교체하는 것이 원래 특허제품과의 동일성을 해할 정도에 이르게 된 경우에는 재생산으로 특허권을 침해하는 것으로, 동일성을 유지되는 경우에는 수리로서 특허권을 침해하지 않은 것으로 판단하고 있고, 부품 교체행위가 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에 해당하는지 여부는 당해 제품의 객관적 성질, 이용형태 및 특허법의 규정취지 등을 종합하여 판단하여야 한다고 하여 상표법에서의 판단기준과 동일한 판단기준을 제시함. 이는 본질적 부분의 교체라면 생산이 된다는 기존의 판례보다 수리의 범위를 조금 더 넓게 인정해 주려는 경향으로 파악됨 </li> </ol> |

#### Ⅳ 특허권의 하자에 의한 제한

| 구 분                  |    | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문제의 소재               |    | 착오로 등록된 경우 ① 당연무효인지 여부, ② 권리범위 인정 여부 ③ 권리행사의 제한 가능성 여부가 문제됨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 당연무효인지 여부            |    | 실용신안법은 실용신안등록이 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 실용신안등록의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 등록실용신안은 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 실용신안등록을 무효로 한다는 심결이 확정되지 아니하면 유효하며, 위와 같은 실용신안등록을 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 절차에서 그 전제로서 실용신안등록이 당연무효라고 판단할 수 없다(97후2095 등). - 행정청분의 공정력에 의해 하자있는 행정처분이 당연무효가 되기 위해서는 그 하자가 중대명백하여야 하는데 특허결정을 할 때 일정한 절차를 거치는 점, 특허요건 흠결은 사실확정의 문제가 아니라 법적 평가의 성격을 지녀서 판단이 자명하지 아니한 점 등에 비추어 보면 특허권의 하자는 중대명백하지 않음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 권리<br>범위<br>인정<br>여부 | 원칙 | 특허요건의 흠결이 있더라도 원칙적으로 권리범위가 인정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | 예외 | <ol style="list-style-type: none"> <li>특허발명이 공지기술과 동일하여 신규성에 위반된 경우 <ol style="list-style-type: none"> <li>특허발명이 공지기술과 문언적 동일하거나 내재적 동일성이 있는 경우 → 권리행사불가, 이를 이유로 항변하는 것을 강학상 무효의 항변이라 (예를 들어, 공지기술 a+b+c와 동일한 발명인 a+b+c로 구성된 발명이 출원하여 신규성이 없음에도 불구하고 착오로 등록된 경우에는 무효심판여부와 관계없이 a+b+c 실시 에 대해서는 권리범위를 인정하지 아니한다.)</li> <li>특허발명이 공지기술과 실질적 동일성이 있는 경우 → 공지된 실시태양에 대해서는 권리행사불가(예를 들어, 공지기술 a1+b+c로 이루어진 발명보다 상위개념발명인 A+b+c(여기서, A는 a1과 a2를 포괄하는 개념 임)로 구성된 발명을 출원하여 신규성이 없음에도 불구하고 착오로 등록된 경우에는 무효심판여부와 관 계없이 a1+b+c 실시에 대해서는 권리범위를 인정하지 아니하여야 할 것이다.</li> <li>특허발명의 구성요소 일부가 공지기술인 경우 → 구성요소가 공지이나 여부에 상관없이 모든 구성요소에 의 하여 보호범위 판단(따라서, “청구범위의 일부에 공지사유가 있는 경우 그 공지기술이 신규의 발명과 유기적으로 결합되어 있으면 그 공지부분에까지 권리범위가 미치고, 신규의 발명에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지사유에 대하여는 그 권리범위를 확장할 수 없다”는 1964.10.22. 선고 63후45 전원합의체판결은 비판받아야 함)</li> </ol> </li> <li>특허발명이 선출원주의, 확대된 선출원에 위반된 경우</li> <li>특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없거나 특허발명의 실시가 불가능한 경우</li> </ol> |
| 권리<br>행사<br>제한<br>여부 | 원칙 | <ol style="list-style-type: none"> <li>특허요건의 흠결이 있음에도 불구하고 착오로 등록되었더라도 권리범위가 인정된 경우 - 특허권에 기해 제3자의 실시에 대하여 침해를 이유로 권리행사가 가능</li> <li>권리행사후 특허권이 소급하여 소멸한 경우의 처리 <ol style="list-style-type: none"> <li>권리행사한 침해소송 등 → 재심</li> <li>특허권자의 책임 <ul style="list-style-type: none"> <li>고의/과실 有 : 손해배상 책임</li> <li>고의/과실 無 : 부당이득반환 책임</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 예외 | <ol style="list-style-type: none"> <li>특허발명이 공지기술로부터 용이: 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보 성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다 는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이다.”고 판시함.</li> <li>권리범위확인심판에서 진보성이 부정된다는 이유로 권리범위를 부정해서는 안 됨.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## V 권리남용에 의한 제한

| 구 분    | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 의의     | 민법 제2조에는 “권리는 남용하지 못한다.”고 규정되어 있다. 권리남용이란 권리 자체는 유효한 것으로 전제로 그 권리의 행사가 외관상으로 적법한 것으로 보이지만 권리의 사회적·경제적 목적 또는 사회적으로 허용되는 한계를 일탈한 것일 때 이에 대한 법적 보호를 부정하는 것을 말한다. 특허권 남용의 제한은 i) 특허법 규정에 의한 제한, ii) 판례의 의한 제한, iii) 타법에 의한 제한으로 구분될 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 특허법 제한 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 실시 의무에 의한 제한 <ol style="list-style-type: none"> <li>① 의의 - 특허권자가 스스로 특허발명을 실시하여 공중의 이용을 도모할 의무를 말한다.</li> <li>② 제한 - 특허법은 불실시에 대한 제재인 재정에 의한 강제실시권(法 107 내지 115)을 인정하고 있다. 그러나 특허권의 취소와 관련하여서는 구법 제116조에서 “지식재산처장은 불실시를 이유로 재정이 있는 날부터 계속하여 2년 이상 그 특허발명이 국내에서 실시되고 있지 아니하는 경우에는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 그 특허권을 취소할 수 있다.”라고 규정하였으나 i) 개인의 재산권을 침해한다는 비판이 있어 왔고, ii) 「대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환」을 국내법에 반영하기 위해 2012. 3. 15. 시행된 현행법(법률 제11117호, 2011. 12. 2. 개정)에서는 이를 삭제하였다.</li> </ol> </li> <li>2. 실시협조에 의한 제한 <ol style="list-style-type: none"> <li>① 의의 - 특허발명을 실시하려는 자에 대하여 정당한 이유가 없는 한 실시협조를 하여야 할 의무를 말한다.</li> <li>② 제한 - 이용자촉발명에 대한 실시협조, 재정사유에 해당할 때의 실시협조를 하지 않으면 강제실시권을 허락받을 수 있도록 함</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 판례 제한  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 민법상 권리남용에 해당하기 위해서는 주관적으로 그 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없는 경우이어야 하고, 객관적으로는 그 권리행사가 사회질서에 위반된다고 볼 수 있어야 함(2002다62319). cf) 특허법은 주관적 요건을 필요로 하지 않음</li> <li>2. 하지있는 특허권에 의한 권리행사 - 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니함(2010다95390).</li> <li>3. 장기간 행사하지 않았던 특허권에 의한 권리행사 <ol style="list-style-type: none"> <li>① 등록고안이 등록된 지 6년 가량 지나서야 실용신안권을 행사하였다 하여 권리남용이라 할 수 없다고 판시함(2000다48272).</li> <li>② 실효의 향반이 인정되기 위한 요건 - i) 권리자가 실제로 권리를 행사할 수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 상당한 기간이 경과하도록 권리를 행사하지 아니하여 ii) 의무자인 상대방으로서도 이제는 권리자가 권리를 행사하지 아니할 것으로 신뢰할 만한 정당한 기대를 가지게 된 다음에 iii) 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것이 법질서 전체를 지배하는 신의성실의 원칙에 위반하는 것으로 인정되는 결과 발생(2005다45827).</li> </ol> </li> <li>4. 표준필수특허에 대하여 FRAND 선언한 특허권자의 권리행사 제한 - 특허권의 행사 자체에 대하여 권리남용의 항변을 인정할 것인지와 관련하여, 상대방에 대한 특허권의 행사가 특허제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 거래 질서를 어지럽히고 수요자 또는 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 특허권의 행사는 실령 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록특허에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 특허권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 특허권의 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게서는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니라고 판시함(특허권자는 FRAND 선언을 통해 곧바로 제3자에게 실시권을 허락하는 것이 아니라 ‘FRAND 조건에 의한 실시권 허락’이라는 제한을 수용하는 의사표시를 한 것에 불과하므로, 표준필수특허에 대하여 실시권 허락 요청 없이 무단으로 실시하고 있거나 표준필수특허의 유효 여부나 침해 여부를 부인하면서 표준필수특허를 실시하고 있는 제3자에게 특허권에 기하여 침해금지 등을 구한다고 하더라도 금반언의 원칙에 반한다거나 권리남용에 해당한다고 할 수 없다)(2011가39552).</li> </ol> |
| 타법 제한  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 공정거래법 제59조 - 공정거래법 제59조에 의하면 “이 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다.”고 규정되어 있다. 다만, 이 규정이 경쟁질서의 유지라는 공정거래법의 법 목적달성을 불가능하게 할 정도로 특허권을 남용하는 행위(지식재산권의 부당한 행사)까지 배제하는 것은 아니다. 「특허권을 남용하는 행위」란 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 그 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하는지는 특허법의 목적과 취지, 해당 특허권의 내용과 아울러 해당 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단하여야 한다. 공정거래위원회는 공정거래법 제59조와 관련하여 지식재산권의 행사가 정당한 것인지 여부를 판단하는 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」을 마련하고 부당한 행사에 해당하는 유형을 예시하고 있다.</li> <li>2. 특허권 남용과의 관계 - 특허권 남용은 공정거래법 위반보다 광범위한 불법행위이기 때문에 공정거래법 위반이 아닌 경우에도 특허권 남용이 될 수 있다. 특허권 남용에 해당하는지 여부는 특허법 내에서 판단을 하게 되고, 특허권 남용이 인정되면 그로 인해 관련 시장에서의 독점적 시장지배력 확보나 공정한 경쟁질서 훼손 등 경쟁법적 효과까지 발생하였는지를 고려하여 공정거래법 위반 여부를 판단하게 된다. 특허권의 행사가 특허권 남용으로 인정되면 권리행사의 효과가 부정되는 것에 그침에 반해, 공정거래법 위반에 해당하면 특허권자는 시정조치, 과징금 및 민형사상 책임을 지게 된다.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



# 43

## 특허발명의 보호범위(法 97)

### I 법조문

#### 제97조 【특허발명의 보호범위】(★★) 法 43

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다.

[전문개정 2014.6.11.]

- 보호범위란 법률적 가치판단에 의하여 그 특허권의 배타적 효력이 미치는 영역을 말함. 법 제97조에서 해석기준을 제시하고 있으나 무형의 기술적 사상의 창작인 발명을 청구범위의 문구로 명료하게 표현하는 것에는 발명의 추상성으로 인해 한계가 있기 때문에 법률적 가치판단이 가미된 해석이 필요
- 보호범위를 해석하는 방법으로는 주변한정주의와 중심한정주의가 존재
- 주변한정주의는 청구항에 기재된 구성요소 전체에 의하여 해석하며 명세서·도면은 필요한 경우 참작하는 방법으로, 판단이 용이하나 보호범위가 좁음(법적 안정성 추구)
- 중심한정주의는 청구항에 기재된 구성요소로부터 발명의 핵심사상을 추출하여 확장해석하는 방법으로, 판단이 어려우나 보호범위가 넓음(구체적 타당성 추구)
- 判例 - 90's 초반의 중심한정주의에서 90's 후반 이후 주변한정주의로 변화
- 단점 보완
  - ① 다항제 - 주변한정주의하에서 발명의 다면적 보호를 위한 청구범위 기재방법
  - ② 간접침해 - 특허발명의 실시가 아니지만 침해로 인정
  - ③ 균등론
    - 구성요소가 일치하지 않지만 기술적 사상이 균등한 범위까지 특허발명 실시로 인정
    - 주변한정주의를 채택하는 국가에서 보호범위 확장해석 위한 이론(중심한정주의를 채택하고 있는 국가에서는 중심한정주의 개념이 균등론을 내포하기 있기 때문에 논의의 실익이 없음)
    - 어느 범위까지 확장해석할 것인지 문제이고 여기에 대한 명확한 기준은 판례가 제시함.

## II 보호범위(法 97)의 판단

| 구 분                          |              | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서설                           |              | 보호범위의 판단은 단순히 특허발명의 범위라고 하는 사실구성의 상태를 확정하는 것이 아니라 확인대상발명과 관계에서 특허발명의 권리가 미치는 범위를 객관적으로 확정하는 것이다. 따라서 보호범위의 판단은 i) 특허발명의 특정과 ii) 확인대상발명의 특정을 한 후, iii) 특허발명과 확인대상발명을 대비하여 구성요소완비의 원칙과 균등론을 적용함으로써 특허발명의 실시인지 판단하고 iv) 법률의 제한 및 확장을 고려하여 이루어진다.                                                                                                                                                                                                                              |
| 특<br>허<br>발<br>명<br>특<br>정   | 序            | 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(法 97). 이는 특허발명의 보호범위가 청구범위에 기재된 그대로 정해진다는 의미는 아니며, 발명의 설명·도면의 참작과 함께 출원 당시의 기술수준, 출원의 경과 및 특허권의 하자 등을 참작하여 해석된 청구범위가 특허발명의 보호범위결정의 기준이 된다는 의미이다. 즉 특허발명을 특정할 때, 청구범위 기준의 원칙, 발명의 설명 참작의 원칙, 공지기술 참작의 원칙, 출원경과 참작의 원칙 및 특허권 하자 참작의 원칙 등이 고려된다.                                                                                                                                                                                        |
|                              | 청구범위 기준 원칙   | 1. 청구범위에 기재되지 아니한 사항은 보호범위에 속하지 않음<br>2. 청구항별로 독립적으로 보호범위를 판단하고, 하나의 청구항의 보호범위에 포함된다면 그 특허발명의 보호범위에 속함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                              | 발명의 설명 참작 원칙 | 특별한 사정이 없는 한 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하려는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다.<br>* 제한해석되는 특별한 사정(진실로 발명하지 않은 부분까지 권리범위를 인정하는 것은 제3자에게 불측의 손해를 줄 수 있음)<br>① 발명의 설명에 의하여 보충을 하더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우 발명의 설명 또는 도면에 의하여 뒷받침되는 범위내로(단 확정이 안되면 보호범위 불인정)<br>② 문언 그대로 해석하는 것이 명백히 불합리한 경우 - 기능적 표현 청구항 |
|                              | 공지기술 참작 원칙   | 공지기술로부터 개량진보의 정도가 큰 발명의 보호범위는 넓게, 개량진보의 정도가 작은 발명의 보호범위는 좁게 인정(산업발전촉진에 대한 기여력의 측정) - 균등범위에서 차이가 발생                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | 출원경과 참작 원칙   | 출원과정에서 확인대상발명의 치환된 구성요소가 청구범위로부터 의식적으로 제외되는 등 특단의 사정을 참작해야 함. 균등론의 적용에 따른 청구범위의 확장해석을 억제하기 위한 이론                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | 특허권 하자 참작 원칙 | 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지여서 신규성이 없는 경우, 선행특허와 동일하여 선출원주의, 확대된 선출원에 위반된 경우, 명세서의 기재불비 등으로 인하여 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우, 특허발명의 실시가 불가능한 경우는 권리범위를 불인정함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 확인대상발명<br>(피고제품, 실시제품)<br>특정 |              | 1. 확인대상발명은 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어야 하고, 해당 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이나 다만, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 한다.<br>2. 다만, 확인대상발명이 독립항의 권리범위에 속하지 아니하면 종속항에 대응되는 부분의 구성이 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 특정된 것으로 보고 종속항의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단할 수 있다.<br>3. 특허권자가 확인대상발명을 구체적으로 특정하는 것이 실시자의 자유기술의 향연을 어렵게 만들기 때문에 특허권자에게 이익이 된다.               |
| 특허발명의 실시 판단                  |              | 1. 구성요소완비의 원칙(All Elements Rule) - 구성요소를 모두 가지고 실시하는 경우에만 보호범위에 속함<br>2. 균등론 - ① 과제의 해결원리가 동일할 것, ② 변경가능성이 있을 것, ③ 변경용이성이 있을 것, ④ 공지기술이 아닐 것(자유기술의 향변), ⑤ 의식적으로 제외된 것이 아닐 것(포대금반언의 원칙 적용×)을 만족해야 함                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 법률의 제한·확장<br>고려              |              | 1. 법률의 제한 - 특허발명의 실시라도 법률의 제한에 해당하면 침해가 아님. 법률의 제한은 특정물건이나 행위에 대하여 효력이 제한되는 것으로서 행위주체를 묻지 않음. 예를 들어, ① 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(法 96), ② 재심에 의하여 회복된 특허권의 효력의 제한(法 181), ③ 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권의 효력 제한(法 81의3④) 등은 이에 해당하나, 실시권의 존재, 권리소진의 적용을 받는 물건 등은 고려 대상이 아님.<br>2. 법률의 확장 - 특허발명의 실시가 아닐지라도 간접침해를 인정(法 127)                                                                                                                                                |

### III 균등론

| 구 분                  | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서 의 설                | <p>확인대상발명과 청구범위에 기재된 발명의 구성요소가 완전히 일치하지는 않지만 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 청구범위에 기재된 발명의 구성요소로부터 확인대상발명의 구성요소를 쉽게 변경하여 실질적으로 동일한 효과를 얻을 수 있는 것일 때에는 확인대상발명이 특허발명의 기술사상과 균등한 것으로서 특허발명의 보호범위에 포함된다고 보는 이론이다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 취 지                  | <p>1. 주변환경주의를 보완하여 특허권자의 실질적인 보호를 위해 경험적으로 발전된 이론.<br/>2. 단, 최소한의 법적안정성을 유지하기 위해 명확한 적용요건이 필요한데 판례가 이를 제시함.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 적 극 적<br><br>적 용 요 건 | <p>1. 과제의 해결원리가 동일할 것(발명 전체로 파악)</p> <p>① 의의 - 「과제의 해결원리가 동일」한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 「기술사상의 핵심」이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다. 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다(2017후424).</p> <p>② 과제해결원리의 파악 - 우선 내적 증거인 명세서에 적힌 발명의 설명에 기재된 종래기술의 문제점, 과제해결수단, 발명의 목적·효과의 기재에 기초하여 판단하되, 필요한 경우 출원결과나 다른 공지의 증거 등 외적 증거에 대한 추가심리를 통하여 객관적으로 추출한다. 구체적으로 「기술사상의 핵심」을 파악함에 있어서, 명세서의 기재에 기초하여 특허발명의 과제와 해당 과제를 해결하기 위해 균등 여부가 문제된 구성이 기능하는 원리를 파악하되, 그 구성이 문언의 범위를 넘어 확인대상발명의 대응구성까지 포섭할 수 있을 정도로 상위개념화가 가능한지 검토한다. 다만, 발명의 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.</p> <p>③ 구성요소별이 아닌 발명 전체로 파악(2016마5698) - 비본질적 구성이 변경된 경우에는 동일한 해결원리</p> <p>2. 변경가능성(원칙은 발명전체, 예외는 구성별로 파악) - 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내어야 한다. 또한 확인대상발명과 대비하는 특허발명의 '작용효과'는 다른 구성요소들과의 유기적 결합 속에서 균등 여부가 문제 되는 당해 구성요소가 나타내는 효과이다. 완전히 동일한 작용 효과를 발휘할 것까지는 필요 없고, 확인대상발명의 효과가 더욱 크거나 넓어도 좋고 더욱 작거나 좁아도 좋으며, 실질적으로 동일한 작용 효과라면 충분하다. 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원당시에 이미 공지되었거나 그와 다른없는 것에 불과한 경우에는 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(2018다267252).</p> <p>3. 변경용이성(구성별로 파악)</p> <p>① 판단시점 - 변경용이성의 판단시점과 관련하여 대법원(2022후10210)은 균등론에 의한 발명 보호의 실효성을 높이기 위해 침해시(제조시점)를 기준으로 판단하고 있다. 즉, 특허발명의 출원 이후 침해 시(권리범위확인심판에서는 심결 시)까지 사이에 공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다.</p> <p>② 진보성과의 관계 - 진보성의 용이성이 균등론의 변경용이성보다 더 높은 수준이라는 것이라는 것이 다수설. 기본발명의 발명자는 변경용이성과 용이성 사이의 영역에서 제3자의 실시행위가 있다 하더라도 침해를 주장할 수는 없지만 그 제3자가 자신이 실시한 것을 후출원을 하게 되면 진보성이 없어 특허거절결정을 받게 된다.</p> |
| 소 극 적                | <p>1. 확인대상발명이 공지기술이 아닐 것 - 자유기술의 항변을 의미함</p> <p>2. 의식적으로 제외된 것이 아닐 것 - 출원경과참작의 원칙(포대금반언의 원칙(File Wrapper Estoppel))</p> <p>① 의의 - 해당 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성요소가 청구범위로부터 의식적으로 제외되는 등 특단의 사정이 없어야 한다. 예를 들어 청구항에 「A+B+C」를 구성요소로 하여 출원하였다가 「A+B'+C」로 보정되어 특허된 경우 최종의 「A+B+C」에 대해서는 균등물임을 이유로 권리주장을 할 수 없다.</p> <p>② 적용대상 - 선행기술과의 관계에서 특허성을 확보하기 위한 보정, 예를 들어, 신규성 등을 상실하는 것을 회피하기 위하여 청구범위를 제한적으로 보정하거나 그러한 해석에 관한 주장을 한 경우(안락의자 사건 - 2000후2712) 포대금반언의 원칙이 적용됨에는 이론의 여지가 없다. 또한, 판례는 i) 등록 후 청구범위의 정정(2002후2105), ii) 보정없이 의견서만 제출한 경우(2002허635), iii) 분할출원한 경우(2006다35308, 2023후11340)에도 금반언의 원칙을 적용하고 있다.</p> <p>③ 적용범위 - 감축 등이 된 청구범위의 구성요소에 일절의 균등범위를 인정하지 아니한다는 엄격한 규정의 입장(absolute bar approach)과 일정 범위에서 균등범위를 인정하는 유연한 규정의 입장(flexible bar approach)이 있다. 미국의 Festo 사건은 보정한 경우 일단 균등범위에서 제외되는 것으로 추정하되, 특허권자의 증명에 의하여 추정의 복명을 시킬 수 있다는 것인데 반해, 우리나라의 대법원 판결(2014후638)은 보정했다고 하더라도 출원인이 이를 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재하지 않는다면 균등범위에서 제외할 수 없다고 판시하였다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Ⅳ 특허요건 판단과 보호범위 판단 시 발명의 특정

| 발명의 특정        | 특허요건 판단                                                                                                     | 보호범위 판단                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 청구범위 중심의 원칙   | 적용                                                                                                          | 적용                                                                                                        |
| 발명의 설명 참작의 원칙 | 적용                                                                                                          | 적용 (제한 해석 가능)                                                                                             |
| 공지기술 참작의 원칙   | 부적용<br>(발명의 특정 후 신규성, 진보성 판단으로 같음)                                                                          | 적용 (제한 해석 가능)                                                                                             |
| 출원경과 참작의 원칙   | 부적용<br>(다만, 출원인이 공지되었음을 자인하는 경우 공지된 것으로 추정).                                                                | 적용 (제한 해석 가능)                                                                                             |
| 특허권하자 참작의 원칙  | 부적용<br>(발명의 특정 후 신규성, 진보성 등의 판단으로 같음)                                                                       | 적용 (제한 해석 가능)                                                                                             |
| 비고            | 출원인이 표시한 의사를 심사하는 측에서 임의로 변경하는 것을 허용하는 결과가 되고, 기재 불비가 있거나 특허요건을 구비하지 못한 발명이 등록될 수 있는 불합리가 발생하기 때문에 제한 해석 불가 | 청구범위에 적혀 있는 사항이라는 사정만으로 보호할 가치가 없는 사항이나 진실로 발명하지 아니한 부분까지 그 권리를 인정하는 것은 제3자에게 불측의 손해를 줄 수 있기 때문에 제한 해석 가능 |

# 44

## 이용 및 저촉 발명(法 98)

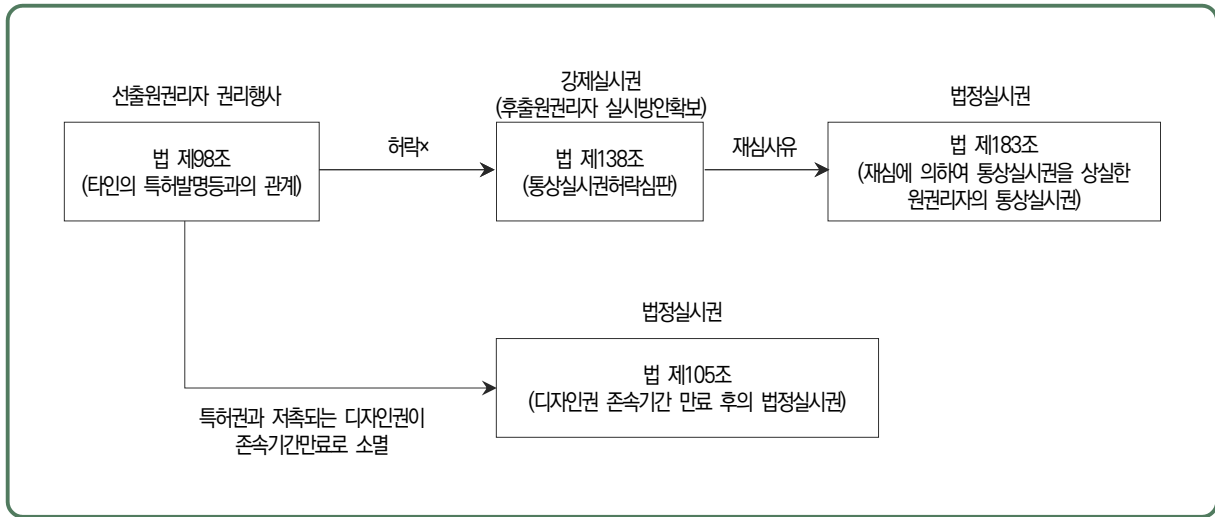
### I 법조문

#### 제98조 【타인의 특허발명 등과의 관계】(★★) 法 138, 183, 105

특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

## II 이용·저촉관계의 조문 정리





### III 이용 및 저촉발명(法 98)

| 구 분 |            |    | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서   | 의의         | 이용 | 1. 후출원 권리자가 자기의 특허발명 등을 실시하면 선출원인 타인의 특허발명 등을 실시하게 되지만, 선출원 권리자가 자기의 특허발명 등을 실시하는 경우에는 후출원 특허발명 등의 실시로는 되지 아니한 일방적 충돌관계<br>2. 이용발명이 무엇인가에 대해서는 ① 주요부설, ② 개량확장설, ③ 그대로설, ④ 실시불가피설이 대립하고 있으나 선행발명의 구성요소에 새로운 기술적 요소를 부가한 것으로서 선행발명의 특허요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용한 것이라는 그대로설이 통설이다. 다만 선출원발명이 물건발명이고 후출원발명이 물건의 제조방법발명인 경우를 고려하여 실시불가피설도 포함하는 것이 타당하다.<br>3. 판례(2001후393 ; 98후522 등)는 “선행특허발명과 후발명이 이용관계에 있는 경우에는 후발명은 선행발명의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후발명이 선행특허발명의 기술적 구성요소에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후발명이 선행특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후발명 내에 선행특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하는 것이며, 이는 선행특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지이다.”고 함으로써 그대로설의 입장에서 판시. 다만, 판례는 균등물을 이용하는 경우에도 이용관계를 긍정함으로써 그대로설을 확장해석 |
|     |            | 저촉 | 후출원인 특허권이 선출원인 타인의 디자인권 또는 상표권과 완전히 동일한 것으로서, 두 개의 권리가 중복되어 그 어느 쪽을 실시해도 타방의 권리를 실시하게 되는 쌍방적 충돌관계를 말하며, 저촉발명이란 이러한 저촉관계가 성립되는 발명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 취지         |    | 1. 권리의 경합 발생시 선출원우위의 원칙에 의하여 선출원권리자를 보호하고(法 98)<br>2. 후출원권리자의 실시를 확보하는 제도를 마련(法 138)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 유형  | 이용         | 내용 | 1. 사상상의 이용<br>① 동일 카테고리내에서 선출원발명의 구성요소 전부를 포함하고 이에 별도의 구성요소를 부가하여 발명을 완성한 경우(그대로설의 입장). 선출원발명이 「A+B+C」로 구성된 발명인데 선출원의 기술사상에 「D」라는 구성요소를 추가하여 전체적인 기술사상을 「A+B+C+D」로 하는 발명을 말함.<br>② 종래의 대법원 판례(92후1660)는 축매의 부가로 인해 작용효과상의 우월성이 있다면 후출원특허발명이 선행발명을 이용하지 아니한다고 판시. 그러나 이는 특허요건의 판단과 침해여부판단을 혼동하는 것으로서 현저한 효과로 인해 진보성(法 29②)에 위반되지 않아 등록되더라도 일체성을 상실하지 않았다면 침해, 즉 이용발명으로 봄이 타당하며 최근에 판례(98후522)는 이를 바로 잡고 있음.<br>2. 실시상의 이용 - 다른 카테고리내에서 후출원발명을 실시할 때 선출원발명의 실시가 되는 경우(실시불가피설의 입장). 선출원의 물질발명과 후출원의 제법발명 등이 이에 해당                                                                                                                                                                                      |
|     |            | 대상 | ① 특허발명 상호간은 물론 ② 특허발명과 등록실용신안, ③ 특허발명과 등록디자인 또는 유사한 디자인 간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 저촉         |    | 특허권과 디자인권, 특허권과 상표권간, 단, 특허권과 특허권(실용신안권)간은 法 36위반으로 무효사유.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 판단  | 주체         |    | 침해소송에서 법원이 판단하거나 권리범위확인심판에서 심판원이 판단(단, 특허권 상호간의 저촉관계를 확인하는 적극적권리범위확인심판은 인용심결이 타방의 권리를 부정하기 때문에 불가)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 대상         |    | 타인의 권리이며, 상호 등록되었을 것. 공유자 중 일부가 이용발명한 경우 타인이 아니므로 法 98이 적용되지 않아 다른 공유자의 동의없이 이용발명 실시 가능.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 시기         |    | 특허출원일전의 해석 - 출원일을 기준으로 선출원우위의 원칙에 의하여 판단하나 동일출원은 法 98이 적용되지 않아 자유롭게 실시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 효과  | 선출원 권리자 보호 |    | 1. 특허권의 행사 - 선출원권리자는 이용·저촉관계에 있는 후출원발명의 권리자가 선출원권리자의 허락을 받지 않거나 통상실시권허락심판에 의하지 않고 자기의 특허발명을 업으로 실시하면 선출원 권리의 침해를 구성하기 때문에 선출원권리에 의하여 민·형사상 제재조치를 취할 수 있다.<br>2. 크로스라이선스 - 통상실시권허락심판에 따라 통상실시권을 허락한 선출원 권리자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 후출원 권리자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다(法 138③).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 후출원 권리자 보호 |    | 1. 선출원권리자의 실시허락 - 이용·저촉관계에 있는 후출원권리자는 선출원권리자의 허락을 받아야 즉, 허락에 의한 실시권을 획득한 후에야 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다(法 98). 다만, 후출원권리자는 선출원권리자의 허락을 받지 않고는 후출원발명을 실시할 수 없지만 타인이 후출원발명을 실시하는 경우에는 후출원권리의 침해를 이유로 민형사상 제재조치를 취할 수 있으며, 이는 타인이 선출원권리자라고 하더라도 마찬가지이다.<br>2. 통상실시권허락심판의 청구 - 후출원 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 법 제98조에 해당되어 실시의 허락을 받으려는 경우에 선출원권리자가 정당한 이유없이 실시허락을 하지 않거나 실시허락을 받을 수 없는 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위안에서 통상실시권허락심판을 청구할 수 있다. 다만, 후출원특허발명이 그 특허출원일전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 이용관계에 있는 경우에는 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 정보를 가져오는 것이어야 한다(法 138①②).                                                                                                                                               |



#### IV 구체적 예

##### 1. 그대로실

- ① 외적부가(사상상의 이용) - 甲이 A+B+C로 구성된 발명을 출원 후 실시중이고, 乙이 A+B+C+D로 구성된 발명을 출원 후 실시중인 경우 후출원의 등록가능성 및 실시가 침해인지 여부(촉매부기발명 判例)

| 선출원여부 | 후출원의 등록가능성                                                           | 후출원의 실시가 선출원의 침해인지 여부                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 甲 > 乙 | 1. 甲의 공개 전 → 등록가능<br>2. 甲의 공개 후 → A+B+C로부터 쉽게 발명할 수 있는 경우 제29조제2항 위반 | 1. 乙의 실시는 甲의 특허권의 침해<br>2. 정당한 권원획득 후 실시<br>① 허락<br>② 통상실시권허락심판(乙이 등록된 경우)<br>(甲으로부터 A+B+C를 구매한 후 D를 추가하여 실시하는 것도 가능) |
| 甲 < 乙 | 1. 乙의 공개 전 → 제29조제3항, 제36조 위반<br>2. 乙의 공개 후 → 제29조제1항, 제36조 위반       | 1. 甲의 실시는 AER에 의하여 乙의 특허권의 직접침해 ×<br>2. 단, 乙의 특허권의 간접침해일 수는 있음                                                        |
| 甲 = 乙 | 실질적 동일성이 없는 경우 양자 모두 등록가능                                            | 양자 모두 등록된 경우 자유롭게 실시(·제98조의 “특허출원일 전”의 해석결과 동일자 출원의 부적용)                                                              |

- ② 내적부가 - 甲이 A+B+C로 구성된 발명을 출원 후 실시중이고, 乙이 a1(A의 하위구성요소)+B+C로 구성된 발명을 출원 후 실시중인 경우 후출원의 등록가능성 및 실시가 침해인지 여부(선택발명 判例)

| 선출원여부 | 후출원의 등록가능성                                                           | 후출원의 실시가 선출원의 침해인지 여부                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 甲 > 乙 | 1. 甲의 공개 전 → 등록가능<br>2. 甲의 공개 후 → A+B+C로부터 쉽게 발명할 수 있는 경우 제29조제2항 위반 | 1. 乙의 실시는 甲의 특허권의 침해로 보는 것이 타당<br>2. 단, 판례는 현저한 효과가 있어 등록된 경우 침해가 아니라고 판시. |
| 甲 < 乙 | 1. 乙의 공개 전 → 제29조제3항, 제36조 위반<br>2. 乙의 공개 후 → 제29조제1항, 제36조 위반       | 1. 甲이 a1+b+c를 실시하는 경우 침해<br>2. 그렇지 않으면 비침해                                 |
| 甲 = 乙 | 실질적 동일성이 없는 경우 양자 모두 등록가능                                            | 양자 모두 등록된 경우 자유롭게 실시(·제98조의 “특허출원일 전”의 해석결과 동일자 출원 부적용)                    |

2. 실시불가피설(실사상의 이용) - 甲이 물건발명(物)을 출원 후 실시중이고, 乙이 물건을 제조하는 방법(方1)을 출원 후 실시중인 경우 후출원의 등록가능성 및 실시가 침해인지 여부

| 선출원여부 | 후출원의 등록가능성                                                                                                                                                                                                                 | 후출원의 실시가 선출원의 침해인지 여부                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 甲 > 乙 | 1. 物의 최초 명세서 또는 도면(최·명·도)에 기재된 方이 方1인 경우<br>① 物의 공개 전 출원 → 제29조제3항 위반<br>② 物의 공개 후 출원 → 제29조제1항 위반<br>2. 物의 최·명·도에 기재된 方이 方1이 아닌 경우<br>① 物의 공개 전 출원 → 등록가능<br>② 物의 공개 후 출원 → 物의 최·명·도에 기재된 方으로부터 쉽게 발명할 수 있는 경우 제29조제2항 위반 | 1. 方1의 실시는 物의 침해 ○(·法 제2조제3호(가)목의 실시의 유형-물건생산을 청약하는 행위는 제외)<br>2. 정당한 권원획득 후 실시<br>① 허락<br>② 통상실시권허락심판(乙이 등록된 경우)                          |
| 甲 < 乙 | 1. 方1의 공개 전 출원 → 제29조제3항, 제36조 위반<br>2. 方1의 공개 후 출원 → 제29조제1항, 제36조 위반                                                                                                                                                     | 1. 物의 실시가 方1의 실시에 의한 경우 - 方1의 침해 ○<br>2. 物의 실시가 方1의 실시가 아닌 경우<br>① 方1의 침해 ×<br>② 단, 方1의 출원 전 物이 공지되지 않았다면 方1의 실시에 의하여 物을 생산한 것으로 추정(法 129) |
| 甲 = 乙 | 실질적 동일성이 없는 경우 양자 모두 등록가능                                                                                                                                                                                                  | 양자 모두 등록된 경우 자유롭게 실시(·제98조의 “특허출원일 전”의 해석결과 동일자 출원의 부적용)                                                                                   |

# 45

## 특허권의 침해 (法 97, 98, 126~132, 225, 230, 231)

### I 법조문

#### 제97조 【특허발명의 보호범위】(★★) 法 43

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제98조 【타인의 특허발명 등과의 관계】(★★) 法 138, 183, 105

특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제126조 【권리침해에 대한 금지청구권 등】(★)

① **(금지 및 예방청구권)** 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

② **(폐기·제거청구)** 특허권자 또는 전용실시권자가 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제126조의2 【구체적 행위의 내용·방식·형태 제시 의무】(★) 法 132

① **(행위태양 제시)** 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 내용·방식·형태를 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시하여야 한다. <개정 2025. 5. 27.>

② **(자료제출명령)** 법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다. <개정 2025. 5. 27.>

③ **(자료제출을 거부할 정당한 이유가 있는 경우 & 영업비밀에 해당하는 경우)** 제2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중 "침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때"를 "구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때"로 한다. <개정 2025. 5. 27.>

④ **(제재)** 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 내용·방식·형태를 진실한 것으로 인정할 수 있다. <개정 2025. 5. 27.>

[본조신설 2019. 1. 8.]

[제목개정 2025. 5. 27.]

#### 제127조 【침해로 보는 행위】(★★) 法 65⑤ / 181②II, III / 225

다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다. <개정 2025. 1. 21.>

1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제128조 【손해배상청구권 등】(★★★)

① **(의의)** 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다. <신설 2016.3.29.>

② **(산정: 손해액)** 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. <개정 2020. 6. 9.>

1. 그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액
2. 그 물건의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액

③ 삭제 <2020. 6. 9.>

④ **(추정)** 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다. <개정 2016.3.29.>

⑤ **(의제)** 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

<개정 2016. 3. 29., 2019. 1. 8.>

⑥ **(참작)** 제5항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다. <개정 2016.3.29.>

⑦ **(인정)** 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제2항부터 제6항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. <개정 2016.3.29.>

⑧ **(징벌적 손해배상: 의의)** 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다. <신설 2019. 1. 8., 2024. 2. 20.>

⑨ **(징벌적 손해배상: 고려사항)** 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. <신설 2019. 1. 8.>

1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모
4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
5. 침해행위의 기간·횟수 등
6. 침해행위에 따른 벌금
7. 침해행위를 한 자의 재산상태
8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

[전문개정 2014.6.11.]

[제목개정 2016.3.29.]

## 제128조의2 【감정사항 설명의무】

특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 법원이 침해로 인한 손해액의 산정을 위하여 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하여야 한다. [본조신설 2016.3.29.]

## 제129조 【생산방법의 추정】(★) 法 65⑤ / 29㉠

물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다. 다만, 그 물건이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건
2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 물건

[전문개정 2014.6.11.]

## 제130조 【과실의 추정】(★)

타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

## 제131조 【특허권자 등의 신용회복】(★)

법원은 고의나 과실로 특허권 또는 전용실시권을 침해함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용을 떨어뜨린 자에 대해서는 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

**제132조 【자료의 제출】(★)** 法 224의3-224의5 / 126의2 / 65⑥

- ① **(자료제출명령)** 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다. <개정 2016.3.29.>
- ② **(자료제출을 거부할 정당한 이유가 있는 경우)** 법원은 자료의 소지자가 제1항에 따른 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다. <신설 2016.3.29.>
- ③ **(영업비밀에 해당하는 경우)** 제1항에 따라 제출되어야 할 자료가 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제1항 단서에 따른 정당한 이유로 보지 아니한다. 이 경우 법원은 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다.

<신설 2016.3.29.>

- ④ **(제제)** 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. <신설 2016.3.29.>
- ⑤ **(제제)** 제4항에 해당하는 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. <신설 2016.3.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

[제목개정 2016.3.29.]

**제225조 【침해죄】(★)** 法 230, 231 / 127

- ① **(요건 및 처벌)** 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.
- ② **(반의사불벌죄)** 제1항의 죄는 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소(公訴)를 제기할 수 없다. <개정 2020. 10. 20.>

[전문개정 2014.6.11.]

**제230조 【양벌규정】(★)**

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제225조제1항【침해죄】, 제228조【허위표시의 죄】, 제229조【거짓행위의 죄】 또는 제229조의3【외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령 위반죄】의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2025. 1. 21.>

1. 제225조제1항의 경우: 3억원 이하의 벌금
2. 제228조 또는 제229조의 경우: 6천만원 이하의 벌금
3. 제229조의3의 경우: 1억원 이하의 벌금

[전문개정 2014.6.11.]

**제231조 【물수 등】(★)**

- ① **(물수)** 제225조제1항에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 물수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.
- ② **(초과손해액에 대한 배상청구)** 피해자는 제1항에 따른 물건을 받은 경우에는 그 물건의 가액을 초과하는 손해액에 대해서만 배상을 청구할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

## II 침해의 성립요건(法 97, 98, 127)

| 구 분              | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서                | 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하므로 특허권의 존속 중 정당한 권원 없는 제3자가 업으로서 특허발명의 보호범위에 속하는 확인대상발명을 실시하면 특허권의 침해를 구성한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 성<br>립<br>요<br>건 | <b>특허권의 존속 중</b><br>1. 특허권의 존속 중 실시이어야 한다. 그러므로 특허출원중의 실시 또는 특허료의 불납, 존속기간의 만료, 특허권의 포기, 상속인 부존재 등으로 인해 특허권이 소멸된 후의 실시는 특허권의 침해가 아니다.<br>2. 일단 설정등록에 의하여 특허권이 발생한 이상 특허요건의 흠결이 있다고 할지라도 특허취소신청에 의한 취소결정이나 특허무효심판에 의한 무효심결이 확정되기 전까지는 특허권은 존속중인 것으로 본다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | <b>정당한 권원 없는 자</b><br>정당한 권원 없는 자의 실시이어야 한다. 정당한 권원이란 침해가 되지 아니한 주관적인 측면으로서, 실시권의 존재, 권리소진이 적용되는 물건의 실시 등이 이에 해당한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | <b>업으로서 실시</b><br>1. 업 - 단순히 개인적 또는 가정적인 실시를 제외하는 의미로 해석된다.<br>2. 실시 - 제2조 제3호의 행위를 말한다. 예를 들면, 물건을 생산하는 방법발명의 실시는 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 제외하고는 전부 물건발명의 실시가 된다. 한편, 실시의 각 행위는 독립되어 있으며 하나의 행위가 적법해도 다른 행위까지 적법한 것은 아니며 각각의 실시행위별로 침해인지 여부를 판단하여야 한다(實施行爲의 獨立性).<br>3. 방법의 발명인 경우에 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 발명의 실시로 규정하여, 컴퓨터 프로그램 실행(방법의 사용)을 위한 온라인 전송행위(청약)를 방법발명의 실시의 일 유형으로 포함함으로써 특허권의 침해가 될 수 있도록 하였다(法 2Ⅲ나). 다만, 소프트웨어 산업의 위축을 방지하기 위하여 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 특허권의 효력이 미치도록 제한하고 있다(法 94②). 따라서 방법의 사용을 청약하는 행위에는 특허법 제130조의 과실추정 규정이 적용되지 않으며, 특허권자로부터 침해 경고를 받은 이후에 실시를 중단하면 특허권의 침해가 되지 않는다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | <b>보호범위에 속하는 발명</b><br>1. 특허발명의 보호범위에 속하는 확인대상발명을 실시하여야 한다. 보호범위에 속하는지 여부는 먼저, 특허발명의 청구범위를 중심으로, 발명의 설명의 참작, 공지기술의 참작, 출원경과의 참작 및 특허권 하자의 참작 등을 하여 특허발명을 특정한 후, 확인대상발명과 비교하여 구성요소완비의 원칙, 균등론 등에 특허발명의 실시인지 판단한다.<br>2. 다만, 특허발명의 실시라고 할지라도, ① 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(法 96), ② 재심에 의하여 회복된 특허권의 효력의 제한(法 181), ③ 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권의 효력 제한(法 81의3④) 등의 법률의 제한에 해당한다면 보호범위에 속하지 않게 된다.<br>3. 한편, 특허발명의 실시가 아니더라도 간접침해에 해당한다면 보호범위에 속하게 된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | <b>관련문제</b><br>1. 고의·과실 불요<br>① 일반적으로 특허권의 침해의 성립요건에는 침해자의 고의나 과실을 요구하지 아니한다. 다만, 방법의 사용을 청약하는 행위의 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 한 경우에만 침해가 성립한다(法 94②).<br>② 한편, 고의 또는 과실의 유무는 침해가 성립된 이후 특허권자가 취할 수 있는 조치에 영향을 미친다. 구체적으로 고의나 과실이 있는 경우에는 민사상 손해배상이나 신용회복청구를 할 수 있고, 형사상 고의가 있는 경우에는 침해죄를 물을 수 있다.<br>2. 복수주체의 의한 분산실시<br>① 간접침해인지 여부 - 개별적인 행위가 법 제127조에 해당한다면 그에 따라 해결<br>② 직접침해인지 여부 - 특허 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지 각 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니므로, 원칙적으로 단일 주체가 모든 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 특허발명을 실시하여야 그 특허발명에 관한 특허권을 침해한 것으로 된다(이른바 ‘구성요소 완비의 원칙’). 다만, 복수 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도, i) 복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배, 관리하고, 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배, 관리하면서 영업상의 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로, ii) 복수 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 특허발명의 전체 구성요소를 나누어 실시하는 경우에는 이들 복수 주체가 공동으로 특허침해를 한 것으로 봄이 타당하다(2015라 20296). |



### III 침해의 유형

| 구 분 |      | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유 형 | 직접침해 | 1. 의의 - 직접침해란 정당한 권원 없는 제3자가 특허발명을 업으로서 실시하는 행위를 말한다.<br>2. 유형<br>① 문언침해 - 특허발명의 청구항 구성요소 전부를 실시하는 경우 구성요소완비의 원칙에 의한 침해<br>② 균등침해 - 균등론의 적용에 의한 침해<br>③ 이용·저촉침해 - 문언침해, 균등침해에 해당하는 확인대상발명이 등록된 것 → 후출원권리자의 실시방안 마련(法 138)<br>④ 생략침해·불완전이용침해 - 특허권자의 보호를 강화하기 위해 생략발명, 불완전이용발명을 침해로 봐야한다는 견해이나 주변한정주의의 해석방법인 구성요소완비의 원칙에 반하므로 침해를 부정하는 것이 타당(법적 안정성보다 구체적 타당성을 우선시킬 수 없음)<br>⑤ 선택침해 - 판례(90후960)는 선택발명이 현저히 향상된 작용효과가 있어 등록된 경우 침해가 아니라고 판시하였으나 특허요건 판단과 침해 판단은 별개의 것으로서 선택발명이 그 기본이 되는 특허발명의 기술사상을 그대로 이용하고 있다면 특허발명의 침해로 봄이 타당.<br>⑥ 우회침해 - 선행발명의 공정의 중간단계에 새로운 공정을 삽입할 때에는 선행발명의 공정이 도중에서 분단되어 발명의 일체성이 상실되므로 원칙적으로 침해라고 단정하기 어려우며, 일체성이 상실되지 아니한 범위내에서만 침해라고 할 수 있는데 이를 우회침해라고 함. 판례(97후2194)는 우회침해의 요건으로서 ① 부가공정은 통상의 기술자라면 주지된 관용기술에 의하여 쉽게 부가시킬 수 있는 공정에 불과하다고 보여지고, ② 그 작용효과 역시 주지된 관용기술을 부가함으로써 인한 효과 이상으로 우월하거나 현저하게 향상되었다고 보기 어려울 것을 요구. |
|     | 간접침해 | 1. 의의 - 간접침해란 특허발명의 실시는 아니지만 침해의 전단계로서 침해의 개연성이 있는 경우 법률상 침해로 간주해 주는 것을 말한다.<br>2. 유형<br>① 특허가 물건의 발명인 경우 - 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위<br>② 특허가 방법의 발명인 경우 - 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### IV 직접침해의 유형별 검토

| 구 분       | 특허발명      | 확인대상발명                                                                       | 대법원 판례                                 | 비 고                                                                                                                                        |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문언 침해     | A + B + C | A + B + C                                                                    | 침해(99후1584 ; 99후2372 등)                | 최근 판례는 개별 구성요소의 중요성을 강화하는 방향으로 나아감(생략침해나 불완전이용침해의 인정여부와 상관관계 있음)                                                                           |
|           | A + B + C | A + B + C + D                                                                | 침해(98후522)                             | 촉매를 이용한 화학발명의 이용침해의 해당 여부에 대한 중요한 판례의 변화가 있음                                                                                               |
| 균등 침해     | A + B + C | A + B + C'                                                                   | 침해(98후836 ; 298후2016 등)                | 과제의 해결원리의 동일성, 출원금반언의 원칙, 적용범위의 해석 확립 필요                                                                                                   |
|           | A + B + C | A + B + C' + D                                                               | 침해(98후522 ; 2001후393)                  | 균등물을 기초로 한 이용발명을 침해로 인정함                                                                                                                   |
| 생략 침해     | A + B + C | A + B                                                                        | 최근 대법원 판례는 침해 부정(2000후617 ; 98후2351 등) | 침해를 문언침해와 균등론적 침해로 나누고 개별적 구성요소의 존재를 중요시하는 최근 판례의 동향과 관련하여 그 존재의 의의 및 별도의 침해이론으로서의 인정여부를 심도있게 논의하여 나가야 함. 최근에는 균등침해의 하나의 유형으로 파악하려는 경향이 있음 |
| 불완전 이용 침해 | A + B + C | A + B + <span style="border: 1px dashed black; padding: 0 5px;"> </span> + D | 대법원 판례 없음                              |                                                                                                                                            |
| 선택 침해     | A + B + C | a + B + C                                                                    | 침해를 부정한 과거의 판례(90후960)는 존재하나 논란있음      | 최근 판례의 경향에 따라 이용침해의 한 유형으로서 파악해야 한다는 주장이 강하게 제기되고 있음                                                                                       |
| 우회 침해     | A + B + C | A + B1 + B + C                                                               | 침해(96후2135 ; 97후2194 등)                | 균등침해와의 관계 정립 필요                                                                                                                            |

**V** 침해에 대한 조치(法 126, 128~132, 225, 230, 231)

| 구 분    |               | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 민사상 조치 | 침해금지 및 예방 청구권 | <p>1. 의의<br/>특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 및 예방을 청구할 수 있다. 고의·과실 유무를 불문한다(法 126①).</p> <p>2. 폐기·제거청구(法 126②) → 반드시 침해금지소송과 함께만 행사가능<br/>           ① 침해행위를 조성한 물건의 폐기<br/>           ② 침해행위에 제공된 설비의 제거<br/>           ③ 그 밖에 침해 예방에 필요한 행위</p> <p>3. 침해금지가처분 신청 → 본안소송확정 전 긴급한 행위가 필요한 경우 / 침해 사실 외에 처분의 긴급성이 필요 / 본안소송에서 패소확정된 경우 고의, 과실 추정</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 손해배상 청구권      | <p>1. 의의<br/>특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다(法 128①).</p> <p>2. 손해액의 산정(法 128②): ①과 ②의 금액의 합계액<br/>           ① 그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액<br/>           ② 그 물건의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액</p> <p>3. 손해액의 추정(法 128④) → 침해행위로 인한 이익액<br/>           4. 손해액의 의제(法 128⑤) → 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 액<br/>           5. 손해액의 참작(法 128⑥) → 손해액 의제 초과액에 대해서도 청구가능, 고의·중과실이 없으면 참작<br/>           6. 손해액의 인정(法 128⑦) → 변론 전체의 취지 및 증거조사의 결과<br/>           7. 징벌적 손해배상(法 128⑧⑨) → 손해액의 5배를 넘지 아니하는 범위 내에서 배상액을 결정</p> |
|        | 신용회복 청구권      | <p>1. 의의<br/>법원은 고의나 과실로 특허권 또는 전용실시권을 침해함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용을 떨어뜨린 자에 대해서는 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다(法 131).</p> <p>2. 법원의 조치 → 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 신용회복에 필요한 조치(사죄광고명령 x)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 부당이득 반환 청구권   | <p>1. 의의<br/>특허권자 또는 전용실시권자는 법률상 원인없이 특허권을 침해하여 이익을 얻고 그로 인하여 손해를 끼친 자에 대하여 부당이득반환청구권을 행사할 수 있다(民法 741준용).</p> <p>2. 선의·악의 불문</p> <p>3. 실효성<br/>           ① 고의·과실에 관계없이 행사가능<br/>           ② 단기소멸시효의 적용 x</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 기 타           | <p>1. 경 고 → 특허권 침해에 관한 분쟁시 고의를 증명하는데 유력한 증거로 활용/방법의 사용 청약에서의 침해성립요건과 침해일 때 민사적 징벌적 손해배상, 형사상 침해죄에 영향</p> <p>2. 증거보전 → 증거인멸 또는 훼손의 우려</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 형사상 조치 | 침해죄           | <p>1. 의의<br/>특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다(法 225①).</p> <p>2. 반의사불벌죄(法 225②)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 몰 수           | <p>1. 의의<br/>제225조제1항에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다(法 231①).</p> <p>2. 초과손해액청구(法 231②) → 물건을 받은 후 물건의 가액을 초과하는 손해액</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 양벌규정          | <p>법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 침해죄의 행위를 한 때에는 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 3억원 이하의 벌금에 해당하는 벌금형을, 그 개인에게는 1억원 이하의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위해 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리 하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다(法 230).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## Ⅵ 침해에 대한 손해배상청구권(法 128)

| 구 분        | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 의의         | 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다(法 128①).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                         |
| 요건         | i) 침해자에게 고의·과실이 있을 것, ii) 침해행위가 있을 것, iii) 침해행위로 인해 손해가 발생하였을 것, iv) 침해행위와 손해발생 사이에 인과관계가 있을 것이 요구된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |
| 손해액의 범위    | 1. 침해행위로 인하여 특허권자 등이 이미 가지고 있던 이익이 손실되는 적극적 손해, ii) 침해행위가 없었더라면 특허권자가 얻을 수 있었던 이익의 손실인 소극적 손해 및 iii) 정신적 손해를 모두 포함한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                         |
|            | 2. 소극적 손해로는 i) 특허권자의 매상감소, ii) 특허품의 가격하락 또는 iii) 실시료 수입의 감소가 있을 수 있는데, 침해행위에 의해서만 발생한 것이라는 인과관계의 증명은 통상적으로 다음과 같이 상당히 어렵다. 따라서 손해배상청구의 실효성 확보를 위해 인과관계를 증명하지 않더라도, 매상감소에 의한 일실이익에 관해서는 법 제128조제2항에서, 실시료 수입의 감소에 대해서는 법 제128조제5항에서 별도의 규정에 의하고 있고, 법 제128조제4항에서는 손해발생과 침해자가 얻은 이익액만 증명하면 침해와 손해 사이에 인과관계를 증명하지 않더라도 손해액을 추정하여 손해배상액에 대한 증명책임을 경감시켰다. 한편, 그 외의 적극적 손해, 정신적 손해, 제품가격 인하로 인한 일실이익 등의 손해에 대한 손해배상청구는 법 제128조제1항의 일반적인 손해배상의 법리에 의한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                         |
|            | 소극적 손해                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 계산식                                        | 비고                                      |
|            | 매상감소                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 감소된 판매수량×특허권자 제품의 단위수량당 이익액                | 감소된 판매수량이 침해자 때문이라는 것을 증명해야 함           |
|            | 제품가격 인하                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (원가격-인하된 가격)×판매수량                          | 가격 인하가 영업상의 문제가 아니라 침해자 때문이라는 것을 증명해야 함 |
| 실시료 수입의 감소 | 침해품 판매수량×실시권자 판매가격×약정실시료율                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 침해자 때문에 침해품 판매수량만큼 실시권자가 판매하지 못하였음을 증명해야 함 |                                         |
| 손해액의 산정    | 1. 손해액 1과 손해액 2의 합계액을 손해액으로 산정가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                         |
|            | 2. 손해액 1: 그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액(法 128②Ⅰ)<br>- i) 특허권자 생산능력 범위내에서 침해자의 양도수량을 특허권자의 판매 감소량으로 간주할 수 있게 되었다는 점, ii) 특허권자 등이 침해자의 양도수량만 확인하면 침해자의 단위수량당 이익액을 알 수 없다고 하더라도 특허권자 등의 단위수량당 이익액을 이용할 수 있으므로 계산이 용이하다는 점에서 의미가 있음<br>- 단위수량당 이익액은 한계 이익(매출액-변동경비)(2005다36830)<br>- 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있다는 것을 침해자가 증명하면 양도수량 중 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량은 빼야 함<br>- 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이란 침해자의 시장개발 노력, 판매망, 침해자의 상표, 광고·선전, 침해제품의 품질의 우수성 등으로 인하여 디자인권의 침해와 무관한 판매수량이 있는 경우를 말하는 것으로서, 디자인권을 침해하지 않으면서 디자인권자의 제품과 시장에서 경쟁하는 경쟁제품이 있다는 사정이나 침해제품에 실용신안권이 실시되고 있다는 사정 등을 말함(2005다36830). |                                            |                                         |
| 손해액의 추정    | 3. 손해액 2: 그 물건의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액(法 128②Ⅱ)<br>- i) 오늘날 특허권을 활용한 제품의 제조방식이 OEM 등 다양한 방식으로 이루어지는 점, ii) 설령 생산을 하지 않더라도 특허권자는 수많은 제조업자에게 실시계약을 체결하여 실시할 가능성이 열려 있는 점 등 특허권의 특성을 고려하였을 때, 침해자가 특허권자의 생산능력을 초과하여 취득한 이익을 상당 특허권자가 얻을 수 있었던 이익으로 볼 필요가 있음<br>- 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 것을 침해자가 증명하면 해당 수량은 초과수량에서 빼야 함                                                                                                                                                        |                                            |                                         |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 3. 침해행위로 인한 이익액은 한계 이익설이 판례(서울지방법원 2002가합30683호)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                         |
|          | 학설                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 침해자의 이익                                         | 근거                                                                                                                                                      |
|          | 총이익설                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 매출액 - 제조원가(판매원가)                                | 권리자의 이익을 보호하는 규정이므로 권리자의 증명책임을 경감해야 함(매출액의 증명책임은 권리자, 제조원가에 대한 증명책임은 침해자에 있음)                                                                           |
|          | 순이익설                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 매출액 - 변동경비(재료비, 운송비, 보관비) - 고정경비(설비비, 임차료, 인건비) | 민법 제750조의 일반 불법행위책임 원리상 일실효익은 필요경비를 공제한 순이익책임(권리자가 침해자의 순이익이 얼마인지를 증명해야 함)                                                                              |
|          | 한계이익설                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 매출액 - 변동경비                                      | 순이익을 산정할 때 기초가 되는 판매비, 일반관리비는 기업에 따라 다르고, 침해행위 초기단계에서는 거의 이익이 생기지 아니한 경우도 있는데 고정비용까지 공제한다면, 권리자의 손해전보를 쉽게 하지 못함(매출액의 증명책임은 권리자, 변동경비에 대한 증명책임은 침해자에 있음) |
|          | 4. 손해는 일반적으로 “매상감소에 의한 일실효익(逸失利益)”이고 특허권자의 생산능력 범위 내에서 손해의 한도를 제한하는 것으로 해석되기 때문에 특허권자 또는 전용실시권자가 스스로 실시하고 있지 아니한 경우와 같이 특허권자의 생산능력이 없는 경우에는 추정의 전제인 손해의 발생 자체를 관념할 수 없으므로 이 추정규정은 부적용(96다43119; 2004다36505).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                         |
|          | 5. 침해품의 일부가 특허의 침해인 경우 그 물건에서 침해된 특허가 차지하는 비중, 즉 그 특허가 유발되는 구매동기의 정도를 기여율로 평가하여 물건 전체가 특허의 대상이 되는 경우에 산정되는 손해액에 위 기여율을 곱하여 계산되는 금액을 손해액으로 해야 한다는 견해가 다수설                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                         |
| 손해액의 의제  | 1. 손해액의 의제(法 128⑤) → 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 액<br>2. 특허권의 침해가 있는 경우 그로 인해 특허권자가 별도로 실시 계약을 체결할 수 있는 기회를 상실하게 되어 손해를 입게 되기 때문에, 그에 대한 보상으로 합리적으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 인정하는 것으로서, 「손해의 하한액」을 정함<br>3. 이 규정은 특허권의 침해가 손해액의 추정 규정(法 128④)과는 달리 특허권자가 특허발명을 실시하고 있지 않아 매상감소의 일실효익(逸失利益)이 없는 경우에도 적용된다는 점에 그 의의가 있다. 특허권자는 손해발생에 대하여 주장·증명을 할 필요가 없고, 권리침해사실과 합리적으로 받을 수 있는 금액을 주장·증명하면 된다(2002다 33175).                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                         |
| 손해액의 참작  | 1. 손해액의 참작(法 128⑥) → 손해액 의제 초과액에 대해서도 청구가능, 고의·중과실이 없으면 참작가능<br>2. 다만, 이 경우에도 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액보다 적은 금액까지 경감 不可                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                         |
| 손해액의 인정  | 1. 손해액의 인정(法 128⑦) → 변론 전체의 취지 및 증거조사의 결과에 기초하여 상당 손해액 인정<br>2. 다만, 이는 자유심증주의하에서 손해가 발생한 것은 인정되나 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 증명도·심증도를 경감함으로써 손해의 공평·타당한 분담을 지도 원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하려는 데 취지가 있는 것이지, 법관에게 손해액 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단할 때에는 손해액 산정 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수증할 수 있는 손해액을 산정해야 한다(2010다58728).<br>3. 법 제132조(자료의 제출)의 실효성 확보 가능하고, 영업비밀 누설 우려에 대해서는 비밀유지명령제도(法 224의3)를 통해 보완 |                                                 |                                                                                                                                                         |
| 징벌적 손해배상 | 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(法 128⑧). 법원은 배상액을 판단할 때에는 다음의 사항을 고려하여야 한다(法 128⑨).<br>i) 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부<br>ii) 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도<br>iii) 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모<br>iv) 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익<br>v) 침해행위의 기간·횟수 등<br>vi) 침해행위에 따른 벌금<br>vii) 침해행위를 한 자의 재산상태<br>viii) 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                         |

Ⅶ 간접침해(法 127)

| 구 분  |              | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서    | 의의           | 특허발명 그 자체의 실시가 아니므로 직접침해는 아니지만, 직접침해의 전단계로서 그대로 방치할 경우 침해의 개연성이 높은 일정한 행위에 대하여 특허권을 침해하는 것으로 의제하는 것을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 침해행위 특수성     | 현재 특허권을 침해하고 있지는 않으나 그대로 방치하면 침해로 이어질 개연성이 높은 예비적 행위나, 특허발명의 구성부품만을 업으로서 판매하여 최종조립에 의한 특허발명의 실시를 개인적·가정적으로 유도하는 행위 등에 대해서는 실질적으로 특허발명이 실현하고 있는 기술적 사상을 이용하여 이익을 올리고 특허권자에게 손해를 미칠 우려가 존재하기 때문에 특허발명의 실시가 아니더라도 침해로 보는 행위로 간주하여 특허발명의 보호범위에 속함을 인정.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 성립요건 | 개설           | 간접침해가 성립되기 위해서는 ① 특허권 존속기간 중에 ② 정당한 권원없는 자가 ③ 간접침해행위를 ④ 업으로서 하여야 한다. ①②④의 경우 일반적인 침해의 성립요건이므로 ③에 대해서 중점적으로 살펴본다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 간접침해 행위를 할 것 | <p>1. 특허가 물건발명인 경우</p> <p>① 의의 - 특허가 물건의 발명에 관한 것일 때에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위(法 127Ⅰ)이어야 한다.</p> <p>② 생산 - 특허발명의 구성요소를 충족하지 아니한 물건을 받은 자가 이를 사용하여 특허발명의 구성요소를 충족하는 물건을 만들어 내는 모든 의식적 행위를 의미하고, 반드시 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립, 수리 등의 행위도 포함</p> <p>③ 부품의 교체가 생산인지 여부 - 부품이 비소모품인 경우에는 발명의 기술적 사상과 관련된 본질적인 구성요소라면 부품의 교체가 생산에 해당하고, 특허발명의 대상 또는 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모품인 경우에는 i) 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 ii) 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 iii) 해당 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, iv) 특허권자 측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면 생산에 해당. 다만, 최근 판례(2017나1001)는 부품을 교체하는 것이 원래 특허제품과의 동일성을 해할 정도에 이르게 된 경우에는 재생산으로 특허권을 침해하는 것으로, 동일성을 유지되는 경우에는 수리로서 특허권을 침해하지 않은 것으로 판단하고 있고, 부품 교체행위가 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에 해당하는지 여부는 당해 제품의 객관적 성질, 이용형태 및 특허법의 규정취지 등을 종합하여 판단하여야 한다고 하여 상표법에서의 판단기준과 동일한 판단기준을 제시함. 이는 본질적 부분의 교체라면 생산이 된다는 기존의 판례보다 수리의 범위를 조금 더 넓게 인정해 주려는 경향으로 파악됨</p> <p>2. 특허가 방법발명인 경우 - 특허가 방법의 발명에 관한 것일 때에는 「그 방법의 실시에만」 사용되는 「물건」을 업으로서 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위(法 127Ⅱ)이어야 한다.</p> <p>3. 「특허발명인 물건발명의 생산, 방법발명의 실시」에 사용되는지 여부(供用性) - 물건의 사용이 구성요소완비의 원칙에 의한 특허발명인 물건발명의 생산, 방법발명의 실시에 해당하는 경우뿐만 아니라 균등론에 의한 물건발명의 생산, 방법발명의 실시인 경우에도 실질적으로 특허발명을 생산, 실시한 것으로 볼 수 있기 때문에 간접침해를 긍정해야 한다(2016나1011).</p> <p>4. 「에만」에 사용되는지 여부(專用性)</p> <p>① 「...에만」이란 「해당발명 A에 있어서 사용하는 물건 B가 해당발명 이외의 타용도를 갖고 있지 않다는 것」을 의미한다. 「타용도」가 무엇인가에 대하여는 여러 가지 학설이 있지만, 가능성만으로는 부족하고 상업적·경제적 내지 실용적으로 타용도로 사용하고 있어야 한다는 經濟的·商業的·實用的 使用事實說이 타당하다.</p> <p>② 한편, 타용도가 없음은 특허권자가 주장·증명하여야 한다(98후2580). 그러나, 그 자체로 범용성(汎用性)이 있는 물건이 아닌 한 특허발명인 물건발명의 생산이나 방법발명의 실시에 사용하는 물건이라는 점이 증명된 후 실시자가 그 물건에 타용도가 있음에 관하여 구체적이고 합리성이 있는 주장을 하는 경우에 한하여 그 증명책임이 현실화된다고 봄이 상당하다. 이 경우 특허권자는 실시자가 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는다는 점을 증명하여야 할 것이다(2016허7305).</p> <p>③ 물건의 용도는 시간의 경과에 따라 변할 수 있으므로 타용도의 유무 판단은 해당 행위로 해석하는 것이 타당함</p> <p>5. 「물건」에 해당하는지 여부</p> <p>① 특허된 물건의 생산에만 사용하거나 방법의 실시에만 사용하는 「물건」이 특허발명의 출원 시점에서 공지되어 있는 경우 자유기술의 영역이라고 할 수 있고, 타용도가 없다고 말할 수 없기 때문에 간접침해가 아니다(2000다27602).</p> <p>② 물건을 개선하여 특허성이 있더라도 간접침해의 성립에는 영향×(98후2580).</p> |

|             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                  | <p>③ 특허된 물건의 생산에만 사용하거나 방법의 실시에만 사용하는 물건과 동일한 물건뿐만 아니라 균등한 물건인 경우에도 간접침해가 성립(2006허6679)</p> <p>④ 확인대상발명인 물건에 다른 구성요소를 부가하여 그 다른 구성요소로 인해 타용도를 창출해 낸 경우라고 하더라도 간접침해가 성립(2011가합39552).</p>                                                                                                                                                                                    |
|             | <b>직접침해와의 관계</b> | <p>1. 특허발명의 실시를 국외에서 하여 직접침해가 아닌데, 그 자에게 국내에서 간접침해행위에 해당하는 물건을 생산하여 양도 등을 하는 행위는 비침해(종속설)</p> <p>2. 최종 특허발명의 실시를 업이 아닌 개인적, 가정적으로 유도하여 직접침해가 아닌데, 그 자에게 간접침해행위에 해당하는 물건을 생산하여 양도 등을 하는 행위는 침해(독립설)</p> <p>3. 실시권, 권리소진설이 적용되는 물건 등과 같이 정당한 권원을 가진 자가 특허발명을 실시하거나 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(法 96) 등에서 특허발명을 실시하여 직접침해가 아닌데, 그 자에게 간접침해행위에 해당하는 물건을 생산하여 양도 등을 하는 행위는 비침해(종속설)</p> |
| <b>조치</b>   | <b>민사적 조치</b>    | <p>1. 침해금지청구권의 행사 - 변론 종결시를 기준으로 타용도가 없다면 행사 가능</p> <p>2. 손해배상청구권인정여부 - 특허권자·전용실시권자가 손해의 발생 및 손해액을 증명하는 경우에는 손해배상청구권을 행사할 수 있을 것이다.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | <b>형사적 조치</b>    | 직접침해의 미수단계도 처벌되지 아니한데 미수의 전단계로서 예비적 행위인 간접침해를 처벌되지 말아야 하며, 죄형법정주의원칙상 형벌의 대상에서는 제외되는 것이 타당(92도3350).                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>관련문제</b> | <b>자유기술의 항변</b>  | 판례(2008허4523)는 간접침해에 있어서도 자유기술의 항변을 인정하되, 확인대상발명은 간접침해 대상 물건인 부품이 아닌 권리자가 특정한 부품이 결합된 전체라는 판단기준을 제시함                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | <b>보상금 청구권</b>   | 특허출원된 발명의 간접침해에 해당하는 물건을 출원공개 후 제3자가 정당한 권원없이 실시하고 있는 경우에는 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 설정등록시까지의 기간동안 그 특허발명의 실시예 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다(法 65⑤).                                                                                                                                                                                                                 |
|             | <b>권리소진</b>      | 방법의 발명에 대한 특허권자가 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 양도한 경우 특허권은 소진됨. 공유자 중 1인이 다른 공유자의 동의없이 물건을 양도한 경우에는 특허권이 소진되지 않음(2008허13299).                                                                                                                                                                                                                                                  |

**VIII 특허출원된 발명을 제3자가 실시하고 있을 때 출원인 및 제3자의 대응방안**

| 구 분      |     | 출원인의 조치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 제3자의 조치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 침해여부의 판단 |     | ① 특허권 존속 중 ② 정당한 권원없이 ③ 특허발명의 보호범위에 속하는 확인대상발명을 ④ 업으로서 실시했는지 판단                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 조치       | 침해  | <p>1. 특허권의 행사</p> <p>① 전제(조기권리화 방안)</p> <p>    a 초기공개신청(法 64①)</p> <p>    b 심사청구(法 59) 및 우선심사청구(法 61)</p> <p>② 행사</p> <p>    a 민사상 조치 (法 126, 128, 131, 민법 741)</p> <p>    b 형사상 조치(法 225, 231, 230)</p> <p>2. 보상금청구권의 행사</p> <p>① 전제</p> <p>    a 초기공개신청(法 64①)</p> <p>    b 경고(法 65①)</p> <p>② 행사</p> <p>    a 보상금액(法 65②)</p> <p>    b 행사시기(法 65③)</p> <p>    c 독립성(法 65④)</p> <p>    d 준용규정(法 65⑤)</p> <p>    e 소멸(法 65⑥)</p> <p>3. 기타</p> <p>① 적극적 권리범위확인심판 청구</p> <p>② 실시권 설정</p> <p>③ 크로스 라이선스 청구</p> | <p>1. 특허권의 유효성 검토</p> <p>2. 특허요건의 흠결이 있는 경우(심사관여방안)</p> <p>    ① 심사청구(法 59) 및 우선심사신청(法 61)</p> <p>    ② 정보제공(法 63의2)</p> <p>    ③ 특허취소신청(法 132의3)</p> <p>    ④ 특허무효심판청구(法 133)</p> <p>3. 특허요건의 흠결이 없는 경우</p> <p>    ① 실시중지</p> <p>    ② 정당한 권원 획득 후 실시</p> <p>        a 특허를 받을 수 있는 권리의 양수·특허권의 양수 또는 실시권 설정</p> <p>        b 통상실시권허락심판 청구(法 138①②)</p> <p>    ③ 회피설계(Design-Around) 실시</p> <p>    ④ 대응특허 매입하고 역경고</p> <p>참고) 제3자의 특허무효심판 청구에 대한 대응방안</p> <p>1. 특허무효심판청구의 타당성 판단(이해관계 여부, 무효사유 존재 여부 등)</p> <p>2. 심판청구가 타당○</p> <p>    ① 정정심판의 청구</p> <p>    ② 특허의 정정</p> <p>3. 심판청구가 타당×</p> <p>    ① 심판절차에 적극 관여</p> |
|          | 비침해 | 아무런 조치도 취할 수 없다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>1. 상대방의 조치에 대한 적극적 대응(예를 들면, 경고에 대한 대응으로는 답변서 제출) - 무효의 항변, 권리남용의 항변 등</p> <p>2. 소극적 권리범위확인심판 청구</p> <p>3. 별도의 소제기(예를 들어, 선사용권 확인의 소)</p> <p>4. 소송절차의 중지 신청</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## 참고자료 5.1 특허요건 판단과 침해 성립요건 판단의 구별

### 1. 구별의 필요성

발명을 완성한 후 특허출원하였을 때 특허를 받을 수 있는지 여부인 특허요건 판단과 발명을 실시하는 것이 타인의 특허를 침해하는 것인지 여부인 침해 성립요건 판단은 전혀 별개의 문제라고 할 수 있다. 특허요건 판단은 선행기술과의 관계에서 특허출원한 발명이 동일성, 용이성이 있는지 여부를 판단하는 것이지만, 침해 성립요건 판단은 선행특허와의 관계에서 특허를 받은 발명의 실시가 구성요소완비의 원칙과 균등론의 적용에 의하여 선행특허의 보호범위에 속하는지 여부를 판단하는 것이기 때문이다. 이것은 디자인이나 상표가 등록요건 판단과 침해 성립 요건 판단이 대체로 비슷한 점에 비추어 봤을 때 특허의 가장 큰 차이점이라 할 수 있다.

### 2. 구체적 예

#### (1) 서 설

「a+b+c」가 출원되어 출원공개 또는 등록공고된 특허발명이라는 가정하에 「a+b」, 「a+b'+c」, 「a+b+c+d」 발명을 출원하였을 때 특허를 받을 수 있는지 여부와 실시가 「a+b+c」의 특허발명을 침해하는지 여부에 대하여 구체적으로 검토해 본다.

#### (2) 「a+b」와 관련하여

##### ① 특허를 받을 수 있는지 여부

소기재 광범위의 원칙에 따라 「a+b」는 「a+b+c」보다 상위개념발명이기 때문에 「a+b+c」의 공개시 또는 출원일보다 후출원한 경우 동일성과 관련된 특허요건인 신규성(法 29①각호), 확대된 선출원(法 29③④) 또는 선출원주의(法 36)의 위반으로 특허를 받을 수 없다.

##### ② 침해인지 여부

「a+b」를 실시하더라도 구성요소완비의 원칙에 의할 경우 일반적으로 「a+b+c」의 보호범위에 속하지 않아 「a+b+c」의 침해가 아니다. 다만, 「a+b」가 「a+b+c」의 생산에만 사용되는 물건에 해당하는 경우 간접침해일 수 있다.

#### (3) 「a+b+c+d」와 관련하여

##### ① 특허를 받을 수 있는지 여부

다기재 협범위의 원칙에 따라 「a+b+c+d」는 「a+b+c」보다 하위개념발명이기 때문에 「a+b+c」와 관련하여 동일성 위반이 아니다. 다만, 「a+b+c」의 공개시 이후에 출원한 경우 진보성이 있는지 문제가 된다. 구성요소 「d」의 결합에 채택과 결합의 곤란성이 있다면 진보성이 있기 때문에 출원발명은 다른 거절이유가 없는 한 특허를 받을 수 있다.

##### ② 침해인지 여부

「a+b+c+d」를 실시하는 경우 구성요소완비의 원칙에 의할 경우 「a+b+c」의 보호범위에 속하게 되어 「a+b+c+d」의 실시자에게 정당한 권원이 없다면 「a+b+c」의 침해가 된다. 한편, 만약 「a+b+c+d」가 등록이 되었다면 이를 이용관계라 한다.

#### (4) 「a+b'+c」와 관련하여

##### ① 특허를 받을 수 있는지 여부

1) 「b」와 「b'」의 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면(선출원주의에서는 그 차이가 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용 효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우라면) 서로 실질적으로 동일성이 있어서 신규성(法 29①각호), 확대된 선출원(法 29③④) 또는 선출원주의(法 36)의 위반으로 특허를 받을 수 없다.

2) 한편, 「a+b'+c」가 동일성 위반이 아니더라도 「a+b+c」의 공개시 이후에 출원되었다면 진보성이 있어야 특허를 받을 수 있다.

##### ② 침해인지 여부

「a+b'+c」가 「a+b+c」와 관련하여, i) b와 b'의 변경이 있는 경우에도 과제의 해결원리가 동일할 것, ii) b를 b'로의 변경에 의하더라도 a+b+c와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낼 것, iii) b를 b'로의 변경이 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도일 것이어야 하고, iv) a+b'+c가 특허발명인 a+b+c의 출원 시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나 v) a+b+c의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 변경된 구성요소 b'가 청구범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특별한 사정이 없는 경우 「a+b+c」의 균등물이 되어 「a+b+c」의 보호범위에 속하게 되고 「a+b'+c」의 실시자에게 정당한 권원이 없다면 「a+b+c」의 침해가 된다.

IX 특허요건 판단과 침해 성립요건 판단의 구별

| 구 분   |          | 특허발명  | 확인대상발명  | 침해 성립요건 판단                                                                        | 특허요건 판단                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AER   | 부가<br>법칙 | a+b+c | a+b+c   | 침해                                                                                | 동일성이 있어 등록불가(法 29①·29③④·36 위반)                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |          |       | a+b+c+d | 침해                                                                                | 공개 전 출원은 등록가능하고, 공개 후 출원이라면 진보성이 있는 경우 등록가능(등록된 경우 이를 이용 관계라 함)                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 생략<br>법칙 | a+b+c | a+b     | 1. 원칙 → 비침해<br>2. 예외 → 간접침해                                                       | 동일성이 있어 등록불가(法 29①·29③④·36 위반)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 균 등 론 |          | a+b+c | a+b+c'  | 1. 침해<br>(1) 과제해결원리○<br>(2) 변경가능성○<br>(3) 변경용이성○<br>(4) 특별사정 ×<br>2. 그렇지 아니하면 비침해 | 1. 구성의 차이가 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경에 불과하고 새로운 효과도 발생하지 아니한 경우라면(선출원주의에서는 그 차이가 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용 효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우라면) 실질적 동일성이 있어 등록불가(法 29①·29③④·36 위반)<br>2. 구성의 곤란성이 없고 효과의 현저성이 없어서 용이하다면, 공개 전 출원은 등록가능하고 공개 후 출원이라면 진보성 위반으로 등록불가<br>3. 그렇지 아니하면 등록가능 |



# 46

## 벌칙(法 225~232)

### I 법조문

#### 제225조 【침해죄】(★) 法 230, 231 / 127

- ① (요건 및 처벌) 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.
- ② (반의사불벌죄) 제1항의 죄는 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소(公訴)를 제기할 수 없다. <개정 2020. 10. 20.>  
[전문개정 2014.6.11.]

#### 제226조 【비밀누설죄 등】

- ① (지식재산처, 특허심판원 소속 직원 등) 지식재산처 또는 특허심판원 소속 직원이거나 직원이었던 사람이 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2021. 4. 20.>
- ② (전문심리위원) 전문심리위원 또는 전문심리위원이었던 자가 그 직무수행 중에 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하는 경우에는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <신설 2021. 4. 20.> 法 164의2, 226의2②  
[전문개정 2014. 6. 11.]

#### 제226조의2 【전문기관 등의 임직원에 대한 공무원 의제】

- ① (전문기관 또는 전담기관 임직원의 지식재산처 소속 직원 의제) 제58조제2항에 따른 전문기관 또는 제58조제3항에 따른 전담기관의 임직원이거나 임직원이었던 사람은 제226조 제1항을 적용하는 경우에는 지식재산처 소속 직원 또는 직원이었던 사람으로 본다. <개정 2016. 12. 2., 2018. 4. 17., 2021. 4. 20., 2024. 2. 6.> 法 58의2①Ⅲ
- ② (전문심리위원의 공무원 의제) 전문심리위원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정[제129조(수뢰, 사전수뢰), 제130조(제삼자뇌물제공), 제131조(수뢰후부정처사, 사후수뢰), 제132조(알선수뢰)]을 적용할 때에는 공무원으로 본다. <신설 2021. 4. 20.> 法 164의2, 226②  
[전문개정 2014. 6. 11.]

#### 형법 제129조-제132조

##### 제129조(수뢰, 사전수뢰)

- ① 공무원 또는 중재인이 그 직무에 관하여 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 때에는 5년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지에 처한다.
- ② 공무원 또는 중재인이 될 자가 그 담당할 직무에 관하여 청탁을 받고 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 후 공무원 또는 중재인이 된 때에는 3년 이하의 징역 또는 7년 이하의 자격정지에 처한다.

##### 제130조(제삼자뇌물제공)

공무원 또는 중재인이 그 직무에 관하여 부정한 청탁을 받고 제3자에게 뇌물을 공여하게 하거나 공여를 요구 또는 약속한 때에는 5년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지에 처한다.

##### 제131조(수뢰후부정처사, 사후수뢰)

- ① 공무원 또는 중재인이 전2조의 죄를 범하여 부정한 행위를 한 때에는 1년 이상의 유기징역에 처한다.
- ② 공무원 또는 중재인이 그 직무상 부정한 행위를 한 후 뇌물을 수수, 요구 또는 약속하거나 제삼자에게 이를 공여하게 하거나 공여를 요구 또는 약속한 때에도 전항의 형과 같다.
- ③ 공무원 또는 중재인이었던 자가 그 재직 중에 청탁을 받고 직무상 부정한 행위를 한 후 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 때에는 5년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지에 처한다.
- ④ 전3항의 경우에는 10년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다.

##### 제132조(알선수뢰)

공무원이 그 지위를 이용하여 다른 공무원의 직무에 속한 사항의 알선에 관하여 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 때에는 3년 이하의 징역 또는 7년 이하의 자격정지에 처한다.

#### 제227조 【위증죄】

- ① (요건 및 처벌) 이 법에 따라 선서한 증인, 감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 거짓으로 진술·감정 또는 통역을 한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2017.3.21.>
- ② (감면) 제1항에 따른 죄를 범한 자가 그 사건의 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결이 확정되기 전에 자수한 경우에는 그

형을 감경 또는 면제할 수 있다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제228조 【허위표시의 죄】 法 230

제224조를 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2017.3.21.>

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제229조 【거짓행위의 죄】 法 230

거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2016.2.29., 2017.3.21.>

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제229조의2 【비밀유지명령 위반죄】

① (요건 및 처벌) 국내외에서 정당한 사유 없이 제224조의3제1항에 따른 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

② (친고죄) 제1항의 죄는 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없다.

[본조신설 2011.12.2.]

#### 제229조의3 【외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령 위반죄】

제41조제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

[본조신설 2025. 1. 21.]

#### 제230조 【양벌규정】(★)

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제225조제1항[**침해죄**], 제228조[**허위표시의 죄**], 제229조[**거짓행위의 죄**] 또는 제229조의3[**외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령 위반죄**]의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2025. 1. 21.>

1. 제225조제1항의 경우: 3억원 이하의 벌금
2. 제228조 또는 제229조의 경우: 6천만원 이하의 벌금
3. 제229조의3의 경우: 1억원 이하의 벌금

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제231조 【몰수 등】(★)

① (몰수) 제225조제1항에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.

② (초과손해액에 대한 배상청구) 피해자는 제1항에 따른 물건을 받은 경우에는 그 물건의 가액을 초과하는 손해액에 대해서만 배상을 청구할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제232조 【과태료】 法 125

① (대상) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 50만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 「민사소송법」 제299조제2항 및 같은 법 제367조에 따라 선서를 한 자로서 특허심판원에 대하여 거짓 진술을 한 자

##### 민사소송법 제299조제2항 및 제367조

##### 제299조(소명의 방법)

② 법원은 당사자 또는 법정대리인으로 하여금 보증금을 공탁하게 하거나, 그 주장이 진실하다는 것을 선서하게 하여 소명에 갈음할 수 있다.

##### 제367조(당사자신문)

법원은 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 당사자 본인을 신문할 수 있다. 이 경우 당사자에게 선서를 하게 하여야 한다.

2. 특허심판원으로부터 증거조사 또는 증거보전에 관하여 서류나 그 밖의 물건 제출 또는 제시의 명령을 받은 자로서 정당한 이유 없이 그 명령에 따르지 아니한 자 法 157, 222

3. 특허심판원으로부터 증인·감정인 또는 통역인으로 소환된 자로서 정당한 이유 없이 소환에 따르지 아니하거나 선서·진술·증언·감정 또는 통역을 거부한 자

② (부과 및 징수) 제1항에 따른 과태료는 대통령령[**질서위반행위규제법**]으로 정하는 바에 따라 지식재산청장이 부과 징수한다.

[전문개정 2014.6.11.]

## II 벌칙의 구별(法 225~232)

| 죄 명                                            | 구성요건                                                                                                                              | 처 별               |            | 반의사<br>불벌죄 | 친고죄 | 양벌<br>규정 | 비 고                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|-----|----------|-----------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                   | 징역/금고             | 벌금         |            |     |          |                                               |
| 침해죄<br>(法 225)                                 | 특허권 또는 전용실시권을 침해한자                                                                                                                | 7년이하<br>징역        | 1억원<br>이하  | ○          | ×   | ○        | 몰수* · 교부                                      |
| 비밀누설죄<br>(法 226,<br>226의2)                     | 지식재산처 또는 특허심판원 소속 직원이거나 직원 (전문기관 또는 전담기관의 임직원이거나 임직원이었던 사람 포함)이었던 사람이 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우 | 5년이하<br>징역        | 5천만원<br>이하 | ×          | ×   | ×        |                                               |
|                                                | 전문심리위원 또는 전문심리위원이었던 자가 그 직무수행 중에 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하는 경우                                                                          | 2년이하<br>징역/<br>금고 | 1천만원<br>이하 | ×          | ×   | ×        |                                               |
| 위증죄<br>(法 227)                                 | 이 법에 따라 선서한 증인·감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 허위의 진술·감정 또는 통역을 한 경우                                                                       | 5년이하<br>징역        | 5천만원<br>이하 | ×          | ×   | ×        | 특허취소신청에<br>대한 결정 또는<br>심결 확정전<br>자수시<br>감경·면제 |
| 허위표시죄<br>(法 228)                               | 허위표시의 금지(法 224)에 위반한 자                                                                                                            | 3년이하<br>징역        | 3천만원<br>이하 | ×          | ×   | ○        |                                               |
| 거짓행위죄<br>(法 229)                               | 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로써 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자                                                                  | 3년이하<br>징역        | 3천만원<br>이하 | ×          | ×   | ○        |                                               |
| 비밀유지명령<br>위반죄<br>(法 229의2)                     | 국내외에서 정당한 사유 없이 제224조의3 제1항에 따른 비밀유지명령을 위반한 자                                                                                     | 5년이하<br>징역        | 5천만원<br>이하 | ×          | ○   | ×        |                                               |
| 외국에의<br>특허출원 금지/<br>비밀취급명령<br>위반죄<br>(法 229의3) | 제41조제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 자                                                                                         | 5년이하<br>징역        | 5천만원<br>이하 | ×          | ×   | ○        | ×                                             |

\* 특허법은 필요적 몰수, 실용신안법은 임의적 몰수

# 47

## 특허권의 이전 및 공유(法 99, 99의2)

### I 법조문

#### 제99조 【특허권의 이전 및 공유 등】(★★) 法 37

- ① **(이전)** 특허권은 이전할 수 있다. 法 101① I
- ② **(공유)** 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다. 法 99의2③ / 100⑤ / 102⑦
- ③ **(공유)** 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다. 法 100⑤ / 102⑦
- ④ **(공유)** 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다. 法 100⑤

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제99조의2 【특허권의 이전청구】(★) 法 133① II 단서, 103의2 / 35 / 86③ II

- ① **(이전청구)** 특허가 제133조제1항제2호 본문【특허무효사유】에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.
- ② **(권리의 귀속시기)** 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다.
  1. 해당 특허권
  2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권
  3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구권
- ③ **(권리가 공유인 경우)** 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항【지분양도나 질권설정시 다른 공유자의 동의 필요】에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.

[본조신설 2016.2.29.]

## II 특허권의 이전(法 99①, 99의2)

| 구 분                        |                | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                             |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서                          | 의의             | 특허권의 주체인 특허권자를 변경하는 것을 말한다. 특허권의 이전은 주체의 변경으로서 상대적 소멸이라는 점에서 특허권이 절대적으로 소멸하는 무효심결의 확정 또는 특허권의 포기 등과 구별된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                             |
|                            | 취지             | 특허권의 재산권적 성질을 인정하고 일정절차에 의하여 특허권의 이전을 허용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                             |
| 요 건                        | 전부이전과 일부이전     | 이전범위에 따라 전부이전과 일부이전으로 나뉜다. 특허권의 일부이전은 특허권의 지분의 양도를 의미하는 것이며, 특허발명 중의 일부발명 또는 일부청구항의 이전을 의미하는 것은 아니다. 이는 설정등록 후에는 청구항별 일부이전이 허용되지 아니하기 때문이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                             |
|                            | 특정승계와 일반승계     | 매매·증여 등과 같이 개개의 권리가 개개의 취득원인에 의하여 취득되는 「특정승계」와 상속·포괄유증·회사의 합병 등과 같이 하나의 취득원인에 의하여 다수의 권리가 일괄해서 취득되는 「일반승계」로 나뉜다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                             |
| 절 차                        | 신청             | 1. 공동신청의 원칙 - 특허권을 이전하려는 자는 이전등록신청서를 지식재산처장에게 제출하여야 하며(登録令 24 ①), 이전등록 신청은 등록권리자와 등록의무자가 공동으로 신청함을 원칙으로 한다(登録令 15①).<br>2. 단독신청의 경우 - 등록의무자의 승낙서를 첨부하거나(登録令 15②) 판결 또는 상속이나 그 밖의 일반 승계의 경우에는 등록권리자 단독으로 이전등록신청을 할 수 있다(登録令 16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                             |
|                            | 직권·촉탁          | 지식재산처장은 특허권의 수용의 경우 직권으로 등록을 행하며(登録令 14), 일정한 경우 법원 등의 촉탁에 의하여 등록을 행한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                             |
| 효 과                        | 이전의 효력발생       | 1. 특정승계의 경우 - 특허권의 이전은 특허 등록원부에 등록하여야만 그 효력이 발생한다(法 101①I). 즉 이전등록은 특허권 이전의 효력발생요건이다. 공시의 원칙에 기한 결과이지만, 공시의 원칙은 성립하지 아니한다. 다만, 공시의 원칙에 의하여 등록사항이 일응 진실한 권리관계와 일치한다고 추정될 뿐이다.<br>2. 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우 - 상속 또는 회사의 합병 등의 경우에 사망 또는 합병 등의 사실이 있으면 권리는 당연히 상속인 또는 흡수법인에 포괄적으로 이전되어 버리므로 그것만으로 권리이전의 효력이 발생한다. 다만 상속인이나 그 밖의 일반승계인은 지체없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다(法 101②).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                             |
|                            | 절차의 효력 승계 및 속행 | 1. 절차의 효력의 승계 - 특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 밟은 절차의 효력은 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에게 미친다(法 18).<br>2. 절차의 속행 - 지식재산처장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중일 때 특허권 또는 특허에 관한 권리가 이전되면 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 절차를 속행하게 할 수 있다(法 19).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                             |
| 관 련 문 제                    | 부수적 권리와 의 관계   | 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 비 고                                                                           |                                                                                                             |
|                            |                | 원 칙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. 이전되더라도 부수적인 권리는 소멸하지 않음<br>2. 특허권의 이전등록 전에 미리 등록을 하였다면 새로운 특허권자에게 효력 주장 가능 | 법 제122조의 법정실시권자는 전 특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)에 한하여 부수적인 권리자는 법정실시권을 갖지 아니하여도 됨 |
|                            |                | 예 외                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 특허권이 수용된 경우 부수적인 권리의 소멸(法 106②)                                               | 실시권자는 보상받을 수 있으나(法 106③), 질권자는 물상대위(法 123) 가능하므로 보상받지 못함.                                                   |
| 질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권 |                | 특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 122).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                             |
| 이전청구와 법정실시권                |                | 1. 이전청구 - 특허가 i) 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나(法 33①본문) ii) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 공동출원하지 아니하여(法 44) 특허무효사유(法 133①II)에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다(法 99의2①).<br>2. 권리의 귀속시기 - 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 법원에의 이전청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 해당 특허권과 보상금 지급 청구권(法 65②, 207④)은 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다(法 99의2②).<br>3. 권리가 공유인 경우 - 이전청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 법 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다(法 99의2③).<br>4. 무효사유에서 제외 - 이전청구에 기초하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 이전등록(法 99의2)이 있으면 이전등록된 특허권(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)은 특허무효심판을 청구할 수 있는 대상에서 제외된다(法 133①II단서).<br>5. 특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권 - 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 특허권의 이전청구에 기초하여 특허권의 이전등록이 있기 전에(法 99의2②) 특허무효사유(法 133①II)에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 유상의 통상실시권을 가진다(法 103의2).<br>i) 이전등록된 특허의 원(原)특허권자<br>ii) 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자(다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다) |                                                                               |                                                                                                             |



### III 특허권의 공유(法 99②③④)

| 구 분 |             | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서   | 의의          | 하나의 특허권을 2명 이상이 지분에 의하여 공동으로 소유하는 것을 말한다. 특허권의 공유에 관하여는 민법의 공유규정이 준용되지만 특허권의 특수성을 고려하여 민법의 규정과는 다른 특별한 규정(法 99②③④)을 두어 공유 특허권자의 보호에 적정을 도모하고 있다. 특허권의 객체인 발명은 무형인 기술적 사상의 창작으로서 추상적인 것이어서 점유를 수반하지 않으므로 특허발명을 수인이 동시에 실시할 수 있는 등 유체재산권과는 다른 특수성을 지니고 있기 때문이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 성질          | 무체재산권인 특수성에 기인하여 일정범위(法 99②④)에 대해서는 합유와 유사한 성질을 보이나, 특허권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 특허권의 공유에도 특허법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다고 할 것이다(2002후567).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 발생  |             | ① 공동발명하여 공동출원에 의한 경우, 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 이전 등과 같이 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인들 그대도 등록된 경우와 ② 질권에 의한 특허권 지분의 경락, 특허권의 일부 이전 등과 같이 등록 후 특허권이 공유가 된 경우가 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 효 력 | 실시          | 1. 공유발명 전체 실시 - 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 지분비율에 관계없이 그 특허발명 전체를 자신이 실시할 수 있다(法 99③). 공유자 중 일부가 특허발명을 실시하여 이익을 얻은 경우 지분의 효과가 발생하지 아니하기 때문에 특약이 없는 한 실시자의 전속적인 재산으로 귀속<br>2. 이용발명 - 공유자 일부가 이용발명을 하여 특허권을 획득한 경우 이용발명을 한 공유자는 특약이 없는 한 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 이용발명을 실시할 수 있다. 이는 공유자 일부가 이용발명을 한 경우에는 법 제98조의 「타인」이 아니므로 법 제98조가 적용되지 아니하기 때문이다.<br>3. 1기판의 범위 - 「1기판의 범위」에 해당하기 위한 요건은 i) 계약관계가 존재하고, ii) 실질적으로 그 공유자가 하청업자를 감독·지휘해야 하고, iii) 생산된 물품이 전부 공유자에게 인도되어야 한다. 만약 위 조건이 성립되지 아니한다면, 공유자의 하청을 받은 자의 실시행위는 다른 공유자의 동의가 없는 한 특허권의 침해에 해당한다.                                                                                                                                                                                                |
|     | 지분양도 및 질권설정 | 1. 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다(法 99②). 공유자는 자신의 지분비율과 관계없이 특허발명 전체를 실시할 수 있어 새로운 공유자로 된 자의 자본력·기술력·신용력 여하에 따라 다른 공유자의 이해관계에 영향을 미치기 때문이다.<br>2. 공유자 사이의 지분양도는 단지 공유자간의 지분변동에 불과하고, 다른 공유자의 이익을 해하는 것이 아니기 때문에 다른 공유자의 동의를 얻을 필요가 없다. 또한, 상속에 의한 특허권의 지분 이전은 다른 공유자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없기 때문에 다른 공유자의 동의를 받지 않아도 무방하다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 실시권 설정      | 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다(法 99④). 이러한 제한에 위반된 실시권은 무효이므로 무효인 실시권에 기한 실시는 정당한 권원이 없는 자의 실시가 되고, 따라서 특허권의 침해를 구성한다고 본다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 기타          | 1. 존속기간연장등록출원의 제한 - 특허권이 공유인 경우에는 모두가 출원을 하여야 하며 그렇지 아니한 경우 거절이유(法 91, 92의4), 무효사유(法 134①)이다.<br>2. 심판청구의 제한 - 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여 청구하여야 하며, 특허권의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(法 139②③). 이에 위반된 경우 부적법한 심판청구로서 심판관 합의체는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 심결로써 이를 각하할 수 있다(法 142).<br>3. 침해에 대한 문제<br>① 침해금지청구권 - 보존행위이기 때문에 지분에 기하여 단독으로 특허권 전체에 대하여 행사 가능<br>② 손해배상청구권 - 가분채권이기 때문에 지분비율에 따른 손해액의 청구를 하는 손해배상 청구 가능<br>4. 심결취소의 소 제기 - 공유자 1인이 원고 가능, 단 피고일 때는 전원<br>5. 분할청구<br>① 특허권은 무체재산권이기 때문에 분할방식은 특허권의 처분에 따른 대금분할방식에 의해야만 함.<br>② 공유인 특허권의 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자가 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 나머지 공유특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 122). |
| 소멸  |             | 공유관계는 특허권 자체의 소멸, 수용, 지분의 포기로 공유자 1인만이 남는 경우 또는 공유자 중 1인이 다른 공유자의 지분을 모두 양수한 때 또는 공유 특허권을 제3자에게 양도한 경우에 소멸한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# 48

## 실시권 일반(法 100~102, 118)

### I 법조문

#### 제100조 【전용실시권】 法 102

- ① (발생) 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다. 法 119①Ⅰ, 136⑧
- ② (효력) 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.
- ③ (변동: 이전) 전용실시권자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 이전할 수 있다.
  1. 전용실시권을 실시사업(實施事業)과 함께 이전하는 경우
  2. 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우
- ④ (변동: 질권설정·통상실시권 허락) 전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다. 法 119①Ⅲ, 136⑧ / 119②
- ⑤ (공유) 전용실시권에 관하여는 제99조제2항부터 제4항[특허권의 공유]까지의 규정을 준용한다.  
[전문개정 2014.6.11.]

#### 제101조 【특허권 및 전용실시권의 등록의 효력】 法 28② / 118

- ① (등록의 효력) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.
  1. 특허권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다), 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한 法 87①Ⅰ
  2. 전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한
  3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한
- ② (상속 기타 일반승계) 제1항 각 호에 따른 특허권·전용실시권 및 질권의 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 지체 없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다.  
[전문개정 2014.6.11.]

#### 제102조 【통상실시권】 法 100

- ① (발생) 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다. 法 119①Ⅳ, 136⑧ / 119②
- ② (효력) 통상실시권자는 이 법에 따라 또는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 가진다.
- ③ (변동: 재정실시권의 이전) 제107조에 따른 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있다.
- ④ (변동: 통상실시권허락심판에 의한 실시권의 이전) 제138조, 「실용신안법」 제32조 또는 「디자인보호법」 제123조에 따른 통상실시권은 그 통상실시권자의 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권과 함께 이전되고, 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권이 소멸되면 함께 소멸된다.
- ⑤ (변동: 이전) 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 이전할 수 있다.
- ⑥ (변동: 질권설정) 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.
- ⑦ (공유) 통상실시권에 관하여는 제99조제2항 및 제3항[특허권의 공유, 실시권 제외]을 준용한다.  
[전문개정 2014.6.11.]

#### 제118조 【통상실시권의 등록의 효력】(★) 法 28② / 101

- ① (설정등록의 효력) 통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다.
- ② (법정실시권 설정등록 不要) 제81조의3제5항, 제103조부터 제105조까지, 제122조, 제182조, 제183조 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권은 등록이 없더라도 제1항에 따른 효력이 발생한다.
- ③ (그 밖의 등록의 효력) 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다.  
[전문개정 2014.6.11.]



## II 전용실시권과 통상실시권의 법조문 비교

| 비교     | 전용실시권                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 통상실시권                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일반론    | <p><b>제100조 【전용실시권】</b></p> <p>① (발생) 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다.</p> <p>② (효력) 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.</p> <p>③ (변동: 이전) 전용실시권자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 이전할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 전용실시권을 실시사업(實施事業)과 함께 이전하는 경우</li> <li>2. 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우</li> </ol> <p>④ (변동: 질권설정·통상실시권 허락) 전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.</p> <p>⑤ (공유) 전용실시권에 관하여는 제99조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.</p>               | <p><b>제102조 【통상실시권】</b></p> <p>① (발생) 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다.</p> <p>② (효력) 통상실시권자는 이 법에 따라 또는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 가진다.</p> <p>③ (변동: 재정실시권의 이전) 제107조에 따른 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있다.</p> <p>④ (변동: 통상실시권허락심판에 의한 실시권의 이전) 제138조, 「실용신안법」 제32조 또는 「디자인보호법」 제123조에 따른 통상실시권은 그 통상실시권자의 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권과 함께 이전되고, 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권이 소멸되면 함께 소멸된다.</p> <p>⑤ (변동: 이전) 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 이전할 수 있다.</p> <p>⑥ (변동: 질권설정) 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.</p> <p>⑦ (공유) 통상실시권에 관하여는 제99조제2항 및 제3항을 준용한다.</p> |
| 등록의 효력 | <p><b>제101조 【특허권 및 전용실시권의 등록의 효력】</b></p> <p>① (등록의 효력) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 특허권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다), 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한</li> <li>2. 전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한</li> <li>3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한</li> </ol> <p>② (상속이나 그 밖의 일반승계) 제1항 각 호에 따른 특허권·전용실시권 및 질권의 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 지체 없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다.</p> | <p><b>제118조 【통상실시권의 등록의 효력】</b></p> <p>① (설정등록의 효력) 통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다.</p> <p>② (법정실시권 설정등록 不要) 제81조의3제5항, 제103조부터 제105조까지, 제122조, 제182조, 제183조 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권은 등록이 없더라도 제1항에 따른 효력이 발생한다.</p> <p>③ (그 밖의 등록의 효력) 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

III 실시권 일반(法 100~102, 118)

| 권 리  | 전용실시권                                                                                                                                                                          | 통상실시권                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                | 허락실시권                                                                 | 법정실시권                                                                                                                                           | 강제실시권                                                                   |
| 의 의  | 특허권자 이외의 자가 설정행위로 정한 범위에서 독점·배타적으로 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리                                                                                                                      | 특허권자 이외의 자가 이 법에 따라 또는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리           |                                                                                                                                                 |                                                                         |
| 성 질  | 부수적, 물권적                                                                                                                                                                       | 부수적, 채권적                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                         |
| 발 생  | 계약 + 등록                                                                                                                                                                        | 계약                                                                    | 법률 규정 만족                                                                                                                                        | 법률 규정 만족 + 행정처분                                                         |
| 효 력  | 효력범위                                                                                                                                                                           | 설정행위로 정한 범위                                                           |                                                                                                                                                 | 법률 규정에 의하여 정한 범위                                                        |
|      | 효력내용                                                                                                                                                                           | 1. 특허발명을 실시 가능<br>2. 타인의 실시 금지 가능                                     |                                                                                                                                                 | 1. 특허발명을 실시 가능<br>2. 타인의 실시 금지 불가능                                      |
| 변 동  | 이 전                                                                                                                                                                            | 사업과 함께, 상속이나 그 밖의 일반승계, 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의 |                                                                                                                                                 |                                                                         |
|      | 실시권허락                                                                                                                                                                          | 특허권자의 동의                                                              | 불가                                                                                                                                              |                                                                         |
|      | 질권설정                                                                                                                                                                           | 특허권자의 동의                                                              | 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의                                                                                                   | 1. 제106조의2 → 학설 대립<br>2. 제107조, 제138조 → 불가                              |
|      | 특허권포기                                                                                                                                                                          | 동의권 ○                                                                 | 직무발명에 대한 통상실시권자만 동의권 ○                                                                                                                          | 동의권 ×                                                                   |
|      | 실시권포기                                                                                                                                                                          | 통상실시권자, 질권자의 동의                                                       | 질권자의 동의                                                                                                                                         |                                                                         |
| 소 멸  | 일반                                                                                                                                                                             | 특허권의 소멸(전용실시권에 대한 허권의 수용, 혼동)                                         | 통상실시권의 경우에는 전용실시권 또는 특허권의 소멸, 실시권의 포기, 특허권의 수용, 혼동                                                                                              |                                                                         |
|      | 특수                                                                                                                                                                             | 설정기간 만료, 설정계약의 해지                                                     | 제105조, 제122조, 발진법 제10조제1항을 제외하고는 실시사업의 폐지                                                                                                       | 1. 제106조의2 → 지식재산 처장 결정취소<br>2. 제107조 → 재정의 취소나 실효<br>3. 제138조 → 원권리 소멸 |
| 대 가  | 약정시 정한 대가                                                                                                                                                                      |                                                                       | 제103조, 제105조(디자인권자), 제182조, 발진법 제10조제1항을 제외하고는 대가 지급                                                                                            | 행정처분시 정한 대가                                                             |
| 등록효과 | 전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한, 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한은 등록이 효력발생요건 |                                                                       | 1. 통상실시권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 등록이 대항요건<br>2. 법정실시권은 설정등록없이도 대항가능<br>3. 강제실시권의 설정등록은 지식재산처장의 직권등록사항 |                                                                         |

# 49

## 법정실시권(法 81의3⑤, 103~105, 122, 182, 183, 발진법 10)

### I 법조문

#### 제81조의3 【특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원과 특허권의 회복 등】(★★)

- ① **(회복요건: 등록료, 유지료)** 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 정당한 사유로 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 그 특허료를 내거나 보전할 수 있다. 다만, 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.>
- ② **(회복효과)** 제1항에 따라 특허료를 내거나 보전한 자는 제81조제3항에도 불구하고 그 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.
- ③ **(회복요건2: 유지료)** 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허발명의 특허권이 소멸한 경우 그 특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부터 3개월 이내에 제79조에 따른 특허료의 2배를 내고, 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다. **(회복효과)** 이 경우 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.
- ④ **(효력제한)** 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원 또는 특허권의 효력은 추가납부기간 또는 보전기간이 지난 날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간(이하 이 조에서 "효력제한기간"이라 한다) 중에 타인이 특허출원된 발명 또는 특허발명을 실시한 행위에 대해서는 그 효력이 미치지 아니한다.
- ⑤ **(법정실시권의 발생)** 효력제한기간 중 국내에서 선의로 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원된 발명 또는 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명 또는 특허발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다. **法 118②③**
- ⑥ **(법정실시권의 대가)** 제5항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.
- ⑦ 제1항 본문에 따른 납부나 보전 또는 제3항 전단에 따른 신청에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

[시행일:2014.6.11.] 제81조의3제3항

[시행일:2015.1.1.] 제81조의3

#### 제103조 【선사용에 의한 통상실시권】(★★) **法 96①Ⅲ / 118②③**

특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제103조의2 【특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권】(★★) **法 99의2 / 133①Ⅱ단서 / 118②③**

- ① **(성립요건 및 효력)** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제99조의2제2항에 따른 특허권의 이전등록이 있기 전에 해당 특허가 제133조제1항제2호 본문(특허무효사유)에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1. 이전등록된 특허의 원(原)특허권자
2. 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.

- ② **(대가)** 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 이전등록된 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

[본조신설 2016.2.29.]

#### 제104조 【무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권】(★★) **法 118②③**

- ① **(성립요건 및 효력)** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하

거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.

<개정 2016.2.29.>

1. 동일한 발명에 대한 둘 이상의 특허 중 그 하나의 특허를 무효로 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자
2. 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우 그 무효로 된 실용신안등록의 원(原)실용신안권자
3. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자 **法 35 / 133①II**
4. 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 실용신안의 원실용신안권자 **法 35 / 133①II**
5. 제1호부터 제4호까지의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.

- ② **(대가)** 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제105조 【디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권】(★★) **法 98 / 118②③**

- ① **(성립요건 및 효력: 원디자인권자)** 특허출원일 전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원되어 등록된 디자인권이 그 특허권과 저촉되는 경우 그 디자인권의 존속기간이 만료될 때에는 그 디자인권자는 그 디자인권의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 그 디자인권의 존속기간 만료 당시 존재하는 그 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.
- ② **(성립요건 및 효력: 등록된 실시권자(단, 법정실시권 등록 不要))** 특허출원일 전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원되어 등록된 디자인권이 그 특허권과 저촉되는 경우 그 디자인권의 존속기간이 만료될 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 권리를 가진 자는 원(原)권리의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 그 디자인권의 존속기간 만료 당시 존재하는 그 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1. 그 디자인권의 존속기간 만료 당시 존재하는 그 디자인권에 대한 전용실시권

2. 그 디자인권이나 그 디자인권에 대한 전용실시권에 대하여 「디자인보호법」 제104조제1항에 따라 효력이 발생한 통상실시권

- ③ **(대가)** 제2항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제122조 【질권행사 등으로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권】(★★)

특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다. <개정 2021. 10. 19.>

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제182조 【재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권】(★★) **法 181 / 118②③**

제181조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해당 특허최소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 실시하고 있거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 통상실시권을 가진다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제183조 【재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권】(★★) **法 98, 138 / 118②③**

- ① **(성립요건 및 효력)** 제138조제1항 또는 제3항에 따라 통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후 재심에서 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우에는 재심청구 등록 전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 원(原)통상실시권의 사업목적 및 발명의 범위에서 그 특허권 또는 재심의 심결이 확정된 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.

- ② **(대가)** 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 발명진흥법 제10조 【직무발명】

- ① **(법정실시권의 성립요건)** 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다. 다만, 사용자 등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아

닌 기업인 경우 종업원 등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013.7.30>

1. 종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자 등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정
2. 종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정

② **(공무원의 직무발명의 승계 및 소유)** 제1항에도 불구하고 공무원 또는 국가나 지방자치단체에 소속되어 있으나 공무원이 아닌 자(이하 “공무원등”이라 한다)의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계할 수 있으며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원등의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교(이하 “국·공립학교”라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계할 수 있으며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권 등은 그 전담조직의 소유로 한다. <개정 2021. 4. 20>

③ **(예약승계)** 직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.

④ **(국유특허권의 처분 및 관리)** 제2항에 따라 국유로 된 특허권 등의 처분과 관리(특허권 등의 포기를 포함한다)는 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 지식재산처장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2009.1.30., 2010.1.27>



## II 법정실시권의 성립요건 및 효력

| 유 형                 |            | 성립요건                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 효력범위                                                                                                                            | 효력<br>내용  |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 특수한<br>경우<br>(규칙×)  | 發振法<br>10① | 1. 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명하였을 것<br>2. 성질상 사용자 등의 업무범위에 속할 것<br>3. 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거에 직무에 속할 것<br>4. 종업원 등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 것<br>5. 사용자 등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원 등과의 협의를 거쳐 미리 예약승계에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하였을 것                                                                                                                                                                                                                                                                   | 특허발명 전체                                                                                                                         |           |
|                     | 法 105      | 1. 특허출원일 전 또는 같은 날에 출원되어 등록되었을 것<br>2. 디자인권이 특허권과 저촉될 것<br>3. 존속기간 만료로 소멸할 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. 디자인권자 → 원디자인권<br>의 범위<br>2. 등록된 실시권자(단, 법정실시<br>권은 등록불요) → 원실시권<br>의 범위                                                      |           |
|                     | 法 122      | 1. 특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한<br>공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)가 특허권을 목적<br>으로 하는 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구이전에<br>그 특허발명을 실시하고 있을 것<br>2. 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전될 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 특허발명전체<br>(무제한설이 통설)                                                                                                            |           |
| 일반적인<br>경우<br>(규칙○) | 시기적        | 1. 제81조의3제5항 → 효력제한기간중(추가납부기간 또는 보전<br>기간이 경과한 날로부터 납부하거나 보전한 날)<br>2. 제103조 → 특허출원 시<br>3. 제103조의2 → 특허권의 이전등록이 있기 전<br>4. 제104조 → 무효심판청구의 등록전에<br>5. 제182조 → ① 무효가 된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우,<br>② 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후<br>재심에 의하여 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우, ③ 거<br>절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속<br>기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는<br>특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우 및 ④ 취소된 특허권<br>이 재심에 의하여 회복된 경우 중 어느 하나에 해당하는 심결/<br>결정이 확정후 재심청구등록전<br>6. 제183조 → 통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후 재<br>심에 의하여 이에 상반되는 심결의 확정이 있는 경우에 심<br>결확정후 재심청구등록전 | 1. 제81조의3제5항, 제103조,<br>제103조의2, 제104조, 제<br>182조 → 실시 또는 준비를<br>하고 있는 발명 및 사업목적<br>의 범위<br>2. 제183조 → 원통상실시권의<br>사업목적 및 발명의 범위 | 통상<br>실시권 |
|                     | 주체적        | 1. 선의일 것<br>2. 선의의 해석<br>① 제103조 → 그 특허출원된 발명의 내용의 알지 못하고 그<br>발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 된 자<br>② 제103조의2<br>- 제33조제1항본문, 제44조 위반의 무효사유에 해당하는<br>것을 알지 못하고<br>- 취득할 수 있는 자(法 103의2①각호)에 해당<br>③ 제104조<br>- 제29조제1항각호, 제29조제3항, 제36조, 제33조제1항 본<br>문 위반의 무효사유에 해당되는 것을 알지 못하고<br>- 취득할 수 있는 자(法 104①각호)에 해당                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |           |
|                     | 지역적        | 국내                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |           |
|                     | 객체적        | 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있을 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |           |
|                     | 대 가        | 발명진흥법 제10조제1항, 제103조, 제105조(원디자인권자에 한함), 제182조의 경우 무상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |           |

### III 법정실시권의 비교(1)

| 권 리    |       | 發振法 제10조제1항                                                                                                                                                                     | 제81조의3제5항                                                                                                                                                                           | 제103조                                                                                                                                                                   | 제103조의2                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 의 의    |       | 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명에 대하여 종업원 등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에는 사용자 등에게 인정되는 전범위에 대한 통상실시권을 말한다. | 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원 또는 특허권의 효력제한기간 중 국내에서 선의로 특허출원된 발명 또는 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명 또는 특허발명에 대한 특허권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다. | 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다. | 특허권의 이전청구에 기초하여 특허권의 이전등록이 있기 전에(法 99의2②) 해당 특허가 법 제33조제항본문, 제44조 위반의 특허무효사유(法 133①Ⅱ)에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다 |
| 성립요건   | 주체적   | · 종업원 등이 직무에 관해 발명<br>· 사용자 등의 업무범위에 속할 것<br>· 사용자 등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원 등과의 협의를 거쳐 미리 예약승계에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하였을 것                                  | · 선의 → 특허출원 또는 특허권이 소멸되었음을 신뢰하고 특허출원된 발명 또는 특허발명을 실시한 자                                                                                                                             | · 선의 → 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 된 자                                                                                                             | · 선의 → 법 제33조제1항본문, 제44조 위반의 특허무효사유(法 133①Ⅱ)에 해당하는 것을 알지 못할 것                                                                                                                                           |
|        | 객체적   | · 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것                                                                                                                                        | · 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|        | 시기적   | · 종업원 등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받을 것                                                                                                                               | · 효력제한기간 중                                                                                                                                                                          | · 특허출원 시                                                                                                                                                                | · 특허권의 이전청구에 기초하여 특허권의 이전등록이 있기 전의 실시일 것                                                                                                                                                                |
|        | 지역적   | · 국내                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| 발 생    |       | · 법률 규정을 만족하면 발생(등록하지 아니하여도 대항 가능 → 단지 증명책임의 문제)                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| 효 력    | 범 위   | · 특허발명의 범위                                                                                                                                                                      | · 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|        | 실시금지효 | · 없음                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| 변 동    | 실시권허락 | · 설정불가                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|        | 질권설정  | · 특허권자의 동의                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|        | 이 전   | · 특허권자의 동의, 사업과 함께, 상속이나 그 밖의 일반 승계                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|        | 특허권포기 | · 직무발명에 대한 통상실시권자의 경우만 동의가능                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|        | 실시권포기 | · 질권자의 동의                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| 소 멸    |       | · 특허권의 소멸, 실시권의 포기, 특허권의 수용, 혼동, 실시사업폐지(단, 발진법 제10조 제외)                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| 대 가    |       | · 無                                                                                                                                                                             | · 有                                                                                                                                                                                 | · 無                                                                                                                                                                     | · 有                                                                                                                                                                                                     |
| 설정등록효과 |       | · 설정등록하지 않더라도 제3자에게 대항 가능, 그러나 통상실시권의 이전, 변경, 소멸, 처분의 제한은 등록이 대항요건(法 118)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |



#### IV 법정실시권의 비교(2)

| 제104조                                                                                                                                                                                                                          | 제105조                                                                                                                                                                                                                                         | 제122조                                                                                                                                                         | 제182조                                                                                                                                                                                                                                                                           | 제183조                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 그 특허권 또는 그 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다. | 특허출원일 전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원되어 등록된 디자인권이 그 특허권과 저촉되는 경우 그 디자인권의 존속기간이 만료될 때에는 그 디자인권자에게 그 디자인권의 범위에서, 디자인권에 대한 전용실시권자 또는 그 디자인권이나 전용실시권에 관한 등록된 통상실시권을 가진 자에게 원(原)권리의 범위에서 그 특허권 또는 그 디자인권의 존속기간이 만료 당시 존재하는 그 특허권의 전용실시권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다. | 특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)가 질권 설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다. | 법 제181조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자에게 그 실시하고 있거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 인정되는 통상실시권을 말한다.                                                                                              | 통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후 재심에서 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우에 재심청구 등록 전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자에게 원통상실시권의 사업목적 및 발명의 범위에서 그 특허권 또는 재심의 심결이 확정된 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다. |
| · 선의<br>· 자기의 특허발명 또는 등록 실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못한 자<br>· 취득할 수 있는 자<br>· 원특허권자 및 원실용신안권자, 무권리자, 등록된 실시권자(단, 법정실시권자는 등록 不要)                                                                                                    | · 디자인권자<br>· 등록된 실시권자(단, 법정실시권자는 등록 不要)                                                                                                                                                                                                       | · 전 특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)                                                                                                   | · 선의 → 재심사유가 있음을 알지 못한 자                                                                                                                                                                                                                                                        | · 선의 → 재심사유가 있음을 알지 못한 자                                                                                                                                                                          |
| · 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비                                                                                                                                                                                                     | · 특허권과 저촉<br>· 존속기간 만료로 소멸                                                                                                                                                                                                                    | · 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시                                                                                                                        | · 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업의 준비                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
| · 무효심판청구 등록 전<br>· 무효사유 → 法 제29조제1항, 제29조제3항 및 제4항, 제36조, 제33조제1항 본문                                                                                                                                                           | · 특허출원일 전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원되어 등록                                                                                                                                                                                                             | · 질권설정되어 특허권이 경매 등에 의하여 이전                                                                                                                                    | · i) 무효가 된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우, ii) 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우, iii) 자잘하다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우 및 iv) 취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에 해당 심결/결정이 확정된 후 재심청구 등록 전의 실시일 것 | · 통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후 재심에서 그 심결과 상반되는 심결이 확정되어야 하고 재심청구 등록 전                                                                                                                                   |
| · 국내                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| · 법률 규정을 만족하면 발생(등록하지 아니하여도 대항 가능 → 단지 증명책임의 문제)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| · 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위                                                                                                                                                                                                | · 디자인권자<br>· 디자인권의 범위<br>· 원실시권자<br>· 원권리의 범위                                                                                                                                                                                                 | · 특허발명 전체(무제한설이 통설)                                                                                                                                           | · 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위                                                                                                                                                                                                                                               | · 원통상실시권의 사업목적 및 발명의 범위                                                                                                                                                                           |
| · 없음                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| · 설정불가                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| · 특허권자의 동의                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| · 특허권자의 동의, 사업과 함께, 상속이나 그 밖의 일반 승계                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| · 없음                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| · 질권자의 동의                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| · 특허권의 소멸, 실시권의 포기, 특허권의 수용, 혼동, 실시사업폐지(法 제105조, 제122조 제외)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| · 有                                                                                                                                                                                                                            | · 디자인권자 → 無<br>· 원실시권자 → 有                                                                                                                                                                                                                    | · 有                                                                                                                                                           | · 無                                                                                                                                                                                                                                                                             | · 有                                                                                                                                                                                               |
| · 설정등록하지 않더라도 제3자에게 대항 가능, 그러나 통상실시권의 이전, 변경, 소멸, 처분의 제한은 등록이 대항요건(法 118)                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |

## I 법조문

## 제106조의2 【정부 등에 의한 특허발명의 실시】

- ① **(성립요건 및 효력)** 정부는 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자에게 실시하게 할 수 있다.
- ② **(통지)** 정부 또는 제1항에 따른 정부 외의 자는 타인의 특허권이 존재한다는 사실을 알았거나 알 수 있을 때에는 제1항에 따른 실시 사실을 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 신속하게 알려야 한다.
- ③ **(보상)** 정부 또는 제1항에 따른 정부 외의 자는 제1항에 따라 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 정당한 보상금을 지급하여야 한다.
- ④ 특허발명의 실시 및 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령[특허권의 수용 실시 등에 관한 규정]으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

## 제107조 【통상실시권 설정의 재정】(★★)

- ① **(주체적 및 객체적 요건)** 특허발명을 실시하려는 자는 특허발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하고, 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의(이하 이 조에서 "협의"라 한다)를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 지식재산처장에게 통상실시권 설정에 관한 재정(裁定)(이하 "재정"이라 한다)을 청구할 수 있다. 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 경우와 제4호에 해당하는 경우에는 협의 없이도 재정을 청구할 수 있다.
  1. 특허발명이 천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우
  2. 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우
  3. 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우
  4. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우
  5. 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하려는 국가(이하 이 조에서 "수입국"이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우
- ② **(시기적 요건)** 특허출원일로부터 4년이 지나지 아니한 특허발명에 관하여는 제1항제1호 및 제2호를 적용하지 아니한다.
- ③ **(재정방법: 청구별 검토)** 지식재산처장은 재정을 하는 경우 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토하여야 한다.
- ④ **(재정방법: 조건 부과)** 지식재산처장은 제1항제1호부터 제3호까지 또는 제5호에 따른 재정을 하는 경우 재정을 받는 자에게 다음 각 호의 조건을 붙여야 한다.
  1. 제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 재정의 경우에는 통상실시권을 국내수요충족을 위한 공급을 주목적으로 실시할 것
  2. 제1항제5호에 따른 재정의 경우에는 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것
- ⑤ **(재정방법: 대가)** 지식재산처장은 재정을 하는 경우 상당한 대가가 지급될 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제1항제4호 또는 제5호에 따른 재정을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 대가 결정에 고려할 수 있다.
  1. 제1항제4호에 따른 재정의 경우에는 불공정거래행위를 바로잡기 위한 취지
  2. 제1항제5호에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치
- ⑥ **(반도체 기술)** 반도체 기술에 대해서는 제1항제3호(공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하는 경우만 해당한다) 또는 제4호의 경우에만 재정을 청구할 수 있다.
- ⑦ **(수입국의 요건)** 수입국은 세계무역기구회원국 중 세계무역기구에 다음 각 호의 사항을 통지한 국가 또는 세계무역기구회원국이 아닌 국가 중 대통령령[특허권의 수용 실시 등에 관한 규정 제2조의3]으로 정하는 국가로서 다음 각 호의 사항을 대한민국정부에 통지한 국가의 경우만 해당한다.

1. 수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량
  2. 국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 해당 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인
  3. 수입국에서 해당 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인
- ⑧ (의약품의 요건) 제1항제5호에 따른 의약품은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

1. 특허된 의약품
2. 특허된 제조방법으로 생산된 의약품
3. 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분
4. 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트

- ⑨ 재정을 청구하는 자가 제출하여야 하는 서류, 그 밖에 재정에 관하여 필요한 사항은 대통령령[특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제33조]으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제108조 【답변서의 제출】 法 114②

지식재산처장은 재정의 청구가 있으면 그 청구서의 부분(副本)을 그 청구에 관련된 특허권자·전용실시권자, 그 밖에 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제109조 【산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 부처의 장의 의견청취】 法 114②

지식재산처장은 재정을 할 때 필요하다고 인정하는 경우에는 「발명진흥법」 제41조에 따른 산업재산권분쟁조정위원회(이하 “조정위원회”라 한다) 및 관계 부처의 장의 의견을 들을 수 있고, 관계 행정기관이나 관계인에게 협조를 요청할 수 있다. <개정 2021. 8. 17.>

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제110조 【재정의 방식 등】

- ① (방식) 재정은 서면으로 하고, 그 이유를 구체적으로 적어야 한다. 法 114②
- ② (기재사항) 제1항에 따른 재정에는 다음 각 호의 사항을 구체적으로 적어야 한다.
  1. 통상실시권의 범위 및 기간
  2. 대가와 그 지급방법 및 지급시기 法 112-113
  3. 제107조제1항제5호에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 따른 경우는 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소 法 111의 2 / 114①Ⅲ
  4. 그 밖에 재정을 받은 자가 그 특허발명을 실시할 경우 법령 또는 조약에 따른 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항 法 114①Ⅲ
- ③ (재정시기) 지식재산처장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 재정청구일부터 6개월 이내에 재정에 관한 결정을 하여야 한다.
- ④ (수입국 수출) 제107조제1항제5호에 따른 재정청구가 같은 조 제7항 및 제8항에 해당하고 같은 조 제9항에 따른 서류가 모두 제출된 경우에는 지식재산처장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 통상실시권 설정의 재정을 하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제111조 【재정서등본의 송달】

- ① (송달) 지식재산처장은 재정을 한 경우에는 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 재정서등본을 송달하여야 한다. 法 114②
- ② (효력) 제1항에 따라 당사자에게 재정서등본이 송달되었을 때에는 재정서에 적혀 있는 바에 따라 당사자 사이에 협의가 이루어진 것으로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제111조의2 【재정서의 변경】

- ① (변경청구) 재정을 받은 자는 재정서에 적혀 있는 제110조제2항제3호의 사항에 관하여 변경이 필요하면 그 원인을 증명하는 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 변경청구를 할 수 있다.
- ② (변경결정) 지식재산처장은 제1항에 따른 청구가 이유있다고 인정되면 재정서에 적혀 있는 사항을 변경할 수 있다. 이 경우 이해관계인의 의견을 들어야 한다.
- ③ (등본 송달 및 효력) 제2항의 경우에 관하여는 제111조를 준용한다.

[전문개정 2014.6.11.]

### 제112조 【대가의 공탁】

제110조제2항제2호에 따른 대가를 지급하여야 하는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 대가를 공탁(供託)하여야 한다.

1. 대가를 받을 자가 수령을 거부하거나 수령할 수 없는 경우
2. 대가에 대하여 제190조제1항에 따른 소송이 제기된 경우
3. 해당 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우. 다만, 질권자의 동의를 받은 경우에는 그러하지 아니하다. **法 123**

[전문개정 2014.6.11.]

### 제113조 【재정의 실효】

재정을 받은 자가 제110조제2항제2호에 따른 지급시기까지 대가(대가를 정기 또는 분할하여 지급할 경우에는 최초의 지급분)를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니한 경우에는 그 재정은 효력을 잃는다.

[전문개정 2014.6.11.]

### 제114조 【재정의 취소】

① **(요건)** 지식재산처장은 재정을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이해관계인의 신청에 따라 또는 직권으로 그 재정을 취소할 수 있다. 다만, 제2호의 경우에는 재정을 받은 통상실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우로 한정한다.

1. 재정을 받은 목적에 적합하도록 그 특허발명을 실시하지 아니한 경우
2. 통상실시권을 재정한 사유가 없어지고 그 사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정되는 경우
3. 정당한 사유 없이 재정서에 적혀 있는 제110조제2항제3호 또는 제4호의 사항을 위반하였을 경우

② **(절차)** 제1항의 경우에 관하여는 제108조[**답변서의 제출**]·제109조[**산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 부처의 장의 의견청취**]·제110조제1항[**방식**] 및 제111조제1항[**등본 송달**]을 준용한다.

③ **(효력)** 제1항에 따라 재정이 취소되면 통상실시권은 그때부터 소멸된다.

[전문개정 2014.6.11.]

### 제115조 【재정에 대한 불복이유의 제한】 **法 224의2② / 190**

재정에 대하여 「행정심판법」에 따라 행정심판을 제기하거나 「행정소송법」에 따라 취소소송을 제기하는 경우에는 그 재정으로 정한 대가는 불복이유로 할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

### 제116조 삭제 <2011.12.2.>

#### 구특허법 제116조

아래의 내용인데 한미FTA 체결에 따라 삭제됨

#### 제116조(특허권의 취소)

- ① 특허청장(현재 지식재산청장)은 제107조제1항제1호의 사유로 인한 재정이 있는 날부터 계속하여 2년이상 그 특허발명이 국내에서 실시되고 있지 아니하는 경우에는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 그 특허권을 취소할 수 있다.
- ② 제108조·제109조·제110조제1항 및 제111조제1항의 규정은 제1항의 경우에 이를 준용한다.
- ③ 제1항의 규정에 의한 특허권의 취소가 있는 때에는 특허권은 그때부터 소멸된다.

### 제138조 【통상실시권 허락의 심판】(★★) **法 98, 183 / 140③**

① **(일반적인 경우: 요건)** 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.

② **(일반적인 경우: 요건)** 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다.

③ **(CROSS-LICENSE 경우: 요건)** 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.

④ **(대가 지급 또는 공탁 후 실시)** 제1항 및 제3항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다.

⑤ **(대가 지급하지 아니하고 공탁하지 아니한 경우 실시不可)** 제4항에 따른 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]



## II 재정제도(法 107~115)

| 구 분      |     | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서        | 의의  | ① 특허권자가 정당한 이유없이 특허발명을 실시하지 않거나 ② 불충분하게 실시하는 경우, ③ 공공의 이익을 위하여 특허 실시할 필요가 있는 경우, ④ 사법적·행정적 절차에 의하여 불공정 거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위한 경우 또는 ⑤ 수입국에 의약품의 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 이를 실시하려는 자의 청구와 지식재산처장의 재정(裁定)에 의하여 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 통상실시권을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 취지  | 1. 불 실시 또는 불충분 실시의 경우 - 특허발명의 실시유도, 특허권의 남용을 방지<br>2. 공공의 이익을 위해 특허 필요하거나 불공정거래행위 시정의 경우 - 공익상 필요<br>3. 수입국에 의약품의 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 - 후진국의 공중보건문제의 해결(국내수요를 주목적으로 하도록 규정되어 있는 TRIPs 협정 제31조(f)와 국내에서의 경제적 가치를 고려하여 적절한 보상을 해야한다는 TRIPs 협정 제31조(h)를 유보함)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 성립<br>요건 | 주체적 | 특허권자 또는 전용실시권자와 협의를 구하고 협의가 성립되지 않거나(不成) 협의할 수 없는 경우(不能)에 한하여 재정을 청구. 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 경우와 불공정거래행위 시정의 경우에는 협의의 不必要.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 객체적 | 1. 불 실시 또는 불성실 실시의 경우<br>① 의의 - 특허발명이 천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 대통령령으로 정하는 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우, 특허발명이 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우를 말한다(法 107① I II).<br>② 대통령령이 정하는 정당한 이유 - i) 특허권자가 심신장애로 인한 활동불능의 경우(의료기관장이 증명한 경우에 한함), ii) 특허발명의 실시에 필요한 정부기관이나 타인의 인·허가, 동의 또는 승낙을 받지 못한 경우, iii) 특허발명의 실시가 법령으로 금지 또는 제한된 경우, iv) 특허발명의 실시에 필요한 원료 또는 시설이 국내에 없거나 수입이 금지된 경우, v) 물건의 수요가 없거나 그 수요가 적어 이를 영업적 규모로 실시할 수 없는 경우를 말한다.<br>③ 계속 - 연속과 현재를 의미함. 즉 연속하여 3년이상 실시하지 아니하여야 하며, 과거에 3년이상 실시하지 않았을지라도 현재 실시하고 있는 경우에는 여기에 해당하지 않음.<br>2. 공익상 필요하거나 불공정거래행위의 시정의 경우<br>① 의의 - 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특허 필요한 경우, 사법적·행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우를 말한다(法 107① III IV).<br>② 반도체기술의 경우 - 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우, 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 한하여 재정을 청구할 수 있다(法 107⑥).<br>3. 수입국에 의약품의 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우<br>① 의의 - 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효 성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하려는 국가(이하 이 조에서 "수입국"이라 한다)에 그 의약품의 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우를 말한다(法 107① V).<br>② 수입국 - WTO 회원국 중 WTO에 다음의 사항을 통지한 국가 또는 WTO 회원국이 아닌 국가 중 대통령령이 정하는 국가(국제연합총회 결의에 따른 최빈개발도상국)로서 다음의 사항을 대한민국 정부에 통지 국가에 한한다(法 107⑦).<br>i) 수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량<br>ii) 국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 해당 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인<br>iii) 수입국에서 해당 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인<br>③ 의약품 - i) 특허된 의약품, ii) 특허된 제조방법으로 생산된 의약품, iii) 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분, iv) 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트 |
|          | 시기적 | 불 실시 또는 불성실 실시의 경우 특허발명이 특허출원일로부터 4년(실시를 위한 준비기간)이 경과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 절차  | 재정청구서 제출<br>특허발명을 실시하려는 자는 특허권자 또는 특허권자와 전용실시권자를 피청구인으로 하여 재정청구서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 107①). 재정을 청구하는 자가 제출하여야 하는 서류, 그 밖에 재정에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다(法 107⑨).<br>부분송달 및 답변서 제출<br>지식재산처장은 재정의 청구가 있는 때에는 그 청구서의 부분을 그 청구에 관련된 특허권자·전용실시권자, 그 밖에 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 108).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

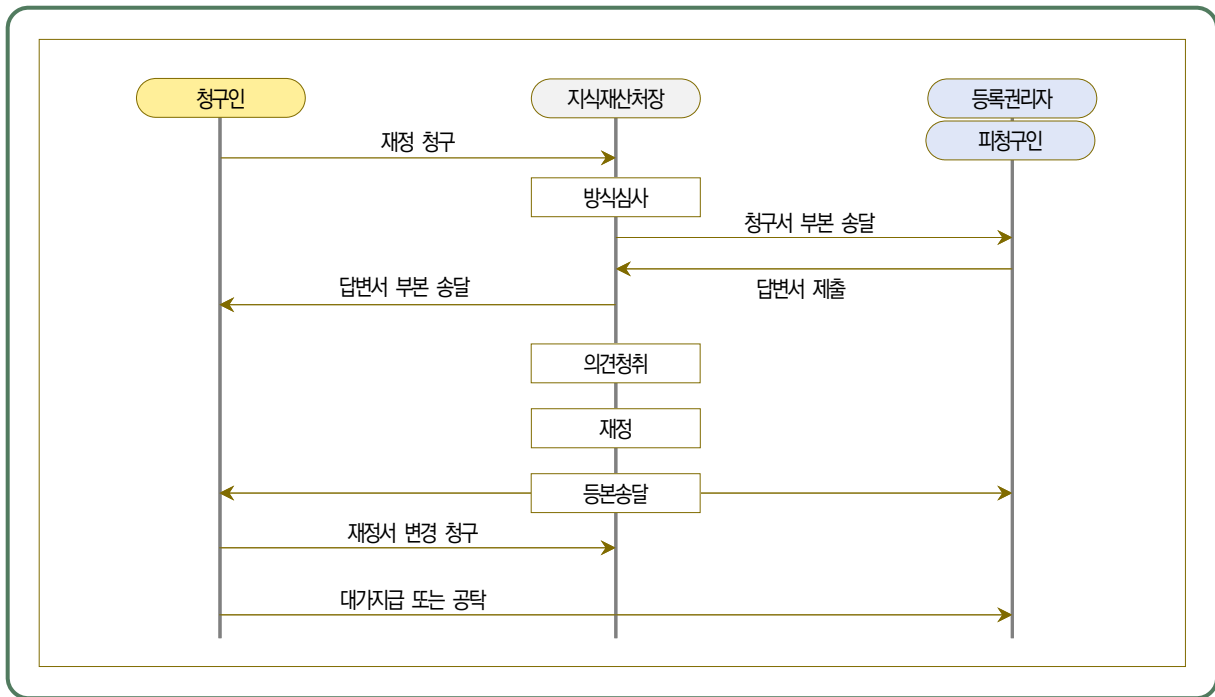
|           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <b>의견청취</b> | 지식재산처장은 재정을 할 때 필요하다고 인정하는 경우에는 「발명진흥법」 제41조에 따른 산업재산권 분쟁조정위원회(이하 “조정위원회”라 한다) 및 관계부처의 장의 의견을 들을 수 있고, 관계 행정기관이나 관계인에게 협조를 요청할 수 있다(法 109).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>재정</b> | <b>시기</b>   | 지식재산처장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 재정청구일부터 6개월 이내에 재정에 관한 결정을 하여야 한다(法 110③).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | <b>검토</b>   | <p>1. 지식재산처장은 재정을 할 때 매 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토하여야 하며(法 107③), 다음의 조건을 부과하여야 한다(法 107④).</p> <p>① 불실시, 불충분실시 또는 공익상 필요한 경우에 의한 실시의 경우에는 강제실시권 허락의 취지가 국내 수요의 충족에 있기 때문에 그 통상실시권이 국내수요충족을 위한 공급을 주목적으로 실시할 것</p> <p>② 수입국에 의약품의 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에는 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것</p> <p>2. 수입국에 그 의약품의 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정청구가 다음의 요건을 만족하는 경우에 지식재산처장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 통상실시권 설정의 재정을 하여야 한다(法 110④).</p> <p>① 법 제107조 제7항의 수입국의 요건</p> <p>② 법 제107조 제8항의 의약품의 요건</p> <p>③ 법 제109조 제9항에 따른 서류가 모두 제출되었을 요건</p>                       |
|           | <b>대가</b>   | <p>지식재산처장은 재정을 할 때 상당한 대가가 지급될 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 재정을 하는 경우에는 다음의 사항에 대해서는 대가 결정에 참작할 수 있다(法 107⑤).</p> <p>① 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우에는 불공정거래행위를 바로잡기 위한 취지</p> <p>② 수입국에 그 의약품의 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | <b>방식</b>   | <p>재정은 서면으로 하고 그 이유를 적어야 하며, 다음의 사항을 적어야 한다(法 110①②).</p> <p>① 통상실시권의 범위 및 기간</p> <p>② 대가와 그 지급방법 및 지급시기</p> <p>③ 수입국에 그 의약품의 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 따른 경우는 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소</p> <p>④ 재정을 받은 자가 특허발명을 실시할 경우 법령 또는 조약에 따른 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항</p>                                                                                                                                                                                                         |
|           | <b>송달</b>   | 지식재산처장은 재정을 한 경우에는 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 재정서 등본을 송달하여야 하며 당사자에게 재정서등본이 송달되었을 때에는 재정서에 적혀 있는 바에 따라 당사자 사이에 협의가 이루어진 것으로 본다(法 111). 따라서 특허발명을 실시하려는 자에게 통상실시권이 발생한다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | <b>변경</b>   | <p>1. 재정을 받은 자는 재정서에 적혀 있는 수입국에 그 의약품의 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우에 ① 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 의한 경우를 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 ② 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소의 사항에 관하여 변경이 필요하면 그 원인을 증명하는 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 변경청구를 할 수 있다(法 111의2①).</p> <p>2. 지식재산처장은 청구가 이유 있다고 인정되면 재정서에 적혀 있는 사항을 변경할 수 있다. 이 경우 이해관계인의 의견을 들어야 한다(法 111의2②).</p> <p>3. 재정서에 적혀 있는 사항의 변경이 있는 경우 지식재산처장은 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 변경된 재정서 등본을 송달하여야 하며 당사자에게 변경된 재정서 등본이 송달되었을 때에는 해당 재정서에 적혀 있는 바에 따라 당사자 사이에 협의가 이루어진 것으로 본다(法 111의2 준용 111).</p> |
|           | <b>불복</b>   | 재정에 대해서는 행정심판법에 따라 행정심판을 제기하거나 행정소송법에 따라 취소소송을 제기할 수 있으나 그 재정으로 정한 대가를 불복이유로 할 수는 없다(法 115). 대가만의 불복을 하고자 할 경우에는 별도로 법원에 소송을 제기하여야 한다(法 190, 191).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Ⅲ 재정요건(法 107)의 비교

| 구 분                  | 불 실시   | 불충분 실시 | 공공의 이익 실시 |      | 불공정거래행위 시정 실시       | 수입국에 수출 실시                        |
|----------------------|--------|--------|-----------|------|---------------------|-----------------------------------|
|                      |        |        | 상업적       | 비상업적 |                     |                                   |
| 협약<br>(제107조제1항)     | ○      | ○      | ○         | ×    | ×                   | ○                                 |
| 기간경과<br>(제107조제2항)   | ○      | ○      | ×         | ×    | ×                   | ×                                 |
| 청구별 검토<br>(제107조제3항) | ○      |        |           |      |                     |                                   |
| 조건부과<br>(제107조제4항)   | 국내수요충족 |        |           |      | -                   | 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출               |
| 대가참작<br>(제107조제5항)   | -      |        |           |      | 불공정거래행위를 바로잡기 위한 취지 | 그 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치 |
| 반도체기술<br>(제107조제6항)  | ×      | ×      | ×         | ○    | ○                   | ×                                 |
| 수입국요건<br>(제107조제7항)  | ×      | ×      | ×         | ×    | ×                   | ○                                 |
| 의약품요건<br>(제107조제8항)  | ×      | ×      | ×         | ×    | ×                   | ○                                 |



#### IV 재정절차



## V 강제실시권의 비교

| 권 리  |       | 제106조의2                                                                                                                                  | 제107조                                                                                                                                                                                                       | 제138조                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 의 의  |       | 특허발명이 i) 국가 비상사태, ii) 극도의 긴급상황 또는 iii) 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정되는 경우에 정부가 특허발명을 실시하거나 정부의 자에게 실시하게 할 수 있는 통상실시권을 말한다(法 106의2①). | 특허권자가 정당한 이유없이 특허발명을 실시하지 않거나, 불충분하게 실시하는 경우, 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우, 사법적·행정적 절차에 의하여 불공정 거래행위로 판정된 사항을 바로 잡기 위한 경우 또는 수입국에 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 지식재산처장의 재정에 의하여 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 실시권을 말한다. | 특허발명이 이용·저촉관계에 해당하여 통상실시권의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유없이 허락을 하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때, 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권허락심판을 청구할 수 있으며 상기 심판에 의하여 허락되는 실시권을 말한다.                                                 |
| 성립요건 | 주체적   | · 정부 또는 정부 외의 자                                                                                                                          | · 불실시·불충분실시·공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우(비상업적 실시 제외)·수입국에 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 특허권자 등과 협의 불성립                                                                                                        | · 일반적 통상실시권허락심판<br>청구인은 이용·저촉관계의 후출원특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자이며 피청구인은 선출원특허권자, 전용실시권자, 실용신안권자 또는 디자인권자<br>· CROSS-LICENSE<br>청구인은 통상실시권을 허락한 선출원특허권자·실용신안권자 또는 디자인권자, 전용실시권자이며 피청구인은 원특허권자·전용실시권자(통상실시권자의 경우 학설 대립) |
|      | 객체적   | · i) 국가 비상사태, ii) 극도의 긴급상황 또는 iii) 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요                                                                             | · 불실시·불충분실시<br>· 공공의 이익을 위하여 특히 필요, 불공정 거래행위 시정 → 반도체 기술은 이 경우에만 해당(단, 상업적 실시는 제외)<br>· 수입국에 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요                                                                                    | · 이용·저촉관계(法 98)<br>· 협의 불성립 → 위반된 경우 심결각하<br>· 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술상의 진보(法 138②)<br>· 자기의 특허발명 실시에 필요한 범위일 것<br>· 크로스 라이선스의 경우(法 138③)                                                                        |
|      | 시기적   | -                                                                                                                                        | · 불실시·불충분실시의 경우 특허발명이 출원일로부터 4년 경과                                                                                                                                                                          | · 타방 권리의 존속중                                                                                                                                                                                                   |
|      | 지역적   | · 국내                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
| 절 차  |       | · 특허권 존재 사실의 통지<br>· 처분의 신청<br>· 부분의 송달<br>· 처분 및 보상금액의 결정<br>· 등본의 송달 및 공고<br>· 불복                                                      | · 청구<br>· 부분송달 및 답변서 제출<br>· 의견청취<br>· 재정<br>· 등본의 송달<br>· 불복                                                                                                                                               | · 청구<br>· 부분송달 및 답변서 제출<br>· 심리<br>· 심결<br>· 등본의 송달<br>· 불복                                                                                                                                                    |
| 발 생  |       | 결정서 등본의 송달                                                                                                                               | 재정서 등본 송달                                                                                                                                                                                                   | 심결확정                                                                                                                                                                                                           |
| 효 력  | 효력범위  | 지식재산처장의 결정범위                                                                                                                             | 재정에서 정한 바                                                                                                                                                                                                   | 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위                                                                                                                                                                                           |
|      | 실시금지효 | 없음                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
| 변 동  | 실시권허락 | 설정불가                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
|      | 질권설정  | 학설의 대립                                                                                                                                   | 질권설정 불가                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|      | 이 전   | 학설의 대립                                                                                                                                   | 실시사업과 함께                                                                                                                                                                                                    | 실시권 허락의 원인되는 원권리와 함께                                                                                                                                                                                           |
|      | 특허권포기 | 동의 불가                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
|      | 실시권포기 | 질권설정가능한 경우 동의                                                                                                                            | 자유롭게 포기 가능                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
| 소멸   |       | 특허권의 소멸, 특허권의 수용, 실시권의 포기, 혼동, 정부의 실시허가의 취소(法 106의2), 재정의 취소(法 114) 및 실효(法 113), 원권리 소멸(法 138)                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
| 대 가  |       | 有                                                                                                                                        | 1. 有<br>2. 다만 예외적인 경우 공탁                                                                                                                                                                                    | 1. 有<br>2. 다만 예외적인 경우 공탁                                                                                                                                                                                       |

# 51

## 특허권상 질권(法 121~123)

### I 법조문

#### 제121조 【질권】 法 119①Ⅱ, 136⑧ / 119② / 119③

특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하였을 때에는 질권자는 계약으로 특별히 정한 경우를 제외하고는 해당 특허발명을 실시할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제122조 【질권행사 등으로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권】(★★)

특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다. <개정 2021. 10. 19.>

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제123조 【질권의 물상대위】 法 106③ / 112Ⅲ

질권은 이 법에 따른 보상금이나 특허발명의 실시에 대하여 받을 대가나 물건에 대해서도 행사할 수 있다. 다만, 그 보상금 등의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

## II 특허법상 질권(法 121~123)

| 권 리       |              | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서         |              | 「질권」이란 채권자가 그 채권의 담보로서 채무자 또는 제3자로부터 받은 물건이나 재산을 점유하고 채무의 변제가 있을 때까지 유치함으로써 채무의 변제를 간접적으로 강행하는 동시에 채무의 변제가 없을 때에는 그 목적물로부터 우선적으로 변제받는 권리를 말한다.                                                                                                                               |
| 질권의<br>설정 | 대상           | 1. 특허를 받을 수 있는 권리에 대해서는 질권설정 불가<br>2. 특허권에 대해서는 질권설정 가능<br>3. 실시권에 대해서도 질권설정 가능. 단, 강제실시권 중 통상실시권허락심판(法 138)에 의한 실시권 및 재정에 의한 통상실시권(法 107)은 질권설정이 불가이며(法 102⑥), 국가 비상사태 등에 의한 통상실시권(法 106의2)의 경우 논란이 있으나 질권의 대상이 될 수 없다고 해석함이 타당.                                            |
|           | 제한           | 1. 전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다(法 100④). 또한, 통상실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자의 동의를 받아야만 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다(法 102⑥).<br>2. 특허권, 전용실시권 및 통상실시권이 공유인 경우 다른 공유자의 동의를 받아야만 질권을 설정할 수 있다(法 99②, 100⑤, 102⑦).                                   |
| 질권의<br>효력 | 우선변제         | 등록한 질권자는 질권에 기해 후순위 채권자보다 우선하여 변제받을 수 있다. 다만, 특허권은 무체재산권이기에 때문에 물건의 인도로 인한 유치적 효력은 없다.                                                                                                                                                                                       |
|           | 실시 불가        | 질권자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 해당 특허발명을 실시할 수 없다.                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 법정<br>실시권    | 특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 122).                                             |
|           | 물상<br>대위     | 질권은 특허법에 의한 보상금(예, 특허권 수용 등에 의한 보상금, 비밀취급에 대한 보상금 등) 또는 특허발명의 실시에 대하여 받을 대가나 물건(실시료 등)에 대하여도 이를 행사할 수 있다. 다만, 그 지급 및 인도 전에 이를 압류하여야 한다(法 123).                                                                                                                               |
|           | 동의권          | 특허권자는 질권자의 동의를 받아야만 특허권의 포기(法 119①), 특허의 정정 및 정정심판 청구(다만, 질권자가 특허취소신청, 무효심판을 청구한 경우는 제외)(法 132의3③, 133의2④, 136⑧)를 할 수 있다. 한편, 전용실시권자 및 통상실시권자는 질권자의 동의를 받아야만 전용실시권 및 통상실시권을 포기할 수 있다(法 119②③).                                                                               |
|           | 심판장의<br>통지의무 | 무효심판이 청구된 경우 등록된 질권자는 심판장으로부터 이를 통지받아 심판에 참가할 수 있다(法 133④, 134②, 137②).                                                                                                                                                                                                      |
| 질권의 소멸    |              | ① 채무변제, ② 설정계약 해제, ③ 특허권의 소멸, ④ 상속인 부존재 등에 의하여 질권은 소멸한다.                                                                                                                                                                                                                     |
| 등록의 효력    |              | 1. 특허권, 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계의 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한은 등록하여야만 효력이 발생한다(法 101①Ⅲ). 한편, 질권의 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 지체없이 그 취지를 지식재산 처장에게 신고하여야 한다(法 101②).<br>2. 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다(法 118③). |

### Ⅲ 특허권의 변동과 특허를 받을 수 있는 권리의 변동의 비교

| 권 리    | 특허를 받을 수 있는 권리                                                                                                                                                                                                                                          | 특허권                                                                                                                                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이 전    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 이전가능(法 37①), 공유인 경우 다른 공유자모두의 동의를 받아야만 양도가능(法 37③) → 단, 다른 공유자의 동의를 받지 않고도 상속은 가능</li> <li>· 특허출원 전 이전 → 출원하여야 대항요건취득(法 38①)</li> <li>· 특허출원 후 이전 → 상속이나 그 밖의 일반승계를 제외하고 출원인명의변경신고를 하여야 효력발생(法 38④)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 이전가능(法 99①), 공유인 경우 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 양도가능(法 99②) → 단, 다른 공유자의 동의를 받지 않고도 상속은 가능</li> <li>· 상속이나 그 밖의 일반승계를 제외하고는 이전등록을 하여야 효력발생</li> </ul> |
| 실시권 설정 | 실시권설정불가                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 실시권설정가능(法 100, 102), 단 공유인 경우 다른 공유자의 동의를 받아야만 실시권설정가능(法 99④)</li> <li>· 전용실시권은 등록하여야 효력발생하며, 통상실시권은 설정계약에 의하여 효력발생하나 등록하여야 대항가능</li> </ul>   |
| 질권 설정  | 질권설정불가(法 37②)                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 질권설정가능(法 121), 단 공유인 경우 다른 공유자의 동의를 받아야만 질권설정가능(法 99②)</li> <li>· 질권설정등록하여야 효력발생</li> </ul>                                                   |
| 수용 등   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국방상 필요한 경우 외국에의 출원금지, 비밀취급명령, 불특허가능</li> <li>· 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에 수용가능</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에 정부가 수용할 수 있음</li> </ul>                                                                                      |
| 포 기    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 포기 가능, 지분포기는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 자유롭게 가능</li> <li>· 포기서를 제출하여 수리된 경우 효력발생</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 포기 가능, 지분포기는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 자유롭게 가능</li> <li>· 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 의한 통상실시권자, 질권자의 동의 요</li> <li>· 포기등록을 하여야 효력발생</li> </ul>    |

# 52

## 특허권의 소멸(法 119, 120, 124)

### I 법조문

#### 제119조 【특허권 등의 포기의 제한】(★★)

① (특허권 포기의 제한) 특허권자는 다음 각 호의 모두의 동의를 받아야만 특허권을 포기할 수 있다. 法 6 / 136⑧ / 215

1. 전용실시권자
2. 질권자
3. 제100조제4항[전용실시권에 대한 허락실시권]에 따른 통상실시권자
4. 제102조제1항[특허권에 대한 허락실시권]에 따른 통상실시권자
5. 「발명진흥법」 제10조제1항[직무발명에 대한 통상실시권]에 따른 통상실시권자

② (전용실시권 포기의 제한) 전용실시권자는 질권자 또는 제100조제4항에 따른 통상실시권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 포기할 수 있다.

③ (통상실시권 포기의 제한) 통상실시권자는 질권자의 동의를 받아야만 통상실시권을 포기할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제120조 【포기의 효과】(★★)

특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 포기한 때에는 특허권·전용실시권 또는 통상실시권은 그때부터 소멸된다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제124조 【상속인이 없는 경우 등의 특허권 소멸】

① 특허권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 그 특허권은 소멸된다. <개정 2016.2.29.>

② 청산절차가 진행 중인 법인의 특허권은 법인의 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날로 한다. 이하 이 항에서 같다)까지 그 특허권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일의 다음 날에 소멸한다. <신설 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

[제목개정 2016.2.29.]



## II 특허권의 소멸(法 119, 120, 124)

| 소 멸                            |               | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서                              | 의의            | 특허권의 소멸이란 유효하게 발생한 특허권이 일정한 법정사유에 의하여 장래를 향하여 효력이 상실되거나, 소급하여 처음부터 없었던 것으로 보는 것을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                | 취지            | ① 일정사유에 해당하는 특허권을 소멸시켜 발명을 공유화함으로써 기술의 진보를 통한 산업발전에 이바지, ② 독점배타적인 특허권의 부작용을 최소화                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 장<br>래<br>향<br>해<br><br>소<br>멸 | 특허료 불납        | 추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허출원은 이를 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 낸 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다(法 81③).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | 존속기간만료        | 특허권은 설정등록한 날로부터 특허출원일 후 20년(연장된 경우에는 연장기간의 만료일)이 지나면 존속기간 만료되어 소멸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | 특허권의 포기       | 1. 의의<br>특허권자의 의사에 의하여 특허권을 장래를 향하여 소멸시키는 것을 말한다.<br>2. 대상<br>특허권자는 특허권 자체를 포기할 수도 있고, 청구범위에 둘 이상의 청구항이 기재되고 있는 경우에는 각 청구항별로 포기할 수도 있다(法 215).<br>3. 절차<br>특허권을 포기하려는 자는 특허권 소멸등록 신청서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 다만, 특허권자는 전용실시권자·질권자·직무발명에 의한 통상실시권자·허락에 의한 통상실시권자의 동의를 받아야만 특허권을 포기할 수 있다(法 119①).<br>4. 효력<br>특허권의 포기는 소멸등록을 하여야만 포기의 효력이 발생한다(法 101①). 특허권의 포기가 있으면 특허권은 그 때부터 소멸된다(法 120).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | 상속인 부존재       | 1. 상속인이 없는 자연인의 경우<br>① 의의<br>특허권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 그 특허권은 소멸된다(法 124). 널리 사회일반에 개방하여 자유로이 실시하게 하는 것이 산업정책상 유리하기 때문.<br>② 공유 특허권의 경우<br>특허권이 공유인 경우 공유자 중 1명이 상속인 없이 사망하면, 그 지분이 다른 공유자에게 그 지분비율로 귀속되고 특허권은 소멸되지 아니한다.<br>③ 효력발생시기<br>상속인 부존재에 의한 특허권 소멸의 효력발생시기는 피상속인의 사망시가 되며, 소멸등록이 없어도 효력이 발생한다. 한편, 지식재산처장은 상속인의 부존재로 특허권이 소멸된 때에는 그 취지를 특허공보에 공고하여야 한다(施規 55).<br>2. 청산절차가 진행 중인 법인의 경우<br>청산절차가 진행 중인 법인의 특허권은 법인의 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날로 한다)까지 그 특허권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날로 한다)의 다음 날에 소멸한다(法 124②). |
| 소<br>급<br>하<br>여<br><br>소<br>멸 | 특허취소신청에 의한 취소 | 특허취소신청이란 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 법 제132조의2 제1항 각 호의 특허취소사유에 해당하는 경우 특허심판원에 그 특허권의 효력을 소급하여 소멸시켜 줄 것을 요구하는 신청을 말한다(法 132의2). 특허취소결정이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 132의13).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | 무효심판에 의한 무효   | 특허무효심판이란 이해관계인 또는 심사관이 유효하게 설정등록된 특허권이 법 제133조제1항 각 호의 무효사유에 해당하는 경우 그 특허권의 효력을 소급하여 또는 장래를 향하여 소멸시켜 줄 것을 청구하는 심판을 말한다. 특허무효심판청구에 대하여 무효심결이 확정된 경우에는 원칙적으로 특허권설정등록시로 소급하여 특허권이 소멸한다. 다만, 특허된 후에 특허권자가 외국인의 권리능력의 규정(法 25)에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자가 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우로 무효심판청구에 의한 무효심결이 확정된 경우에는 그 사유가 발생하게 된 때부터 장래를 향하여 소멸한다(法 133).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# 53

## 실시보고 및 집행권원(法 125, 125의2)

### 제125조 【특허실시보고】 法 232

지식재산처장은 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에게 특허발명의 실시 여부 및 그 규모 등에 관하여 보고하게 할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

### 제125조의2 【대가 및 보상금액에 대한 집행권원】 法 166

이 법에 따라 지식재산처장이 정한 대가와 보상금액에 관하여 확정된 결정은 집행력 있는 집행권원(執行權原)과 같은 효력을 가진다. 이 경우 집행력 있는 정본은 지식재산처 소속 공무원이 부여한다.

[전문개정 2014.6.11.]

- 실시보고(法 125) → 기존에는 50만원 이하의 과태료에 처하였으나 행정적 편의를 위한 규제라는 이유로 개정법(法律 제7871호, 2006. 03. 03. 공포 / 시행)에서 이를 삭제함.
- 집행권원(法 125의2) → 강제집행에 필요한 채권에 갈음한 증서

|    |    |                                            |
|----|----|--------------------------------------------|
| 주체 | 54 | 특허심판원(法 132의16, 143~153의2)                 |
|    | 55 | 심판의 당사자(청구인, 피청구인)(法 139)                  |
|    | 56 | 심판의 참가인(法 155, 156)                        |
|    | 57 | 국선대리인, 전문심리위원 및 참고인(法 139의2, 154의2, 154의3) |
| 청구 | 58 | 심판의 청구(法 140, 140의2)                       |
| 진행 | 59 | 방식심리와 적법성 심리(法 141, 142)                   |
|    | 60 | 본안심리(法 154, 157~160)                       |
| 종료 | 61 | 심판청구의 취하(法 161)                            |
|    | 62 | 심결(法 162, 163)                             |
| 관련 | 63 | 조정위원회 회부, 심판비용 및 집행권원(法 164의2, 165, 166)   |
| 각론 | 64 | 거절결정불복심판(法 132의17, 170~172, 176)           |
|    | 65 | 특허무효심판(法 133)                              |
|    | 66 | 존속기간연장등록무효심판(法 134)                        |
|    | 67 | 권리범위확인심판(法 135)                            |
|    | 68 | 정정심판(法 136)                                |
|    | 69 | 정무효심판(法 137)                               |
|    | 70 | 통상실시권허락심판(法 138)                           |
|    | 71 | 특허취소신청(法 132의2~132의15)                     |
|    | 72 | 정정청구(法 132의3, 133의2, 137③④)                |
|    | 73 | 재심(法 178~185)                              |

참고자료 6.1 심판의 분류

| 구 분            |       |                                                                                      | 내 용                                        |                    |                                                |                                                                                                                  |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 심 판 의<br>독 립 성 | 독 립 적 | 의의                                                                                   | 심판의 청구취지가 독립되어 있는 심판으로서 심결이라는 형식으로 판단하는 심판 |                    |                                                |                                                                                                                  |
|                |       | 종류                                                                                   | 구 분                                        |                    | 결정계                                            | 당사자계                                                                                                             |
|                |       |                                                                                      | 의의                                         |                    | 당사자로서 청구인과 피청구인의 대립 구조를 취하지 아니하고 청구인만 존재하는 심판  | 당사자로서 청구인과 피청구인이 존재하고 그 당사자가 서로 대립구조를 취하는 심판                                                                     |
|                |       |                                                                                      | 종류                                         |                    | 1. 특허거절결정에 대한 불복심판(法 132의17)<br>2. 정정심판(法 136) | 1. 특허무효심판(法 133)<br>2. 존속기간 연장등록의 무효심판(法 134)<br>3. 권리범위확인심판(法 135)<br>4. 정정의 무효심판(法 137)<br>5. 통상실시권허락심판(法 138) |
|                |       |                                                                                      | 실익                                         | 참가제도               | 인정 ×                                           | 인정 ○(단, 통상실시권허락심판은 보조 참가만 허용된다는 것이 통설)                                                                           |
|                |       |                                                                                      |                                            | 심판비용               | 청구인이 부담                                        | 통상실시권허락심판(청구인 부담)을 제외하고 패심자가 부담                                                                                  |
|                |       |                                                                                      |                                            | 일사부재리              | 적용 ×(단, 정정심판의 경우 학설대립)                         | 적용 ○                                                                                                             |
|                |       |                                                                                      |                                            | 부분송달 및 답변서제출       | 적용 ×                                           | 적용 ○                                                                                                             |
|                |       |                                                                                      | 인용심결 불복                                    | 불복 ×, 등본송달과 동시에 확정 | 불복 ○, 등본송달일로부터 30일 경과 후 확정.                    |                                                                                                                  |
|                |       | 실익                                                                                   | 독립하여 불복 허용                                 |                    |                                                |                                                                                                                  |
| 부 수 적          | 의의    | 그 자체만으로는 독립해서 심판의 대상이 되지 못하고 독립된 본안심판의 청구사항에 부수하거나 본안심판의 청구를 전제로 하는 심판               |                                            |                    |                                                |                                                                                                                  |
|                | 종류    | 1. 심판관의 제척·기피심판(法 152①)<br>2. 참가심판(法 156③)<br>3. 증거보전심판(法 157)<br>4. 심판비용심판(法 165) 등 |                                            |                    |                                                |                                                                                                                  |
|                | 실익    | 독립하여 불복 불허                                                                           |                                            |                    |                                                |                                                                                                                  |
| 심급             | 심판    | 특허심판원에 최초로 청구되는 심판                                                                   |                                            |                    |                                                |                                                                                                                  |
|                | 특허소송  | 심결취소소송으로서 심판의 심결에 대한 불복 또는 심판관의 각하결정등에 대하여 불복하려는 경우 제기하는 소송                          |                                            |                    |                                                |                                                                                                                  |
|                | 상고    | 특허법원의 판결에 불복하려는 자가 법률심을 받기 위하여 대법원에 제기하는 소송                                          |                                            |                    |                                                |                                                                                                                  |

## I 법조문

**제132조의16 【특허심판원】**

- ① (역할) 특허·실용신안에 관한 취소신청, 특허·실용신안·디자인·상표에 관한 심판과 재심 및 이에 관한 조사·연구 사무를 관장하게 하기 위하여 지식재산청장 소속으로 특허심판원을 둔다. <개정 2016.2.29.>
- ② (구성) 특허심판원에 원장과 심판관을 둔다.
- ③ 특허심판원에 제1항에 따른 조사·연구와 그 밖의 사무를 담당하는 인력을 둘 수 있다. <신설 2021. 8. 17.>
- ④ 특허심판원의 조직과 정원 및 운영에 필요한 사항은 대통령령[지식재산청과 그 소속기관 직제]으로 정한다. <개정 2021. 8. 17.>

[전문개정 2014.6.11.]

[제132조의2에서 이동 &lt;2016.2.29.&gt;]

**제143조 【심판관】 法 132의7 / 226**

- ① (심판관의 심판) 특허심판원장은 심판이 청구되면 심판관에게 심판하게 한다.
- ② (심판관의 자격) 심판관의 자격은 대통령령[시행령 제8조 제2항]으로 정한다.
- ③ (심판관의 독립) 심판관은 직무상 독립하여 심판한다. 法 144②

[전문개정 2014.6.11.]

**제144조 【심판관의 지정】 法 132의7**

- ① (심판관합의체의 구성) 특허심판원장은 각 심판사건에 대하여 제146조에 따른 합의체를 구성할 심판관을 지정하여야 한다.
- ② (심판관의 교체) 특허심판원장은 제1항의 심판관 중 심판에 관여하는 데 지장이 있는 사람이 있으면 다른 심판관에게 심판하게 할 수 있다. 法 143③

[전문개정 2014.6.11.]

**제145조 【심판장】 法 132의7**

- ① (심판장의 지정) 특허심판원장은 제144조제1항에 따라 지정된 심판관 중에서 1명을 심판장으로 지정하여야 한다.
- ② (심판장의 업무) 심판장은 그 심판사건에 관한 사무를 총괄한다.

[전문개정 2014.6.11.]

**제146조 【심판의 합의체】 法 132의7**

- ① (심판의 주체) 심판은 3명 또는 5명의 심판관으로 구성되는 합의체가 한다.
- ② (합의: 과반수) 제1항의 합의체의 합의는 과반수로 결정한다.
- ③ (합의: 비공개) 심판의 합의는 공개하지 아니한다.

[전문개정 2014.6.11.]

**제147조 【답변서 제출 등】**

- ① (부분 송달 및 답변서 제출기회의 부여) 심판장은 심판이 청구되면 심판청구서 부분을 피청구인에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 法 132의4③ / 171, 136⑨ / 133의2, 137③④
- ② (답변서 부분 송달) 심판장은 제1항의 답변서를 받았을 때에는 그 부분을 청구인에게 송달하여야 한다. 法 171, 136⑨
- ③ (당사자 심문) 심판장은 심판에 관하여 당사자를 심문할 수 있다. 法 132의15

[전문개정 2014.6.11.]

**제148조 【심판관의 제척】 法 68, 93 / 132의7 / 154의2⑥**

심판관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 심판에서 제척된다. <개정 2016.2.29.>

1. 심판관 또는 그 배우자이거나 배우자이었던 사람이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인인 경우
2. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 친족이거나 친족이었던 경우
3. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 법정대리인이거나 법정대리인이었던 경우
4. 심판관이 사건에 대한 증인, 감정인이거나 감정인이었던 경우

5. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 대리인이거나 대리인이었던 경우
6. 심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 심결에 관여한 경우
7. 심판관이 사건에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우

[전문개정 2014.6.11.]

#### **제149조 【제척신청】** 法 132의7 / 154의2⑥

제148조에 따른 제척의 원인이 있으면 당사자 또는 참가인은 제척신청을 할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### **제150조 【심판관의 기피】** 法 132의7 / 154의2⑥

- ① (주체적 요건 및 객체적 요건) 심판관에게 공정한 심판을 기대하기 어려운 사정이 있으면 당사자 또는 참가인은 기피신청을 할 수 있다.
- ② (시기적 요건) 당사자 또는 참가인은 사건에 대하여 심판관에게 서면 또는 구두로 진술을 한 후에는 기피신청을 할 수 없다. 다만, 기피의 원인이 있는 것을 알지 못한 경우 또는 기피의 원인이 그 후에 발생한 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### **제151조 【제척 또는 기피의 소명】** 法 132의7 / 154의2⑥

- ① (신청서의 제출) 제149조 또는 제150조에 따라 제척 또는 기피 신청을 하려는 자는 그 원인을 적은 서면을 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 다만, 구술심리를 할 때에는 구술로 할 수 있다.
- ② (원인 소명) 제척 또는 기피의 원인은 신청한 날부터 3일 이내에 소명하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### **제152조 【제척 또는 기피 신청에 관한 결정】** 法 132의7 / 154의2⑥

- ① (결정) 제척 또는 기피 신청이 있으면 심판으로 결정하여야 한다.
- ② (심판 관여 배제) 제척 또는 기피 신청의 대상이 된 심판관은 그 제척 또는 기피에 대한 심판에 관여할 수 없다. 다만, 의견을 진술할 수 있다.
- ③ (방식) 제1항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.
- ④ (불복 不可) 제1항에 따른 결정에 대해서는 불복할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### **제153조 【심판절차의 중지】** 法 132의7

제척 또는 기피 신청이 있으면 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 심판절차를 중지하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### **제153조의2 【심판관의 회피】** 法 132의7

심판관이 제148조 또는 제150조에 해당하는 경우에는 특허심판원장의 허가를 받아 그 사건에 대한 심판을 회피할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

### ■ 심판원의 조직 및 구성(法 132의16, 143-147) + 심판관의 제척, 기피 및 회피(法 148-153의2)

## II 심판관의 제척·기피 및 회피(法 148~153의2)

| 제 도     |                 |                                                                                                                                   | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서       | 의의              | 제척                                                                                                                                | 심판관이 법정사유에 해당하는 경우 법률상 당연히 그 심판의 관여로부터 배제되는 것을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                 | 기피                                                                                                                                | 심판관에게 심판의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있을 때 당사자 또는 참가인의 신청과 결정에 의하여 그 사건에 관여할 수 없게 하는 것을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 취지              |                                                                                                                                   | 심판의 공정성 확보                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 요건      | 주체적             |                                                                                                                                   | 당사자 또는 참가인의 신청                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 객체적             | 제척                                                                                                                                | 1. 심판관 또는 그 배우자이거나 배우자이었던 사람이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인인 경우<br>2. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 친족이거나 친족이었던 경우<br>3. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 법정대리인이거나 법정대리인이었던 경우<br>4. 심판관이 사건에 대한 증인, 감정인이거나 감정인이었던 경우<br>5. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 대리인이거나 대리인이었던 경우<br>6. 심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 심결에 관여한 경우<br>① 사건이란 동일사건을 의미. 따라서, 거절결정불복심판사건에 관여한 심판관은 그 후의 특허무효심판사건에 제척되어야 한다(2000허3463). 그러나, 정정심판에 관여한 심판관이 같은 특허에 대한 무효심판에 관여하였다 하더라도 제척원인에 해당한다고 할 수 없다(98허1822).<br>② 관여한 경우란 최종처분에 관여한 것을 의미. 따라서, 거절이유통지에 관여한 경우는 해당×(78후3)<br>7. 심판관이 사건에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우 |
|         |                 | 기피                                                                                                                                | 심판관에게 공정한 심판을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 시기적             | 제척                                                                                                                                | 신청여부에 관계없이 법률상 당연히 심판관여로부터 배제되지만 직권발동의 촉구를 위하여 심결시까지 신청, 심결 후에는 확정 전에는 심결취소소송으로, 확정 후에는 재심으로 다투어야 함.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                 | 기피                                                                                                                                | 당사자 또는 참가인은 사건에 대하여 심판관에게 서면 또는 구두로 진술을 한 후에는 기피신청을 할 수 없다. 다만, 기피의 원인이 있는 것을 알지 못한 경우 또는 기피의 원인이 그 후에 발생한 경우에는 그러하지 아니하다(法 150②)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 절차              | 신청서제출                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 소명      |                 | 제척 또는 기피의 신청을 한 날로부터 3일 이내 제척·기피의 원인을 소명하여야 한다(法 151②).                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 결정 및 불복 |                 | 1. 제척·기피의 신청을 당한 심판관은 그 제척 또는 기피에 대한 심판에 관여할 수 없으나, 의견을 진술할 수는 있다(法 152②)<br>2. 심판에 의하여 서면으로 이유를 붙여 결정. 그 결정에 대해서는 불복×(法 152①③④). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 심판절차중지  |                 | 제척 또는 기피 신청이 있으면 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 심판절차를 중지하여야 한다. 다만 긴급한 경우에는 그러하지 아니하다(法 153)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 효과      |                 |                                                                                                                                   | 1. 직무수행 불가. 심판관 교체.<br>2. 제척결정은 확인적 성질 / 기피결정은 형성적 성질을 가짐.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 관련문제    | 심사관의 제척         |                                                                                                                                   | 심판관의 제척규정은 심사단계에서의 심사관에 준용하나 전심판여 및 제척절차의 규정은 준용되지 아니한다(法 68, 93).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 심판관의 회피         |                                                                                                                                   | 심판관은 제척·기피사유에 해당하는 경우에는 특허심판원장의 허가를 받아 그 사건에 대한 심판을 회피할 수 있다(法 153의2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 기술심리관의 제척·기피·회피 |                                                                                                                                   | 기술심리관의 제척·기피는 특허법 및 민사소송법의 규정이 준용되며, 기술심리관은 특허법원장의 허가를 받아 회피할 수 있다(法 188의2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



# 55

## 심판의 당사자(청구인, 피청구인)(法 139)

### I 법조문

#### 제139조 【공동심판의 청구 등】(★★)

- ① (이해관계인의 심판청구) 동일한 특허권에 관하여 제133조제1항[특허무효심판], 제134조제1항·제2항[존속기간연장등록무효심판] 또는 제137조제1항[정정무효심판]의 무효심판이나 제135조제1항·제2항의 권리범위 확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다. <개정 2016.2.29.> 法 155① / 215
- ② (공유특허권자: 피청구인) 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다.
- ③ (공유특허권자: 청구인) 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다. 法 140②Ⅰ, 140의2②Ⅰ / 132의2, 133의2, 137③④
- ④ (청구인·피청구인 중 1인에게 정지원인이 있는 경우) 제1항 또는 제3항에 따른 청구인이나 제2항에 따른 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다. 法 132의8② / 155⑥

[전문개정 2014.6.11.]

## II 심판의 당사자(法 139)

| 요 건        |                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                     |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 서설         |                           | 당사자란 특허심판절차에 있어서 자기의 이름으로 심판을 요구하거나 요구받는 자이다. 청구인·피청구인이라고 부르며, 당사자능력자 중 당사자적격자가 심판의 당사자가 될 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                     |
| 당사자<br>능력자 | 의의                        | 일반적인 절차의 주체가 될 수 있는 자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |
|            | 내용                        | 권리능력을 가진 자 및 비법인 사단·재단(法 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                     |
| 심판별<br>적격자 | 의의                        | 해당 절차의 주체가 될 수 있는 자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                     |
|            | 구 분                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 청구인                                                                                                      | 피청구인                                                                |
|            | 거절결정불복심판<br>(法 132의17)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 출원인                                                                                                      | -                                                                   |
|            | 정정심판(法 136)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 특허권자                                                                                                     | -                                                                   |
|            | 무효심판<br>(法 133, 134, 137) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 이해관계인 또는 심사관<br>(다만 제33조제1항본문, 제44조를 위반한<br>경우에는 심사관 또는 특허를 받을 수<br>있는 권리를 가진 자가 특허무효심판(法<br>133) 청구 가능) | 특허권자                                                                |
|            | 권리범위<br>확인심판<br>(法 135)   | 적극적                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 특허권자, 전용실시권자                                                                                             | 과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나<br>현재 실시하고 있는 이해관계인<br>(실시할 예정이 있는 이해관계인 제외) |
|            |                           | 소극적                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나<br>현재 실시하고 있는 자뿐만 아니라 실시할<br>예정인 이해관계인                                            | 특허권자(전용실시권자 제외)                                                     |
|            | 통상실시권<br>허락심판<br>(法 138)  | 일반적                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 후출원 특허권자, 전용실시권자 또는<br>통상실시권자                                                                            | 선출원 특허권자, 전용실시권자, 실용신안권자<br>또는 디자인권자(상표권자 제외)                       |
|            |                           | 크로스<br>라이선스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 선출원 특허권자, 전용실시권자,<br>실용신안권자 또는 디자인권자                                                                     | 후출원 특허권자, 전용실시권자<br>(통상실시권자 제외)                                     |
| 당사자<br>적격자 | 적격자<br>로서<br>이해<br>관계인    | 1. 무효심판에서의 이해관계인<br>심판청구의 난립을 방지하고 심판사건의 적체를 해소하는 한편 산업질서의 안정화를 도모하기 위해 이해관계가 있는 자가 무효심판청구 가능. 이해관계인의 의미에 대하여 i) 권리의 대항을 받을 염려가 있는 자, ii) 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자 등 대법원 판례가 일치하지 않았으나, 2017후 2819 전원합의체 판결에서 후자를 지지함. 따라서 실시권자도 특별한 사정이 없는 한 이해관계인에 해당함. 여기서 특별한 사정이란 실시권자가 아무런 제한 없이 실시를 허락받아 특허권 그 자체를 취득한 것과 마찬가지로 볼 수 있거나, 당사자 간에 조합관계가 성립하는 등으로 실시권자가 특허권자와 그 법률상 이해관계를 같이하여 불이익이 없다는 등의 사정의 의미(2017허2727). |                                                                                                          |                                                                     |
|            |                           | 2. 권리범위확인심판에서의 이해관계인<br>특허권자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말한다. 구체적으로 적극적 권리범위확인심판(法 135)에서 피청구인으로서 이해관계인은 과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나 현재 실시하고 있는 자이며, 피청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없어 심결각하됨. 그에 반해 소극적 권리범위확인심판에서 청구인으로서 이해관계인은 과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나 현재 실시하고 있는 자뿐만 아니라 실시하고 있지 않다고 하더라도 실시할 예정이 있는 자도 포함됨                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                     |
| 공동<br>심판   | 공통<br>심판                  | 3. 이해관계의 판단 - 심결 시를 기준으로 판단. 심판청구 후 합의가 있었다는 사실만으로 곧바로 이해관계가 소멸하였다고 볼 수는 없고, 각각의 심판별로 합의에 이르게 된 경위, 합의의 내용, 합의 후의 사정 등을 종합하여 이해관계의 소멸 여부를 판단해야 함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                     |
|            |                           | 4. 주장 및 판단방법 - 심판청구이유 부분에 이해관계에 대한 주장을 해야 하며, 직권조사하여 판단함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                     |
| 총결의 효과     |                           | 1. 이해관계인 → 공동으로 심판을 청구할 수 있다(유사필수적 공동소송에 대응)(法 139①).<br>2. 공유 특허권자 → 모두를 청구인·피청구인으로 하여야 한다(고유필수적 공동소송에 대응)(法 139②③).<br>3. 1인에게 정지의 원인 → 모두에게 효력(法 139④).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                     |

# 56

## 심판의 참가인(法 155, 156)

### I 법조문

#### 제155조 【참가】 法 84①IX, X / 136⑤, 171 / 162⑥, 186②

- ① (당사자 참가: 요건) 제139조제1항에 따라 심판을 청구할 수 있는 자는 심리가 종결될 때까지 그 심판에 참가할 수 있다.
- ② (당사자 참가: 효과) 제1항에 따른 참가인은 피참가인이 그 심판의 청구를 취하한 후에도 심판절차를 속행할 수 있다.
- ③ (보조 참가: 요건) 심판의 결과에 대하여 이해관계를 가진 자는 심리가 종결될 때까지 당사자의 어느 한쪽을 보조하기 위하여 그 심판에 참가할 수 있다. 法 132의9①
- ④ (보조 참가: 효과) 제3항에 따른 참가인은 모든 심판절차를 밟을 수 있다. 法 132의9②
- ⑤ (참가인 1인에게 정지원인이 있는 경우) 제1항 또는 제3항에 따른 참가인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대해서도 그 효력이 발생한다. 法 132의9② / 139④

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제156조 【참가의 신청 및 결정】 法 132의9②

- ① (신청서 제출) 심판에 참가하려는 자는 참가신청서를 심판장에게 제출하여야 한다.
- ② (의견서 제출기회의 부여) 심판장은 참가신청이 있는 경우에는 참가신청서 부분을 당사자 및 다른 참가인에게 송달하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.
- ③ (참가여부의 결정) 참가신청이 있는 경우에는 심판으로 그 참가 여부를 결정하여야 한다.
- ④ (방식) 제3항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.
- ⑤ (불복 不可) 제3항에 따른 결정에 대해서는 불복할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

## II 심판의 참가인(法 155, 156)

| 제 도     |             | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서       | 의의          | 타인간의 심판계속 중에 그 심결에 대하여 이해관계 있는 제3자가 자기의 법률상의 이익을 보호하기 위해 심리가 종결될 때까지 어느 한쪽 당사자의 심판을 보조하거나 또는 스스로 심판청구의 당사자가 되어 심판절차에 관여하는 것을 말한다(法 155).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | 취지          | 심판의 적정·공평성 및 절차의 신속성과 경제성을 도모                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | 종류          | 1. 당사자참가<br>法 139①의 당사자 적격자가 타인간의 계속중인 심판에 참가하는 것을 말하며, 이는 심판청구인측에만 참가할 수 있다(法 155①).<br>2. 보조참가<br>심판결과에 법률상 이해관계를 가지는 자가 당사자의 어느 한쪽을 보조하기 위하여 심판에 참가하는 것으로서 당사자 참가와는 달리 당사자 중 어느 쪽에도 참가할 수 있다(法 155③).                                                                                                                                                                                                                                 |
| 요 건     | 주체적         | 1. 이해관계가 있을 것<br>① 당사자참가의 경우는 심판청구인 적격자로서의 이해관계가, 보조참가의 경우는 그 심판의 결과에 대하여 받을 구체적 이해관계가 요구<br>② 이해관계 유무의 판단시점은 참가허부 결정시<br>2. 행위능력이 있을 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 객체적         | 결정계 심판이 아닌 당사자계 심판일 것을 요한다. 따라서 특허무효심판, 정정무효심판, 특허권의 존속기간연장등록무효심판, 권리범위확인심판에 대해서만 참가할 수 있다. 다만 통상실시권허락심판의 경우에는 당사자참가가 아닌 보조참가만이 인정된다는 것이 통설이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 시기적         | 타인간의 심판절차가 계속중이어야 하며, 심리종결전이어야 한다(法 155①③).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 절 차     | 신청서제출       | 심판에 참가하려는 자는 심판장에게 참가신청서를 제출(法 156①)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 의견제출 기회부여   | 심판장은 당사자 및 다른 참가인에게 신청서 부분을 송달하고 기간을 정하여 의견서 제출기회를 주어야 한다(法 156②).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 결정/불복       | 서면으로 이유를 붙여 결정하고 그 결정에 대해서는 불복불가(法 156③④⑤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 효 과     | 지위와 권한      | 1. 당사자 참가인<br>당사자 참가인은 당사자로서 참가하는 것이므로 피참가인, 즉 심판청구인과 대등한 법적 지위를 갖는다. 그러므로 피참가인의 행위와 모순되는 절차를 밟을 수 있고, 피참가인이 그 심판의 청구를 취하한 후에도 심판절차를 속행할 수 있다(法 155②).<br>2. 보조 참가인<br>보조 참가인은 당사자 적격이 없는 자로서 어느 한쪽 당사자를 보조하기 위하여 심판에 참가한 자이므로 피참가인에게 종속된다. 그러나 참가인은 피참가인의 대리인이 아니며 자기의 이익을 주장하기 위해 독자적인 권한으로 심판에 관여하므로 독자성이 인정된다. 즉, 보조참가인은 공격·방어방법의 제출이나 그 밖의 모든 심판절차를 밟을 수 있다(法 155④). 다만, 당사자 참가인과는 달리 피참가인이 그 심판청구를 취하하면 참가인의 지위를 상실한다(法 155②반대해석). |
|         | 절차의 정지      | 참가인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대해서도 그 효력이 발생한다(法 155⑤).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 관 련 문 제 | 참가신청이 거부된 자 | 1. 심결등본을 송달받을 수 있는 권리<br>심판장은 심결이 확정된 경우 심결등본을 참가신청을 하였으나 참가가 거부된 자에게 송달해 주어야 한다.<br>2. 심결에 대한 특허법원에 소제기 가능<br>해당 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자는 해당 심결에 대하여 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 참가신청의 취하    | 1. 심결확정전까지 취하할 수 있다. 피참가인의 이익을 해하는 것이 아니므로 당사자의 동의를 필요로 하지 아니한다. 다만 ① 당사자 참가시 ② 심판 청구인의 심판청구 취하에 의하여 참가인만이 심판절차를 밟으며 ③ 피청구인의 답변서 제출이 있을 때는 피청구인의 동의를 받아야 취하할 수 있다.<br>2. 참가신청이 취하되면 참가신청은 없었던 것으로 간주된다.                                                                                                                                                                                                                                  |



## 국선대리인, 전문심리위원 및 참고인 (法 139의2, 154의2, 154의3)

### I 법조문

#### 제139조의2 【국선대리인】

- ① **(국선대리인 선임)** 특허심판원장은 총리령으로 정하는 요건을 갖춘 심판 당사자의 신청에 따라 대리인(이하 "국선대리인"이라 한다)을 선임하여 줄 수 있다. 다만, 심판청구가 이유 없음이 명백하거나 권리의 남용이라고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② **(수수료 감면)** 국선대리인이 선임된 당사자에 대하여 심판절차와 관련된 수수료를 감면할 수 있다.
- ③ 국선대리인의 신청절차 및 수수료 감면 등 국선대리인 운영에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

[본조신설 2019. 1. 8.]

#### 제154조의2 【전문심리위원】 法 226②, 226의2②

- ① **(직권에 의한 참여)** 심판장은 직권에 따른 결정으로 전문심리위원을 지정하여 심판절차에 참여하게 할 수 있다.
- ② **(지정)** 심판장은 제1항에 따라 전문심리위원을 심판절차에 참여시키는 경우 당사자의 의견을 들어 각 사건마다 1명 이상의 전문심리위원을 지정하여야 한다.
- ③ **(수당 등의 지급)** 전문심리위원에게는 총리령으로 정하는 바에 따라 수당을 지급하고, 필요한 경우에는 그 밖의 여비, 일당 및 숙박료를 지급할 수 있다.
- ④ 전문심리위원의 지정에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.
- ⑤ **(역할)** 제1항에 따른 전문심리위원에 관하여는 「민사소송법」 제164조의2제2항부터 제4항까지 및 제164조의3을 준용한다. 이 경우 "법원"은 "심판장"으로 본다.

#### 민사소송법 제164조의2, 제164조의3

##### 제164조의2(전문심리위원의 참여)

- ② 전문심리위원은 전문적인 지식을 필요로 하는 소송절차에서 설명 또는 의견을 기재한 서면을 제출하거나 기일에 출석하여 설명이나 의견을 진술할 수 있다. 다만, 재판의 합의에는 참여할 수 없다.
- ③ 전문심리위원은 기일에 재판장의 허가를 받아 당사자, 증인 또는 감정인 등 소송관계인에게 직접 질문할 수 있다.
- ④ 법원은 제2항에 따라 전문심리위원이 제출한 서면이나 전문심리위원의 설명 또는 의견의 진술에 관하여 당사자에게 구술 또는 서면에 의한 의견진술의 기회를 주어야 한다.

[본조신설 2007. 7. 13.]

##### 제164조의3(전문심리위원 참여결정의 취소)

- ① 법원은 상당하다고 인정하는 때에는 직권이나 당사자의 신청으로 제164조의2제1항에 따른 결정을 취소할 수 있다.
- ② 제1항에도 불구하고 당사자가 합의로 제164조의2제1항에 따른 결정을 취소할 것을 신청하는 때에는 법원은 그 결정을 취소하여야 한다.

[본조신설 2007. 7. 13.]

- ⑥ **(제척 및 기피 준용)** 제1항에 따른 전문심리위원의 제척 및 기피에 관하여는 제148조부터 제152조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "심판관"은 "전문심리위원"으로 본다. 法 188의2

[본조신설 2021. 4. 20.]

#### 제154조의3 【참고인 의견서의 제출】

- ① **(공공단체, 그 밖의 참고인의 의견서 제출)** 심판장은 산업에 미치는 영향 등을 고려하여 사건 심리에 필요하다고 인정되는 경우 공공단체, 그 밖의 참고인에게 심판사건에 관한 의견서를 제출하게 할 수 있다.
- ② **(국가기관과 지방자치단체의 의견서 제출)** 국가기관과 지방자치단체는 공익과 관련된 사항에 관하여 특허심판원에 심판사건에 관한 의견서를 제출할 수 있다.
- ③ **(의견진술기회의 부여)** 심판장은 제1항 또는 제2항에 따라 참고인이 제출한 의견서에 대하여 당사자에게 구술 또는 서면에 의한 의견진술의 기회를 주어야 한다.
- ④ 제1항 또는 제2항에 따른 참고인의 선정 및 비용, 준수사항 등 참고인 의견서 제출에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

[본조신설 2023. 9. 14.]

## II 전문심리위원

| 구 분           |    | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서             | 의의 | 심판장은 직권에 따른 결정으로 전문심리위원을 지정하여 심판절차에 참여하게 할 수 있고, 전문심리위원을 심판절차에 참여시키는 경우 당사자의 의견을 들어 각 사건마다 1명 이상의 전문심리위원을 지정하여야 한다. 전문심리위원에게는 총리령으로 정하는 바에 따라 수당을 지급하고, 필요한 경우에는 그 밖의 여비, 일당 및 숙박료를 지급할 수 있다(法 154의2①②③).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | 취지 | 최근 특히 분쟁 내용이 복잡·고도화되고 디지털 혁신·융복합 등 4차 산업혁명 시대의 일부 첨단기술 또는 현장지식이 필요한 분야에 대하여 심판의 전문성을 확보하기 위해 전문가의 협력 필요성이 증대되고 있음을 고려하여 2021. 10. 21. 시행되는 현행법(法律 제16208호, 2019. 1. 8. 일부개정)에서는 전문심리위원 제도를 도입하였다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 참여 및 참여결정의 취소 |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 전문심리위원은 전문적인 지식을 필요로 하는 심판절차에서 설명 또는 의견을 기재한 서면을 제출하거나 기일에 출석하여 설명이나 의견을 진술할 수 있다. 심판장은 전문심리위원이 제출한 서면이나 전문심리위원의 설명 또는 의견의 진술에 관하여 당사자에게 구술 또는 서면에 의한 의견진술의 기회를 주어야 한다. 다만, 심판의 합의에는 참여할 수 없다. 또한, 전문심리위원은 기일에 심판장의 허가를 받아 당사자, 증인 또는 감정인 등 소송관계인에게 직접 질문할 수 있다(法 154의2⑤ 준용 민소 164의2).</li> <li>2. 심판장은 상당하다고 인정하는 때에는 직권이나 당사자의 신청으로 전문심리위원의 참여결정을 취소할 수 있다. 한편, 당사자가 합의로 전문심리위원의 참여결정을 취소할 것을 신청하는 때에는 특허심판원은 그 결정을 취소하여야 한다(法 154의2⑤ 준용 민소 164의3).</li> </ol> |
| 제척 및 기피       |    | 전문심리위원의 제척 및 기피에 관하여는 심판관의 제척 및 기피에 관한 규정(法 148-152)을 준용한다. 이 경우 “심판관”은 “전문심리위원”으로 본다(法 154의2⑥).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 비밀누설죄 등       |    | 전문심리위원 또는 전문심리위원이었던 자가 그 직무수행 중에 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하는 경우에는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다(法 226②). 전문심리위원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정(제129조(수뢰, 사전수뢰), 제130조(제삼자뇌물제공), 제131조(수뢰후부정처사, 사후수뢰), 제132조(알선수뢰))를 적용할 때에는 공무원으로 본다(法 226의2②).                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**제140조 【심판청구방식】**

① **(심판청구서의 제출)** 심판을 청구하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. **法 132의4① / 132의2, 133의2, 137③④**

1. 당사자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
3. 심판사건의 표시
4. 청구의 취지 및 그 이유

② **(심판청구서의 보정)** 제1항에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.> **法 132의4② / 132의2, 133의2, 137③④**

1. 제1항제1호에 따른 당사자 중 특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(특허권자를 추가하는 것을 포함하되, 청구인이 특허권자인 경우에는 추가되는 특허권자의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우  
**法 139③**

2. 제1항제4호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우 **法 159①**

3. 제135조제1항에 따른 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상 발명(청구인이 주장하는 피청구인의 발명을 말한 다)의 설명서 또는 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상 발명의 설명서 또는 도면을 보정하는 경우

③ **(권리범위확인심판의 첨부사항)** 제135조제1항·제2항에 따른 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비할 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다. <개정 2016.2.29.>

④ **(통상실시권허락심판의 기재사항)** 제138조제1항에 따른 통상실시권 허락의 심판의 심판청구서에는 제1항 각 호의 사항 외에 다음 사항을 추가로 적어야 한다.

1. 실시하려는 자기의 특허의 번호 및 명칭
2. 실시되어야 할 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 번호·명칭 및 특허나 등록 연월일
3. 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 통상실시권의 범위·기간 및 대가

⑤ **(정정심판의 첨부사항)** 제136조제1항에 따른 정정심판을 청구할 때에는 심판청구서에 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 한다. **法 132의2, 133의2, 137③④**

[전문개정 2014.6.11.]

**제140조의2【특허거절결정에 대한 심판청구방식】**

① **(심판청구서의 제출)** 제132조의17에 따라 특허거절결정에 대한 심판을 청구하려는 자는 제140조제1항에도 불구하고 다음 각 호의 사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. <개정 2016.2.29.>

1. 청구인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
3. 출원일 및 출원번호
4. 발명의 명칭
5. 특허거절결정일
6. 심판사건의 표시
7. 청구의 취지 및 그 이유

② **(심판청구서의 보정)** 제1항에 따라 제출된 심판청구서를 보정하는 경우에는 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.



1. 제1항제1호에 따른 청구인의 기재를 바로잡기 위하여 보정(청구인을 추가하는 것을 포함하되, 그 청구인의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우 **法 139③**
  2. 제1항제7호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우 **法 159①**
- [전문개정 2014.6.11.]

■ 심판청구방식(法 140①, 140의2①) + 추가기재사항 및 첨부사항(法 140③④⑤)

| 심판의 분류       |               | 공동기재사항                                                                                                                                                                                                                                          | 추가 기재사항 및 첨부사항                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 결정<br>계      | 거절결정<br>불복심판  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당사자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)</li> <li>- 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)</li> <li>- 심판사건의 표시</li> <li>- 청구의 취지 및 그 이유</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 출원일 및 출원번호</li> <li>- 발명의 명칭</li> <li>- 특허거절결정일</li> </ul>                                                                                          |
|              | 정정심판          |                                                                                                                                                                                                                                                 | - 정정한 명세서 또는 도면을 첨부                                                                                                                                                                          |
| 당사<br>자<br>계 | 무효심판          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |
|              | 권리범위<br>확인심판  |                                                                                                                                                                                                                                                 | - 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면을 첨부                                                                                                                                                                   |
|              | 통상실시권<br>허락심판 |                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시하려는 자기의 특허의 번호 및 명칭</li> <li>- 실시되어야 할 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 번호·명칭 및 특허나 등록 연월일</li> <li>- 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 통상실시권의 범위·기간 및 대가</li> </ul> |

■ 심판청구서의 보정(法 140②, 140의2②) → 원칙적으로 요지변경이 되지 아니한 범위 내에서만 보정 인정

## I 법조문

**제141조 【심판청구서 등의 각하】(★) 法 84①Ⅷ / 132의5**

- ① **(대상)** 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다. 다만, 보정할 사항이 경미하고 명확한 경우에는 직권으로 보정할 수 있다. <개정 2023. 9. 14.>
1. 심판청구서가 제140조제1항 및 제3항부터 제5항까지 또는 제140조의2제1항을 위반한 경우
  2. 심판에 관한 절차가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
    - 가. 제3조제1항 또는 제6조를 위반한 경우
    - 나. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우
    - 다. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우
- ② **(각하결정)** 심판장은 제1항 본문에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 제140조제2항 또는 제140조의2제2항을 위반한 경우에는 심판청구서 또는 해당 절차와 관련된 청구나 신청 등을 결정으로 각하하여야 한다. <개정 2016. 2. 29., 2023. 9. 14.>
- ③ **(방식)** 제2항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.
- ④ **(직권보정의 절차: 통지)** 심판장은 제1항 단서에 따라 직권보정을 하려면 그 직권보정 사항을 청구인에게 통지하여야 한다. <신설 2023. 9. 14.>
- ⑤ **(직권보정의 절차: 의견서의 제출)** 청구인은 제1항 단서에 따른 직권보정 사항을 받아들일 수 없으면 직권보정 사항의 통지를 받은 날부터 7일 이내에 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 심판장에게 제출하여야 한다. <신설 2023. 9. 14.>
- ⑥ **(직권보정의 효과: 의견서가 제출된 경우)** 청구인이 제5항에 따라 의견서를 제출한 경우에는 해당 직권보정 사항은 처음부터 없었던 것으로 본다. <신설 2023. 9. 14.>
- ⑦ **(직권보정의 효과: 명백히 잘못된 경우)** 제1항 단서에 따른 직권보정이 명백히 잘못된 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다. <신설 2023. 9. 14.>

[전문개정 2014. 6. 11.]

[제목개정 2016. 2. 29.]

**제142조 【보정할 수 없는 심판청구의 심결각하】(★) 法 132의6**

부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고, 심결로써 그 청구를 각하할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

## II 방식심리와 적법성심리(法 141~142)

| 제 도 |     | 방식심리(法 141)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 적법성심리(法 142)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 의 의 |     | 심판장의 심판청구서에 대한 적식심리, 즉 심판청구서가 법령에 정한 방식에 적합한지 여부를 심리하는 것을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                               | 심판관 합의체가 심판청구 자체의 적법성 여부를 심리하는 것을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 요 건 | 주 체 | 심판장                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 심판관 합의체                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 대 상 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 심판청구서 기재방식 위반(法 140①③④⑤, 法 140의 2①)</li> <li>2. 심판에 관한 절차가 다음에 해당하는 경우 <ol style="list-style-type: none"> <li>① 행위능력(法 3) 위반</li> <li>② 대리권범위(法 6) 위반</li> <li>③ 수수료 불납</li> <li>④ 이 법에서 정한 방식 위반</li> </ol> </li> </ol>                                                           | <p>부적법한 심판청구로서 흠을 보정할 수 없을 경우, 구체적인 예를 들면,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 특허심판사항이 아닌 심판청구</li> <li>2. 실존하지 아니한 자를 당사자로 하는 심판청구</li> <li>3. 당사자능력이 없는 자의 심판청구</li> <li>4. 당사자적격이 없는 자의 심판청구(이해관계 없는 자나 공유자 중의 일부만을 당사자로 한 심판청구)</li> <li>5. 심판청구기간이 지난 후의 심판청구</li> <li>6. 제척·기피 심판의 불복심판청구</li> <li>7. 일사부재리에 위반된 경우</li> <li>8. 심판청구 시에는 적법한 심판청구였으나 심판청구 후 대상출원이 취하·포기된 경우</li> <li>9. 심결확정 전에 재심청구</li> <li>10. 중복심판청구금지의 원칙에 위반된 경우</li> <li>11. 권리범위확인심판에서 확인의 이익이 없는 경우(i) 확인대상발명이 청구취지와 청구원인으로서 특정되지 않은 경우, ii) 실시하고 있는 발명(실시한 적이 있는 발명)을 대상으로 한 심판에서 확인대상발명이 실시하고 있는 발명과 사실적 관점에서 일치하지 않아서 동일성이 없는 경우, iii) 특허권 대 특허권(실용신안권) 간의 저촉관계를 확인하는 적극적 권리범위확인심판의 경우, iv) 권리가 소멸한 경우 등)</li> <li>12. 그 밖의 부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없는 경우</li> </ol> |
| 절 차 |     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 보정기회부여</li> <li>2. 보정할 사항이 경미하고 명확한 경우에는 직권보정 가능 <ol style="list-style-type: none"> <li>① 심판장이 직권보정 사항 통지</li> <li>② 청구인이 받아들일 수 없으면 통지를 받은 날로부터 7일 이내 의견서를 심판장에게 제출하고, 의견서 제출한 경우 해당 직권보정사항은 처음부터 없었던 것으로 간주</li> <li>③ 직권보정사항이 명백히 잘못된 경우 처음부터 없었던 것으로 간주</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 피청구인에게 답변서제출기회(재량) - 언제든지 심결 각하 가능</li> <li>2. 심판청구가 보정가능한 것이라면 보정기회를 주어야 함.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 효 과 |     | 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 요지변경인 경우(法 140②, 140의2② 위반)에는 심판청구서 또는 해당 절차와 관련된 청구나 신청 등을 결정각하                                                                                                                                                                                                                    | 심판청구 심결각하                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 불 복 |     | 심판청구서의 각하결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 소 제기 / 지식재산처장이 피고.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 소 제기 / 결정계 심판은 지식재산처장, 당사자계 심판은 원심판의 피청구인이 피고                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Ⅲ 심사단계에서 직권보정과 심판단계에서 직권보정의 비교

| 제 도 | 심사단계에서의 직권보정(제66조의2)                                                                                                                                                                                                             | 심판단계에서의 직권보정(제141조)                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요 건 | 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우. 단, 신규사항이 추가되지 아니한 범위에서 가능                                                                                                                                               | 심판청구서의 보정할 사항이 경미하고 명확한 경우                                                                                                  |
| 절 차 | 1. 심사관이 직권보정을 하려면 특허결정의 등본 송달과 함께 출원인에게 통지<br>2. 특허출원인은 직권보정 사항의 일부 또는 전부를 받아들일 수 없으면 특허료를 낼 때까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 지식재산처장에게 제출                                                                                                  | 1. 심판장이 청구인에게 통지<br>2. 청구인이 받아들일 수 없으면 통지를 받은 날로부터 7일 이내 의견서를 심판장에게 제출                                                      |
| 효 과 | 1. 의견서 제출한 경우<br>① 해당 직권보정사항은 처음부터 없었던 것으로 간주<br>② 그 특허결정도 함께 취소된 것으로 간주. 다만, 요약서에 관한 직권보정 사항만 처음부터 없었던 것으로 보는 경우는 제외<br>2. 의견서를 제출하지 않은 경우<br>직권보정 수용한 것으로 취급. 단, 직권보정사항이 신규사항을 추가하거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 처음부터 없었던 것으로 간주 | 1. 의견서 제출한 경우<br>해당 직권보정사항은 처음부터 없었던 것으로 간주<br>2. 의견서를 제출하지 않은 경우<br>직권보정 수용한 것으로 취급. 단, 직권보정사항이 명백히 잘못된 경우 처음부터 없었던 것으로 간주 |



## 본안심리(法 154, 157~160)

### I 법조문

#### 제154조【심리 등】 法 132의8①

- ① **(심리방식의 선택)** 심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청하였을 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다. <개정 2014.6.11.>
- ② 삭제 <2001.2.3.>
- ③ **(구술심리: 공개)** 구술심리는 공개하여야 한다. 다만, 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋날 우려가 있으면 그러하지 아니하다. <개정 2014.6.11.>
- ④ **(구술심리: 통지)** 심판장은 제1항에 따라 구술심리로 심판을 할 경우에는 그 기일 및 장소를 정하고, 그 취지를 적은 서면을 당사자 및 참가인에게 송달하여야 한다. 다만, 해당 사건의 이전 심리에 출석한 당사자 및 참가인에게 알렸을 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2014.6.11.>
- ⑤ **(구술심리: 조서작성)** 심판장은 제1항에 따라 구술심리로 심판을 할 경우에는 특허심판위원장이 지정한 직원에게 기일마다 심리의 요지와 그 밖에 필요한 사항을 적은 조서를 작성하게 하여야 한다. <개정 2014.6.11.>
- ⑥ **(구술심리: 기명날인)** 제5항의 조서에는 심판의 심판장 및 조서를 작성한 직원이 기명날인하여야 한다. <개정 2014.6.11.>
- ⑦ **(준용규정)** 제5항의 조서에 관하여는 「민사소송법」 제153조·제154조 및 제156조부터 제160조까지의 규정을 준용한다. <개정 2014.6.11.>

#### 민사소송법 제153조, 제154조, 제156조-제160조

##### 제153조(형식적 기재사항)

조서에는 법원사무관등이 다음 각호의 사항을 적고, 재판장과 법원사무관등이 기명날인 또는 서명한다. 다만, 재판장이 기명날인 또는 서명할 수 없는 사유가 있는 때에는 합의부원이 그 사유를 적은 뒤에 기명날인 또는 서명하며, 법관 모두가 기명날인 또는 서명할 수 없는 사유가 있는 때에는 법원사무관등이 그 사유를 적는다. <개정 2017. 10. 31.>

1. 사건의 표시
2. 법관과 법원사무관등의 성명
3. 출석한 검사의 성명
4. 출석한 당사자·대리인·통역인과 출석하지 아니한 당사자의 성명
5. 변론의 날짜와 장소
6. 변론의 공개여부와 공개하지 아니한 경우에는 그 이유

##### 제154조(실질적 기재사항)

조서에는 변론의 요지를 적되, 특히 다음 각호의 사항을 분명히 하여야 한다.

1. 화해, 청구의 포기·인낙, 소의 취하와 자백
2. 증인·감정인의 선서와 진술
3. 검증의 결과
4. 재판장이 적도록 명한 사항과 당사자의 청구에 따라 적는 것을 허락한 사항
5. 서면으로 작성되지 아니한 재판
6. 재판의 선고

##### 제156조(서면 등의 인용·첨부)

조서에는 서면, 사진, 그 밖에 법원이 적당하다고 인정한 것을 인용하고 소송기록에 붙여 이를 조서의 일부로 삼을 수 있다.

##### 제157조(관계인의 조서낭독 등 청구권)

조서는 관계인이 신청하면 그에게 읽어 주거나 보여주어야 한다.

##### 제158조(조서의 증명력)

변론방식에 관한 규정이 지켜졌다는 것은 조서로만 증명할 수 있다. 다만, 조서가 없어진 때에는 그러하지 아니하다.

**제159조(변론의 속기와 녹음)**

- ① 법원은 필요하다고 인정하는 경우에는 변론의 전부 또는 일부를 녹음하거나, 속기자로 하여금 받아 적도록 명할 수 있으며, 당사자가 녹음 또는 속기를 신청하면 특별한 사유가 없는 한 이를 명하여야 한다.
- ② 제1항의 녹음테이프와 속기록은 조서의 일부로 삼는다.
- ③ 제1항 및 제2항의 규정에 따라 녹음테이프 또는 속기록으로 조서의 기재를 대신한 경우에, 소송이 완결되기 전까지 당사자가 신청하거나 그 밖에 대법원규칙이 정하는 때에는 녹음테이프나 속기록의 요지를 정리하여 조서를 작성하여야 한다.
- ④ 제3항의 규정에 따라 조서가 작성된 경우에는 재판이 확정되거나, 양 쪽 당사자의 동의가 있으면 법원은 녹음테이프와 속기록을 폐기할 수 있다. 이 경우 당사자가 녹음테이프와 속기록을 폐기한다는 통지를 받은 날부터 2주 이내에 이의를 제기하지 아니하면 폐기에 대하여 동의한 것으로 본다.

**제160조(다른 조서에 준용하는 규정)**

법원·수명법관 또는 수탁판사의 신문(訊問) 또는 심문과 증거조사에는 제152조 내지 제159조의 규정을 준용한다.

- ⑧ **(준용규정)** 심판에 관하여는 「민사소송법」 제143조·제259조[중복된 소제기의 금지]·제299조 및 제367조를 준용한다. <개정 2014.6.11.>

**민사소송법 제143조, 제259조, 제299조, 제367조**

**제143조(통역)**

- ① 변론에 참여하는 사람이 우리말을 하지 못하거나, 듣거나 말하는 데 장애가 있으면 통역인에게 통역하게 하여야 한다. 다만, 위와 같은 장애가 있는 사람에게는 문자로 질문하거나 진술하게 할 수 있다.
- ② 통역인에게는 이 법의 감정인에 관한 규정을 준용한다.

**제259조(중복된 소제기의 금지)**

법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.

**제299조(소명의 방법)**

- ① 소명은 즉시 조사할 수 있는 증거에 의하여야 한다.
- ② 법원은 당사자 또는 법정대리인으로 하여금 보증금을 공탁하게 하거나, 그 주장이 진실하다는 것을 선서하게 하여 소명에 갈음할 수 있다.
- ③ 제2항의 선서에는 제320조, 제321조제1항·제3항·제4항 및 제322조의 규정을 준용한다.

**제367조(당사자신문)**

법원은 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 당사자 본인을 신문할 수 있다. 이 경우 당사자에게 선서를 하게 하여야 한다.

- ⑨ **(구술심리: 질서유지)** 심판장은 구술심리 중 심판정 내의 질서를 유지한다.

<신설 2014.6.11.>

[제목개정 2014.6.11.]

**제157조【증거조사 및 증거보전】(★) 法 132의15**

- ① **(증거조사 증거보전: 일반)** 심판에서는 당사자, 참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다.
- ② **(준용규정)** 제1항에 따른 증거조사 및 증거보전에 관하여는 「민사소송법」 중 증거조사 및 증거보전에 관한 규정을 준용한다. 다만, 심판관은 다음 각 호의 행위는 하지 못한다.
  1. 과태료의 결정
  2. 구인(拘引)을 명하는 행위
  3. 보증금을 공탁하게 하는 행위
- ③ **(증거보전: 심판청구 전)** 증거보전신청은 심판청구 전에는 특허심판원장에게 하고, 심판계속 중에는 그 사건의 심판장에게 하여야 한다.
- ④ **(증거보전: 심판청구 전)** 특허심판원장은 심판청구 전에 제1항에 따른 증거보전신청이 있으면 그 신청에 관여할 심판관을 지정한다.
- ⑤ **(증거조사 증거보전: 직권)** 심판장은 제1항에 따라 직권으로 증거조사나 증거보전을 하였을 때에는 그 결과를 당사자, 참가인 또는 이해관계인에게 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

**제158조【심판의 진행】 法 132의15**

심판장은 당사자 또는 참가인이 법정기간 또는 지정기간에 절차를 밟지 아니하거나 제154조제4항에 따른 기일에 출석하지 아니하여도 심판을 진행할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

## 제158조의2 【적시제출주의】

심판절차에서의 주장이나 증거의 제출에 관하여는 「민사소송법」 제146조[적시제출주의], 제147조[제출기간의 제한] 및 제149조[실기한 공격·방어방법의 각하]를 준용한다.

[본조신설 2021. 8. 17.]

### 민사소송법 제146조, 제147조, 제149조

#### 제146조(적시제출주의)

공격 또는 방어의 방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다.

#### 제147조(제출기간의 제한)

- ① 재판장은 당사자의 의견을 들어 한 쪽 또는 양 쪽 당사자에 대하여 특정한 사항에 관하여 주장을 제출하거나 증거를 신청할 기간을 정할 수 있다.
- ② 당사자가 제1항의 기간을 넘긴 때에는 주장을 제출하거나 증거를 신청할 수 없다. 다만, 당사자가 정당한 사유로 그 기간 이내에 제출 또는 신청하지 못하였다는 것을 소명한 경우에는 그러하지 아니하다.

#### 제149조(실기한 공격·방어방법의 각하)

- ① 당사자가 제146조의 규정을 어기어 고의 또는 중대한 과실로 공격 또는 방어방법을 뒤늦게 제출함으로써 소송의 완결을 지연시키게 하는 것으로 인정할 때에는 법원은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다.
- ② 당사자가 제출한 공격 또는 방어방법의 취지가 분명하지 아니한 경우에, 당사자가 필요한 설명을 하지 아니하거나 설명할 기일에 출석하지 아니한 때에는 법원은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다.

## 제159조 【직권심리】(★★) 法 132의10 / 140②Ⅱ, 140의2②Ⅱ

- ① **(범위)** 심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. **(의견서 제출기회의 부여)** 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다. 法 132의13② / 185 / 133의2, 137③④
- ② **(한계)** 심판에서는 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대해서는 심리할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

## 제160조 【심리·심결의 병합 또는 분리】 法 132의11

심판관은 당사자 양쪽 또는 어느 한쪽이 동일한 둘 이상의 심판에 대하여 심리 또는 심결을 병합하거나 분리할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]



## II 본안심리(法 154, 157~160)

| 구 분         |                                  | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |      |        |   |                         |        |                                  |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--------|---|-------------------------|--------|----------------------------------|
| 서설          |                                  | 해당 심판청구가 이유 있는지 여부를 심리하는 것으로서, 보다 구체적으로는 심판청구에 대하여 심결을 하기 위하여 기초가 될 심판자료, 즉 사실과 증거를 수집하는 것을 말한다. 심판의 심리절차는 민사소송의 심리절차를 대부분 준용하나(法 154⑧) 특허심판의 결과는 당사자뿐만 아니라 널리 제3자의 이해에도 영향을 미치기 때문에 대세적 효력을 피할 필요가 있어 직권주의적 요소가 강화되어 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |      |        |   |                         |        |                                  |
| 심리방식        |                                  | “심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청한 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다.”고 하여 서면 또는 구술에 의하여 심리하도록 하였다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청한 때에는 특별한 사정이 없는 한 구술심리를 열도록 하고 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |      |        |   |                         |        |                                  |
| 직 권 진 행 주 의 | 의의                               | 심판절차의 진행에 있어 당사자가 아닌 심판관이 직권에 의하여 심판절차의 주도권을 가지는 것을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |   |                         |        |                                  |
|             | 심판의 진행                           | 심판장은 당사자 또는 참가인이 법정기간 또는 지정기간에 절차를 밟지 않거나 구술심리 기일에 출석하지 아니하여도 심판을 진행할 수 있다(法 158).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |      |        |   |                         |        |                                  |
|             | 심리의 분리 또는 병합                     | 심판관은 당사자 양쪽 또는 어느 한쪽이 동일한 둘 이상의 심판에 대하여 심리 또는 심결을 병합하거나 분리할 수 있다(法 160).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |   |                         |        |                                  |
|             | 적시제출 주의                          | 심판절차에서의 주장이나 증거의 제출에 관하여는 「민사소송법」 제146조(적시제출주의), 제147조(제출기간의 제한) 및 제149조(실기한 공격·방어방법의 각하)를 준용한다(法 158의2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |      |        |   |                         |        |                                  |
|             | 기일의 지정 등                         | 심판장은 기일을 지정한 때에는 청구에 따라 또는 직권으로 그 기일을 변경할 수 있으며, 지정기간을 연장할 수도 있다(法 152③, 154④). 또한 심판관은 심판절차의 중지 또는 중단된 절차 등의 수계를 명할 수도 있다(法 22, 23).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |        |   |                         |        |                                  |
| 심 리 진 행     | 의의                               | 심판관이 당사자의 주장에 구속되지 않고 심판에 있어서 필요한 사실을 적극적으로 탐지할 수 있는 것을 말한다. 직권탐지주의는 심판부의 권능이지 의무는 아닐 것이어서 직권으로 탐지하거나 증거조사를 하지 않았다고 하여 위법이 되는 것은 아니라 할 것이다(92후2090, 93후107).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |      |        |   |                         |        |                                  |
|             | 직권심리                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유 또는 취하한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있다. 다만, 이 경우 당사자 또는 참가인에게 의견서제출기회를 주어야 한다(法 159①).</li> <li>당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 취지에 대해서는 심리할 수 없다(法 159②). <ol style="list-style-type: none"> <li>소극적 권리범위확인심판청구가 이유가 없으면 그 청구를 배척함에 그쳐야 하고 나아가 적극적으로 그것이 권리범위에 속한다는 내용의 심결을 한 것은 위법이다(70후20).</li> <li>다항의 청구항 중 하나의 청구항에 대해서 특허무효심판이 청구된 경우 다른 청구항에 대해서 특허무효의 이유가 발견되었다고 하더라도 심판관이 이를 심리할 수는 없다. 특허무효심판의 경우 청구항을 달리 하면 청구취지를 달리 하기 때문이다.</li> <li>한편, 정정심판을 청구한 것은 일체불가분의 1개의 정정사항으로 하여 정정심판을 청구한 것으로 본다. 그러므로 명세서의 일부에 대하여 정정을 인정 또는 불인정하는 것은 결국 1개의 기술적 사상인 발명을 분리하여 판단하는 것이 되며, 청구인이 신청하지 아니한 취지에 대하여 심리하는 것이 되므로 일부인용 또는 일부기각심결은 인정되지 아니한다고 할 것이다.</li> </ol> </li> <li>재심의 경우 당사자가 불복한 범위내에서 심리할 수 있으므로 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대해서 심리할 수 없다(法 184).</li> </ol> |     |      |      |        |   |                         |        |                                  |
|             | 증거조사·증거보전                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>특허심판의 증거조사 및 증거보전에 대해서는 민사소송법 중 증거조사 및 증거보전에 관한 규정을 준용한다(法 157②본문). 구체적으로는 증인신문, 감정, 서증, 검증, 당사자신문 등이 있다. 다만, 특허심판은 직권주의에 의한 것이므로 민사소송법 중 당사자주의와 관련된 규정은 준용하지 아니한다. 예를 들어, 불요증사실 중 재판상 자백(民訴法 288), 당사자가 문서를 제출하지 아니한 때의 효력(民訴法 349), 당사자가 사용을 방해한 때의 효과(民訴法 350), 출석·선서·진술의 의무(民訴法 369)는 준용하지 아니한다.</li> <li>다만, 심판관은 과태료의 결정을 하거나 구인을 명하거나 보증금을 공탁하게 하지 못한다(法 157②단서).</li> <li>구체적 방법(法 157①③④⑤) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>증거조사</th><th>증거보전</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>심판청구 전</td><td>×</td><td>심판원장에게 신청(심판원장이 심판관 지정)</td></tr> <tr> <td>심판청구 후</td><td>1. 심판장에게 신청<br/>2. 직권 → 의견진술기회 부여</td><td></td></tr> </tbody> </table> </li> </ol>                                                                                    | 구 분 | 증거조사 | 증거보전 | 심판청구 전 | × | 심판원장에게 신청(심판원장이 심판관 지정) | 심판청구 후 | 1. 심판장에게 신청<br>2. 직권 → 의견진술기회 부여 |
| 구 분         | 증거조사                             | 증거보전                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |      |        |   |                         |        |                                  |
| 심판청구 전      | ×                                | 심판원장에게 신청(심판원장이 심판관 지정)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |      |        |   |                         |        |                                  |
| 심판청구 후      | 1. 심판장에게 신청<br>2. 직권 → 의견진술기회 부여 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |      |        |   |                         |        |                                  |

# 61

## 심판청구의 취하(法 161)

### I 법조문

#### 제161조 【심판청구의 취하】 法 84①XI / 132의12

- ① **(주체적 및 시기적 요건)** 심판청구는 심결이 확정될 때까지 취하할 수 있다. 다만, 답변서가 제출된 후에는 상대방의 동의를 받아야 한다.
- ② **(객체적 요건)** 둘 이상의 청구항에 관하여 제133조제1항의 무효심판 또는 제135조의 권리범위 확인심판을 청구하였을 때에는 청구항마다 취하할 수 있다.
- ③ **(효과)** 제1항 또는 제2항에 따른 취하가 있으면 그 심판청구 또는 그 청구항에 대한 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 본다. 法 164의2③

[전문개정 2014.6.11.]

## II 참가의 취하 및 심판청구의 취하의 비교

| 제 도 |     | 참가의 취하                                                                                                                          | 심판청구의 취하                                                                 |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 요 건 | 주체적 | 1. 참가인이 취하<br>2. 원칙적으로 상대방 동의를 요하지 않으나 i) 당사자 참가시 ii) 심판 청구인의 심판청구 취하에 의하여 참가인만이 심판절차를 밟으며 iii) 피청구인의 답변서 제출이 있을 때는 피청구인의 동의 必要 | 1. 심판청구인이 취하<br>2. 원칙적으로 피청구인의 동의를 필요로 하지 않으나 피청구인의 답변서 제출이 있는 후에는 동의 必要 |
|     | 객체적 | 참가                                                                                                                              | 1. 심판청구<br>2. 특허무효심판·권리범위확인심판 경우 청구항마다 가능                                |
|     | 시기적 | 심결확정 전                                                                                                                          | 심결확정 전                                                                   |
| 절 차 |     | 취하서의 제출(심판청구를 취하하기로 합의했으나, 취하서를 제출하지 아니한 경우 취하의 효력이 발생하지 아니하지만 심결 시를 기준으로 이해관계가 없어져 심결각하)                                       |                                                                          |
| 효 과 |     | 참가신청이 없었던 것으로 간주                                                                                                                | 심판청구가 없었던 것으로 간주                                                         |



## 심결(法 162, 163)

### I 법조문

#### 제162조 【심결】

- ① **(심결에 의한 종료)** 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결한다. **法 132의13①④**
- ② **(심결의 방식)** 제1항의 심결은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 하며, 심결을 한 심판관은 그 서면에 기명날인하여야 한다. **法 132의14①**
1. 심판의 번호
  2. 당사자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
  3. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
  4. 심판사건의 표시
  5. 심결의 주문(제138조에 따른 심판의 경우에는 통상실시권의 범위·기간 및 대가를 포함한다)
  6. 심결의 이유(청구의 취지 및 그 이유의 요지를 포함한다)
  7. 심결연월일
- ③ **(심리종결통지)** 심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.
- ④ **(심리재개)** 심판장은 필요하다고 인정하면 제3항에 따라 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다.
- ⑤ **(심결시기)** 심결은 제3항에 따른 심리종결통지를 한 날부터 20일 이내에 한다.
- ⑥ **(송달)** 심판장은 심결 또는 결정이 있으면 그 등본을 당사자, 참가인 및 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다. **法 132의14② / 186② / 186③④⑤**

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제163조 【일사부재리】(★★)

이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.

## II 심결(法 162)

| 구 분 |         | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서   |         | 합의체로서 심판관이 내리는 심판청구에 대한 최종적 판단으로 심리를 통해 인식하게 된 사실에 대한 법의 적용이라 할 수 있다. 심판은 청구의 취하 등 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결된다(法 162①).                                                                                                                                                                                                                          |
| 종 류 | 각하심결    | 각하심결이란 심판청구요건의 불비를 이유로 그 심판청구를 부적법각하하는 심결을 말한다. 심판청구가 부적법하고 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 심결로써 그 청구를 각하할 수 있다(法 142).                                                                                                                                                                                                                |
|     | 본안심결    | 본안심결이란 청구의 당부에 대한 판단, 즉 심판청구취지에 대한 심결을 말한다. 본안심결은 심판청구인의 주장이 인용되는 “인용심결”과 심판청구인의 주장이 배제되는 “기각심결”로 구별된다.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 절 차 | 방식      | 심결은 다음 사항을 적은 서면으로 하여야 하며 심결한 심판관은 이에 기명날인하여야 한다(法 162②).<br>1. 심판의 번호<br>2. 당사자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)<br>3. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)<br>4. 심판사건의 표시<br>5. 심결의 주문(法 138의 심판에 있어서는 통상실시권의 범위·기간 및 대가를 포함한다)<br>6. 심결의 이유(청구의 취지 및 그 이유의 요지를 포함한다)<br>7. 심결연월일 |
|     | 심리종결통지  | 심판장은 그 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다. 그러나, 심판장은 필요하다고 인정하면 심리종결통지를 한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 따라 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다(法 162③④).                                                                                                                                                                                                   |
|     | 심결      | 심결은 심리종결통지를 한 날로부터 20일 이내에 함을 원칙으로 한다(法 162⑤). 다만, 이 규정은 심리종결 후의 조속한 심결을 촉구하는 훈시적 규정에 불과하다.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 등본송달    | 심판장은 심결 또는 결정이 있는 때에는 그 등본을 당사자, 참가인 및 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다(法 162⑥).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 효 력 | 구속력     | 심판사건에 대하여 법적 안정성과 심판의 신뢰성을 유지하기 위하여 일단 심결등본이 당사자 등에게 송달되어 심결이 성립하면(심결의 확정을 기다릴 필요 x), 심결한 심판기관 자신도 그 내용을 철회하거나 변경할 수 없는 구속력을 가진다.                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 형식적 확정력 | 심결에 대하여 법정불복기간내에 당사자가 불복신청을 하지 않거나 또는 불복을 하더라도 종국적으로 그 심결이 지지되어 통상의 불복절차로는 더 이상 다룰 수 없게 된 상태를 형식적 확정력이라 한다. 이러한 형식적 확정력이 생긴 심결에 대하여는 비상의 불복수단인 재심에 의하여 취소·변경을 구할 수 있을 뿐이다.                                                                                                                                                                          |
|     | 실질적 확정력 | 심결이 형식적으로 확정되어 재심사유가 없는 한 더 이상 취소·변경할 수가 없게 되면, 그 “심결의 내용”에 대하여도 더 이상 다룰 수 없게 되는 것을 실질적 확정력이라 한다. 특허법에서는 이러한 실질적 확정력을 “일사부재리의 원칙”이라 표현하고 있다.                                                                                                                                                                                                        |

### III 일사부재리(法 163)

| 구 분  |               | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서    | 의의            | 일사부재리란 특허심판의 본안심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없는 것을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 취지            | 1. 절차의 번거로움과 심판상의 불경제를 방지하고<br>2. 상호 모순·저촉되는 심결의 발생을 방지하여 법적 안정성을 도모                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 내용   | 본안심결이 확정되었을 것 | 1. 본안심결<br>본안심결이 확정된 경우에만 적용되며 각하심결이 확정된 경우에는 적용되지 아니한다(法 163단서).<br>2. 확정<br>심결에 대하여 통상의 불복방법으로서 더 이상 다룰 수 없는 상태, 즉 형식적으로 확정되어야 한다. 따라서 전심이 아직 확정되지 않거나 심판계속중일 때에는 적용되지 아니한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 누구든지          | 일사부재리의 효력은 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에 대하여도 인정된다. 즉, 일사부재리의 원칙을 규정한 특허법 제163조는 특허심결의 대세적 효력이 인정되는 실정법상의 근거규정이 된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 동일사실 및 동일증거   | 1. 동일사실<br>동일사실이란 청구원인사실의 동일성을 말한다. 즉 청구취지를 이유있게 하는 구체적인 무효사유 등이 동일한 것을 말한다. 기존에 신규성 위반이라고 무효심판을 청구하여 심결이 확정되었으나 신규성 위반 이외에 진보성 위반이 추가되어 무효심판을 청구한 경우에는 동일사실이라고 할 수 없다(2013후37).<br>2. 동일증거<br>동일증거란 증거의 표시가 다르더라도 그 내용이 실질적으로 동일한 경우(확정심결을 뒤집을 수 있을 정도로 유력하지는 아니한 증거를 부가하는 것을 포함)를 말한다. 다만 i) 전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 않았던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나 ii) 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 반복할 만한 유력한 증거의 선행기술에 추가적, 보충적으로 결합하여 판단하는 경우 등과 같이 후행 심판청구에 대한 판단 내용이 확정된 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없는 경우에는 동일증거라고 할 수 없다(2013후37).<br>3. 동일사실 “및” 동일증거<br>동일사실에 의한 심판청구라도 다른 증거에 의한 경우나 동일한 증거에 의한 것이라도 다른 사실에 관하여 새로운 심판청구를 하는 것은 허용된다. |
|      | 동일한 심판청구일 것   | 1. 동일심판이란 청구취지의 대상으로 되어 있는 권리가 같고 그 종류가 동일한 심판을 말한다. 다만 적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판 또는 전부무효심판과 일부무효심판의 경우에는 동일심판으로 취급된다.<br>2. 심판실무는 무효심판절차 중에 청구된 정정을 인정하는 심결이 확정된 경우, 해당 정정의 가부판단에 대해서도 일사부재리를 적용하고 있다. 따라서, 무효심판의 심결에서 채택된 동일사실 및 동일증거를 근거로 무효심판절차에서의 정정이 부적법하다는 이유로 정정무효심판을 청구하는 경우, i) 무효심판절차 중의 정정청구에 대한 심리는 정정무효심판의 심리와 실질적으로 동등하며, ii) 무효심판과 정정무효심판은 둘 다 당사자계 심판이므로 일사부재리의 법리를 적용하여 그 심판청구를 심결각하한다.                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 적용대상          | 당사자계 심판에 대해서만 적용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 판단   | 적용시기          | 1. 심결 시(2018후11360) - 예를 들어, 신규성 위반으로 청구된 무효심판의 기각심결이 확정된 후에 다시 무효심판을 청구한 사건에서 심판청구 당시에서 신규성 위반이라고만 하였으나 심결취소소송단계에서 신규성 위반 이외에 다른 무효사유(진보성 위반)를 주장하는 경우에는 일사부재리의 판단이 심결 시를 기준으로 하기 때문에 불인정<br>2. 단, 선행심결의 확정시점은 심판청구 시(2009후2234)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 적용효과 |               | 일사부재리에 위반하여 동일심판이 청구된 경우에는 부적법한 심판청구로서 심결각하의 대상이 된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 구별   | 재심            | 「재심」은 확정된 심결에 대해서 그 심결에 이르는 과정에서 중대한 절차상의 하자가 있거나 심결이 불공정한 상태에서 확정되었다는 이유를 들어 확정된 심결의 취소를 구하는 심판이다. 재심의 청구는 확정된 심결을 그 전제로 하고 있는 점과 새로운 이유나 증거가 아닌 해당 확정심결의 범위안에서 이루어진다는 점에서 일사부재리의 원칙과 공통되나, 양자는 심판청구의 이유가 다르다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 중복심판청구의 금지    | 특허심판이 계속 중인 사건에 대하여 당사자는 다시 심판을 청구하지 못한다(法 154⑧ 준용 民訴 259). 이는 이미 계속되고 있는 사건에 대하여 다시 심판 청구를 허용함은 심판제도의 남용으로서, 심판원이나 당사자에게 시간·노력·비용을 이중으로 낭비시키는 것이어서 심판경제상 바람직하지 않고, 심결이 서로 모순·저촉될 염려가 있기 때문이다. 중복심판청구는 전심판이 계속중이라는 점 및 심판청구의 당사자가 동일하다는 점 등에서 일사부재리의 원칙과 다르다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Ⅳ 일사부재리와 중복심판청구금지의 비교

| 요 건 |    | 일사부재리                                                | 중복심판청구                                                                  |
|-----|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 내용  |    | 본안심결이 확정                                             | 특허심판이 계속 중<br>(특허법원, 대법원 계속 중도 포함(2013허9805))                           |
|     |    | 누구든지                                                 | 동일 당사자                                                                  |
|     |    | 동일사실 및 동일증거                                          | -                                                                       |
|     |    | 동일심판<br>(적극적 vs 소극적 권리범위확인심판을 동일심판으로 인정(75후18))      | 동일심판<br>(적극적 vs 소극적 권리범위확인심판이 동일심판인지에 대하여 판례 나뉨(2008허12289, 2016허2249)) |
| 판단  | 주체 | 심판관 합의제                                              |                                                                         |
|     | 객체 | 당사자계 심판                                              | 당사자계 심판+결정계 심판                                                          |
|     | 시기 | 심결 시(2018후11360)<br>단, 선행심결의 확정시점은 심판청구 시(2009후2234) | 심결 시(2016후2317)                                                         |
|     | 방법 | 직권조사사항                                               |                                                                         |
| 조치  |    | 심결각하                                                 |                                                                         |





## 조정위원회 회부, 심판비용 및 집행권원 (法 164의2, 165, 166)

### 제164조의2 【조정위원회 회부】

- ① **(중지 및 회부)** 심판장은 심판사건을 합리적으로 해결하기 위하여 필요하다고 인정되면 당사자의 동의를 받아 해당 심판사건의 절차를 중지하고 결정으로 해당 사건을 조정위원회에 회부할 수 있다.
- ② **(기록송부)** 심판장은 제1항에 따라 조정위원회에 회부한 때에는 해당 심판사건의 기록을 조정위원회에 송부하여야 한다. **法 217①의II**
- ③ **(조정효력)** 심판장은 조정위원회의 조정절차가 조정 불성립으로 종료되면 제1항에 따른 중지 결정을 취소하고 심판을 재개하며, 조정이 성립된 경우에는 해당 심판청구는 취하된 것으로 본다.

[본조신설 2021. 8. 17.]

### 제165조 【심판비용】

- ① **(비용부담: 당사자에게 심판)** 제133조제1항, 제134조제1항·제2항, 제135조 및 제137조제1항의 심판비용의 부담은 심판이 심결에 의하여 종결될 때에는 그 심결로써 정하고, 심판이 심결에 의하지 아니하고 종결될 때에는 결정으로써 정하여야 한다.
- ② **(준용규정)** 제1항의 심판비용에 관하여는 「민사소송법」 제98조부터 제103조까지, 제107조제1항·제2항, 제108조, 제111조, 제112조 및 제116조를 준용한다.

#### 민사소송법 제98조부터 제103조까지, 제107조제1항·제2항, 제108조, 제111조, 제112조 및 제116조

##### 제98조(소송비용부담의 원칙)

소송비용은 패소한 당사자가 부담한다.

##### 제99조(원칙에 대한 예외)

법원은 사정에 따라 승소한 당사자로 하여금 그 권리를 늘리거나 지키는 데 필요하지 아니한 행위로 말미암은 소송비용 또는 상대방의 권리를 늘리거나 지키는 데 필요한 행위로 말미암은 소송비용의 전부나 일부를 부담하게 할 수 있다.

##### 제100조(원칙에 대한 예외)

당사자가 적당한 시기에 공격이나 방어의 방법을 제출하지 아니하였거나, 기일이나 기간의 준수를 게을리 하였거나, 그 밖에 당사자가 책임하여야 할 사유로 소송이 지연된 때에는 법원은 지연됨으로 말미암은 소송비용의 전부나 일부를 승소한 당사자에게 부담하게 할 수 있다.

##### 제101조(일부패소의 경우)

일부패소의 경우에 당사자들이 부담할 소송비용은 법원이 정한다. 다만, 사정에 따라 한 쪽 당사자에게 소송비용의 전부를 부담하게 할 수 있다.

##### 제102조(공동소송의 경우)

- ① 공동소송인은 소송비용을 균등하게 부담한다. 다만, 법원은 사정에 따라 공동소송인에게 소송비용을 연대하여 부담하게 하거나 다른 방법으로 부담하게 할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 불구하고 법원은 권리를 늘리거나 지키는 데 필요하지 아니한 행위로 생긴 소송비용은 그 행위를 한 당사자에게 부담하게 할 수 있다.

##### 제103조(참가소송의 경우)

참가소송비용에 대한 참가인과 상대방 사이의 부담과, 참가이의신청의 소송비용에 대한 참가인과 이의신청 당사자 사이의 부담에 대하여는 제98조 내지 제102조의 규정을 준용한다.

##### 제107조(제3자의 비용상환)

- ① 법정대리인·소송대리인·법원사무관등이나 집행관이 고의 또는 중대한 과실로 쓸데없는 비용을 지급하게 한 경우에는 수소법원은 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 그에게 비용을 갚도록 명할 수 있다.
- ② 법정대리인 또는 소송대리인으로서 소송행위를 한 사람이 그 대리권 또는 소송행위에 필요한 권한을 받았음을 증명하지 못하거나, 추인을 받지 못한 경우에 그 소송행위로 말미암아 발생한 소송비용에 대하여는 제1항의 규정을 준용한다.

##### 제108조(무권대리인의 비용부담)

제107조제2항의 경우에 소가 각하된 경우에는 소송비용은 그 소송행위를 한 대리인이 부담한다.

##### 제111조(상대방에 대한 최고)

- ① 법원은 소송비용액을 결정하기 전에 상대방에게 비용계산서의 등본을 교부하고, 이에 대한 진술을 할 것과 일정한 기간 이내에 비용

계산서와 비용액을 소명하는 데 필요한 서면을 제출할 것을 최고(催告)하여야 한다.

- ② 상대방이 제1항의 서면을 기간 이내에 제출하지 아니한 때에는 법원은 신청인의 비용에 대하여서만 결정할 수 있다. 다만, 상대방도 제110조제1항의 확정결정을 신청할 수 있다.

**제112조(부담비용의 상계)**

법원이 소송비용을 결정하는 경우에 당사자들이 부담할 비용은 대등한 금액에서 상계(相計)된 것으로 본다. 다만, 제111조제2항의 경우에는 그러하지 아니하다.

**제116조(비용의 예납)**

- ① 비용을 필요로 하는 소송행위에 대하여 법원은 당사자에게 그 비용을 미리 내게 할 수 있다.  
② 비용을 미리 내지 아니하는 때에는 법원은 그 소송행위를 하지 아니할 수 있다.

- ③ **(비용부담: 결정계 심판 및 통상실시권허락심판)** 제132조의17, 제136조 또는 제138조에 따른 심판비용은 청구인이 부담한다.

<개정 2016.2.29.> **法 132의15**

- ④ **(준용규정)** 제3항에 따라 청구인이 부담하는 비용에 관하여는 「민사소송법」 제102조를 준용한다. **法 132의15**

**민사소송법 제102조**

**제102조(공동소송의 경우)**

- ① 공동소송인은 소송비용을 균등하게 부담한다. 다만, 법원은 사정에 따라 공동소송인에게 소송비용을 연대하여 부담하게 하거나 다른 방법으로 부담하게 할 수 있다.  
② 제1항의 규정에 불구하고 법원은 권리를 늘리거나 지키는 데 필요하지 아니한 행위로 생긴 소송비용은 그 행위를 한 당사자에게 부담하게 할 수 있다.

- ⑤ **(심판비용액의 결정)** 심판비용액은 심결 또는 결정이 확정된 후 당사자의 청구에 따라 특허심판원장이 결정한다. **法 132의15**

- ⑥ **(준용규정)** 심판비용의 범위·금액·납부 및 심판에서 절차상의 행위를 하기 위하여 필요한 비용의 지급에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 「민사소송비용법」 중 해당 규정의 예에 따른다.

- ⑦ **(변리사 보수)** 심판의 대리를 한 변리사에게 당사자가 지급하였거나 지급할 보수는 지식재산청장이 정하는 금액의 범위에서 심판비용으로 본다. 이 경우 여러 명의 변리사가 심판의 대리를 한 경우라도 1명의 변리사가 심판대리를 한 것으로 본다.

**法 191의2**

[전문개정 2014.6.11.]

**제166조 【심판비용액 또는 대가에 대한 집행권원】** **法 125의2 / 132의15**

이 법에 따라 특허심판원장이 정한 심판비용액 또는 심판관이 정한 대가에 관하여 확정된 결정은 집행력 있는 집행권원과 같은 효력을 가진다. 이 경우 집행력 있는 정본은 특허심판원 소속 공무원이 부여한다.

[전문개정 2014.6.11.]

■ **심판비용의 부담**

- 당사자계 심판(法 165①②) - 패심자 부담
- 결정계 심판, 특허취소신청 및 통상실시권허락심판(法 165③) - 청구인(신청인) 부담

■ **심판비용액의 결정(法 165⑤) - 특허심판원장**

# 64

## 거절결정불복심판(法 132의17, 170~172, 176)

### I 법조문

**제132조의17【특허거절결정 등에 대한 심판】** 法 6, 11 / 15①, 17 / 51③, 52①Ⅲ / 52의2 / 67의2①Ⅱ / 140의2, 170~172, 176

특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 결정에 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다. <개정 2021. 10. 19.>

[전문개정 2014.6.11.]

**제170조【심사규정의 특허거절결정에 대한 심판에의 준용】(★)**

① **(준용규정)** 특허거절결정에 대한 심판에 관하여는 제47조제1항제1호·제2호[최초·최후거절이유통지에 대한 의견제출기간내 보정], 같은 조 제4항[여러 차례 보정이 있는 경우], 제51조[보정각해], 제63조[거절이유통지], 제63조의2[정보제공] 및 제66조[특허결정]를 준용한다. 이 경우 제51조제1항 본문 중 "제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정"은 "제47조제1항제2호에 따른 보정(제132조의17의 특허거절결정에 대한 심판청구 전에 한 것은 제외한다)"으로, 제63조의2 본문 중 "지식재산처장"은 "특허심판원장"으로 본다. <개정 2016.2.29.> 法 51①Ⅲ

② **(제63조의 준용요건)** 제1항에 따라 준용되는 제63조는 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에만 적용한다.

[전문개정 2014.6.11.]

**제171조【특허거절결정에 대한 심판의 특칙】** 法 136③

특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정에 대한 심판에는 제147조제1항·제2항[답변서 제출기회의 부여], 제155조 및 제156조[참가]를 적용하지 아니한다.

[전문개정 2009.1.30.]

**제172조【심사의 효력】**

심사에서 밝은 특허에 관한 절차는 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정에 대한 심판에서도 그 효력이 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

**제176조【특허거절결정 등의 취소】** 法 189

① **(인용심결: 원거절결정의 취소)** 심판관은 제132조의17에 따른 심판이 청구된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 심결로써 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 취소하여야 한다. <개정 2016.2.29.> 法 84①Ⅶ

② **(인용심결: 환송가능)** 심판에서 제1항에 따라 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 취소할 경우에는 심사에 부칠 것이라는 심결을 할 수 있다.

③ **(심사관 기속)** 제1항 및 제2항에 따른 심결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심사관을 기속한다.

[전문개정 2014.6.11.]

## II 거절결정불복심판(法 132의17, 170~172, 176)

| 제 도     |          | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서       | 의의       | 특허출원에 대하여 특허거절결정(法 62)을 받거나, 존속기간연장등록출원에 대하여 연장등록거절결정(法 91, 92의4)을 받은 자가 이에 불복하여 그 거절결정을 취소하여 줄 것을 요구하는 심판을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 취지       | ① 당사자 - 권리구제의 기회, ② 지식재산처 - 자기시정의 기회                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 요 건     | 주체적      | 1. 거절결정을 받은 경우 특허출원인(존속기간연장등록출원은 특허권자)만이 청구<br>2. 공동출원의 경우에는 공유자 모두(法 139③) / 임의대리인은 특별히 권한을 위임받아야 함(法 6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 객체적      | 1. 거절결정받은 특허출원 또는 존속기간연장등록출원<br>2. 최후거절이유통지에 따른 보정이 부적법하여 보정각하된 경우 함께 다룰 수 있음. 다만, i) 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 보정각하결정과 ii) 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정각하결정은 거절결정불복심판에서 다룰 수 없다(法 51③괄호).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 시기적      | 거절결정등본을 송달받은 날로부터 3개월 이내에 청구가능 / 연장가능하고(法 15①), 추후보완 가능(法 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 청 구     | 청구서 제출   | 1. 수수료를 납부하고 법정사항을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출(法 140의2①).<br>2. 다만, 피청구인에 대한 청구서 부분의 송달 및 답변서 제출(法 147①②)과 참가에 관한 규정(法 155, 156)은 부적용(法 171).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 심 리     | 심리범위     | 1. 심사단계에서의 거절이유 적정여부 및 심판청구인 주장의 타당성을 심리한다. 이 때 원결정의 거절이유에 한견되지 않고, 그 특허출원이 특허요건 또는 존속기간연장등록출원의 요건을 만족하고 있는지 여부를 재심리할 수 있다.<br>2. 심사단계에서 최후거절이유통지에 대한 보정, 재심사청구할 때 보정이 부적법함을 이유로 각하되어 거절결정불복심판에서 함께 불복한 경우에는 그 타당성 역시 심리범위에 포함된다. 그 결과 심사단계에서의 보정각하가 부당한 경우에는 보정을 인정하고 거절이유의 해소여부를 판단하게 된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 심사규정의 준용 | 1. 최초·최후거절이유통지 및 보정<br>심판관은 원거절결정의 이유에 대해서는 심판청구인에게 다시 거절이유를 통지하지 않고, 새로이 다른 거절이유를 발견한 경우에만 심판청구인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출기회를 주어야 한다(法 170②, 法 170① 준용 法 63). 한편, 심판청구인은 이 기간내에 보정할 수 있으며, 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①I) 또는 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①II)에 보정을 하는 경우에는 각각의 보정절차에서 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하된 것으로 본다(法 170① 준용 法 47④).<br>2. 보정각하<br>심판관은 심판단계에서 최후거절이유에 대한 보정이 부적법한 경우에는 보정각하결정을 하여야 한다(法 170① 준용 法 51). 다만, 심판청구 이전에 한 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 내(法 47①II) 또는 재심사를 청구할 때(法 47①III) 부적법한 보정이 심판단계에서 밝혀진 경우 심판관은 심사관의 판단을 신뢰한 출원인을 보호하기 위해 보정각하를 하지 않고 보정을 인정하고 심리를 진행한다(法 170①단서).<br>3. 정보제공<br>특허출원에 관하여 누구든지 그 특허출원이 거절이유(단, 法 42③II·42⑧·45 제외)에 해당하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허심판원장에게 제공할 수 있다(法 170 준용 法 63의2). 거절결정불복심판단계에서는 참가가 허용되지 않기 때문에 제3자에게 정보제공을 할 수 있는 기회를 부여하고 있다.<br>4. 특허심결<br>심판관은 원거절이유가 해소되고 재판 결과 더 이상 새로운 거절이유가 없는 경우 원거절결정을 취소하고 특허를 허락한다는 취지의 심결을 할 수 있다(法 170 준용 法 66) |
|         | 심사의 효력   | 심사에서 밝는 특허에 관한 절차는 특허거절결정, 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 거절결정에 대한 심판에서도 그 효력이 있다(法 172).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 심 결     | 내용       | 심판관은 ① 심판청구가 타당하지 아니하고 원결정이 타당하다고 인정된 때에는 기각심결을 하며, ② 원결정이 위법·부당하여 심판청구가 이유있다고 인정되는 때에는 심결로서 특허거절결정·존속기간연장등록거절결정을 취소하여야 한다. 이 때 심판관은 해당 사건을 재판하여 특허심결하거나 심사에 부칠 것이라는 심결을 할 수 있다(法 176①②). 즉, 심사국으로 환송할 수도 있다. 심판에 의하여 심사국으로 환송할 경우 심결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심사관을 기속한다(法 176③). 심사관은 취소환송 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대해서는 다시 최초거절이유를 통지한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 불복       | 기각심결등본송달받은 날로부터 30일 이내 특허법원에 심결취소소송 제기 / 특허가능한 청구항에 대한 분리출원 가능(法 52의2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 확 정 효 과 | 인용심결     | 인용심결의 결과 특허결정 또는 심결이 확정되고 출원인이 특허결정 또는 심결 등본송달일로부터 3월 이내 최초 3년분의 특허료를 낸 경우 특허권이 발생한다(法 79②, 87①②). 한편, 지식재산처장은 연장등록결정이 있으면 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하고 특허공보에 게재하여야 한다(法 92, 92의5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 기각심결     | 출원인이 기각심결등본을 송달받은 날로부터 30일 이내 특허법원에 소를 제기하지 않거나 제기하더라도 중국적으로 그 심결이 지지되어 통상의 불복신청방법으로는 취소할 수 없는 상태로 된 때에 기각심결은 확정된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# 65

## 특허무효심판(法 133)

### I 법조문

#### 제133조 【특허의 무효심판】(★★) 法 62, 63의2, 132의2 / 134, 137

- ① **(주체적 및 객체적 요건)** 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. <개정 2016. 2. 29., 2021. 10. 19.> 法 161②
- 제25조[외국인의 권리능력], 제29조[특허요건], 제32조[특허를 받을 수 없는 발명], 제36조제1항부터 제3항까지[선출원], 제42조제3항제1호[일반적인 발명의 설명 기재방법] 또는 같은 조 제4항[청구범위 기재방법: 기재원칙을 위반한 경우]
  - 제33조제1항 본문[특허를 받을 수 있는 재에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조[공동출원]를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다. 法 103의2]
  - 제33조제1항 단서[특허를 받을 수 없는 재에 따라 특허를 받을 수 없는 경우]
  - 특허된 후 그 특허권자가 제25조에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우
  - 조약을 위반하여 특허를 받을 수 없는 경우
  - 제47조제2항 전단[신규사항추가금지: 외국어특허출원의 경우 원문의 범위만에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우]
  - 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원 또는 제52조의2제1항 각 호 외의 부분 전단에 따른 범위를 벗어난 분리출원인 경우
  - 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우
- ② **(시기적 요건)** 제1항에 따른 심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다.
- ③ **(효과)** 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제4호에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 특허권은 그 특허가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다. 法 84①II, 65⑥IV / 132의13③ / 215
- ④ **(통지)** 심판장은 제1항에 따른 심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다. 法 132의4④

[전문개정 2014.6.11.]



## II 특허무효심판(法 133)

| 제 도     |                | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서       | 의의             | 일단 유효하게 설정등록된 특허권이 법정무효사유에 해당하는 경우 심판절차에 의하여 그 효력을 소급적으로 또는 장래를 향하여 소멸시키는 행정처분을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 취지             | ① 제3자 - 특허분쟁을 미연방지하여 보호, ② 지식재산처 - 행정처분의 적정성과 공정성을 확보                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 요 건     | 주 체 적          | 청구인 1. 원칙 - 이해관계인(비법인 사단, 재단도 가능(法 4) 또는 심사관(공익의 대표자)<br>2. 단, 法 33①본문, 44 위반은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만<br>피청구인 특허권자, 공유인 경우 모두(法 139②)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 객 체 적          | 대상 1. ① 주체적(法 25, 33①본문, 33①단서, 44), ② 실체적(法 29, 32, 36, 42③ I, 42④, 47②전단, 52①, 52의2①각호 외의 부분 전단, 53①), ③ 조약에 위반된 경우, ④ 후발적인 무효사유<br>2. 단, 法 33①본문, 44 위반은 이전청구에 기초하여 이전등록(法 99의2)이 있으면 제외<br>범위 청구항마다 법 제133조 제1항 각호의 무효사유에 해당함을 이유로 청구(法 133①단서).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 시기적            | 존속기간중은 물론 장래를 향해 소멸된 후에도 청구가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 청구서 제출         | 수수료를 납부하고 법정사항을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출(法 140①).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 부분 송달 및 답변서 제출 | 심판장은 심판청구가 있는 때에는 청구서 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출기회를 주어야 하며 답변서를 받았을 때에는 그 부분을 청구인에게 송달(法 147①②). 취지를 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지(法 133④).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 심리      |                | 청구인이 신청한 청구취지의 범위내에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 이를 심리할 수 있다. 예를 들어, 청구항 1 내지 청구항 3이 신규성에 위반되어 무효로 되어야 한다는 취지의 무효심판을 청구한 경우 심판관은 신청하지 아니한 청구취지인 청구항 4에 대해서는 직권으로 심리할 수 없지만 청구항 1 내지 청구항 3이 신규성 위반이 아닌 진보성 위반이라고 할 수 있다. 다만, 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리하는 경우에는 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 159).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 심 결     | 내용             | 심판청구의 이유가 타당하지 아니한 경우 기각심결을 하며, 심판청구의 이유가 타당한 경우 인용심결을 하여야 한다. 한편, 일부 청구항에 대해서만 특허무효사유가 있는 경우 일부인용·일부기각심결 가능. 단, 하나의 청구항에 여러 개의 발명이 포함되어 있고 그 중 일부가 무효라면 그 청구항 전체를 무효로 함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 불복             | 심결등본송달받은날로부터 30일 이내 특허법원에 심결취소소송 제기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 확 정 효 과 | 인용심결           | 1. 특허권의 소멸 - 소급효. 다만, 후발적 사유의 경우 사유가 발생한 때부터 특허권이 소멸(法 133③).<br>2. 하지않는 특허권에 기한 권리행사한 경우 - 무효심결이 확정되어 특허권이 소급하여 소멸한 경우 민사소송의 확정판결 혹은 침해죄의 확정판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있다. 또한, 특허권자가 무효심결의 확정전에 특허권을 행사하여 고의 또는 과실로 타인에게 손해를 입힌 경우 그 손해를 배상하여야 하며, 고의 또는 과실에 의하지 아니한 경우에도 부당이득은 반환하여야 한다.<br>3. 무효심결이 재심에 의하여 상반된 심결이 확정된 경우 - 특허무효심결이 확정된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우에 해당 심결확정 후 재심청구등록 전에 선의로 수출 또는 수입하거나 또는 국내에서 생산하거나 취득한 물건, 선의의 실시, 선의의 간접침해행위에 대하여는 특허권의 효력이 미치지 아니한다(法 181). 한편, 해당 심결확정 후 재심청구등록 전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위안에서 그 특허권에 관하여 무상의 통상실시권(소위 後用權)을 갖는다(法 182).<br>4. 중용권의 발생 - 특허에 대한 무효심판청구의 등록전에 법 제104조 제1항 각호에 해당하는 자가 자기의 특허발명이 무효사유에 해당되는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위에서 유상의 중용권을 가진다(法 104).<br>5. 정당한 권리자의 출원 - 무권리자의 특허가 무효심결이 확정된 경우 그 날로부터 30일 이내 정당한 권리자의 출원이 있는 경우 정당한 권리자의 출원일은 무권리자의 출원일로 소급한다(法 35).<br>6. 특허료 반환 - 반환대상에 해당함을 통지받은 날로부터 5년 이내 특허료를 낸 자의 청구에 의하여 무효심결이 확정된 연도의 다음 연도부터의 특허료 해당분을 반환한다(法 84①③).<br>7. 실시(금지)계약의 효력 - 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다. 따라서 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 실시료를 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 없다. 또한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다. 실시금지계약도 동일한 법리가 적용되어 실시금지계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 무단실시에 대해 채무불이행에 의한 손해배상청구 가능. |
|         | 기각심결           | 기각심결이 확정된 경우에 특허권은 유지된다. 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일한 무효심판(전부무효심판과 일부무효심판은 동일한 심판)을 청구할 수 없으며 동일한 무효심판을 청구한 경우 심결각하된다(法 163).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

III 정보제공(法 63의2)와 특허무효심판(法 133)의 비교

| 제 도     |           | 정보제공(法 63의2)                                                                                                           | 특허무효심판(法 133)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서       | 의 의       | 특허출원이 있으면 누구든지 해당 발명이 法 제62조 각 호의 거절이유(단, 法 42③II·42⑧·45 제외)에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 지식재산처장에게 제공할 수 있는 제도를 말한다. | 유효하게 설정등록된 특허권이 법 제133조제1항 각 호의 무효사유에 해당하는 경우 이해관계인 또는 심사관의 심판청구에 의한 심판절차에 의하여 그 특허권의 효력을 소급하여 또는 장래를 향하여 소멸시킬 수 있는 제도를 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 취 지       | 심사관에 의한 심사의 신속성 및 정확성을 높여 심사의 질적 향상에 기여                                                                                | 하자있는 권리를 소멸시켜 공중의 피해방지와 행정처분의 적정성과 공정성을 확보                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 요건      | 주 체       | 누구든지                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이해관계인 또는 심사관</li> <li>■ 단, 제33조제1항 본문 위반, 제44조 위반은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만이 청구 가능</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 시 기       | 출원계속 중<br>(거절결정불복심판단계에서도 가능)                                                                                           | 특허권의 존속기간 중에는 물론 특허권이 장래를 향해 소멸된 후라도 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 대 상       | 출원된 발명                                                                                                                 | 설정등록된 특허발명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 사유        | 공통점                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주체적 사유<br/>외국인의 권리능력(法 25), 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 자(法 33①본문), 특허를 받을 수 없는 자(法 33①단서), 공동출원(法 44)</li> <li>■ 실체적 사유<br/>산업상 이용가능성(法 29①본문), 신규성(法 29①각호), 진보성(法 29②), 확대된 선출원(法 29③④), 불특허발명(法 32), 선출원주의(法 36), 일반적인 발명의 설명 기재(法 42③I), 청구범위 기재(法 42④), 신규사항추가금지(원문의 범위를 벗어난 경우)(法 47②전단), 분할출원의 범위를 벗어난 경우(法 52①), 분리출원의 범위를 벗어난 경우(法 52의2①각호 외의 부분 전단), 변경출원의 범위를 벗어난 경우(法 53①)</li> <li>■ 조약에 위반된 경우</li> </ul> |
|         |           | 차이점                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 신규사항추가금지(외국어특허출원, 외국어국제특허출원의 번역문의 범위를 벗어난 경우)(法 47②후단)</li> <li>■ 분리출원의 경우 청구범위의 요건(法 52의2①후단)</li> </ul> 후발적 무효사유(法 133①IV)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 절차 / 효과 | 심사(심리) 주체 | 심사관이 단독으로 참고                                                                                                           | 3명 또는 5명의 심판관 합의체가 심리                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 심사(심리) 구조 | 당사자 지위×. 제공 자료를 심사에 활용하여야 한다는 의무×                                                                                      | 특허무효심판청구인과 특허권자의 대립구조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 제3자의 지위   | 법률상 응답할 의무×, 실무상 정보제공자에게 통보                                                                                            | 결정 또는 심결로 응답                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 불 복       | 불복불가                                                                                                                   | 심결(결정)등본 송달받은 날로부터 30일 이내 특허법원에 심결취소소송 제기하여 불복 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## I 법조문

## 제134조 【특허권 존속기간의 연장등록의 무효심판】 法 133, 137

- ① (허가 등에 따른 연장등록에 대한 무효심판청구: 주체적 및 객체적 요건) 이해관계인 또는 심사관은 제92조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. <개정 2025. 1. 21.> 法 91
1. (객체: 허가 등의 필요성) 특허발명을 실시하기 위하여 제89조에 따른 허가 등을 받을 필요가 없는 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
  2. (객체: 허가 등의 취득) 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조에 따른 허가 등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
  3. (객체: 연장기간) 연장등록에 따라 연장된 기간이 제89조에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하는 경우
  4. (주체) 해당 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
  5. (주체) 제90조제3항을 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
  6. (객체: 연장횟수) 제90조제7항을 위반하여 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권의 존속기간이 연장등록된 경우
- ② (등록지연에 따른 연장등록에 대한 무효심판청구: 주체적 및 객체적 요건) 이해관계인 또는 심사관은 제92조의5에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 무효심판을 청구할 수 있다. 法 92의4
1. (객체: 연장기간) 연장등록에 따라 연장된 기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과한 경우
  2. (주체) 해당 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
  3. (주체) 제92조의3제3항을 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
- ③ (시기적 요건 및 통지) 제1항 및 제2항에 따른 심판의 청구에 관하여는 제133조제2항 및 제4항을 준용한다.
- ④ (효과) 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 연장등록에 따른 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기간에 대해서만 연장이 없었던 것으로 본다. <개정 2025. 1. 21.> 法 84①Ⅲ
1. 연장등록이 제1항제3호에 해당하여 무효로 된 경우: 제89조에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하여 연장된 기간
  2. 연장등록이 제2항제1호에 해당하여 무효로 된 경우: 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하여 연장된 기간
- ⑤ (연장등록출원의 지위가 없는 경우) 연장등록이 제1항제6호에 해당하여 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 처음부터 없었던 것으로 본다. <신설 2025. 1. 21.>

[전문개정 2014.6.11.]

## II 존속기간연장등록무효심판(法 134)

| 제 도   |      | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서     | 의의   | 존속기간이 연장등록된 특허권이 법정무효사유에 해당하는 경우 심판절차에 의하여 그 연장등록의 효력을 소급하여 소멸시키는 행정처분을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 취지   | ① 일반공중의 자유실시이익을 보호하는 한편, ② 특허권자에 대한 부당한 보호를 방지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 요건    | 주체적  | 청구인<br>이해관계인 또는 심사관                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 피청구인 | 특허권자, 공유인 경우 모두(法 139③)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 객체적  | 대상<br>1. 허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록의 무효사유(法 134①)<br>① 그 특허발명을 실시하기 위하여 법 제89조에 따른 허가 등을 받을 필요가 없는 출원에 대하여 연장등록이 된 경우<br>② 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가진 자가 법 제89조에 따른 허가 등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우<br>③ 연장등록에 따라 연장된 기간이 제89조에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하는 경우<br>④ 해당 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우<br>⑤ 제90조제3항(특허권이 공유인 경우 공유자 모두가 출원)을 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우<br>⑥ 제90조제7항을 위반하여 하나의 허가 등에 대하여 둘 이상의 특허권의 존속기간이 연장등록된 경우<br>2. 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록의 무효사유(法 134②)<br>① 연장등록에 따라 연장된 기간이 법 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과한 경우<br>② 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우<br>③ 법 제92조의3 제3항(특허권이 공유인 경우 공유자 모두가 출원)을 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우<br>범위<br>연장등록 자체 |
|       | 시기적  | 1. 연장된 존속기간중은 물론 소멸된 후에도 청구가능<br>2. 다만, 연장등록무효심판에 의하여 연장등록된 존속기간이 소급하여 소멸한 경우나 원래의 존속기간이 만료될 때까지 특허권이 유지되지 아니한 사유가 발생한 경우에는 청구불가                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 청구   | 청구서 제출<br>수수료를 납부하고 법정사항을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출한다(法 140①).<br>부분 송달 및 답변서 제출<br>심판관은 심판청구가 있는 때에는 청구서 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출기회를 주어야 하며 답변서를 받았을 때에는 그 부분을 청구인에게 송달(法 147①②). 취지를 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지(法 134③ 준용 133④).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 심리    |      | 심판관은 청구인이 신청한 청구취지의 범위내에서 심리하여야 한다. 그러나 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 직권으로 심리할 수 있다. 심판관은 청구인이 신청하지 아니한 이유에 대하여 직권으로 심리를 한 경우 당사자 또는 참가인에게 기간을 정하여 의견서 제출기회를 주어야 한다(法 159).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 심결    | 내용   | 심판관은 특허권의 존속기간연장등록무효사유에 해당되지 않아 심판청구의 이유가 타당하지 아니하다고 인정된 때에는 기각심결을 하며, 특허권의 존속기간연장등록무효사유에 해당되어 심판청구의 이유가 타당하다고 인정된 때에는 인용심결을 하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 불복   | 심결등본송달받은날로부터 30일 이내 특허법원에 심결취소소송 제기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 확정 효과 | 인용심결 | 1. 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 연장등록에 따른 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 해당하는 기간에 대하여만 연장이 없었던 것으로 본다(法 134④).<br>i) 허가 등에 따라 특허권의 존속기간이 연장등록 되었는데, 연장등록에 따라 연장된 기간이 제89조에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하여 무효로 된 경우에는 제89조에 따른 인정되는 연장의 기간을 초과하여 연장된 기간<br>ii) 등록지연에 따라 특허권의 존속기간이 연장등록 되었는데, 연장등록에 따라 연장된 기간이 법 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하여 무효로 된 경우에는 법 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하여 연장된 기간<br>2. 연장등록이 제90조제7항을 위반하여 하나의 허가 등에 대하여 둘 이상의 특허권의 존속기간이 연장등록된 경우에 해당하여 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 134⑤).                                                                                                         |
|       | 기각심결 | 기각심결이 확정된 경우에 연장등록된 특허권은 유지된다. 이 경우 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일한 특허권의 존속기간연장등록무효심판을 청구할 수 없으며 동일한 특허권의 존속기간연장등록무효심판을 청구한 경우 심결각하된다(法 163).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# 67

## 권리범위확인심판(法 135)

### I 법조문

#### 제135조 【권리범위 확인심판】 法 140③

- ① **(주체적 요건: 적극적 권리범위확인심판)** 특허권자 또는 전용실시권자는 자신의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
- ② **(주체적 요건: 소극적 권리범위확인심판)** 이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다. <신설 2016.2.29.>
- ③ **(객체적 요건)** 제1항 또는 제2항에 따른 특허권의 권리범위 확인심판을 청구하는 경우에 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. <개정 2016.2.29.> 法 161②

[전문개정 2014.6.11.]

## II 권리범위확인심판(法 135)

| 제 도  |                | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서    | 의의             | 특허권이 효력이 미치는 범위를 특정대상물(확인대상발명)과의 관계에서 구체적으로 확인하기 위해 청구하는 심판을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 취지             | ① 공적인 확인을 통한 분쟁의 조기해결, ② 침해소송에서 법원의 판단기준 제공                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 종류             | 1. 대상에 의한 구분 - 권리 대 비권리간, 권리 대 권리간 권리범위확인심판<br>2. 방식에 의한 구분 - 권리범위에 속한다는 취지의 심결을 구하는 적극적 권리범위확인심판과 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 심결을 구하는 소극적 권리범위확인심판                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 요건   | 주체             | 적극적 - 특허권자, 전용실시권자 / 소극적 - 과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나 현재 실시하고 있는 자뿐만 아니라 실시할 예정이 있는 이해관계인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 적 피청구인         | 적극적 - 과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나 현재 실시하고 있는 이해관계인 / 소극적 - 특허권자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 객체적            | 청구항마다 청구가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 시기적            | 확인이익이 있어야 하기 때문에 특허권 존속기간중에만 가능하며 소멸후에는 불가                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 청구   | 청구서 제출         | 1. 수수료를 납부하고 법정사항을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출한다(法 140①). 특허발명과 대비할 수 있는 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여 특허심판원장에게 제출하여야 한다(法 140③).<br>2. 원칙적으로 확인대상발명은 권리범위확인을 구하는 청구취지의 일부를 구성하므로 요지변경이 되지 아니하는 범위내에서 보정 가능. 다만 적극적 권리범위확인심판에서 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 또는 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명(실시주장발명)과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 또는 도면을 보정하는 경우에는 요지변경이 되더라도 상관없다(法 140②Ⅲ).                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 부분 송달 및 답변서 제출 | 심판장은 심판청구가 있는 때에는 청구서 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출기회를 주어야 하며 답변서를 받았을 때에는 그 부분을 청구인에게 송달(法 147①②).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 심리   |                | 1. 원칙 - 특허발명과 확인대상발명을 특정하고, 구성요소완비의 원칙, 균등론 등을 적용하여 특허발명의 실시인지 판단하고 법률의 제한, 확장을 고려하여 판단<br>2. 특허발명의 특정<br>① 청구범위를 중심으로 발명의 설명·도면의 참작과 함께 출원 당시의 기술수준 및 출원의 경과 등을 참작하여 특정하여야 한다<br>② 특허발명이 공지기술과 동일하거나 특허발명이 선출원주의, 확대된 선출원 위반 또는 특허발명이 명세서의 기재불비 등으로 인하여 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우이거나 실시가 불가능한 경우에 해당하여 권리범위를 인정할 수 없다는 무효의 항변과 확인대상발명이 공지기술과 동일하거나 공지기술로부터 용이하다는 자유기술의 항변 가능. 다만, 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 권리범위를 부정하거나 권리소진이 적용되거나 실시권이 있기 때문에 권리범위에 속하지 않는다는 항변은 불인정<br>3. 확인대상발명의 특징 - 확인대상발명은 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 특정되어야 하고, 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다.<br>4. 법률의 제한, 확장의 고려 - 간접침해 물건에 대하여 권리범위확인심판을 청구가능(98후2580) |
| 심결   | 내용             | 심판청구의 이유가 타당하지 않다고 인정된 때에는 기각심결을 하여야 하며, 청구취지에 반하는 심결을 하여서는 안 된다. 예를 들어 심판청구인이 소극적 권리범위확인심판을 청구한 경우에 확인대상발명이 상대방의 권리범위에 속한다고 심결함은 심판청구인이 신청하지 아니한 청구를 심결한 것이어서 위법하다. 한편, 심판청구의 이유가 타당하다고 인정된 때에는 「확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속한다」 또는 「확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다」라는 형식의 인용심결을 하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 불복             | 심결등본송달받은날로부터 30일 이내 특허법원에 심결취소소송 제기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 확정효과 |                | 1. 보호범위의 공적확인 - 권리범위확인심판의 심결이 확정되면 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부가 전문 관청인 특허심판원에 의하여 공적으로 확인된 결과가 된다. 그러나 법원은 순수한 기술적 범위에서의 권리범위확인을 넘어서 사실관계를 고려한 사법적 판단에 준하는 권리범위확인심결은 법원이 판단하는 사항을 심판관이 판단한 것으로 보아 이에 구속되지 아니한다는 입장이다. 다만, 최근에는 침해민사본안소송의 항소심이 특허법원에서 전속 관할하게 되어 권리범위확인심판의 심결 취소소송을 심리하는 특허법원과 일원화됨에 따라 침해소송과 권리범위확인심판의 심결취소소송이 다른 결론을 내리는 것이 다소 힘들게 되었다고 볼 수 있다.<br>2. 일사부재리 - 권리범위확인심판의 심결이 확정되면 일사부재리의 원칙이 적용이 된다. 즉, 기각심결이 확정되면 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일심판을 청구할 수 없다. 이에 위반되면 부적법한 심판청구를 이유로 심결각하된다. 한편, 적극적 권리범위확인심판이 청구되어 그 기각심결이 확정된 이후 소극적 권리범위확인심판을 청구한 경우에도 실질적으로 동일한 심결을 구하는 것으로 보아 일사부재리의 원칙이 적용된다(法 163).       |

### III 확인대상발명의 특정

|          | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 의의       | <p>확인대상발명이란 권리범위확인심판에서 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부의 판단대상이 되는 구체적인 실시형태를 말하며, 침해소송에서는 대상 제품, 피고 제품, 피고 실시제품 등으로 표시된다. 확인대상발명은 대상물을 주관적으로 가 공하여 심판청구서에 첨부된 설명서 또는 도면에 의하여 기재되고, 청구취지의 일부를 구성한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 특정<br>정도 | <p><b>1. 청구취지와 청구원인으로서 특정의 구별</b><br/>         권리범위확인심판에서도 침해소송과 마찬가지로 청구취지에 있어서 확인대상발명의 특정과 청구원인에 있어서 확 인대상발명의 특정을 구별할 필요가 있다. 양자의 구별실익은 청구취지로서 특정이 명확하다면 일사부재리의 효 과가 미치는 범위가 명확하므로 청구원인으로서 특정이 다소 불명확하다고 할지라도 권리범위에 속하는지 여부 를 판단할 수 있는 경우에는 각하심결하지 않고 본안심결을 할 수 있다는 점이다. 다만 청구취지로서 특정이 불 명확하다면 침해소송과 마찬가지로 특허심판원으로서의 요지변경이 되지 아니한 범위 내에서 확인대상발명의 설 명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 하여야 할 것이고, 그런데도 그와 같은 특정에 미흡함이 있다 면 심판의 심결이 확정되더라도 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만 으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있는 경우라도 심판청구를 각하하여야 한다.</p> <p><b>2. 청구취지로서의 특정</b><br/>         청구취지에서의 확인대상발명의 특정은 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있도록 기재되어야 한다. 확인대발명을 식별할 수 있는 제품명, 제품번호 등이 있는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이를 기재하는 것만으로도 확인대 상발명을 다른 것과 구별할 수 있을 정도로 특정한 것으로 볼 수 있다. 또한 설명서 및 도면(사진) 등을 이용하여 확인대상발명의 구성을 기재하는 방법 역시 확인대상발명을 구체적으로 특정하는 방법으로서 적절하다고 할 것이다. 이때 확인대상발명의 특정을 위해서 특허발명의 구성과 대응되는 부분의 구성을 명확하게 기재하여야 한 다. 다만 확인대상발명의 특정 방법은 일률적으로 정하기 어렵고, 요구되는 특정의 정도도 사안에 따라 달라질 수 있으므로, 확인대상발명을 특정하는 방법이 반드시 위에서 언급한 방법들로 제한된다고 보기 어렵다.</p> <p><b>3. 청구원인으로서 특정(원칙: 대비 가능, 권리범위 판단 가능): 대응되는 부분의 구체적인 구성을 차이점을 판단함에 필요할 정 도로 기재</b><br/>         청구원인에서의 확인대상발명의 특정은 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 기재하여야 한다. 이는 특허발명의 구성과 확인대상발명의 구성을 비교하여 권리범위에 속하는지 여부를 판단하기 위한 것이기 때문이 다. 일반적으로 특허발명의 구성과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 대응되는 부분의 구체적인 구성이 기재된 경우에 충분히 서로 대비할 수 있을 정도로 특정한 것으로 볼 수 있다. 다만 권리범위 에 속하는지 판단할 수 없게 모호하게 기재되어 있거나 확인대상발명의 특정결과에 따라 결론이 달라질 때는 청 구원인으로서 특정되었다고 할 수 없다. 한편 소극적 권리범위확인심판의 경우 심판청구인이 스스로 확인대상발 명의 실시자에 해당하기 때문에 확인대상발명을 정확하게 특정하여야 할 의무에 있어서 적극적 권리범위확인심 판의 경우보다 그 정도가 더 높다.</p> <p><b>4. 청구원인으로서 특정(예외): 독립항과 종속항의 관계에 있어서 특정 정도</b><br/>         종속항의 구성요소에 대응되는 확인대상발명의 구성이 기재되어 있지 않더라도 확인대상발명이 독립항의 권리범위에 속하지 아니한 경우에는 확인대상발명이 특허발명과 대비될 수 있을 정도로 특정되었다고 봄이 상당하다(2010후 296). 그러나 이는 독립항의 권리범위가 인정됨을 전제로 하는 것으로서 만일 독립항의 권리범위가 인정되지 않는다 면 독립항의 권리범위에 속하지 않더라도 종속항의 권리범위에 속할 수도 있기 때문에 종속항의 권리범위에 속하는지 여부를 개별적으로 판단해야 한다. 그리고, 확인대상발명이 독립항의 권리범위에 속하는 경우 종속항의 권리범위에 속하는지 여부는 개별적으로 판단되어야 한다.</p> <p><b>5. 청구원인으로서 특정(예외): 발명의 범주가 다른 확인대상발명의 특정</b><br/>         ① 특허발명이 제법발명인 경우에는 어떤 제법발명에 의하여 생산된 물건인지 여부에 따라 권리범위에 속하는지 여 부가 달라지기 때문에 확인대상발명이 어떤 제법발명에 의하여 생산되었는지를 구체적으로 특정하여야 한다. 한 편, 제법발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건이 출원 전에 공지되지 않았다면 그 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정된다(法 129). 따라서 특허권자는 물건이 출원 전에 공지되지 않았다면 확인대상발명 의 물건이 특허된 제법발명에 의하여 생산된 것이라는 것을 증명할 필요없이 i) 특허된 제법발명에 의하여 생산 된 물건이 출원 전 공지되지 않았다는 점, ii) 확인대상발명의 물건이 구성완비의 원칙, 균등론을 적용한 결과 특허된 제법발명에 의하여 생산된 물건의 실시라는 점을 증명하면 된다.</p> <p>② 특허발명이 물건발명이고 확인대상발명이 제법발명인 경우 설명서에 제법발명에 의하여 생산된 물건의 구성이 구체적으로 특정되어야만 한다. 그 물건의 구성이 특정되어야만 특허발명의 구성과 대비하여 구성완비의 원칙, 균등론에 의하여 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단할 수 있기 때문이다. 물건발명의 특허권자가 적극적 권리범위 확인심판을 청구하면서 확인대상발명의 설명서 등에 피심판청구인이 실시한 물건을 사용하는 구체적 방법을 부가적으로 기재했다고 하더라도 그 물건을 그러한 방법으로 사용하는 경우만이 심판대상으로서 확 인대상발명이 되는 것은 아니다.</p> |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>해석을 통한 특정 여부 판단</p> | <p><b>1. 원칙</b><br/> 확인대상발명이 특정되었는지 파악하는 방법은 청구범위의 해석을 통해 특허발명이 특정되었는지 파악하는 방법과 다르지 않다. 따라서 설명서를 중심으로 확인대상발명의 구성을 파악해야 하고, 기술적 의미를 정확히 알 수 없는 경우에는 도면 등의 기재를 참작하여 파악해야 하지만, 특별한 사정이 없는 한 도면에 의하여 설명서에 기재된 확인대상발명의 구성이 제한되거나 확장되어 해석되는 것은 허용되지 않아야 한다. 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건이므로, 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다.</p> <p><b>2. 설명서와 도면의 불일치가 있는 경우의 해석방법</b><br/> 확인대상발명의 특정 대상은 설명서와 도면이다. 설명서와 도면이 일치하지 아니한 경우 확인대상발명의 설명서를 기준으로 확인대상발명의 기술적 구성을 파악하는 것이지만, 이와 달리 확인대상발명의 설명서와 도면 사이에 불일치가 없는 경우에 확인대상발명의 도면이 예시적인 것에 불과하다는 별도의 기재가 없는 한, 확인대상발명의 도면을 단지 참고도면 정도로만 이해하여서는 아니 되고, 확인대상발명의 설명서와 도면을 일체로 해석하여 확인대상발명의 기술적 구성을 확정하여야 한다. 또한, 확인대상발명에서 사용되는 용어의 의미가 명확하지 아니하면 확인대상발명의 설명서뿐만 아니라 필요한 경우 특허발명의 명세서나 출원경과도 참작될 수 있다.</p> <p><b>3. 설명서에 확인대상발명의 구성이 기능적 표현으로 기재된 경우의 해석방법</b><br/> 설명서에 기능적 표현으로 기재한 경우에는 설명서의 나머지 부분과 도면 등의 기재와 기술상식을 고려하여 그 구성의 기술적 의미를 명확하게 파악할 수 있는 경우에 한해 확인대상발명의 구성이 특정된 것으로 볼 수 있다.</p> <p><b>4. 설명서와 도면에 기재된 발명이 실시하고 있는 발명과 다른 경우의 해석방법</b><br/> ① 적극적 권리범위확인심판에서는 청구인인 특허권자 또는 전용실시권자가 주장한 실시 형태가 피청구인이 실제로 실시하고 있는 형태와 동일성이 인정되지 않으면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다. 그리고 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 하며, 요지가 동일하여 균등관계에 있다고 할지라도 확인대상발명이 특정되었다고 볼 수 없다.</p> <p>② 소극적 권리범위확인심판에서 심판의 대상이 되는 확인대상발명에는 현재 실시하고 있는 발명뿐만 아니라 장래 실시 예정인 발명도 포함되나, 권리범위의 확인을 구하는 심판을 청구한 자는 확인대상발명을 현재 실시하고 있는지 또는 장래 실시할 예정인지 여부를 적어도 심결 시까지 명확히 밝혀야 하고, 심판청구인이 심결 시까지 자신이 현재 실시하고 있는 제품이 확인대상발명이라고 밝혔다면 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 심판청구인의 의사대로 실제 실시하고 있는 제품으로 확정되었다고 할 것이다. 또한 확인대상발명이 위와 같이 확정되었다면 그것이 적법하게 특정되었는지는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다. 따라서 심판청구인인 이해관계인이 심결절차를 통하여 확인을 받으려고 한 대상인 실제 실시하고 있는 제품과 심판청구인이 특정한 확인대상발명이 사실적 관점에서 같지 않다면, 특허심판원으로서서는 다름을 지적하여 이를 보정할 수 있는 기회를 부여하여야 하고, 심판청구인이 그러한 기회를 제공받았음에도 이를 보정하지 않았다면 잘못 특정된 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결이 확정되더라도 그 효력이 확인대상발명과 다른 청구인이 실제 실시하고 있는 발명에 미친다고 볼 수 없으므로 이를 각하하여야 할 것이다. 한편 소극적 권리범위확인심판에서 심판의 대상이 실시 예정 제품인 경우, 즉 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다른 경우라도 실시할 가능성이 있다면 심판청구의 적법성을 인정받을 수 있다. 이때 현재 실시 형태가 아닌 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단한다.</p> <p><b>5. 설명서와 도면에 기재된 확인대상발명이 복수 개로 파악된 경우의 해석방법</b><br/> 기존 판결(2007허4816)은 확인대상발명이 1개이어야 하며(다만, 하나의 확인대상발명의 하위개념에 속하는 복수개의 실시예가 기재될 수 있다), 여러 개인 것이 명백하거나 확인대상발명이 하나인 것으로 인정하기에는 불명확한 점이나 모순이 있는 경우 석명권 등을 행사하여 그 흠결을 보정하도록 보정명령을 하고, 그 흠결이 해소되지 아니한 때는 심판청구를 심결각하한다는 입장이다. 다만, 최근 특허법원 2013허4954 판결은 i) 법 제135조에서 확인대상발명의 개수를 특별히 제한하고 있지는 않은 점, ii) 확인대상발명을 복수로 하여 권리범위확인심판을 청구하는 것은 결국 두 개의 청구를 병합하는 것인데, 특허법상의 심판절차와 성질이 유사한 일반 행정심판 절차를 규정하고 있는 행정심판법은 관련 청구의 병합을 인정하고 있는 점(행정심판법 제37조 참조), iii) 관련되는 복수의 청구를 하나의 심판절차에서 해결하는 것이 분쟁의 일회적 해결이나 심판경제상 바람직한 점 등을 종합하여 보면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명이 복수라는 것만으로 바로 권리범위확인심판청구가 위법하다고 볼 수는 없다고 판시하였다.</p> <p><b>특정의 증명책임</b><br/> 1. 법률요건분류설에 의하면, 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정에 대한 증명책임은 청구인인 특허권자 또는 전용실시권자에게 있고, 소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정에 대한 증명책임은 청구인인 이해관계인에게 있다. 적극적 권리범위확인심판의 경우 청구인인 특허권자는 피청구인이 실제로 확인대상발명을 실시하고 있음을 증명하여야 한다. 만약, 피청구인이 확인대상발명을 실시한 사실 등이 없어 증명에 실패한다면, 본안심리를 할 확인의 이익이 없으므로 심판청구는 심결각하된다. 즉, 확인대상발명을 실시하고 있는지 실시주장발명을 실시하고 있는지에 대한 증명자료는 대부분 이해관계인의 지배영역에 있음에도 불구하고, 이에 대한 증명책임은 특허권자에게 있고, 증명에 실패한다면 심결각하된다.</p> <p>2. 다만, 확인대상발명이 실시주장발명과 일치하지 아니한 경우 요지변경이라도 특허권자는 보정을 통해서 이를 일치시킬 수 있다.</p> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Ⅳ 권리 사이의 권리범위확인심판 인정여부

| 청구방식<br>대상 |       | 적극적                                                                      | 소극적                                   |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 권리 대 비권리   |       | 허용                                                                       | 허용                                    |
| 권리 대 권리    | 동종 권리 | 원칙은 불허. 단 이용관계에 있어 인용심결을 하더라도 등록권리의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에 허용 | 인용심결을 하더라도 타방의 권리의 효력을 부정하지 않기 때문에 허용 |
|            | 이종 권리 | 인용심결을 하더라도 등록권리의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에 허용                    |                                       |



## I 법조문

## 제136조 【정정심판】(★★) 法 140⑤ / 132의3, 133의2, 137③④

- ① **(요건: 객체적)** 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
1. 청구범위를 감축하는 경우
  2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우
  3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우
- ② **(요건: 시기적)** 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다. <신설 2016.2.29.>
1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다.
  2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간
- ③ **(요건: 객체적)** 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 다만, 제1항제2호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
- ④ **(요건: 객체적)** 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다. <개정 2016.2.29.>
- ⑤ **(요건: 객체적)** 제1항에 따른 정정 중 같은 항 제1호 또는 제2호에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다. <개정 2016.2.29.>
- ⑥ **(절차: 의견서 제출기회의 부여)** 심판관은 제1항에 따른 심판청구가 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다고 인정하는 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. <개정 2016.2.29.>
1. 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 경우
  2. 제3항에 따른 범위를 벗어난 경우
  3. 제4항 또는 제5항을 위반한 경우
- ⑦ **(요건: 시기적)** 제1항에 따른 정정심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만, 특허취소결정이 확정되거나 특허를 무효(제133조제1항제4호에 의한 무효는 제외한다)로 한다는 심결이 확정된 후에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.>
- ⑧ **(요건: 주체적)** 특허권자는 전용실시권자, 질권자와 제100조제4항[전용실시권에 대한 허락실시권·제102조제1항[특허권에 대한 허락실시권] 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권[직무발명에 대한 법정실시권]을 갖는 자의 동의를 받아야만 제1항에 따른 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허권자가 정정심판을 청구하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 무효심판을 청구한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.> 法 119①
- ⑨ **(절차: 답변서 제출기회 및 참가 부적용)** 제1항에 따른 정정심판에는 제147조제1항·제2항[답변서 제출기회의 부여], 제155조 및 제156조[참가]를 적용하지 아니한다. <신설 2016.2.29.> 法 171
- ⑩ **(효과: 소급효)** 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다. <개정 2016.2.29.> 法 86③ 1
- ⑪ **(절차: 명세서 또는 도면의 보정)** 청구인은 제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에 제140조제5항에 따른 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
- ⑫ **(효과: 통보)** 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 한다는 심결이 있는 경우 특허심판원장은 그 내용을 지식재산처장에게 알려야 한다. <개정 2016.2.29.>
- ⑬ **(효과: 특허공보 게재)** 지식재산처장은 제12항에 따른 통보가 있으면 이를 특허공보에 게재하여야 한다.

&lt;개정 2016.2.29.&gt;

[전문개정 2014.6.11.]

## II 정정심판(法 136)

| 제 도   |               | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서     | 의의            | 특허권자가 특허권이 설정등록된 후에 특허발명의 명세서 또는 도면의 내용을 정정하는 심판을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 취지            | ① 특허권자 - 특허무효방지, ② 제3자 - 제한적 변경을 통해 불측의 손해방지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 요건    | 주체적           | 1. 특허권자 / 특허권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동(法 139③)<br>2. 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 의한 통상실시권자, 질권자의 동의 필요. 다만, 특허권자가 정정심판을 청구하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 무효심판을 청구한 경우에는 不要(法 136⑧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 객체적           | 1. 청구범위의 감축, ②. 잘못 기재된 사항의 정정, ③. 분명하지 아니하게 기재된 사항의 명확화 중 어느 하나(法 136①)<br>2. 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내. 단, 잘못된 기재의 정정은 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내(法 136③)<br>3. 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않을 것(法 136④).<br>4. 청구범위의 감축 또는 잘못 기재된 사항의 정정에 해당하는 정정은 정정후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있을 것(法 136⑤).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 원칙            | 특허권 존속중에는 물론 특허권이 장래를 향해 소멸후에도 가능(法 136⑦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 시기적 예외        | 1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고로 말한다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다.<br>2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 청구    | 청구서 제출        | 1. 수수료를 납부하고 법정사항을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출한다(法 140①). 이 때 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 한다(法 140⑤).<br>2. 다만, 피청구인에 대한 청구서 부분의 송달 및 답변서 제출(法 147①②)과 참가에 관한 규정(法 155, 156)은 부적용(法 136⑨).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 명세서 또는 도면의 보정 | 심리종결의 통지가 있기 전에, 심판청구서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다(法 136⑩).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 심리    |               | 심판관은 심리결과 정정의 객체적 요건 위반이 있는 경우 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 136⑥).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 심결    | 내용            | 1. 심판청구의 이유가 타당하지 아니한다고 인정된 때에는 기각심결을 하며, 심판청구의 이유가 타당하다고 인정된 때에는 인용심결을 하여야 한다.<br>2. 다만, 정정심판을 청구한 것은 일체불가분의 1개의 정정사항으로 하여 정정심판을 청구한 것으로 보기 때문에 일부인용·일부기각심결은 不可(2001허2894 등).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 불복            | 기각심결등본송달받은날로부터 30일 이내 특허법원에 심결취소소송 제기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 확정 효과 | 인용심결          | 1. 소급효<br>특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원·출원공개·특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다(法 136⑩).<br>2. 특허공보에 게재<br>특허심판원장은 그 내용을 지식재산처장에게 알려야 하며(法 136⑫), 지식재산처장은 특허심판원장으로부터 통보를 받은 때에는 이를 특허공보에 게재하여야 한다(法 136⑬).<br>3. 새로운 특허증의 발급(法 86③).<br>4. 정정심결 이전의 특허권에 기한 권리행사<br>사실심 변론종결이전에 정정심결이 확정된 경우 정정심결은 소급효가 있으므로, 정정전의 명세서 또는 도면에 의거하여 행하여진 심결 또는 판결은 그것을 이유로 하여 재심의 대상이 될 수 있다(法 178). 다만, 이 경우 특허권자가 상대방의 손해에 대하여 무과실 배상책임은 지는 것은 아니다.<br>5. 침해죄<br>청구범위에 대한 신뢰의 이익을 보호하기 위해 정정전의 청구범위를 기준으로 침해죄를 판단(2005도 1262)<br>6. 과실의 추정<br>특허권을 침해하는 제품을 생산·판매한 후에 정정하는 심결이 확정된 경우에도 정정으로 인해 청구범위의 실질적 변경이 있다고 할 수 없으므로 법 제130조에 의하여 특허권 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정하는 법리는 정정을 전·후하여 그대로 유지된다고 봄이 타당하다(2009다19925). |
|       | 기각심결          | 정정의 불인정.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### III 정정심판과 특허취소신청, 특허무효심판과의 관계

| 구 분                                        | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 동시에 계속 중인 경우                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간에는 정정심판을 청구할 수 없지만 특허무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다(法 136② I)</li> <li>2. 특허무효심판의 심결에 대한 취소소송이 특허법원이나 대법원에 계속 중인 경우에는 독립하여 그 정정심판을 청구할 수 있다(法 136② II). 또한, 특허취소신청, 특허무효심판청구 전에 정정심판이 청구된 때는 특허취소신청, 특허무효심판과 정정심판이 특허심판원에서 동시에 계속되게 된다.</li> <li>3. 이 경우 정정심판제도의 취지상 정정심판을 특허취소신청, 특허무효심판에 우선하여 심리·판단하는 것이 바람직하나, 그렇다고 하여 반드시 정정심판을 먼저 심리·판단하여야 하는 것은 아니다(法 제 164조의 타절차와의 관계에서 중지는 재량이다).</li> <li>4. 한편 특허취소신청, 특허무효심판을 먼저 심리하는 경우에는 그 판단대상은 정정심판청구 전 특허발명이다.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 특허취소신청, 특허무효심판 계속 중에 정정심판을 인정하는 심결이 확정된 경우 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 특허심판원에 계속중인 경우<br/>정정심판에 의하여 소급효가 인정되므로, 특허심판원은 정정후 명세서 또는 도면을 기준으로 특허취소사유, 특허무효사유를 판단하면 된다.</li> <li>2. 특허법원에 계속중인 경우 <ol style="list-style-type: none"> <li>① 특허법원에 특허무효심결에 대한 취소소송이 계속 중 정정심결이 확정된 경우에는 특허심판원의 심결이 심판 대상을 잘못 정한 흠결이 있지만, 특허법원은 법률심이 아닌 사실심이고 심리범위에 제한을 받지 않기 때문에 정정된 청구범위를 기준으로 특허무효사유가 있는지 여부를 판단하여 그에 따라 심결의 적법성 여부를 판단하면 된다.</li> <li>② 특허법원에 특허취소결정에 대한 취소소송이 계속 중 정정심결이 확정된 경우에는 특허법원이 사실심이기에는 하나 지식재산처장이 특허심판원에 제출하지 않았던 새로운 특허취소신청의 이유나 증거를 제출할 수 없을 것이기 때문에, 결정을 취소하고 환송함이 타당해 보인다.</li> <li>③ 다만, 특허법원에 특허취소신청, 특허무효심판이 계속 중인데 청구항을 삭제하는 정정심결이 확정된 경우에는 정정된 내용대로 소급효가 인정되므로 취소소송을 구할 실익이 없어져 소각하된다.</li> </ol> </li> <li>3. 대법원에 계속중인 경우 <ol style="list-style-type: none"> <li>① 2016후2522 전원합의체 판결에서 “특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.”고 판시하였다. 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 “판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”라는 재심사유는, 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, i) 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 ii) 확정적· iii) 소급적으로 변경된 경우를 말하는 것인데, i) 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 하는 대상이지 판결의 기초가 되는 행정처분으로 볼 수 없다는 점, ii) 정정이 종전 특허발명과 실질적 동일성을 유지하는 것을 전제로 하는 것이고, 정정심결이 확정되더라도 일사부재리가 적용되지 않고, 정정무효심판에 의하여 다룰 수 있기 때문에 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 확정적으로 변경되었다고 단정할 수 없는 점, iii) 특허법 제136조 제10항에서 규정한 정정의 소급효는 사후적으로 명세서 등을 정정하더라도 이미 진행된 특허심사·심판절차의 내용과 효력을 정정 후 명세서 등에 일체성을 유지하면서 승계시킴으로써 특허심사·심판절차와 조화를 유지하면서 정정제도의 실효성을 추구하고 특허권자가 정정으로 인해 불이익을 받지 않도록 한 것이지, 정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵다는 점, iv) 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 소송절차와 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것인데, 민사소송법 제1조 제1항에서 “법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다.”라고 규정한 공정·신속·경제라는 민사소송의 이상에 비춰 당사자에 의한 소송지연을 적절히 방지할 필요성이 있다는 점을 그 근거로 하고 있다.</li> <li>② 이러한 법리는 정정청구에 대한 심결이 확정된 경우에도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다. 따라서 특허무효심판이나 권리범위확인심판 등에 대한 심결취소소송과 별개로 진행되던 특허무효심판 절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 판결에 민사소송법 제451조제1항제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다.</li> <li>③ 또한, 2016후522 판결에서는, “이러한 법리는 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송과 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에서도 그대로 적용되어야 한다. 특히, 특허권에 기초한 침해</li> </ol> </li> </ol> |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p>금지 또는 손해배상 등을 구하는 소송에서 그 특허가 무효로 될 것임이 명백하여 특허권자의 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 특허권자로서는 특허권에 대한 정정심판청구, 정정청구를 통해 정정을 인정받아 그러한 무효사유를 해소했거나 해소할 수 있다는 사정을 그 재항변으로 주장할 수 있다. 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 종국판결이 확정되거나 그 확정 전에 특허권자가 정정의 재항변을 제출하지 않았음에도 사실심 변론종결 후에 정정심결의 확정을 이유로 사실심 법원의 판단을 다투는 것은 허용되지 않는다.”고 판시하였다.</p> |
| <b>정정심판 계속 중에 특허취소신청에 대한 취소결정이나 특허무효심판에 대한 인용심결이 확정된 경우</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 특허발명의 전체 청구항에 대한 무효심결이 확정된 경우, 정정을 구하는 정정심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정심판을 구할 이익도 없게 되고, 특허발명이 소급적으로 무효로 된 이상, 정정심결의 취소를 구할 법률상의 이익도 없게 됨.</li> <li>2. 심판원에 계속중인 경우 - 심판의 심결각하</li> <li>3. 특허법원에 계속중인 경우 - 심결취소소송의 소각하.</li> <li>4. 대법원에 계속중인 경우 - 파기소각하</li> </ol>        |

#### Ⅳ 특허의 정정과 정정심판의 구별

| 구 분                  | 독립적 청구                      | 독립적 처분               | 독립적 불복           |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| 특허의 정정청구<br>(가생제도)   | ×(특허취소신청·특허무효심판·정정무효심판에 기생) | ×(심결문의 주문 및 이유란에 기재) | ×(불복의 대상이 없기 때문) |
| 특허정정심판의 청구<br>(독립제도) | ○                           | ○                    | ○                |

| 시기              | 종류     | 정정청구       | 정정심판청구 |
|-----------------|--------|------------|--------|
| 심판원 계속 중        | 특허취소신청 | ○(法 132의3) | △*     |
|                 | 특허무효심판 | ○(法 133의2) | ×      |
|                 | 정정무효심판 | ○(法 137③④) | ×      |
| 특허법원 / 대법원 계속 중 | 특허취소신청 | ×          | △*     |
|                 | 특허무효심판 | ×          | ○      |
|                 | 정정무효심판 | ×          | ○      |
| 계속 중이지 아니한 경우   |        | ×          | ○      |

\* 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고로 말한다)된 날까지 정정심판청구 가능

#### Ⅴ 청구범위의 실질적 변경 여부에 대한 구체적 예

| 정정 전 명세서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 정정 후 명세서                            |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 사례1                                 | 사례2                                  |
| 【발명의 설명】 A, A+B, A+C, A+B+C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                      |
| 【청구범위】<br>1. A<br>2. A+B<br>3. A+C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 【청구범위】<br>1. A+B<br>2. 삭제<br>3. A+C | 【청구범위】<br>1. A+B+C<br>2. 삭제<br>3. 삭제 |
| <p><b>해설</b> 【사례 1】은 청구항 1이 정정 전 'A'에서 정정 후 'A+B'로 변경되었으나, 'A+B'는 정정 전에 이미 발명의 설명 부분에 기재되어 있었던 사항이고, 정정 전 청구항 2에 기재되어 있던 기술 구성을 그 청구항만을 달리하여 정정한 것이므로 형식적으로 감축된 것일 뿐만 아니라, 청구항은 정정 전후에 달라졌다 하더라도 그 청구범위의 실질적인 내용은 동일한 것이어서 그 정정은 인정되어야 할 것이다. 그런데 위의 경우와는 달리, 【사례 2】는 청구항 1의 경우에 정정 전 'A'에서 'A+B+C'로 변경된 것으로, 'A+B+C'가 정정 전에 명세서에 없던 새로운 기술적 사항을 청구범위에 새로 추가한 것은 아니나, 정정 전 청구범위에 기재되어 있지 않았던 기술적 사항이 청구항 1에 추가된 것이어서 정정된 청구항 1이 새로운 목적 및 효과를 갖는지 여부를 판단하여 최종적으로 실질적 변경 여부가 결정되어야 하는 것이다. 즉 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 기술적 사항이 비록 정정 전의 명세서 또는 도면에 기재되어 있었던 기술적 사항이라 할지라도, 새로운 목적 및 효과를 갖는 것으로 인정될 경우에는 그 정정은 인정될 수 없는 것이다.</p> |                                     |                                      |

# 69

## 정정무효심판(法 137)

### I 법조문

#### 제137조 【정정의 무효심판】 法 133, 134

- ① **(주체적 및 객체적 요건)** 이해관계인 또는 심사관은 제132조의3제1항[특허소신청에서의 정정], 제133조의2제1항[특허무효심판에서의 정정], 제136조제1항[정정심판에서의 정정] 또는 이 조 제3항[정정무효심판에서의 정정]에 따른 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정이 다음 각 호의 어느 하나의 규정을 위반한 경우에는 정정의 무효심판을 청구할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
  1. 제136조제1항 각 호의 어느 하나의 규정
  2. 제136조제3항부터 제5항까지의 규정(제132조의3제3항 또는 제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)
- ② **(시기적 요건 및 통지)** 제1항에 따른 심판청구에 관하여는 제133조제2항 및 제4항을 준용한다.
- ③ **(특허의 정정청구: 요건)** 제1항에 따른 무효심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조 제1항[답변서 제출기간] 또는 제159조제1항 후단[의견서 제출기간]에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. <개정 2016.2.29.> 法 132의3, 133의2 / 136
- ④ **(특허의 정정청구: 준용규정)** 제3항에 따른 정정청구에 관하여는 제133조의2제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 제133조의2제3항 중 "제133조제1항"은 "제137조제1항"으로 보고, 같은 조 제4항 후단 중 "제133조의2제1항"을 "제137조제3항"으로 보며, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제1호 중 "제1항"을 각각 "제3항"으로 본다. <개정 2016.2.29.> 法 132의3, 133의2 / 136
- ⑤ **(효과)** 제1항에 따라 정정을 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다. [전문개정 2014.6.11.]



## II 정정무효심판(法 137)

| 제 도   |                | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서     | 의의             | 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정(특허취소신청, 특허무효심판 또는 정정무효심판절차에서의 정정, 정정심판에 의한 정정)이 부적법한 경우에 그 정정을 무효로 하는 심판을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 취지             | 권리범위 사후적 확장이나 유효한 특허에 의한 제3자의 불측 손해 방지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 요건    | 주체적            | 청구인<br>이해관계인 또는 심사관                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 피청구인           | 특허권자, 공유인 경우 모두(法 139②)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 객체적            | 대상<br>다음의 요건을 만족하지 않을 것(정정의 객체적 요건과 동일)<br>1. 청구범위의 감축, 잘못 기재된 사항의 정정, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확히 하는 경우,<br>2. 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있으나, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 정정할 것<br>3. 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않을 것<br>4. 청구범위의 감축 또는 잘못된 기재의 정정에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것 |
|       | 범위             | ① 특허취소신청, 특허무효심판 또는 정정무효심판에서의 정정, ② 정정심판에 의한 정정                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 시기적            | 1. 존속기간중은 물론 장래를 향해 소멸된 후에도 청구가능<br>2. 다만, 정정된 명세서 또는 도면에 의하여 특허 무효심결이 확정이나 취소결정이 확정되어 특허권이 소급소멸한 경우에는 청구불가.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 청구    | 청구서 제출         | 수수료를 납부하고 법정사항을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출한다(法 140①).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 부분 송달 및 답변서 제출 | 심판장은 심판청구가 있는 때에는 청구서 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출기회를 주어야 하며 답변서를 받았을 때에는 그 부분을 청구인에게 송달(法 147①②). 취지를 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지(法 137② 준용 133④).                                                                                                                                                                                   |
| 심리    |                | 정정무효심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청한 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다(法 154①). 한편, 정정무효심판은 당사자계 심판으로서 심판의 참가가 허용된다.                                                                                                                                                                                                                     |
| 심결    | 내용             | 심판청구의 이유가 타당하지 아니한다고 인정된 때에는 기각심결을 하며, 심판청구의 이유가 타당하다고 인정된 때에는 인용심결을 하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 불복             | 심결등본송달받은날로부터 30일 이내 특허법원에 심결취소소송 제기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 확정 효과 | 인용심결           | 정정을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 137⑤).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 기각심결           | 기각심결이 확정되면 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일심판을 청구할 수 없다. 이에 위반되면 부적법한 심판청구를 이유로 심결각하된다(法 163).                                                                                                                                                                                                                                                                        |





## 통상실시권허락심판(法 138)

### I 법조문

#### 제138조 【통상실시권 허락의 심판】(★★) 法 98, 183 / 140④

- ① **(일반적인 경우: 요건)** 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.
- ② **(일반적인 경우: 요건)** 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다.
- ③ **(CROSS-LICENSE 경우: 요건)** 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.
- ④ **(대가 지급 또는 공탁 후 실시)** 제1항 및 제3항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다.
- ⑤ **(대가 지급하지 아니하고 공탁하지 아니한 경우 실시 不可)** 제4항에 따른 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

## II 통상실시권허락심판(法 138)

| 제 도  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서    | 의의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 특허발명이 이용·저촉 관계에 해당되어 통상실시권의 허락을 받으려는 경우 그 타인이 실시에 대한 허락을 하지 아니한 때에 한하여 강제적으로 특허발명을 실시할 수 있는 통상실시권을 허락하는 심판을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 취지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 후출원 권리자에 대하여도 실시할 수 있는 방안을 마련하여 산업발전에 이바지라는 법 목적을 달성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 종류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. 일반적인 경우(法 138①②) - 후출원권리자가 선출원권리자에게 청구하는 심판을 말한다.<br>2. CROSS - LICENSE(法 138③) - 심판에 의하여 통상실시권을 허락한 선출원권리자가 심판에 의하여 통상실시권을 허락받은 후출원권리자에게 청구하는 심판이다.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 요건   | 주체적                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 청구인<br>1. 일반적인 경우(法 138①②) - 이용·저촉관계의 후출원특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자<br>2. CROSS - LICENSE(法 138③) - 선출원특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 전용실시권자                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 피청구인<br>1. 일반적인 경우(法 138①②) - 선출원특허권자·실용신안권자, 디자인권자 또는 전용실시권자<br>2. CROSS - LICENSE(法 138③) - 통상실시권을 허락받은 특허권자·전용실시권자(통상실시권자는 통상실시권이 채권적 권리이므로 이론적으로 不可)                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 객체적<br>1. 이용·저촉관계에 있을 것(法 138①) - 특허발명이 선출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 이용하거나 타인의 디자인권과 저촉관계에 있어야 한다(상표권과 저촉x).<br>2. 정당한 이유없이 실시허락을 아니하거나 실시허락을 받을 수 없을 것(法 138①)<br>후출원권리자는 심판청구전에 선출원권리자와 협의를 통해 실시허락을 받기 위해 노력해야 한다. 그렇지 아니한 경우 부적법한 심판청구로서 심결각하된다.<br>3. 특허발명 또는 등록실용신안을 이용하는 경우 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술상의 진보가 있을 것(法 138②)<br>4. CROSS - LICENSE(法 138③) - 통상실시권허락심판에 의하여 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권의 허여를 받는 자의 특허발명의 실시를 필요로 하는 경우에 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없는 때에는 통상실시권의 허락을 받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 시기적<br>타방의 권리 존속중인 경우에만                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 청구   | 청구서 제출                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 수수료를 납부하고 법정사항을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출(法 140①). 심판청구서에는 ① 실시를 요하는 자기의 특허의 번호 및 명칭, ② 실시되어야 할 타인의 특허발명·등록실용신안이나 등록디자인의 번호·명칭 및 특허나 등록의 연월일, ③ 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 통상실시권의 범위·기간 및 대가를 기재(法 140④)                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 부분송달등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 심판장은 심판청구가 있는 때에는 청구서 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출 기회를 주어야 한다(法 147①).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 심리   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 청구인이 신청한 청구취지의 범위내에서 심리하여야 한다. 구체적으로 그 특허발명이 타인의 선출원된 특허발명 등과 이용·저촉관계에 있는지 여부 및 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보 여부, 통상실시권설정의 범위, 통상실시권허락에 따른 대가 및 그 지불방법, 지불시기에 대하여 심리하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 심결   | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 심판청구의 이유가 타당하지 아니한다고 인정된 때에는 기각심결을 하며, 심판청구의 이유가 타당하다고 인정된 때에는 심결의 주문에 통상실시권의 범위, 기간 및 대가를 구체적으로 명시하여 인용심결을 하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 불복                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 심결등본송달받은날로부터 30일 이내 특허법원에 심결취소소송 제기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 확정효과 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. 통상실시권의 발생 - 통상실시권을 허락하는 심결이 확정되면 통상실시권이 발생한다. 따라서 통상실시권자는 심결에 의하여 정해진 효력범위 내에서 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다. 이 때 실시권은 해당 특허권과 함께 이전하여야 하며, 특허권이 소멸한 때에 함께 소멸하며, 실시권에 대한 질권을 설정할 수 없다(法 102④⑥).<br>2. 대가의 지급 - 통상실시권자는 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 그 전용실시권자에 대하여 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유에 의하여 대가를 지급할 수 없을 때에는 그 대가를 공탁하여야 하며(法 138④) 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다(法 138⑤). |

참고자료 6.2 심판각론의 비교

I 비교 1

| 제 도     |          | 거절결정불복심판                                                                   | 정정심판                                                                                                                                                                                                                         | 권리범위확인심판                                                                |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 요 건     | 청구인      | 출원인                                                                        | 특허권자                                                                                                                                                                                                                         | 1. 적극적 - 특허권자 또는 전용실시권자<br>2. 소극적 - 실시한 적/하고 있거나 예정이 있는 이해관계인           |
|         | 피<br>청구인 | ×                                                                          | ×                                                                                                                                                                                                                            | 1. 적극적 - 실시한 적/실시하고 있는 이해관계인<br>2. 소극적 - 특허권자                           |
|         | 대 상      | 거절결정                                                                       | 1. 청구범위의 감축, 잘못 기재된 사항의 정정 및 분명하지 아니하게 기재된 사항의 명확화 중 어느 하나<br>2. 특허발명의 명세서·도면(단, 잘못 기재된 사항의 정정은 최초 명세서·도면)<br>3. 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것<br>4. 청구범위의 감축, 잘못 기재된 사항의 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때 특허를 받을 수 있을 것 | 청구항마다 가능                                                                |
|         | 시 기      | 등본송달받은 날로부터 3개월 이내(연장, 추후보완 가능)                                            | 1. 존속기간 중은 물론 장래를 향해 소멸한 경우도 가능<br>2. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간(단, 특허/정정 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지 가능)과 특허/정정무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간에는 불가             | 특허권 존속기간 중에만 가능                                                         |
| 절 차     | 청구       | 출원일 및 출원번호, 발명의 명칭, 특허거절결정일을 추가 기재                                         | 1. 정정한 명세서 또는 도면의 첨부<br>2. 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 대한 통상실시권자 및 질권자의 동의서를 첨부(단, 동의받아야 하는 자가 무효심판청구한 경우 제외)                                                                                                               | 1. 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면의 첨부<br>2. 부분 송달 및 답변서 제출기회 부여                   |
|         | 진행       | 1. 보정각하도 함께 불복한 경우 심리범위 포함<br>2. 심사에서 밝은 절차의 효력이 심판에도 미침<br>3. 거절이유 전면적 심리 | 1. 정정청구사유를 만족하는지 직권심리 후 의견서를 제출할 수 있는 기회 부여<br>2. 심리종결통지 전까지 정정명세서 또는 도면의 보정                                                                                                                                                 | 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 심리                                             |
|         | 종료       | 1. 심판청구가 타당한 경우 원 거절결정을 취소하고 재판 (특허심결) 또는 환송<br>2. 환송 시 심사관의 기속            | 일부인용·기각 불가                                                                                                                                                                                                                   | 1. 심판청구가 타당하지 않은 경우 기각한다고 하여야 되며, 청구취지에 반하는 심결을 해서는 안됨<br>2. 청구항별 취하 가능 |
| 확 정 효 과 | 인용       | 1. 특허결정된 경우 특허료 내면 특허권 발생<br>2. 연장등록결정된 경우 지식재산처장이 특허원부 등록/특허공보 게재         | 1. 정정된 내용대로 출원·공개·결정·심결·등록된 것으로 간주<br>2. 심판원장이 지식재산처장에게 알리면, 지식재산처장이 특허공보에 게재<br>3. 침해죄는 정정 전 청구범위 기준 판단<br>4. 정정전후 과실 추정 불변                                                                                                 | 보호범위의 공적 확인/단, 법원의 기속력 불인정                                              |
|         | 기각       | 거절결정 확정                                                                    | 정정의 불인정                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |
| 심판비용    |          | 청구인                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | 패심자                                                                     |
| 일사부재리   |          | 부적용                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | 적용(적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판)                                          |
| 참가여부    |          | 불허(단, 정보제공 가능)                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | 허용                                                                      |
| 비 고     |          | 정정심판과 특허취소신청/특허무효심판의 관계                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | 권리 사이의 권리범위확인심판                                                         |

## II 비교 2

| 제 도              |                           | 특허무효심판                                        | 연장등록무효심판                                                                                                                                           | 정정무효심판                                                                            | 통상실시권허락심판                                                                                                  |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요<br>건           | 청구인                       | 이해관계인(제2호 본문의 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자) 또는 심사관 | 이해관계인 또는 심사관                                                                                                                                       |                                                                                   | 1. 일반적 - 후출원 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자<br>2. 크로스 라이선스 - 통상실시권을 허락한 선출원 권리자                                      |
|                  | 피청구인                      | 특허권자                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                   | 1. 일반적 - 선출원 특허권자, 전용실시권자, 실용실안권자, 디자인권자<br>2. 크로스 라이선스 - 통상실시권을 허락받은 후출원 특허권자, 전용실시권자                     |
|                  | 대 상                       | 청구항마다 특허무효사유에 해당함을 이유로 청구                     | 허가 등/등록지연에 따른 연장등록이 연장등록 무효사유(거절이유와 동일)에 해당함을 이유로 청구                                                                                               | 특허취소신청에서의 정정, 특허무효심판 또는 정정무효심판에서의 정정, 정정심판에서의 정정이 정정무효사유(정정청구사유와 동일)에 해당함을 이유로 청구 | 1. 이용·저촉관계<br>2. 실시허락 x<br>3. 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위 이내일 것<br>4. 선출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 기술상의 진보가 있을 것 |
|                  | 시 기                       | 존속기간 중은 물론 장래를 향해 소멸한 경우도 가능                  |                                                                                                                                                    |                                                                                   | 타방 권리 존속 중에만 가능                                                                                            |
| 절<br>차           | 청구                        | 1. 부분 송달 및 답변서 제출기회 부여<br>2. 등록된 권리자에게 취지 통지  |                                                                                                                                                    |                                                                                   | 1. 청구서에 자기의 권리, 타인의 권리 특정과 범위·기간·대가의 추가 기재<br>2. 부분 송달 및 답변서 제출기회 부여                                       |
|                  | 진행                        | 신청한 청구항에 대해서 특허무효사유가 있는지 심리                   |                                                                                                                                                    |                                                                                   | 연장등록무효사유가 있는지 심리                                                                                           |
|                  | 종료                        | 1. 청구항마다 일부인용·기각 가능<br>2. 청구항별 취하 가능          |                                                                                                                                                    |                                                                                   | 심결의 주문에 통상실시권의 범위, 기간 및 대가를 구체적으로 명시하여 인용심결                                                                |
| 확<br>정<br>효<br>과 | 인용<br>심결                  | 특허권이 처음부터 없었던 것으로 간주(단, 후발적 무효사유는 발생 시부터 장래효) | 1. 연장등록이 처음부터 없었던 것으로 간주(단, 연장기간을 초과하여 등록된 경우에는 초과된 기간에 대해서만 연장등록 불인정)<br>2. 하나의 허가 등에 대하여 둘 이상의 특허권의 존속기간이 연장등록된 경우 존속기간의 연장등록출원은 처음부터 없었던 것으로 간주 | 정정이 처음부터 없었던 것으로 간주                                                               | 1. 통상실시권 허락<br>2. 실시권은 해당 특허권과 함께 이전하며, 함께 소멸<br>3. 대가 지급하지 않거나 공탁하지 않으면 실시불가                              |
|                  | 기각<br>심결                  | 특허권의 유지                                       | 연장등록의 유지                                                                                                                                           | 정정의 유지                                                                            | 통상실시권 불허                                                                                                   |
| 심판비용             | 패심자                       |                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                   | 청구인                                                                                                        |
| 일사부재리            | 적용(전부무효심판과 일부무효심판)        |                                               | 적용                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                            |
| 참가여부             | 허용                        |                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                   | 보조 참가만이 허용                                                                                                 |
| 비 고              | 특허무효심판이 심판원에 계속 중 정정청구 가능 |                                               |                                                                                                                                                    | 정정무효심판이 심판원에 계속 중 정정청구 가능                                                         | 크로스 라이선스 요건<br>- 통상실시권허락심판에 의하여 실시권허락<br>- 후출원 권리자가 실시허락x<br>- 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위 이내일 것                   |



## 특허취소신청(法 132의2~132의15)

### I 법조문

#### 제132조의2 【특허취소신청】(★) 法 62, 63의2, 133

① (요건) 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 특허취소신청을 할 수 있다.

1. 제29조(같은 조 제1항제1호에 해당하는 경우와 같은 호에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우는 제외한다)에 위반된 경우
2. 제36조제1항부터 제3항까지의 규정에 위반된 경우

② (예외) 제1항에도 불구하고 특허공보에 게재된 제87조제3항제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다. 法 63의3, 83③Ⅶ

[본조신설 2016.2.29.]

[충전 제132조의2는 제132조의16으로 이동 <2016.2.29.>]

#### 제132조의3 【특허취소신청절차에서의 특허의 정정】 法 133의2, 137③④ / 136

① (요건) 특허취소신청절차가 진행 중인 특허에 대한 특허권자는 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제132조의13제2항[특허취소결정하려고 특허의 취소이유를 통지하고 의견서 제출기회 부여]에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다.

② (여러 차례 정정이 있는 경우) 제1항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 특허취소신청절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다.

③ (준용규정) 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지[정정심판의 객체적 요건, 제8항[정정심판의 주체적 요건, 제10항부터 제13항까지[소급효, 명세서 또는 도면의 보정, 통보 및 특허공보에 게재], 제139조제3항[공동심판청구] 및 제140조제1항·제2항·제5항[정정심판의 청구 및 보정]을 준용한다. 이 경우 제136조제11항[명세서 또는 도면의 보정] 중 "제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에는 "제132조의13제2항[정정청구가능기간] 또는 제136조제6항[정정심판의 직권심리에 대한 의견서 제출기간]에 따라 지정된 기간"에"로 본다.

④ (정정청구의 취하) 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다.

1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간
2. 제3항에서 준용하는 제136조제6항[정정심판의 직권심리에 대한 의견서 제출기간]에 따라 지정된 기간

⑤ (특허출원하였을 때 특허를 받을 수 있을 것의 판단) 제3항을 적용할 때 제132조의2에 따라 특허취소신청이 된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다.

[본조신설 2016.2.29.]

[충전 제132조의3은 제132조의17로 이동 <2016.2.29.>]

#### 제132조의4 【특허취소신청의 방식 등】

① (취소신청서의 제출) 특허취소신청을 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허취소신청서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 法 140①

1. 신청인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
3. 특허취소신청의 대상이 되는 특허의 표시
4. 특허취소신청의 이유 및 증거의 표시

② (취소신청서의 보정) 제1항에 따라 제출된 특허취소신청서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 제132조의2제1항에 따른 기간(그 기간 중 제132조의13제2항[특허취소결정하려고 특허의 취소이유를 통지하고 의견서 제출기회 부여]에 따른 통지가 있는 경우에는 통지한 때까지로 한정한다)에 제1항제4호의 사항을 보정하는 경우에는 그러하지 아니하다. 法 140②

- ③ **(부분 송달)** 심판장은 특허취소신청이 있으면 그 신청서의 부분을 특허권자에게 송달하여야 한다. **法 147①②**
- ④ **(통지)** 심판장은 특허취소신청이 있으면 그 사실을 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다. **法 133④**

[본조신설 2016.2.29.]

#### 제132조의5 【특허취소신청서 등의 보정·각하】 **法 141**

- ① **(대상)** 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다.
1. 특허취소신청서가 제132조의4제1항(같은 항 제4호는 제외한다)을 위반한 경우
  2. 특허취소신청에 관한 절차가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
    - 가. 제3조제1항[미성년자 등의 행위능력] 또는 제6조[대리권의 범위]를 위반한 경우
    - 나. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우
    - 다. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우
- ② **(각하결정)** 심판장은 제1항에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 제132조의4제2항을 위반한 경우에는 특허취소신청서 또는 해당 절차와 관련된 청구 또는 신청 등을 결정으로 각하하여야 한다.
- ③ **(방식)** 제2항에 따른 각하결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.

[본조신설 2016.2.29.]

#### 제132조의6 【보정할 수 없는 특허취소신청의 각하결정】 **法 142**

- ① **(대상)** 제132조의7제1항에 따른 합의체는 부적법한 특허취소신청으로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 제132조의4제3항에도 불구하고 특허권자에게 특허취소신청서의 부분을 송달하지 아니하고, 결정으로 그 특허취소신청을 각하할 수 있다.
- ② **(불복)** 제1항에 따른 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다. **法 186①**

[본조신설 2016.2.29.]

#### 제132조의7 【특허취소신청의 합의체 등】 **法 146**

- ① **(심판의 주체)** 특허취소신청은 3명 또는 5명의 심판관으로 구성되는 합의체가 심리하여 결정한다.
- ② **(준용)** 제1항의 합의체 및 이를 구성하는 심판관에 관하여는 제143조부터 제145조까지[심판관, 심판장의 지력 및 지정], 제146조 제2항·제3항[심판관 합의체의 합의], 제148조부터 제153조까지 및 제153조의2[심판관의 재직, 기피 및 회피]를 준용한다. 이 경우 제148조제6호 중 "심결"은 "특허취소결정"으로 본다.

[본조신설 2016.2.29.]

#### 제132조의8 【심리의 방식 등】

- ① **(서면심리)** 특허취소신청에 관한 심리는 서면으로 한다. **法 154**
- ② **(특허권자 1인에게 절차의 정지원인이 있는 경우)** 공유인 특허권의 특허권자 중 1인에게 특허취소신청절차의 중단 또는 중지的原因이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다. **法 139④**

[본조신설 2016.2.29.]

#### 제132조의9 【참가】 **法 155, 156**

- ① **(보조참가의 요건)** 특허권에 관하여 권리를 가진 자 또는 이해관계를 가진 자는 특허취소신청에 대한 결정이 있을 때까지 특허권자를 보조하기 위하여 그 심리에 참가할 수 있다.
- ② **(준용)** 제1항의 참가에 관하여는 제155조제4항[보조참가의 효과]·제5항[참가인 1인에게 정지원인이 있는 경우] 및 제156조[참가의 절차]를 준용한다.

[본조신설 2016.2.29.]

#### 제132조의10 【특허취소신청의 심리에서의 직권심리】 **法 159**

- ① **(범위)** 심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인, 특허권자 또는 참가인이 제출하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다.
- ② **(한계)** 심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인이 신청하지 아니한 청구항에 대해서는 심리할 수 없다.

[본조신설 2016.2.29.]

#### 제132조의11 【특허취소신청의 병합 또는 분리】 **法 160**

- ① **(병합)** 심판관 합의체는 하나의 특허권에 관한 둘 이상의 특허취소신청에 대해서는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 그 심리를 병합하여 결정하여야 한다.
- ② **(분리)** 심판관 합의체는 특허취소신청의 심리에 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항에 따라 병합된 심리를 분리할 수 있다.

[본조신설 2016.2.29.]

#### 제132조의12 【특허취소신청의 취하】 **法 161**

- ① **(시기적 요건)** 특허취소신청은 제132조의14제2항에 따라 결정등본이 송달되기 전까지만 취하할 수 있다. 다만, 제132조의



13제2항에 따라 특허권자 및 참가인에게 특허의 취소이유가 통지된 후에는 취하할 수 없다.

② **(객체적 요건)** 둘 이상의 청구항에 관하여 특허취소신청이 있는 경우에는 청구항마다 취하할 수 있다.

③ **(효과)** 제1항 또는 제2항에 따른 취하가 있으면 그 특허취소신청 또는 그 청구항에 대한 특허취소신청은 처음부터 없었던 것으로 본다.

[본조신설 2016.2.29.]

#### 제132조의13 【특허취소신청에 대한 결정】(★)

① **(취소결정: 의의)** 심판관 합의체는 특허취소신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 그 특허를 취소한다는 취지의 결정(이하 "특허취소결정"이라 한다)을 하여야 한다.

② **(취소결정: 절차)** 심판장은 특허취소결정을 하려는 때에는 특허권자 및 참가인에게 특허의 취소이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다. **法 132의3①, 132의4②, 132의12① / 159①후단**

③ **(취소결정: 효과)** 특허취소결정이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. **法 84①Ⅱ, 65⑥Ⅲ / 133③ / 215**

④ **(기각결정: 의의)** 심판관 합의체는 특허취소신청이 제132조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하거나 같은 조 제2항을 위반한 것으로 인정되는 경우에는 결정으로 그 특허취소신청을 기각하여야 한다.

⑤ **(기각결정: 불복)** 제4항에 따른 기각결정에 대해서는 불복할 수 없다.

**法 186①**

[본조신설 2016.2.29.]

#### 제132조의14 【특허취소신청의 결정 방식】 **法 162**

① **(결정의 방식)** 특허취소신청에 대한 결정은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 하며, 결정을 한 심판관은 그 서면에 기명날인하여야 한다.

1. 특허취소신청사건의 번호

2. 특허취소신청인, 특허권자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)

3. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]

4. 결정에 관련된 특허의 표시

5. 결정의 결론 및 이유

6. 결정연월일

② **(송달)** 심판장은 특허취소신청에 대한 결정이 있는 때에는 그 결정의 등본을 특허취소신청인, 특허권자, 참가인 및 그 특허취소신청에 대한 심리에 참가를 신청하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다. **法 186②**

[본조신설 2016.2.29.]

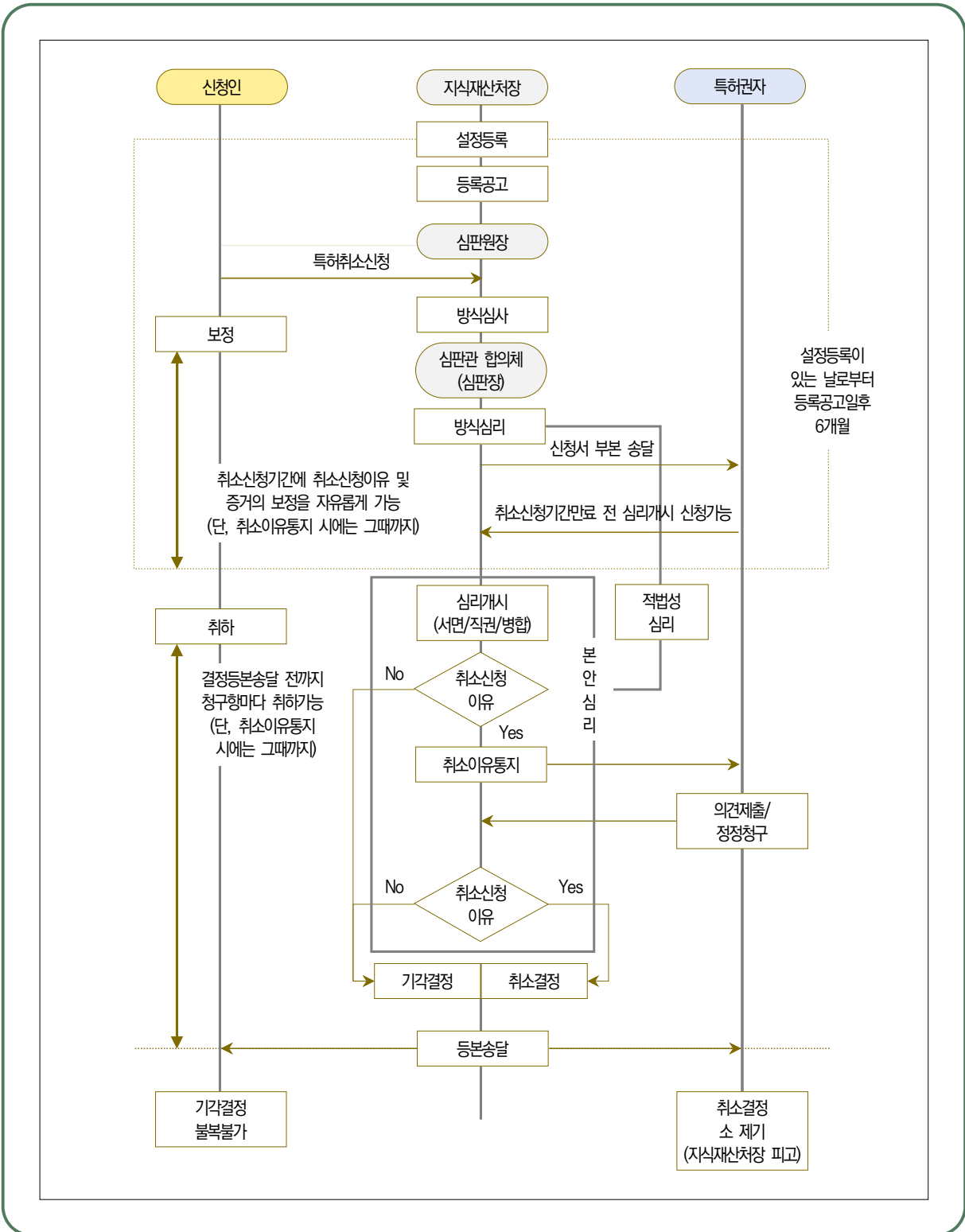
#### 제132조의15 【심판규정의 특허취소신청에의 준용】

특허취소신청의 심리·결정에 관하여는 제147조제3항[당사자 심문], 제157조[증거조사 및 증거보전], 제158조[심판의 진행], 제164조[소송과의 관계], 제165조제3항부터 제6항까지[청구인의 심판비용 부담] 및 제166조[심판비용액 또는 대가에 대한 집행권원]를 준용한다.

[본조신설 2016.2.29.]



## II 특허취소신청절차



### III 특허취소신청과 특허무효심판의 비교(법조문)

| 특허취소신청                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 특허무효심판                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>제132조의2 【특허취소신청】</b></p> <p>① <b>(요건)</b> 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 특허취소신청을 할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>제29조(같은 조 제1항제1호에 해당하는 경우와 같은 호에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우는 제외한다)에 위반된 경우</li> <li>제36조제1항부터 제3항까지의 규정에 위반된 경우</li> </ol> <p>② <b>(예외)</b> 제1항에도 불구하고 특허공보에 게재된 제87조제3항제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>제133조 【특허의 무효심판】</b></p> <p>① <b>(주체적 및 객체적 요건)</b> 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>제25조[외국인의 권리능력], 제29조[특허요건], 제32조[특허를 받을 수 없는 발명], 제36조제1항부터 제3항까지[선출원], 제42조제3항제1호[일반적인 발명의 설명 기재방법] 또는 같은 조 제4항[청구범위 기재방법] 기재원칙을 위반한 경우</li> <li>제33조제1항 본문[특허를 받을 수 있는 자에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조[공동출원]를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.</li> <li>제33조제1항 단서[특허를 받을 수 없는 자에 따라 특허를 받을 수 없는 경우</li> <li>특허된 후 그 특허권자가 제25조에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우</li> <li>조약을 위반하여 특허를 받을 수 없는 경우</li> <li>제47조제2항 전단[신규사항추가금지: 외국어특허출원의 경우 원문의 범위만]에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우</li> <li>제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원인 경우 또는 제52조의2제1항 각 호 외의 부분 전단에 따른 범위를 벗어난 분리출원인 경우</li> <li>제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우</li> </ol> <p>② <b>(시기적 요건)</b> 제1항에 따른 심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다.</p> <p>③ 생략</p> <p>④ 생략</p> |
| <p><b>제132조의3 【특허취소신청절차에서의 특허의 정정】</b></p> <p>① <b>(요건)</b> 특허취소신청절차가 진행 중인 특허에 대한 특허권자는 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제132조의13제2항[특허취소결정하러고 특허의 취소이유를 통지하고 의견서 제출기한 부여]에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다.</p> <p>② <b>(여러 차례 정정이 있는 경우)</b> 제1항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 특허취소신청절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다.</p> <p>③ <b>(준용규정)</b> 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지[정정심판의 객체적 요건, 제8항[정정심판의 주체적 요건, 제10항부터 제13항까지[소급효, 명세서 또는 도면의 보정, 통보 및 특허공보에 게재, 제139조제3항[공동심판청구] 및 제140조제1항·제2항·제5항[정정심판의 청구 및 보정]을 준용한다. 이 경우 제136조제11항[명세서 또는 도면의 보정] 중 "제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에는"는 "제132조의13제2항[정정청구가능기간] 또는 제136조제6항[정정심판의 직권심리에 대한 의견서 제출기간]에 따라 지정된 기간에"로 본다.</p> | <p><b>제133조의2 【특허무효심판절차에서의 특허의 정정】</b></p> <p>① <b>(요건)</b> 제133조제1항[특허무효심판]에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항[답변서 제출기간] 또는 제159조제1항 후단[의견서 제출기간]에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.</p> <p>② <b>(여러 차례 정정이 있는 경우)</b> 제1항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 무효심판절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다.</p> <p>③ <b>(송달)</b> 심판장은 제1항에 따른 정정청구가 있을 때에는 그 청구서의 부분을 제133조제1항에 따른 심판의 청구인에게 송달하여야 한다.</p> <p>④ <b>(준용규정)</b> 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지[정정심판의 객체적 요건, 제8항[정정심판의 주체적 요건] 및 제10항부터 제13항까지[소급효, 명세서 또는 도면의 보정, 통보 및 특허공보에 게재, 제139조제3항[공동심판청구] 및 제140조제1항·제2항·제5항[정정심판의 청구 및 보정]을 준용한다. 이 경우 제136조제11항[명세서 또는 도면의 보정] 중 "제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에는"는 "제133조의2제1항[정정청구가능기간] 또는 제136조제6항[정정심판의 직권심리에 대한 의견서 제출기간]에 따라 지정된 기간에"로 본다.</p>             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>④ <b>(정정청구의 취하)</b> 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간</li> <li>2. 제3항에서 준용하는 제136조제6항[정정심판의 직권심리에 대한 의견서 제출기간]에 따라 지정된 기간</li> </ol> <p>⑤ <b>(특허출원하였을 때 특허를 받을 수 있을 것의 판단)</b> 제3항을 적용할 때 제132조의2에 따라 특허취소신청이 된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>⑤ <b>(정정청구의 취하)</b> 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간</li> <li>2. 제4항에서 준용하는 제136조제6항[정정심판의 직권심리에 대한 의견서 제출기간]에 따라 지정된 기간</li> </ol> <p>⑥ <b>(특허출원하였을 때 특허를 받을 수 있을 것의 판단)</b> 제4항을 적용할 때 제133조제1항에 따른 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>제132조의4 【특허취소신청의 방식 등】</b></p> <p>① <b>(취소신청서의 제출)</b> 특허취소신청을 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허취소신청서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 신청인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)</li> <li>2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]</li> <li>3. 특허취소신청의 대상이 되는 특허의 표시</li> <li>4. 특허취소신청의 이유 및 증거의 표시</li> </ol> <p>② <b>(취소신청서의 보정)</b> 제1항에 따라 제출된 특허취소신청서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 제132조의2 제1항에 따른 기간(그 기간 중 제132조의13제2항[특허취소결정하러고 특허의 취소이유를 통지하고 의견서 제출기간] 부여에 따른 통지가 있는 경우에는 통지한 때까지로 한정한다)에 제1항제4호의 사항을 보정하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>③ <b>(부분 송달)</b> 심판장은 특허취소신청이 있으면 그 신청서의 부분을 특허권자에게 송달하여야 한다.</p> <p>④ <b>(통지)</b> 심판장은 특허취소신청이 있으면 그 사실을 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다.</p> | <p><b>제140조 【심판청구방식】</b></p> <p>① <b>(심판청구서의 제출)</b> 심판을 청구하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 당사자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)</li> <li>2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]</li> <li>3. 심판사건의 표시</li> <li>4. 청구의 취지 및 그 이유</li> </ol> <p>② <b>(심판청구서의 보정)</b> 제1항에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제1항제1호에 따른 당사자 중 특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(특허권자를 추가하는 것을 포함하되, 청구인이 특허권자인 경우에는 추가되는 특허권자의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우</li> <li>2. 제1항제4호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우</li> </ol> <p>③ 생략</p> <p>④ 생략</p> <p>⑤ 생략</p> <p><b>제147조 【답변서 제출 등】</b></p> <p>① <b>(부분 송달 및 답변서 제출기회의 부여)</b> 심판장은 심판이 청구되면 심판청구서 부분을 피청구인에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.</p> <p>② <b>(답변서 부분 송달)</b> 심판장은 제1항의 답변서를 받았을 때에는 그 부분을 청구인에게 송달하여야 한다.</p> <p>③ 생략</p> <p><b>제133조 【특허의 무효심판】</b></p> <p>① 생략</p> <p>② 생략</p> <p>③ 생략</p> <p>④ <b>(통지)</b> 심판장은 제1항에 따른 심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다.</p> |
| <p><b>제132조의5 【특허취소신청서 등의 보정·각하】</b></p> <p>① <b>(대상)</b> 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 특허취소신청서가 제132조의4제1항(같은 항 제4호는 제외한다)을 위반한 경우</li> <li>2. 특허취소신청에 관한 절차가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 <ul style="list-style-type: none"> <li>가. 제3조제1항 또는 제6조를 위반한 경우</li> <li>나. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우</li> <li>다. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>제141조 【심판청구서 등의 각하】</b></p> <p>① <b>(대상)</b> 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다. 다만, 보정할 사항이 경미하고 명확한 경우에는 직권으로 보정할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 심판청구서가 제140조제1항 및 제3항부터 제5항까지 또는 제140조의2제1항[심판청구서 기재]을 위반한 경우</li> <li>2. 심판에 관한 절차가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 <ul style="list-style-type: none"> <li>가. 제3조제1항[미성년자 등의 행위능력] 또는 제6조[대리권의 범위]를 위반한 경우</li> <li>나. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우</li> <li>다. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>② <b>(각하결정)</b> 심판장은 제1항에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 제132조의4제2항을 위반한 경우에는 특허취소신청서 또는 해당 절차와 관련된 청구 또는 신청 등을 결정으로 각하하여야 한다.</p> <p>③ <b>(방식)</b> 제2항에 따른 각하결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.</p>                                                                                                                      | <p>② <b>(각하결정)</b> 심판장은 제1항에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 제140조제2항 또는 제140조의2제2항을 위반한 경우에는 심판청구서 또는 해당 절차와 관련된 청구나 신청 등을 결정으로 각하하여야 한다.</p> <p>③ <b>(방식)</b> 제2항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.</p> <p>④ <b>(직권보정의 절차: 통지)</b> 심판장은 제1항 단서에 따라 직권보정을 하려면 그 직권보정 사항을 청구인에게 통지하여야 한다. &lt;신설 2023. 9. 14.&gt;</p> <p>⑤ <b>(직권보정의 절차: 의견서의 제출)</b> 청구인은 제1항 단서에 따른 직권보정 사항을 받아들일 수 없으면 직권보정 사항의 통지를 받은 날부터 7일 이내에 그 직권보정 사항에 대한 의견을 심판장에게 제출하여야 한다. &lt;신설 2023. 9. 14.&gt;</p> <p>⑥ <b>(직권보정의 효과: 의견서가 제출된 경우)</b> 청구인이 제5항에 따라 의견을 제출한 경우에는 해당 직권보정 사항은 처음부터 없었던 것으로 본다. &lt;신설 2023. 9. 14.&gt;</p> <p>⑦ <b>(직권보정의 효과: 명백히 잘못된 경우)</b> 제1항 단서에 따른 직권보정이 명백히 잘못된 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다. &lt;신설 2023. 9. 14.&gt;</p> |
| <p><b>제132조의6 【보정할 수 없는 특허취소신청의 각하결정】</b></p> <p>① <b>(대상)</b> 제132조의7제1항에 따른 합의체는 부적법한 특허취소신청으로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 제132조의4제3항에도 불구하고 특허권자에게 특허취소신청서의 부분을 송달하지 아니하고, 결정으로 그 특허취소신청을 각하할 수 있다.</p> <p>② <b>(불복)</b> 제1항에 따른 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다.</p>                                                                                   | <p><b>제142조 【보정할 수 없는 심판청구의 심결각하】</b></p> <p>부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고, 심결로써 그 청구를 각하할 수 있다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>제132조의7 【특허취소신청의 합의체 등】</b></p> <p>① <b>(심판의 주체)</b> 특허취소신청은 3명 또는 5명의 심판관으로 구성되는 합의체가 심리하여 결정한다.</p> <p>② <b>(준용)</b> 제1항의 합의체 및 이를 구성하는 심판관에 관하여는 제143조부터 제145조까지[<b>심판관, 심판장의 자격 및 지정</b>, 제146조제2항·제3항<b>심판관 합의체의 합의</b>, 제148조부터 제153조까지 및 제153조의2<b>심판관의 제척, 기피 및 회피</b>]를 준용한다. 이 경우 제148조제6호 중 "심결"은 "특허취소결정"으로 본다.</p> | <p><b>제146조 【심판의 합의체】</b></p> <p>① <b>(심판의 주체)</b> 심판은 3명 또는 5명의 심판관으로 구성되는 합의체가 한다.</p> <p>② <b>(합의: 과반수)</b> 제1항의 합의체의 합의는 과반수로 결정한다.</p> <p>③ <b>(합의: 비공개)</b> 심판의 합의는 공개하지 아니한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>제132조의8 【심리의 방식 등】</b></p> <p>① <b>(서면심리)</b> 특허취소신청에 관한 심리는 서면으로 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>제154조 【심리 등】</b></p> <p>① <b>(심리방식의 선택)</b> 심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청하였을 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다.</p> <p>② 삭제</p> <p>③ 생략</p> <p>④ 생략</p> <p>⑤ 생략</p> <p>⑥ 생략</p> <p>⑦ 생략</p> <p>⑧ 생략</p> <p>⑨ 생략</p> <p><b>제139조 【공동심판의 청구 등】</b></p> <p>① 생략</p> <p>② 생략</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>② <b>(특허권자 1인에게 절차의 정지원인이 있는 경우)</b> 공유인 특허권의 특허권자 중 1인에게 특허취소신청절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p>③ 생략<br/>④ <b>(청구인·피청구인 중 1인에게 정지원인이 있는 경우)</b> 제1항 또는 제3항에 따른 청구인이나 제2항에 따른 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>제132조의9 【참가】</b></p> <p>① <b>(보조참가의 요건)</b> 특허권에 관하여 권리를 가진 자 또는 이해관계를 가진 자는 특허취소신청에 대한 결정이 있을 때까지 특허권자를 보조하기 위하여 그 심리에 참가할 수 있다.</p> <p>② <b>(준용)</b> 제1항의 참가에 관하여는 제155조제4항<b>[보조참가의 효과]</b>·제5항<b>[참가인 1인에게 정지원인이 있는 경우]</b> 및 제156조<b>[참가의 절차]</b>를 준용한다.</p>                                                                         | <p><b>제155조 【참가】</b></p> <p>① <b>(당사자 참가: 요건)</b> 제139조제1항에 따라 심판을 청구할 수 있는 자는 심리가 종결될 때까지 그 심판에 참가할 수 있다.</p> <p>② <b>(당사자 참가: 효과)</b> 제1항에 따른 참가인은 피참가인이 그 심판의 청구를 취하한 후에도 심판절차를 속행할 수 있다.</p> <p>③ <b>(보조 참가: 요건)</b> 심판의 결과에 대하여 이해관계를 가진 자는 심리가 종결될 때까지 당사자의 어느 한쪽을 보조하기 위하여 그 심판에 참가할 수 있다.</p> <p>④ <b>(보조 참가: 효과)</b> 제3항에 따른 참가인은 모든 심판절차를 밟을 수 있다.</p> <p>⑤ <b>(참가인 1인에게 정지원인이 있는 경우)</b> 제1항 또는 제3항에 따른 참가인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대해서도 그 효력이 발생한다.</p> <p><b>제156조 【참가의 신청 및 결정】</b></p> <p>① <b>(신청서 제출)</b> 심판에 참가하려는 자는 참가신청서를 심판장에게 제출하여야 한다.</p> <p>② <b>(의견서 제출기회의 부여)</b> 심판장은 참가신청이 있는 경우에는 참가신청서 부분을 당사자 및 다른 참가인에게 송달하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.</p> <p>③ <b>(참가여부의 결정)</b> 참가신청이 있는 경우에는 심판으로 그 참가 여부를 결정하여야 한다.</p> <p>④ <b>(방식)</b> 제3항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.</p> <p>⑤ <b>(불복不可)</b> 제3항에 따른 결정에 대해서는 불복할 수 없다.</p> |
| <p><b>제132조의10 【특허취소신청의 심리에서의 직권심리】</b></p> <p>① <b>(범위)</b> 심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인, 특허권자 또는 참가인이 제출하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다.</p> <p>② <b>(한계)</b> 심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인이 신청하지 아니한 청구항에 대해서는 심리할 수 없다.</p>                                                                                                                                 | <p><b>제159조 【직권심리】</b></p> <p>① <b>(범위)</b> 심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. <b>(의견서 제출기회의 부여)</b> 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.</p> <p>② <b>(한계)</b> 심판에서는 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대해서는 심리할 수 없다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>제132조의11 【특허취소신청의 병합 또는 분리】</b></p> <p>① <b>(병합)</b> 심판관 합의체는 하나의 특허권에 관한 둘 이상의 특허취소신청에 대해서는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 그 심리를 병합하여 결정하여야 한다.</p> <p>② <b>(분리)</b> 심판관 합의체는 특허취소신청의 심리에 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항에 따라 병합된 심리를 분리할 수 있다.</p>                                                                                                            | <p><b>제160조 【심리·심결의 병합 또는 분리】</b></p> <p>심판관은 당사자 양쪽 또는 어느 한쪽이 동일한 둘 이상의 심판에 대하여 심리 또는 심결을 병합하거나 분리할 수 있다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>제132조의12 【특허취소신청의 취하】</b></p> <p>① <b>(시기적 요건)</b> 특허취소신청은 제132조의14제2항에 따라 결정등본이 송달되기 전까지만 취하할 수 있다. 다만, 제132조의13제2항에 따라 특허권자 및 참가인에게 특허의 취소 이유가 통지된 후에는 취하할 수 없다.</p> <p>② <b>(객체적 요건)</b> 둘 이상의 청구항에 관하여 특허취소신청이 있는 경우에는 청구항마다 취하할 수 있다.</p> <p>③ <b>(효과)</b> 제1항 또는 제2항에 따른 취하가 있으면 그 특허취소신청 또는 그 청구항에 대한 특허취소신청은 처음부터 없었던 것으로 본다.</p> | <p><b>제161조 【심판청구의 취하】</b></p> <p>① <b>(주체적 및 시기적 요건)</b> 심판청구는 심결이 확정될 때까지 취하할 수 있다. 다만, 답변서가 제출된 후에는 상대방의 동의를 받아야 한다.</p> <p>② <b>(객체적 요건)</b> 둘 이상의 청구항에 관하여 제133조제1항의 무효심판 또는 제135조의 권리범위 확인심판을 청구하였을 때에는 청구항마다 취하할 수 있다.</p> <p>③ <b>(효과)</b> 제1항 또는 제2항에 따른 취하가 있으면 그 심판청구 또는 그 청구항에 대한 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 본다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>제132조의13 【특허취소신청에 대한 결정】</b></p> <p>① <b>(취소결정: 의의)</b> 심판관 합의체는 특허취소신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 그 특허를 취소한다는 취지의 결정(이하 "특허취소결정"이라 한다)을 하여야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                | <p><b>제162조 【심결】</b></p> <p>① <b>(심결에 의한 종료)</b> 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>② <b>(취소결정: 절차)</b> 심판장은 특허취소결정을 하려는 때에는 특허권자 및 참가인에게 특허의 취소이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다.</p> <p>③ <b>(취소결정: 효과)</b> 특허취소결정이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.</p> <p>④ <b>(기각결정: 의의)</b> 심판관 합의체는 특허취소신청이 제132조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하거나 같은 조 제2항을 위반한 것으로 인정되는 경우에는 결정으로 그 특허취소신청을 기각하여야 한다.</p> <p>⑤ <b>(기각결정: 불복)</b> 제4항에 따른 기각결정에 대해서는 불복할 수 없다.</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>제159조 【직권심리】</b></p> <p>① <b>(범위)</b> 심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. <b>(의견서 제출기회의 부여)</b> 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.</p> <p>② 생략</p> <p><b>제133조 【특허의 무효심판】</b></p> <p>③ <b>(효과)</b> 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제4호에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 특허권은 그 특허가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.</p> <p><b>제162조【심결】</b></p> <p>① <b>(심결에 의한 종료)</b> 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>제132조의14 【특허취소신청의 결정 방식】</b></p> <p>① <b>(결정의 방식)</b> 특허취소신청에 대한 결정은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 하며, 결정을 한 심판관은 그 서면에 기명날인하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 특허취소신청사건의 번호</li> <li>2. 특허취소신청인, 특허권자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)</li> <li>3. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]</li> <li>4. 결정에 관련된 특허의 표시</li> <li>5. 결정의 결론 및 이유</li> <li>6. 결정연월일</li> </ol> <p>② <b>(송달)</b> 심판장은 특허취소신청에 대한 결정이 있는 때에는 그 결정의 등본을 특허취소신청인, 특허권자, 참가인 및 그 특허취소신청에 대한 심리에 참가를 신청하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다.</p> | <p><b>제162조 【심결】</b></p> <p>① <b>(심결에 의한 종료)</b> 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결한다.</p> <p>② <b>(심결의 방식)</b> 제1항의 심결은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 하며, 심결을 한 심판관은 그 서면에 기명날인하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 심판의 번호</li> <li>2. 당사자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)</li> <li>3. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]</li> <li>4. 심판사건의 표시</li> <li>5. 심결의 주문(제138조에 따른 심판의 경우에는 통상실시권의 범위·기간 및 대가를 포함한다)</li> <li>6. 심결의 이유(청구의 취지 및 그 이유의 요지를 포함한다)</li> <li>7. 심결연월일</li> </ol> <p>③ <b>(심리종결통지)</b> 심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.</p> <p>④ <b>(심리재개)</b> 심판장은 필요하다고 인정하면 제3항에 따라 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다.</p> <p>⑤ <b>(심결시기)</b> 심결은 제3항에 따른 심리종결통지를 한 날부터 20일 이내에 한다.</p> <p>⑥ <b>(송달)</b> 심판장은 심결 또는 결정이 있으면 그 등본을 당사자, 참가인 및 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다.</p> |
| <p><b>제132조의15 【심판규정의 특허취소신청에의 준용】</b></p> <p>특허취소신청의 심리·결정에 관하여는 제147조제3항[당사자 심문], 제157조[증거조사 및 증거보전], 제158조[심판의 진행], 제164조[소송과의 관계], 제165조제3항부터 제6항까지[청구인의 심판비용 부담] 및 제166조[심판비용액 또는 대가에 대한 집행권원]를 준용한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



#### Ⅳ 특허취소신청과 특허무효심판의 비교

| 제 도     |            | 특허취소신청                                                                                                                                                                                                                                                                       | 특허무효심판                                                                                                                              |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서       | 의 의        | 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 법 제132조의2 제1항 각 호의 특허취소사유에 해당하는 경우 특허심판원에 그 특허권의 효력을 소급하여 소멸시켜 줄 것을 요구하는 신청을 말한다(法 132의2).                                                                                                                                       | 유효하게 설정등록된 특허권이 법 제133조제1항 각 호의 무효사유에 해당하는 경우 이해관계인 또는 심사관의 심판청구에 의한 심판절차에 의하여 그 특허권의 효력을 소급하여 또는 장래를 향하여 소멸시킬 수 있는 제도를 말한다(法 133). |
|         | 취 지        | 특허심사결과의 재검토                                                                                                                                                                                                                                                                  | 당사자 간의 분쟁해결                                                                                                                         |
|         | 성 격        | 공중심사, 항고심판(결정제)                                                                                                                                                                                                                                                              | 당사자 심판                                                                                                                              |
| 요건      | 주 체        | 누구든지                                                                                                                                                                                                                                                                         | 이해관계인(단, 法 33①본문, 44 위반은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자) 또는 심사관                                                                               |
|         | 객 체        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 산업상 이용가능성, 법 제29조제1항제2호와 관련된 신규성, 진보성, 확대된 선출원 및 선출원주의 위반</li> <li>■ 단, 특허공보에 기재된 선행기술에 기초하여 不可</li> </ul>                                                                                                                          | 법 제133조제1항 각 호의 무효사유                                                                                                                |
|         |            | 청구항마다 청구가능                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|         | 시 기        | 특허권의 설정등록일로부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 가능                                                                                                                                                                                                                                         | 특허권의 존속기간 중에는 물론 특허권이 장래를 향해 소멸된 후라도 가능                                                                                             |
| 신청 / 청구 | 신청서 제출     | 신청인만 특정(결정제)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 청구인, 피청구인 특정(당사자제)                                                                                                                  |
|         | 신청서 보정     | 취소신청기간의 만료일 또는 취소이유의 통지 시까지 특허취소신청의 이유 및 증거의 표시 보정                                                                                                                                                                                                                           | 심리종결 전까지 심판청구이유의 보정                                                                                                                 |
|         | 부분송달/ 취지통지 | 부분송달 및 등록권리자 취지통지                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|         |            | 답변서 제출기회 미부여                                                                                                                                                                                                                                                                 | 답변서 제출기회 부여                                                                                                                         |
|         | 참가         | 특허취소신청에 대한 결정이 있을 때까지 특허권자 측에 보조참가만 가능                                                                                                                                                                                                                                       | 심리종결 전까지 당사자참가, 보조참가 모두 가능                                                                                                          |
|         | 정정청구       | 의견서 제출기간(원칙적으로 1회 기회 부여)                                                                                                                                                                                                                                                     | 답변서 제출기간/의견서 제출기간/심판장이 정한 기한(복수의 기회 부여)                                                                                             |
| 진행      | 방식심리       | 직권보정 불가                                                                                                                                                                                                                                                                      | 직권보정 가능                                                                                                                             |
|         | 적법성심리      | 불복불가                                                                                                                                                                                                                                                                         | 불복가능                                                                                                                                |
|         | 본안심리       | 서면심리                                                                                                                                                                                                                                                                         | 서면심리 또는 구술심리                                                                                                                        |
|         |            | 둘 이상의 특허취소신청에 대해서는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 그 심리와 결정을 필요적 병합                                                                                                                                                                                                                     | 둘 이상의 특허무효심판에 대해서는 심리 또는 심결의 임의적 병합                                                                                                 |
| 종료      | 취하         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 취소신청에 대한 결정등본이 송달되기 전까지 청구항마다</li> <li>■ 단, 특허취소이유가 통지된 후에는 불가</li> </ul>                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 심결확정 전까지 청구항마다</li> <li>■ 단, 피청구인의 답변서가 제출된 후에는 동의없이 불가</li> </ul>                         |
|         | 결정/심결      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 특허취소결정만 불복(기각결정 불복 불가)</li> <li>■ 지식재산처장이 피고</li> </ul>                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 인용/기각심결에 대한 불복</li> <li>■ 심판의 당사자가 피고</li> </ul>                                           |
|         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
| 확정 효과   | 인용         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 특허권 및 부수적인 권리의 소멸</li> <li>■ 보상금청구권의 소멸(法 65⑥) - 단, 후발적 사유에 의하여 무효가 된 경우는 제외</li> <li>■ 확정 전 침해소송은 재심사유</li> <li>■ 재심에 의하여 회복한 특허권의 효력 제한과 후용권(法 181, 182)</li> <li>■ 실시료 불반환</li> <li>■ 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분 반환(法 84)</li> </ul> |                                                                                                                                     |
|         |            | 중용권(法 104)의 불인정                                                                                                                                                                                                                                                              | 중용권(法 104)의 인정                                                                                                                      |
|         | 기각         | 특허무효심판청구하더라도 일사부재리 부적용                                                                                                                                                                                                                                                       | 다시 특허무효심판청구 시 일사부재리 적용                                                                                                              |
| 심판비용부담  |            | 신청인                                                                                                                                                                                                                                                                          | 패심자                                                                                                                                 |



## 정정청구(法 132의3, 133의2, 137③④)

### I 법조문

#### 제132조의3 【특허취소신청절차에서의 특허의 정정】 法 133의2, 137③④/136

- ① (요건) 특허취소신청절차가 진행 중인 특허에 대한 특허권자는 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제132조의3제2항[특허취소결정하려고 특허의 취소이유를 통지하고 의견서 제출기회 부여]에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다.
- ② (여러 차례 정정이 있는 경우) 제1항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 특허취소신청절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다.
- ③ (준용규정) 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지[정정심판의 객체적 요건], 제8항[정정심판의 주체적 요건], 제10항부터 제13항까지[소급효, 명세서 또는 도면의 보정, 통보 및 특허공보에 게재], 제139조제3항[공동심판청구] 및 제140조제1항·제2항·제5항[정정심판의 청구 및 보정]을 준용한다. 이 경우 제136조제11항[명세서 또는 도면의 보정] 중 "제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에는 "제132조의3제2항[정정청구가능기간] 또는 제136조제6항[정정심판의 직권심리에 대한 의견서 제출기간]에 따라 지정된 기간"에"로 본다.
- ④ (정정청구의 취하) 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다.
  1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간
  2. 제3항에서 준용하는 제136조제6항[정정심판의 직권심리에 대한 의견서 제출기간]에 따라 지정된 기간
- ⑤ (특허출원하였을 때 특허를 받을 수 있을 것의 판단) 제3항을 적용할 때 제132조의2에 따라 특허취소신청이 된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다.

[본조신설 2016.2.29.]

[충전 제132조의3은 제132조의17로 이동 <2016.2.29.>]

#### 제133조의2 【특허무효심판절차에서의 특허의 정정】(★) 法 132의3, 137③④/136

- ① (요건) 제133조제1항[특허무효심판]에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항[당면서 제출기간] 또는 제159조제1항 후단[의견서 제출기간]에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
- ② (여러 차례 정정이 있는 경우) 제1항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 무효심판절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다.
- ③ (송달) 심판장은 제1항에 따른 정정청구가 있을 때에는 그 청구서의 부분을 제133조제1항에 따른 심판의 청구인에게 송달하여야 한다.
- ④ (준용규정) 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지[정정심판의 객체적 요건], 제8항[정정심판의 주체적 요건] 및 제10항부터 제13항까지[소급효, 명세서 또는 도면의 보정, 통보 및 특허공보에 게재], 제139조제3항[공동심판청구] 및 제140조제1항·제2항·제5항[정정심판의 청구 및 보정]을 준용한다. 이 경우 제136조제11항[명세서 또는 도면의 보정] 중 "제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에는 "제133조의2제1항[정정청구가능기간] 또는 제136조제6항[정정심판의 직권심리에 대한 의견서 제출기간]에 따라 지정된 기간"에"로 본다. <개정 2016.2.29.>
- ⑤ (정정청구의 취하) 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다. <신설 2016.2.29.>
  1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간
  2. 제4항에서 준용하는 제136조제6항[정정심판의 직권심리에 대한 의견서 제출기간]에 따라 지정된 기간
- ⑥ (특허출원하였을 때 특허를 받을 수 있을 것의 판단) 제4항을 적용할 때 제133조제1항에 따른 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

**제137조 【정정의 무효심판】** **法 133, 134**

- ① **(주체적 및 객체적 요건)** 이해관계인 또는 심사관은 제132조의3제1항[특허추소신청에서의 정정], 제133조의2제1항[특허무효심판에서의 정정], 제136조제1항[정정심판에서의 정정] 또는 이 조 제3항[정정무효심판에서의 정정]에 따른 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정이 다음 각 호의 어느 하나의 규정을 위반한 경우에는 정정의 무효심판을 청구할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
1. 제136조제1항 각 호의 어느 하나의 규정
  2. 제136조제3항부터 제5항까지의 규정(제132조의3제3항 또는 제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)
- ② **(시기적 요건 및 통지)** 제1항에 따른 심판청구에 관하여는 제133조제2항 및 제4항을 준용한다.
- ③ **(특허의 정정청구: 요건)** 제1항에 따른 무효심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조 제1항[답변서 제출기간] 또는 제159조제1항 후단[의견서 제출기간]에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. <개정 2016.2.29.> **法 132의3, 133의2 / 136**
- ④ **(특허의 정정청구: 준용규정)** 제3항에 따른 정정청구에 관하여는 제133조의2제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 제133조의2제3항 중 "제133조제1항"은 "**제137조제1항**"으로 보고, 같은 조 제4항 후단 중 "제133조의2제1항"을 "**제137조제3항**"으로 보며, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제1호 중 "제1항"을 각각 "**제3항**"으로 본다. <개정 2016.2.29.> **法 132의3, 133의2 / 136**
- ⑤ **(효과)** 제1항에 따라 정정을 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다.
- [전문개정 2014.6.11.]

## II 특허의 정정청구(法 132의3, 133의2, 137③④)

| 제 도 |             | 특허취소신청                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 특허무효심판                                                                                                                                  | 정정무효심판 |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 서   | 의 의         | 특허의 정정이란 특허권자가 특허취소신청, 특허무효심판 또는 정정무효심판이 특허심판원에 계속 중에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구하는 것을 말한다.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |        |
|     | 취 지         | 명세서 또는 도면을 정정할 수 있게 하여 특허취소신청, 특허무효심판, 정정무효심판에 대한 방어적 기회를 줌                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |        |
| 요건  | 주체적         | 1. 특허권자만이 할 수 있으며, 특허권이 공유인 경우 공유자 모두가 하여야 함<br>2. 전용실시권자, 직무발명 통상실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 질권자의 동의 要(다만, 특허권자가 정정청구를 하려면 동의를 받아야 하는 자가 특허취소신청, 무효심판을 청구한 경우는 제외)                                                                                                                               |                                                                                                                                         |        |
|     | 객체적         | 1. 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 및 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나<br>2. 특허발명의 명세서·도면의 범위 이내이어야 하며, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위일 것<br>3. 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위의 실질적 확장·변경×<br>4. 청구범위의 감축이나 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 정정 후의 청구범위 기재사항이 특허출원을 하였을 때 특허를 받을 수 있을 것 |                                                                                                                                         |        |
|     |             | 단, 특허취소신청, 특허무효심판에 대한 정정청구에 있어서 특허취소신청, 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 4번 판단×                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | -      |
|     | 시기적         | 취소결정하려고 취소이유를 통지하고 준 의견서 제출기간                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. 답변서 제출기간<br>2. 답변서 제출기간 후에도 청구인이 증거서류를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정되는 경우에 심판장이 정한 기간<br>3. 무효심판의 직권심리에 의한 의견서 제출기간 |        |
|     |             | 해당 특허취소신청절차, 특허무효심판절차, 정정무효심판절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |        |
| 절차  | 제출          | 1. 정정청구서를 제출<br>2. 정정을 청구하는 때에는 정정청구서에 정정한 명세서 또는 도면과 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 대한 통상실시권자 및 질권자의 동가 필요한 경우(다만, 특허권자가 정정청구를 하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 특허취소신청, 특허무효심판, 정정무효심판을 청구한 경우에는 제외)에는 그 동의를 증명하는 서류를 첨부                                                                                |                                                                                                                                         |        |
|     | 부분송달        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 심판장은 특허무효심판, 정정무효심판 절차 중에 특허권자의 정정청구가 있을 때에는 그 부분을 심판청구인에게 송달                                                                           |        |
|     | 정정명세서 등의 보정 | 정정청구를 할 수 있는 기간 또는 정정청구의 직권심리에 의한 의견서 제출기간에 정정명세서 등을 다시 보정가능                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |        |
|     | 취하          | i) 정정청구를 할 수 있는 기간과 그 기간의 만료일로부터 1개월 이내의 기간과 ii) 정정청구의 직권심리에 의한 의견서 제출기간 중 어느 하나에 해당하는 기간                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |        |
| 효과  | 원칙          | 정정한 명세서 또는 도면에 의하여 특허취소신청, 심판청구에 대한 심리를 진행하게 되며, 최종적으로 결정문, 심결문의 주문 및 이유란에 기재                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |        |
|     | 소급효         | 1. 정정된 내용으로 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권이 설정등록된 것으로 간주<br>2. 정정만이 따로 확정되지 않고 특허취소신청의 결정 또는 무효심판의 심결이 확정된 때 함께 확정                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |        |
|     | 특허공보 게재     | 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 한다는 심결이 있는 경우 특허심판원장은 그 내용을 지식재산처장에게 알려야 하며 지식재산처장은 통보가 있으면 이를 특허공보에 게재                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |        |
|     | 부칙          | 별도의 각하결정없이 결정, 심결의 「이유란」에 특허의 정정 불채택이유 기재                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |        |
|     | 간과          | 정정무효사유에 해당                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |        |
| 불복  | 독립하여 불복×    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |        |

### III 특허의 정정과 정정심판의 비교

| 제 도 |             | 특허의 정정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | 정정심판                                                                                                                                                                                                                                                              |            |      |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 의 의 |             | 특허의 정정이란 특허권자가 특허취소신청, 특허무효심판 또는 정정무효심판이 특허심판원에 계속 중에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구하는 것을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | 정정심판이란 특허권자가 특허권이 설정등록된 후에 특허발명의 명세서 또는 도면의 내용을 정정하는 심판을 말한다.                                                                                                                                                                                                     |            |      |
| 요 건 | 주체적         | 1. 특허권자만이 할 수 있으며, 특허권이 공유인 경우 공유자 모두가 하여야 함<br>2. 전용실시권자, 직무발명 통상실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 질권자의 동의 필요(다만, 특허권자가 정정청구를 하려면 동의를 받아야 하는 자가 특허취소신청, 무효심판을 청구한 경우는 제외)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |
|     | 객체적         | 1. 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 및 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나<br>2. 특허발명의 명세서·도면의 범위 이내이어야 하며, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위일 것<br>3. 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위의 실질적 확장·변경×<br>4. 청구범위의 감축이나 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 정정 후의 청구범위 기재사항이 특허출원을 하였을 때 특허를 받을 수 있을 것(단, 특허취소신청, 특허무효심판에 대한 정정청구에 있어서 특허취소신청, 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 판단×) |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |
|     | 시기적         | 1. 답변서 제출기간(답변서 제출기간 후에도 청구인이 증거서류를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정되는 경우에 심판장이 정한 기간)<br>2. 직권심리에 대한 의견서 제출기간(특허취소신청의 경우는 취소결정하려고 취소이유통지하고 의견서 제출기간을 준 경우 이 기간에만)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 1. 원 칙<br>특허권 소멸 후에도 가능<br>2. 예 외<br>① 특허가 취소되거나 무효(단, 후발적 사유는 제외)된 경우<br>② 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간(다만, 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지 정정심판을 청구가능)<br>③ 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간 |            |      |
| 절차  | 부분송달        | 무효심판절차에서 청구인에게 송달(취소신청은 제외)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |
|     | 정정명세서 등의 보정 | 정정청구를 할 수 있는 기간 또는 정정청구의 직권심리에 의한 의견서 제출기간에 보정가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 심리종결통지 전에 정정명세서 등을 다시 보정가능                                                                                                                                                                                                                                        |            |      |
|     | 취하          | i) 정정청구를 할 수 있는 기간(法 132의3①, 133의2①, 137③)과 그 기간의 만료일로부터 1개월 이내의 기간, ii) 정정청구의 직권심리에 의한 의견서 제출기간 중 어느 하나에 해당하는 기간                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 심결확정전                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      |
| 효 과 | 적법          | 원 칙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 정정한 명세서 또는 도면에 의하여 특허취소신청, 심판청구에 대한 심리를 진행하게 되며, 최종적으로 결정문, 심결문의 주문 및 이유란에 기재                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 인용심결       |      |
|     |             | 소급효                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 정정된 내용으로 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권이 설정등록된 것으로 간주                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |
|     |             | 특허공보 게재                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 특허의 정정 또는 적법한 정정심판에 대해서는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 한다는 심결이 있는 경우 특허심판원장은 그 내용을 지식재산처장에게 알려야 하며 지식재산처장은 통보가 있으면 이를 특허공보에 게재 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |
|     | 부적법         | 기 간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 불수리                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 심판청구를 심결각하 |      |
|     |             | 범 위                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 원칙                                                                                                                       | 별도의 각하결정없이 결정, 심결의 「이유란」에 특허의 정정 불채택이유 기재                                                                                                                                                                                                                         |            | 기각심결 |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 간과                                                                                                                       | 정정무효사유에 해당                                                                                                                                                                                                                                                        |            |      |
|     | 불 복         | 독립하여 불복×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | 특허법원에 기각심결에 대하여 불복                                                                                                                                                                                                                                                |            |      |

Ⅳ 특허출원을 하였을 때 특허를 받을 수 있을 것의 판단

| 사실관계                                                                                                            | 설 명                                                                                                                                                                                                            | 비 고                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <pre> graph TD     A[특허무효심판청구] --&gt; B[정정청구]     B --&gt; C[정정적법성 판단]     C --&gt; D[무효사유 판단]           </pre> | 【청구항 1】과 【청구항 2】에 대한 특허무효심판청구                                                                                                                                                                                  |                                                              |
|                                                                                                                 | 【청구항 1】과 【청구항 3】에 대한 정정청구                                                                                                                                                                                      | 특허무효심판을 청구하지 아니한 【청구항 3】에 대해서도 정정가능                          |
|                                                                                                                 | 【청구항 3】에 대해서는 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있을 것을 판단하여야 하지만, 【청구항 1】에 대해서는 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있을 것을 판단하지 아니함                                                                                                        | 【청구항 1】에 대해서 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있을 것을 판단하는 경우 무효사유판단과 중복됨 |
|                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 정정이 적법하면 정정 후 명세서 또는 도면에 의하여, 정정이 부적법하면 정정 전 명세서 또는 도면에 의하여 특허무효사유를 판단</li> <li>■ 신청한 취지인 【청구항 1】과 【청구항 2】에 대해서만 특허무효사유를 판단할 수 있으며, 【청구항 3】에 대해서는 판단할 수 없음</li> </ul> |                                                              |





## 재심(法 178~185)

### I 법조문

#### 제178조 【재심의 청구】

- ① **(재심대상)** 당사자는 확정된 특허취소결정 또는 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다.  
<개정 2016.2.29.>
- ② **(재심사유 및 관할)** 제1항의 재심청구에 관하여는 「민사소송법」 제451조 및 제453조를 준용한다.  
[전문개정 2014.6.11.]

#### 민사소송법 제451조 및 제453조

##### 제451조(재심사유)

- ① 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하면 확정된 중국판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있다. 다만, 당사자가 상소에 의하여 그 사유를 주장하였거나, 이를 알고도 주장하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다.
  1. 법률에 따라 판결법원을 구성하지 아니한 때
  2. 법률상 그 재판에 관여할 수 없는 법관이 관여한 때
  3. 법정대리권·소송대리권 또는 대리인의 소송행위를 하는 데에 필요한 권한의 수여에 흠이 있는 때. 다만, 제60조 또는 제97조의 규정에 따라 승인한 때에는 그러하지 아니하다.
  4. 재판에 관여한 법관이 그 사건에 관하여 직무에 관한 죄를 범한 때
  5. 형사상 처벌을 받은 다른 사람의 행위로 말미암아 자백을 하였거나 판결에 영향을 미칠 공격 또는 방어방법의 제출에 방해를 받은 때
  6. 판결의 증거가 된 문서, 그 밖의 물건이 위조되거나 변조된 것인 때
  7. 증인·감정인·통역인의 거짓 진술 또는 당사자신문에 따른 당사자나 법정대리인의 거짓 진술이 판결의 증거가 된 때
  8. 판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결, 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀐 때
  9. 판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락한 때
  10. 재심을 제기할 판결이 전에 선고한 확정판결에 어긋나는 때
  11. 당사자가 상대방의 주소 또는 거소를 알고 있었음에도 있는 곳을 잘 모른다고 하거나 주소나 거소를 거짓으로 하여 소를 제기한 때
- ② 제1항제4호 내지 제7호의 경우에는 처벌받을 행위에 대하여 유죄의 판결이나 과태료부과의 재판이 확정된 때 또는 증거부족 외의 이유로 유죄의 확정판결이나 과태료부과의 확정재판을 할 수 없을 때에만 재심의 소를 제기할 수 있다.
- ③ 항소심에서 사건에 대하여 본안판결을 하였을 때에는 제1심 판결에 대하여 재심의 소를 제기하지 못한다.

##### 제453조(재심관할법원)

- ① 재심은 재심을 제기할 판결을 한 법원의 전속관할로 한다.
- ② 심급을 달리하는 법원이 같은 사건에 대하여 내린 판결에 대한 재심의 소는 상급법원이 관할한다. 다만, 항소심판결과 상고심판결에 각각 독립된 재심사유가 있는 때에는 그러하지 아니하다.

#### 제179조 【제3자에 의한 재심청구】

- ① **(사해심결: 재심청구인)** 심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리나 이익을 사해(詐害)할 목적으로 심결을 하게 하였을 때에는 제3자는 그 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다.
- ② **(사해심결: 재심피청구인)** 제1항의 재심청구의 경우에는 심판의 당사자를 공동피청구인으로 한다.  
[전문개정 2014.6.11.]

#### 제180조 【재심청구의 기간】

- ① **(원칙)** 당사자는 특허취소결정 또는 심결 확정 후 재심사유를 안 날부터 30일 이내에 재심을 청구하여야 한다.  
<개정 2016.2.29.> **法 17**
- ② **(예외: 대리권 흠)** 대리권의 흠을 이유로 재심을 청구하는 경우에 제1항의 기간은 청구인 또는 법정대리인이 특허취소결정등본 또는 심결등본의 송달에 의하여 특허취소결정 또는 심결이 있는 것을 안 날의 다음 날부터 기산한다. <개정 2016.2.29.>
- ③ **(원칙)** 특허취소결정 또는 심결 확정 후 3년이 지나면 재심을 청구할 수 없다. <개정 2016.2.29.>
- ④ **(예외: 심결확정 후 사유발생)** 재심사유가 특허취소결정 또는 심결 확정 후에 생겼을 때에는 제3항의 기간은 그 사유가 발생한 날의 다음 날부터 기산한다. <개정 2016.2.29.>
- ⑤ **(예외: 저촉)** 제1항 및 제3항은 해당 심결 이전의 확정심결에 저촉된다는 이유로 재심을 청구하는 경우에는 적용하지 아니한다.  
[전문개정 2014.6.11.]

**제181조 【재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한】(★★) 法 182**

- ① **(선의의 물건)** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 수출 또는 수입하거나 국내에서 생산 또는 취득한 물건에는 미치지 아니한다. <개정 2016. 2. 29., 2025. 1. 21.>
1. 무효가 된 특허권(존속기간이 연장등록된 특허권을 포함한다)이 재심에 의하여 회복된 경우
  2. 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우
  3. 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우
  4. 취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우
- ② **(선의의 실시행위 및 간접침해행위)** 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 특허권의 효력은 다음 각 호의 어느 하나의 행위에 미치지 아니한다. <개정 2016.2.29.>
1. 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 한 해당 발명의 선의의 실시
  2. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
  3. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여를 청약하는 행위

[전문개정 2014.6.11.]

**제182조 【재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권】(★★) 法 181 / 118②③**

제181조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 실시하고 있거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 통상실시권을 가진다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

**제183조 【재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권】(★★) 法 98, 138 / 118②③**

- ① **(성립요건 및 효력)** 제138조제1항 또는 제3항에 따라 통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후 재심에서 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우에는 재심청구 등록 전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 원(原)통상실시권의 사업목적 및 발명의 범위에서 그 특허권 또는 재심의 심결이 확정된 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.
- ② **(대가)** 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

**제184조 【재심에서의 심판규정 등의 준용】**

특허취소결정 또는 심판에 대한 재심의 절차에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 특허취소신청 또는 심판의 절차에 관한 규정을 준용한다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

[제목개정 2016.2.29.]

**제185조 【「민사소송법」의 준용】**

재심청구에 관하여는 「민사소송법」 제459조제1항을 준용한다. [전문개정 2014.6.11.]

**민사소송법 제459조제1항**

제459조(변론과 재판의 범위)

- ① 본안의 변론과 재판은 재심청구이유의 범위안에서 하여야 한다.

## II 재심에 대한 조문정리

| 구 분        |        | 내 용                                                                           |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 의의         |        | 1. 확정된 특허취소결정 또는 심결에 대한 비상의 불복방법(法 178①)<br>2. 원특허취소결정 또는 심결의 취소와 재심판을 구함     |
| 취지         |        | 법적 안정성의 바탕 위에 구체적 타당성(재심)의 확보                                                 |
| 요건         | 관할     | 특허심판원(法 178② 준용 民訴法 453)                                                      |
|            | 재심사유   | 1. 일반재심사유(法 178② 준용 民訴法 451)<br>2. 사해심결에 대한 재심사유(法 179)                       |
|            | 재심청구기간 | 1. 원칙 - 法 180①③<br>2. 예외 - 法 180②④⑤                                           |
| 절차 및<br>효과 | 공통점    |                                                                               |
|            | 차이점    | 절차                                                                            |
|            |        | 효과                                                                            |
|            |        | 원심판절차 준용(法 184)                                                               |
|            |        | 1. 심리순서 - 방식심리, 적법성 심리, 재심사유의 존부확인, 본안심리<br>2. 재심사유의 존부확인 - 재심청구이유에 한함(法 185) |
|            |        | 원심판 효과 이외에 plus 효과 발생<br>- 法 181, 182<br>- 法 183                              |

### III 재심(法 178~185)

| 제 도 |        | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서   | 의의     | 확정된 특허취소결정 또는 확정된 심결에 재심사유에 해당하는 중대한 하자가 있는 경우 특허취소결정이나 그 심결의 취소와 그 사건의 재심판을 구하는 비상의 불복신청방법을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 취지     | 법적 안정성과 구체적 타당성의 확보라는 상반하는 요청을 조화                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 요건  | 주체적    | 일반<br>1. 특허취소결정 또는 심결의 확정에 의하여 불이익을 받는 자가 청구인이 된다. 따라서 특허취소신청에 대한 특허취소결정에 있어서는 특허권자가 재심청구인이 되고, 결정계 심판의 심결에 대한 재심에 있어서는 심판청구인이 재심청구인이 된다. 한편, 당사자에게 심판의 심결에 대한 재심을 청구할 때는 각각심결이 확정된 경우에는 심판청구인이 재심청구인, 심판피청구인이 재심피청구인이 되고, 인용심결이 확정된 경우에는 심판피청구인이 재심청구인, 심판청구인이 재심피청구인이 된다.<br>2. 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 이름으로 재심의 청구인 및 피청구인이 될 수 있다(法 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |        | 사해심결<br>확정심결에 의하여 권리나 이익의 침해를 받는 제3자가 청구인이 되며, 심판의 당사자가 공동피청구인이 된다(法 179①②).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 객체적    | 대상<br>1. 일반재심사유(法 178 준용 民訴法 451①)<br>① 법 제146조 제1항 및 제171조에 규정한 심판의 합의체를 구성하지 아니한 때<br>② 특허법상 그 심결에 관여할 수 없는 심판관이 관여한 때<br>③ 대리인이 출원·심사·심판절차에서의 대리행위를 하는 데에 필요한 권한의 수여에 흠이 있는 때<br>④ 심판에 관여한 심판관이 그 사건에 관하여 직무에 관한 죄를 범한 때<br>⑤ 형사상 처벌을 받을 다른 사람의 행위로 말미암아 자백을 하였거나 심결에 영향을 미칠 공격 또는 방어방법의 제출에 방해로 받은 때<br>⑥ 심결의 증거가 된 문서나 그 밖의 물건이 위조 또는 변조된 것인 때<br>⑦ 증인·감정인·통역인의 거짓 진술 또는 당사자신문에 따른 당사자나 법정대리인의 거짓 진술이 심결의 증거가 된 때<br>⑧ 심결의 기초로 된 민사 또는 형사의 판결이나 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판 또는 행정처분에 따라 바뀐 때<br>⑨ 심결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락한 때<br>⑩ 재심을 청구할 심결이 전의 확정심결과 저촉되는 때<br>⑪ 당사자가 상대방의 주소 또는 거소를 알고 있었음에도 있는 곳을 잘 모른다고 하거나 주소나 거소를 거짓으로 하여 소를 제기한 때<br>2. 사해심결에 대한 재심사유<br>심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리나 이익을 사해할 목적으로 심결을 하게 하였을 때에는 제3자는 그 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다(法 179①). |
|     |        | 범위<br>재심청구의 대상은 확정된 중국심결이다. 그러므로 미확정심결은 재심의 대상이 될 수 없다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 시기적    | 원칙<br>1. 당사자는 재심의 사유를 안 날부터 30일 이내 및 특허취소결정 또는 심결 확정 후 3년 이내에 재심을 청구해야 한다(法 180①③).<br>2. 청구인이 책임질 수 없는 사유로 인하여 30일의 재심의 청구기간을 준수할 수 없을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 지키지 못한 절차를 추후보완할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 경과한 때에는 그러하지 아니하다(法 17).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |        | 예외<br>1. 대리권 흠의 경우<br>재심청구인은 대리권의 흠을 이유로 하여 재심을 청구하는 경우에 안 날로부터 30일은 청구인 또는 법정대리인이 특허취소결정등본 또는 심결등본의 송달에 의하여 특허취소결정 또는 심결이 있는 것을 안 날의 다음 날부터 기산한다(法 180②).<br>2. 재심사유가 심결확정후 생긴 경우<br>재심사유가 특허취소결정 또는 심결 확정 후에 생겼을 때에는 특허취소결정 또는 심결 확정 후 3년은 그 사유가 발생한 날의 다음 날부터 기산한다(法 180④).<br>3. 이전의 확정심결과 저촉되는 경우<br>해당 심결 이전의 확정심결과 저촉한다는 이유로 재심을 청구하는 경우에는 기간의 제한이 없다(法 180⑤).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 청구  | 관할     | 재심은 재심을 청구할 특허취소결정 또는 심결을 한 특허심판원의 전속관할이므로 재심을 청구하려는 자는 재심청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다(法 178②). 다만, 재심사유가 특허법원 단계에서 발생한 경우나 대법원 단계에서 발생하였다면 각 단계의 법원에 재심사청구서를 제출하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 청구서 제출 | 수수료를 납부하고 법정사항을 기재한 재심청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 한편, 재심청구서에서 주장한 재심사유는 후에 변경할 수 없는 것으로 해석된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 심리      | 서설          | 재심의 본안심리의 대상은 확정된 특허취소결정 또는 심결의 취소와 본안사건에 대하여 이에 갈음한 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 할 것인지 여부이다. 재심에 대한 심리는 재심청구 이유의 범위내에서 하여야 한다(法 185 준용 民訴法 459①).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 재심사유의 존부 확인 | 재심의 청구가 적법하면 재심사유의 존부를 조사하여야 한다. 그 결과 재심사유가 없는 것으로 인정되면 재심청구를 기각하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 본안심리        | 재심사유가 있는 것으로 인정되면 원특허취소결정 또는 심결을 취소하고 본안에 대한 심리에 들어가게 된다. 특허취소결정 또는 심판에 대한 재심의 절차에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 특허취소신청 또는 심판의 절차에 관한 규정을 준용한다(法 184). 예를 들어 특허무효심판에 대한 재심에 있어서는 특허무효심판과 같은 심리를 하고 거절결정불복심판에 대한 재심에 있어서는 거절결정불복심판과 같은 심리를 하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 심결 / 결정 | 내용          | 확정된 원특허취소결정 또는 심결을 유지할 수 없을 때에는 특허취소신청에 대한 기각결정 또는 새로운 심결을 하여야 하고, 유지할 수 있을 때에는 원특허취소결정 또는 심결과 같은 내용의 결정 또는 심결을 하여야 한다. 즉, 재심사유가 존재하는 경우에는 원특허취소결정 또는 심결의 결과가 정당하더라도 바로 재심청구를 기각하는 취지의 결정 또는 심결을 하여서는 아니 된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 불복          | 심판장으로부터 특허취소결정 또는 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 취소소송을 제기할 수 있다(法 186①).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 확정 효과   | 일반          | 재심의 결정 또는 심결이 확정되면 원특허취소신청 또는 심판에 있어서 결정 또는 심결이 확정되는 경우에 인정되는 기속력과 형식적 확정력, 실질적 확정력(일사부재리의 원칙(취소신청은 제외))이 동일하게 적용된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | 특유          | <p>1. 재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한</p> <p>i) 무효가 된 특허권(존속기간이 연장등록된 특허권을 포함한다)이 재심에 의하여 회복된 경우, ii) 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우, iii) 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우 및 iv) 취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 해당 특허취소결정 또는 이 확정된 후 재심청구 등록 전에 i) 선의로 수입 또는 국내에서 생산하거나 취득한 물건, ii) 선의의 실시행위 및 iii) 선의의 간접침해행위 중 어느 하나에 대해서는 미치지 아니한다(法 181).</p> <p>2. 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권</p> <p>법 제181조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 실시하고 있거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 무상의 통상실시권을 가진다(法 182). 이 통상실시권은 법정실시권이므로 등록을 하지 않더라도 효력이 발생한다.</p> <p>3. 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권</p> <p>통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이에 상반되는 심결의 확정이 있는 경우에는 재심청구 등록전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 원통상실시권의 사업의 목적 및 발명의 범위안에서 그 특허권 또는 재심의 심결의 확정이 있는 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 통상실시권은 법정실시권이므로 등록이 없어도 효력이 발생하지만, 통상실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 183).</p> |





도해특허법

제7장  
특허소송

제8장  
국제출원

제9장  
실용신안법

74 심결취소소송(협회의 특허소송)(法 186~189)

75 보상금 또는 대가에 대한 불복의 소(法 190, 191)

76 변리사의 보수와 소송비용(法 191의2)



## 심결취소소송(협의의 특허소송)(法 186~189)

### I 법조문

#### 제186조 【심결 등에 대한 소】

- ① **〔관할: 전속관할〕** 특허취소결정 또는 심결에 대한 소 및 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다. <개정 2016.2.29.> **法 132의6②, 132의13⑤**
- ② **〔원고〕** 제1항에 따른 소는 다음 각 호의 자만 제기할 수 있다. <개정 2016.2.29.> **法 187 / 162⑥**
  1. 당사자
  2. 참가인
  3. 해당 특허취소신청의 심리, 심판 또는 재심에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자
- ③ **〔제소기간: 일반〕** 제1항에 따른 소는 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다. **法 15①**
- ④ **〔제소기간: 불변기간〕** 제3항의 기간은 불변기간으로 한다.
- ⑤ **〔제소기간: 부가기간〕** 심판장은 주소 또는 거소가 멀리 떨어진 곳에 있거나 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 제4항의 불변기간에 대하여 부가기간을 정할 수 있다.
- ⑥ **〔관할: 심판전치주의〕** 특허취소를 신청할 수 있는 사항 또는 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 특허취소결정이나 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다. <개정 2016.2.29.> **法 224의2②**
- ⑦ **〔관할: 대가/심판비용에 대하여 특허법원에 독립하여 불복 不可〕** 제162조제2항제5호에 따른 대가의 심결 및 제165조제1항에 따른 심판비용의 심결 또는 결정에 대해서는 독립하여 제1항에 따른 소를 제기할 수 없다. **法 190, 191**
- ⑧ **〔관할: 상고〕** 제1항에 따른 특허법원의 판결에 대해서는 대법원에 상고할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제187조 【피고적격】 **法 186②**

제186조제1항에 따라 소를 제기하는 경우에는 지식재산처장을 피고로 하여야 한다. 다만, 제133조제1항[특허무효심판], 제134조제1항·제2항[존속기간연장등록무효심판], 제135조제1항·제2항[권리범위확인심판], 제137조제1항[정정무효심판] 또는 제138조제1항·제3항[통상실시권허락심판]에 따른 심판 또는 그 재심의 심결에 대한 소를 제기하는 경우에는 그 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다. <개정 2016.2.29.> **法 188의2**

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제188조 【소 제기 통지 및 재판서 정본 송부】

- ① **〔소의 제기 통지〕** 법원은 제186조제1항에 따른 소 또는 같은 조 제8항에 따른 상고가 제기되었을 때에는 지체 없이 그 취지를 특허심판원장에게 통지하여야 한다.
- ② **〔소송절차 완결의 통지〕** 법원은 제187조 단서에 따른 소에 관하여 소송절차가 완결되었을 때에는 지체 없이 그 사건에 대한 각 심급(審級)의 재판서 정본을 특허심판원장에게 보내야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제188조의2 【기술심리관의 제척·기피·회피】 **法 154의2⑥**

- ① **〔준용규정〕** 「법원조직법」 제54조의2에 따른 기술심리관의 제척·기피에 관하여는 제148조[심판관의 제척], 「민사소송법」 제42조부터 제45조까지, 제47조 및 제48조를 준용한다.

#### 민사소송법 제42조-제45조, 제47조 및 제48조

##### 제42조(제척의 재판)

법원은 제척의 이유가 있는 때에는 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 제척의 재판을 한다.

##### 제43조(당사자의 기피권)

- ① 당사자는 법관에게 공정한 재판을 기대하기 어려운 사정이 있는 때에는 기피신청을 할 수 있다.

- ② 당사자가 법관을 기피할 이유가 있다는 것을 알면서도 본안에 관하여 변론하거나 변론준비기일에서 진술을 한 경우에는 기피신청을 하지 못한다.

#### 제44조(제척과 기피신청의 방식)

- ① 합의부의 법관에 대한 제척 또는 기피는 그 합의부에, 수명법관(受命法官)·수탁판사(受託判事) 또는 단독판사에 대한 제척 또는 기피는 그 법관에게 이유를 밝혀 신청하여야 한다.
- ② 제척 또는 기피하는 이유와 소명방법은 신청한 날부터 3일 이내에 서면으로 제출하여야 한다.

#### 제45조(제척 또는 기피신청의 각하 등)

- ① 제척 또는 기피신청이 제44조의 규정에 어긋나거나 소송의 지연을 목적으로 하는 것이 분명한 경우에는 신청을 받은 법원 또는 법관은 결정으로 이를 각하(却下)한다.
- ② 제척 또는 기피를 당한 법관은 제1항의 경우를 제외하고는 바로 제척 또는 기피신청에 대한 의견서를 제출하여야 한다.

#### 제47조(불복신청)

- ① 제척 또는 기피신청에 정당한 이유가 있다는 결정에 대하여는 불복할 수 없다.
- ② 제45조제1항의 각하결정(却下決定) 또는 제척이나 기피신청이 이유 없다는 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다.
- ③ 제45조제1항의 각하결정에 대한 즉시항고는 집행정지의 효력을 가지지 아니한다.

#### 제48조(소송절차의 정지)

법원은 제척 또는 기피신청이 있는 경우에는 그 재판이 확정될 때까지 소송절차를 정지하여야 한다. 다만, 제척 또는 기피신청이 각하된 경우 또는 종국판결(終局判決)을 선고하거나 긴급을 요하는 행위를 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ② **(제척 및 기피 재판)** 제1항에 따른 기술심리관에 대한 제척·기피의 재판은 그 소속 법원이 결정으로 하여야 한다.
- ③ **(회피)** 기술심리관은 제척 또는 기피의 사유가 있다고 인정하면 특허법원장의 허가를 받아 회피할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제189조 【심결 또는 결정의 취소】 **法 176**

- ① **(인용판결: 해당 심결/결정 취소)** 법원은 제186조제1항에 따라 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 판결로써 해당 심결 또는 결정을 취소하여야 한다.
- ② **(인용판결: 필요적 환송)** 심판관은 제1항에 따라 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.
- ③ **(심판관의 기속)** 제1항에 따른 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.

[전문개정 2014.6.11.]

## II 특허소송(심결취소소송)

| 제 도 |           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서   | 의의        | 특허심판원의 특허취소결정, 심결 또는 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서의 각하결정에 불복하여 특허법원에 그 취소를 구하는 소송을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 법적성질      | 1. 행정소송의 일종으로 보는 것이 통설·판례(2000후1306)<br>2. 특허소송에 대하여는 ① 우선 특허법이 적용되고 ② 특허법에 규정이 없는 사항의 경우에는 행정소송법이 준용되고, ③ 행정소송법에 특별한 규정이 없는 경우에는 행정소송법 제8조의 규정에 따라 민사소송법이 준용.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 특허심판과의 관계 | 1. 심판전치주의 - 특허취소를 신청할 수 있는 사항 또는 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 특허취소결정이나 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다(法 186⑥).<br>2. 절차의 중지 - 법원은 소송절차에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허출원에 대한 특허여부결정, 특허취소신청에 대한 결정이나 특허에 관한 심결의 확정이 있을 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다(法 78②, 164②).<br>3. 심판 및 소송기록의 송부 - 심급관계가 없으므로 심판원과 별도로 특허법원에 자료를 다시 제출                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 요건  | 주체        | 원고<br>당사자, 참가인 또는 해당 특허취소신청의 심리, 심판 또는 재심에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자에 한하여 청구할 수 있다(法 186②).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |           | 피고<br>특허취소결정, 결정계 심판의 심결 및 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서 각하결정에 대한 소를 제기하는 경우에는 지식재산청장을 피고로 하여야 한다. 한편, 당사자에게 심판의 심결 또는 그 재심의 심결에 대한 소를 제기하는 경우에는 그 심판의 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다(法 187).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |           | 대리인<br>소송대리인에 의할 경우 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 소송대리인은 변호사 또는 변리사가 될 수 있다(辨理士法 8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 객체        | 소송물<br>해당 심판 실체상의 위법과, 절차상의 위법, 판단누락의 유무 등 행정처분의 위법성 일반이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |           | 소의 이익<br>1. 의의<br>당사자가 소송을 이용할 정당한 이익 또는 필요성을 말하는 것으로 중요한 소송요건이다. 심결취소소송 역시 소의 이익이 있어야 하고, 소의 이익이 없다면 그 소송은 부적합한 것으로 소각하 판결을 받게 된다. 일반적으로 원고의 소의 이익이 긍정되나, i) 다른 사정으로 심결 자체가 이제는 무의미하게 되거나 ii) 심결을 취소하더라도 이제는 유리한 심결을 받을 가능성이 없게 된 경우 등은 소의 이익이 부정된다.<br>2. 판단<br>소의 이익의 유무는 변론종결 시를 기준으로 판단한다. 다만, 상고심 계속중에 소의 이익 등 소송요건이 흠결되는 경우에는 그러한 사정도 고려하여 소의 이익이 없다고 보는 것이 대법원 판례의 일반적인 경향이다(98후1921).<br>3. 침해소송과 권리범위확인심판의 관계<br>① 소극적 권리범위확인심판의 기각심결이 내려진 후, 침해와 관련된 민사소송에서 이 심결을 고려하여 원고의 승소판결이 선고되고, 이 사건의 심결취소소송의 상고심 계속 중에 민사판결이 그대로 확정된 경우 심결을 취소할 이익, 즉 소의 이익이 있는지 여부와 관련하여서는, i) 여전히 원고에게 불리한 이 사건 심결이 유효하게 존속하고 있는 점, ii) 확정된 위 민사판결은 이 사건 심결취소소송을 담당하는 법원에 대하여 법적 기속력이 없으므로 원고는 위 민사판결이 확정되었음에도 불구하고 자신에게 불리한 이 사건 심결을 취소할 법률상 이익이 있고, 달리 이 사건 심결 이후 이 사건 등록상표의 상표권이 소멸되었다거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸되었다는 등 이 사건 심결 이후 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다는 사정도 보이지 아니하는 점 등에 비추어 긍정함이 타당하다(2008후4486).<br>② 침해소송이 제기된 후에 소극적 권리범위확인심판을 청구한 경우 심판에 대한 확인의 이익이 있는지 여부와 관련하여서는, i) 권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송(이하 ‘침해소송’이라고 한다)과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만(대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결의 다수의견에 대한 보충의견 등 참조), 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가지고 있다는 점, ii) 특허법 제164조 제1항은 심판장이 소송절차가 완결될 때까지 심판절차를 중지할 수 있다고 규정하고, 제2항은 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있다고 규정하며, 제3항은 법원은 침해소송이 제기되거나 종료되었을 때에 그 취지를 특허심판원장에게 통보하도록 규정하고, 제4항은 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여 |

|    |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |             | 야 한다고 규정하고 있는 점 등을 고려할 때, 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다(2016후328).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 관할          |             | 1. 심급관할 - 심판원 → 특허법원(제1심) → 대법원(제2심)<br>2. 전속관할<br>① 특허취소결정 또는 심결에 대한 소 및 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다(法 186①). 통상실사권 허락의 심결에서 정한 대가의 심결 및 심판비용의 심결 또는 결정에 대하여는 독립하여 특허법원에 의한 소를 제기할 수 없다(法 186⑦).<br>② 한편, 2016년 1월 1일부터는 지식재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권) 침해소송의 민사본안관할을 1심은 고등법원 소재지가 있는 6개 지방법원(서울중앙지방법원, 대구지방법원, 대전지방법원, 광주지방법원, 부산지방법원, 수원지방법원)이 전속적으로 맡고, 2심은 특허법원으로 집중하게 되도록 민사소송법 및 법원조직법이 개정되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 시기          |             | 특허법원에 소를 제기하려는 자는 심결 또는 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 소장을 특허법원에 제출하여야 한다(法 186③). 이 기간은 불변기간이지만 심판장은 심결 또는 결정등본을 송달할 때 주소 또는 거소가 멀리 떨어진 곳에 있거나 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 30일 이내 범위에서 부가기간을 정할 수 있다(法 186④⑤).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 제기 | 소의 제기       |             | 당사자가 소장을 특허법원에 제출하여 소를 제기함으로써 심결취소소송이 개시된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 특허심판원장에게 통지 |             | 법원은 심결취소소송 또는 상고가 제기되었을 때에는 지체 없이 그 취지를 특허심판원장에게 통지하여야 한다(法 188①). 또한, 당사자에게 심판의 불복에 대한 소에 관하여 소송절차가 완결된 때에는 지체없이 그 사건에 대한 각 심급의 재판서 정본을 특허심판원장에게 송부하여야 한다(法 188②).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 심리 | 소장의 심사      |             | 소장의 필요적 기재사항을 심사하여 흠결이 있는 때에는 보정을 명하고, 보정기간내에 그 흠결을 보정하지 아니한 경우에는 재판장은 명령으로 그 소장을 각하하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 소송요건 심리     |             | 해당 소가 소송요건을 갖춘 적법한 것인지를 심리하는 것을 말한다. 심리의 결과, 특허소송의 제기요건을 갖추지 못한 것이라고 인정되는 때에는 판결로서 각하한다. 소송요건은 법원의 직권조사사항이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 본안심리        | 변론주의 원칙     | 1. 일반 민사소송과 마찬가지로 공개심리주의, 쌍방심리주의, 구술심리주의에 의하여 판결의 기초가 될 소송자료를 제출하는 방법으로 소송절차를 진행하며, 예외적으로 직권심리주의가 가미(行政訴訟法 26)된다.<br>2. 다만, 직권심리주의는 행정소송의 특수성에 연유하는 당사자주의, 변론주의에 대한 일부 예외규정일 뿐 법원이 아무런 제한없이 당사자가 주장하지 아니한 사실을 판단할 수 있는 것은 아니고, 일견 기록에 현출되어 있는 사항에 관하여서만 직권으로 증거조사를 하고 이를 기초로 하여 판단할 수 있을 따름이고, 그것도 법원이 필요하다고 인정할 때에 한하여 청구범위 내에서 증거조사를 하고 판단할 수 있을 뿐이다(94누4820). 한편 변론종결 후 제출된 참고자료는 기록에 나타난 자료에 포함되지 아니한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |             | 위법판단의 기준 시점 | 1. 심결취소소송에 있어서도 심결의 위법 여부는 심결 당시의 법령과 사실 상태를 기준으로 판단하여야 하고, 원칙적으로 심결이 있는 이후 비로소 발생한 사실을 고려하여 판단의 근거로 하여서는 안된다.<br>2. 예컨대, 심판계속중 확인대상발명이 등록된 경우에는 저촉관계를 확인하는 적극적 권리범위확인심판은 부적법한 것으로 되지만, 인용심결이 있는 후에 그 심결에 대한 취소소송 계속중에 확인대상발명이 등록된 경우에는 그 심판 자체가 부적법한 것으로 되는 것은 아니게 된다(99후2211). 이 경우 특허법원에서 심결의 위법성 여부에 대한 실체판단 후 심결이 위법하여 심결을 취소하고 환송하면, 심판관 합의체가 심결각하하면 된다. 다만, 적극적 권리범위확인심판을 기각하는 심결인 경우 판례(98허9079)는 단순히 각하되어야 할 것이 기각된 것에 불과하여 심결취소를 구할 법률상 이익이 인정되지 아니하여 소의 이익이 부정된다고 판시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 심리범위        |             | 1. 문제의 소재 - 특허소송에 있어서 심판단계에서 주장한 거절이유 또는 무효사유와 다른 사유가 주장되고 이 주장을 증명하기 위한 새로운 증거가 제출되는 경우에 이를 어떻게 취급할 것인가의 문제이다.<br>2. 다수의 판례(2000후1306 등)가 무제한설을 채택 - 국민의 법관에 의한 사실심에 대한 재판받을 권리를 인정하기 위해 생긴 특허법원의 설립배경을 보더라도 타당.<br>3. 다만, 특허취소결정과 결정계 심판의 심결에 대한 취소소송의 경우 주장이 제한됨<br>① 특허출원에 대한 심사단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조, 제63조, 제170조 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 지식재산처장은 심사 또는 심판단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각심결의 취소소송절차에서 지식재산처장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주 |



|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |           | <p>요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이다(2013후1054).</p> <p>② 다만 거절결정불복심판청구 기각심결의 취소소송절차에서 지식재산처장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이다(2013후1054).</p> <p>③ 법원은 특허거절결정을 유지한 심결의 위법성 여부를 판단하는 것일 뿐 특허출원에 대하여 직접 특허결정 또는 특허거절결정을 하는 것은 아니다. 따라서 심사관이 특허출원의 보정에 대한 각하결정을 한 후 「보정 전의 특허출원」에 대하여 거절결정을 하였고, 그에 대한 불복심판 절차에서 위 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 심판청구를 기각하는 특허심판원의 심결이 있었던 경우, 그 심결취소소송에서 법원은 위 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 「보정 이후의 특허출원」에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니다(2012후3121).</p> <p>④ 지식재산처가 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하할 때는 특허거절결정의 경우와 달리 그 결정 이전에 출원인에게 의견제출기회를 주지 않아도 되므로(法 63①단서), 심결취소소송 단계에 이르러 지식재산처가 보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 사유를 내세워 보정이 부적법함을 주장하더라도 출원인으로서의 이에 대응하여 소송절차에서 그 심리의 방식에 따라 충분히 그 다른 사유와 관련하여 보정의 적법 여부에 대하여 다룰 수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없어, 지식재산처는 특허거절결정에 대한 심결취소소송 단계에서 보정각하결정에 부치거나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 이유를 들어 보정의 부적법을 주장할 수 있다(2006허9197; 2008허11064; 2008허3452 등)</p> <p>⑤ 정정심판에서 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여함으로써 정정심판청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지한다는 공익상의 요구에 기인하는 강행규정이다. 따라서 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출 통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나, 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하다. 특히 정정심판을 기각하는 이유가 선행고안에 의하여 고안의 진보성이 부정된다는 취지라면 지식재산처장이 취소소송절차에 이르러 비로소 제출한 자료들은, 선행고안을 보충하여 출원 당시 해당 고안과 동일한 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술을 증명하기 위한 것이거나, 정정의견제출 통지서에 기재된 선행고안의 기재를 보충 또는 뒷받침하는 것에 불과한 경우라고 인정될 때 판단의 근거로 삼을 수 있다(2018후12004).</p> <p>⑧ 특허취소결정에 대한 취소소송에서도, 피고인 지식재산처장이 특허취소결정 당시 취소신청이유로 삼지 아니한 새로운 사유를 주장할 수 있다면 특허권자는 새로운 취소신청이유에 대하여 의견서를 제출하거나 정정청구를 할 수 있는 기회를 박탈당하는 결과가 되므로, 이를 제한함이 바람직할 것이다.</p> |
|  | 주장·증명 책임  | <p>1. 법률요건분류설에 따라 분배 - 각 당사자는 자기에 유리한 법규의 요건사실의 존부에 대하여 증명 책임을 지는 것으로 분배</p> <p>2. 특허발생요건(法 5, 29①본문, 30①각호, 42③④⑤, 44, 45) VS 특허장예요건(法 29(단, 29①본문 제외), 32, 36①②③)</p> <p>3. 거절결정불복심판의 심결취소소송 - 특허발생요건은 출원인이, 특허장예요건은 지식재산처장이 주장·증명 책임</p> <p>4. 무효심결 또는 기각심결의 심결취소소송 - 특허발생요건은 특허권자, 특허장예요건은 무효심판청구인.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 자백과 자백 간주 | <p>1. 행정소송인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되고, 따라서 자백 또는 자백간주도 인정되나, 자백의 대상은 사실이고 이러한 사실에 대한 법적 판단 내지 평가는 자백의 대상이 되지 아니한다(2000후1542).</p> <p>2. 구체적인 예를 들면, 특허발명과 확인대상발명의 동일 또는 균등 여부(대법원 2022. 01. 27. 선고 2019다277751), 등록고안과 확인대상고안의 동일 여부(98허4883), 신규성 또는 진보성이 있는지 여부(99허6640), 특허청구항의 해석(특허법원 2000. 9. 21. 선고 99허5654)은 평가개념으로 보아 자백의 대상이 아니라고 한 반면, 발명의 공지 시기(98허3804), 특허발명의 진보성 판단에 제공되는 선행발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지 여부(2004후905), 피심판청구인의 확인대상발명 실시 여부(2011허11255), 확인대상발명(피고 제품)이 어떤 구성을 가지고 있는지 여부(대법원 2022. 01. 27. 선고 2019다277751)는 사실개념으로서 자백의 대상이라고 보고 있다. 사실에 대한 진술인지, 아니면 그 구성요소가 특허발명의 구성요소와 동일 또는 균등하다는 법적 판단 내지 평가에 관한 진술인지는 당사자 진술의 구체적 내용과 경위, 변론의 진행 경과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 그리고 일단 재판상 자백이 성립하면 그것이 적법하게 취소되지 않는 한 법원은 이에 구속되므로 법원은 자백과 배치되는 사실을 증거에 의하여 인정할 수 없다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|    |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 종료 | 기술심리관의<br>관여          |          | 1. 심결취소소송에서는 기술심리관이 재판장의 허가를 받아 해당기술분야에 대하여 질문할 수 있고, 재판의 합의에 의견을 진술할 수 있다.<br>2. 기술심리관도 엄격한 소송의 중립·공정성을 유지하기 위해 제척·기피의 대상이 된다. 한편, 기술심리관은 제척 또는 기피사유가 있다고 인정할 경우에는 특허법원장의 허가를 받아 회피할 수 있다(法 188의2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 당사자에 의한<br>종료         |          | 1. 소의 취하 - 일부청구도 가능하므로 일부 청구항에 대해서도 취하할 수 있다.<br>2. 재판상 화해 및 청구의 포기·인락은 불인정 - 대세효가 있어 공정을 기할 필요가 있음.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 종국<br>판결에<br>의한<br>종료 | 내용       | 법원은 특허소송이 제기된 경우에 그 청구가 이유없을 때에는 청구기각판결을 하며, 청구가 이유있다고 인정한 때에는 판결로써 해당 심결 또는 결정을 취소하여야 한다(法 189①).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                       | 불복       | 특허법원의 판결에 불복이 있는 때에는, 판결이 송달된 날로부터 2주일 이내에 상고장을 특허법원에 제출하여 대법원에 상고할 수 있다(法 186⑧). 상고심은 법률심이고, 최종심이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                       | 확정<br>효과 | 1. 특허법원의 심결취소소송에서 해당 심결 또는 결정의 취소판결이 확정된 때에는 심판관은 그 사건을 다시 심리하여 심결 또는 결정을 하여야 한다. 이 경우 판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다(法 189②③). 그러므로 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한 판결의 취소된 이유에 반하여 심결이나 결정을 할 수 없다. 여기에서 「새로운 증거」라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택·조사되지 아니한 것으로서 사실심 변론 종결 이후에 발생한 심결취소판결의 결론을 반복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 한다(2000후2590; 2001후96).<br>2. 1차 심결 당시에 직권심리에 의하여 수집한 자료에 있는 사실 자체는 심결취소소송의 변론종결 이후에 발생한 새로운 사유로 볼 수 없고, 자백에 의하여 인정된 사실이라도 그것이 심결취소소송의 판단의 전제가 된 경우에는 취소의 기본이 된 이유에 해당하므로, 특허심판원으로서 1차 심결 때의 판단 자료에 기하여 종전과 같은 심결을 하는 것은 기속력에 반하는 위법이라고 보아야 한다(2001후96). |

### Ⅲ 광의의 특허소송의 분류

| 종 류                        | 관 할              | 관련조문                                 |
|----------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 침해소송                       | 민·형사법원<br>(특허법원) | 法 제126조 내지 제132조<br>法 제225조 내지 제232조 |
| 행정처분(무효, 불수리, 재정 등)에 대한 소송 | 행정법원/행정심판원       | 法 제224조의2                            |
| 특허취소결정, 심결 또는 각하결정에 대한 소송  | 특허법원             | 法 제186조 내지 제189조                     |
| 보상금에 대한 소송                 | 민사법원/행정법원        | 法 제190조 및 제191조                      |

### Ⅳ 심판당사자의 원·피고적격

| 심판의 종류  | 결정/심결             | 원고      | 피고     |
|---------|-------------------|---------|--------|
| 특허취소신청  | 각하결정<br>(심판장)     | 특허취소신청인 | 지식재산처장 |
|         | 각하결정<br>(심판관 합의제) | 불복×     |        |
|         | 취소결정              | 특허권자    | 지식재산처장 |
|         | 기각결정              | 불복×     |        |
| 당사자계 심판 | 각하결정              | 심판청구인   | 지식재산처장 |
|         | 각하심결              | 심판청구인   | 심판피청구인 |
|         | 인용심결              | 심판피청구인  | 심판청구인  |
|         | 기각심결              | 심판청구인   | 심판피청구인 |
| 결정계 심판  | 각하결정              | 심판청구인   | 지식재산처장 |
|         | 각하심결              | 심판청구인   | 지식재산처장 |
|         | 인용심결              | 불복×     |        |
|         | 기각심결              | 심판청구인   | 지식재산처장 |

### Ⅴ 공유특허권 또는 공동심판청구인 1인의 원·피고적격

| 구 분             | 원 고                                                                                                                                                                                                                      | 피 고                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 공유특허권자 중<br>1명  | 判例가 긍정 → 다른 공유자의 이익을 해한다거나 합일확정의 요청에 반하는 사태가 생긴다고 볼 수 없기 때문(승소할 경우에는 그 취소판결의 효력은 행정소송법 제29조제1항에 의하여 다른 공유자에게도 미쳐 특허심판원에서 공유자 모두와의 관계에서 심판절차가 재개됨으로써 충족되고, 그 소송에서 패소하더라도 이미 심판절차에서 패소한 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 아니함)           | 判例가 부정 → 모두를 대상으로 하여야 한다고 해석하더라도 공유자가 원고인 경우와 달리 특별히 부당한 결과가 발생하는 것이 아니기 때문                                                  |
| 공동심판청구인 중<br>1명 | 학설이 긍정 → 심결이 있은 후 공동심판청구인 모두에 대하여 출소기간이 지나야 심결이 확정되므로 1명이라도 심결취소소송을 제기하면 심결은 확정되지 않고, 출소기간을 지난 공동심판청구인은 스스로 심결취소소송을 제기할 수는 없지만, 심결이 확정되지는 않았으므로 승소의 확정판결에 의하여 다시 심판이 계속되면 그 심판에서 심결취소소송을 제기하지 아니한 공동심판청구인도 심판청구인의 지위를 유지 | 判例가 긍정 → 1명의 피고를 상대로 심결취소소송을 제기함으로써 그 심결은 확정되지 아니한 것이 되고, 원고가 패소판결이 확정된 경우에만 비로소 심결이 확정됨(분리확정할 수 없는 유사필수적 공동소송으로, 당사자변경은 불허) |

# 75

## 보상금 또는 대가에 대한 불복의 소 (法 190, 191)

### 제190조 【보상금 또는 대가에 관한 불복의 소】 法 112Ⅱ / 115 / 186㉔

- ① (보상금 또는 대가에 대한 불복) 제41조제3항[외국의 출원금지, 비밀취급명령·제4항[특허하지 아니하거나 특허를 받을 수 있는 권리의 수용한 경우], 제106조제3항[특허권의 수용], 제106조의2제3항[국가의 비상사태 등에 의한 통상실시권], 제110조제2항제2호[재정에 대한 대가 지급방법·지급시기] 및 제138조제4항[통상실시권하락심판]에 따른 보상금 및 대가에 대하여 심결·결정 또는 재정을 받은 자가 그 보상금 또는 대가에 불복할 때에는 법원에 소송을 제기할 수 있다.
- ② (제소기간: 일반) 제1항에 따른 소송은 심결·결정 또는 재정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다.
- ③ (제소기간: 불변기간) 제2항에 따른 기간은 불변기간으로 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

### 제191조 【보상금 또는 대가에 관한 소송에서의 피고】

제190조에 따른 소송에서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 피고로 하여야 한다.

1. 제41조제3항 및 제4항에 따른 보상금에 대해서는 보상금을 지급하여야 하는 중앙행정기관의 장 또는 출원인
2. 제106조제3항 및 제106조의2제3항에 따른 보상금에 대해서는 보상금을 지급하여야 하는 중앙행정기관의 장, 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자
3. 제110조제2항제2호 및 제138조제4항에 따른 대가에 대해서는 통상실시권자·전용실시권자·특허권자·실용신안권자 또는 디자인권자

[전문개정 2014.6.11.]

# 76

## 변리사의 보수와 소송비용(法 191의2)

### 제191조의2 【변리사의 보수와 소송비용】 法 165②

소송을 대리한 변리사의 보수에 관하여는 「민사소송법」 제109조를 준용한다. 이 경우 "변호사"는 "변리사"로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 민사소송법 제109조

##### 제109조(변호사의 보수와 소송비용)

- ① 소송을 대리한 변호사에게 당사자가 지급하였거나 지급할 보수는 대법원규칙이 정하는 금액의 범위안에서 소송비용으로 인정한다.
- ② 제1항의 소송비용을 계산할 때에는 여러 변호사가 소송을 대리하였더라도 한 변호사가 대리한 것으로 본다.

- 기존에는 변리사가 소송대리를 하였을 경우 근거 규정이 없다는 이유로 변리사의 보수를 소송비용으로 지급받지 못하였기 때문에(95쿠3), 제191조의2를 신설(法律 제7871호, 2006. 03. 03. 개정 / 시행)하여 이를 해결함.

도해특허법

제8장  
국제출원

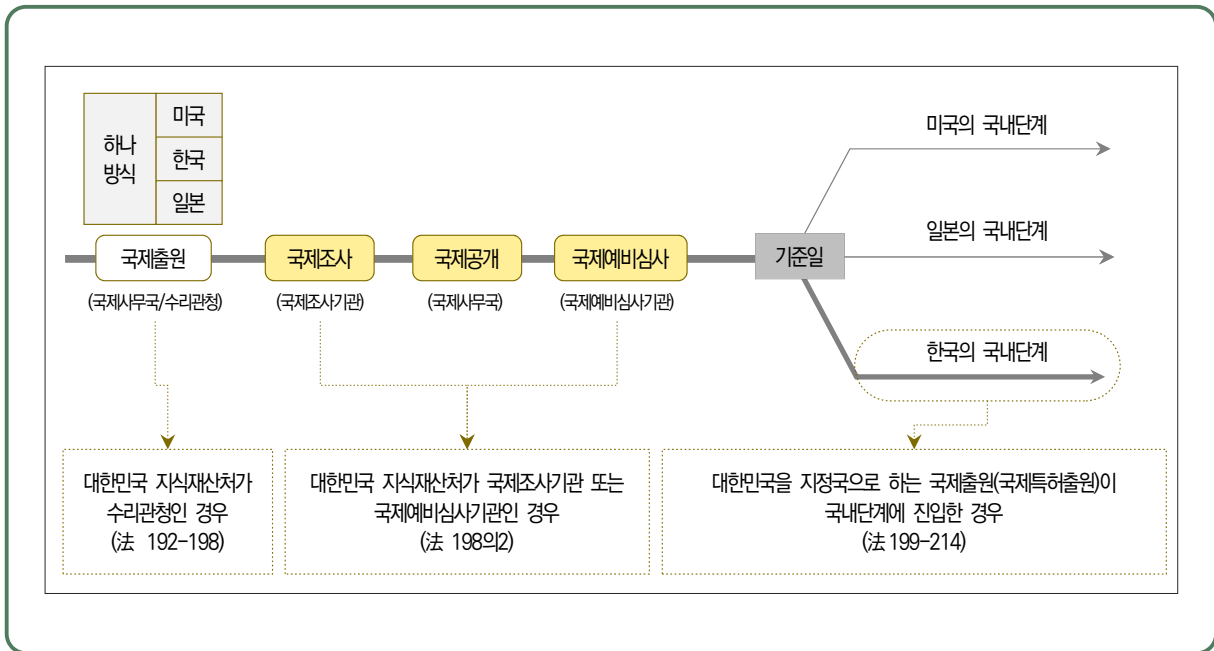
제9장  
실용신안법

77 국제출원절차(法 192~198)

78 국제조사 및 국제예비심사(法 198의2)

79 국제특허출원에 관한 특례(法 199~214)

참고자료 8 우리나라 특허법 규정에 반영된 특허협력조약(PCT)







## 국제출원절차(法 192~198)

### I 법조문

#### 제192조 【국제출원을 할 수 있는 자】(★) 法 194①I

지식재산처장에게 국제출원을 할 수 있는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다.

1. 대한민국 국민
2. 국내에 주소 또는 영업소를 가진 외국인
3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 자가 아닌 자로서 제1호 또는 제2호에 해당하는 자를 대표자로 하여 국제출원을 하는 자
4. 총리령[시행규칙 제90조]으로 정하는 요건에 해당하는 자

[전문개정 2014.6.11.]

#### 시행규칙 제90조

##### 제90조(국제출원을 할 수 있는 자)

법 제192조제4호에서 “총리령이 정하는 요건에 해당하는 자”란 같은 조 제1호부터 제3호까지에 해당하는 자가 아닌 자로서 1명 이상의 대한민국 국민이나 국내에 주소 또는 영업소를 가진 외국인과 공동으로 국제출원하는 자를 말한다. <개정 2008. 9. 30., 2013. 3. 23.>

[전문개정 1999. 7. 1.]

#### 제193조 【국제출원】(★) 法 42

- ① (제출서류) 국제출원을 하려는 자는 총리령[시행규칙 제91조]으로 정하는 언어로 작성한 출원서와 발명의 설명·청구범위·필요한 도면 및 요약서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 法 194①II, III

#### 시행규칙 제91조

##### 제91조(국제출원의 사용어)

법 제193조제1항에서 “총리령이 정하는 언어”란 국어, 영어 또는 일본어를 말한다. <개정 2011. 2. 25., 2013. 3. 23.>

- ② (출원서 기재사항) 제1항의 출원서에는 다음 각 호의 사항을 적어야 한다.
  1. 해당 출원이 「특허협력조약」에 따른 국제출원이라는 표시 法 194①IV
  2. 해당 출원된 발명의 보호가 필요한 「특허협력조약」 체약국(締約國)의 지정 法 194①IV
  3. 제2호에 따라 지정된 체약국(이하 “지정국”이라 한다) 중 「특허협력조약」 제2조(iv)의 지역특허를 받으려는 경우에는 그 취지
  4. 출원인의 성명이나 명칭·주소나 영업소 및 국적 法 194①IV
  5. 대리인이 있으면 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소
  6. 발명의 명칭
  7. 발명자의 성명 및 주소(지정국의 법령에서 발명자에 관한 사항을 적도록 규정되어 있는 경우만 해당한다)
- ③ (발명의 설명 기재방법) 제1항의 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다.
- ④ (청구범위 기재방법) 제1항의 청구범위는 보호를 받으려는 사항을 명확하고 간결하게 적어야 하며, 발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침되어야 한다.
- ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 국제출원에 관하여 필요한 사항은 총리령[시행규칙 제92조 내지 제95조]으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 시행규칙 제92조-제95조

##### 제92조(출원서 등의 제출)

- ① 국제출원을 하려는 자는 국제출원의 출원서에 발명의 설명, 청구범위, 도면 및 요약서 각 1통을 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 다만, 국제출원의 출원서를 포함한 해당 서류를 서면으로 제출하는 경우에는 각 3통을 별개의 서류로 작성하여 제출하여야 한다. <개정 2014. 12. 30.>

- ② 삭제 <2014. 12. 30.>

[전문개정 2003. 12. 31.]

#### 제93조(출원서 등의 서식)

- ① 국제출원의 출원서는 별지 제41호서식, 별지 제41호의2서식 또는 별지 제42호서식에 따라 작성하여야 한다. <개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29., 2008. 12. 31., 2014. 12. 30.>
- ② 국제출원의 발명의 설명은 별지 제43호서식, 청구범위는 별지 제44호서식, 요약서는 별지 제45호서식, 도면은 별지 제46호서식에 따라 작성하여야 한다. <개정 2006. 12. 29., 2009. 6. 30., 2014. 12. 30.>

[전문개정 1999. 7. 1.]

[제목개정 2014. 12. 30.]

#### 제93조의2(국가의 지정 등)

- ① 제92조의 규정에 따라 국제출원의 출원서 등이 제출된 경우에는 다음 각호의 사항이 행하여진 것으로 본다. <개정 2008. 12. 31.>
1. 국제출원일에 조약에 구속되는 모든 계약국의 지정
  2. 지정된 계약국(이하 "지정국"이라 한다)중 조약 제43조 또는 제44조가 적용되는 각 지정국에서 얻을 수 있는 모든 종류의 권리를 위한 것이라는 표시
  3. 조약 제45조(1)이 적용되는 각 지정국의 지역특허[조약 제2조(iv)의 규정에 따른 특허를 말한다] 및 국내특허[조약 제45조(2)가 적용되는 경우를 제외한다]를 위한 것이라는 표시
- ② 제1항의 규정에 불구하고 조약규칙 4.9(b)의 규정에 따라 우선권 주장의 기초가 되는 자국내 선출원에 대하여 취하되는 효과를 규정하고 있는 계약국에 대하여는 국제출원의 출원인은 당해 계약국의 지정을 제외할 수 있다.

[본조신설 2003. 12. 31.]

#### 제94조(국제출원번호등의 통지)

지식재산처장은 국제출원으로 제출된 서류를 접수한 때에는 그 국제출원번호 및 그 국제출원의 접수일을 출원인에게 통지하여야 한다.

[전문개정 1999. 7. 1.]

#### 제95조(출원서 기재사항의 직권말소)

지식재산처장은 국제출원의 출원서에 법 제193조제2항 및 이 규칙에 정한 사항외의 사항이 기재되어 있는 경우에는 직권으로 그 사항의 기재를 말소하여야 한다.

### 제194조 【국제출원일의 인정 등】(★★) 法 28②

- ① (도달주의) 지식재산처장은 국제출원이 지식재산처에 도달한 날을 「특허협력조약」 제11조의 국제출원일(이하 "국제출원일"이라 한다)로 인정하여야 한다. (보완사유) 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 출원인이 제192조 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우
  2. 제193조제1항에 따른 언어로 작성되지 아니한 경우
  3. 제193조제1항에 따른 발명의 설명 또는 청구범위가 제출되지 아니한 경우
  4. 제193조제2항제1호·제2호에 따른 사항 및 출원인의 성명이나 명칭을 적지 아니한 경우

#### 시행규칙 제98조 및 제100조

##### 제98조(국제출원으로 취급하지 아니한다는 취지의 통지)

지식재산처장은 법 제194조제2항에 따른 절차의 보완명령을 받은 자가 지정된 기간에 절차의 보완을 하지 아니하는 경우에는 조약규칙 20.4(i)에 따라 그 출원은 국제출원으로 취급하지 아니한다는 취지 및 이유를 출원인에게 통지하여야 한다.

<개정 2008. 12. 31.>

[전문개정 1999. 7. 1.]

##### 제100조(국제출원일의 통지)

지식재산처장은 국제출원일을 인정한 때에는 당해국제출원일을 출원인에게 통지하여야 한다. <개정 2003. 12. 31.>

[전문개정 1999. 7. 1.]

- ② (보완명령) 지식재산처장은 국제출원이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 서면으로 절차를 보완할 것을 명하여야 한다.
- ③ (도면 미제출시 통지) 지식재산처장은 국제출원이 도면에 관하여 적고 있으나 그 출원에 도면이 포함되어 있지 아니하면 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다.
- ④ (보완 및 도면 제출시 효과) 지식재산처장은 제2항에 따른 절차의 보완명령을 받은 자가 지정된 기간에 보완을 한 경우에는 그 보완에 관계되는 서면의 도달일을, 제3항에 따른 통지를 받은 자가 총리령[시행규칙 제99조]으로 정하는 기간에 도면을 제출한 경우에는 그 도면의 도달일을 국제출원일로 인정하여야 한다. 다만, 제3항에 따른 통지를 받은 자가 총리령[시행규칙 제99조]으로 정하는 기간에 도면을 제출하지 아니한 경우에는 그 도면에 관한 기재는 없는 것으로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 시행규칙 제99조 및 제99조의2

##### 제99조(도면의 제출기간)

- ① 법 제194조제4항에서 "총리령이 정하는 기간"이란 같은 조 제3항에 따른 통지일부터 2개월을 말한다. <개정 2008. 9. 30., 2008. 12. 31., 2013. 3. 23.>

② 법 제194조제4항의 규정에 의한 도면을 제출하고자 하는 자는 별지 제35호서식의 서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다. <개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29.>

1. 도면 3통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통 [전문개정 1999. 7. 1.]

#### 제99조의2(국제출원의 명세서 등의 보완)

① 지식재산처장은 법 제194조제1항에 따른 국제출원일을 인정할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2개월 이내에 그 누락된 부분 또는 잘못 제출된 부분을 정정하는 부분(이하 "정정 부분"이라 한다)을 제출하도록 출원인에게 보완을 명하여야 한다. <개정 2014. 12. 30., 2020. 7. 1.>

1. 발명의 설명 또는 청구범위의 일부가 누락(법 제194조제1항제3호에 해당하는 경우는 제외한다)되어 있거나 잘못 제출된 경우
2. 도면의 전부 또는 일부가 누락되어 있거나 잘못 제출된 경우

② 제1항에도 불구하고 출원인은 국제출원의 접수일부터 2개월 이내에 제1항에 따른 누락된 부분 또는 정정 부분을 지식재산처장에게 제출할 수 있다. <개정 2020. 7. 1.>

③ 제1항 또는 제2항에 따라 누락된 부분 또는 정정 부분을 제출하려는 자는 별지 제35호서식의 서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출해야 한다. <개정 2014. 12. 30., 2020. 7. 1.>

1. 누락된 부분 또는 정정 부분을 적은 발명의 설명, 청구범위 또는 도면 각 3통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

④ 출원인은 제1항에 따른 기간에 그 보완명령에 대한 의견서를 지식재산처장에게 제출할 수 있다.

⑤ 제4항에 따라 의견서를 제출하려는 자는 별지 제40호서식의 의견제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

1. 의견서 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

⑥ 지식재산처장은 제3항에 따른 서류제출서가 접수된 경우에는 해당 서류의 접수일을 법 제194조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 국제출원일로 인정하여야 한다. 다만, 해당 접수일이 법 제194조제4항에 따라 국제출원일로 인정되는 날보다 앞서는 경우에는 그러하지 아니하다.

[본조신설 2008. 12. 31.]

#### 제100조의2(명세서 등의 보완의 취하)

① 제99조의2제6항 본문에 따라 국제출원일이 인정된 경우에는 국제출원을 한 출원인은 제100조에 따른 통지일부터 1개월 이내에 제99조의2 제3항에 따라 제출된 서류의 제출을 취하할 수 있다.

② 제1항에 따라 서류의 제출이 취하된 경우에는 제99조의2제6항 본문에 따른 국제출원일의 인정은 없었던 것으로 본다.

③ 제1항에 따라 서류의 제출을 취하하려면 별지 제49호서식의 취하서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

[본조신설 2008. 12. 31.]

### 제195조 【보정명령】(★★) 法 46

지식재산처장은 국제출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다.

1. 발명의 명칭이 적혀 있지 아니한 경우
2. 요약서가 제출되지 아니한 경우
3. 제3조[미성년자 등의 행위능력] 또는 제197조제3항[국제출원의 대리인]을 위반한 경우
4. 총리령[시행규칙 제110조]으로 정하는 방식을 위반한 경우

[전문개정 2014.6.11.]

### 제196조 【취하된 것으로 보는 국제출원 등】(★)

① (국제출원의 취하간주) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국제출원은 취하된 것으로 본다.

1. 제195조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니한 경우
2. 국제출원에 관한 수수료를 총리령[시행규칙 제106조]으로 정하는 기간에 내지 아니하여 「특허협력조약」 제14조(3)(a)에 해당하게 된 경우
3. 제194조에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원에 관하여 총리령[시행규칙 제106조]으로 정하는 기간에 그 국제출원이 제194조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 것이 발견된 경우

#### 시행규칙 제106조

##### 제106조(국제출원이 취하된 것으로 보는 시기)

① 법 제196조제1항제2호에서 "총리령이 정하는 기간"이란 제104조제1항에 따라 수수료미납부에 대한 보정을 명한 날부터 1개월을 말한다. <개정 2008. 9. 30., 2013. 3. 23.>

② 법 제196조제1항제3호에 따른 기간은 국제출원일부터 4개월로 한다.

<개정 2008. 9. 30.>

[본조신설 1999. 7. 1.]

- ② **(지정국의 취하간주)** 국제출원에 관하여 내야 할 수수료의 일부를 총리령[시행규칙 제106조]으로 정하는 기간에 내지 아니하여 「특허협력조약」 제14조(3)(b)에 해당하게 된 경우에는 수수료를 내지 아니한 지정국의 지정은 취하된 것으로 본다.
- ③ **(출원인에게 통지)** 지식재산처장은 제1항 및 제2항에 따라 국제출원 또는 지정국의 일부가 취하된 것으로 보는 경우에는 그 사실을 출원인에게 알려야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제197조 【대표자 등】(★)

- ① **(대표자: 절차 수행)** 2인 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 제192조부터 제196조까지 및 제198조에 따른 절차는 출원인의 대표자가 밟을 수 있다.
- ② **(대표자: 지정)** 2인 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 출원인이 대표자를 정하지 아니한 경우에는 총리령[시행규칙 제106조의4]으로 정하는 방법에 따라 대표자를 정할 수 있다.

##### 시행규칙 제106조의4

###### 제106조의4(대표자의 지정)

법 제197조제2항의 규정에 의한 출원인의 대표자지정은 법 제192조제1호 또는 제2호에 해당하는 출원인중 첫번째로 기재되어 있는 자로 한다.

[본조신설 1999. 7. 1.]

- ③ **(대리인)** 제1항의 절차를 대리인에 의하여 밟으려는 자는 제3조에 따른 법정대리인을 제외하고는 변리사를 대리인으로 하여야 한다. **法 195Ⅲ**

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제198조 【수수료】

- ① 국제출원을 하려는 자는 수수료를 내야 한다.
- ② 제1항에 따른 수수료, 그 납부방법 및 납부기간 등에 관하여 필요한 사항은 총리령[시행규칙 제106조의5, 8 및 특허료 등의 징수규칙]으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

## II 국제출원절차(法 192~198)의 법조문 정리

| 구 분      | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주체       | 1. 국제출원인(法 192)<br>2. 대표자(法 197①②)<br>3. 대리인(法 197③)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 서류 등의 제출 | 1. 첨부서류 & 언어(法 193①)<br>2. 기재방법<br>○ 출원서(法 193②)<br>○ 발명의 설명(法 193③)<br>○ 청구범위(法 193④)<br>○ 기타(法 193⑤)<br>3. 수수료의 납부(法 198)                                                                                                                                                                                                        |
| 출원일인정    | 1. 보완<br>○ 보완사유(法 194①각호)<br>○ 보완명령(法 194②)<br>○ 보완한 경우의 효과(法 194④전단부)<br>○ 보완하지 아니한 경우의 효과(法 194①단서)<br>2. 보정<br>○ 보정사유(法 195)<br>○ 보정명령(法 195)<br>○ 보정한 경우의 효과(명문의 규정 없음)<br>○ 보정하지 아니한 경우의 효과(法 196① I, II)<br>3. 누락 부분 등의 보완(法 194③④, 施規 99의2)<br>○ 보완사유<br>○ 명령 또는 의사에 의한 보완<br>○ 보완한 경우의 효과<br>○ 보완하지 아니한 경우의 효과<br>○ 보완의 취하 |
| 기타       | 1. 취하된 것으로 보는 국제출원 등(法 196)<br>○ 국제출원의 취하간주(法 196①)<br>○ 지정국의 취하간주(法 196②)<br>○ 출원인에게 통지(法 196③)<br>2. 국제조사 및 국제예비심사기관 등(法 198의2)                                                                                                                                                                                                  |

### III 국제출원절차(法 192~198)

| 구 분      |           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주체       | 출원인       | 1. 대한민국 국민<br>2. 대한민국에 주소 또는 영업소를 가진 외국인<br>3. 대한민국에 주소 또는 영업소를 가지지 아니한 외국인으로서 대한민국 국민이나 대한민국에 주소 또는 영업소를 가지는 외국인을 대표자로 하여 공동으로 국제출원을 하는 자,<br>4. 1명 이상의 대한민국 국민 또는 국내에 주소 또는 영업소를 가진 외국인과 공동으로 국제출원을 하는 자(法 192, 施規 90).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 대표자       | 2명 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에는 대표자가 절차를 행할 수 있는데(法 197①), 2인 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 출원인이 대표자를 정하지 아니한 때에는 지식재산처에 국제출원할 자격을 가지는 대한민국 국민 또는 국내에 주소나 영업소를 갖는 외국인의 출원인 중 출원서에 최초로 기재되어 있는 출원인을 대표자로 정할 수 있다(法 197②, 施規 106의4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 대리인       | 법정대리인을 제외하고는 변리사를 대리인으로 해야 한다(法 197③).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 서류 등의 제출 | 첨부서류 & 언어 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 기재 방법     | 국제출원을 하려는 자는 총리령으로 정하는 언어로 작성한 출원서, 발명의 설명, 청구범위, 필요한 도면 및 요약서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 193①). 「총리령이 정하는 언어」란 국어, 영어 또는 일어를 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |           | 1. 국제출원서에는 다음의 사항을 기재하여야 한다(法 193①②).<br>① 해당 특허출원이 특허협력조약에 따른 국제출원이라는 표시<br>② 해당 특허출원이 발명의 보호가 필요한 특허협력조약 체결국의 지정(단, 자동지정으로 무의미)<br>③ 지역특허를 받으려는 경우에는 그 취지<br>④ 출원인의 성명이나 명칭, 주소나 영업소 및 국적<br>⑤ 대리인이 있으면 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소<br>⑥ 발명의 명칭<br>⑦ 발명자의 성명 및 주소나 영업소(지정국의 법령에 발명자에 관한 사항의 기재가 규정되어 있는 경우에 한한다)<br>2. 다만, 출원서 등이 제출된 경우에는 다음의 사항이 행하여진 것으로 본다(施規 93의2)<br>① 조약 제11조에 따른 국제출원일에 조약에 구속되는 모든 체결국의 지정(이를 자동지정제도로 한다. 다만, 조약규칙 4.9(b)에 따른 우선권 주장의 기초가 되는 자국내 선출원에 대하여 취해지는 효과를 규정하고 있는 체결국에 대해서는 국제출원의 출원인은 해당 체결국의 지정을 제외할 수 있다.)<br>② 지정국 중 조약 제43조 또는 제44조가 적용되는 각 지정국에서 얻을 수 있는 모든 종류의 권리를 위한 것이라는 표시<br>③ 조약 제45조(1)이 적용되는 각 지역구의 지역특허[조약 제2조(iv)에 따른 특허를 말한다] 및 국내특허[조약 제45조(2)가 적용되는 경우를 제외한다]를 위한 것이라는 표시 |
|          |           | 발명의 설명<br>국제출원서에 첨부하여야 할 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다(法 193③).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |           | 청구범위<br>국제출원서에 첨부될 청구범위는 보호를 받으려는 사항을 명확하고 간결하게 적어야 하며 발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침되어야 한다(法 193④).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 수수료의 납부   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 출원 일 인정  | 보완        | 보완사유<br>1. 국제출원서에 발명의 설명 및 청구범위가 제출되지 아니한 경우<br>2. 출원인의 성명이나 명칭을 적지 아니한 경우<br>3. 대한민국에 국제출원할 수 있는 자격(法 192)을 갖추지 아니한 자가 출원한 경우<br>4. 국제출원서에 특허협력조약에 따른 국제출원이라는 표시가 되어 있지 아니한 경우<br>5. 국제출원이 총리령으로 정하는 언어(국어, 영어 또는 일어)로 작성되지 아니한 경우<br>6. 특허협력조약 체결국의 지정을 하지 아니한 경우(자동지정으로 사문화)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |           | 보완명령<br>지식재산처장은 다음의 국제출원일을 인정할 수 없는 요건, 즉 보완사유에 해당함을 발견한 경우 국제출원일을 인정하지 않고 기간을 정하여 서면으로 절차의 보완을 명하여야 한다(法 194①②).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |           | 보완한 경우<br>지식재산처장은 절차의 보완명령을 받은 자가 지정된 기간에 보완을 한 경우에는 그 보완에 관계되는 서면의 도달일을 국제출원일로 인정한다(法 194④전단부).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |           | 보완하지 아니한 경우<br>지식재산처장은 절차의 보완명령을 받은 자가 지정된 기간에 보완을 하지 아니한 경우에는 국제출원일을 인정하지 않으며, PCT 규칙 20.7(i)의 규정에 의하여 그 출원은 국제출원으로 취급하지 아니한다는 취지 및 이유를 출원인에게 통지하여야 한다(法 194①단서, 施規 98).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|    |                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 누락<br>부분<br>등 의<br>보완 | 누락 부분<br>등의<br>보완사유 | 1. 발명의 설명 또는 청구범위의 일부가 누락(발명의 설명 및 청구범위가 제출되지 아니한 경우는 제외한다)되어 있거나 잘못 제출된 경우<br>2. 도면의 전부 또는 일부가 누락되어 있거나 잘못 제출된 경우                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                       | 보완                  | 1. 명령에 의한 보완<br>지식재산처장은 국제출원일을 인정할 때 누락된 부분 등에 대한 보완사유에 해당하는 경우에는 그 취지 통지일로부터 2개월 이내에 그 누락된 부분 또는 정정 부분을 제출하도록 출원인에게 보완을 명하여야 한다(法 194③④, 施規 99의2①). 출원인은 보완명령을 받은 경우 그 기간내에 보완서나 의견서를 지식재산처장에게 제출할 수 있다(施規 99의2③④).<br>2. 의사에 의한 보완<br>지식재산처장의 보완명령과 상관없이 출원인은 국제출원의 접수일부터 2개월 이내 누락된 부분 또는 정정 부분을 지식재산처장에게 제출할 수 있다(施規 99의2②③).     |
|    |                       | 보완한<br>경우           | 지식재산처장은 보완서류제출서가 접수된 경우에는 해당 서류의 접수일을 국제출원일로 인정하여야 한다(施規 99의2⑥본문). 다만, 해당 접수일이 법 제194조 제4항에 따라 국제출원일로 인정되는 날 보다 앞서는 경우에는 그러하지 아니하다(施規 99의2⑥단서).                                                                                                                                                                                       |
|    |                       | 보완하지<br>아니한<br>경우   | 지식재산처장은 국제출원이 도면에 관하여 기재하고 있으나 그 출원에 도면이 포함되어 있지 아니함에도 불구하고, 출원인이 도면을 제출하지 아니한 경우에는 그 도면에 관한 기재는 없는 것으로 본다(法 194④후단부).                                                                                                                                                                                                                |
|    |                       | 보완의<br>취하           | 시행규칙 제99조의2 제6항 본문에 따라 누락된 부분 등의 보완서류 접수일이 국제출원일로 인정된 경우에는 국제출원을 한 출원인은 국제출원일의 통지일로부터 1개월 이내에 누락된 부분 등의 보완서류의 제출을 취하할 수 있다. 서류의 제출이 취하된 경우에는 누락된 부분 등의 보완서류 접수일을 국제출원일로 인정한 것은 없었던 것으로 본다(施規 100의2). 이는 국제출원일이 정정된 경우 출원인이 누락된 부분 등을 무시할 것을 신청할 수 있음을 규정한 것이다. 이 경우 누락된 부분 등은 제출되지 아니한 것으로 간주되고 해당 규정에 의한 국제출원일의 정정은 행해지지 아니한 것으로 본다. |
|    | 국제출원일 인정              |                     | 1. 국제출원일이 인정된 국제출원은 출원서에 기재된 각 지정국에서 정규의 국내출원으로서의 효력을 갖고, 국제출원일은 각 지정국의 실제의 출원일로 간주된다.<br>2. 수리판청은 국제출원일이 인정된 국제출원에 대하여 수리판청용 사본(home copy)은 보유하고, 기록원본(record copy)은 우선일로부터 13월을 만료하기 전까지 국제사무국에 도달하도록 송부하고, 조사용 사본(search copy)은 관할국제조사기관에 송부하여야 하며, 일정기간내 송부되지 아니한 경우 국제출원은 취하된 것으로 간주한다.                                          |
|    | 보정                    | 보정사유                | 1. 발명의 명칭이 적혀 있지 아니한 경우<br>2. 요약서가 제출되지 아니한 경우<br>3. 행위능력이 없는 자가 법정대리인에 의하지 않고 절차를 밟거나 선임된 임의대리인이 변리사가 아닌 경우<br>4. 총리령으로 정하는 방식에 위반된 경우<br>5. 국제출원을 한 자가 수수료를 해당 기간 내에 내지 아니한 경우                                                                                                                                                      |
|    |                       | 보정명령                | 지식재산처장은 국제출원일의 인정요건은 충족하였으나 보정사유에 해당하는 경우에는 보정을 명하여야 한다(法 195).                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                       | 보정한<br>경우           | 보정이 적법하게 이루어진 경우에는 보정된 내용대로 출원된 것으로 본다.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                       | 보정하지<br>아니한<br>경우   | 보정명령에 대한 기간 내에 보정이 이루어지지 아니한 경우에는 그 국제출원은 취하한 것으로 간주된다(法 196① I II).                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 기타 | 국제<br>출원<br>의<br>취하   | 의사                  | 우선일로부터 2년 6개월을 지나기 전 또는 국제출원인이 출원심사청구를 하기 전 중 빠른 때까지 국제출원, 지정국의 지정 또는 우선권주장을 취하할 수 있다(施規 106의7).                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                       | 법률규정                | 1. 국제출원의 취하간주<br>국제출원이 ① 보정사유에 해당하는 경우 또는 ② 국제출원일이 인정된 국제출원에 관하여 국제출원일로부터 4개월내에 그 국제출원이 국제출원의 보완명령사유에 해당되는 것이 발견된 경우 해당 국제출원은 취하된 것으로 간주한다(法 196①)<br>2. 지정국의 취하간주<br>국제출원에 관하여 내야 할 수수료의 일부를 내지 아니하여 특허협력조약 제14조(3)(b)에 해당하게 된 경우에는 수수료를 내지 아니한 지정국의 지정은 취하된 것으로 본다(法 196②). 다만, 국제출원                                                |

|         |       |       |                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       |       | 할 때 모든 지정국이 지정된 것으로 보며 지정료가 국제출원료에 포함되었기 때문에 수수료의 일부를 내지 아니한 경우 국제출원 전체가 취하간주되는 것이지, 지정국 일부가 취하간주 되는 경우는 없을 것이다.<br>3. 출원인에게 통지<br>지식재산처장은 국제출원 또는 지정국의 일부가 취하된 것으로 보는 때에는 그 사실을 출원인에게 통지하여야 한다(法 196③). |
| 번역문의 제출 | 국제조사용 | 제출 시기 | 국제조사기관이 인정하지 아니하는 언어로 국제출원이 출원된 경우 출원인은 국제조사를 위하여 국제출원의 접수일로부터 1개월 이내에 조약규칙 12.3(a)의 규정에 따라 국제조사기관이 인정하는 언어로 된 번역문을 지식재산처장에게 제출하여야 한다(施規 95의2①).                                                         |
|         |       | 보정 명령 | 지식재산처장은 국제출원의 접수일로부터 1개월 이내에 번역문을 제출하지 아니한 경우에는 보정을 명한 날로부터 1개월 이내에 그 번역문을 제출하도록 출원인에게 보정을 명하여야 한다(施規 95의2②).                                                                                            |
|         |       | 취하 간주 | 출원인이 보정기간에 번역문을 제출하지 아니하거나 가산료를 내지 아니하면 조약규칙 12.3(d)에 따라 그 출원은 취하된 것으로 본다. 이 경우 지식재산처장은 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다(施規 95의2③).                                                                                  |

#### Ⅳ 자동지정제도와 자동선택제도

| 구 분    | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 자동지정제도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국제출원할 때 모든 PCT 계약국이 자동적으로 지정된 것으로 보는 제도 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지정국을 1개도 지정하지 아니한 경우 보완사유에 해당한다는 규정(法 194각호)은 무의미</li> </ul> </li> <li>○ 자동지정의 도입으로 PCT 출원할 때 지정료가 출원료에 포함됨. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지정료를 내지 아니한 지정국은 취하간주(法 196②)는 무의미</li> </ul> </li> <li>○ 단, 자기지정에 의하여 선출원이 취하됨으로써 출원인에게 불이익이 되는 것을 방지하기 위해 한국, 일본, 독일, 러시아의 경우에는 자동지정 배제 가능</li> </ul> |
| 자동선택제도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국제예비심사를 청구할 때 PCT 제2장에 구속되고 지정이 이루어진 모든 PCT 계약국이 자동적으로 선택된 것으로 보는 제도</li> <li>○ PCT 제2장에 구속되는 PCT 계약국 : 국제예비심사를 허용하는 PCT 계약국을 의미.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### Ⅴ 국내출원과 국제출원의 방식심사의 비교

| 구 분  | 경미 흠결 | 중대 흠결     | 비 고                                                                                                                       |
|------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 국내출원 | 무효    | 불수리       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 불복의 대상이 있기 때문에 독립하여 행정소송이나 행정심판으로 불복가능</li> </ul>                                |
| 국제출원 | 취하간주  | 국제출원일 불인정 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 불복의 대상이 없기 때문에 독립하여 불복 불가능</li> <li>■ 단, 지정국에서의 구제방법(法 214)에 의한 구제 가능</li> </ul> |

# 78

## 국제조사 및 국제예비심사(法 198의2)

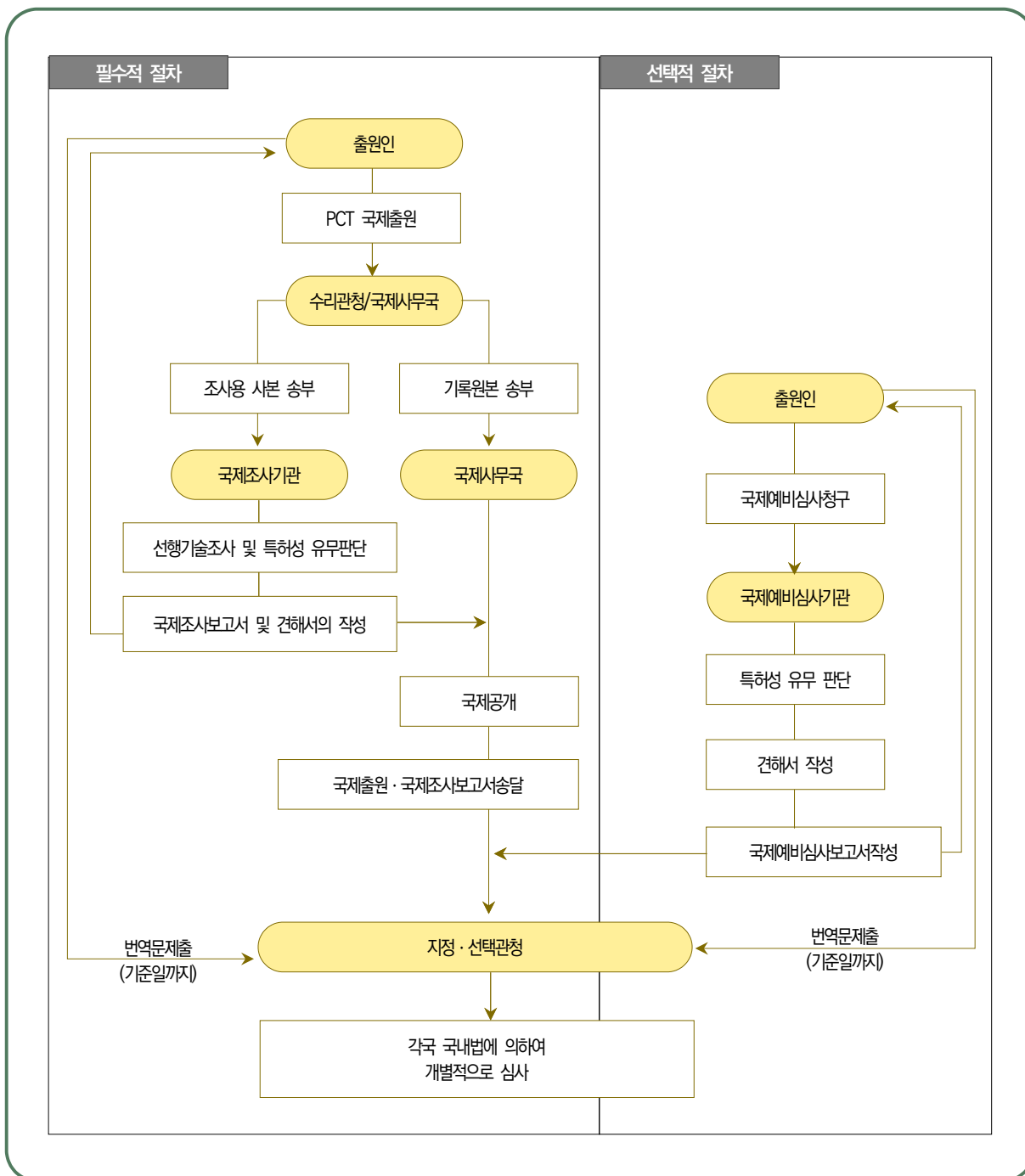
### I 법조문

#### 제198조의2 【국제조사 및 국제예비심사】

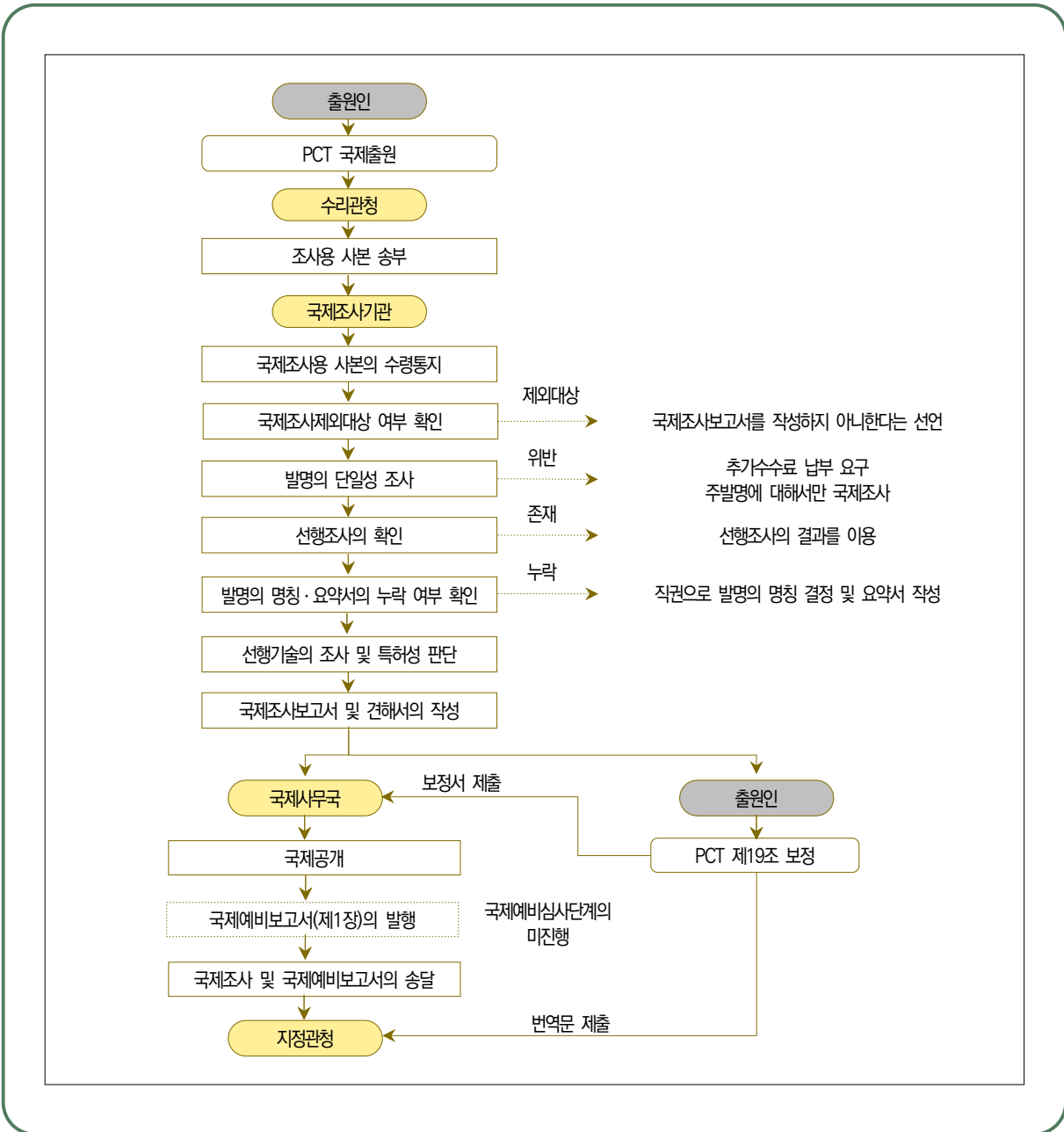
- ① 지식재산청은 「특허협력조약」 제2조(xix)의 국제사무국(이하 "국제사무국"이라 한다)과 체결하는 협정에 따라 국제출원에 대한 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로서의 업무를 수행한다.
- ② 제1항에 따른 업무수행에 필요한 사항은 총리령[시행규칙 제106조의10 내지 46]으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

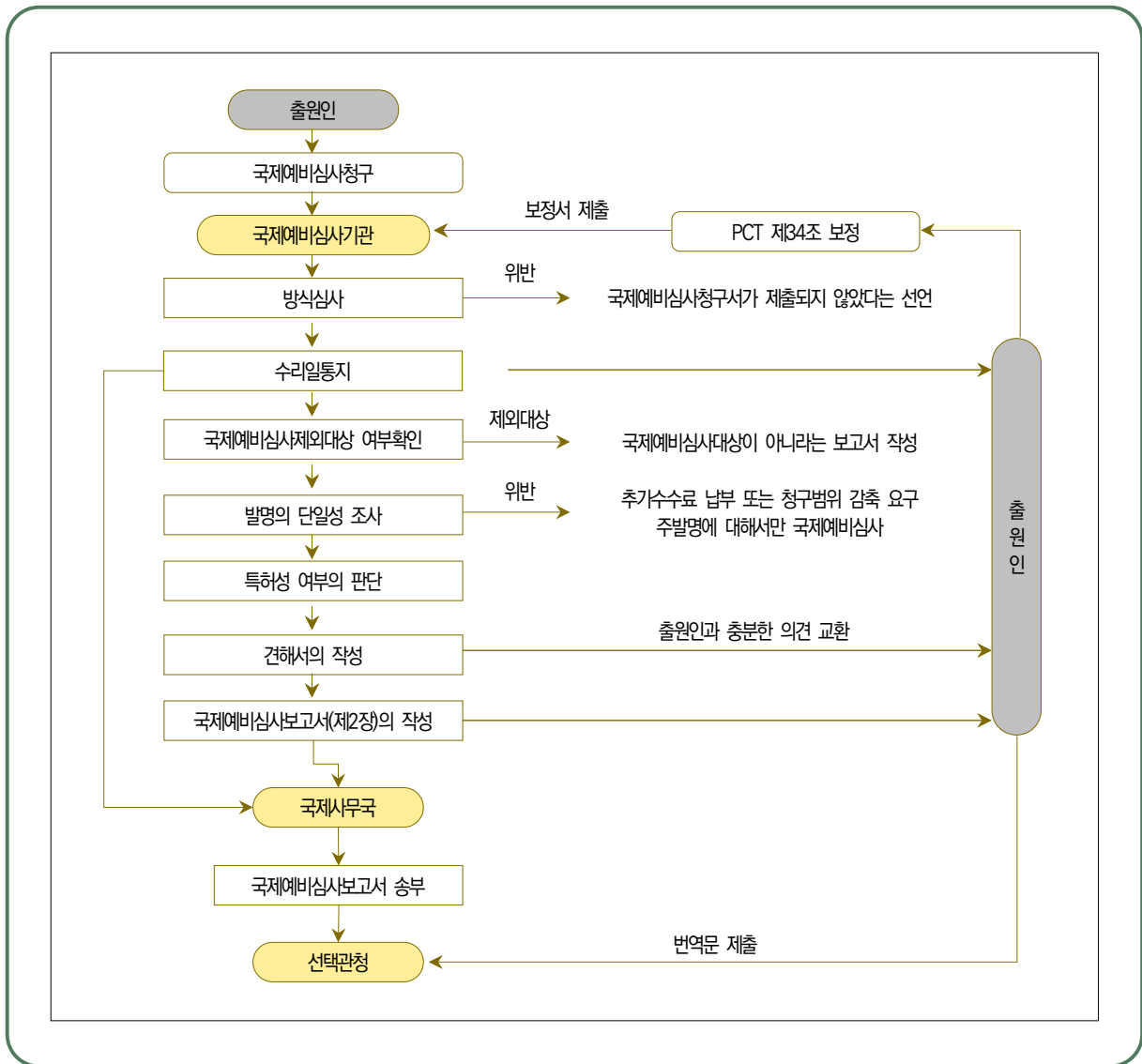
## II 국제단계절차의 개략도



### III 국제조사업무 흐름도



IV 국제예비심사 업무 흐름도





## V 국제조사와 국제예비심사의 비교

| 구 분        | 국제조사                                                                                                                                                         | 국제예비심사                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 목 적        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국제조사기관이 국제출원과 관련된 선행기술의 존재 여부의 발견</li> <li>■ 국제조사기관이 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성 인정여부에 대하여 예비적이고 구속력이 없는 견해를 표시</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국제예비심사기관이 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성 인정여부에 대하여 예비적이며 구속력이 없는 견해를 표시</li> </ul>                                                                             |
| 대 상        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 모든 국제출원이 국제조사의 대상</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국제조사와는 달리 출원인의 선택에 의한 임의적 절차로 국제출원의 청구범위에 기재되어 있는 발명</li> </ul>                                                                                      |
| 범 위        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 발명의 설명, 도면에 타당한 고려를 하여 청구범위를 기초</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 청구범위와 발명의 설명, 도면을 기초</li> </ul>                                                                                                                      |
| 이용할 수 있는 자 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국제출원을 할 수 있는 자</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PCT 제2장 규정에 구속된 계약국의 거주자 또는 국민으로서 그러한 계약국을 위해 행동하는 수리관청에 출원한 경우</li> </ul>                                                                           |
| 지정/선택      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 출원서 제출로 출원일의 모든 계약국의 지정을 구성</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 청구서 제출로 조약 제2장에 구속되는 모든 지정국의 선택을 구성</li> </ul>                                                                                                       |
| 의견교환       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 불리한 보고서 작성 전에 예고받을 권리가 없으며 원칙적으로 국제조사기관과 출원인간의 의견교환 불허용</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 불리한 보고서 작성 전에 예고받을 권리(견해서 송부)있으며 국제예비심사기관과 출원인간의 구두 또는 서면에 의한 의견교환 허용</li> </ul>                                                                     |
| 보정의 범위     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국제조사 보고서를 송달받은 후 국제사무국에 대하여 1회에 한해 청구범위에 대하여 보정(PCT 19)</li> <li>■ 동시에 설명서 제출 가능</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국제예비심사 보고서가 작성 전까지 국제예비심사기관에 대하여 청구범위, 발명의 설명 및 도면에 대하여 횟수의 제한없이 보정(PCT 34)</li> </ul>                                                               |
| 발명의 단일성    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 추가수수료의 납부를 요구</li> <li>■ 주발명에 관계되는 국제출원 부분과 추가수수료가 소정의 기간에 지불된 발명에 관계되는 국제출원 부분에 관하여 국제조사보고서를 작성</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 출원인에게 그의 선택에 따라 요건을 충족하도록 청구범위를 제한하거나 추가수수료를 낼 것을 요구</li> <li>■ 주발명에 관계되는 국제출원 부분과 추가수수료가 소정의 기간에 지불된 발명에 관계되는 국제출원 부분에 관하여 국제예비심사보고서를 작성</li> </ul> |
| 공개여부       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국제조사보고서와 견해서는 국제출원의 공개시에 전자적 형태로 공개</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국제예비심사보고서는 비공개 (선택관청은 제외)</li> </ul>                                                                                                                 |
| 종료형식       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국제조사보고서의 작성 또는 국제조사보고서를 작성하지 아니한다는 선언 / 견해서의 작성</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국제예비심사보고서의 작성</li> </ul>                                                                                                                             |

## Ⅵ 국제공개와 국내공개의 비교

| 제 도 |             | 국제출원의 국제공개                                                                                                                               | 국내공개                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |                                                                                                                                          | 국제특허출원의 국내공개                                                                                                                                                                                                             | 통상의 국내출원의 국내공개                                                                                                                                                                                         |
| 요건  | 주체적         | 국제사무국                                                                                                                                    | 지식재산처장                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
|     | 객체적         | 1. 원칙 - 출원계속 중인 모든 국제출원<br>2. 예외<br>① 국제공개의 기술적 준비가 완료되기 전 국제출원절차가 종료된 경우<br>② 공서양속에 위반<br>③ 국제출원이 국제공개를 행할 필요가 없다고 선언한 국가만을 지정국으로 하는 경우 | 대한민국을 지정국으로 하는 국제출원으로서 국내단계에 진입한 경우                                                                                                                                                                                      | 1. 원칙 - 지식재산처에 출원계속 중인 모든 특허출원<br>2. 예외<br>① 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우(法 64② I)<br>② 외국어특허출원인데 국어번역문을 제출하지 아니한 경우<br>③ 등록공고를 한 특허의 경우<br>④ 국방상 필요한 발명으로서 비밀취급이 필요한 경우<br>⑤ 공서양속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 경우 |
|     | 시기적         | 1. 국제출원의 우선일로부터 18개월을 지난 후 국제공개<br>2. 이 기간 이내라도 출원인의 신청에 의하여 조기공개가능                                                                      | 1. 원칙적으로 국내서면 제출기간을 지난 후 지체없이 공개<br>2. 이 기간에 심사청구한 국제특허출원으로서 국제공개된 경우에는 우선일로부터 1년 6개월이 되는 날과 심사청구일 중 늦은 날이 지난 후 국내공개<br>3. 1년 6개월이 지나기 전이라도 번역문을 제출하면 출원인의 신청에 의하여 조기공개가능<br>4. 단, 국어로 국제특허출원한 경우에는 국제공개된 때 국내공개된 것으로 간주 | 1. 지식재산처장의 강제공개에의 경우 출원일로부터 1년 6개월 지난 후 공개<br>2. 출원인의 신청에 의한 조기공개 시 1년 6개월이 지나기 전이라도 공개 가능                                                                                                             |
| 절차  | 형식          | 전자적 형태로 공개                                                                                                                               | CD-ROM에 의한 공개특허공보 발행                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|     | 언어          | 영어, 불어, 독어, 일본어, 중국어, 스페인어, 러시아어, 아랍어, 한국어 또는 포르투갈어로 된 경우에는 그 언어로 그대로 국제공개되나 그 이외의 언어로 된 경우에는 영어에 의한 번역문                                 | 국어                                                                                                                                                                                                                       | 국어                                                                                                                                                                                                     |
|     | 내용          | 1. 서지적 사항, 발명의 설명, 청구범위, 도면 및 원칙적으로 국제조사보고서가 기재된다. 또한 PCT 19에 의한 보정이 있는 경우 보정사항, 국제조사견해서도 공개<br>2. 국제예비보고서는 국제공개되지 아니함.                  | 국제공개를 보완할 목적으로 이루어지는 것임과 동시에 국내출원에 대한 출원공개와 같은 목적으로 이루어지는 것이므로 공개공보에 기재될 사항도 국제공개 사항에 준함                                                                                                                                 | 명세서의 전문을 공개                                                                                                                                                                                            |
| 효과  | 보상금 청구권     | 국어로 국제특허출원한 경우에만 보상금청구권 인정                                                                                                               | ○                                                                                                                                                                                                                        | ○                                                                                                                                                                                                      |
|     | 확대된 선출원의 지위 |                                                                                                                                          | ○                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |



## 국제특허출원에 관한 특례(法 199~214)

### I 법조문

#### 제199조 【국제출원에 의한 특허출원】(★)

- ① **(국제특허출원의 출원일)** 「특허협력조약」에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정 국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다.
- ② **(법 제42조의2, 제42조의3 및 제54조 적용)** 제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원(이하 "국제특허출원"이라 한다)에 관하여는 제42조의2, 제42조의3 및 제54조를 적용하지 아니한다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제200조 【공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 특례】(★)

국제특허출원된 발명에 관하여 제30조제1항제1호를 적용받으려는 자는 그 취지를 적은 서면 및 이를 증명할 수 있는 서류를 같은 조 제2항에도 불구하고 총리령(시행규칙 제111조)으로 정하는 기간에 지식재산처장에게 제출할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 시행규칙 제111조

##### 제111조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 서류제출기간의 특례)

법 제200조에서 "총리령이 정하는 기간"이란 법 제201조제5항에 따른 기준일 경과후 30일을 말한다. <개정 2007. 6. 29., 2008. 9. 30., 2013. 3. 23., 2015. 12. 31.>

[전문개정 1999. 7. 1.]

[제목개정 2007. 6. 29.]

#### 제200조의2 【국제특허출원의 출원서 등】(★)

- ① **(출원서 취급)** 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 출원서는 제42조제1항에 따라 제출된 특허출원서로 본다.
- ② **(발명의 설명, 청구범위 및 도면 취급)** 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 및 도면은 제42조제2항에 따른 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면으로 본다.
- ③ **(요약서/국어번역문 취급)** 국제특허출원에 대해서는 다음 각 호의 구분에 따른 요약서 또는 국어번역문을 제42조제2항에 따른 요약서로 본다.
  1. 국제특허출원의 요약서를 국어로 적은 경우: 국제특허출원의 요약서
  2. 국제특허출원의 요약서를 외국어로 적은 경우: 제201조제1항에 따라 제출된 국제특허출원의 요약서의 국어번역문(제201조 제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국제특허출원의 요약서의 국어번역문을 말한다)

[본조신설 2014.6.11.]

#### 제201조 【국제특허출원의 국어번역문】(★★★) **法 42의3**

- ① **(국어번역문의 제출)** 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 「특허협력조약」 제2조(xi)의 우선일(이하 "우선일"이라 한다)부터 2년 7개월(이하 "국내서면제출기간"이라 한다) 이내에 다음 각 호의 국어번역문을 지식재산처장에게 제출하여야 한다. **(국어번역문 제출기간의 연장)** 다만, 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 제203조제1항에 따른 서면에 적어 국내서면제출기간 만료일 전 1개월부터 그 만료일까지 제출한 경우(그 서면을 제출하기 전에 국어번역문을 제출한 경우는 제외한다)에는 국내서면제출기간 만료일부터 1개월이 되는 날까지 국어번역문을 제출할 수 있다. **法 203**
  1. 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문
  2. 국제특허출원의 요약서의 국어번역문
- ② **(원문 국어번역문 제출 전 PCT 제19조 보정)** 제1항에도 불구하고 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 청구범위에 관한 보정을 한 경우에는 국제출원일까지 제출한 청구범위에 대한 국어번역문을 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문으로 대체하여 제출할 수 있다. **法 204**
- ③ **(국어번역문의 교체)** 제1항에 따라 국어번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간(제1항 단서에 따라 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 출원인이 출원심사의 청구를 한 후에는 그러하지 아니하다. **法 210**

- ④ **(국어번역문의 불제출의 효과)** 제1항에 따른 출원인이 국내서면제출기간에 제1항에 따른 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하면 그 국제특허출원을 취하한 것으로 본다.
- ⑤ **(국어번역문의 제출의 효과)** 특허출원인이 국내서면제출기간의 만료일(국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 경우에는 그 청구일을 말하며, 이하 "기준일"이라 한다)까지 제1항에 따라 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문(제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국어번역문을 말한다. 이하 이 조에서 "최종 국어번역문"이라 한다)을 제출한 경우에는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 최종 국어번역문에 따라 국제출원일에 제47조제1항에 따른 보정을 한 것으로 본다.
- ⑥ **(오역의 정정)** 특허출원인은 제47조제1항 및 제208조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 총리령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제5항을 적용하지 아니한다.
- ⑦ **(여러 차례 오역정정이 있는 경우)** 제6항 전단에 따라 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다. <신설 2016.2.29.> **법 204 / 47④**
- ⑧ **(원문 국어번역문 제출 전 PCT 제19조 보정)** 제2항에 따라 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문을 제출하는 경우에는 제204조제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다. <개정 2016.2.29.> **법 204**

[전문개정 2014.6.11.]

## 제202조 【특허출원 등에 의한 우선권 주장의 특례】

- ① **(후출원이 국제특허출원인 경우: 법 제55조제2항 및 제56조제2항 부적용)** 국제특허출원에 관하여는 제55조제2항 및 제56조제2항을 적용하지 아니한다.
- ② **(후출원이 국제특허출원인 경우: 확대된 선출원)** 제55조제4항을 적용할 때 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 국제특허출원인 경우에는 같은 항 중 "특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면"으로, "출원공개되거나"는 "출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개되거나"로 본다. 다만, 그 국제특허출원이 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 경우에는 제55조제4항을 적용하지 아니한다.
- ③ **(선출원이 국제특허출원인 경우)** 제55조제1항, 같은 조 제3항부터 제5항까지 및 제56조제1항을 적용할 때 선출원이 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원인 경우에는 다음 각 호에 따른다.
1. **(소급효 인정 범위)** 제55조제1항 각 호 외의 부분 본문, 같은 조 제3항 및 제5항 각 호 외의 부분 중 "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 다음 각 목의 구분에 따른 것으로 본다.
    - 가. 선출원이 국제특허출원인 경우: "국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면"
    - 나. 선출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원인 경우: "국제출원일까지 제출된 국제출원의 고안의 설명, 청구범위 또는 도면"
  2. **(확대된 선출원)** 제55조제4항 중 "선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 다음 각 목의 구분에 따른 것으로 보고, "선출원에 관하여 출원공개"는 "선출원에 관하여 출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개"로 본다. **법 55⑥**
    - 가. 선출원이 국제특허출원인 경우: "선출원의 국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면"
    - 나. 선출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원인 경우: "선출원의 국제출원일까지 제출된 국제출원의 고안의 설명, 청구범위 또는 도면"
  3. **(선출원의 취하간주)** 제56조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때"는 "국제출원일부터 1년 3개월이 지난 때 또는 제201조제5항이나 「실용신안법」 제35조제5항에 따른 기준일 중 늦은 때"로 본다.
- ④ **(선출원이 지식재산처리의 결정에 의하여 특허출원으로 보는 국제출원인 경우)** 제55조제1항, 같은 조 제3항부터 제5항까지 및 제56조제1항을 적용할 때 제55조제1항에 따른 선출원이 제214조제4항 또는 「실용신안법」 제40조제4항에 따라 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 되는 국제출원인 경우에는 다음 각 호에 따른다.
1. **(소급효 인정 범위)** 제55조제1항 각 호 외의 부분 본문, 같은 조 제3항 및 제5항 각 호 외의 부분 중 "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 다음 각 목의 구분에 따른 것으로 본다.
    - 가. 선출원이 제214조제4항에 따라 특허출원으로 되는 국제출원인 경우: "제214조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면"
    - 나. 선출원이 「실용신안법」 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 되는 국제출원인 경우: "「실용신안법」 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 국제출원의 고안의 설명, 청구범위 또는 도면"
  2. **(확대된 선출원)** 제55조제4항 중 "선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 다음 각 목의 구분에 따른 것으로 본다.
    - 가. 선출원이 제214조제4항에 따라 특허출원으로 되는 국제출원인 경우: "제214조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 선출원의 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면"
    - 나. 선출원이 「실용신안법」 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 되는 국제출원인 경우: "「실용신안법」 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 선출원의 국제출원의 고안의 설명, 청구범위 또는 도면"

3. (선출원의 취하간주) 제56조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때"는 "제214조제4항 또는 「실용신안법」 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날부터 1년 3개월이 지난 때 또는 제214조제4항이나 「실용신안법」 제40조제4항에 따른 결정을 한 때 중 늦은 때"로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제203조 【서면의 제출】(★) 法 201

- ① (국내 진입 의사 표시 서면의 제출) 국제특허출원의 출원인은 국내서면제출기간에 다음 각 호의 사항을 적은 서면을 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 이 경우 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 제201조제1항에 따른 국어번역문을 함께 제출하여야 한다. 法 92의④N
1. 출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
  2. 출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
  3. 발명의 명칭
  4. 발명자의 성명 및 주소
  5. 국제출원일 및 국제출원번호
- ② (국어번역문 제출기간의 연장) 제1항 후단에도 불구하고 제201조제1항 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적어 제1항 전단에 따른 서면을 제출하는 경우에는 국어번역문을 함께 제출하지 아니할 수 있다.
- ③ (보정명령) 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보정기간을 정하여 보정을 명하여야 한다.
1. 제1항 전단에 따른 서면을 국내서면제출기간에 제출하지 아니한 경우
  2. 제1항 전단에 따라 제출된 서면이 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식에 위반되는 경우
- ④ (절차의 무효) 제3항에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하면 지식재산처장은 해당 국제특허출원을 무효로 할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제204조 【국제조사보고서를 받은 후의 보정】(★) 法 201②③, 205, 208

- ① (보정서의 번역문 또는 사본의 제출) 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 국제조사보고서를 받은 후에 국제특허출원의 청구범위에 관하여 보정을 한 경우 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다. 이하 이 조 및 제205조에서 같다) 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.
1. 외국어로 출원한 국제특허출원인 경우: 그 보정서의 국어번역문
  2. 국어로 출원한 국제특허출원인 경우: 그 보정서의 사본
- ② (번역문 또는 사본 제출의 효과) 제1항에 따라 보정서의 국어번역문 또는 사본이 제출되었을 때에는 그 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 제47조제1항에 따른 청구범위가 보정된 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 한정한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다.
- ③ (설명서의 번역문 또는 사본의 제출) 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제19조(1)에 따른 설명서를 국제사무국에 제출한 경우 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 기준일까지 지식재산처장에게 제출하여야 한다.
1. 외국어로 출원한 국제특허출원인 경우: 그 설명서의 국어번역문
  2. 국어로 출원한 국제특허출원인 경우: 그 설명서의 사본
- ④ (번역문 또는 사본 제출의 효과) 국제특허출원의 출원인이 기준일까지 제1항 또는 제3항에 따른 절차를 밟지 아니하면 「특허협력조약」 제19조(1)에 따른 보정서 또는 설명서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만, 국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서 또는 그 설명서가 지식재산처에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제205조 【국제예비심사보고서 작성 전의 보정】(★) 法 204, 208

- ① (보정서의 번역문 또는 사본의 제출) 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제34조(2)(b)에 따라 국제특허출원의 발명의 설명, 청구범위 및 도면에 대하여 보정을 한 경우 기준일까지 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.
1. 외국어로 작성된 보정서인 경우: 그 보정서의 국어번역문
  2. 국어로 작성된 보정서인 경우: 그 보정서의 사본
- ② (번역문 또는 사본 제출의 효과) 제1항에 따라 보정서의 국어번역문 또는 사본이 제출되었을 때에는 그 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 제47조제1항에 따른 명세서 및 도면이 보정된 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다.



- ③ **(번역문 또는 사본 불제출의 효과)** 국제특허출원의 출원인이 기준일까지 제1항에 따른 절차를 밟지 아니하면 「특허협력조약」 제34조(2)(b)에 따른 보정서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제206조 【재외자의 특허관리인의 특례】(★)

- ① **(기준일까지 행위능력 인정)** 재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 제5조제1항에도 불구하고 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다.
- ② **(기준일 경과후 2월 이내 선임신고)** 제201조제1항에 따라 국어번역문을 제출한 재외자는 총리령[시행규칙 제116조]으로 정하는 기간에 특허관리인을 선임하여 지식재산처장에게 신고하여야 한다.

#### 시행규칙 제116조

##### 제116조(재외자의 특허관리인 선임기간의 특례)

법 제206조제2항에서 “총리령이 정하는 기간”이란 법 제201조제5항에 따른 기준일부터 2개월로 한다.

〈개정 2013. 3. 23., 2017. 2. 28.〉

[전문개정 2008. 9. 30.]

- ③ **(불선임신고의 효과)** 제2항에 따른 선임신고가 없으면 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제207조 【출원공개시기 및 효과의 특례】

- ① **(출원공개시기: 외국어 국제특허출원)** 국제특허출원의 출원공개에 관하여 제64조제1항을 적용하는 경우에는 “다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 6개월이 지난 후”는 “국내서면제출기간(제201조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장해 달라는 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다. 이하 이 항에서 같다)이 지난 후(국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 국제특허출원으로서 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개된 경우에는 우선일부터 1년 6개월이 되는 날 또는 출원심사의 청구일 중 늦은 날이 지난 후)”로 본다. **法 29⑤⑥⑦**
- 시규 44②**
- ② **(출원공개시기: 국어 국제특허출원)** 제1항에도 불구하고 국어로 출원한 국제특허출원에 관하여 제1항에 따른 출원공개 전에 이미 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개가 된 경우에는 그 국제공개가 된 때에 출원공개가 된 것으로 본다. **法 29⑤⑥⑦**
- ③ **(효과: 경고)** 국제특허출원의 출원인은 국제특허출원에 관하여 출원공개(국어로 출원한 국제특허출원인 경우 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 있는 후 국제특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 국제특허출원된 발명인 것을 서면으로 경고할 수 있다.
- ④ **(효과: 보상금청구권의 발생)** 국제특허출원의 출원인은 제3항에 따른 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고도 그 국제특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록 시까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 다만, 그 청구권은 해당 특허출원이 특허권의 설정등록된 후에만 행사할 수 있다. 〈개정 2019. 1. 8.〉 **法 99의2②**

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제208조 【보정의 특례 등】(★)

- ① **(보정시기)** 국제특허출원에 관하여는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추지 아니하면 제47조제1항에도 불구하고 보정(제204조 제2항 및 제205조제2항에 따른 보정은 제외한다)을 할 수 없다. 〈개정 2014.6.11.〉 **法 204, 205**
1. 제82조제1항에 따른 수수료를 낸 것
  2. 제201조제1항에 따른 국어번역문을 제출할 것. 다만, 국어로 출원된 국제특허출원인 경우는 그러하지 아니하다.
  3. 기준일(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사를 청구한 때를 말한다)이 지날 것
- ② 삭제 〈2001.2.3.〉
- ③ **(보정범위: 법 제47조 제2항 전단)** 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정할 수 있는 범위에 관하여 제47조제2항 전단을 적용할 때에는 “특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”으로 본다. 〈개정 2014.6.11.〉
- ④ **(보정범위: 법 제47조 제2항 후단)** 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정할 수 있는 범위에 관하여 제47조제2항 후단을 적용할 때에는 “외국어특허출원”은 “외국어로 출원된 국제특허출원”으로, “최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)”은 “제201조제5항에 따른 최종 국어번역문(제201조제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 국제출원일까지 제출한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)”으로 본다. 〈신설 2014.6.11.〉
- ⑤ 삭제 〈2001.2.3.〉

[제목개정 2014.6.11.]

#### 제209조 【변경출원시기의 제한】(★) 法 210 I

「실용신안법」 제34조제1항에 따라 국제출원일에 출원된 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 기초로 하여 특허출원으로 변경출원을 하는 경우에는 이 법 제53조제1항에도 불구하고 「실용신안법」 제17조제1항에 따른 수수료를 내고 같은 법 제35조제1항에 따른 국어번역문(국어로 출원된 국제실용신안등록출원의 경우는 제외한다)을 제출한 후(「실용신안법」 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 것으로 보는 국제출원을 기초로 하는 경우에는 같은 항에 따른 결정이 있는 후)에만 변경출원을 할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제210조 【출원심사청구시기의 제한】(★) 法 210

국제특허출원에 관하여는 제59조제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에만 출원심사의 청구를 할 수 있다.

1. **(출원인)** 국제특허출원의 출원인은 제201조제1항에 따라 국어번역문을 제출하고(국어로 출원된 국제특허출원의 경우는 제외한다) 제82조제1항에 따른 수수료를 낸 후 法 209
2. **(제3자)** 국제특허출원의 출원인이 아닌 자는 국내서면제출기간(제201조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다)이 지난 후

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제211조 【국제조사보고서 등에 기재된 문헌의 제출명령】

지식재산청장은 국제특허출원의 출원인에 대하여 기간을 정하여 「특허협력조약」 제18조의 국제조사보고서 또는 같은 조약 제35조의 국제예비심사보고서에 적혀 있는 문헌의 사본을 제출하게 할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

#### 제212조 삭제 <2006.3.3.>

##### 구특허법 제212조

이의신청제도(法 69-77, 78의2)가 폐지됨에 따라 삭제됨

#### 제213조 삭제 <2014.6.11.>

##### 구특허법 제213조

기존에는 번역문을 국내출원할 때 최초로 첨부된 명세서, 도면으로 본다는 번역문주의의 입장에서 원문과 번역문이 일치하지 않으면 제213조에 의한 특허무효사유로 규정하였으나, 현재는 원문을 국내출원할 때 최초로 첨부된 명세서, 도면으로 본다는 원문주의(法 200의2)로 전환하는 한편 번역문에 대해서는 보정의 효과를 부여(法 201⑤)하기 때문에 번역문이 원문과 반드시 일치할 필요는 없고 신규 사항이 추가되지 않으면 인정되어 제213조가 삭제됨

#### 제214조 【결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원】 法 92의④ V / 202④

- ① **(대상)** 국제출원의 출원인은 「특허협력조약」 제4조(1)(ii)의 지정국에 대한민국을 포함하는 국제출원(특허출원만 해당한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 총리령[시행규칙 제117조]으로 정하는 기간에 총리령[시행규칙 제117조]으로 정하는 바에 따라 지식재산청장에게 같은 조약 제25조(2)(a)에 따른 결정을 하여줄 것을 신청할 수 있다.

1. 「특허협력조약」 제2조(xv)의 수리관청이 그 국제출원에 대하여 같은 조약 제25조(1)(a)에 따른 거부를 한 경우
2. 「특허협력조약」 제2조(xv)의 수리관청이 그 국제출원에 대하여 같은 조약 제25조(1)(a) 또는 (b)에 따른 선언을 한 경우
3. 국제사무국이 그 국제출원에 대하여 같은 조약 제25조(1)(a)에 따른 인정을 한 경우

##### 시행규칙 제117조

###### 제117조(결정의 신청기간 등)

- ① 법 제214조제1항의 규정에 의한 기간은 거부·선언 또는 인정이 출원인에게 통지된 날부터 2월로 한다.
- ② 법 제214조제1항에 따른 결정의 신청을 하려는 자는 별지 제58호서식의 신청서 2통에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지식재산청장에게 제출하여야 한다. <개정 1998. 12. 31., 2006. 12. 29., 2014. 12. 30.>
  1. 발명의 설명, 청구범위, 요약서 및 도면의 번역문 각 2통
  2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 2통
  3. 기타 법령의 규정에 의한 증명서류 2통

[제목개정 2014. 12. 30.]

- ② **(국어번역문의 제출)** 제1항의 신청을 하려는 자는 그 신청 시 발명의 설명, 청구범위 또는 도면(도면 중 설명부분에 한정한다), 그 밖에 총리령[시행규칙 제118조]으로 정하는 국제출원에 관한 서류의 국어번역문을 지식재산청장에게 제출하여야 한다.



## 시행규칙 제118조

### 제118조(결정의 신청에 관련된 번역문)

법 제214조제2항에서 “총리령이 정하는 국제출원에 관한 서류”란 해당 국제출원에 관하여 출원인이 조약 제2조(xv)에 따른 수리관청 또는 같은 조 (xix)에 따른 국제사무국에 제출한 서류 및 수리관청 또는 국제사무국이 당해 국제출원에 관하여 행한 처분에 관한 서류를 말한다. <개정 1993. 12. 31., 1996. 6. 22., 1998. 12. 31., 1999. 7. 1., 2008. 9. 30., 2013. 3. 23.>

- ③ **(지식재산처장의 결정)** 지식재산처장은 제1항의 신청이 있으면 그 신청에 관한 거부·선언 또는 인정이 「특허협력조약」 및 같은 조약규칙에 따라 정당하게 된 것인지에 관하여 결정을 하여야 한다.
- ④ **(결정의 효과)** 지식재산처장은 제3항에 따라 그 거부·선언 또는 인정이 「특허협력조약」 및 같은 조약규칙에 따라 정당하게 된 것이 아니라고 결정을 한 경우에는 그 결정에 관한 국제출원은 그 국제출원에 대하여 거부·선언 또는 인정이 없었다면 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 특허출원으로 본다.
- ⑤ **(송달)** 지식재산처장은 제3항에 따른 정당성 여부의 결정을 하는 경우에는 그 결정의 등본을 국제출원의 출원인에게 송달 하여야 한다.
- ⑥ **(준용규정)** 제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원에 관하여는 제199조제2항[조약우선권규정(法 54)의 부적용], 제200조[공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 특례], 제200조의2[국제특허출원의 출원서 등], 제201조제5항부터 제8항까지[국어번역문의 제출], 제202조제1항·제2항[후출원이 국제특허출원인 경우 국내우선권주장출원의 특례], 제208조[보정의 특례] 및 제210조[심사청구시기의 특례]를 준용한다. <개정 2016.2.29.>
- ⑦ **(출원공개시기)** 제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원에 관한 출원공개에 관하여는 제64조제1항 중 "다음 각 호의 구분에 따른 날"을 "제201조제1항의 우선일"로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

## II 국제특허출원에 관한 특례(法 199~214)

| 구 분                     |           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시설                      |           | 「국제특허출원」이란 특허협력조약에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원을 말하며, 「특례」는 국내단계의 진입시 취급을 말한다. 「국제특허출원에 관한 특례」란 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원이 국내단계로 진입시 국내법과의 관계에서 어떤 취급을 받는지에 대한 것이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 국제출원에 의한 특허출원           |           | 1. 국제특허출원일의 인정<br>특허협력조약에 의하여 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다(法 199①).<br>2. 법 제42조의2, 제42조의3 및 제54조의 부적용<br>국제특허출원에 관하여는 법 제42조의2, 제42조의3 및 제54조를 적용×(法 199②).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우 |           | 국제특허출원한 발명에 관하여 제30조 제1항 제1호의 규정을 적용받으려는 자는 그 취지를 적은 서면 및 이를 증명할 수 있는 서류를 제30조 제2항에 불구하고 기준일이 지난 후 30일 이내 지식재산처장에게 제출(法 200).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 출원서 등의 취급               |           | 1. 원문주의<br>국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 출원서는 제42조제1항에 따라 제출된 특허출원서로 보고, 국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 및 도면은 제42조제2항에 따른 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면으로 본다(法 200의2①②).<br>2. 요약서는 국어주의<br>국제특허출원에 대해서는 다음의 요약서 또는 국어번역문을 법 제42조제2항에 따른 요약서로 본다(法 200의2③).<br>i) 국제특허출원의 요약서를 국어로 적은 경우에는 국제특허출원의 요약서<br>ii) 국제특허출원의 요약서를 외국어로 적은 경우에는 법 제201조제1항에 따라 제출된 국제특허출원의 요약서의 국어번역문(법 제201조제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국제특허출원의 요약서의 국어번역문을 말한다)                                                                                                                                                                                              |
| 국제특허출원의 번역문             | 국어 번역문 제출 | 1. 원칙<br>국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 우선일부터 2년 7개월(이하 "국내서면제출기간"이라 한다) 이내에 다음의 국어번역문을 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 다만, 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 제203조제1항에 따른 서면에 적어 국내서면제출기간 만료일 전 1개월부터 그 만료일까지 제출한 경우(그 서면을 제출하기 전에 국어번역문을 제출한 경우는 제외한다)에는 국내서면제출기간 만료일부터 1개월이 되는 날까지 국어번역문을 제출할 수 있다(法 201①).<br>i) 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정)의 국어번역문<br>ii) 국제특허출원의 요약서의 국어번역문<br>2. 번역문 제출전 PCT 제19조 보정된 경우<br>제1항에도 불구하고 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 청구범위에 관한 보정을 한 경우에는 국제출원일까지 제출한 청구범위에 대한 국어번역문을 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문으로 대체하여 제출할 수 있다(法 201②). 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문을 제출하는 경우에는 제204조제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다(法 201⑧). |
|                         | 국어 번역문 교체 | 국어번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간(제1항 단서에 따라 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 출원인이 출원심사의 청구를 한 후에는 그러하지 아니하다(法 201③).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | 불제출 효과    | 출원인이 국내서면제출기간에 제1항에 따른 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하면 그 국제특허출원을 취하한 것으로 본다(法 201④).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | 제출 효과     | 특허출원인이 국내서면제출기간의 만료일(국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 경우에는 그 청구일을 말하며, 이하 "기준일"이라 한다)까지 제1항에 따라 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문(제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국어번역문을 말한다. 이하 이 조에서 "최종 국어번역문"이라 한다)을 제출한 경우에는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 최종 국어번역문에 따라 국제출원일에 제47조제1항에 따른 보정을 한 것으로 본다(法 201⑤).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | 오역의 정정    | 1. 특허출원인은 법 제47조제1항 및 법 제208조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 총리령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 보정의 효과(法 201⑤)를 부여하지 아니한다(法 201⑥). 한편, 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47① I) 또는 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47① II)에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 201⑦).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

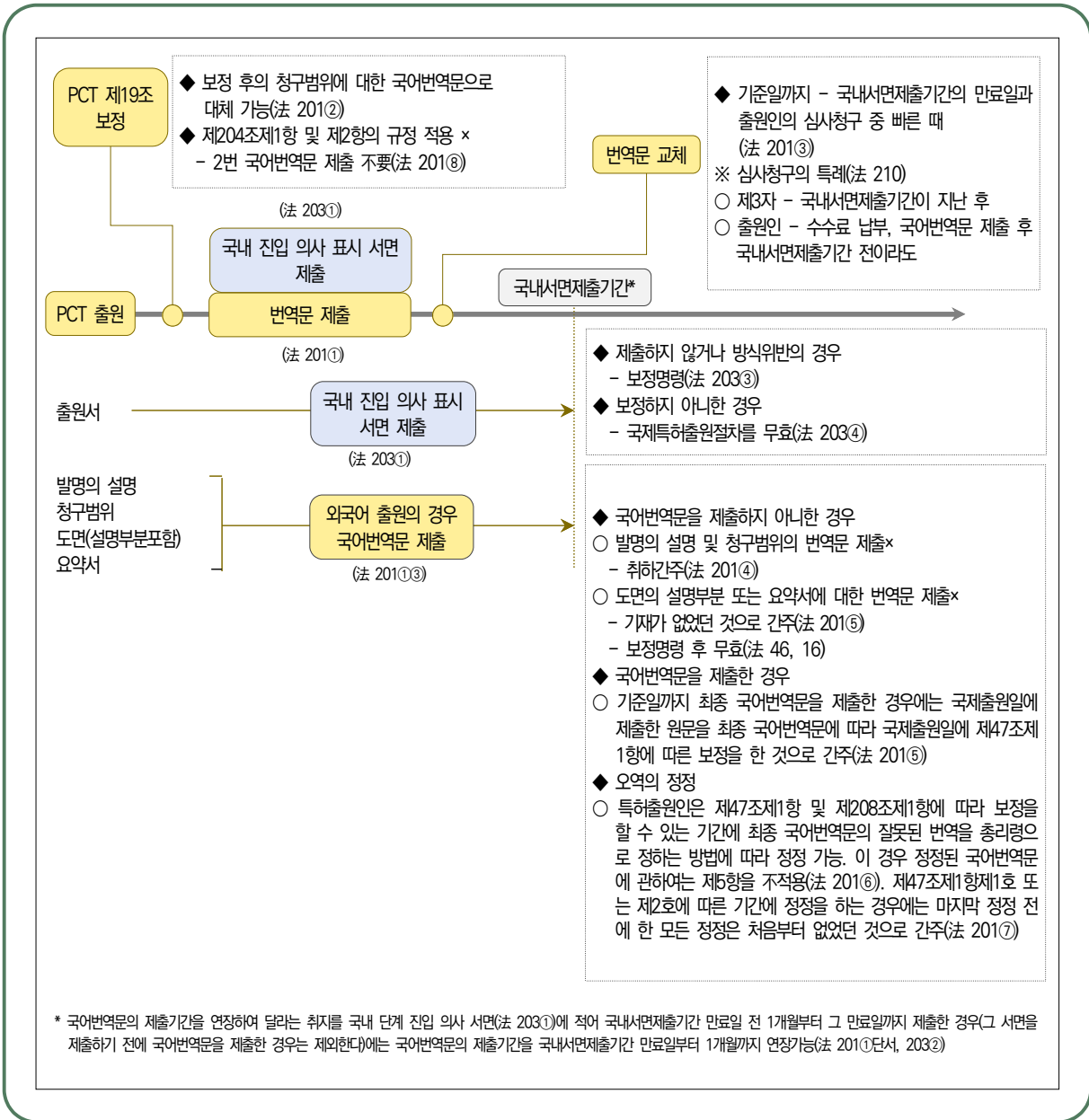
|                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                           | 2. 오역 정정은 발명의 설명, 청구범위를 보정한 것이 아니라 국어번역문만을 정정한 것이기 때문에 국어번역문에 오역이 있는 경우에는 국어번역문에 대한 오역정정과 별도로 심사대상 발명의 설명, 청구범위 등에 대하여 보정을 하여야 한다. 한편 오역의 정정이 있는 경우 정정된 국어번역문이 제47조제2항후단에 따라 보정에 대한 신규사항의 판단대상이 된다(法 208④).                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 국내우선권<br>주장의<br>특례         | 후출원이<br>국제특허<br>출원인<br>경우 | 1. 우선권을 주장한 국제특허출원의 법 제55조제2항 및 제56조제2항 부적용<br>통상적인 국내우선권주장출원의 경우 출원 시에 국내우선권을 주장하여야 하며(法 55②), 이는 선출원일로부터 1년 3개월이 지난 후에는 취할 수 없다(法 56②). 그러나 국제특허출원이 우선권을 주장하는 경우에는 법 제55조제2항 및 제56조제2항을 적용하지 아니한다(法 202①). 이는 국제특허출원의 우선권주장은 PCT 제8조에 따라 수리관청에 하는 것이므로 지정국 국내법인 법 제55조제2항에 따른 우선권을 주장할 수는 없기 때문이다. 또한, 국제출원 시 주장한 우선권 선언은 우선일로부터 2년 6개월을 지나기 전과 국내서면제출기간이 지나기 전에 국제출원인이 출원심사청구를 하기 전 중 빠른 때까지는 우선권주장의 일부 또는 전부를 취할 수 있기 때문에 역시 우선권 주장 취하에 관한 국내법 제56조제2항은 적용되지 아니한다(施規 106의7). |
|                            | 선출원이<br>국제특허<br>출원인<br>경우 | 2. 우선권을 주장한 국제특허출원의 확대된 선출원<br>① 우선권 주장을 수반하는 국제특허출원의 「국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」에 기재된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 그 「특허출원이 출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개되거나」 특허가 등록공고되었을 때에 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 확대된 선출원을 적용한다.<br>② 다만, 출원인이 국내서면제출기간에 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하여 그 국제특허출원이 취하된 것으로 보는 경우에는 확대된 선출원(法 55④)을 적용하지 아니한다(法 202②단서).                                                                          |
| 서면의<br>제출                  | 제출                        | 1. 우선권주장할 수 있는 범위(法 55①) 및 판단시점 소급효 범위(法 55③)(法 202③ I)<br>선출원이 국제특허출원인 경우에 「출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면」은 「국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」으로 본다(法 202③ I).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 보정명령                      | 2. 확대된 선출원(法 202③ II)<br>① 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 「선출원의 국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」에 기재된 발명과 같은 발명은 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록공고되었을 때에 해당 우선권 주장의 기초가 된 「선출원에 관하여 출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개」가 된 것으로 보고 확대된 선출원을 적용한다.<br>② 선출원이 국내서면제출기간에 발명(고안)의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하여 취하된 것으로 보는 국제특허출원(국제실용신안등록출원)인 경우에도 확대된 선출원 적용 시 다른 출원의 지위가 인정된다(法 55⑥).                                                                  |
|                            | 절차무효                      | 3. 선출원의 취하간주(法 202③ III)<br>선출원이 국제특허출원인 경우에 「그 출원일로부터 1년 3개월이 지난 때」는 「국제출원일로부터 1년 3개월이 지난 때와 기준일 중 늦은 때」에 취하된 것으로 본다(法 202③ III).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 국제조사<br>보고서<br>받은 후의<br>보정 | 국어<br>번역문<br>/사본의<br>제출   | 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 국제조사보고서를 받은 후에 국제특허출원의 청구범위에 관하여 보정을 하거나 설명서를 국제사무국에 제출한 경우에는 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다.) 다음의 어느 하나에 해당하는 서류를 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 204①③).<br>i) 외국어로 출원한 국제특허출원인 경우 그 보정서 또는 설명서의 국어번역문<br>ii) 국어로 출원한 국제특허출원인 경우 그 보정서 또는 설명서의 사본                                                                                                                                                                                         |
|                            | 제출의<br>효과                 | 보정서의 국어번역문 또는 사본이 제출되었을 때에는 그 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 제47조 제1항에 따른 청구범위가 보정된 것으로 본다. 즉, 기준일(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다)이 지나기 전임에도 불구하고 국내법의 적용을 받는 보정으로 간주한다. 다만, 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다) 그 보정서(국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 한정한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다(法 204②).                                                                                                                                                  |
|                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 국제특허출원의 출원인이 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다.) 번역문 또는 사본을 제출하지 아니하면 「특허협력조약」 제19조(1)에 따른 보정서 또는 설명서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만, 국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서 또는 그 설명서가 지식재산처에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다(法 204④). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 국제예비심사보고서 작성 전의 보정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 국어 번역문 / 사본의 제출                                                                                                                                                                                                                        | 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제34조(2)(b)에 따라 국제특허출원의 발명의 설명, 청구범위 및 도면에 대하여 보정을 한 경우 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다.) 다음의 어느 하나에 해당하는 서류를 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 205①).<br>i) 외국어로 작성된 보정서인 경우 그 보정서의 국어 번역문<br>ii) 국어로 작성된 보정서인 경우 그 보정서의 사본                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 제출의 효과                                                                                                                                                                                                                                 | 보정서의 번역문 또는 사본이 제출된 때에는 그 보정서의 번역문 또는 사본에 따라 제47조 제1항에 따른 명세서 및 도면이 보정된 것으로 본다. 즉, 기준일(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다.)이 지나기 전임에도 불구하고 국내법의 적용을 받는 보정으로 간주한다. 다만, 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다.) 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다(法 205②). |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 국제특허출원의 출원인이 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다.) 번역문 또는 사본을 제출하지 아니하면 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다.) 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다(法 205③).         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 특허관리인의 특례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 행위능력                                                                                                                                                                                                                                   | 재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차수행 가능(法 206①)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 선임신고                                                                                                                                                                                                                                   | 국어번역문을 제출한 재외자는 기준일 경과 후 2개월 이내 특허관리인을 선임하여 지식재산처장에게 신고하여야 하며 선임신고가 없는 경우에는 그 국제특허출원은 취하된 것으로 간주(法 206②③).                                                                                                                                                                                                                       |
| 출원공개의 특례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 공개시기                                                                                                                                                                                                                                   | 1. 원칙 → 국내서면제출기간이 지난 후<br>2. 예외<br>① 국제공개 + 심사청구 → 우선일로부터 1년 6개월이 되는 날과 출원인의 심사청구일 중 늦은 날이 지난 후<br>② 번역문 제출 + 조기공개신청 → 우선일로부터 1년 6개월 전이라도 공개<br>③ 국어로 국제특허출원한 경우 → 국제공개시에 국내공개된 것으로 간주                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 공개효과                                                                                                                                                                                                                                   | 국내공개가 있는 후(국어로 국제특허출원한 경우에는 국제공개가 있는 후) 보상금청구권(法 65②)이 인정(法 207③④).                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 보정의 특례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 보정시기                                                                                                                                                                                                                                   | 1. 수수료 납부 + 번역문 제출 + 기준일이 지난 후(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구 이후를 말한다) 국내법의 적용을 받는 보정가능<br>2. 단, PCT 제19조, 제34조 보정후 국어번역문 또는 사본을 제출한 경우 기준일이 지나기 전임에도 불구하고 국내법의 적용을 받는 보정으로 간주(法 204②, 205② 제외)                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 보정범위                                                                                                                                                                                                                                   | 외국어로 출원된 국제특허출원의 경우 명세서 또는 도면의 보정은 「국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」에 기재된 사항의 범위에서 하여야 하고, 「법 제201조제5항에 따른 최종 국어번역문(법 제201조제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 국제출원일까지 제출한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)」에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다. 즉, 원문과 번역문에 공통으로 기재된 범위에서 보정하여야 한다.                                                                  |
| 변경출원시기의 특례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 실용신안법 제34조제1항에 따라 국제출원일에 출원된 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 기초로 하여 특허출원으로 변경출원을 하는 경우에는 이 법 제53조제1항에도 불구하고 실용신안법 제17조제1항에 따른 수수료를 내고 같은 법 제35조제1항에 따른 국어번역문(국어로 출원된 국제실용신안등록출원의 경우는 제외한다)을 제출한 후(실용신안법 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 것으로 보는 국제출원을 기초로 하는 경우에는 같은 항에 따른 결정이 있은 후)에만 변경출원을 할 수 있다(法 209). 수수료 납부와 국어번역문 제출은 대한민국 지식재산처에서 최소한 심사를 받기 위한 요건이기 때문에 이를 만족한 후 변경출원할 수 있도록 시기적 제한을 두고 있다. |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 심사 청구 시기의 특례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 출원인                                                                                                                                                                                                                                    | 수수료 납부, 국어번역문 제출(단, 국어출원 제외)후이면 국내서면제출기간 전이라도 심사청구가 가능(法 210).                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 제3자                                                                                                                                                                                                                                    | 제3자는 국내서면제출기간(법 제201조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다)이 지난 후 국제출원일로부터 3년 이내 심사청구가 가능(法 210).                                                                                                                                                                                  |
| 문헌의 제출명령                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 지식재산처장은 국제특허출원의 출원인에 대하여 기간을 정하여 특허협력조약 제18조의 국제조사보고서 또는 동조약 제35조의 국제예비심사보고서에 적혀 있는 문헌의 사본을 제출하게 할 수 있다(法 211).                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



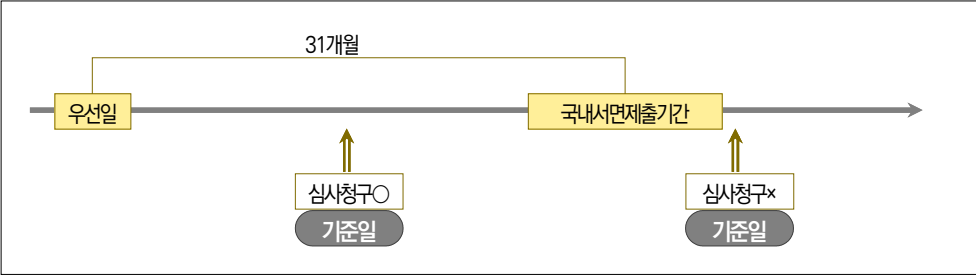
|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 결정에<br>의하여<br>특허출원<br>으로 되는<br>국제출원 | 요건 | <p>1. 주체<br/>국제출원의 출원인</p> <p>2. 대상<br/>다음 중 어느 하나에 해당되는 것으로 대한민국을 지정국에 포함한 국제출원(法 214①)</p> <p>① 수리관청에 의하여 국제출원일 인정이 거부된 경우</p> <p>② 수리관청에 의하여 국제출원 취하간주 선언된 경우</p> <p>③ 국제사무국에 의하여 소정기간 내 기록원본의 불수리가 인정된 경우</p> <p>3. 시기<br/>총리령으로 정하는 기간 내 - 거부·선언·인정이 출원인에게 통지된 날부터 2월(施規 117①, 法 214②)</p>                                                                                                                                                                     |
|                                     | 절차 | <p>1. 서류의 제출</p> <p>① 신청서</p> <p>② 발명의 설명, 청구범위, 도면(설명부분에 한함)의 번역문</p> <p>③ 총리령으로 정하는 국제출원에 관한 서류</p> <p>2. 결정<br/>지식재산처장은 출원인의 신청이 있는 경우 그 신청에 관한 거부·선언 또는 인정이 PCT 및 동조약의 규칙에 따라 정당하게 된 것인지에 관해 결정해야 하고, 정당성 여부의 결정을 하는 때에는 그 결정의 등본을 국제출원의 출원인에게 송달하여야 한다(法 214③⑤).</p>                                                                                                                                                                                           |
|                                     | 효과 | <p>1. 그 신청에 관계되는 거부·선언 또는 인정이 정당하다고 결정한 경우<br/>우리나라의 특허출원으로 인정되지 아니한다.</p> <p>2. 그 신청에 관계되는 거부·선언 또는 인정이 부당하다고 결정한 경우</p> <p>① 우리나라에 한 정규의 특허출원으로 간주 - 정당하게 된 것이 아니라는 결정을 한 때에는 그 결정에 관한 국제출원은 그 국제출원에 대하여 거부·선언 또는 인정이 없었다면 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 특허출원으로 본다(法 214④).</p> <p>② 국제특허출원에 관한 규정 중 일부를 결정에 의하여 특허출원으로 인정되는 국제출원에 준용(法 214⑥)</p> <p>③ 출원공개시기에 관해서는 우선일(法 201①) 기준으로 기산(法 214⑦).</p> <p>※ 국제특허출원에 관한 특례규정이 대부분 적용되지만, 번역문의 제출기한과 관련된 규정 등은 준용되지 않음.</p> |
| 국제특허출원의<br>심사에 관한 특례                |    | 국제특허출원에 관한 심사에 있어 해당 국제특허출원이 국제공개되지 아니하여 지식재산처장이 조약 제2조(xv)에 따른 수리관청 또는 국제사무국에 제출된 서류(지식재산처장에게 제출된 서류는 제외한다)의 확인이 곤란한 경우에는 해당 서류의 사본을 제출하게 할 수 있으며, 해당 서류의 사본을 지식재산처장에게 제출하지 아니한 경우에는 그 국제특허출원의 국제공개일까지 그 국제특허출원에 대한 심사를 보류할 수 있다((施規 116의2).                                                                                                                                                                                                                       |

### III 국어번역문의 제출





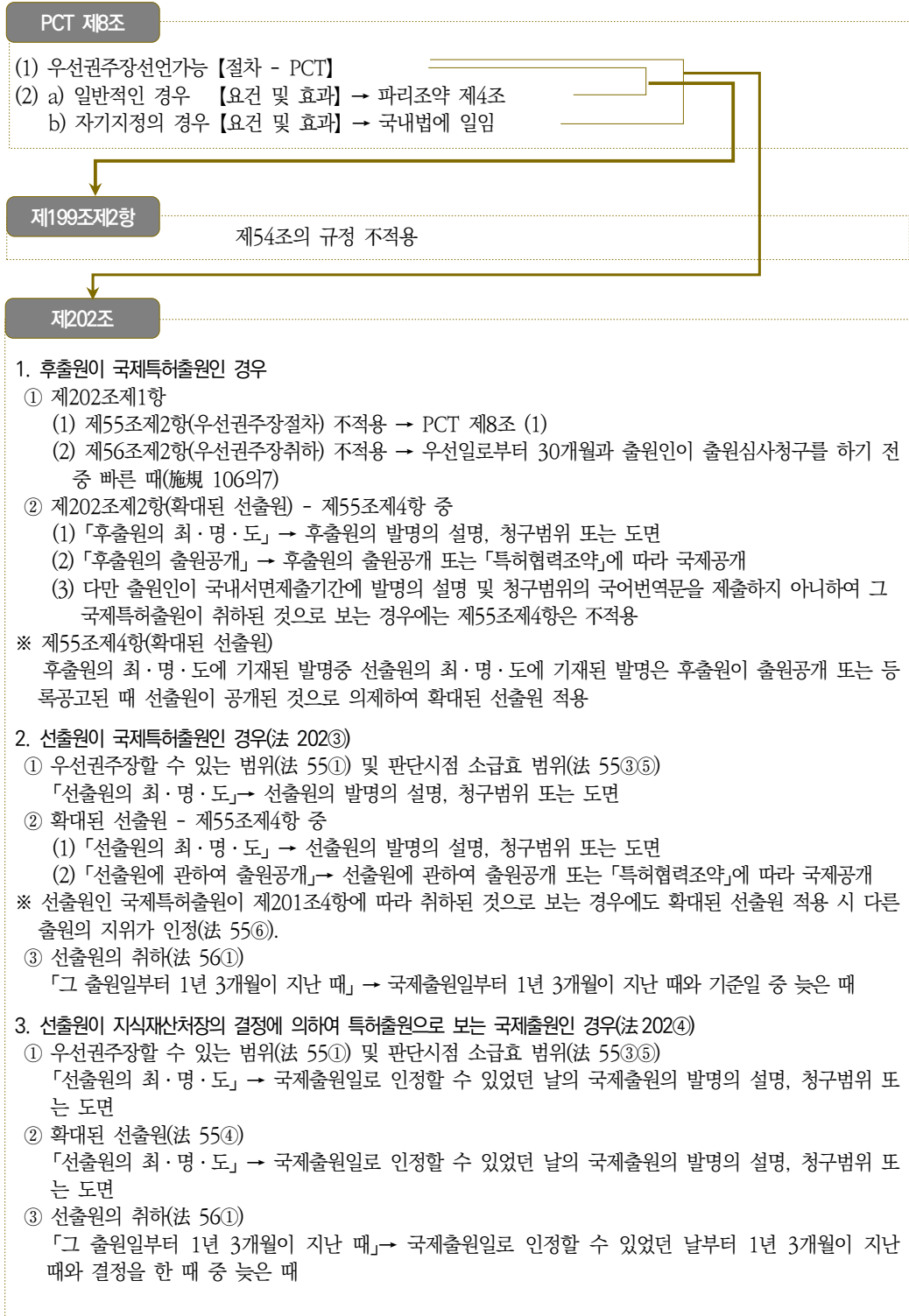
#### Ⅳ 기준일의 정의

| 구 분               |    | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 번역문 교체시기          |    | 기준일 전까지 가능(단, 시각주의에 의하여 판단)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 기준일의 정의           |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 국제단계에서 국내단계로 진입시점</li> <li>2. 국어번역문의 확정일(기준일이 지난 후에는 더 이상 번역문 교체 불가)</li> <li>3. 국내서면제출기간의 만료일과 출원인의 심사청구일 중 빠른 때</li> </ol>                                                                                        |
| 국내서면제출기간의 정의      |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 번역문 제출기간(원칙적으로 국내서면제출기간까지 번역문을 제출할 수 있음)</li> <li>2. 우선일로부터 2년 7월</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                          |
| 우선일               | 정의 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 국제출원이 우선권주장을 수반하는 경우 - 우선권주장의 최우선일</li> <li>2. 국제출원이 우선권주장을 수반하지 아니한 경우 - 국제출원일</li> </ol>                                                                                                                                                                                                            |
|                   | 판단 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 조약/국내우선권주장의 판단시점이 소급하는 경우 - 우선일</li> <li>2. 조약/국내우선권주장의 판단시점이 소급하지 아니한 경우(심사청구기간, 존속기간, 재정 등) - 국제출원일</li> </ol>                                                                                                                                                                                      |
| 심사청구시기의 특례(法 210) |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 출원인 - 수수료 납부와 번역문을 제출한 경우 국내서면제출 전이라도 심사청구가 가능</li> <li>2. 제3자 - 국내서면제출기간(법 제201조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다)이 지난 후 국제출원일로부터 3년 이내 심사청구가 가능(국내서면제출기간 전 심사청구하는 경우 번역문이 확정되는 데 제3자의 심사청구로 인해 번역문이 확정되는 경우 출원인에게 불측의 손해를 줄 염려가 있기 때문)</li> </ol> |
| 비고                |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 수수료 납부와 국어번역문 제출은 대한민국 지식재산처에서 최소한 심사를 받기 위한 요건</li> <li>2. 변경출원시기의 제한(法 209) - 수수료 납부와 번역문 제출후 가능(최소한 출원계속증일 요건을 만족한 경우에 가능)</li> </ol>                                                                                                                                                              |

**V** 외국어특허출원과 외국어국제특허출원의 국어번역문 제출의 비교

| 조 문    | 외국어특허출원(法 42의3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 외국어국제특허출원(法 201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제출     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특허출원인이 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다. 이하 제2항 및 제5항에서 같다)을 국어가 아닌 총리령으로 정하는 언어(영어)로 적겠다는 취지를 특허출원을 할 때 특허출원서에 적은 경우에는 그 언어로 적을 수 있다(法 42의3①).</li> <li>- 특허출원인이 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 제1항에 따른 언어로 적은 특허출원(이하 "외국어특허출원"이라 한다)을 한 경우에는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 그 명세서 및 도면의 국어번역문을 총리령으로 정하는 방법에 따라 제출하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 제출하여야 한다(法 42의3②).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 우선일부터 2년 7개월(이하 "국내서면제출기간"이라 한다) 이내에 다음의 국어번역문을 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 다만, 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 제203조제1항에 따른 서면에 적어 국내서면제출기간 만료일 전 1개월부터 그 만료일까지 제출한 경우(그 서면을 제출하기 전에 국어번역문을 제출한 경우는 제외한다)에는 국내서면제출기간 만료일부터 1개월이 되는 날까지 국어번역문을 제출할 수 있다(法 201①). <ul style="list-style-type: none"> <li>i) 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정)의 국어번역문</li> <li>ii) 국제특허출원의 요약서의 국어번역문</li> </ul> </li> <li>- 제1항에도 불구하고 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 청구범위에 관한 보정을 한 경우에는 국제출원일까지 제출한 청구범위에 대한 국어번역문을 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문으로 대체하여 제출할 수 있다(法 201②). 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문을 제출하는 경우에는 제204조제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다(法 201③).</li> </ul> |
| 교체     | <p>국어번역문을 제출한 특허출원인은 기한 이전에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다(法 42의3③).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) 명세서 또는 도면을 보정(제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외)한 경우</li> <li>ii) 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>국어번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간(제1항 단서에 따라 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 출원인이 출원심사의 청구를 한 후에는 그러하지 아니하다(法 201③).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 부제출 효과 | <p>특허출원인이 명세서의 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다(法 42의3④).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>출원인이 국내서면제출기간에 제1항에 따른 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하면 그 국제특허출원을 취하한 것으로 본다(法 201④).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 제출 효과  | <p>특허출원인이 제2항에 따른 국어번역문 또는 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 외국어특허출원의 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다. 다만, 제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막 국어번역문(이하 이 조 및 제47조제2항 후단에서 "최종 국어번역문"이라 한다) 전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 42의3⑤).</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>특허출원인이 국내서면제출기간의 만료일(국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 경우에는 그 청구일을 말하며, 이하 "기준일"이라 한다)까지 제1항에 따라 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문(제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국어번역문을 말한다. 이하 이 조에서 "최종 국어번역문"이라 한다)을 제출한 경우에는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 최종 국어번역문에 따라 국제출원일에 제47조제1항에 따른 보정을 한 것으로 본다(法 201⑤).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 오역의 정정 | <p>특허출원인은 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 총리령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제5항을 적용하지 아니한다(法 42의3⑥). 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47① I) 또는 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47① II)에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 42의3⑦).</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>특허출원인은 제47조제1항 및 제208조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 총리령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제5항을 적용하지 아니한다(法 201⑥). 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47① I) 또는 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47① II)에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 201⑦).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 1. 해석도



## 2. 국제특허출원과 국내우선권주장

| 구<br>분                | 유<br>형                        |                               | 국내우선권<br>주장절차                                                             | 선출원의<br>취하                                      | 국내우선권주<br>장의 취하                                                                                 | 확대된 선출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 선출원                           | 후출원                           |                                                                           |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 자<br>기<br>지<br>정<br>× | 국내                            | 국내                            |                                                                           | 선출원일로부터 1년 3개월이 지난 후 취하 간주(法 56①)               |                                                                                                 | 후출원의 최·명·도에 기재된 발명 중 선출원의 최·명·도에 기재된 발명과 같은 발명은 후출원이 출원공개 또는 등록공고되었을 때에 선출원에 관하여 출원공개된 것으로 간주                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | PCT<br>(지정국 :<br>한국, 일본<br>등) | 국내<br>(국내<br>우선권<br>선택)       | 특허출원 시 특허출원서에 그 취지 및 선출원의 표시(法 55②)                                       |                                                 | 선출원의 출원일로부터 1년 3개월을 지나기 전까지 취하 가능(法 56②)                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 후출원의 최·명·도에 기재된 발명 중 선출원의 「국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구 범위 또는 도면」에 기재된 발명과 같은 발명은 후출원이 출원공개 또는 등록공고되었을 때에 「선출원에 관하여 출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개」된 것으로 간주</li> <li>2. 선출원인 국제특허출원이 법 제201조4항에 따라 취하된 것으로 보는 경우에도 확대된 선출원 적용 시 다른 출원의 지위가 인정된다(法 55⑥).</li> </ol>                                                                                                                                                  |
| 자<br>기<br>지<br>정<br>○ | PCT<br>(지정국 :<br>한국)          | PCT<br>(지정국 :<br>한국, 일본<br>등) | PCT 제8조에 의하여 국제출원서에 우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시(法 202①)                          | 국제출원일로부터 1년 3개월이 지난 때와 기준일 중 늦은 때 취하 간주(法 202③) | 우선일로부터 2년 6개월을 지나기 전과 국내서면제출 기간전에 출원인이 출원 심사 청구를 하기 전 중 빠른 때까지 우선권 주장의 일부 또는 전부 취하 가능(施規 106의7) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 후출원의 「국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구 범위 또는 도면」에 기재된 발명 중 선출원의 「국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구 범위 또는 도면」에 기재된 발명과 같은 발명은 후출원이 「출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개되거나」 또는 등록공고되었을 때에 「선출원에 관하여 출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개」된 것으로 간주</li> <li>2. 선출원인 국제특허출원이 법 제201조4항에 따라 취하된 것으로 보는 경우에도 확대된 선출원 적용 시 다른 출원의 지위가 인정된다(法 55⑥).</li> <li>3. 후출원인 국제특허출원이 법 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 경우에는 확대된 선출원(法 55④) 부적용(法 202②단서).</li> </ol> |
|                       | 국내                            | PCT<br>(지정국 :<br>한국, 일본<br>등) |                                                                           | 선출원일로부터 1년 3개월이 지난 후 취하 간주(法 56①)               |                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 후출원의 「국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구 범위 또는 도면」에 기재된 발명 중 선출원의 최·명·도에 기재된 발명과 같은 발명은 후출원이 「출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개되거나」 또는 등록공고되었을 때에 선출원에 관하여 출원공개된 것으로 간주</li> <li>2. 후출원인 국제특허출원이 법 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 경우에는 확대된 선출원(法 55④) 부적용(法 202②단서).</li> </ol>                                                                                                                                                           |
| 비 고(판단방법)             |                               |                               | ※ 국내우선권주장의 절차, 국내우선권주장의 취하 → 후출원을 기준으로 판단<br>※ 선출원의 취하간주시기 → 선출원을 기준으로 판단 |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 3. 자기지정

| 구 분   | 선출원                                                                                                                                                                                                                             | 후출원(우선권주장출원)      | 비 고                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 자기지정○ | 한국                                                                                                                                                                                                                              | PCT(한국, 미국, 일본 등) | 지정국 한국에 대해서는 PCT 8(1),(2)b)가 적용이 되며, 한국이 아닌 지정국에 대해서는 PCT 8(1),(2)a)가 적용 |
|       | PCT(한국)                                                                                                                                                                                                                         | PCT(한국, 미국, 일본 등) |                                                                          |
| 자기지정× | PCT(한국, 미국, 일본 등)                                                                                                                                                                                                               | PCT(한국, 미국, 일본 등) | PCT 8(1),(2)a)에 의한 조약우선권주장의 요건 및 효과 적용                                   |
|       | PCT(한국, 미국, 일본 등)                                                                                                                                                                                                               | 한국                | 출원인의 의사에 의하여 조약우선권주장(法 54) 또는 국내우선권주장(法 55) 중 선택가능                       |
| 해 설   | PCT 출원서에서는 우선권주장을 체크하는 란은 있지만 국내우선권과 조약우선권을 구별하는 란이 존재하지 아니한다. 따라서 우선권주장을 체크하였을 때, 원칙은 PCT 8(1), (2)a)가 적용이 되며, 이를 적용할 수 없는 경우에만 예외적으로 PCT 8(1), (2)b)가 적용되는 것이다. 한편, 국내출원서에는 출원시 조약우선권주장(法 54) 또는 국내우선권주장(法 55)을 선택하여 적을 수 있다. |                   |                                                                          |

## VII 보정의 특례

### 1. 국제출원의 보정

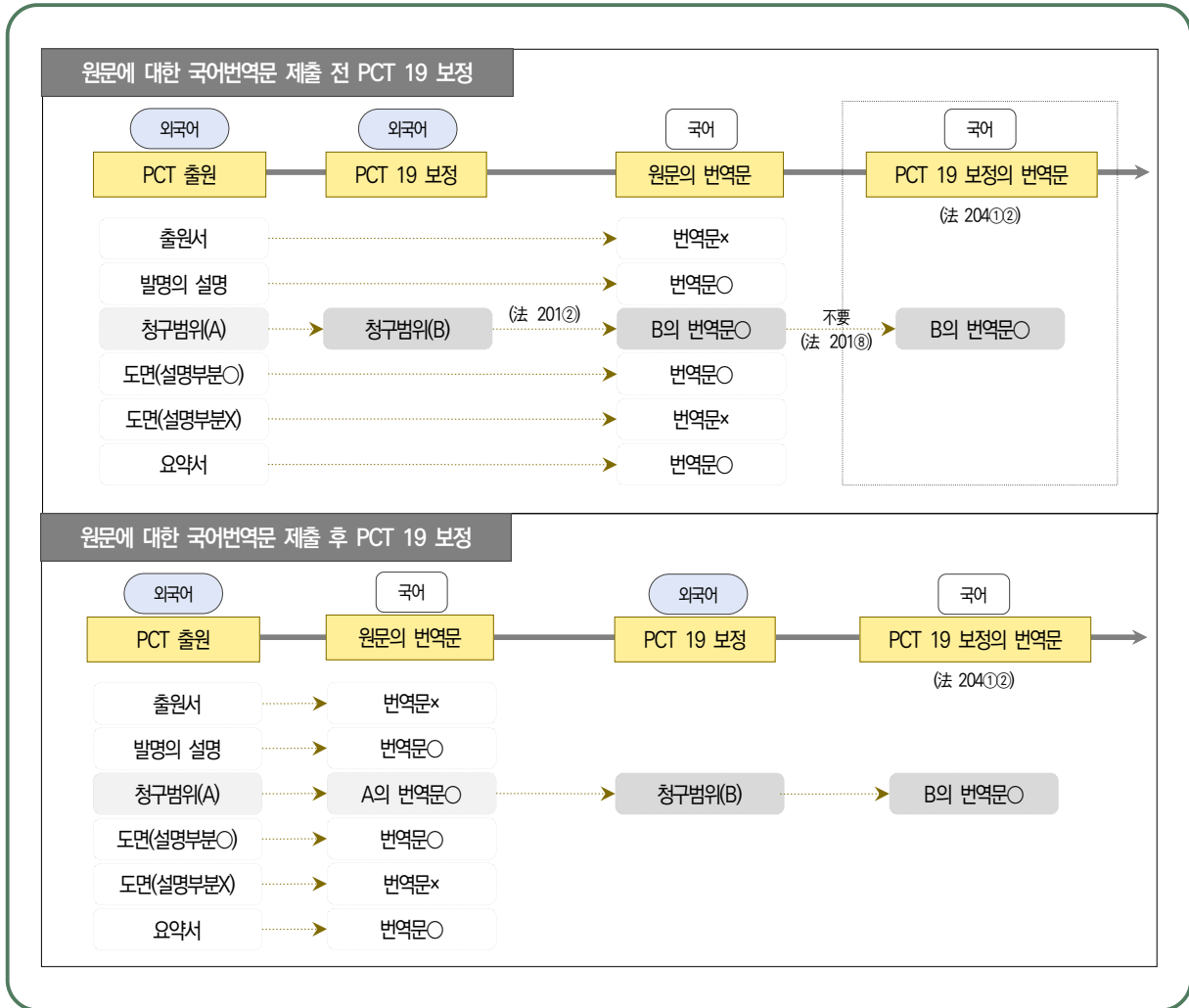
| 구 분                | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 국제출원절차에서의 보정(절차보정) | 1. 보완(法 194①②④)<br>2. 보정(法 195, 196①)<br>3. 누락 부분의 보완(法 194③④, 施規 99의2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 국제단계에서의 보정(실체보정)   | 1. PCT 제19조 보정<br>2. PCT 제34조 보정<br>3. 국내단계진입시 국어번역문 또는 사본의 제출(法 201②⑦, 204, 205)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 국내단계에서의 보정(실체보정)   | 1. 보정시기(法 208①)<br>① 수수료 납부 + 번역문 제출 + 기준일 지난 후(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구 이후를 말한다) 국내법의 적용을 받는 보정가능<br>② 단, PCT 제19조, 제34조 보정후 번역문을 제출한 경우 기준일이 지나기 전임에도 불구하고 국내법의 적용을 받는 보정으로 간주(法 204②, 205② 제외)<br><div data-bbox="409 838 1380 1159"> </div> 2. 보정범위(法 208③)<br>「국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」에 기재된 사항의 범위와 「법 제201조제5항에 따른 최종 국어번역문(법 제201조제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 국제출원일까지 제출한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)」에 기재된 범위<br><div data-bbox="409 1350 1380 1648"> </div> |



## 2. PCT 제19조 보정과 PCT 34 보정의 비교

| 구 분           |     | PCT 제19조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PCT 제34조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요 건           | 주체적 | 재외자의 경우라도 가능(法 206①)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | 객체적 | 청구범위를 기준으로 1회 보정가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 청구범위·발명의 설명·도면을 기준으로 횟수에 제한없이 보정가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | 시기적 | 국제조사보고서를 송부한 날로부터 2개월 이내 또는 우선일로부터 16개월 중 늦은 때                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 국제예비심사보고서 작성되기 전                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 절 차           |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국제사무국에 보정서 제출(설명서 제출가능)</li> <li>- 국제사무국은 보정서를 첨부하여 국제공개하고 지정(선택)관청에 송부</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국제예비심사기관에 보정서 제출</li> <li>- 국제예비심사기관은 국제예비심사보고서에 보정사항을 기록하고, 보정서를 첨부하여 출원인, 국제사무국에 송부하며, 국제사무국은 선택관청에 송부</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 번역문 또는 사본의 제출 |     | <ol style="list-style-type: none"> <li>원문의 국어번역문 제출 전 보정한 경우(외국어로 국제특허출원한 경우에 한함) <ol style="list-style-type: none"> <li>원문에 대한 국어번역문을 제출할 때 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문으로 대체 제출가능(法 201②)</li> <li>法 제204조제1항 및 제2항 부적용(번역문 두 번 제출 불요)(法 201⑧)</li> </ol> </li> <li>원문의 국어번역문 제출 후 보정한 경우 <ol style="list-style-type: none"> <li>기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다) <ol style="list-style-type: none"> <li>외국어로 출원한 국제특허출원인 경우 그 보정서의 국어번역문 또는 ii) 국어로 출원한 국제특허출원인 경우 그 보정서의 사본 이 지식재산처장에게 제출되었을 때에는 그 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 法 제47조제1항에 따른 청구범위가 보정된 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 한정한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다(法 204①②).</li> </ol> </li> <li>국제특허출원의 출원인이 기준일까지 국어번역문 또는 사본을 제출하지 아니하면 보정서 또는 설명서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만, 국어로 출원한 국제특허출원에 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서 또는 그 설명서가 지식재산처에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다(法 204④).</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>기준일까지 <ol style="list-style-type: none"> <li>외국어로 작성된 보정서의 경우 그 보정서의 국어번역문, ii) 국어로 작성된 보정서의 경우 그 보정서의 사본이 지식재산처장에게 제출되었을 때에는 法 제47조제1항에 따른 명세서 및 도면이 보정된 것으로 한다. 다만, 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다(法 205①②).</li> </ol> </li> <li>국제특허출원의 출원인이 기준일까지 국어번역문 또는 사본을 제출하지 아니하면 보정서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다(法 205③).</li> </ol> |

### 3. 원문에 대한 번역문 제출 전·후에 있어서 PCT 제19조 보정





도해특허법

## 제9장 실용신안법

80 실용신안법의 보호대상

81 특허법과 실용신안법의 비교

80

## 실용신안법의 보호대상

| 구 분     |                              | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 보호대상    | 물품의<br>형상·구조·조합에<br>관한 고안일 것 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 물품성<br/>물품이란 공간적으로 일정한 형태를 가진 것으로서 일반 상거래의 대상이 되는 자유롭게 운반 가능한 상품으로서 사용목적이 명확한 것을 말한다.</li> <li>2. 물품의 형상<br/>「형상」이란, 선이나 면 등으로 표현된 외형적 형상을 의미하며, 【예】 캠의 형상, 톱니바퀴의 치형, 공구의 날</li> <li>3. 물품의 구조<br/>「구조」란 공간적, 입체적으로 조립된 구성으로서 물품의 외관만이 아니고 평면도와 입면도에 의하여, 경우에 따라서는 측면도나 단면도를 이용하여 표현되는 것을 말한다. 구조상의 특징은 외관상 명료할 것을 필요로 하지 아니한다. 시각적으로 보아 동일구조라고 인정되는 것이라도 절단함으로써, 또는 물리적·화학적 분석에 의하여 구별할 수 있는 경우(재료가 상이한 면도칼, 가열 자성을 갖는 면도칼의 날과 자성을 갖지 아니한 날)는 구조상의 차이가 있는 것으로 본다.</li> <li>4. 물품의 조합<br/>일정한 형상 또는 구조로서의 가치와 기능을 가진 2개 이상의 물품이 결합하여 1개의 물품으로서 새로운 효과를 낳게 하는 것을 말한다. 【예】라이터와 담배통, 볼트와 너트, 트럼프, 바둑판과 바둑돌</li> </ol> |
| 구체적인 예시 | 고안이 아닌 것                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 자연법칙자체 → 에너지보존의 법칙, 만유인력의 법칙 등</li> <li>2. 단순한 발견 → 천연광물 등</li> <li>3. 자연법칙에 반하는 것 → 영구운동장치 등</li> <li>4. 자연법칙을 이용하고 있지 아니한 것 → 계산방법, 사업방법 등</li> <li>5. 정보의 단순한 제시(제시되는 정보의 내용에만 특징을 갖는 것) → 기계의 사용방법에 관한 매뉴얼, 음악을 녹음한 CD(음악에 특징이 있는 경우)</li> <li>6. 단순한 미적창조물 → 회화, 조각 등</li> <li>7. 컴퓨터프로그램 언어, 컴퓨터프로그램 자체</li> <li>8. 목적달성이 명백하게 불가능한 것 등</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 물품의 형상·구조 또는 조합이 아닌 것        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 방법, 제조방법<br/>실용신안법상 물품이라고 말할 수 있기 위해서는 적어도 일정한 형태를 갖는 「물건」이어야 한다. 따라서 「방법」과 같이 물건과 다른 카테고리에 속하는 것은 실용신안법의 보호 대상이 되지 아니한다.</li> <li>2. 기능적 표현만으로 기재되어 형상·구조를 특정할 수 없는 것(예: ~ 하는 것, ~하는 방식 등)</li> <li>3. 조성물, 합금, 화합물 등 물질에 관한 것</li> <li>4. 삼차원의 것이 아닌 것-마크, 모양, 선, 기호</li> <li>5. 시퀀스(sequence)</li> <li>6. 「기능」, 「게임」 등은 그 자체로는 실용신안법의 보호대상이 되지 아니한다. 이와 같은 경우에는 「...을 갖는 장치」, 「게임기」와 같이 고안의 대상이 물품이라는 것을 명확히 하여야만 실용신안등록을 받을 수 있다.</li> <li>7. 일반적으로 아래와 같은 것들은 일정한 형상 또는 구조를 갖는 것으로 인정되지 아니하므로 실용신안등록을 받을 수 없다. - 토양, 점토, 모래, 액체(물, 우유 등), 분체, 음료수 등</li> </ol>                                                |

## 81

## 특허법과 실용신안법의 비교

| 구 분     |            | 特許法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 實用新案法                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 보호대상    |            | 발명(방법발명, 물질발명, 용도발명도 특허 가능)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 물품의 형상·구조·조합에 관한 고안(·:물품성질, 방법 또는 물질에 관한 고안은 등록불가)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 성립요건    |            | 고도성 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 고도성 不要                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 등록요건    | 진보성        | 용이성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 「극히 용이성」(즉, 낮은 수준의 진보성)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 부등록사유      | 공서양속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * +국기 또는 훈장과 동일하거나 유사한 고안                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 출원 및 심사 | 도면첨부       | 필요한 경우에만 첨부                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. 필수적으로 첨부<br>2. 미첨부시 불수리                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 심사청구기간     | 출원일로부터 3년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 출원일로부터 3년                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 우선심사대상의 상이 | 녹색기술과 직접 관련된 특허출원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 공해방지에 유용한 실용신안등록출원                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |            | 1. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원<br>2. 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 특허출원(지식재산처장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 특허출원으로 한정한다)<br>3. 제198조의2에 따라 지식재산처가 「특허협력조약」에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원<br>4. 지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관의 장과 우선심사 하기로 합의한 특허출원<br>5. 규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법 제36조의8에 따라 규제특례가 적용된 특화사업과 직접 관련된 특허출원<br>6. 첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법 제26조에 따라 규제 특례가 적용되는 입주의료연구개발기관이 제출한 첨단의료복합단지 안 의료연구개발과 관련한 특허출원 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 효력      | 존속기간       | 특허권 설정등록을 한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 실용신안권 설정등록을 한 날부터 실용신안등록출원일 후 10년이 되는 날까지                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 존속기간연장     | 허가등에 따른 연장 + 등록지연에 따른 연장                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 등록지연에 따른 연장만 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | 효력범위제한     | 의약, 의약제법방법 적용 可(法 96②)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 의약, 의약제법방법 적용 不可                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 간접침해       | 물건발명, 방법발명 모두 적용 可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 방법발명 / 물질발명은 적용 不可                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 생산방법추정     | 규정 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 규정 無                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | 침해죄        | 반의사불벌죄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 반의사불벌죄                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 몰수규정       | 필요적 몰수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 임의적 몰수                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PCT     | 도면의 제출     | 도면의 설명부분에 대한 국어번역문을 제출하지 아니한 경우 도면의 설명부분에 대한 기재가 없었던 것으로 본다(法 201⑤).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. 국제실용신안등록출원이 도면(도면에 간단한 설명을 포함)을 포함하지 아니한 경우 「기준일」까지 이를 제출(實用 36①)<br>2. 미제출시 지식재산처장은 기간을 정하여 도면 및 도면의 설명부분의 국어번역문의 제출을 명령(實用 36②)<br>3. 지식재산처장의 명령에도 불구하고 도면을 제출하지 아니한 경우 그 국제실용신안등록출원을 무효로 할 수 있다(實用 36③).<br>4. 제출된 도면 및 도면의 설명부분의 국어번역문은 「특허법」 제47조제1항에 따른 보정으로 간주(단, 보정기간은 부적용)(實用 36④). |



# 저 자 소 개

임 | 병 | 응

| 저자약력                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 주요저서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 한양대학교 전자전기공학부 학사 졸업</li><li>• 한양대학교 법학과 석사 졸업</li><li>• 한양대학교 법학과 박사 졸업</li><li>• 37회 변리사 시험 합격</li><li>• (前)이지특허법률사무소 근무</li><li>• (前)엠텍비전주식회사 근무</li><li>• (前)주식회사 이지팩스 근무</li><li>• (前)특허그룹 인사이트플러스 대표변리사</li><li>• (前)특허법인 이지 대표변리사</li><li>• (現)특허법인 리담 대표변리사</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 이지특허법 사례연구 《2002, (주)한빛지적소유권센터》</li><li>• 理智 특허법서브 《2009, 한빛지적소유권센터》</li><li>• 반도체설계재산 관련 지식재산권 《2009, 지식재산처》</li><li>• 특허법의 이론과 판례 《2013, 국제지식재산연수원》</li><li>• 지식재산의 정석 《2015, 박문각》</li><li>• 특허법의 이론과 실제 《2016, 국제지식재산연수원》</li><li>• 특허법 《윤선희 저/ 임병응, 박태일 강명수 교정자, 2019, 법문사》</li><li>• 음식레시피, 보호와 공유에 관한 이야기<br/>《김성민, 임병응 공저, 2025, 특허법인 리담》</li><li>• 理談 특허법 《2026, 특허법인 리담》</li><li>• 도해 특허법 《2026, 리담지식재산교육원 주식회사》</li><li>• 理談 특허법 객관식I(기출문제편) 《2026, 리담지식재산교육원 주식회사》</li><li>• 理談 특허법 객관식II(예상문제편) 《2026, 리담지식재산교육원 주식회사》</li><li>• 理談 특허법 강의노트 《2026, 리담지식재산교육원 주식회사》</li><li>• 理談 특허법 판례 《2026, 리담지식재산교육원 주식회사》</li><li>• 理談 특허법 조문 《2026, 리담지식재산교육원 주식회사》</li></ul> |

**도해특허법**

|       |     |     |          |   |    |
|-------|-----|-----|----------|---|----|
| 2002년 | 10월 | 20일 | 초        | 판 | 발행 |
| 2007년 | 8월  | 20일 | 제 2      | 판 | 발행 |
| 2010년 | 4월  | 17일 | 제 3      | 판 | 발행 |
| 2010년 | 10월 | 1일  | 제 3 판 2쇄 |   | 발행 |
| 2011년 | 4월  | 2일  | 제 4      | 판 | 발행 |
| 2011년 | 11월 | 10일 | 제 4 판 2쇄 |   | 발행 |
| 2012년 | 4월  | 20일 | 제 5      | 판 | 발행 |
| 2013년 | 3월  | 16일 | 제 6      | 판 | 발행 |
| 2013년 | 10월 | 30일 | 제 6 판 2쇄 |   | 발행 |
| 2014년 | 3월  | 22일 | 제 7      | 판 | 발행 |
| 2014년 | 7월  | 19일 | 제 8      | 판 | 발행 |
| 2014년 | 11월 | 11일 | 제 8 판 2쇄 |   | 발행 |
| 2015년 | 3월  | 20일 | 제 9      | 판 | 발행 |
| 2015년 | 10월 | 12일 | 제 9 판 2쇄 |   | 발행 |
| 2016년 | 3월  | 18일 | 제 10     | 판 | 발행 |
| 2017년 | 4월  | 7일  | 제 11     | 판 | 발행 |
| 2018년 | 2월  | 21일 | 제 12     | 판 | 발행 |
| 2019년 | 5월  | 30일 | 제 13     | 판 | 발행 |
| 2020년 | 4월  | 28일 | 제 14     | 판 | 발행 |
| 2021년 | 4월  | 12일 | 제 15     | 판 | 발행 |
| 2022년 | 4월  | 12일 | 제 16     | 판 | 발행 |
| 2023년 | 6월  | 1일  | 제 17     | 판 | 발행 |
| 2024년 | 4월  | 1일  | 제 18     | 판 | 발행 |
| 2025년 | 2월  | 19일 | 제 19     | 판 | 발행 |
| 2026년 | 3월  | 16일 | 제 20     | 판 | 발행 |

